

FELIPE NOVAES
RODRIGO BELLO

MANUAL *de* PRÁTICA PENAL

OAB • PROVAS
INDICADO
CONCURSOS

- Teoria sintetizada: Direito Penal e Processual Penal
- Quadros explicativos e fluxogramas
- Peças práticas com modelos e comentários
- Questões discursivas

6^a
edição

revista,
atualizada
e ampliada

Grátis  **genio**

Processo Penal

- Superpeças

Direito Penal

- Teoria do erro
- Tentativa, desistência e arrependimento
- Prescrição



EDITORA
MÉTODO

MANUAL *de* PRÁTICA PENAL



O GEN | Grupo Editorial Nacional – maior plataforma editorial brasileira no segmento científico, técnico e profissional – publica conteúdos nas áreas de concursos, ciências jurídicas, humanas, exatas, da saúde e sociais aplicadas, além de prover serviços direcionados à educação continuada.

As editoras que integram o GEN, das mais respeitadas no mercado editorial, construíram catálogos inigualáveis, com obras decisivas para a formação acadêmica e o aperfeiçoamento de várias gerações de profissionais e estudantes, tendo se tornado sinônimo de qualidade e seriedade.

A missão do GEN e dos núcleos de conteúdo que o compõem é prover a melhor informação científica e distribuí-la de maneira flexível e conveniente, a preços justos, gerando benefícios e servindo a autores, docentes, livreiros, funcionários, colaboradores e acionistas.

Nosso comportamento ético incondicional e nossa responsabilidade social e ambiental são reforçados pela natureza educacional de nossa atividade e dão sustentabilidade ao crescimento contínuo e à rentabilidade do grupo.

FELIPE NOVAES
RODRIGO BELLO

MANUAL *de* PRÁTICA PENAL

6^a
edição revista,
atualizada
e ampliada



- A EDITORA FORENSE se responsabiliza pelos vícios do produto no que concerne à sua edição (impressão e apresentação a fim de possibilitar ao consumidor bem manuseá-lo e lê-lo). Nem a editora nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas a pessoa ou bens, decorrentes do uso da presente obra.
- Nas obras em que há material suplementar *on-line*, o acesso a esse material será disponibilizado somente durante a vigência da respectiva edição. Não obstante, a editora poderá franquear o acesso a ele por mais uma edição.
- Todos os direitos reservados. Nos termos da Lei que resguarda os direitos autorais, é proibida a reprodução total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive através de processos xerográficos, fotocópia e gravação, sem permissão por escrito do autor e do editor.

Impresso no Brasil – *Printed in Brazil*

- Direitos exclusivos para o Brasil na língua portuguesa

Copyright © 2020 by

EDITORA FORENSE LTDA

Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional

Rua Conselheiro Nébias, 1384 – Campos Elíseos – 01203-904 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 5080-0770 / (21) 3543-0770

faleconosco@grupogen.com.br / www.grupogen.com.br

- O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível (art. 102 da Lei n. 9.610, de 19.02.1998).
Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (art. 104 da Lei n. 9.610/98).
- Capa: Aurélio Corrêa
Produção digital: Geethik
- Data de fechamento: 06.09.2019
- **CIP – BRASIL. CATALOGAÇÃO NA FONTE.**
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ.

B386m

Bello, Rodrigo

Manual de prática penal / Rodrigo Bello, Felipe Novaes. – 6. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020.

Inclui índice

ISBN 978-85-309-8784-8

1. Direito penal – Brasil. I. Novaes, Felipe. II. Título.

19-59430

CDU: 343.2(81)

Vanessa Mafra Xavier Salgado – Bibliotecária – CRB-7/6644

À minha filha Maria Antônia, por tudo que tem me ensinado e pela força que tem me dado.

Felipe Novaes

À Paola, por ter me compreendido e ajudado na confecção desta obra.

Rodrigo Bello

AGRADECIMENTOS

Aos alunos e ex-alunos de nossas turmas preparatórias para a 2.^a fase de Penal.

APRESENTAÇÃO

Anos de docência, vários Exames de Ordem ao lado dos alunos, o início da advocacia, vitórias comemoradas, dificuldades percebidas e emoções administradas – esse é o contexto de surgimento desta obra, definitiva para a preparação para o intrigante, emotivo e difícil Exame de Ordem. O livro hoje se torna também um instrumento de consulta para os recém-formados.

Sentimo-nos na obrigação de ajudar ainda mais no caminho para a aprovação. Aceitamos o desafio.

Apresentamos, a todos aqueles que escolhem a disciplina de Direito Penal, uma obra didática, dinâmica, completa e facilmente estruturada.

Como dissemos, esta obra é fruto de horas e horas ao lado de alunos que escolhem a disciplina Direito Penal. Quais são suas maiores angústias, dificuldades, do que precisariam em um livro?

Abordamos os critérios de correção da banca, como identificar uma peça corretamente, a postura defensiva muitas vezes complicada de se perceber, em um caso concreto, o que pode e o que não pode ser feito durante a prova, quais os termos, as formas, as disposições e as abordagens que o examinador considera.

Todos os modelos de peças com fácil visualização de uma forma hábil tanto para os que já possuem certa experiência na área, quanto para aqueles que jamais tiveram contato com tais modelos.

Não só de peças prático-profissionais, no entanto, se faz o caminho para a aprovação. Questões oficiais comentadas e outras inéditas também possuem seu espaço de destaque na obra, além de um grande roteiro doutrinário penal e processual penal com temas fundamentais, tais como excludentes de ilicitude, extinções da punibilidade e todo o panorama da persecução penal e processual penal brasileira.

Ousadia. Este livro tem uma pretensão sim. Ser o porto seguro, o companheiro de preparação. Pensamos em cada detalhe. Nossa intenção é dar segurança, confiança e

fazer que o leitor conheça a prova, saiba o que é preciso fazer para obter a tão sonhada carteira vermelha. Esse é o sentimento da nossa obra, aliado ao treinamento árduo de peças e questões.

A estrutura segue uma metodologia das mais simples possíveis, com quadros explicativos, modelos das peças e questões discursivas que podem ser objeto de indagação no Exame de Ordem. Uma ânsia de nossos leitores foi atendida na obra: a inserção de todas as peças oficiais comentadas, além de casos inéditos propostos que incluem, evidentemente, comentários e gabaritos.

Precisamos mudar o contexto dos altos índices de reprovação. Começamos desde já a mudar a realidade. Só nós mesmos somos capazes. Mãos à obra e rumo à aprovação.

Para que o leitor possa estar sempre atualizado, serão disponibilizados, pelo QR Code abaixo, vídeos com comentários dos autores sobre as provas da OAB, à medida que forem realizadas.

Acesse o **QR Code** e assista ao vídeo sobre este assunto.

<https://youtu.be/vBkm9T8rahc>



Felipe Novaes

Rodrigo Bello

Felipe Novaes

Rodrigo Bello

SUMÁRIO

MANDAMENTOS PARA A APROVAÇÃO – CONHEÇA E RESPONDA A PROVA

1 DIREITO PENAL

- 1.1 Espécies de normas penais
- 1.2 Norma penal em branco
- 1.3 Princípio da legalidade
- 1.4 Princípio da intervenção mínima
- 1.5 Princípio da lesividade
- 1.6 Princípio da insignificância
- 1.7 Princípio da culpabilidade
- 1.8 Princípio da humanidade das penas
- 1.9 Princípio da responsabilidade pessoal ou da intranscendência das penas
- 1.10 *Ne bis in idem*
- 1.11 Lei penal no tempo
- 1.12 Tempo do crime
- 1.13 Retroatividade benéfica
- 1.14 Combinação das leis no tempo
- 1.15 Leis penais temporárias e excepcionais
- 1.16 Crime permanente, crime habitual e crime continuado
- 1.17 Lei penal no espaço
- 1.18 Lugar do crime
- 1.19 Extraterritorialidade
- 1.20 Sistema bipartido
- 1.21 Conceito de crime
- 1.22 Conceito analítico
- 1.23 Conceito brasileiro
- 1.24 Elementos do crime
- 1.25 Conduta

- 1.26 Ação e omissão
- 1.27 Sujeitos do crime
- 1.28 Bem jurídico e objeto material
- 1.29 Dolo
- 1.30 Classificação do dolo. O dolo pode ser direto ou indireto
- 1.31 Outras espécies de dolo
- 1.32 Culpa
- 1.33 Preterdolo
- 1.34 Resultado
- 1.35 Relação de causalidade
- 1.36 Teorias da imputação objetiva
- 1.37 Tipicidade
- 1.38 Tipicidade conglobante
- 1.39 Tipicidade no Brasil
- 1.40 Elementos do tipo penal
- 1.41 Antijuridicidade ou ilicitude
- 1.42 Excludentes legais gerais de ilicitude
- 1.43 Consentimento do ofendido
- 1.44 Culpabilidade
- 1.45 Imputabilidade
- 1.46 Potencial consciência da ilicitude
- 1.47 Exigibilidade de comportamento conforme o Direito
- 1.48 Crime consumado e *iter criminis*
- 1.49 Tentativa
 - 1.49.1 Espécies de tentativa
 - 1.49.2 Consequências da tentativa
 - 1.49.3 Infrações que não admitem tentativa
 - 1.49.4 Tentativa inidônea
- 1.50 Desistência voluntária ou arrependimento eficaz
 - 1.50.1 Desistência voluntária
 - 1.50.2 Arrependimento eficaz
- 1.51 Arrependimento posterior

- 1.52 Teoria do erro
 - 1.52.1 Erro de tipo
 - 1.52.2 Erro de proibição
 - 1.52.3 Descriminantes putativos
- 1.53 Erros acidentais
- 1.54 Espécies de pena
- 1.55 Pena privativa de liberdade – regimes
- 1.56 Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
- 1.57 Progressão de regime
- 1.58 Regressão de regime
- 1.59 Remição
- 1.60 Outros pontos
- 1.61 Restritivas de direito
- 1.62 Pena de multa
- 1.63 Concurso de crimes
- 1.64 Extinção da punibilidade
- 1.65 Prescrição

2 PROCESSO PENAL

- 2.1 Princípios constitucionais
- 2.2 Panorama da persecução penal
 - 2.2.1 Investigação preliminar
 - 2.2.2 Ação penal
 - 2.2.2.1 Requisitos, condições e pressupostos processuais
 - 2.2.2.2 Ação penal pública incondicionada
 - 2.2.2.3 Ação penal pública condicionada à representação
 - 2.2.2.4 Ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça
 - 2.2.2.5 Ação penal privada
 - 2.2.2.6 Ação penal privada personalíssima
 - 2.2.2.7 Ação penal privada subsidiária da pública
- 2.3 Competência
- 2.4 Prisões e medidas cautelares
 - 2.4.1 Introdução e a reforma da Lei 12.403/2011

- 2.4.2 Quadro de modalidades de prisão cautelar
- 2.4.3 Prisão em flagrante
- 2.4.4 Prisão temporária
- 2.4.5 Prisão preventiva
- 2.4.6 Contracautelas
- 2.5 Das nulidades (art. 564 do CPP)
 - 2.5.1 Princípios que regem as nulidades
 - 2.5.2 Rol das nulidades
- 2.6 A defesa no processo penal
 - 2.6.1 Apresentação das peças
 - 2.6.1.1 Fase investigatória até a propositura da ação penal (atualização pela Lei 12.403/2011)
 - 2.6.1.2 Fase da propositura da ação penal
 - 2.6.1.3 Da ação penal até a sentença penal
 - 2.6.1.4 Da sentença penal
 - 2.6.1.5 Das decisões interlocutórias
 - 2.6.1.6 Do acórdão na 2.^a Instância
 - 2.6.1.7 Do trânsito em julgado
 - 2.6.1.8 Da fase de execução
 - 2.6.1.9 No Juizado Especial Criminal
 - 2.6.1.10 No Tribunal do Júri
 - 2.6.1.11 Nos Tribunais Superiores
 - 2.6.1.12 No procedimento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos (art. 513 do CPP)
 - 2.6.1.13 No procedimento dos crimes contra a honra (art. 519 do CPP)
 - 2.6.1.14 No procedimento da Lei de Tóxicos (Lei 11.343/2006)
 - 2.6.1.15 Quadro sistemático das peças processuais penais
 - 2.6.1.16 Quadro sistemático das contracautelas
 - 2.6.2 Endereçamentos
 - 2.6.3 Termos empregados
 - 2.6.4 Prazos no processo penal
 - 2.6.5 Ressalvas no processo penal
- 2.7 A influência do novo Código de Processo Civil na prática penal
 - 2.7.1 Introdução
 - 2.7.2 Emendar a inicial
 - 2.7.3 Princípio da identidade física do juiz

- 2.7.4 Prazos
- 2.7.5 Citação por hora certa
- 2.7.6 Embargos de declaração no Juizado Especial Criminal
- 2.7.7 Alterações na Lei 8.038/1990

3 PROCEDIMENTOS

4 COMO IDENTIFICAR A PEÇA

5 REQUISITOS E ESTRUTURA DAS PEÇAS

5.1 Preliminares

6 CASOS PRÁTICOS INTRODUTÓRIOS

7 MODELOS DAS PEÇAS PRÁTICO-PROFISSIONAIS

7.1 Notícia-crime

7.1.1 Modelo de peça

7.1.2 Exercício

7.2 Relaxamento de prisão

7.2.1 Modelo de peça

7.2.2 Exercícios

7.3 Liberdade provisória

7.3.1 Modelo

7.3.2 Exercício

7.4 Revogação da prisão preventiva

7.4.1 Modelo

7.4.2 Exercício

7.5 Queixa-crime (ação penal privada propriamente dita)

7.5.1 Modelo

7.5.2 Exercício

7.6 Queixa-crime subsidiária ou supletiva ou substitutiva (ação penal privada subsidiária da pública)

7.6.1 Modelo

7.6.2 Exercício

7.7 Resposta do acusado ou resposta à acusação

7.7.1 Modelo

7.7.2 Exercícios

- 7.8 Exceções
 - 7.8.1 Modelo
 - 7.8.2 Exercício
- 7.9 Alegações finais escritas por memoriais
 - 7.9.1 Modelo
 - 7.9.2 Exercícios
- 7.10 Procuração
 - 7.10.1 Modelo

8 COMO ELABORAR RECURSOS E AÇÕES AUTÔNOMAS DE IMPUGNAÇÃO

- 8.1 Introdução
 - 8.1.1 Quadro sistemático dos endereçamentos recursais
 - 8.1.2 Quadro sistemático dos recursos no processo penal
- 8.2 Recurso em sentido estrito
 - 8.2.1 Modelo
 - 8.2.2 Exercícios
- 8.3 Apelação
 - 8.3.1 Modelo
 - 8.3.2 Exercícios
- 8.4 Apelação supletiva
 - 8.4.1 Modelo
 - 8.4.2 Exercícios
- 8.5 Razões ou contrarrazões recursais
 - 8.5.1 Modelos
 - 8.5.2 Exercício
- 8.6 Embargos de declaração
 - 8.6.1 Modelo
 - 8.6.2 Exercício
- 8.7 Embargos infringentes e de nulidade
 - 8.7.1 Modelo
 - 8.7.2 Exercício
- 8.8 Recurso especial
 - 8.8.1 Modelo
 - 8.8.2 Exercício

8.9 Recurso extraordinário

8.9.1 Modelo

8.9.2 Exercício

8.10 Carta testemunhável

8.10.1 Modelo

8.11 Agravo em execução

8.11.1 Modelo

8.11.2 Exercícios

8.12 Revisão criminal

8.12.1 Modelo

8.12.2 Exercícios

8.13 *Habeas corpus*

8.13.1 Modelo

8.13.2 Exercício

9 PEÇAS DA FASE DE EXECUÇÃO

9.1 Livramento condicional

9.1.1 Modelo

9.2 Progressão de regime

9.2.1 Modelo

9.3 Remição da pena

9.3.1 Modelo

9.4 Detração da pena

9.4.1 Modelo

9.5 Pedido de extinção da punibilidade

9.5.1 Modelo

10 PEÇAS DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

10.1 Queixa-crime (ação penal privada) no Juizado Especial Criminal

10.1.1 Modelo

10.2 Apelação no Juizado Especial Criminal

10.2.1 Modelo

10.3 Embargos de declaração no Juizado Especial Criminal

10.3.1 Modelo

- 10.4 Resposta do acusado ou resposta à acusação no Tribunal do Júri
 - 10.4.1 Modelo
- 10.5 Defesa preliminar no procedimento dos Tribunais Superiores
 - 10.5.1 Modelo
- 10.6 Defesa prévia no procedimento dos Tribunais Superiores
 - 10.6.1 Modelo
- 10.7 Alegações escritas no procedimento dos Tribunais Superiores
 - 10.7.1 Modelo
- 10.8 Reclamação no procedimento dos Tribunais Superiores
 - 10.8.1 Modelo
- 10.9 Recurso ordinário constitucional no procedimento dos Tribunais Superiores
 - 10.9.1 Modelo
- 10.10 Agravo no procedimento dos Tribunais Superiores
 - 10.10.1 Modelo
- 10.11 Defesa preliminar no procedimento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos
 - 10.11.1 Modelo
 - 10.11.2 Exercício
- 10.12 Exceção da verdade no procedimento dos crimes contra a honra
 - 10.12.1 Modelo
- 10.13 Defesa preliminar no procedimento dos crimes da Lei 11.343/2006 – Lei de Tóxicos
 - 10.13.1 Modelo
 - 10.13.2 Exercício
- 10.14 Mandado de segurança
 - 10.14.1 Modelo
- 10.15 Ação civil *ex delicto*
 - 10.15.1 Modelo

11 QUESTÕES

- 11.1 Questões discursivas oficiais
 - 11.1.1 Exame OAB Unificado – 2010.2 – FGV
 - 11.1.2 Exame OAB Unificado – 2010.3 – FGV
 - 11.1.3 IV Exame OAB Unificado – FGV
 - 11.1.4 V Exame OAB Unificado – FGV
 - 11.1.5 VI Exame OAB Unificado – FGV

- 11.1.6 VII Exame OAB Unificado – FGV
- 11.1.7 VIII Exame OAB Unificado – FGV
- 11.1.8 IX Exame OAB Unificado – FGV
- 11.1.9 X Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.10 XI Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.11 XII Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.12 XIII Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.13 XIV Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.14 XV Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.15 XVI Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.16 XVII Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.17 XVIII Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.18 XIX Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.19 XX Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.20 XX Exame de Ordem Unificado Reaplicação Porto Velho – FGV
- 11.1.21 XXI Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.22 XXII Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.23 XXIII Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.24 XXIV Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.25 XXV Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.26 XXVI Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.27 XXVII Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.28 XXVIII Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.1.29 XXIX Exame de Ordem Unificado – FGV
- 11.2 Questões discursivas penais inéditas
- 11.3 Questões discursivas processuais penais inéditas

12 GABARITOS

- 12.1 Peças prático-profissionais inéditas que estão ao longo da obra
- 12.2 Gabarito das discursivas oficiais
 - 12.2.1 Exame OAB Unificado – 2010.2 – FGV
 - 12.2.2 Exame OAB Unificado – 2010.3 – FGV
 - 12.2.3 IV Exame OAB Unificado – FGV
 - 12.2.4 V Exame OAB Unificado – FGV
 - 12.2.5 VI Exame OAB Unificado – FGV
 - 12.2.6 VII Exame OAB Unificado – FGV

- 12.2.7 VIII Exame OAB Unificado – FGV
- 12.2.8 IX Exame OAB Unificado – FGV
- 12.2.9 X Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.10 XI Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.11 XII Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.12 XIII Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.13 XIV Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.14 XV Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.15 XVI Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.16 XVII Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.17 XVIII Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.18 XIX Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.19 XX Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.20 XX Exame de Ordem Unificado – Reaplicação em Porto Velho/RO – FGV
- 12.2.21 XXI Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.22 XXII Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.23 XXIII Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.24 XXIV Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.25 XXV Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.26 XXVI Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.27 XXVII Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.28 XXVIII Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.2.29 XXIX Exame de Ordem Unificado – FGV
- 12.3 Gabarito das questões discursivas penais inéditas
- 12.4 Gabarito das questões discursivas processuais penais inéditas

MANDAMENTOS PARA A APROVAÇÃO – CONHEÇA E RESPONDA A PROVA

Sabemos que a peça processual é de alta relevância na prova. Todavia, esta obra tem o objetivo de, em um primeiro momento, preparar o candidato antes mesmo de se preocupar com a prova em si. É o que chamamos em sala de aula de “preparação do terreno”, se planejar, se organizar. Essa fase preliminar consiste em otimizar a legislação que será levada no dia da prova, entre outras precauções. Com a disposição do edital acerca da possibilidade apenas de se levar lei não comentada, a chamada “Lei Seca”, é de suma importância que tenhamos maior intimidade com nossa legislação, que saibamos achar adequadamente os artigos e leis.

Em primeiro lugar, nossa sugestão é que o candidato adquira o Código unificado e atualizado. As obras conjugadas com todas as leis e códigos são geralmente maiores, difíceis de manusear e sua legislação possui tamanho de letra menor. Já as obras separadas e conjugadas são mais fáceis, práticas e otimizam a procura. Além disso, a colocação editorial de artigos e leis é espaçadamente mais considerável do que as obras com todas as leis e códigos.

Outra medida que o candidato deve ter é etiquetar sua legislação. O tempo é um dos maiores inimigos do Exame de Ordem e, conseqüentemente, quanto mais rápida a abertura da legislação ou da disposição de lei querida, mais economia de tempo se terá. Essa postura de organização faz parte da preparação, embora muitos não percebam que é preciso ter agilidade no manuseio do Código. Portanto, é imprescindível lutarmos contra o tempo.

Uma novidade nos últimos exames foi a proibição de uso de “post-its” escritos. Sendo assim, nossa sugestão é que se coloquem alguns deles nos procedimentos, pois, como veremos, um bom início de prova começa pela abertura do procedimento correto.

Ao adquirir a legislação, é primordial que ela esteja atualizada. Uma das

sensíveis características do Exame de Ordem é cobrar do candidato atualizações, não só legislativas como também jurisprudenciais. Uma das preocupações desta obra é alertar o leitor a ficar atento às mudanças, pois elas são constantemente objeto de indagação não só em concursos públicos como também no Exame de Ordem.

Para se ter uma ideia da importância das leis novas, na 2ª fase do Exame de Ordem, em outubro de 2008, foi solicitada ao candidato a elaboração de uma nova peça processual, a Resposta do Acusado ou Resposta à Acusação (arts. 396 e 396-A do CPP), que fora criada com a recente Lei 11.719, de junho de 2008, ou seja, meses antes.

Ainda na questão de preparação, é importante o candidato saber identificar os índices, os capítulos e as matérias que são tratadas na legislação. Uma breve passada pelo índice faz com que o candidato se posicione melhor durante o exame. Muitos alunos desconhecem onde se encontra o índice da legislação, gerando, assim, uma perda impiedosa do tempo precioso no momento da prova.

Em um segundo momento, e seguindo uma linha de orientação das provas em geral (e, por que não, de nossa atual legislação pontual), seria adequado identificarmos os pontos constitucionais referentes a Penal e Processo Penal. Explicamos. Os Códigos Penal e de Processo Penal datam, respectivamente, de 1940 e 1941, e retratam momentos duros, ditatoriais da história brasileira. Estávamos sob a égide do Estado Novo liderado por Getúlio Vargas. Nosso diploma processual, por exemplo, é altamente autoritário e muitas normas ainda expressas no Código não foram recepcionadas pela Constituição de 1988. Também, pudera, nossa legislação adjetiva tem como influência o fascismo italiano. Pois bem. Com essa falta de sintonia entre a legislação e a Constituição de 1988, o que podemos fazer para estudarmos adequadamente o Direito Criminal? Devemos adotar uma postura sensivelmente constitucional, ou seja, basear nosso estudo e postura em mandamentos constitucionais, sendo que tais orientações estão colocadas nos diversos incisos do art. 5.º da Constituição Federal de 1988, em que são retratados os direitos fundamentais, os pilares de um Estado Democrático de Direito. Assim, o candidato deve abrir o mencionado artigo e destacar todos os incisos referentes a Direito Penal

e Processo Penal. Essa perspectiva constitucional ajuda, inclusive, numa postura de pensamento como defesa, bastante exigida nessa prova.

Muitos podem ficar perplexos com a quantidade de incisos referentes à ciência criminal. Existiria algum motivo para isso? A resposta foi dada anteriormente. Com a postura retrógrada de ambos os diplomas infraconstitucionais, nos resta analisar todas as questões apresentadas sob uma ótica constitucional baseada em direitos e garantias constitucionais.

Para nossa reflexão: Será que temos maturidade suficiente para adotarmos uma postura de respeito ao princípio da presunção de inocência estampado no art. 5.º, LVII, da CF/1988? Dispõe esta garantia que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Ainda, será que conseguiremos adotar um sistema acusatório constitucional baseado em diversos princípios constitucionais, tais como o próprio princípio acusatório, que não permite uma participação efetiva do juiz na persecução criminal? Será que temos habilidade para deixarmos o magistrado equidistante da persecução criminal? Acreditamos que só assim conseguiremos uma tão almejada imparcialidade.

Essas preocupações estão sendo verificadas nas recentes reformas processuais e penais, nas quais o legislador infraconstitucional constitucionaliza, aos poucos, os diplomas penais. Não é a postura mais adequada, pois interessante seria termos uma nova legislação de acordo com a Constituição, mas é melhor assim do que uma despreocupação leviana. Tramita no Congresso Nacional um novo Código de Processo Penal, entretanto, quando teremos sua publicação?

Assim, exemplificando, em 2003, pela Lei 10.792, foi confirmado o direito ao silêncio no momento do interrogatório. A Lei 11.690/2008 confirmou o princípio da vedação das provas ilícitas e a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada e a Lei 12.403/2011, que alterou o capítulo referente às prisões cautelares, consagrou mandamento e dogma constitucional de que “a regra é a liberdade, a exceção é a prisão”. A pontualidade constitucional impera nas novas leis.

Portanto, estudar para um Exame de Ordem, na visão constitucional, é o primeiro passo para a aprovação. Fundamentos constitucionais são excelentes em todos os

sentidos para uma prova e, destacando todos eles, mais uma vez o candidato ganha tempo e facilidade no momento da resolução da questão.

Visto tudo isso, o compromisso agora é **aprender a fazer a prova**. Muitos candidatos se desesperam ao tentar, em um mês praticamente, aprender tudo sobre Direito Penal e Processo Penal. Esta obra foi pensada no tempo de estudo. A ansiedade deve ser respeitada e confortada, senão ela gera um perigo tremendo aos excelentes alunos que não passam, não por desconhecerem a matéria, mas porque estão sensivelmente pressionados com o Exame. Um alerta: passar no Exame de Ordem não significa felicidade plena, é apenas o início do caminho de uma etapa, chamada vida profissional. Foi colocado esse obstáculo na nossa frente. O que podemos fazer? Não podemos deixar que a ansiedade seja uma inimiga invencível.

A Ordem não exige conhecimento pleno da matéria. Não exige gabarito de todas as questões e **“como fazer a prova”** é o que passaremos a orientar a partir de agora.

Recomendamos começar a prova pela questão prática, pois ela tem o maior peso. Muitos, ao lerem pela primeira vez a questão, já querem saber qual é a peça, o que argumentar, que está difícil, “logo agora na minha prova”, pensa o candidato. Com data no enunciado já pensa em prescrição e por aí vai. Os pensamentos confundem. A ansiedade vence. Essa não é uma postura inteligente. Calma e concentração são palavras de ordem nesse instante. Usemos técnica!

Devemos adotar uma postura sóbria, coerente, paciente, organizada e planejada, que consiste, em um primeiro momento, em identificar o procedimento, para depois ler o enunciado com o procedimento e só então identificar a peça. Com essa etapa superada, o candidato terá que analisar da forma mais correta o mérito da questão, que é, na verdade, a maior dificuldade da prova, em nossa opinião. Nesse momento é que se faz presente a intimidade com a legislação para que achemos o mais rápido possível eventuais teses que poderão ser adotadas.

Assim, seguindo a linha de primeiro identificar o procedimento para depois acompanhar o enunciado com o procedimento e assim chegar à identificação da peça, o candidato otimiza tempo, não confronta ideias e analisa melhor as teses jurídicas cabíveis na questão.

Veremos também que, se adotarmos uma postura de rascunho para depois passar para a folha original, provavelmente não teremos tempo para enfrentar as questões discursivas que se seguem. Assim, entendemos que a melhor tática é separarmos o que chamamos de parte inicial da peça, a parte mecânica da peça, que vai do endereçamento até os fatos. Deixemos eventuais preliminares e mérito para depois. Essa parte inicial, chamada de mecânica, deve ser colocada diretamente na folha original, por trazer informações, em sua maioria, fornecidas pelo examinador. Nesse instante a preocupação é com a roupagem da peça, ou seja, com a competência, com o endereçamento, com o espaço a ser colocado, com o nome fornecido, se a qualificação foi fornecida, com o nome da peça e seu respectivo dispositivo legal e com os fatos narrados na questão, que, frise-se, são imutáveis. Seria, portanto, a parte mecânica da peça. Fazendo isso, o candidato ganha tempo e se livra desses cuidados todos, que já foram objetos de sua preciosa atenção. Lembrando que uma exigência importante ao começar a escrever na folha original é com a qualidade da letra, o “layout”, a apresentação e o português. Capricho, letra boa e organização serão aferidos pelo legislador também. Lembre-se de que hoje as provas são escaneadas e levadas ao corretor por meio da informática. Ler em computador não é uma das tarefas mais prazerosas, por isso, a leitura deve estar adequada.

Preocupando-se com esses detalhes no início, o candidato não confronta as ideias argumentativas do caso particular da prova que serão objeto de análise posteriormente. E mais, economiza tempo, pois grande parte da peça processual já está na folha original.

Concluindo, a boa técnica exige elaboração direta na folha original de endereçamento, titularidade, nome da peça e dispositivo legal e os fatos. Mais adiante veremos os requisitos gerais de todas as peças.

Encerrada a parte mecânica, o candidato deixa de lado a folha original de resposta e inicia a pesquisa de eventuais preliminares, dependendo da peça e dos fundamentos jurídicos.

Pesquisar preliminares significa verificar se temos exceções (art. 95 do CPP) presentes, no caso de resposta à acusação, se houve algum desrespeito constitucional

(art. 5.º da CF), se temos extinções de punibilidade (art. 107 do CP) e, ainda, se temos nulidades (art. 563 do CPP). Basicamente, essas são as preliminares exigidas em um Exame de Ordem. Nessa pesquisa, o ideal é usar o rascunho para depois transcrever para a folha original. A argumentação redigida de forma livre pode gerar erros, portanto, recomenda-se a utilização do rascunho.

Assim que o candidato mencionar as partes da peça (preliminares e fundamentos jurídicos), mais uma vez a pesquisa deve ser associada à utilização do rascunho. Recomenda-se que os argumentos sejam expostos nessa folha, pois talvez em um primeiro momento não percebamos as melhores teses. E sabemos que a boa prática penal exige sempre que os melhores argumentos estejam no início da peça jurídica.

Identificados os argumentos caso a caso, o candidato esboçará no rascunho uma forma adequada de inserir a argumentação para depois passar para a folha original. Note-se que, nesse momento, como se trata de uma redação livre, as chances de erro são maiores e, assim, devemos verificar primeiro no rascunho se a frase seguiu as normas de concordância e regência para depois transcrevermos na folha oficial.

Feita a peça – certifique-se de que não se identificou –, o candidato seguirá para as questões discursivas, nas quais se deve adotar a postura mais objetiva possível, ou seja, deve responder primeiramente a indagação para depois justificar. Nenhum examinador quer aprender Direito lendo a prova, ele quer corrigi-la o mais breve possível. Então, primeiramente, forneça a resposta para depois fundamentá-la.

Vale observar que uma das exigências da banca corretora é cobrar do candidato os dispositivos de lei e súmulas. Assim, nunca deixe de colocar referências acerca da disposição legal. Insira sempre na resposta artigo, leis e súmulas. É importante para a pontuação da questão. Convide o examinador a ler a prova colocando os dispositivos de lei. Lembre-se: essa postura se traduz em pontuação, que pode fazer diferença no momento da correção.

Basicamente, a postura para uma boa prova é essa. Durante a obra analisaremos casos particulares, estudaremos os requisitos gerais que todas as peças precisam ter, mandamentos para elaborá-las e nossa metodologia de como identificá-las. Além disso, todas terão seus modelos individuais e os procedimentos serão colocados da

melhor forma possível para a sua visualização.

Sintetizamos no quadro abaixo o que chamamos de mandamentos para a aprovação, como estudar e como otimizar o tempo. Vejamos:

1.º	Legislação atualizada e artigos constitucionais destacados
2.º	Treinamento
3.º	Identificação do procedimento
4.º	Simplicidade e objetividade
5.º	Letra legível e apresentação adequada
6.º	Sem invenções argumentativas e fáticas
7.º	Administração do tempo de estudo e de prova

1.º ☒ Legislação atualizada e artigos constitucionais destacados

Preocupação esta demonstrada para que não percamos tempo de prova e saibamos otimizar a sua realização. Essa medida encontra-se em sintonia com a nova postura que devemos ter em relação à constitucionalização do processo penal. Percebemos claramente uma tendência em Exames de Ordem e também em concursos públicos de indagações acerca do tema. Essa postura também é visualizada com as novas leis penais e processuais, que, lentamente, vêm constitucionalizando as normas autoritárias e defasadas.

2.º ☒ Treinamento

O candidato deve ter a consciência de que é com o treinamento que os erros aparecem e serão devidamente consertados. Os erros acontecerão, serão identificados e jamais repetidos. Outro benefício é a confiança que será adquirida com o maior número de peças feitas. As preocupações diminuirão gradativamente. Se compararmos a primeira peça feita durante a preparação com a última, às vésperas da

prova, o candidato irá cristalinamente perceber o progresso. A prática realiza milagres. A dificuldade inicial não pode se tornar um empecilho para o início do treinamento.

A dúvida e a insegurança devem aparecer no treino, não na prova. Em recente depoimento, um aluno disse que seguiu tão à risca o treinamento que fazia as peças em casa, sem interrupções, na folha fornecida pelo examinador, que se encontra disponível no *site* oficial da banca, e que essa postura lhe deu mais confiança na hora da prova.

São os detalhes, principalmente técnicos e emocionais, que geram a aprovação. O treinamento deve beirar a perfeição. Devemos agir no treinamento da mesma forma que agiríamos na prova. Por exemplo, se na hora da prova pudermos consultar apenas a legislação não comentada, devemos fazer o mesmo no treinamento. Se não temos interrupções durante a prova, também não devemos ser interrompidos durante o treinamento.

3.º ☒ Identificação do procedimento

Em capítulo próprio verificaremos que a identificação do procedimento é fundamental para a identificação correta da peça. Estudando corretamente, o candidato terá a noção exata de onde o examinador o está levando. A leitura do enunciado com o procedimento confirma a peça adequada a ser elaborada. Explicaremos melhor no capítulo referente a como identificar a peça.

4.º ☒ Simplicidade e objetividade

A argumentação jurídica coloquial não deve ser mais a preocupação do operador do direito nos dias atuais. Quanto mais simples, clara e direta a escrita, mais fácil será o entendimento e mais compreensível se tornará a correção. Uma das inúmeras medidas hoje para que tenhamos um maior acesso à justiça é justamente simplificar o português jurídico.

Nunca deixemos de mencionar artigos, princípios e números de leis. Essa forma de apresentação da resposta é exigida pelo examinador. Facilite o trabalho do

examinador inserindo todos os dispositivos legais.

5.º ☒ Letra legível e apresentação adequada

É fundamental para uma predisposição de correção por parte do examinador. São muitas provas e pouco tempo para correção. Quanto mais o candidato “facilitar” a vida do examinador, melhor será, para que a correção seja aprofundada e justa, acima de tudo.

6.º ☒ Sem invenções argumentativas e fáticas

Muitos candidatos podem se desesperar no momento da prova, imaginando que o caso apresentado não tem solução ou, aparentemente, que não é possível fazer nada pelo personagem da assertiva. O perigo reside nas invenções mirabolantes de teses e fatos até então não narrados na questão sugerida. Em hipótese alguma o candidato pode inovar num Exame de Ordem. A dissertação dos fatos é taxativa. Trabalha-se com o que foi incisivamente trazido na questão. A invenção identifica a prova e gera a possibilidade de anulação completa da questão, fato este que gerará a reprovação.

Lembre-se: a atuação do advogado criminalista nunca foi fácil e, por isso, o desafio: O que pode ser feito? Uma junção de conhecimento jurídico e perspicácia nunca fizeram mal ao penalista. Mãos à obra!

Fundamentar uma defesa. Eis a arte na ciência criminal.

7.º ☒ Administração do tempo de estudo e de prova

Começemos a tratar da administração do tempo de estudo.

Um dos altos índices de reclamação durante a preparação para a prova, que gira em torno de um mês, um mês e meio, é a falta de tempo livre para estudar. Sabemos que administrá-lo nunca foi e nunca será fácil, mas nossa experiência nos informa que o passo inicial para tanto é olhar para o calendário. Visualizar o período de estudo, anotar o dia do exame e organizar o período é fundamental, ou melhor, é vital para que não deixemos o tempo passar num piscar de olhos. A postura do candidato deve ser de guardião do tempo. As realidades são inúmeras: famílias, filho pequeno,

trabalho de estágio, monografia da faculdade, festa de colação, feriados, viagens, enfim, uma gama de obstáculos e armadilhas para não se concentrar. Por falar nelas, tempo de estudo é tempo de estudo, tempo de computador é tempo de computador, tempo de “Facebook” é tempo de “Facebook”, tempo de atender o telefone é tempo de atender o telefone. Não deixemos as armadilhas da distração nos atrapalharem.

A palavra de ordem é planejamento. Tudo na vida tem um preço. A aprovação deve ser conquistada. A família e os amigos devem saber que esse é um momento de dedicação exclusiva. É muito confortável, às vezes, colocarmos a culpa no trabalho, na família, mas saibamos ter maturidade nesse momento de privações.

Organize-se. Coloque no calendário quantas peças deverão ser feitas durante aquela semana. Atinja metas. Saiba conciliar tempo de estudo e boas horas de sono, o que se definiu chamar de ociosidade inteligente.

Já administrar o tempo em prova é outra questão que passamos a abordar. O começo de prova é eletrizante, adrenalina pura. Respiração ofegante, ansiedade, ambiente de prova, tensão. Na vida, só fazemos algo com qualidade se pensarmos e raciocinarmos com tranquilidade. O controle respiratório é essencial. Veja nossa sugestão de como administrar as 5 horas de prova:

10 min iniciais	Controle de Ansiedade e Respiração
2h e 40 min	Elaboração da Peça Prático-Profissional
2h e 20 min	Elaboração das Questões

Finalmente, conheça as peças exigidas nos últimos Exames de Ordem:

Ranking das Peças Prático-Profissionais Oficiais

Prova (ano)	Peça
2007.1	Habeas Corpus

2007.2	Embargos Infringentes e de Nulidade
2007.3	Alegações Finais
2008.1	Alegações Finais
2008.2	Apelação
2008.3	Resposta do Acusado
2009.1	Recurso em Sentido Estrito
2009.2	Alegações Finais por Memoriais
2009.3	Apelação (prova anulada)
2009.3	Queixa-Crime
2010.1	Alegações Finais por Memoriais
2010.2 (II Exame Unificado)	Resposta à Acusação
2010.3 (III Exame Unificado)	Recurso em Sentido Estrito
IV Exame Unificado	Apelação
V Exame Unificado	Apelação
VI Exame Unificado	Relaxamento de Prisão
VII Exame Unificado	Apelação Supletiva
VIII Exame	Resposta do Acusado
IX Exame	Alegações Finais por Memoriais
X Exame	Revisão Criminal

XI Exame	Recurso em Sentido Estrito
XII Exame	Apelação
XIII Exame	Apelação
XIV Exame	Alegações Finais por Memoriais
XV Exame	Queixa-Crime
XVI Exame	Agravo em Execução
XVII Exame	Alegações Finais por Memoriais
XVIII Exame	Apelação
XIX Exame	Contrarrazões de Apelação
XX Exame	Alegações Finais por Memoriais
XX Exame (reaplicação Porto Velho)	Alegações Finais por Memoriais
XXI Exame	Resposta à Acusação
XXII Exame	Apelação
XXIII Exame	Alegações Finais por Memoriais
XXIV Exame	Agravo em Execução
XXV Exame	Apelação
XXVI Exame	Alegações Finais por Memoriais
XXVII Exame	Contrarrazões de Apelação

XXVIII Exame	Recurso em Sentido Estrito
XIX Exame	Agravo em Execução

DIREITO PENAL

Este capítulo destina-se a tratar dos principais tópicos de direito penal na preparação para a segunda fase em direito penal do Exame de Ordem. Tanto na peça prático-profissional quanto nas questões, o mérito está sempre ligado a questões penais. Por essa razão, a preparação só estará completa quando, além dos temas processuais e da elaboração das peças, os examinandos tiverem domínio dos principais tópicos de direito penal.

Os tópicos abordam inicialmente a teoria da norma penal, com ênfase na aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Logo depois são abordados temas essenciais de teoria do crime, aqui estão os pontos mais relevantes para a preparação; da teoria do crime, em especial dos elementos que o compõem, são extraídas as principais teses defensivas que serão utilizadas nas respostas das questões e no mérito da peça prático-profissional.

Por fim, são tratados os aspectos mais importantes da teoria da pena e de execução penal, temas recorrentes nos Exames de Ordem, com destaque para progressão de regime, regressão de regime e remição da pena.

Todos os tópicos devem ser estudados com o acompanhamento da legislação. O leitor também deve aproveitar o momento de estudo para realizar as marcações mais importantes na legislação que depois será consultada na hora da prova.

1.1 ESPÉCIES DE NORMAS PENAIS

As normas penais podem ser divididas em **normas penais incriminadoras e normas penais não incriminadoras (normas penais explicativas e normas penais permissivas)**. Incriminadoras são as normas penais que proíbem ou determinam certas condutas e cominam, para os casos de descumprimento, penas. As normas permissivas permitem a prática das condutas proibidas dentro de situações específicas, são

exemplos as excludentes de antijuridicidade (ilicitude) e de culpabilidade. Por normas penais explicativas entendem-se aquelas que, sem incriminar ou permitir condutas, apresentam regras gerais de aplicação do direito penal, por exemplo, os arts. 5.º e 7.º do Código Penal.

1.2 NORMA PENAL EM BRANCO

As normas penais em branco são normas penais que, por motivo de política legislativa, não apresentam seu preceito integralmente descrito, por isso dependem de outra norma jurídica que as complementem para que tenham eficácia. São complementadas por normas penais ou extrapenais, legais ou infralegais. As normas penais em branco serão homogêneas quando seu complemento provier da mesma fonte Legislativa que a norma penal, ou seja, tanto a norma penal quando o complemento tem origem no Congresso Nacional. As normas penais em branco heterogêneas são aquelas que têm complemento em normas oriundas de órgãos diversos daqueles com competência penal. Essas normas, normalmente, têm como complemento normas infralegais, oriundas de órgãos, até mesmo do Poder Executivo.

1.3 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

O princípio da legalidade tem como primeiro aspecto relevante a legalidade formal, somente o Congresso Nacional pode legislar acerca de matéria penal, a competência legislativa fixada pela Constituição é exclusiva para matéria penal. Em sentido material o princípio exige a previsão de crimes e contravenções penais exclusivamente em lei.

Não é possível considerar uma conduta como ilícito penal sem previsão legal. Bem como, a necessidade de previsão legal das penas, o que deve ser entendido como sanção penal, abarcando penas e medidas de segurança. Assim, o uso da analogia em matéria penal está limitado pelo princípio da legalidade, a analogia não pode ser utilizada para criar ilícitos, peias ou sanções penais não previstas em lei. Sua utilização somente será admitida quando em *bonam partem*, ainda assim, quando a legislação não fizer a previsão do benefício taxativamente, quando não poderá ser

utilizada a analogia, pois não haverá lacuna, e sim taxatividade do benefício.

1.4 PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA

O direito penal, entendido como *ultima ratio*, não deve ser utilizado para proteger todos os bens jurídicos, somente os bens jurídicos mais relevantes e essenciais ao convívio do homem em sociedade deverão receber a proteção do direito penal. Os bens jurídicos de menor relevância devem ser protegidos pelos outros ramos do direito (direito civil, administrativo etc.), o direito penal somente atuará quando os demais ramos do direito não forem capazes de proteger os bens jurídicos das possíveis lesões. Por isso o direito penal tem características de fragmentariedade e subsidiariedade.

1.5 PRINCÍPIO DA LESIVIDADE

O princípio da lesividade, também denominado de ofensividade, prevê que o direito penal não deve ser aplicado, ou prever como criminosas, condutas que não lesionem ou representem perigo de lesão concreto e relevante aos bens jurídicos protegidos. O direito penal não deve se confundir com normas de moral, com manifestações de pensamento ou de ideologias. O direito penal não deve intervir sobre comportamentos internos dos indivíduos, somente a efetiva prática da conduta deve ser objeto das normas penais, pois somente assim há a exposição do bem jurídico a situações lesivas ou perigosas.

1.6 PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Consiste na afirmação prática dos dois princípios anteriores. Condutas que, embora descritas em lei como crime, não representam, no caso concreto, uma lesão ou um perigo de lesão grave para o bem jurídico tutelado, não devem ser consideradas como crime. Esta exclusão do crime se dá tornando o fato atípico, a insignificância exclui a tipicidade em seu aspecto material, tornando o fato atípico. O STF e o STJ reconhecem a aplicação do princípio da insignificância, no entanto balizam sua aplicação na análise de quatro vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzido grau de

reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A ausência de qualquer destes requisitos impede a aplicação do princípio, uma vez que são cumulativos. Quanto à aplicação nos crimes contra a ordem tributária, os tribunais admitem a aplicação do princípio da insignificância com valores maiores, o STF e o STJ autorizam a aplicação do princípio quando o valor for até o limite de 20.000,00 reais.

O princípio da insignificância não pode ser aplicado, por força da maior reprovabilidade da conduta, nos crimes praticados contra a administração pública, conforme o enunciado da Súmula 599 do STJ dispondo que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Tal enunciado deve ser interpretado restritivamente, referindo-se aos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração, uma vez que o próprio tribunal aplica o referido princípio nos crimes praticados por particulares, como ocorre no descaminho.

Por outro lado, a Súmula 589 do STJ proibiu a aplicação do princípio da insignificância nos crimes e contravenções penais praticados contra a mulher na forma da Lei Maria da Penha, com violência doméstica ou familiar contra a mulher.

1.7 PRINCÍPIO DA CULPABILIDADE

A culpabilidade é adotada como conceito contrário à responsabilidade objetiva, e nesse aspecto o princípio da culpabilidade afirma que ninguém poderá ser punido se sua conduta não for praticada dolosa ou culposamente, a culpabilidade impede a responsabilidade objetiva exigindo que o comportamento criminoso seja subjetivamente existente. Sem a comprovação de que o agente praticou o fato com dolo, nos crimes dolosos, ou culpa nos crimes culposos, não há responsabilidade penal.

1.8 PRINCÍPIO DA HUMANIDADE DAS PENAS

Estão proibidas na CRFB de 1988, art. 5.º, XLVII, as penas de morte, penas perpétuas, o trabalho forçado, o banimento e as penas de caráter cruel. Vale lembrar

que a pena de morte está autorizada em caso de guerra.

ATENÇÃO: somente a pena de morte comporta esta exceção, as demais proibições são absolutas, nem em caso de guerra estas penas poderão ser aplicadas.

1.9 PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PESSOAL OU DA INTRANSCENDÊNCIA DAS PENAS

A CRFB no art. 5.º, XLV, prevê que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. As penas não podem atingir pessoas diversas das que praticaram o crime. Assim, não pode a pena passar aos sucessores em caso de morte do condenado. Com a morte do condenado estará extinta a punibilidade, com isso cessada estará a execução da pena eventualmente aplicada.

ATENÇÃO: embora a pena de multa seja dívida de valor, executada conforme as regras de execução fiscal, com a morte do condenado **não** poderá ser cobrada dos herdeiros, nem mesmo no patrimônio herdado, entender o contrário altera a natureza penal-punitiva da multa e a equipara a multas de outra natureza, violando o princípio constitucional.

1.10 NE BIS IN IDEM

Ninguém pode ser condenado duas vezes pelo mesmo fato criminoso ou contravencional, em outros termos, está vedada a dupla condenação pela prática de um mesmo fato, localizado temporal e espacialmente. O princípio também pode ser observado no processo penal quando as normas processuais impedem a litispendência e a coisa julgada, a fim de evitar dois processos pelo mesmo fato criminoso.

1.11 LEI PENAL NO TEMPO

A regra geral de aplicação das leis penais no tempo está prevista no art. 5.º, XL, da CRFB, que prevê serem irretroativas as leis penais, salvo quando benéficas para o agente. Portanto, a regra geral é a **irretroatividade das leis penais**, enquanto a exceção é a **retroatividade benéfica das leis penais**.

1.12 TEMPO DO CRIME

O Código Penal determina no art. 4.º que o tempo do crime é o tempo da ação ou omissão criminosa, ainda que outro seja o momento de ocorrência do resultado. **O legislador brasileiro adotou a teoria da atividade** ao considerar praticado o crime no momento da conduta, ação ou omissão. A lei penal vigente no momento da ação ou omissão rege as consequências penais aplicáveis, desprezando o momento do resultado.

ATENÇÃO: não confundir tempo do crime com lugar do crime, para o lugar do crime o CP adotou a teoria da ubiquidade, que considera tanto o lugar da conduta quanto o do resultado como lugar do crime.

1.13 RETROATIVIDADE BENÉFICA

Como exceção ao *tempus regit actum* a legislação penal brasileira admite a retroatividade de leis penais benéficas que atingirão fatos ocorridos antes da sua vigência. O Código Penal trata destas hipóteses no art. 2.º, **prevendo duas situações de retroatividade: a *abolitio criminis* e a *novatio legis in melius***. A *abolitio criminis* ocorre quando lei penal posterior descriminalizar a conduta anteriormente proibida, ou seja, a conduta deixa de ser crime, o que acarreta **extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 107, III, do CP**, e atingirá todos os efeitos penais – os efeitos extrapenais (arts. 91 e 92 do CP) não são atingidos automaticamente – da sentença condenatória, mesmo que transitada em julgado.

Nem sempre a revogação de um dispositivo penal acarreta *abolitio criminis*, há situações em que o legislador cria um novo tipo penal em substituição ao que está sendo revogado, não havendo exclusão da incriminação da conduta, que simplesmente passa a incidir em outro dispositivo penal.

A *novatio legis in melius*, prevista no art. 2.º, parágrafo único, trata da alteração benéfica da norma penal vigente ao tempo do crime, e retroagirá em benefício do agente naquilo que for melhor para ele. O benefício da nova lei pode ser de qualquer natureza, podendo estar ligado à diminuição das penas cominadas ou melhorar qualquer outra consequência penal, como natureza da pena (reclusão ou detenção), as

espécies de penas cominadas (privativa de liberdade e multa), a incidência de benefícios penais (progressão de regime, detração, livramento condicional etc.). Vale ressaltar que a aplicação da lei nova benéfica após o trânsito em julgado da condenação é de competência do juiz da execução penal, conforme entendimento do STF no Enunciado 611 da Súmula.

1.14 COMBINAÇÃO DAS LEIS NO TEMPO

Quando uma lei penal nova, comparada a legislação anterior, representa uma modificação parcialmente pior e parcialmente melhor e o crime ocorreu na vigência da lei anterior, surge a discussão quanto a possibilidade de retroagir apenas a parte benéfica da nova lei, combinando-a com a legislação da época do fato, naquilo que a primeira era melhor. A corrente doutrinária que defende a possibilidade de combinação traz como fundamento principal a interpretação do art. 5.º, XL, da CRFB/1988, que prevê a retroatividade apenas benéfica, fazendo com que a retroatividade da parte pior, da nova lei, seja inconstitucional. Outro argumento neste sentido é o argumento de que a Constituição não proibiu a retroatividade parcial, nem obrigou a retroatividade integral. A corrente oposta, que defende a proibição da combinação, afirma que tal possibilidade viola a separação entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, por possibilitar a criação pelo juiz de uma terceira lei, a partir da combinação das duas anteriores, sendo neste aspecto inconstitucional. A jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido desta última corrente, proibindo a combinação, conforme se verifica no Enunciado 501 da Súmula do STJ.

1.15 LEIS PENAIS TEMPORÁRIAS E EXCEPCIONAIS

São temporárias as leis penais que em seu próprio texto apresentam um prazo de vigência ou uma data específica para sua autorrevogação. Leis penais excepcionais são aquelas de eficácia vinculada a um fato ou circunstância excepcional, com o desaparecimento deste fato ou circunstância excepcional a lei excepcional perde a eficácia, deixando de ser aplicada. **O art. 3.º do CP dispõe que as leis temporárias e excepcionais gozam de ultratividade e se aplicam aos fatos praticados durante a sua vigência, ainda que a decisão judicial seja posterior à revogação. Portanto, afasta**

das leis temporárias e excepcionais a retroatividade de leis posteriores mais benéficas, não incidindo nestas hipóteses o *abolitio criminis* e a *novatio legis in mellius*. Se no curso de seu prazo (temporárias) ou das circunstâncias que ensejaram sua edição (excepcionais), essas leis forem revogadas por outras leis temporárias ou excepcionais mais benéficas haverá retroatividade, desde que a situação fática que gerou a edição das leis não se tenha alterado, o que demonstra a intenção do legislador de alteração de tratamento penal, devendo ser aplicada retroativamente.

1.16 CRIME PERMANENTE, CRIME HABITUAL E CRIME CONTINUADO

Os crimes permanentes, continuados e habituais são crimes que se estendem no tempo, nesses casos o tempo de crime deixa de ser uma data fixa e passa a ser um intervalo de tempo (por exemplo no crime de sequestro que dura vários dias). Assim, as condutas criminosas podem ter se iniciado na vigência de uma lei penal e cessado já na vigência de uma eventual nova lei, que pode ser mais benéfica ou prejudicial. O entendimento que tem prevalecido é no sentido de aplicação da nova legislação, pois a conduta entrou na sua esfera de eficácia, seja ela mais severa ou mais benéfica. Este é o entendimento do STF esboçado no **Verbete de Súmula 711**: “**A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência**”. Esta mesma lógica pode ser empregada nos crimes habituais.

1.17 LEI PENAL NO ESPAÇO

A regra geral de aplicação da lei penal no espaço é o **princípio da territorialidade temperada**, previsto no art. 5.º, *caput*, do CP, portanto as leis penais brasileiras são aplicáveis aos crimes praticados no território nacional. Como território nacional se deve considerar o território geográfico compreendendo a área terrestre ou continental; as águas internas, como rios, lagos, lagoas e baías; as águas de fronteira, na medida em que a legislação específica permitir; o mar territorial que compreende a faixa costeira de 12 milhas; e, por fim, o espaço aéreo localizado sobre todos os elementos anteriores. **Por outro lado, o art. 5.º, §§ 1.º e 2.º, trata do**

território nacional por equiparação ou extensão. Considera como território nacional: (a) as embarcações e aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem. Mesmo que estejam em território estrangeiro, os crimes praticados nestes locais ficam sujeitos à legislação brasileira; (b) as embarcações e aeronaves brasileiras privadas quando estiverem no alto-mar ou no espaço aéreo correspondente, isto é, em águas ou no espaço aéreo internacional; (c) no art. 5.º, § 2.º, o legislador determina a aplicação da lei brasileira também nas embarcações e aeronaves estrangeiras, de propriedade privada, quando estiverem no território brasileiro.

1.18 LUGAR DO CRIME

O Código Penal adotou para determinar o lugar do crime a **teoria mista ou da ubiquidade**. O art. 6.º prevê que se considera lugar do crime o local onde ocorreu a conduta – ação ou omissão – no todo ou em parte, bem como o local onde ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. Por isso, existem crimes plurilocais e crimes a distância, os primeiros são os crimes nos quais a conduta foi partida em vários locais, já o segundo é aquele que teve a conduta em um local e o resultado em outro.

1.19 EXTRATERRITORIALIDADE

A legislação penal nacional pode ser aplicada a crimes praticados fora do território nacional, ou seja, em locais não abrangidos pelo princípio da territorialidade. Tais hipóteses estão previstas **taxativamente** no art. 7.º do CP. Podem as leis especiais prever outras hipóteses, sempre dependentes de previsão legal. O art. 7.º, I, prevê **hipóteses de aplicação incondicionada** da lei brasileira, portanto, nesses casos, a lei brasileira será aplicada independentemente de qualquer exigência legal. Já as situações previstas no art. 7.º, II e no § 3.º, dependem da reunião de todas as condições especificadas no § 2.º do mesmo artigo e, no caso do § 3.º, das condições previstas em suas alíneas *a* e *b*. Sem tais condições a legislação brasileira não pode ser aplicada nestas hipóteses.

ATENÇÃO: a Lei 9.455/1997, lei de tortura, tem dispositivo expresso para a extraterritorialidade, o art. 2.º prevê que os casos de tortura praticados contra brasileiro, fora do Brasil, ficam sujeitos a legislação pátria, independentemente de qualquer condição.

1.20 SISTEMA BIPARTIDO

O Brasil adotou o **sistema bipartido** para classificar as infrações penais. As duas espécies de infrações penais são **os crimes e as contravenções penais**, entre elas não há diferença ontológica, de essência, as diferenças são axiológicas, de consequências penais. Algumas dessas diferenças são:

- 1) **Diferença de penas:** os crimes têm pena de reclusão ou detenção isoladamente ou combinada com a multa; já as contravenções penais penas de prisão simples ou de multa isoladamente ou as duas combinadas, conforme o disposto no art. 1.º da Lei 3.914/1941.
- 2) **Ação penal:** os crimes podem ser de ação penal de iniciativa pública (condicionada ou incondicionada) ou de ação penal privada; já as contravenções penais são sempre de ação penal pública incondicionada, conforme o art. 17 da LCP.
- 3) **Punibilidade da tentativa:** os crimes têm tentativa punível prevista no art. 14 e parágrafo único; já nas contravenções penais não há punibilidade da tentativa – art. 4.º da LCP.
- 4) **Extraterritorialidade da lei:** crime admite hipóteses de extraterritorialidade art. 7.º do CP. As contravenções penais não admitem extraterritorialidade – art. 2.º da LCP.
- 5) **Competência para processo e julgamento** – o art. 109, IV, da CRFB, exclui expressamente as contravenções penais da competência da Justiça Federal, portanto crimes podem ser de competência das justiças estadual ou federal, já as contravenções serão sempre processadas e julgadas na justiça estadual. A única hipótese de as contravenções penais serem julgadas pela justiça

federal é nos casos de foro por prerrogativa de função em órgão federal.

- 6) **Limites das penas** – para os crimes o art. 75 do CP fixa o limite de execução de 30 anos. Para as contravenções penais o limite é de cinco anos de prisão simples, conforme dispõe o art. 10 da LCP.

1.21 CONCEITO DE CRIME

A doutrina conceitua crime de quatro formas:

- 1) **Conceito formal** – sob o enfoque formal crime é a conduta que está estabelecida em uma norma penal incriminadora, sob ameaça de sanção penal.
- 2) **Conceito material** – crime é comportamento humano causador de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, passível de sanção penal.
- 3) **Conceito formal-material** – um comportamento humano previsto em lei, causador de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, passível de sanção penal.
- 4) **Conceito analítico** – o conceito analítico leva em consideração os elementos que compõem a infração penal, sua estrutura, prevalece que os elementos que compõem o crime são: fato típico, ilicitude e culpabilidade (conceito tripartite).

1.22 CONCEITO ANALÍTICO

O conceito analítico utilizado pela doutrina majoritária brasileira tem base no conceito finalista de crime, desenvolvido por Hans Welzel, na Alemanha, com algumas influências de correntes posteriores, como reflexos na tipicidade penal pela teoria da tipicidade conglobante, desenvolvida por Zaffaroni, na Argentina. O conceito divide o crime em fato típico, antijurídico e praticado por agente culpável.

1.23 CONCEITO BRASILEIRO

Grande parte da doutrina brasileira, tais como Damásio de Jesus, Júlio Fabbrini

Mirabete e Celso Delmanto, adota um conceito analítico bipartido de crime, idealizado por René Ariel Dotti, sendo o mesmo uma ação típica e antijurídica, figurando a culpabilidade como um juízo de reprovação *post factum*, sendo apenas um pressuposto de aplicação da pena, não elemento do crime. Não é este o conceito dominante. Prevalece o entendimento de que o crime é uma conduta humana típica, ilícita e culpável.

1.24 ELEMENTOS DO CRIME

O fato típico é composto, em regra, por conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade penal. Na antijuridicidade, também chamada de ilicitude, são analisadas as causas de justificação, capazes de tornar um fato típico, lícito, permitido pelo direito naquelas circunstâncias, como ocorre nas hipóteses previstas pelo art. 23 do CP ou em outras excludentes específicas de ilicitude. A culpabilidade, por sua vez, é o elemento do crime que funde o homem com o fato, para torná-lo crime, quando o homem que o praticou puder ser reprovado por ele. A culpabilidade é um juízo de reprovação que recai sobre o homem, determinando sua reprovação, quando presentes três elementos: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.

1.25 CONDUTA

A conduta dentro da corrente finalista é toda ação ou omissão praticada por um ser humano, com controle voluntário de sua atuação e regida pelo dolo ou pela culpa. A presença do dolo e da culpa na conduta, como elementos reitores do agir ou omitir humano, foi a grande inovação do finalismo penal (Welzel) frente às correntes causalistas anteriores, que localizavam inicialmente o dolo e a culpa na culpabilidade como espécies de culpabilidade (teorias psicológicas) e depois como elementos da consciência da ilicitude (teorias psicológico-normativas). Com o finalismo, dolo e culpa saem definitivamente da culpabilidade e são inseridos no conceito de conduta, assim deixam de ter relação com a consciência da ilicitude, quando eram elementos normativos, passando a ter relação com a consciência da conduta, como elementos naturais.

1.26 AÇÃO E OMISSÃO

A lei penal, por meio do tipo penal, descreve os crimes, função descritiva do tipo penal. Nessa descrição, o legislador, em regra, utiliza um ou mais verbos para descrever a conduta proibida naquele crime. O verbo núcleo do tipo penal é a conduta criminosa, prevista pelo legislador de forma descritiva, por exemplo: matar é a conduta do homicídio, subtrair do furto e do roubo, deixar de prestar assistência da omissão de socorro etc. Quando o tipo penal descreve uma ação como conduta, estamos diante de crimes classificados como comissivos, quando descreve uma omissão os crimes são omissivos próprios. O crime comissivo, que exige ação como conduta, pode excepcionalmente ser praticado por omissão, mas tal hipótese está limitada às situações de omissão imprópria, previstas pelo art. 13, § 2.º, do CP. O omitente deve ter dever e possibilidade concreta de impedir o crime comissivo, caso se omita, será responsabilizado por ele.

A conduta deve ser praticada voluntariamente, ou seja, o homem deve ter o controle consciente e físico da ação ou omissão que realiza, e atos inconscientes ou incontroláveis fisicamente não caracterizam condutas e não podem ser tipificados. São circunstâncias que excluem a voluntariedade, sendo o fato atípico: Estados de inconsciência – hipnose, sonambulismo, desmaios etc. Movimento reflexo: reflexo neurológico, não controlável voluntariamente. Caso fortuito: a força dos ventos ou das águas que empurram o agente. Força maior: coação física irresistível, que exclui o controle do agente dos movimentos do seu próprio corpo, o ato deixa de ser voluntário, excluindo a tipicidade e tornando o fato atípico.

Não confundir coação física irresistível com coação moral irresistível: exclui do agente a possibilidade de decisão por uma conduta diferente, ele é obrigado a praticar aquela conduta, o que caracteriza inexigibilidade de conduta diversa, excluindo a culpabilidade.

1.27 SUJEITOS DO CRIME

Sujeito ativo: sujeito ativo é aquele que pode realizar a conduta abstratamente prevista como típica, ou seja, aquele que pode praticar o crime. Via de regra os fatos

puníveis podem ser realizados por qualquer pessoa (crimes comuns). No entanto, existem crimes que só podem ser praticados por pessoas que reúnam determinadas características próprias, como é o caso do peculato (art. 312 do CP), que só pode ser praticado por funcionário público (crimes próprios). Estes crimes, todavia, apesar de próprios, admitem coautoria mediata ou participação. Há, ainda, casos em que estas formas de concurso de agentes não são admitidas e somente o sujeito com determinadas características próprias pode praticar o crime (crimes de mão própria), como é o caso do falso testemunho (art. 342 do CP).

Entre nossos doutrinadores pátrios afirma-se que a pessoa jurídica é insuscetível de figurar como sujeito ativo de um delito, apesar disso a Constituição de 1988, no art. 225, § 3.º, prevê a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais, o que foi admitido pelos tribunais superiores. Assim, nos crimes em geral, a pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo, exceto nos crimes ambientais, quando será responsabilizada nos termos do art. 3.º da Lei 9.605/1998.

Sujeito passivo: não se deve confundir, apesar de ser prática comum, o sujeito passivo com a vítima, uma vez que esta é quem sofreu o crime e teve o seu bem jurídico violado, ao passo que o sujeito passivo é o titular do bem jurídico tutelado e, portanto, é passível de ser vítima. O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa natural, como no homicídio (art. 121 do CP), a pessoa jurídica, como no furto (art. 155 do CP), o Estado, como no peculato (art. 312 do CP) ou a coletividade, como na falsidade de documento particular (art. 297 do CP).

1.28 BEM JURÍDICO E OBJETO MATERIAL

Bem jurídico: o bem jurídico é um valor social ou jurídico escolhido pelo legislador para merecer a mais proteção do Estado, por meio do direito. Em um sistema democrático, o bem jurídico é o ponto de partida de qualquer estrutura do delito, evitando a incriminação de sentimentos e pessoas pelo que são e não pelo que fizeram. Somente condutas que violem os valores mais relevantes para a sociedade merecem proibição penal. São exemplos de bens jurídicos: a vida, o patrimônio, a honra, a incolumidade pública, entre outros. O direito penal, em razão do caráter

fragmentário, não tem uma concentração de bem jurídico tutelado, como ocorre em outros ramos do direito, mas uma pluralidade de bens jurídicos, os mais relevantes, em várias áreas do convívio social.

Objeto material: o objeto material do crime é o objeto corpóreo sobre o qual recai a ação punível. Esse objeto pode ser uma coisa, como no caso do furto (art. 155 do CP), em que a ação de subtrair recai sobre coisa alheia móvel, ou uma pessoa, como no caso do homicídio (art. 121 do CP).

1.29 DOLO

O dolo é o elemento reitor da conduta humana, toda conduta é dirigida a um determinado fim, por isso não existe tipo penal que não contenha elementos subjetivos, ou seja, que não façam a previsão abstrata do querer, da vontade do agente ao praticar os atos externos.

No finalismo o Dolo passa a ser dolo natural. Assim, todo tipo doloso contém o dolo natural, que é a representação da conduta e do resultado, escolha dos meios e a vontade livre e consciente de praticar a conduta e alcançar o resultado representados, mesmo que o agente não tenha consciência da ilicitude, como era exigido no causalismo.

Dolo do causalismo ou *dolus malus* ou dolo normativo. O dolo na concepção do causalismo penal é elemento constituidor da culpabilidade segundo a teoria psicológica da culpabilidade, porque segundo a teoria causal, além dos elementos constituidores suprarreferidos, encontramos no dolo a consciência da ilicitude, que no finalismo se manteve na culpabilidade na concepção normativa pura.

1.30 CLASSIFICAÇÃO DO DOLO. O DOLO PODE SER DIRETO OU INDIRETO

Dolo direto: é a representação da conduta e do resultado; a vontade livre e consciente de praticar a conduta e alcançar o resultado representados; e a escolha dos meios para alcançar o fim. É regido pela teoria da vontade e está previsto pelo art. 18, I, do CP, na expressão “quis o resultado”.

Dolo direto de 1.º grau e dolo direto de 2.º grau. O dolo direto de 1.º grau tem por conteúdo a pretensão dirigida à realização da conduta e o alcance do fim perseguido, é a vontade de realizar o objetivo principal do agente. Já o dolo direto de 2.º grau compreende os meios para alcançar o fim proposto e os efeitos secundários tidos como certos ou necessários para alcançar o objetivo principal. Isso não se confunde com o dolo eventual, que, como será visto abaixo, os efeitos não são certos ou necessários, são possíveis ou prováveis e o autor assume o risco de sua ocorrência.

Dolo indireto: pode ser alternativo ou eventual. O dolo alternativo se apresenta quando o sujeito representa a conduta e alguns resultados possíveis e tem a vontade livre e consciente de praticar a conduta e alcançar qualquer dos resultados representados, alternativamente. O agente prevê, por exemplo, que sua conduta pode matar ou lesionar alguém, dirigindo a conduta a qualquer um desses resultados. O dolo alternativo também pode ser de natureza subjetiva, quando envolver a possibilidade de atingir várias pessoas e o agente decidir por atingir qualquer uma delas.

Dolo eventual: ocorre sempre que o sujeito representa a possibilidade de realizar a conduta ou de causar o resultado, mas embora não tenha a vontade de alcançar o resultado representado, aceita a sua ocorrência, assumindo o risco de produzi-lo. O dolo eventual é regido pela teoria do consentimento, exigindo a previsão e a aceitação como seus elementos.

Além do dolo, alguns crimes trazem um especial fim de agir ou dolo específico, por meio de um elemento subjetivo especial do tipo. Além do dolo podem existir elementos de vontade secundários, que é o especial fim de agir, que não integram o dolo genérico, como ocorre, por exemplo, no delito de extorsão mediante sequestro que, além do dolo de privar a liberdade da vítima, o agente tem o especial fim de obter um preço de resgate.

1.31 OUTRAS ESPÉCIES DE DOLO

Dolo de perigo e dolo de dano: no dolo de perigo o agente quer expor o bem jurídico tutelado a um risco de dano, não quer causar uma consequência lesiva certa, e

sim expor ao perigo de que esta lesão ocorra. Já o dolo de dano consiste na vontade de lesionar efetivamente o bem jurídico tutelado.

Dolo geral: consiste na consequência do erro na causalidade. Ocorre quando o agente, por erro, acredita que causou um resultado que pretendia, que na verdade ainda não ocorreu. Então pratica uma segunda conduta, sem o dolo anterior, quando causa efetivamente o resultado esperado antes. Ex.: o agente, querendo a morte da vítima, desfere facadas na região do coração, e, depois de constatar a morte, decide atirar o cadáver no rio que passa atrás de sua propriedade, a fim de ocultá-lo. Quando o corpo é localizado e periciado, constata-se que a *causa mortis* foi afogamento no citado rio. A doutrina brasileira defende que nessas hipóteses o dolo da primeira conduta deve ser estendido à segunda, de forma que o agente responda pelo crime consumado, como se tivesse realizado isso na primeira conduta dele.

1.32 CULPA

A culpa está prevista no art. 18, II, do CP. O crime culposos ocorre quando o agente causa um resultado, objetivamente previsível, por inobservância de deveres objetivos de cuidado.

A inobservância do dever de cuidado pode caracterizar uma imprudência, quando o agente pratica uma ação descuidada (atira um objeto pela janela do carro em movimento); uma negligência, quando se omite diante do dever de cuidado, deixando de fazer aquilo que era exigido (não substitui as pastilhas de freio do automóvel); ou imperícia, que consiste na inobservância de deveres inerentes à atividade profissional, arte ou ofício (o médico que deixa de observar regras técnicas durante uma cirurgia).

Resultados imprevisíveis não podem ser imputados culposamente, ainda que diante de um descuido do agente. Em regra, todo crime culposos é material (exige resultado para a consumação). Mas há crimes culposos formais, que independem de resultado, na lei de drogas, art. 38 da Lei 11.343/2006, e no Estatuto do Desarmamento, art. 13 da Lei 10.826/2003.

Classificação da culpa:

- a) Culpa consciente: ocorre quando o agente prevê que a conduta é perigosa, tem previsão do resultado que pode causar, e mesmo assim realiza a conduta, pois acredita com sinceridade ser capaz de evitar o resultado. Difere-se do dolo eventual; quando o agente aceita o resultado, ele assume o risco de que o resultado aconteça; na culpa, o agente, ao contrário, nega o resultado, e está certo de que ele não ocorrerá.
- b) Culpa inconsciente: é a culpa sem previsão do resultado; embora ele fosse previsível, o agente não prevê. É a modalidade mais comum de culpa. O agente, sem prever o resultado previsível, dá causa a ele.
- c) Culpa imprópria: art. 20, § 1.º, do CP. É a culpa derivada do erro de tipo permissivo evitável (inescusável) nas discriminantes putativas. É denominada como culpa imprópria pois o agente realiza o tipo penal dolosamente e responde culposamente em consequência de seu erro na discriminante.

1.33 PRETERDOLO

É uma das espécies de crime qualificado pelo resultado, que se caracteriza pela seguinte construção: crime doloso com previsão de uma qualificadora (ou aumento de pena) exclusivamente culposa. Ex.: lesão corporal (art. 129 do CP) qualificada pela morte (§ 3.º); o agente tem o dolo de lesionar e por culpa acaba ocasionando a morte da vítima. Dolo no antecedente e culpa no consequente.

1.34 RESULTADO

Resultado naturalístico: é a consequência produzida no bem jurídico tutelado como consequência da conduta descrita no tipo penal. Consiste em uma mudança real, uma modificação fática no bem jurídico tutelado. Nem todo crime tem resultado naturalístico. Para determinar se há ou não resultado naturalístico, primeiro é preciso descobrir o bem tutelado, depois a conduta (núcleo previsto no tipo penal), depois saber se essa conduta provoca alguma alteração REAL neste bem jurídico tutelado. Essa alteração REAL no bem jurídico é que consiste no resultado naturalístico. De

acordo com o resultado naturalístico, os crimes se classificam em:

- Material: a conduta é capaz de provocar resultado naturalístico e esse resultado foi exigido para a consumação. Ex.: o homicídio se consuma com a morte.
- Formal: a conduta é capaz de causar um resultado naturalístico, mas o resultado não é exigível para a consumação. A consumação ocorre com a própria conduta, antes do resultado. Ex.: extorsão mediante sequestro, a consumação se dá com o sequestro, o pagamento do resgate é mero exaurimento.
- Mera conduta: só tem conduta. A conduta prevista no tipo penal não acarreta no bem jurídico qualquer tipo de alteração. Ex.: violação de domicílio (art. 150 do CP).

Resultado jurídico ou normativo: é o resultado que ocorre no mundo do direito. É a colocação do bem jurídico tutelado em uma situação de lesão ou de perigo de lesão no campo das normas jurídicas. Está presente em todos os crimes independentemente da existência ou não de resultados naturalísticos.

1.35 RELAÇÃO DE CAUSALIDADE

A relação de causalidade é, no sentido jurídico penal, a conexão entre a conduta humana e o resultado, de tal forma que se possa concluir que este tenha ocorrido em razão daquele, ou seja, se o resultado é efeito da conduta, há relação de causalidade. Permitindo imputar o resultado a quem realizou a conduta, devendo o agente ou omitente responder pelo resultado e não só pela conduta.

O art. 13, *caput*, do CP, adota a teoria da equivalência das condições ou *conditio sine qua non*. Assim, haverá nexo de causalidade entre a conduta e o resultado alcançado sempre que pudermos concluir que este não teria ocorrido sem a prática de determinada ação ou omissão.

Deve se ressaltar, todavia, quanto à omissão temos o nexo de evitação, ou seja,

devemos verificar se a conduta omissiva deu causa ao resultado sempre que sua prática for suficiente para evitar o resultado, daí por que chamamos de nexo de evitação.

Muitas vezes um mesmo resultado pode ter várias causas possíveis, tais situações podem ser de Causas independentes. Os fatos ocorrentes (sejam naturais ou atos humanos) podem ser absolutamente independentes entre si ou dependentes. Quando dois fatos forem absolutamente independentes, decerto apenas um deles guarda nexo de causalidade com o evento considerado como resultado, excluindo o outro fato. É o exemplo de alguém que pretendendo se suicidar ingere veneno e, à beira da morte, é atacado por um sujeito que lhe causa ferimentos que não causam nem apressam a morte, provocada exclusivamente pela ingestão da substância venenosa.

De outro lado, podem ocorrer fatos que guardam uma relativa dependência e que são chamados concausa. Esta pode ser preexistente, concomitante ou superveniente. Em tais hipóteses as causas concorrem para o resultado, podendo este ser imputado a todos que foram responsáveis por cada causa. Como no exemplo do agente que esfaqueia o hemofílico, que morre por sangrar sem parar, em virtude da doença preexistente. Embora a hemofilia tenha colaborado para a morte, tal resultado também foi causado pelas facadas e pode ser imputado ao autor delas que, tendo dolo de matar, responde por homicídio doloso consumado. Todavia, cumpre assinalar que estritamente no caso de uma causa ser superveniente, relativamente independente e, por si só, produzir o resultado, o nexo de causalidade da primeira está excluído, por força do disposto no art. 13, § 1.º do CP. Por exemplo, se “A” é esfaqueado e lavado ao hospital, porém lá chegando, apesar da recomendação médica, foge do local e, em razão do não tratamento morre de gangrena, esta causa (a gangrena) é uma concausa do esfaqueamento, superveniente e relativamente independente, mas não produziu o resultado morte por si só, mantendo a relação de causalidade do esfaqueamento com a morte. Por outro lado, se “A” é esfaqueado, removido por ambulância em direção ao hospital, mas no caminho a ambulância vem a bater, provocando a morte de “A” por traumatismo craniano, este, apesar de superveniente e relativamente independente, exclui o nexo de causalidade em relação ao esfaqueamento, por ter sido o traumatismo

craniano a causa da morte por si só.

1.36 TEORIAS DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA

Como alternativa à teoria da equivalência dos antecedentes causais (*conditio sine qua non*), a doutrina, principalmente alemã, vem desenvolvendo as denominadas teorias da imputação objetiva do resultado, que pretendem realizar a imputação do resultado sem considerar a necessidade de limitação por revisão do dolo ou da culpa, elementos da conduta, e não da relação de causalidade. Tais teorias não devem ser confundidas com responsabilidade objetiva, impossível no direito penal democrático, que permitiria a responsabilização por um crime independente de dolo ou culpa.

Dentre as várias teorias podemos citar a desenvolvida por Claus Roxin, que trabalha com a ideia de que o resultado causado pelo agente só pode ser imputado ao tipo objetivo se a conduta criou um perigo para o bem jurídico, não coberto por um risco permitido, e esse perigo se realizou num resultado concreto.

Por outro lado, quem cria o perigo dentro de riscos permitidos não pode sofrer a imputação do resultado. Assim, se o resultado se apresenta como realização de um perigo criado pelo autor, será imputado, pois se cumpre o tipo objetivo. Entretanto, excepcionalmente poder-se-á excluir a imputação se o alcance do tipo objetivo não abarcar o dever de evitar tais perigos e suas repercussões.

Roxin ainda afirma que há exclusão da imputação nos casos de diminuição do risco, não há possibilidade de imputação se o autor modifica o curso causal de maneira que diminui o perigo já existente para a vítima. Por exemplo, aquele que desvia o curso da pedra, atirada por um terceiro com dolo de lesionar a vítima, fazendo com que ela atinja região menos letal do corpo desta, não poderá ter a lesão corporal que provocou imputada a ele.

Outra teoria de imputação objetiva relevante é a desenvolvida por Günther Jakobs, a partir de alguns vetores:

- a) papel social: posições sociais definidas de modo normativo, ocupadas por indivíduos, trata-se, portanto, de uma instituição que se orienta com base nas

pessoas. O resultado não pode ser imputado a quem deu causa a ele, agindo regularmente dentro de seu papel social;

- b) princípio de confiança: os indivíduos confiam que os outros cumprirão seu papel socialmente instituído, formando uma relação de confiança mútua entre todos os componentes da sociedade. Como ocorre no trânsito, em que cada motorista confia que os demais motoristas cumpriram as regras de trânsito regularmente, por isso, quando causam um resultado baseando-se nessa confiança, não podem ser responsabilizados;
- c) risco permitido: aceitação por parte da sociedade de certos riscos, que poder ser assumidos por serem aceitos como naturais no âmbito social;
- d) proibição de regresso: quem se mantém nos limites do seu papel social não pode responder por resultados, quando sua conduta lícita for utilizada de forma ilícita por outrem;
- e) competência da vítima: exime de responsabilidade o agente se a vítima contribuiu diretamente para a consecução do resultado naturalístico.

1.37 TIPICIDADE

A tipicidade é a perfeita adequação da conduta concreta, ou seja, o fato social, a descrição abstrata do tipo. Exige-se, para que exista tipicidade, que se realize um juízo capaz de verificar a correspondência exata entre os elementos da conduta humana efetivamente praticada e as características objetivas e subjetivas do tipo penal formulado pelo legislador. A ideia da tradicional tipicidade formal é corolário do princípio da legalidade e se funda na ideia de que um fato social somente será crime quando descrito por um tipo penal (na lei penal) como tal. A adequação típica pode ser direta ou imediata, quando o fato corresponde exatamente ao descrito no tipo penal, ou indireta ou mediata, quando é necessário combinar o tipo penal com outra norma jurídica para realizar a adequação, como ocorre na tentativa (art. 14, II) ou no concurso de agentes (art. 29).

1.38 TIPICIDADE CONGLOBANTE

Zaffaroni desenvolveu a teoria da tipicidade conglobante a partir da ideia de que a tipicidade não é simples e sim complexa, ou seja, engloba uma série de elementos adicionais à tipicidade formal, tradicionalmente considerada como tipicidade penal. O penalista argentino parte da ideia de que o crime deve representar um conflito e tal conflitividade deve influenciar na tipicidade e sua ausência na atipicidade do fato. Assim, inclui na tipicidade, além da tipicidade formal a ideia de tipicidade conglobante com os seguintes elementos relacionados a conflitividade:

- a) verificação da lesão de certa relevância – como corolário do princípio da lesividade, exigindo que o fato social, para ser típico materialmente, represente uma lesão relevante para o bem jurídico protegido no tipo penal, do contrário, quando a lesão não é relevante, ocorre a incidência do princípio da insignificância, tornando o fato atípico.
- b) aquiescência do ofendido, esteja ou não previsto no tipo penal, expressa ou implicitamente, se o ofendido consente na prática da conduta, contra um bem jurídico de sua titularidade, não há razão de incriminação da conduta, devendo o consentimento excluir sempre a tipicidade (diferente da doutrina brasileira, que o localiza na antijuridicidade, como causa supralegal de exclusão, quando não previsto no tipo penal).
- c) o alcance da norma não está reduzido por outras normas de igual ou superior hierarquia, se não incidem outras normas que limitem a incidência do tipo penal na espécie, como ocorre quando há normas que determinam o comportamento, em tese proibido por um tipo penal. Assim, para ele, o estrito cumprimento do dever legal deve excluir a própria tipicidade conglobante. Também não devem ser típicos fatos sociais, quando há normas que fomentam tais comportamentos, como ocorre em algumas situações de exercício regular do direito como nas atividades médicas, práticas esportivas etc.
- d) o fato pode ser imputado ao agente como obra sua, verificando nos casos de autoria se o autor tem dominabilidade do fato, como essência deste domínio.

E os partícipes devem ter uma colaboração não banal para ter o fato imputado a eles. Podendo assim realizar a imputação do fato a eles.

1.39 TIPLICIDADE NO BRASIL

A doutrina brasileira, influenciada pela tipicidade conglobante, passou a definir tipicidade penal como um conjunto entre tipicidade formal e tipicidade material. Assim, considera a necessidade de previsão legal, mas também a necessidade de lesão relevante, possibilitando que o princípio da insignificância exclua a tipicidade.

1.40 ELEMENTOS DO TIPO PENAL

O tipo penal tem como função principal a função descritiva, como afirmação do princípio da legalidade, o tipo penal deve descrever o ilícito penal com todos os seus elementos constitutivos. Além da função descritiva o tipo penal também tem uma função dual (Zaffaroni), pois ao mesmo tempo em que fundamenta o exercício do direito de punir o limita como garantia de que o Estado não poderá exercê-lo, a não ser quando autorizado pelas leis penais. Para cumprir tais funções o tipo penal tem que ser taxativo e claro na descrição do crime, para isso utiliza elementos de descrição.

a) Elementos objetivos (descritivos):

– sujeito ativo – aquele que pode praticar a conduta descrita no tipo penal tal qual previsto abstratamente na lei.

– sujeito passivo – aquele que pode sofrer o resultado da conduta descrita no tipo penal tal qual previsto abstratamente na lei.

– núcleo do tipo – a ação humana descrita, o verbo constante do tipo penal.

– resultado – resultado pode ser natural, que é a alteração do mundo exterior, ou jurídico concebido como a ofensa (dano ou perigo) do bem jurídico protegido pelo tipo. Nem todo crime tem resultado naturalístico, como é o caso dos crimes de mera conduta, mas todo crime tem um resultado jurídico. Deve haver, evidentemente, uma relação de causalidade entre a ação (núcleo

do tipo) e o resultado, conforme a teoria da equivalência das condições.

- objeto material – a coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta descrita no tipo penal.

- elementos circunstanciais – alguns tipos penais apresentam elementos de tempo, lugar, meio etc., como é o caso do furto noturno, que se caracteriza pelo tempo em que é praticado.

b) Elementos normativos:

- são elementos do tipo penal que necessitam de uma valoração do intérprete. Os elementos normativos podem ser jurídicos e culturais. Elementos jurídicos são aqueles que trazem conceitos próprios do direito, tais como “coisa alheia” no furto (art. 155 do CP) ou “duplicata” na duplicata simulada (art. 172 do CP). Elementos culturais (axiológicos) são próprios de outras disciplinas ou dependentes de conceitos sociais, tais como “ato obsceno” (art. 233 do CP).

c) Elementos subjetivos:

- o Dolo, a culpa e os elementos subjetivos especiais, que preveem finalidades específicas.

1.41 ANTIJURIDICIDADE OU ILICITUDE

Ser antijurídico ou ilícito significa ser contrário ao direito, um fato que foi praticado contra o ordenamento jurídico penal. Pela teoria da *ratio cognoscendi*, adotada aqui, a conclusão pela tipicidade do fato indicia sua antijuridicidade que precisa ser confirmada. A confirmação é realizada por meio da análise de elementos negativos, ou seja, da presença de elementos que negam a ilicitude e por isso tornam o fato lícito. As excludentes de ilicitude ou antijuridicidade estão, em regra, previstas em lei. A lei incriminou determinados fatos nos tipos penais, mas pode permiti-los por meio de normas de justificação.

1.42 EXCLUDENTES LEGAIS GERAIS DE ILICITUDE

a) Estado de necessidade

O art. 24 do CP traz os requisitos necessários para que um fato típico seja considerado em estado de necessidade. O agente pratica um fato típico contra um direito para salvar outro, e essa relação deve ser razoável, o que se configura quando o direito salvo vale mais ou o mesmo juridicamente que o direito sacrificado. O direito a ser salvo deve estar ameaçado por perigo atual, o que engloba situações de dano atual ou iminente, que não foi provocado pela vontade (dolo) desse agente, a culpa não impede o benefício; quando não havia outro modo de evitar, a única alternativa era a prática do fato típico ou outras ainda mais graves que esta.

O Código Penal adotou somente uma espécie de estado de necessidade, vinculando-se a teoria unitária ou unificadora do estado de necessidade, ele é sempre excludente de ilicitude (estado de necessidade justificante) e ocorre quando o direito salvo vale mais ou o mesmo que o direito sacrificado. Não foi adotada a teoria diferenciadora que admite dois estados de necessidade, um na ilicitude, denominado justificante, e outro na culpabilidade, denominado exculpante, que ocorre quando o direito salvo é de valor menor que o sacrificado, que na nossa legislação pode acarretar diminuição de pena (art. 24, § 2.º), hipótese não prevista na legislação comum brasileira, mas adotada pelo Código Penal Militar.

O dever legal – o art. 24, § 1.º, impede que o estado de necessidade seja configurado em favor de pessoas que têm o dever legal de enfrentar o perigo.

O estado de necessidade será defensivo quando o bem atingido pertencer ao causador do perigo, ou será estado de necessidade agressivo quando atingir direitos de pessoas que não tinham qualquer relação com o perigo que ameaça o direito protegido.

b) Legítima defesa

Conforme o art. 25 do CP, ocorre legítima defesa quando o agente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a um direito próprio ou de terceiro. Consiste em medida de autotutela autorizada pelo

ordenamento jurídico penal.

A legítima defesa depende de uma agressão injusta consistente num ato humano contrário a um direito e proibida (injusta) pelo ordenamento jurídico. Isso significa que somente agressões humanas típicas e antijurídicas podem ser repelidas em legítima defesa, embora não precisem ser culpáveis, devem ser típicas e antijurídicas sempre. Não é possível se defender em legítima defesa de agressões praticadas por sonâmbulos, em erro de tipo, sob coação física irresistível ou acobertadas por outras excludentes de tipicidade ou de ilicitude, quando no máximo se pode ter um estado de necessidade, mas não uma legítima defesa.

A agressão deve ser atual ou iminente. A atualidade caracteriza o momento presente, atual é a agressão que está em curso, já iniciada e não encerrada. Já a iminência se caracteriza por um futuro muito próximo do presente, é a agressão que ainda não foi iniciada, mas está em vias de começar. Está claro que não é admitida legítima defesa de agressões passadas, já encerradas, como também não se fala em legítima defesa quando a agressão está em um futuro distante, sem a certeza de sua ocorrência.

Quer a agressão injusta recaia sobre Direito próprio ou alheio, a legítima defesa pode ser utilizada para defender qualquer direito, não há restrições ou valorações para admitir a defesa de um direito, obviamente deve ser observado um critério de razoabilidade entre o direito lesionado e o que se pretendia defender, mas não há restrições objetivas. O direito protegido pode ser próprio ou de terceiro, configurando a legítima defesa própria ou de terceiros respectivamente.

Agir com moderação, utilizando os meios necessários. Considera-se como necessário o meio proporcional à agressão que se pretende repelir, quanto mais intensa a agressão, mais intenso o meio necessário para repeli-la. A moderação exige que a legítima defesa cesse quando terminada a agressão injusta. Qualquer excesso será punido dolosa ou culposamente.

Há algumas classificações de legítima defesa:

- a) Legítima defesa própria ou de terceiros – leva em consideração a titularidade

do direito protegido; se o direito protegido pertence ao próprio agente da legítima defesa, ela é própria; quando o direito for alheio, ela será de terceiro.

- b) Legítima defesa sucessiva – ocorre quando quem estava se defendendo do agressor inicial se excede na legítima defesa, e o excesso será considerado como uma nova agressão injusta criando a possibilidade de que o agressor inicial, agora na condição de agredido, se defenda legitimamente. Há uma sucessão de legítimas defesas reais.
- c) Legítima defesa preordenada – consiste na utilização de mecanismos de defesa normalmente patrimonial, que são instalados antes que a agressão seja atual ou iminente, mas somente serão utilizados contra o agressor quando a agressão se iniciar. Ex.: ofendículos como a cerca elétrica, cacos de vidro etc.

c) Estrito cumprimento de um dever legal

Previsto pelo art. 23, III, do CP, não tem dispositivo legal próprio apresentando seus requisitos, por isso seu conceito é extraído do próprio nome. Estrito significa dentro das regras, observados os limites, para o cumprimento desse dever; cumprimento porque é uma obrigação, não é uma opção, é um dever legal; dever legal é aquele originado de uma norma jurídica.

Esse dever coincide com o fato previsto por um tipo penal como crime, e em situações normais, se uma pessoa normal praticasse esse fato, seria crime.

Ex.: a prisão em flagrante realizada por um policial caracteriza um fato típico de sequestro ou cárcere privado, mas é lícita em razão do estrito cumprimento do dever legal.

d) Exercício regular do direito

Previsto pelo art. 23, III, do CP, não tem dispositivo legal próprio apresentando seus requisitos, por isso seu conceito é extraído do próprio nome. Exercício regular significa dentro das regras, dos limites normais desse direito; direito é aquilo que a

lei não proíbe, que é permitido fazer. Ex.: o lutador de artes marciais que causa lesão corporal no adversário; a tatuagem; os pais quando corrigem os filhos etc.

1.43 CONSENTIMENTO DO OFENDIDO

O consentimento do ofendido será causa supralegal de exclusão de ilicitude, pois embora não previsto em lei, a doutrina tem defendido que o consentimento do ofendido exclui a ilicitude do fato, quando não estiver previsto como elemento do tipo penal.

O consentimento do ofendido pode aparecer de duas formas no direito penal:

- 1) **excludente de tipicidade:** quando está previsto como elemento do tipo penal, expressa ou implicitamente, o consentimento do ofendido deve ser analisado na tipicidade formal, para verificar se há adequação entre o fato e o tipo penal. Ex.: art. 150 do CP – crime de violação de domicílio: só haverá violação, se for sem autorização, elemento normativo do tipo penal, portanto quando se entra ou permanece na casa de alguém com o consentimento do titular não há tipicidade formal, o fato é atípico e não é crime; estupro (art. 213) tem o consentimento do ofendido como elemento implícito do tipo penal, uma vez que o verbo constranger pressupõe que a vítima seja obrigada a praticar ou sofrer os atos sexuais, havendo consentimento da vítima o constrangimento desaparece e o fato torna-se atípico.
- 2) **excludente supralegal da ilicitude:** quando o consentimento do ofendido não é previsto no tipo penal o fato é típico, ainda que consentido, nessas situações o consentimento é usado como causa de exclusão supralegal da ilicitude. Ex.: o crime de dano patrimonial, art. 163 do CP, não prevê o consentimento do ofendido como elemento do tipo penal, o que significa que o dano mesmo consentido é típico. Requisitos para que o consentimento do ofendido exclua a ilicitude:
 - a) **capacidade** – o ofendido deve ser maior de 18 anos, ter plena consciência quando do consentimento, não pode ser portador de doenças mentais ou

- estar embriagado;
- b) validade do consentimento – não é válido o consentimento obtido mediante coação, fraude, violência, ameaças etc.;
 - c) o consentimento deve incidir sobre direitos (bens) disponíveis – o direito que será atingido mediante o consentimento do ofendido deve ser disponível; tratando-se de direitos indisponíveis, o consentimento não tem validade de excludente de ilicitude. Ex.: a vida é indisponível; portanto, ainda que haja consentimento do ofendido, o homicídio será crime;
 - d) o consentimento deve ser anterior ou simultâneo à prática do fato, e o consentimento posterior não exclui a ilicitude do fato.

1.44 CULPABILIDADE

É um juízo de reprovação pessoal com a finalidade de verificar se a pessoa que praticou o fato típico e antijurídico deve ser ou não reprovada. Consiste em um juízo de reprovação que leva em consideração alguns elementos pessoais para verificar se ele deve ser reprovado, sem que isso transforme o objeto de reprovação do direito penal do fato no homem, o direito penal reprova as pessoas por seus atos, e não por serem quem são.

A culpabilidade é elemento do crime, embora recaia sobre o homem, se ele puder ser reprovado, o fato é crime; não podendo ser reprovado, o fato não é crime. A corrente doutrinária, presente no Brasil, que excluiu a culpabilidade dos elementos do crime, a localizando como pressuposto de aplicação da pena, não prevalece.

Dentro da culpabilidade são analisados os seguintes elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.

1.45 IMPUTABILIDADE

É a capacidade de livre autodeterminação. Para aferir se o agente poderia atuar de forma diversa da que atuou devemos verificar, de antemão, sua capacidade de culpabilidade. Para Welzel a imputabilidade tem dois momentos: um cognoscitivo ou

intelectual, que é a capacidade de compreensão do injusto e outro momento volitivo ou de vontade, que é a capacidade de se determinar de acordo com esta compreensão. Portanto a imputabilidade é a capacidade de se autodeterminar entre o lícito e o ilícito, o que pressupõe antes a capacidade de entendê-lo como ilícito.

Há três critérios para fixar a inimputabilidade ou diminuir a culpabilidade: (a) biológico (sistema francês), que condiciona a capacidade à saúde mental; (b) psicológico, que condiciona a capacidade à inexistência, independente da causa, da faculdade de entender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar conforme esse entendimento; (c) biopsicológico, que é a união dos dois primeiros, isto é, condiciona a capacidade à inexistência da faculdade de entender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar conforme esse entendimento, causada pela enfermidade mental. O Brasil adotou o critério biopsicológico, com exceção da menoridade, que adota o critério meramente biológico.

São cinco os casos previstos de inimputabilidade por ausência da capacidade de autodeterminação:

- 1) menoridade – atende ao critério puramente biológico, pois todos os menores de 18 (dezoito) anos são inimputáveis, independentemente de serem mais ou menos desenvolvidos mentalmente (art. 27 do Código Penal);
- 2) doença mental e desenvolvimento mental incompleto ou retardado – atende ao critério biopsicológico, pois não basta ser doente mental, precisa que esta doença impeça completamente o agente de compreender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar conforme seu entendimento (art. 26 do Código Penal). Caso a doença mental só diminua a capacidade de compreensão ou de autodeterminação, o agente será considerado semi-imputável e sua pena será diminuída, havendo culpabilidade e consequentemente crime, art. 26, parágrafo único.
- 3) embriaguez fortuita - atende ao critério biopsicológico, pois o agente precisa estar em estado de embriaguez completa fortuitamente provocada, caso fortuito ou força maior, e esta embriaguez deve impedir completamente o

agente de compreender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar conforme seu entendimento (§ 1.º do art. 28 do Código Penal). Caso a embriaguez involuntária somente diminua a capacidade o agente será considerado semi-imputável, havendo culpabilidade e configurando o crime, embora com pena diminuída, art. 28, § 2.º, do CP.

A embriaguez que exclui a imputabilidade decorre de caso fortuito, nunca poderá ser voluntária ou culposa, pois que nestes casos de embriaguez, aplica-se a teoria da *actio libera in causa*, em que a condição pessoal de imputabilidade é transferida para momento anterior à embriaguez, vez que o agente se pôs em situação de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, respondendo pelo crime que eventualmente cometer nestas circunstâncias. Conforme prevê o art. 28, II, quando voluntária ou culposa não há alteração na imputabilidade do agente.

Outro caso, ainda diverso, é o da embriaguez preordenada, que constitui não apenas caso em que a imputabilidade é mantida, por ser voluntária (28, II), mas a pena ainda é agravada (art. 61, inciso II, letra I, do CP).

Nos casos de dependência química, ante a ausência de dispositivo específico no CP, deve ser aplicado o art. 26, atendendo ao critério biopsicológico, pois o agente precisa ser dependente químico de substância entorpecente e esta dependência deve impedir completamente o agente de compreender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar conforme seu entendimento. Caso a questão envolva drogas da Portaria 344/1998 da Anvisa devem ser aplicados os arts. 45 (inimputável) e 46 (semi) da Lei 11.343/2006, Lei de Drogas.

1.46 POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE

Somente age de forma reprovável quem sabe ou podia saber que está agindo de forma ilícita. Porém, muitas vezes que alguém age de forma típica e antijurídica não sabe que está agindo de forma ilícita. Agindo com consciência e vontade de praticar o fato típico, mas sem saber ou sem poder saber que a ação é ilícita, o agente agiu com dolo natural, porém sem consciência da ilicitude, o que afasta a reprovabilidade,

inobstante a ação seja típica e antijurídica não será culpável.

Somente não é culpável quem pratica o fato sem consciência da ilicitude, quando não era presumível a ilicitude dele. São situações de erro de proibição ou erro sobre a ilicitude do fato, previstas pelo art. 21 do CP, que serão exploradas em capítulo próprio. Quando o erro de proibição é inevitável ou escusável, o agente é isento de pena, não há culpabilidade; quando o erro é evitável ou inescusável, há apenas diminuição de pena, devendo ser condenado.

1.47 EXIGIBILIDADE DE COMPORTAMENTO CONFORME O DIREITO

Algumas vezes o agente tem imputabilidade, isto é, tem capacidade de compreender e se determinar conforme esse entendimento, tem potencial consciência da ilicitude, sabe o que é lícito e ilícito, mas não podia em uma determinada situação concreta, a despeito de sua capacidade e do seu entendimento, agir de forma diferente da que agiu, ou seja, não lhe era exigível outro comportamento diverso daquele que realizou. Neste caso dizemos que há inexigibilidade de conduta diversa, excluindo a culpabilidade. O CP prevê no art. 22 duas situações de inexigibilidade de conduta diversa:

- a) Coação moral irresistível: a coação moral irresistível atua na culpabilidade, tornando inexigível uma conduta diversa. É a vis compulsiva, em que o agente é obrigado a praticar a conduta; ele pratica a ação ou omissão porque foi obrigado pelo coator, por isso o agente não tem outra escolha, ou pelo menos não se pode exigir dele outra escolha. Por exemplo, o agente que causa a morte de um terceiro para salvar seu filho de sequestradores que ameaçavam matá-lo se ele não cumprisse essa determinação. A coação moral irresistível não deve ser confundida com a coação de natureza física irresistível que torna o fato atípico ao excluir o controle dos movimentos do agente. Em qualquer hipótese o coator responde pelo crime como autor mediato dele.
- b) Obediência hierárquica: depende da existência de hierarquia, própria das

relações laborativas do direito público, não há hierarquia nas relações privadas, domésticas ou religiosas. Deve haver uma ordem dada pelo superior ao subordinado, mas essa ordem não pode ser manifestamente ilegal, o subordinado não pode notar a ilegalidade da ordem para ser beneficiado, e deve parecer se tratar de sua atuação lícita, embora a ordem fosse ilícita. Quando a ordem é manifestamente ilegal, o subordinado deve recusar-se a cumpri-la; se a ordem manifestamente ilegal for obedecida, o agente pratica crime. Em qualquer hipótese, o superior responde pelo crime como autor mediato dele.

1.48 CRIME CONSUMADO E ITER CRIMINIS

O Código Penal (art. 14, I) define crime consumado aquele em que se reúnem todos os elementos de sua definição legal, portanto se o tipo penal descreve um crime que exige resultado (material) a consumação depende da existência deste resultado. Já nos crimes que não exigem (formais) ou que não têm (mera conduta) resultado, a consumação ocorre com a prática da conduta, independentemente de qualquer outro acontecimento. Por outro lado, se diz tentado o crime no qual iniciada a sua execução, não se chega à consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente (art. 14, II, do CP). A consumação e a tentativa são assuntos relacionados diretamente com o estudo do *iter criminis*.

Iter criminis. A prática do crime tem um itinerário que começa na concepção, chamada fase interna (*cogitatio*) e se desenvolve em atos, chamada fase externa (atos preparatórios, atos executórios e consumação). O primeiro momento, cogitação, é aquele em que o crime é planejado, ou seja, mentalmente elaborado. Essa fase é impunível, ninguém pode ser punido por ter cogitado de praticar um crime, mas é nela que surge o dolo, surgem os motivos e etc.

O segundo momento é a preparação, em que se realiza em atos preparatórios já exteriorizados, como a aquisição de apetrechos para o crime, a compra de armas, ou a reunião de diversas pessoas. Esses atos também são impuníveis por si só, a menos que exista um tipo autônomo prevendo a conduta como crime.

O terceiro momento é a execução. No entanto, difícil tarefa é definir o momento do início dos atos executórios. De acordo com esta corrente adotada por nosso Código Penal, a execução se inicia com a prática da conduta que configura o núcleo do tipo (matar, subtrair, apropriar-se etc.). A partir do início da execução o fato torna-se relevante para o direito penal, podendo ser configurada a tentativa.

O último momento é a consumação, que varia conforme a natureza do crime. Nos crimes materiais, a consumação se dá com a ocorrência do resultado naturalístico previsto no tipo. Nos crimes culposos, o momento da ocorrência do resultado naturalístico também é o momento consumativo. Nos crimes formais e de mera conduta a consumação, ocorre com a própria conduta. Nos crimes permanentes, a consumação se prolonga no tempo desde o momento em que todos os elementos do tipo se reúnem. Nos crimes omissivos, o crime se consuma no momento em que o agente deixa de agir quando deveria tê-lo feito.

1.49 TENTATIVA

Está prevista no art. 14, II, do CP. A natureza jurídica da tentativa é de norma de adequação típica indireta ou mediata. Ocorre tentativa quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Se durante a cogitação ou durante a preparação o agente para, por circunstâncias alheias à sua vontade, e queria ter entrado na execução, mas não pôde, não há tentativa, embora atos ilícitos praticados na preparação sejam punidos em si (ex.: porte ilegal de arma, associação criminosa; esses enquanto atos preparatórios para a prática de outro crime). Portanto, os requisitos da tentativa são: o início da execução do crime doloso, a ocorrência de circunstâncias alheias à sua vontade (ele quer continuar, mas não pode) e a não consumação.

1.49.1 Espécies de tentativa

- a) Tentativa imperfeita: ocorre durante a execução do crime; o agente não chega sequer a concluir a conduta na sua integralidade. Pode ocorrer em QUALQUER crime plurissubsistente, seja ele material, formal ou de mera

conduta.

- b) Tentativa perfeita ou crime falho: acontece somente nos crimes materiais, quando o agente fez tudo o que planejou, praticou a conduta na sua integralidade, mas o resultado não ocorre por circunstância alheia à vontade dele. Só pode suceder nos crimes materiais, pois somente estes necessitam do resultado para a consumação. Nos crimes formais, ainda que seja possível impedir o resultado, a consumação já ocorreu com a conduta.
- c) Tentativa branca ou incruenta: o bem jurídico não sofre qualquer tipo de lesão como consequência da tentativa.
- d) Tentativa vermelha ou cruenta: o bem jurídico sofre algum tipo de lesão como consequência da tentativa, embora não chegue à consumação.

1.49.2 Consequências da tentativa

A tentativa será punida com a pena do crime consumado diminuída de 1/3 a 2/3, conforme dispõe o art. 14, parágrafo único, do CP; trata-se de causa de diminuição de pena aplicável na terceira fase da dosimetria da pena.

1.49.3 Infrações que não admitem tentativa

É importante ressaltar que algumas infrações penais não admitem tentativa, são elas:

- Crimes unissubsistentes – como a consumação ocorre com a prática de um único ato de execução, não é possível interrompê-lo, o que impede a configuração da tentativa.
- Crimes culposos e preterdolosos – a tentativa é uma característica exclusiva dos crimes dolosos, pois depende da vontade do agente que será frustrada pela circunstância alheia. Mostra-se absolutamente incompatível com o crime culposos e com os crimes qualificados por resultados culposos (preterdolosos).
- Crimes omissivos próprios – como a omissão é o núcleo do tipo penal, a consumação ocorre com a própria conduta.

do crime, não é possível tentá-la. Tentar uma omissão significa fazer o que a lei determinou, portanto não há possibilidade de tentativa. Os crimes omissivos impróprios, conhecidos como comissivos por omissão (art. 13, § 2.º) admitem tentativa, pois apesar da omissão do garantidor, pode ser que uma circunstância alheia impeça o resultado.

- Crimes habituais – a doutrina majoritária entende que os crimes habituais, por exigirem a reiteração da conduta para sua configuração, não admitem a tentativa, pois a prática da conduta isolada é atípica.
- Crimes de atentado – são crimes que igualam a tentativa e a consumação, portanto a modalidade tentada está prevista diretamente no tipo penal e não depende da utilização do art. 14, II, para tipificação indireta. Por exemplo, o crime previsto no art. 352 do CP.
- Crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio – o crime está previsto no art. 122 do CP que, ao descrever a pena, vincula sua aplicação aos resultados morte ou lesão corporal grave. Assim, caso o induzimento, a instigação ou o auxílio ocorra, mas a vítima não sofra lesões graves ou morte, o fato é atípico.
- Contravenções penais – a Lei de Contravenções Penais, Decreto 3.688/1941 prevê no art. 4.º que as tentativas de contravenções não são punidas. Na verdade, trata-se de fato atípico.

1.49.4 Tentativa inidônea

Crime impossível. De acordo com o art. 17 do Código Penal, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio (exemplo, quando o agente pretende matar alguém o envenenando com suco de uva) ou por absoluta impropriedade do objeto (exemplo, quando o agente pretende matar alguém que já se encontra morto) é impossível consumar-se o crime. Nesse caso, será um irrelevante penal. Também é possível falar em crime impossível por obra do agente provocador: o agente provoca a conduta criminosa em outra pessoa, tomando todos os cuidados para tornar impossível a consumação. Ex.: flagrante provocado. Súmula 145 do STF: não há

crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação.

Os mecanismos de segurança não tornam impossível a consumação do crime de furto, os tribunais entendem que a tentativa é punível, conforme se vê na Súmula 567 do STJ. Ex.: câmeras de monitoramento, alarmes eletrônicos e outros meios de segurança utilizados em estabelecimentos comerciais, conforme decisão do STJ no REsp 1.385.621/MG, publicada no Informativo 563, com efeito de recurso repetitivo.

Súmula 567 do STJ: sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

1.50 DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU ARREPENDIMENTO EFICAZ

O art. 15 do CP prevê duas hipóteses de tentativa abandonada voluntariamente pelo agente, nela o agente inicia a execução, não há a consumação, voluntariamente. Obviamente que desistindo na cogitação ou na preparação, não se deve falar em desistência voluntária, pois esta exige o início da execução do crime.

1.50.1 Desistência voluntária

Ocorre quando o agente desiste durante a execução da conduta, sem que nada o tenha impedido de continuar; ele decide voluntariamente parar os atos de execução que estava praticando. É possível em quaisquer crimes plurissubsistentes, sejam crimes materiais, formais ou de mera conduta.

1.50.2 Arrependimento eficaz

Após o agente praticar toda a conduta, impede a ocorrência do resultado naturalístico, obstando a consumação do crime. O arrependimento eficaz é possível somente nos crimes materiais, pois estes dependem do resultado para a consumação. Por exemplo, após praticar todos os atos executórios de um homicídio, o agente se arrepende do que fez, leva a vítima até o hospital e salva sua vida.

Ainda que seja possível impedir o resultado de crimes formais, minimizando suas consequências, a consumação não se altera, já que ocorreu antecipadamente com a

conduta de execução.

A consequência penal da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz é, segundo a doutrina majoritária, de exclusão da adequação típica indireta ou mediata da tentativa, ou seja, o agente não responde pela tentativa, devendo ser imputados somente os atos já praticados se constituírem crimes. Se após iniciada a execução de um homicídio, com disparos de arma de fogo na direção da vítima, o agente desiste de prosseguir, mas a vítima sofre lesões corporais de natureza leve, sua conduta deve ser tipificada no art. 129, *caput*, do CP, e não como tentativa de homicídio.

1.51 ARREPENDIMENTO POSTERIOR

O arrependimento posterior se caracteriza pela atuação voluntária do agente que pretende reparar o dano que causou à vítima em decorrência da prática do crime. Portanto, o arrependimento posterior ocorre após a consumação do crime, marcando sua diferença diante do arrependimento eficaz que impede a consumação, enquanto o posterior repara o dano pós-consumação. Sua consequência é apenas diminuição de pena em 1/3 a 2/3, não acarretando qualquer implicação na tipificação do crime consumado.

Requisitos legais (art. 16 do CP):

- a) crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa – se o crime tem como meio de execução o uso da violência ou da grave ameaça à pessoa, a reparação do dano não configura arrependimento posterior, mas sim atenuante da pena prevista no art. 65, III, *b*, do CP;
- b) reparação do dano ou restituição da coisa – a finalidade do arrependimento posterior é estimular, por meio da diminuição da pena, que o agente indenize a vítima; a doutrina defende que a reparação deve ser integral, mas a jurisprudência tem admitido o arrependimento quando a diminuição for parcial, sendo inclusive um dos critérios para estabelecer a quantidade de diminuição da pena (STF, HC 94.685, Inf. 608);
- c) até o recebimento da denúncia ou da queixa – requisito temporal, limita o

arrependimento posterior no tempo, fazendo com que o agente indenize mais rapidamente a vítima;

- d) voluntariamente – o arrependimento deve ser voluntário, não precisa ser espontâneo, a ideia de se arrepender pode vir de um terceiro, mas o agente não pode ser obrigado.

1.52 TEORIA DO ERRO

O erro é a falsa percepção da realidade. Em linhas gerais, esta falsa percepção da realidade pode recair sobre elementos do tipo, chamado erro de tipo, ou pode recair sobre a ilicitude da conduta, chamada erro de proibição.

1.52.1 Erro de tipo

O erro de tipo está expressamente previsto no art. 20 do Código Penal, trata-se de erro quanto aos elementos que constituem o tipo penal. Na verdade, é uma falsa representação da realidade que afasta o dolo. No erro de tipo o agente não tem consciência real da conduta que está realizando, falta elemento cognitivo do dolo, o agente não sabe o que está fazendo. Por exemplo, o agente transporta drogas em seu carro, atendendo a um pedido de favor de um amigo, que o enganou dizendo que eram remédios, neste caso, evidentemente, o agente não tem dolo de tráfico de drogas, uma vez que não tem consciência do que transporta de verdade. Neste caso o terceiro que provoca o erro responde pelo crime, conforme dispõe o art. 20, § 2.º.

Vale ressaltar que o erro de tipo, embora exclua o dolo, não isenta de punição por culpa, quando essa estiver presente no comportamento do agente e se prevista a modalidade culposa para o crime praticado. O erro escusável é o erro invencível, inevitável, aquele no qual não houve dolo e nem culpa do agente. Neste caso o agente que age em erro escusável não responde nem por dolo, nem por culpa, sendo o fato atípico. De outro lado o erro de tipo inescusável, ou vencível, evitável, exclui o dolo, mas é punível por culpa, caso haja previsão expressa do delito culposos.

1.52.2 Erro de proibição

O erro de proibição está previsto no art. 21 do Código Penal, e consiste no erro

sobre a ilicitude (antijuridicidade) da conduta. Há erro de proibição quando o agente supõe ser o seu comportamento lícito. É válido esclarecer que o agente não tem qualquer erro quanto aos elementos constitutivos do tipo penal, conhece-os, sabe o que está fazendo e quer fazer, mas supõe que sua conduta seja lícita. Quando o erro for inevitável, isentará o agente de pena; se evitável, reduz a pena de um sexto a um terço. Por outro lado, o que a teoria finalista passou a exigir não é a consciência da ilicitude, e sim a potencial consciência da ilicitude, exige-se o conhecimento da proibição sempre que o agente puder, de acordo com os princípios morais e éticos, bem como com normas de cultura comuns, conhecer a proibição constante do ordenamento. O Código Penal, nesta linha, fez a previsão, no parágrafo único do art. 21, que o erro de proibição será evitável quando for possível ao agente, nas circunstâncias específicas, ter consciência da ilicitude. Em outras palavras, será evitável o erro de proibição quando o agente tiver potencial consciência da ilicitude, ainda que não a tenha efetivamente, devendo ser considerado culpável, respondendo pelo crime com a pena diminuída nos termos da lei.

Existem três modalidades de erro sobre a ilicitude:

- a) erro de proibição direto, no qual o agente engana-se a respeito de uma norma proibitiva, ou seja, há uma norma que proíbe uma conduta (ação) e o agente a desconhece ou a conhece mal;
- b) erro mandamental, este é o erro que recai sobre as condutas omissivas, em que a norma impõe determinada ação e o agente desconhece ou conhece mal o mandamento. Por exemplo, o salva-vidas que no meio do salvamento percebe que seu turno de trabalho terminou e abandona a vítima. O omitente que acredita não estar obrigado pelo crime de omissão de socorro, porque a vítima está passando mal na porta do hospital.
- c) erro de proibição indireto, em que o agente supõe haver uma permissão, exclusão da ilicitude, no caso concreto, seja porque acredita haver uma norma permissiva, excludente, que na realidade não existe, seja porque erra sobre os limites de uma excludente de ilicitude, acreditando poder agir. O

marido que viola a correspondência da mulher, acreditando que o casamento autoriza, age em erro de proibição indireto, pois acredita que o direito o autoriza, quando não existe tal excludente. Assim como o pai que mata o estuprador da filha, depois de encerrada a agressão, acreditando que ainda está em legítima defesa. Percebe-se que nestas hipóteses o erro do agente incide em pressupostos jurídicos da excludente, na sua própria existência legal ou nos seus limites legais.

1.52.3 Discriminantes putativos

O Código Penal brasileiro adotou a Teoria Limitada da Culpabilidade para as discriminantes putativas. Segundo essa teoria, as discriminantes putativas podem ocorrer por erro de tipo permissivo (art. 20, § 1.º), derivado de circunstâncias fáticas, ou por erro de proibição indireto (art. 21), incidindo na abrangência ou existência de discriminantes, erro sobre circunstâncias jurídicas.

As hipóteses de erro de proibição indireto, já analisadas no item anterior, são reguladas pelo art. 21 do CP. Já as situações de discriminantes putativas por erro de tipo permissivo estão tratadas no art. 20, § 1.º, do CP, com consequências diferentes das anteriores. O dispositivo legal dispõe que será isento de pena o agente, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias (fáticas), supõe uma situação fática que, se existisse, tornaria sua atuação legítima. Não ocorre isenção de pena se o erro deriva de culpa (erro culposo), e o fato é punido como crime culposos, embora tenha agido com o dolo, por isso essa culpa é denominada culpa imprópria.

Ex. 1: o agente que dispara contra um cão aparentemente bravo que iria atacar uma criança, e depois verifica que era dócil e somente iria brincar com ela, foi enganado pelas circunstâncias FÁTICAS e supôs estar em estado de necessidade.

Ex. 2: o homem, ao encontrar com um inimigo perigoso, supõe que este irá matá-lo e dispara contra ele acreditando estar em legítima defesa, quando na verdade o outro o procurara para fazer as pazes, foi enganado pelas circunstâncias FÁTICAS; se o erro for inevitável, será isento de pena; se derivou de culpa, responderá culposamente (culpa imprópria).

1.53 ERROS ACIDENTAIS

Dividem-se em:

- a) **Erro quanto ao objeto:** nos crimes que têm a coisa como objeto material. O agente quer atingir uma coisa e atinge outra. Desde que a coisa atingida tenha as características necessárias para o crime, nada muda, responde pelo ilícito que praticou, levando em conta a coisa realmente atingida.
- b) **Erro quanto à pessoa:** art. 20, § 3.º, do CP. Ocorre nos crimes que têm a pessoa como objeto material. O agente quer praticar o crime contra uma pessoa e, por confundir uma pessoa com outra, pratica contra uma pessoa diferente da pretendida. O erro está na escolha da pessoa. Não isenta de pena, nem se levam em consideração as características da vítima, mas da pessoa que ele queria atingir; ele responde como se tivesse praticado o crime contra quem ele queria. Ex.: a mulher que tenta matar o filho no estado puerperal, mas mata outra criança por erro; quanto à pessoa, responde por infanticídio, como se tivesse matado o próprio filho.
- c) **Erro na execução (*aberratio ictus*):** art. 73 do CP. É um erro ou acidente no uso dos meios de execução. O agente queria praticar o crime contra determinada pessoa, mas por erro ou acidente no uso do meio de execução, acabou atingindo pessoa diferente. A consequência é a mesma no erro quanto à pessoa, ou seja, responde como se tivesse praticado contra quem ele queria. Se atingir a pessoa que queria e também outra pessoa, ele responde pelos dois crimes (um por dolo e o outro por culpa), em concurso formal próprio do art. 70, primeira parte, do Código Penal.
- d) **Resultado diverso do pretendido (*aberratio criminis*):** art. 74 do CP. Por erro ou acidente no uso dos meios de execução o agente queria atingir a coisa, mas atinge a pessoa. Assim, o agente responde pelo resultado diverso por culpa. Ex.: o agente, com o dolo de dano à coisa, atira uma pedra na direção dela, mas acaba por erro atingindo uma pessoa que passava pelo local, causando uma lesão corporal, respondendo por lesão corporal culposa. Caso

atinga também o resultado que pretendia, responde pelos dois crimes em concurso formal próprio no art. 70 do CP.

e) **Erro irrelevante na causalidade do crime (*aberratio causae*):** a doutrina brasileira trata de duas situações:

- O agente pratica uma conduta visando causar um resultado, mas causa es resultado de outra forma, e não como planejou. Ex.: o agente tenta matar a vítima jogando-a em um rio, por ela não saber nadar, mas a vítima não morre afogada, e sim porque bateu a cabeça em uma pedra localizada no fundo do rio. O agente responde pelo crime consumado sem importar o motivo do resultado.
- O agente pratica uma conduta dolosa, e por erro ele acredita que já causo o resultado. Então ele pratica uma nova conduta, já sem o mesmo dolo, e esta sim é que causa o resultado. Pela teoria do DOLO GERAL, deve responder pelo crime consumado como se tivesse causado o resultado no primeiro momento, ou seja, aplicam-se as qualificadoras, causas de aumento etc., relativas à primeira conduta. Ex.: o agente, com o dolo de matar, atira na vítima e acha que ela está morta, então ele atira o “cadáver” (pois acha que está morto) em um rio para ocultá-lo. Posteriormente a perícia comprova que a vítima morreu afogada, e não em razão dos disparos feitos pelo agente. Nesse caso, o agente responde pelo dolo geral como se tivesse matado com a primeira conduta.

1.54 ESPÉCIES DE PENA

Confira-se o art. 32 do CP. São elas:

- a) Privativa de liberdade: restringe a liberdade do condenado. Pode ser de reclusão ou detenção nos crimes e de prisão simples nas contravenções penais.
- b) Restritivas de direito: atinge outros direitos que não a liberdade. Estão previstas no art. 43 do CP e em outros dispositivos da legislação

extravagante.

- c) Multa: pena pecuniária, pagamento em dinheiro ao Estado no valor fixado na sentença por meio do critério de dias-multa.

1.55 PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REGIMES

- a) Regime fechado: suas principais características estão no art. 34 do CP. Deve ser cumprido em penitenciária de segurança máxima ou média em presídio federal ou estadual. No começo do cumprimento da pena o condenado passa por um exame criminológico, que analisa sua vida pregressa, o crime praticado e outros aspectos pessoais, com o fim de determinar o tipo de estabelecimento em que ele deva ir e outros aspectos de individualização da execução da pena. O condenado pode trabalhar internamente durante o dia e se recolher à cela individual durante a noite. O trabalho externo é admitido, desde que observados os requisitos do art. 36 da Lei de Execução Penal – Lei 7.210/1984 –, somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.
- b) Regime semiaberto: art. 35 do CP. A pena é cumprida com a pessoa presa, o estabelecimento prisional passa a ser a colônia agrícola ou industrial. Excepcionalmente, ele pode sair para trabalhar, sem vigilância, e voltar para a prisão à noite. Aqui também é feito o exame criminológico. O trabalho externo ou frequência a cursos é permitido.
- c) Regime aberto: art. 36 do CP. A pena é cumprida na casa de albergado, e na falta desse estabelecimento pode ser deferido o regime de albergue domiciliar. O condenado sai durante o dia para trabalhar ou estudar e volta para passar as noites, os dias de folga, os finais de semana e feriados na casa de albergado.

1.56 REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Art. 33, § 2.º + art. 59 do CP	Reclusão	Detenção
a) Pena > 8 anos	Fechado	Semiaberto
b) 8 anos ≥ pena > 4 anos:		
Reincidente	Fechado	Semiaberto
Primário	Fechado ou semiaberto	Semiaberto
c) Pena ≤ 4 anos		
Reincidente	Fechado ou semiaberto (Súmula 269 do STJ)	Semiaberto
Primário	Fechado, semiaberto ou aberto	Semiaberto ou aberto

O regime inicial é estabelecido pela análise de dois dispositivos legais: o art. 33, § 2.º, alíneas *a*, *b* e *c*, combinado com o art. 59, III, do CP. O art. 33, § 2.º, apresenta uma tabela considerando a pena da condenação e a primariedade do condenado:

Nas situações em que o juiz, com base na tabela, tem mais de uma opção de regime inicial deve-se privilegiar o regime mais benéfico, iniciando o regime pelo menos rigoroso. A colocação em regime mais rigoroso do que o admitido, de acordo com a pena ou a primariedade, depende de fundamentação concreta nos elementos do art. 59, III, do CP, e não é outro o entendimento do STF e do STJ nos seguintes Enunciados: Súmula 718 do STF: a opinião do juiz sobre a gravidade do crime não serve como fundamentação para iniciar o regime mais gravoso quando se tem essa opção; Súmula 719 do STF: a motivação pela opção de regime mais gravoso deve ser idônea, ou seja, com base no art. 59, III, do CP; Súmula 440 do STJ: fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Obs.: a Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990) determina que os crimes hediondos e os equiparados (tráfico, tortura e terrorismo), no art. 2.º, § 1.º, têm regime inicial **obrigatoriamente** fechado. O STF decidiu que o regime inicial fechado obrigatório é inconstitucional por ferir a individualização da pena; assim, qualquer regra que obrigue o regime inicial fechado, como as citadas, deve ser afastada e aplicada a regra geral exposta acima (STF, HC 111.840, Inf. 672).

1.57 PROGRESSÃO DE REGIME

O condenado que cumpre pena privativa de liberdade tem o direito à progressão de regime, e prevê o art. 33, § 2.º, do CP que a pena será cumprida em regime progressivo conforme o mérito do condenado. O art. 112 da LEP (Lei 7.210/1984), traz como regra geral que o condenado deve ter cumprido 1/6 da pena no regime anterior e ter bom comportamento carcerário para obter a progressão de regime.

Embora a legislação não preveja mais o exame criminológico como requisito da progressão, a jurisprudência tem admitido sua execução desde que o juiz fundamente sua necessidade, conforme entendimento do STJ no Enunciado 439 da Súmula e do STF na Súmula Vinculante 26.

Nos crimes contra a Administração Pública é necessário, além dos requisitos acima, que o condenado tenha reparado o dano causado à Administração, conforme disposto no art. 33, § 4.º, do CP.

Vale ressaltar que a progressão de regime deve observar a sucessão dos regimes, não se admitindo que o condenado que está no regime fechado progrida diretamente para o aberto, a chamada progressão em saltos, conforme entendimento sumulado do STJ no Enunciado 491.

No caso de prática de falta disciplinar de natureza grave durante a contagem de prazo para a progressão acarreta a interrupção do prazo, que deverá recomeçar do zero, esse é o entendimento do STJ na Súmula 534.

A Lei 13.769/2018 incluiu na Lei de Execução Penal (art. 112, § 3.º) uma nova modalidade especial de progressão de regime em algumas situações específicas envolvendo mulheres. O novo § 3.º do art. 112 da LEP prevê que, no caso de mulher

gestante ou que for mãe ou responsável por crianças (menores de 12 anos) ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

- I – não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
- II – não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
- III – ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;
- IV – ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento e
- V – não ter integrado organização criminosa.

Tal progressão especial aplica-se inclusive em casos de crimes hediondos, conforme dispõe a nova redação do § 2.º do art. 2.º da Lei 8.072/1990, alterado pela mesma legislação.

Conforme dispõe o § 4.º do mesmo artigo, o cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo anterior.

Tratando-se de crimes hediondos ou equiparados, o art. 2.º, § 2.º, da Lei 8.072/1990 dispõe que a progressão depende do cumprimento de 2/5 da pena se for réu primário e 3/5 se reincidente, além de ter bom comportamento carcerário, requisito geral exigido pela LEP. A fração de 3/5 para reincidentes é exigida de qualquer reincidente, mesmo que o primeiro crime não tenha sido hediondo, ou seja, trata-se de reincidência genérica e não específica, como defende parte da doutrina. Esse é o entendimento que o STJ vem adotando, conforme decisão publicada no Informativo 563. Essas frações de 2/5 e 3/5 para os crimes hediondos só se aplicam aos crimes praticados depois da entrada em vigor da Lei 11.464/2007, que inseriu essas frações específicas na lei dos crimes hediondos; para os crimes anteriores à Lei 11.464/2007, aplica-se a Lei de Execução Penal com a fração de 1/6 da pena. Esse é o entendimento do STF na Súmula Vinculante 26 e do STJ na Súmula 471.

Os crimes incluídos no rol de crimes hediondos após a entrada em vigor da Lei 11.464/2007, somente serão considerados hediondos após a previsão legal

específica. Assim, as exigências mais rigorosas, somente serão exigidas a partir da inclusão do referido crime no rol previsto no art. 1.º da Lei 8.072/1990. Por exemplo, o crime de lesão corporal gravíssima ou seguida de morte contra agentes de segurança pública foram incluídos na lei de crimes hediondos pela Lei 13.142/2015, somente a partir desta lei as frações mais rigorosas serão exigidas nestes crimes, antes a progressão era regulada pelo art. 112 da LEP.

1.58 REGRESSÃO DE REGIME

A Lei de Execução Penal no art. 118 prevê a regressão de regime de cumprimento de pena. Diferente da progressão, a regressão pode ser direta de um mais leve para o mais rigoroso, e o condenado pode regredir do aberto diretamente para o fechado. A regressão ocorre quando o condenado praticar falta disciplinar de natureza grave (art. 50 da LEP) ou quando praticar um crime doloso; nessas duas hipóteses a regressão depende da oitiva do condenado, mas não é necessário aguardar sentença condenatória transitada em julgado pelo novo crime ou decisão sancionatória definitiva da falta disciplinar. A doutrina discute se é necessário que o preso seja condenado definitivamente pelo novo crime para a decretação da regressão, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. Entretanto, o STJ entende não ser necessária a condenação definitiva, conforme se verifica na Súmula 526, que dispõe que o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Por outro lado, no que tange à falta grave o STJ, por meio da Súmula 533, fixou entendimento de que, para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Também há regressão quando o condenado sofre uma nova condenação e, somando as penas, atual e a nova, o total impede que continue no regime em que está; conforme o art. 111 da LEP e art. 33, § 2.º, do CP, tem que voltar para o regime mais

grave. Ex.: o condenado está cumprindo pena no regime aberto, faltam dois anos de pena para cumprir, sofre uma nova condenação de sete anos no semiaberto; somando os sete anos da nova condenação com os dois da anterior, tem-se um total de nove anos, o que impõe o regime fechado, conforme o art. 33, § 2.º, *a*.

No regime aberto também há regressão se o condenado frustrar os fins da pena ou não pagar a pena de multa quando solvente. Ex.: o condenado que está no regime aberto e não retorna à noite para casa do albergado ou abandona o trabalho está descumprindo as regras do regime e pode sofrer regressão.

1.59 REMIÇÃO

Prevista nos arts. 126 a 128 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal – LEP). Consiste na possibilidade de cumprimento antecipado da pena por meio do trabalho ou do estudo. Nos regimes fechado e semiaberto, ocorre a remição da pena pelo trabalho, dentro ou fora do estabelecimento prisional, conforme Súmula 562 do STJ; e pelo estudo formal, há diminuição de um dia de pena a cada três dias de trabalho e de um dia de pena a cada 12 horas de estudo distribuídas em três dias.

O art. 126, § 6.º, prevê a remição da pena no regime aberto e do período de prova nas situações de liberdade condicional pelo estudo, na mesma fração acima, mas o trabalho não acarreta remição nessas situações. As atividades de estudo que acarretam a remição são atividades formais no ensino fundamental, médio (inclui o profissionalizante) e superior, bem como as atividades de requalificação profissional, sempre certificadas pelas autoridades competentes e órgãos de classe.

O período de remição será computado como pena cumprida para conceder todos os benefícios que utilizam o tempo de pena cumprida como requisito. Caso o condenado sofra acidente que o impeça de trabalhar ou estudar, ele continua computando tempo de remição.

A prática de falta disciplinar de natureza grave (art. 50 da LEP) acarreta a perda de até 1/3 do período de remição. Até a Lei 12.433/2011 o art. 127 da LEP previa a perda integral dos dias remidos quando da prática de falta grave, e esta regra era criticada pela doutrina, mas o STF, mediante a Súmula Vinculante 09, entendeu que o

art. 127 da LEP fora recepcionado pela CR/1988. Atualmente, não há mais a perda integral e a Súmula não se aplica mais, devendo a nova regra retroagir aos fatos anteriores por ser mais benéfica, acarretando a perda de no máximo 1/3 do período remido, com base no critério previsto no art. 57 da LEP, que determina que sejam levados em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.

1.60 OUTROS PONTOS

Detração penal: prevista no art. 42 do CP, é a possibilidade de diminuir da pena da condenação ou da medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil, ou no estrangeiro de prisão administrativa ou de internação provisória. Ex.: o agente ficou preso provisoriamente por oito meses durante o processo, e ao final foi condenado a cinco anos, o tempo de prisão cautelar deve ser descontado da pena da condenação.

Regime disciplinar diferenciado – RDD: consiste em tratamento penal ainda mais rigoroso que o regime fechado, e as hipóteses de aplicação são: (a) prática de crime doloso pelo preso condenado ou provisório, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas; (b) quando presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; (c) quando recaírem sobre o preso provisório ou o condenado fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações ou associações criminosas. Suas principais características são: (a) duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada; (b) recolhimento em cela individual; (c) visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas; (d) o preso terá direito à saída da cela por duas horas diárias para banho de sol.

1.61 RESTRITIVAS DE DIREITO

São as penas alternativas às penas privativas de liberdade, fruto da constatação da

falência da prisão como meio de prevenção especial, principalmente nas penas de pequena duração. Estão previstas no art. 43 do CP, e o rol é taxativo. Em virtude do princípio da legalidade, não há pena sem prévia cominação legal, consequentemente o rol de penas restritivas de direitos é taxativo. Na legislação especial podem ser encontradas outras penas restritivas de direitos, como na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998) e no Código de Trânsito (Lei 9.503/1997). O rol previsto pelo Código Penal traz as seguintes penas:

- a) Prestação pecuniária
- b) Perda de bens e valores
- c) Prestação de serviço à comunidade
- d) Interdição temporária de direito: as hipóteses de suspensão temporária de direitos estão previstas no art. 47 do CP: (a) proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo; (b) proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público; (c) suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo; (d) proibição de frequentar determinados lugares; e (e) proibição de se inscrever em concurso, avaliação ou exame públicos.
- e) Limitação de fim de semana

Requisitos para a substituição: as penas restritivas de direito são penas substitutivas: substituem as penas privativas de liberdade (art. 44 do CP). Em regra, o legislador não prevê penas restritivas de direitos nos preceitos secundários dos crimes, são previstas penas privativas de liberdade e, às vezes, multas. Portanto, as condenações penais devem aplicar as penas cominadas no tipo penal, invariavelmente penas privativas de liberdade, e, após a aplicação, verificar se é caso de substituição por penas restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. Requisitos previstos no art. 44 do CP:

- a) se o crime for doloso: a pena da condenação deve ser até quatro anos (pena $\leq$ quatro anos) e o crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (requisito discutível quando se tratar de crimes de menor potencial ofensivo);
- b) se o crime for culposo: não importam a pena nem se houve violência ou grave ameaça;
- c) o réu não pode ser reincidente em crime doloso, mas o § 3.º do próprio art. 44 dispõe que, mesmo sendo reincidente, se a substituição for socialmente recomendável, esta pode ser realizada, salvo se for reincidente no mesmo crime doloso (reincidência específica), quando não pode ocorrer a substituição;
- d) elementos subjetivos ligados ao agente devem ser levados em conta; o juiz de verificar se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicam que essa substituição é suficiente. Esse é o único requisito que pode impedir a substituição da pena em crimes culposos, os demais não se aplicam a eles.

Critério de substituição: estando esses requisitos satisfeitos, o juiz concede a substituição. A substituição deve considerar a regra do art. 44, § 2.º, do CP:

Pena $\leq$ um ano substitui por uma restritiva de direito ou uma multa.

Pena $>$ um ano substitui por uma restritiva + multa ou duas restritivas de direito.

A Súmula 171 do STJ: veda a substituição por multa substitutiva quando o crime já tem multa cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade que se pretende substituir. Se a multa já estava prevista cumulativamente para um crime em lei especial, não pode substituir por pena de multa, evitando assim que ao condenado sejam aplicadas duas multas.

A Súmula 493 do STJ: “É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto”.

Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade: art. 44, § 4.º, do CP, prevê que a pena restritiva de direito será convertida em pena privativa de liberdade se o agente descumprir injustificadamente a pena restritiva imposta. O tempo de pena cumprido é descontado do montante a cumprir de prisão, sempre respeitado um saldo mínimo de 30 dias de reclusão ou de detenção. Além da hipótese de descumprimento, o art. 44, § 5.º, do CP prevê que se o agente estiver cumprindo penas restritivas de direitos e for condenado por outro crime, a pena privativa de liberdade pode continuar na restritiva anterior se for compatível com a nova pena; caso ocorra incompatibilidade, é necessário converter a restritiva em privativa e ele passa a cumprir as duas.

Lei Maria da Penha: As penas restritivas de direitos, nos casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher, sofrem restrições pela Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que no art. 17 prevê que ficam proibidas substituições por penas que sejam apenas pecuniárias. Portanto, tal dispositivo não proíbe as penas restritivas nos casos abrangidos pela lei, somente vedando as penas que sejam exclusivamente pagamentos em dinheiro ou outros bens. O STJ, por meio do Enunciado 588, fixou entendimento de que “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Trata-se de situações de violência real ou grave ameaça contra a mulher, como ocorre em crimes como a lesão corporal.

1.62 PENA DE MULTA

Tem natureza de pena pecuniária e consiste no pagamento em dinheiro ao Fundo Penitenciário Nacional. O valor da pena de multa após a reforma da parte geral pela Lei 7.209/1984 é calculado com base no critério dos DIAS-MULTA. Conforme dispõe o art. 49 do CP, o mínimo é de 10 dias-multa e o máximo, de 360 dias-multa. Para fixar essa quantidade de dias, o juiz leva em consideração o critério trifásico de dosimetria da pena (art. 68 do CP). Depois de fixada a quantidade de dias, o art. 49, § 1.º, determina o critério para chegar ao valor de cada dia, e o valor de cada dia-multa

em reais (R\$) é no mínimo de 1/30 do salário mínimo e o valor máximo é de cinco vezes o salário mínimo. O valor é fixado de acordo com a capacidade econômica do acusado. Caso a pena de multa, embora no máximo, seja insuficiente pela capacidade econômica do condenado, o juiz pode elevá-la em até o triplo, conforme dispõe o art. 60, § 1.º, do CP. Os dispositivos legais, anteriores à Lei 7.209/1984, que fixavam valores próprios de multa, em dinheiro ou outras unidades de referência monetária, foram alterados e a multa deve observar o critério previsto no Código Penal.

O pagamento da pena de multa deve ser feito no prazo de dez dias a contar do trânsito em julgado da condenação. A critério do juiz, o pagamento pode ser feito em parcelas e pode até ser descontado em folha, em três situações: (a) condenação somente à pena de multa; (b) condenação à pena de multa em conjunto com restritivas de direitos; (c) condenação à pena de multa em conjunto com pena privativa de liberdade suspensa condicionalmente. Em caso de inadimplemento, a pena de multa não pode mais ser convertida em prisão, pois é considerada dívida e ninguém pode ser preso por dívidas de valor, ressalvado o devedor civil de alimentos. Portanto, se a pena não é paga, o condenado sofre uma execução fiscal, como nas dívidas ativas junto à fazenda pública, adotando-se inclusive as causas interruptivas e suspensivas da prescrição da legislação fiscal, embora os prazos de prescrição continuem regulados pelo art. 114 do CP.

1.63 CONCURSO DE CRIMES

Quando o agente pratica mais de um crime, seja na mesma circunstância ou em circunstâncias diferentes, ocorre o denominado concurso de crimes. O Código Penal brasileiro adotou três espécies de concursos de crimes: o concurso material, o concurso formal e o crime continuado.

Concurso material: previsto no art. 69 do CP, ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou diferentes. Quando os crimes forem idênticos, o concurso será homogêneo; quando forem crimes diferentes, o concurso será heterogêneo. O critério de aplicação das penas é o critério da cumulação. Aqui há cumulação, o agente é condenado por cada crime e ao final as

penas serão somadas. A pena de reclusão é sempre cumprida primeiro, quando houver condenação por crimes apenados com detenção e reclusão. É preciso lembrar que, independentemente do resultado final do concurso material, o cumprimento das penas está limitado pelo art. 75 do CP em 30 anos de pena privativa de liberdade.

O art. 69, §§ 1.º e 2.º, regula a aplicação cumulativa de penas privativas de liberdade e restritivas de direito, bem como a execução de penas restritivas de direitos cumulativamente aplicadas. As penas restritivas de direitos podem ser cumuladas com a privativa de liberdade, quando esta for suspensa (*sursis* penal) ou quando elas forem compatíveis como na hipótese do regime inicial aberto, pois não impede o cumprimento da restritiva. Quando várias penas restritivas de direito forem aplicadas, serão cumpridas em concomitância com as compatíveis e sucessivamente as incompatíveis.

Concurso formal: previsto no art. 70 do CP, ocorre quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, ou seja, mediante conduta única, pratica dois ou mais crimes, idênticos (homogêneos) ou não (heterogêneos). A diferença entre o concurso formal e o concurso material está na quantidade de condutas; enquanto no concurso material há duas ou mais ações ou omissões, no concurso formal ela é única. É dividido em concurso formal próprio ou perfeito e concurso formal impróprio ou imperfeito. O concurso formal será próprio quando o agente: (a) praticar a ação ou omissão dolosa, com apenas um desígnio, ou seja, o agente não quer cada um dos crimes autonomamente, sua conduta é regida com unidade de desígnios, por exemplo: o agente entra em um ônibus com o dolo de roubar de todos os passageiros, anuncia o roubo e com uma única conduta subtrai os pertences de várias pessoas; (b) agindo com culpa, na conduta única, provoca dois ou mais crimes todos culposos, por exemplo, o agente que conduz seu veículo com excesso de velocidade e, por isso, atropela e mata várias pessoas, responde pelos vários homicídios culposos em concurso formal próprio; (c) agindo com dolo, na conduta única, provoca o crime doloso desejado e leva a outro resultado culposos, por exemplo, o agente que, com dolo de matar seu desafeto, corta os dutos que alimentam os freios do automóvel; com essa conduta acaba matando um possível carona do inimigo. No concurso formal

próprio ou perfeito, também conhecido como ideal, aplica-se a primeira parte do art. 70, que determina a incidência de somente uma das penas, se diferentes, a maior, exasperada de um sexto até a metade. Por força do art. 70, parágrafo único, essa operação de exasperação da pena não pode gerar pena superior à que seria cabível se fosse concurso material, e, se isso ocorre, prevalece a cumulação material benéfica.

O concurso formal será impróprio quando o agente tem dolo em todos os resultados, por exemplo, o agente que dolosamente quer matar o motorista e o carona e, para tanto, corta os cabos do freio, responde por dois homicídios dolosos em concurso formal impróprio. Há dolo na prática dos dois crimes, aproveitando-se de uma única ação ou omissão, mas com autonomia de desígnios. Nessas situações, a segunda parte do art. 70 determina a cumulação das penas, como se fosse concurso material.

Crime continuado: o art. 71 do CP dispõe que, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, idêntico ao concurso material, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, ocorre o crime continuado. Assim, não há como confundir o crime continuado com o concurso formal. Enquanto o concurso material e o crime continuado têm várias condutas acarretando vários crimes, o concurso formal, próprio ou impróprio, tem apenas uma conduta causando os vários crimes.

O primeiro requisito configurador do crime continuado é determinar o que se entende por crimes da mesma espécie. Há divergência doutrinária nesse ponto. A corrente majoritária, adotada inclusive na jurisprudência do STJ e do STF, define crimes da mesma espécie como aqueles previstos no mesmo tipo legal incriminador, por exemplo, as várias modalidades de furto previstas no art. 155 do CP – o furto simples, o furto privilegiado e o furto qualificado – são, para essa corrente, da mesma espécie.

Minoritariamente, mas com grande adesão, a doutrina entende como crimes da mesma espécie aqueles que protegem o mesmo bem jurídico. Logo, são considerados da mesma espécie o roubo e a extorsão, a corrupção passiva e o peculato, entre

outros, que pela primeira corrente não podem ser reputados como da mesma espécie e jamais poderiam ser praticados em continuidade delitiva. Além da mesma espécie para configurar a continuidade delitiva, é necessário demonstrar o nexo de continuidade, caracterizado pelas coincidências de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. O legislador não foi taxativo e o rol apresentado é alternativo, basta a presença de alguns elementos caracterizadores da continuidade. Nos crimes continuados a aplicação das penas segue o critério da exasperação. Dispõe o art. 71, *caput*, do CP que deve ser aplicada a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada de 1/6 a 2/3. O aumento deverá ser decidido de acordo com a quantidade de crimes praticados em continuidade. O STF vem adotando o seguinte critério: dois crimes = 1/6; três crimes = 1/5; quatro crimes = 1/4; cinco crimes = 1/3; seis crimes = 1/2; de sete crimes em diante = aumento de 2/3.

O art. 71, parágrafo único, do CP prevê o denominado crime continuado qualificado. Quando os crimes forem todos dolosos, praticados contra vítimas diversas, por meio de atos de violência ou grave ameaça, e os elementos subjetivos indicarem a necessidade de uma exasperação maior, o juiz poderá aplicar somente uma das penas, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, elevada de até três vezes. É importante lembrar que todos os requisitos apontados devem estar presentes, do contrário aplica-se o art. 71, *caput*. A inclusão dessa modalidade de crime continuado mais severa, no parágrafo único do art. 71, fez com que o STF deixasse de aplicar o Enunciado 605 da Súmula, reconhecendo a possibilidade de aplicar crime continuado em crimes contra a vida.

Pena de multa no concurso de crimes: o art. 72 do CP prevê que a pena de multa no concurso de crimes é aplicada distinta e integralmente. Independentemente da espécie de concurso de crimes, aplica-se cada multa e soma-se no final para saber o total que o condenado deve pagar.

Extinção da punibilidade no concurso de crimes: art. 119 do CP. A extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um isoladamente (em qualquer modalidade de concurso). Cada crime segue sua regra de extinção de punibilidade própria. Por exemplo, a prescrição, independentemente do concurso dos crimes, deve ser contada

em separado para cada crime.

1.64 EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

A punibilidade pode ser traduzida na pretensão de exercer ou executar o direito de punir concedido em abstrato ao Estado. O Estado é titular único do *ius puniendi* (direito de punir), e com a prática do crime surge a possibilidade de concretizar esse direito de punir. No entanto, essa possibilidade está limitada por circunstâncias que podem afastá-la, restringindo assim a pretensão punitiva estatal. Entre essas hipóteses estão as condições objetivas de punibilidade, circunstâncias posteriores ao crime que autorizam o exercício do direito de punir do estado; e as causas extintivas da punibilidade, circunstâncias posteriores ao crime que fulminam o direito de punir. Pode-se dizer que as primeiras acarretam seu nascimento, enquanto as segundas, sua morte.

São causas extintivas da punibilidade, previstas no art. 107 do CP:

- a) Morte: segundo o princípio da pessoalidade penal, a pena não ultrapassa a pessoa do condenado, assim a morte extingue a punibilidade, impedindo qualquer repercussão penal do fato. A morte, como todo estado civil das pessoas, é atestada com a certidão de óbito. Na hipótese de atestado de óbito falso, se a decisão que extinguiu a punibilidade ainda for recorrível, é possível desfazer a extinção por meio recursal. Quando a concessão da extinção de punibilidade estiver transitada em julgado, o STF entende que a certidão de óbito atesta um óbito que nunca existiu, acarretando a nulidade de todos os atos baseados nela, afastando-se, assim, a extinção da punibilidade. Nessas hipóteses, a doutrina vem defendendo pela impossibilidade de desfazer a decisão, afirmando que não há meio processual para isso, uma vez que não há revisão criminal em desfavor do condenado. Não sendo possível atacar a coisa julgada, o agente deve ser punido pela falsidade e nada mais, no entanto essa posição não prevalece.
- b) Anistia, graça e indulto: são hipóteses de perdão estatal. A anistia é o ato do

Poder Legislativo, por meio de lei ordinária, com controle de sanção ou veto pelo Executivo. Conforme arts. 21, XVII, e 48, VIII, da CR/1988, a anistia atinge os fatos e não as pessoas, por isso é causa extintiva da punibilidade de natureza objetiva e coletiva. A anistia, em regra, extingue todos os efeitos penais, voltando o agente à condição de primário, somente subsistindo os efeitos extrapenais da condenação. Não cabe ao réu ou condenado aceitá-la ou não, a anistia é irrecusável. A anistia pode ser geral ou plena quando favorece a todos os autores de determinados crimes, independentemente de requisitos pessoais; ou parcial ou restrita, caso em que favorece determinadas pessoas conforme requisitos específicos pessoais, como ser primárias.

A graça, também chamada de indulto individual, é ato do Presidente da República, conforme o art. 84, XII, da CR/1988, dirigindo-se a quaisquer crimes e normalmente concedida após a condenação transitada em julgado. Já o indulto, assim como a graça, é ato do Presidente da República, dirigindo-se a crimes, e não a pessoas, o indulto é coletivo, o que o diferencia da graça que é individual, e dirige-se a um grupo indeterminado de condenados, delimitado àqueles que preencham determinadas condições, como natureza do crime, quantidade de pena e outros definidos no diploma legal que o estabelecer.

A anistia, a graça e o indulto estão proibidos para os crimes hediondos e equiparados, conforme dispõe o art. 2.º, I, da Lei 8.072/1990, e o próprio art. 5.º, XLIII, da CR/1988.

- c) Retroatividade de lei que não mais considera o fato criminoso: *abolitio criminis* – já analisado na aplicação da lei penal no tempo, consiste em modalidade de *Lex mitior*, que retroage aos fatos anteriores por força da regra prevista no art. 5.º, XL, da CR/1988.
- d) Prescrição, decadência ou perempção: a prescrição será estudada em capítulo próprio. A decadência atinge, em matéria penal, o direito de queixa (ações

penais privadas) e o direito de representação (ações penais públicas condicionadas à representação). Em regra, o prazo de decadência é de seis meses a contar da data em que o agente soube quem era o autor do crime, trata-se de prazo de direito material; contam-se os meses pelo calendário comum, mas exclui-se o último dia do prazo. Ex.: em um crime de estupro, ação penal condicionada à representação, se a vítima soube quem era o autor no dia 10 de janeiro, o prazo para representar se encerra em 9 de julho. A perempção é regra processual, prevista no art. 60 do CPP, e ocorre somente na ação penal privada quando: (a) a vítima abandonar o processo por mais de 30 dias; (b) se falecer o querelante e em 60 dias nenhum legitimado comparecer para se habilitar no processo; (c) quando o querelante deixar de comparecer a qualquer ato do processo, que exija sua presença; (d) quando deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais; (e) quando o querelante for pessoa jurídica que se extinguiu sem deixar sucessores.

- e) Renúncia e perdão: a renúncia do direito de queixa é a manifestação de vontade de não exercer a ação penal privada, pode ser expressa ou tácita. A renúncia tácita consiste na prática de ato incompatível com a vontade de ver o agente punido. Ex.: convidá-lo para o casamento da filha ou para um jantar na casa. A renúncia em relação a um dos autores do crime alcança os demais, quando o crime foi cometido em concurso de pessoas, visto que a ação penal privada é indivisível. A renúncia pode se dar antes ou durante a propositura da ação penal, e é unilateral e irrevogável.

O perdão concedido pelo ofendido é bilateral, depende de aceitação do querelado e só pode ser concedido durante a ação penal, o que o diferencia da renúncia, que é anterior a ela. O perdão pode ser expresso ou tácito e pode ser concedido em qualquer fase, inclusive na fase recursal.

- f) Retratação: a retratação extingue a punibilidade somente nos casos em que a lei expressamente, a prevê como causa de extinção da punibilidade. Ex.: é o caso da calúnia e da difamação. Quando o agente se retrata antes da sentença, ocorre a extinção da punibilidade conforme o art. 143 do CP. Outro exemplo

é o falso testemunho ou falsa perícia (art. 342, § 2.º, do CP), que também pode ser objeto de retratação antes da sentença do processo em que ocorreu a falsidade. A retratação depende de previsão legal específica para extinguir a punibilidade, portanto não pode ser aplicada por analogia a crimes que não têm tal previsão.

- g) **Perdão judicial:** o perdão judicial é concedido pelo juiz, em casos previstos expressamente na legislação penal, ou seja, o juiz somente pode perdoar o acusado quando a lei o autorizar. Exemplos de previsão legal são: no homicídio culposo (art. 121, § 5.º, do CP) e nas lesões corporais culposas (art. 129, § 8.º, do CP); na injúria (art. 140, § 1.º); nos casos de réus colaboradores no art. 13 da Lei 9.807/1999, entre outros. O art. 120 do CP prevê que a sentença que concede o perdão judicial não gera reincidência, e o STJ na Súmula 18 reconhece que a sentença que concede o perdão judicial é meramente declaratória da extinção da punibilidade sem efeitos condenatórios.

1.65 PRESCRIÇÃO

Consiste no prazo que não pode ser ultrapassado pelo Estado na concretização da pretensão punitiva ou na efetivação da pretensão executória, ou seja, o Estado tem o direito de punir, e esse direito se concretiza com a prática do delito, mas não é eterno, há um lapso temporal para que o Estado consiga exercê-lo, do contrário estará extinta a punibilidade. A prescrição pode ser dividida inicialmente em prescrição da pretensão punitiva – PPP, que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, e a prescrição da pretensão executória – PPE, quando já houve o trânsito em julgado da condenação.

Prescrição da pretensão punitiva: a prescrição antes de transitar em julgado a sentença será regulada pela pena máxima em abstrato cominada para o crime, observadas as regras do art. 109, I a VI, do CP. Os mesmos prazos são utilizados nas penas restritivas de direitos. As causas de aumento de pena devem ser consideradas para o cálculo da prescrição, e esta é a posição jurisprudencial majoritária, com

exceção das causas referentes ao concurso de crimes, uma vez que, em caso de concurso, a extinção da punibilidade e a prescrição são analisadas para cada crime separadamente. Ex.: um crime de furto simples, previsto no *caput* do art. 155 do CP, que tem pena de reclusão de um a quatro anos, prescreve em oito anos, conforme art. 109, IV. No caso de furto simples com aumento de pena do repouso noturno, art. 155, § 1.º, a pena continua sendo reclusão de um a quatro anos, mas agora há uma causa de aumento de pena de 1/3, portanto a pena máxima para cálculo da prescrição é de quatro anos + 1/3, totalizando cinco anos e quatro meses; o prazo de prescrição passa a ser de 12 anos, art. 109, III, do CP.

Os prazos fixados por intermédio do art. 109, conforme prevê o art. 115, sofrem a redução de metade quando o criminoso era, ao tempo do crime (art. 4.º do CP), menor de 21 anos, ou quando, na data da sentença (primeira decisão condenatória), for maior de 70 anos. Tais idades não foram alteradas pelo Código Civil, que passou a considerar a menoridade de 18 anos, nem pelo Estatuto do Idoso, que passou a considerar idoso quem tem 60 anos.

É importante lembrar que, após a condenação com trânsito em julgado para a acusação, mas pendente de recursos exclusivos da defesa, como a pena fixada na sentença não pode mais ser majorada, pela proibição da *reformatio in pejus*, a prescrição da pretensão punitiva passa a ser calculada com a pena da sentença, a chamada pena concreta, e não mais com a pena máxima do tipo penal, conforme dispõe o art. 110, § 1.º, do CP.

Prescrição retroativa: a prescrição retroativa continua sendo hipótese de PPP, embora o prazo prescricional passe a ser apontado pela pena concretamente aplicada, como tratado na observação acima. São situações de trânsito em julgado parcial somente para a acusação, o que impede a majoração da pena e determina o cálculo do prazo com a pena em concreto. Dispõe o art. 110, § 1.º, que, nessas hipóteses, a prescrição não poderá ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa, concedendo caráter retroativo somente aos demais intervalos entre interrupções, como entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Ex.: no furto simples, art. 155, *caput*, a pena em abstrato máxima é de

reclusão de quatro anos, o prazo prescricional é de oito anos, conforme art. 109, IV, do CP. Suponha que entre a data da consumação e o recebimento da denúncia tenham transcorrido seis anos, já entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória mais cinco anos, evidentemente não houve prescrição. A condenação fixou pena concreta de um ano e seis meses para esse furto, a acusação ficou satisfeita e não recorreu, havendo apenas recurso defensivo. Nessa situação a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto (art. 110, § 1.º), e será de quatro anos, conforme o art. 109, V, e não mais de oito anos, como era com a pena máxima do tipo penal. Esta nova prescrição de quatro anos não pode retroagir à data anterior a do recebimento da denúncia, portanto o período de seis anos entre o crime e o recebimento da denúncia não pode ser considerado, mas pode ser aplicada entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, estando o crime prescrito, uma vez que esse intervalo foi de cinco anos, sendo superior aos quatro anos da prescrição.

Prescrição superveniente ou intercorrente: calculada com a pena em concreto aplicada na sentença condenatória, quando não há recurso da acusação, ou com a pena em abstrato do crime, quando há recurso das duas partes; ocorre entre a publicação da sentença condenatória e a data do julgamento definitivo (trânsito em julgado), nesse ínterim transcorre o prazo prescricional.

Prescrição da pretensão executória: prevista pelo art. 110, *caput*, do CP, consiste na perda da pretensão executória da pena, já fixada em sentença transitada em julgado, pelo decurso do tempo. O Estado, após obter o título condenatório definitivo, tem um prazo para conseguir executar a pena, o qual é denominado de prescrição da pretensão executória. É calculado com a pena fixada na sentença, utilizando-se a mesma regra do art. 109 do CP. Acarreta a extinção da pena, mas são mantidos os demais efeitos condenatórios, como a reincidência ou obrigações extrapenais. Esse prazo será aumentado de 1/3 quando o condenado for reincidente.

Termo inicial da prescrição da pretensão punitiva: o art. 111 do CP regula o termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final: I – do dia em que o crime se consumou, essa é a regra geral que terá algumas exceções nos

incisos seguintes; II – no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa, ou seja, da prática do último ato executório pelo agente; III – nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência, os crimes permanentes têm a consumação estendida enquanto permanecerem praticados; IV – nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido; V – nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal, incluído pela Lei 12.650/2012 como forma de proteger os menores vítimas de crimes sexuais.

A prescrição depois de transitada em julgado a sentença tem o prazo prescricional iniciado conforme dispõe o art. 112: I – do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II – do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Importante ressaltar que nessas hipóteses poderá incidir a regra prevista no art. 113 quando dispõe que, no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Causas interruptivas e suspensivas da prescrição: o art. 116 do CP, com o nome de causas impeditivas da prescrição, trata na verdade de causas suspensivas da prescrição, que são aquelas que, por certo período, suspendem o fluxo dos prazos e, quando desaparecem, permitem que volte a correr de onde havia parado. As causas suspensivas previstas no CP são: I – enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; II – enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro; Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Há outras causas interruptivas da prescrição previstas na legislação especial, por exemplo, a prescrição dos crimes de sonegação de tributos não corre enquanto há pagamento de parcelamento dos valores sonegados, conforme art. 83, § 2.º, da Lei

9.430/1996. A prescrição fica suspensa durante a suspensão condicional do processo (art. 89, § 6.º, da Lei 9.099/1995), entre outras hipóteses.

As causas interruptivas, diferentes das suspensivas, são acontecimentos instantâneos que causam o reinício do prazo prescricional, ou seja, o prazo integral é iniciado novamente, a partir da causa interruptiva. O art. 117 do CP apresenta as seguintes causas de interrupção da prescrição: I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II – pela pronúncia, exclusivamente no procedimento do júri; III – pela decisão confirmatória da pronúncia, exclusivamente no procedimento do júri; IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena, única situação em que o prazo será diferenciado, por força do disposto no art. 113 do CP; VI – pela reincidência.

Outros pontos:

- A prescrição da pena de multa está regulada no art. 114 do CP, que apresenta seguintes situações: I – em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; II – no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
- No caso de concurso de crimes a prescrição deverá ser calculada para cada um dos crimes isoladamente, não devendo levar em consideração o total da pena aplicável.
- A prescrição no concurso de crimes deve ser computada separadamente para cada um dos crimes, mesmo nos casos de concurso formal e crime continuado, quando a exasperação não deve ser levada em conta para o cálculo da prescrição.
- A prescrição penal é aplicável aos atos infracionais praticados por crianças e adolescentes.
- O prazo de prescrição é prazo penal, sua contagem é feita incluindo o dia do início e excluindo o dia do final. Ex.: um crime praticado em 10 de janeiro de 2010, que prescreva em 12 anos, estará prescrito em 9 de janeiro de

2022.

PROCESSO PENAL

Neste capítulo, a intenção é auxiliar o leitor com temas pertinentes para o exercício da advocacia durante seu nobre papel de defesa, em regra, no processo penal, e, ainda, auxiliar os candidatos a resolver exames e provas.

De forma objetiva e sistematizada, veremos neste capítulo:

I – Princípios constitucionais;

II – Panorama da persecução penal:

a) Investigação preliminar;

b) Ação penal.

III – Competência penal;

IV – Prisões e medidas cautelares;

V – Nulidades;

VI – A defesa no Processo Penal;

VII – A influência do Novo Código de Processo Civil na Prática Penal.

2.1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Artigo	Princípio – Garantia	Redação Legal
5.º, caput	Princípio da Igualdade, da Isonomia	Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à

		propriedade, nos termos seguintes:
5.º, III	Proibição de Penas Cruéis	Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
5.º, XI	Proteção à Casa	A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
5.º, XII	Proteção à Intimidade	É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
5.º, XXXIV	Direito de Petição	São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
5.º, XXXVII	Proibição a Tribunal de Exceção	Não haverá juízo ou tribunal de exceção;
		É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei,

5.º, XXXVIII	Tribunal do Júri	assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
5.º, XXXIX	Princípio da Reserva Legal	Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;
5.º, XL	Princípio da Irretroatividade da Lei Penal	A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
5.º, XLI	Punição à Discriminação	A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
5.º, XLII	Racismo	A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
5.º, XLIII	Crimes Inafiançáveis e Insuscetíveis de Determinadas Medidas	A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

5.º, XLIV	Ação de Grupos Armados	Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;
5.º, XLV	Princípio da Intranscendência Penal ou da Pessoaalidade	Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
5.º, XLVI	Princípio da Individualização da Pena	A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos;
5.º, XLVII	Restrição às Penas	Não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados;

		d) de banimento;
5.º, XLVIII	Estabelecimentos Distintos	e) cruéis; Pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
5.º, XLIX	Integridade Física do Preso	É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
5.º, L	Condição das Presidiárias	Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;
5.º, LIII	Princípio do Juiz Natural	Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
5.º, LIV	Princípio do Devido Processo Legal	Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
5.º, LV	Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório	Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
5.º, LVI	Princípio da Vedação das Provas Ilícitas	São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
	Princípio da Presunção	Ninguém será considerado culpado até o

5.º, LVII	de Inocência	trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
5.º, LVIII	Civilmente Identificado	O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei (Lei 12.037/2009);
5.º, LIX	Ação Penal Privada Subsidiária da Pública	Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;
5.º, LX	Princípio da Publicidade	A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;
5.º, LXI	Ordem Escrita e Fundamentada para Prisão	Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
5.º, LXII	Comunicação na Prisão	Prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;
5.º, LXIII	Informação de Direitos ao Preso	O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da

		família e de advogado;
5.º, LXIV	Identificação dos Responsáveis pela Prisão	O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;
5.º, LXV	Prisão Ilegal	A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
5.º, LXVI	Liberdade Provisória	Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;
5.º, LXVIII	Habeas Corpus	Conceder-se-á "habeas corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
5.º, LXXV	Erro Judiciário	O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
5.º, LXXVIII	Razoável Duração do Processo	A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

2.2 PANORAMA DA PERSECUÇÃO PENAL

Persecução Criminal é todo o caminho trilhado pelo Estado a fim de se apurar a autoria e a materialidade de um delito para que ao final seja prolatada uma sentença

penal justa.

Essa persecução pode ser dividida em duas fases bem delimitadas: a primeira é a investigativa e a segunda é a processual. Dizemos “pode”, pois a 1.^a fase é dispensável desde que tenhamos de antemão os indícios de autoria e a materialidade do crime, configurando prontamente a justa causa para a ação penal, que hoje é vista como condição da ação penal, positivada no inciso III do art. 395 do CPP. Como exemplo mais significativo da fase preliminar temos o Inquérito Policial (art. 4.^o e seguintes do CPP) presidido pelo Delegado de Polícia, todavia não podemos esquecer a possibilidade atual de investigação presidida pelo órgão do Ministério Público através dos Procedimentos Investigatórios Criminais (PIC), pois por ordem manifestamente constitucional (art. 144 da CF), a presidência do Inquérito Policial é do Delegado de Polícia.

2.2.1 Investigação preliminar

Nesta primeira fase, além do Inquérito Policial, que pode ser conceituado como o procedimento administrativo que tem por objetivo colher o maior número de informações possíveis para que o titular da ação penal possa ajuizá-la, temos também como exemplo as famosas Comissões Parlamentares de Inquérito, presididas pelos membros do Poder Legislativo, em suas respectivas Casas, que possuem o mesmo objetivo do Inquérito Policial, qual seja, obter o maior número de elementos para que sejam preenchidos os requisitos de materialidade e de indícios de autoria. Outra interessante fase de investigação preliminar são as intrigantes investigações de pessoas que ostentam determinados cargos públicos e que, por isso, são detentoras do denominado foro especial por prerrogativa de função (art. 84 do CPP). Essas pessoas terão as investigações presididas pelos respectivos foros competentes, foros privilegiados. Vale mencionar que a Lei 12.019/2009 permite a delegação dos Tribunais Superiores de atos de instrução.

Questão que nos leva a refletir é acerca da postura do advogado durante a fase preliminar. Teria uma atuação efetiva o criminalista nesse momento preliminar? Vejamos sua atuação e algumas novidades jurisprudenciais.

Durante a investigação, a função principal do advogado é proteger os direitos e garantias de seu cliente, ora indiciado, termo mais técnico para ser utilizado nesse momento, até porque acusado é o nome daquele que já está sendo processado. Eventuais arbitrariedades ou desrespeitos devem ser objeto de intervenção jurídica protetiva por parte do advogado. Ainda, eventuais medidas judiciais só são permitidas por quem tem capacidade postulatória, como os pedidos de relaxamento de prisão, liberdade provisória e revogação da prisão preventiva. Evidentemente que o *habeas corpus* também poderá ser impetrado, mas não existe a necessidade de isso ocorrer por meio de advogado, como todos nós sabemos.

Chamar o indiciado de mero espectador das investigações não seria uma heresia. Isso porque não se aplicam nesse momento princípios constitucionais importantíssimos durante a fase processual, tais como o princípio do devido processo legal (art. 5.º, LIV, da CF) o do contraditório e o da ampla defesa (art. 5.º, LV, da CF). Entenderemos melhor com as respectivas disposições legais e seus conceitos.

Princípio do devido processo legal:

Art. 5.º (...)

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

O princípio do devido processo legal consiste no respeito a todas as garantias que o acusado tem durante a fase processual da persecução criminal, ou seja, em sua 2.^a fase. Essa garantia é traduzida na solenidade exigida na ordem procedimental. O Estado Democrático de Direito exige que toda pessoa, por mais grave que tenha sido o crime cometido, tenha direito a um julgamento justo, sem surpresas e com todos os momentos processuais respeitados. Veremos adiante que os procedimentos, pelo menos os mais abrangentes, como o ordinário e o do júri, sofreram alterações significativas por meio das Leis 11.689/2008 e 11.719/2008, que fazem parte da chamada Reforma Processual de 2008.

Essa garantia traduz, outrossim, uma não surpresa por parte do acusado. Como diriam ilustres autores, trata-se do processo tipificado. Pois bem, desde o momento do oferecimento da ação penal, passando por seu recebimento e consequente citação,

o acusado sabe exatamente qual será o momento oportuno de arrolar testemunhas, de apresentar determinada prova e de externar sua versão quando do interrogatório.

Com este apertado conceito conseguimos entender o porquê de sua não aplicabilidade durante a fase investigativa. O Delegado de Polícia não é obrigado a seguir uma ordem preestabelecida pela legislação processual. O presidente do inquérito, o Delegado, portanto, tem total discricionariedade durante as investigações, conduzindo-as da forma que entende convenientemente melhor. Uma leitura despercebida pelo art. 6.º do CPP pode nos dar a impressão de que o Delegado é obrigado a seguir determinadas orientações. Vejamos o mencionado artigo:

Art.6.º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:

I – dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;

II – apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;

III – colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;

IV – ouvir o ofendido;

V – ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título VII, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura;

VI – proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações;

VII – determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias;

VIII – ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes;

IX – averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuam para a apreciação do seu temperamento e caráter.

X – colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

Talvez a melhor forma de leitura do artigo seja a substituição da palavra “deverá” no *caput* pela palavra “poderá”. Obrigar o delegado a seguir à risca o artigo *supra* é um resquício do autoritarismo penal que vigorava em 1941, que, convenhamos, não deixa saudades.

Seguindo a linha de atualizações, duas se fazem necessárias. Especificamente em relação ao inciso VIII do artigo em comento, vale observar a nova Lei de Identificação Datiloscópica (Lei 12.037/2009), que atualmente permite, no caso de imprescindibilidade da identificação, que a autoridade policial, a defesa e o Ministério Público requeiram ao juiz a providência de identificação.

Em segundo lugar, uma atualização mais recente acrescentando o inciso X no art. 6.º do CPP. Com o advento da Lei 13.257/2016, que claramente demonstrou um fraternalismo legislativo, houve uma proteção à primeira infância. Segundo a Lei 13.257/2016, primeira infância consiste em:

Art. 2.º Para os efeitos desta Lei, considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança.

Nitidamente, houve uma preocupação legal com o futuro dos dependentes dos personagens da investigação. Importante frisar que tal mandamento legal só terá efetividade real com políticas públicas governamentais no sentido de apoio e assistência.

Ainda sobre as possibilidades de diligências perpetradas pelo Delegado de Polícia e requerimentos feitos pelo Ministério Público na fase de investigação, observamos recente alteração legislativa no corpo do Diploma Processual Penal acerca da preocupação mundial com o repugnante crime de tráfico de pessoas. A Lei 13.344/2016 inovou, acrescentando ao Código de Processo Penal os seguintes dispositivos legais:

Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3.º do art. 158 e no art. 159 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 239 da Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conterá: (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

I – o nome da autoridade requisitante; (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

II – o número do inquérito policial; e (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

III – a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

Art. 13-B. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

§ 1.º Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

§ 2.º Na hipótese de que trata o caput, o sinal: (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

I – não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

II – deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 (trinta) dias, renovável por uma única vez, por igual período. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

III – para períodos superiores àquele de que trata o inciso II, será necessária a apresentação de ordem judicial. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

§ 3.º Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

§ 4.º Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 (doze) horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

Destaca-se a urgência da investigação. Num primeiro momento, para dados cadastrais de vítimas e suspeitos não se exige autorização judicial, todavia para sinais de localização a necessidade de manifestação jurisdicional é exigida com urgência, como salientamos acima. Caso o magistrado não se manifeste em até 12 horas (§ 4.º do art. 13-B do CPP), as informações devem ser enviadas diretamente a quem solicitou. Nesse ponto a legislação deu a devida importância à persecução penal destes crimes que assolam vários países, como o Brasil, onde as pessoas são objeto de tráfico para o turismo sexual, trabalho escravo e ainda para a doação de órgãos ilegais.

Além da não aplicabilidade do devido processo legal, não se faz presente

também, durante a fase inquisitorial de investigação, a aplicabilidade dos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5.º, LV, da CF), completando, assim, a tríade processual constitucional. Seguindo a mesma sistemática, vejamos os dispositivos de lei e seus respectivos comentários:

Art. 5.º (...)

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Contraditório é a possibilidade real e atual que o acusado tem de se manifestar em relação a algo que está sendo produzido no processo ou por algo que fora produzido anteriormente e que, pela natureza da informação, não houve possibilidade de manifestação.

Todo cuidado é pouco nesse momento. Contraditar significa ação e reação. Durante o inquérito ainda permanece a impossibilidade de não se manifestar em relação às informações colhidas em seara investigativa. Tudo aquilo que está sendo produzido durante as investigações servem para um único propósito: fundamentar a futura ação penal. Sustentamos, inclusive, a tese de que durante essa fase não são produzidas provas, e sim informações, pois prova penal é toda tentativa de se demonstrar a exatidão dos fatos sob o crivo do contraditório e, como não temos aplicação desse princípio na investigação, a melhor técnica jurídica exige a utilização do termo “informação”. Também é verdade que tudo aquilo que está sendo colhido em esfera investigativa deverá ser repetido em juízo para que seja submetido ao contraditório.

Em síntese, contraditório é a possibilidade real e atual de se manifestar em relação a algo que está sendo produzido processualmente. Assim, o que acontece com as informações colhidas em investigação preliminar e que não podem ser repetidas em juízo, tendo em vista sua natureza de irrepetibilidade? Por exemplo, uma eventual interceptação telefônica (Lei 9.296/1996) colhida em inquérito policial ou até mesmo um laudo pericial feito por meio de um exame de corpo de delito de um cadáver (art. 158 CPP) podem ser atacados? Contraditados? Questionados?

Por não termos ainda a possibilidade de contraditório durante o inquérito policial, tais informações serão levadas em juízo, juntamente com a futura ação penal e, no momento da Resposta do Acusado ou da Resposta à Acusação (art. 396-A do CPP), o agora acusado poderá contraditá-las. Entretanto, percebam que essa não é uma reação presente, trata-se de uma manifestação em relação a algo que fora produzido no passado, durante a investigação. Tal possibilidade que retrata uma junção do pretérito com o presente, ou seja, manifestação processual de algo que fora produzido na investigação, é chamada doutrinariamente de contraditório diferido, postergado ou retardado.

Esta é a postura traduzida pela característica de inquisitorialidade do Inquérito Policial. Mas devemos ficar atentos aos novos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais dos modernos processualistas penais.

Em decisão isolada e polêmica, na Medida Cautelar em *Habeas Corpus* 92.599-5/Bahia, proferida na mais alta corte desse país, o Ministro Gilmar Mendes, em voto, permitiu contraditório durante Inquérito Policial. Vejamos trecho do voto:

Com relação à argumentação expendida pelo acórdão recorrido no sentido de que o inquérito policial seria procedimento investigatório e inquisitorial não envolto pelo contraditório, é pertinente traçar algumas considerações.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (STF) tem assegurado a amplitude do direito de defesa mesmo que em sede de inquéritos policiais e/ou originários. Nesse particular, em especial no que concerne ao exercício do contraditório e ao acesso de dados e documentos já produzidos no âmbito das investigações criminais, destaco os seguintes julgados: (...)

Em idêntico sentido, registro ainda o julgamento do HC n.º 88.520/AP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, maioria, julgado em 23.11.2006, acórdão pendente de publicação), no qual, uma vez mais, o Plenário definiu novas amplitudes constitucionais com relação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (CF, art. 5.º, incisos LIV e LV). Da leitura dos precedentes colacionados, verifica-se que tais julgados respaldam a tendência interpretativa de garantir aos investigados e indiciados a máxima efetividade constitucional no que concerne à proteção dos direitos fundamentais mencionados (CF, art. 5.º, LIV e LV). Destarte, nos termos da jurisprudência colacionada, entendo não haver razão jurídica plausível para que a Corte Especial do STJ indefira pedido de juntada do laudo pericial requerida pela defesa do ora paciente.

Ressalvado melhor juízo quando da apreciação de mérito, constato a existência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada (*fumus boni juris* e *periculum in mora*).

Ante os fundamentos expostos, **de firo** o pedido de medida liminar para determinar a juntada dos

expedientes 00127270/2007 e 00126577/2007 aos autos do Inquérito no 544/BA, em trâmite perante o STJ. Nessa extensão do deferimento, o representante do Ministério Público Federal oficiante deverá ser oportunamente intimado da juntada da documentação referida.

Nesse mesmo voto, o Ministro Gilmar Mendes mencionou outros julgados, de lavra do Ministro Sepúlveda Pertence, que também merecem nosso destaque:

Inaplicabilidade da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa ao inquérito policial, que não é processo, porque não destinado a decidir litígio algum, ainda que na esfera administrativa; existência, não obstante, de direitos fundamentais do indiciado no curso do inquérito, entre os quais o de fazer-se assistir por advogado, o de não se incriminar e o de manter-se em silêncio.

2. Do plexo de direitos dos quais é titular o indiciado – interessado primário no procedimento administrativo do inquérito policial –, é corolário e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8906/94, art. 7.º, XIV), da qual – ao contrário do que previu em hipóteses assemelhadas – não se excluam os inquéritos que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do preceito legal resolve em favor da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesses do sigilo das investigações, de modo a fazer impertinente o apelo ao princípio da proporcionalidade.

3. A oponibilidade ao defensor constituído esvaziaria uma garantia constitucional do indiciado (CF, art. 5.º, LXIII), que lhe assegura, quando preso, e pelo menos lhe faculta, quando solto, a assistência técnica do advogado, que este não lhe poderá prestar se lhe é sonegado o acesso aos autos do inquérito sobre o objeto do qual haja o investigado de prestar declarações.

4. O direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9.296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em consequência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório.

5. *Habeas corpus* de ofício deferido, para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a consulta aos autos do inquérito policial e a obtenção de cópias pertinentes, com as ressalvas mencionadas. (HC 87.827/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, unânime, DJ 23.06.2006).

Tais julgados ainda não foram capazes de influenciar o legislador, que ainda mantém protegida a inquisitorialidade do inquérito policial. A recente Lei 13.245/2016, alterando o Estatuto dos Advogados do Brasil (EOAB – Lei 8.906/1994), acrescentou, nos direitos do advogado (art. 7.º), importante postura ao tema. Senão vejamos:

XXI – assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração.

Essa nova disposição legal ainda não autoriza o advogado a exercer o contraditório no inquérito. “Assistir” significa assessorar, dar conselhos, estar presente, acompanhar, proteger. A influência de investigações de alta repercussão, sem dúvidas, motivou o legislador. Em Comissões Parlamentares de Inquérito, é comum membros da Casa Legislativa e até mesmo a sociedade se incomodarem com a presença do advogado ao lado do investigado/depoente. Com esse novo regramento, essa é uma realidade. Impede-se, em conclusão, o exercício da defesa na fase de investigação que tem basicamente a função de assessoria, proteção e visualização de teses que deverão ser alegadas em juízo, caso a investigação se transforme numa futura ação penal.

Polêmica superada, devemos enfrentar outra questão durante a fase de investigação, relativa ao sigilo das investigações.

De um lado o art. 20 do CPP:

Art.20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.

De outro lado, tem-se o mandamento constitucional da publicidade de todos os atos. Vejamos disposição constitucional:

Art. 5.º (...)

LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

Assim, nos resta tentar aliar a publicidade com o sigilo, tendo em vista que algumas informações que poderão ser colhidas durante o inquérito só serão obtidas efetivamente com o segredo necessário. É o caso da interceptação telefônica (Lei 9.296/1996) ou até mesmo de uma busca e apreensão (art. 240 e seguintes do CPP).

Traduzindo essa problemática, o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2009, publicou a Súmula Vinculante 14:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Assim, a regra atual do sigilo do CPP de 1941 (art. 20) deve ser vista com ressalvas.

Melhorando ainda mais a regra sumulada e fortalecendo a advocacia criminal, a recente Lei 13.245/2016 alterou o inciso XIV do art. 7.º do Estatuto da OAB. Vejamos o dispositivo legal e em seguida os devidos comentários:

XIV – examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital.

A intenção do legislador foi, inegavelmente, explicar, elucidar e modernizar o entendimento já consolidado pela Súmula Vinculante 14, inclusive permitindo a possibilidade de copiar peças e tomar apontamentos em meio digital. Vale observar que continua sendo discricionariedade do presidente da investigação avaliar o que já está documentado, para análise do defensor e aquilo que ainda está em andamento, que, provavelmente, estará protegido pelo manto do sigilo.

Ainda no art. 5.º, LV, da CF, passemos a abordar outro princípio constitucional tão importante quanto o contraditório: a ampla defesa.

Poderíamos conceituá-la como a utilização de todos os meios e medidas defensivas fornecidas pelo Estado por meio da legislação. Esta se dividiria em defesa técnica, exercida pelo advogado ou defensor público (patronos da causa), e a autodefesa, desempenhada pelo próprio acusado.

Ao afirmarmos que a ampla defesa é irrenunciável no processo penal, temos que nos atentar para a vertente da autodefesa. Vejamos a possibilidade que o indiciado

e/ou acusado tem de permanecer em silêncio no momento do interrogatório.

Art. 5.º (...)

LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.

Art. 186 do CPP. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. (Redação dada pela Lei 10.792, de 1.º.12.2003)

Assim, a atuação da defesa técnica na fase investigativa fica limitada, tendo em vista a equiparação do indiciado a espectador das investigações. Nessa fase, o advogado atua na retaguarda, ou seja, adotando medidas judiciais que exigem capacidade postulatória, tais como relaxamento de prisão, liberdade provisória e revogação da prisão preventiva, como já dissemos, acompanhando seu cliente aos atos determinados pelo Delegado de Polícia, protegendo-o de eventuais desrespeitos individuais e, no mais, preparando a defesa para a futura ação penal, caso ela exista.

Questão intrigante que nos deixa perplexos é se a natureza jurídica do inquérito policial é procedimental administrativa. Por que não se aplica neste instante as garantias do contraditório e da ampla defesa como supostamente exige o legislador constitucional? Vamos reler o artigo:

Art. 5.º (...)

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Em primeiro lugar, processo administrativo não se confunde com procedimento administrativo.

Todavia, justificativa mais interessante está no objetivo do Inquérito Policial, que é de obter o maior número de informações possíveis relativas à materialidade do crime e aos indícios de autoria. Não se fala em penalizar em decorrência de Inquérito Policial. Assim, o mandamento constitucional se aplica tão somente a casos de processos administrativos que podem trazer uma eventual pena ao investigado. Inquérito é procedimento, frise-se.

Vejamos a seguinte jurisprudência, que traz essa afirmação:

Mandado de Segurança. 2. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Instauração de processo por quebra de decoro parlamentar contra deputado federal. Ampla defesa e contraditório. Licença médica. 3. As garantias constitucionais fundamentais em matéria de processo, judicial ou administrativo, estão destinadas a assegurar, em essência, a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal em sua totalidade, formal e material (art. 5.º, LIV e LV, da Constituição). 4. O processo administrativo-parlamentar por quebra de decoro parlamentar instaurado contra deputado federal encontra sua disciplina no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e no Regulamento do Conselho de Ética daquela Casa Legislativa, a partir do disposto nos incisos III e IV do art. 51 da Constituição, e se legitima perante o rol dos direitos e garantias fundamentais da Carta de 1988 quando seus dispositivos são fixados pela competente autoridade do Poder Legislativo e preveem ampla possibilidade de defesa e de contraditório, inclusive de natureza técnica, aos acusados. 5. Tal como ocorre no processo penal, no processo administrativo-parlamentar por quebra de decoro parlamentar o acompanhamento dos atos e termos do processo é função ordinária do profissional da advocacia, no exercício da representação do seu cliente, quanto atua no sentido de constituir espécie de defesa técnica. A ausência pessoal do acusado, salvo se a legislação aplicável à espécie assim expressamente o exigisse, não compromete o exercício daquela função pelo profissional da advocacia, razão pela qual neste fato não se caracteriza qualquer espécie de infração aos direitos processuais constitucionais da ampla defesa ou do contraditório. 6. Ordem indeferida (MS 25.917/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.06.2006).

Concluindo o panorama acerca da fase preliminar, não podemos nos esquecer de que algumas medidas durante o inquérito policial só podem ser autorizadas pelo juiz de direito, pois só ele tem competência para avaliar a perda de algumas garantias constitucionais, tais como a liberdade, perdida por meio da prisão, a intimidade, perdida através da interceptação telefônica, e a proteção à casa, ao domicílio, perdida mediante eventual medida de busca e apreensão. É o que chamamos de juiz de garantias, protetor este dos direitos fundamentais insculpidos na Constituição cidadã de 1988.

Determinadas diligências que geram perdas de garantias constitucionais devem obedecer a reserva de jurisdição. Só o juiz de direito competente poderá autorizá-las mediante representação, em geral, do Delegado de Polícia.

Encerrada a investigação, temos como possibilidade os seguintes encaminhamentos:

a) se for crime de Ação Penal Pública, os autos referentes às investigações deverão ser enviados ao Ministério Público (art. 129, I da CF), depois de minucioso relatório (art. 10, § 1.º, CPP) pelo presidente da investigação, delegado, para adotar uma das seguintes medidas:

- 1.^a – Ajuizar a Ação Penal;
- 2.^a – Requisitar novas diligências;

Art.16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

- 3.^a – Opinar pelo arquivamento.

Art.28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

- b) se for crime de Ação Penal Privada:

Art.19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado.

Vale ainda observar a Lei 12.830/2013 que trouxe uma nova roupagem à investigação criminal dando mais importância à atividade policial. Exige a lei em seu art. 3.º que a autoridade policial seja bacharel em Direito, devendo receber o mesmo tratamento protocolar dado a outras autoridades essenciais e exclusivas do Estado. Tal preocupação é real, pois em várias situações o Delegado de Polícia, por exemplo, quando é convocado para prestar depoimento em juízo, aguarda demasiadamente para ser ouvido enquanto suas funções de polícia ficam paralisadas. Esse seria um exemplo prático e real daqueles que interpretam a mudança tão somente com a necessidade de se dirigir ao Delegado como Excelentíssimo.

Outro ponto que merece destaque é a separação na própria lei de polícia judiciária e polícia investigativa. Preceitua o art. 2.º da lei essa divisão. Enquanto aquela é a polícia que auxilia os mandamentos do Poder Judiciário, na execução de mandados e escoltas ordenadas pelo Poder Judiciário, essa investigativa é a que coordena as diligências em busca dos indícios de autoria e materialidade.

Em conclusão, um dos atos mais importantes do inquérito policial, o indiciamento, com a nova lei em seu art. 2.º, § 6.º, deve ser fundamentado. Vejamos disposição legal:

Art. 2.º, § 6.º O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.

Evidencia-se, claramente, a magnitude da atividade policial com a Lei 12.830/2013, sem falar na importância de um bom inquérito policial ser aquele bem conduzido pela autoridade policial.

Observemos que a preocupação com princípios constitucionais durante a persecução penal e um fortalecimento dos direitos humanos em âmbito criminal cresce em cada reforma pontual na legislação. Senão vejamos a recente Lei 13.434/17, acrescentando o parágrafo único no art. 292 do Diploma Processual, que, associada à Súmula Vinculante 11, impede a utilização de algemas também em gestantes, por óbvio:

Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato.

2.2.2 Ação penal

Passemos agora a analisar a 2.^a Fase da Persecução Criminal, que é a fase processual, judicial, na qual serão vistas as modalidades de ação penal, seus requisitos e princípios.

Em um primeiro momento temos que dividir as ações penais em dois blocos. A

ação penal pública, que tem como peça inicial a denúncia, cuja titularidade é do órgão oficial estatal, Ministério Público, e, de outro lado, a ação penal privada, que tem como peça inicial a queixa-crime, cuja titularidade pertence ao ofendido, à vítima.

Acerca da titularidade do Ministério Público, vejamos artigo constitucional que demonstra essa possibilidade:

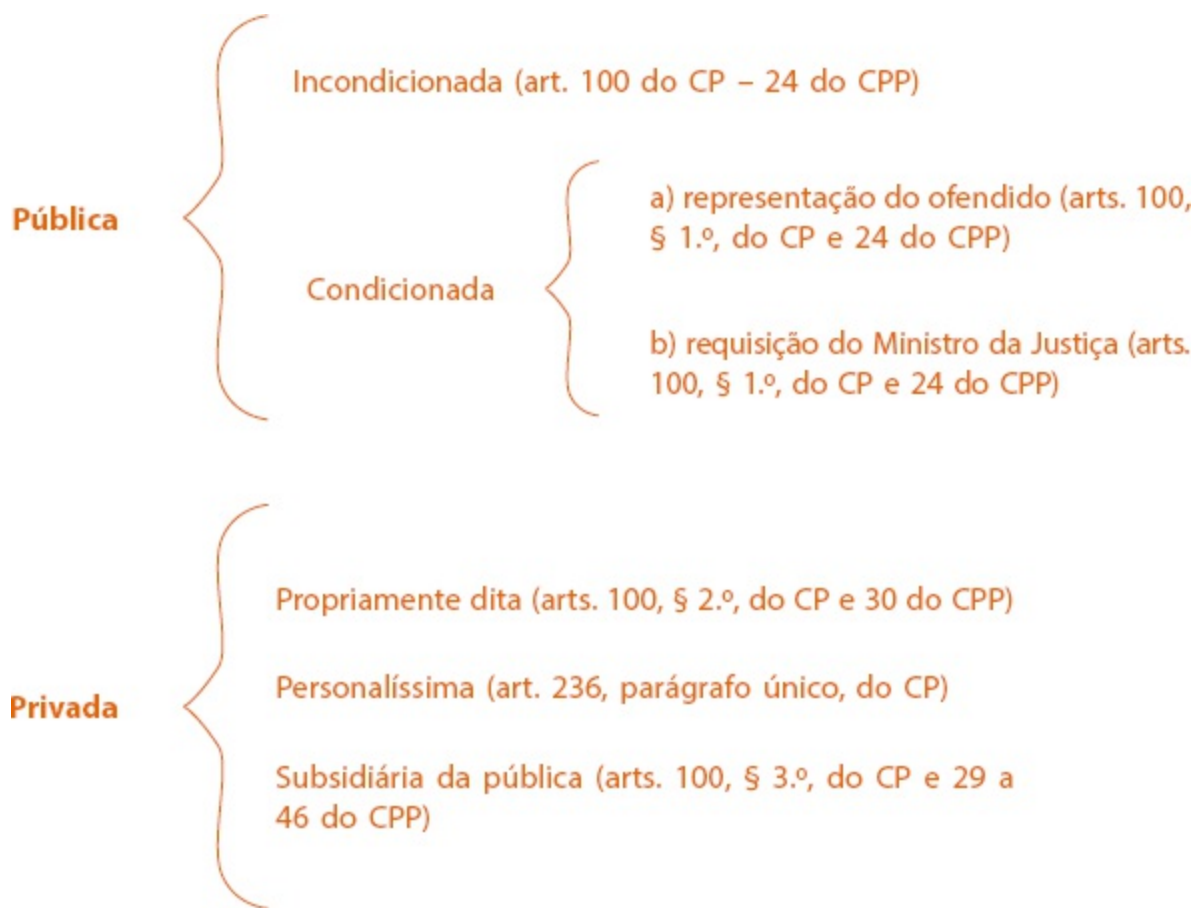
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

Já em relação à titularidade do particular, temos o disposto no art. 30 do CPP:

Art.30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada.

Pelo esquema a seguir ficará mais fácil verificarmos as modalidades de cada ação penal para, em seguida, tecermos algumas considerações a respeito.



Essa diferenciação tão somente acerca da titularidade da ação penal não é o bastante. É bem verdade que ela é pública quando ajuizada pelo Ministério Público e privada quando ajuizada pelo ofendido. Entretanto, aprofundemos para entender melhor o porquê dessa dupla possibilidade de ações penais.

O nosso legislador entendeu que, em casos graves, em que o ataque ao bem jurídico penalmente relevante é de alta monta, era necessário termos um órgão organizado, aparelhado, protegido, sem rosto e insuscetível de eventuais ameaças. Assim, foi dada a titularidade da ação penal pública ao Ministério Público, por também demonstrar um interesse do Estado na persecução criminal desses agentes que cometeram esses determinados crimes. Fazendo uma análise superficial, verificaremos que passíveis de ação penal pública são os crimes mais graves na legislação brasileira.

Do lado oposto, existem situações criminais em que o bem jurídico atacado é de esfera íntima da vítima, ou seja, a conveniência ou não de uma eventual propositura

de ação penal deve ser da própria vítima, avaliando ou não a viabilidade da esfera judicial. Note-se que nesse momento o interesse público estatal não é primordial, por isso a criação de raras e poucas hipóteses desse tipo de ação penal.

Sem delongas, por ser demasiadamente simples, como saber se determinado crime é de ação pública ou de ação penal privada? Nossa legislação penal especial e extravagante adotou uma postura cristalina. Quando não há disposição alguma no tipo penal referente à ação penal é porque ela é pública incondicionada. Se, ao revés, tiver disposições expressas no próprio artigo, ou ao final do capítulo, ou até mesmo em outras leis, faremos as devidas correspondências. Vejamos alguns exemplos:

I) Ação Penal Pública Incondicionada:

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.

Parágrafo único. A pena é duplicada:

Aumento de pena

I – se o crime é praticado por motivo egoístico;

II – se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência.

Receptação

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1.º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena – reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2.º Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

§ 3.º Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

§ 4.º A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

§ 5.º Na hipótese do § 3.º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2.º do art. 155.

§ 6.º Tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena prevista no caput deste artigo aplica-se em dobro.

II) Ação Penal Pública Condicionada à Representação. Percebam as recentes novidades das Leis 12.033/2009 e 12.015/2009.

Injúria Qualificada

Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

(...)

§ 3.º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Redação dada pela Lei 10.741, de 2003)

Pena – reclusão de um a três anos e multa.

(...)

Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2.º, da violência resulta lesão corporal.

Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3.º do art. 140 deste Código. (Redação dada pela Lei 12.033, de 2009).

Vale observar que, neste ponto de estudo, um famoso crime que era de ação penal pública condicionada à representação passou a ser de ação penal pública incondicionada. Estamos falando do estupro e dos demais crimes contra a liberdade sexual (arts. 213 a 218-C CP). Com o advento da Lei 13.718/2018, o legislador demonstra sua preocupação com o início da persecução penal e de sua obrigatoriedade, já que hoje independe da vontade da vítima.

III) Ação Penal Pública Condicionada a Requisição do Ministro da Justiça:

Crimes contra a Honra

Art. 141. As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

I – contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;

(...)

Art. 145. (...)

Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3.º do art. 140 deste Código. (Redação dada pela Lei 12.033, de 2009)

IV) Ação Penal Privada Propriamente Dita:

Crimes contra a Honra

Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2.º, da violência resulta lesão corporal.

V) Ação Penal Privada Personalíssima:

Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento

Art. 236. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento.

VI) Ação Penal Privada Subsidiária da Pública:

Esta será intentada quando o Ministério Público ficar inerte, não ajuizando a competente ação penal no prazo legal do art. 46 do CPP:

Art.46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

2.2.2.1 Requisitos, condições e pressupostos processuais

Antes de analisarmos algumas considerações individuais sobre as espécies de

ação penal, vejamos um quadro que nos traz as condições, requisitos e pressupostos processuais gerais das ações penais.

REQUISITOS (Arts. 41 a 44 do CPP)	CONDIÇÕES (Art. 395 do CPP)	PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
Exposição do Fato Criminoso + Qualificação do Acusado ou Características + Classificação do Crime + Rol de Testemunhas + Se for Ação Penal Privada, Procuração com Poderes Especiais	Legitimidade da Parte + Interesse de Agir + Possibilidade Jurídica do Pedido + Justa Causa	Existência: – Partes – Juiz Investido – Demanda Validade: – Juiz Competente – Imparcialidade – Capacidade dos Atos – Legitimidade Postulatória – Citação Válida

É importante registrar que somos adeptos de uma separação total e completa do Direito Processual Civil e que tais condições da ação penal vistas acima, apesar de serem colocadas pela doutrina majoritária, deveriam ser reanalisadas sob uma ótica processual penal. Por que não colocarmos como condição da ação penal a demonstração da prática de um fato aparentemente criminoso, como vê parte dos autores contemporâneos de processo penal?

2.2.2.2 Ação penal pública incondicionada

Passemos a tratar individualmente a denúncia (ação penal pública).

Vimos que a titularidade é do Ministério Público, confirmado pelos arts. 129, I, da CF, 24 do CPP e 100 do CP:

Art. 129 da CF. São funções institucionais do Ministério Público:

I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

Art. 24 do CPP. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

§ 1.º No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

§ 2.º Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal será pública.

Art. 100 do CP. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido.

§ 1.º A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.

§ 2.º A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo.

§ 3.º A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal.

§ 4.º No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Vigora na ação penal pública o princípio da obrigatoriedade, pela qual o titular da ação penal pública, o Ministério Público, a partir do conhecimento da autoria e da materialidade do delito e sendo o crime de ação penal pública, é obrigado ao ajuizamento da ação penal. E, ainda, deve-se respeitar o prazo do art. 46 do CPP:

Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

Além desse princípio, poderíamos destacar, ainda, o princípio da indisponibilidade, que impede o Ministério Público de desistir da ação penal. Vejamos o art. 42 do CPP:

Art. 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.

Filiamo-nos à posição do Supremo Tribunal Federal de que, na ação penal pública, não se aplica o princípio da indivisibilidade, até porque obviamente o titular da pretensão punitiva deverá ajuizar a ação penal contra todos os eventuais autores do delito, até então conhecidos. Não há necessidade de disposição expressa de tal princípio.

Registre-se que esses princípios são comuns a todas as modalidades de ação penal pública. Passemos agora a perceber as particularidades das ações penais públicas condicionadas.

2.2.2.3 Ação penal pública condicionada à representação

A primeira delas é a ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Dispomos *supra* de alguns exemplos atuais e renovados, tais como a Injúria Qualificada (art. 140, § 3.º c/c o art. 145, parágrafo único, do CP, alterado pela Lei 12.033/2009) e o Estupro na modalidade simples (art. 213 c/c art. 225 do CP, alterado pela Lei 12.015/2009).

A representação é uma simples manifestação de vontade, uma permissão para a atuação ministerial. Simples, sem formalidades. Sua natureza jurídica é de condição de procedibilidade, ou seja, para a atuação do órgão oficial o ofendido precisa representar, isto é, autorizar.

Art.39 do CPP. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.

§ 1.º A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida.

§ 2.º A representação conterà todas as informações que possam servir à apuração do fato e da

autoria.

§ 3.º Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito, ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for.

§ 4.º A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda a inquérito.

§ 5.º O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de quinze dias.

Precisamos tomar cuidado com a possibilidade ou não de retratação da representação. Vejamos o art. 25 do CPP, que não nos deixa qualquer tipo de dúvida.

Art. 25. A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia.

Não devemos confundir, também, oferecimento com recebimento da ação penal. Oferecimento é sinônimo de propositura da demanda, já recebimento significa análise judicial de cumprimento das condições da ação penal (legitimidade de parte, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido e justa causa). Antes, portanto, do oferecimento, o ofendido poderá retirar sua representação.

Não podemos deixar nesse instante de mencionar situação das mais interessantes que habitam as discussões jurídicas modernas: a nova regra de retratação da representação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 11.340/2006):

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

Para a mulher que deseja retirar a representação nos casos especiais de violência doméstica, a regra especial se faz necessária, ou seja, é marcada uma audiência para que o magistrado possa alertar a mulher sobre as consequências jurídicas de tal postura e também para que o juiz afira o motivo real dessa desistência. Sabemos que nesse campo da violência doméstica, é extremamente necessário protegemos cada vez mais a fragilidade da mulher, vítima desses bárbaros crimes que assolam milhares de lares brasileiros.

2.2.2.4 Ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça

Para fecharmos o estudo das ações penais públicas, resta-nos analisar a ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Basicamente, essa modalidade serve para proteger a soberania nacional e tal análise é feita pelo Ministro da Justiça. São raros esses casos na atual história brasileira, mas essa ação penal demonstra uma das preocupações legislativas com o Estado Brasileiro.

Vale salientar, ainda, que nem a representação do ofendido e muito menos a requisição do Ministro da Justiça vinculam o Ministério Público a ajuizar a competente ação penal. Tal discricionariedade é inerente à atuação do órgão oficial, pois lhe foi dada a titularidade da pretensão punitiva.

2.2.2.5 Ação penal privada

Nesta modalidade, tem legitimidade para ajuizamento da ação a vítima, representada no caso pela defesa técnica. Assim dispõem os seguintes artigos:

Art. 100 do CP. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido.

§ 1.º A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.

§ 2.º A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo.

§ 3.º A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal.

§ 4.º No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Art.30 do CPP. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada.

Inicialmente, o princípio que inaugura tal modalidade de ação penal é o da oportunidade, que permite ao ofendido analisar a conveniência e a oportunidade para

ajuizamento ou não ação penal privada. Tem, portanto, discricionariedade para a escolha da esfera judicial. Vale ressaltar que essa escolha tem durabilidade prefixada em lei e, por se tratar de um prazo decadencial, deve ser sumariamente respeitado. O art. 38 do CPP traz a exigência referida:

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

A atenção deve ser direcionada ao momento inicial, do conhecimento da autoria.

Antes mesmo da propositura da ação penal, vigora também o princípio da indivisibilidade, que tem como escopo colocar no polo passivo todos os eventuais autores da infração penal.

Art. 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade.

A indivisibilidade, aqui expressa, ordena que, uma vez escolhida a esfera judicial, a demanda obrigatoriamente deverá ser proposta contra todos os eventuais acusados, autores do delito.

Vigora, ainda, o princípio da disponibilidade, que permite que o autor da ação – querelante – desista da ação.

Tratar de ação penal privada sempre nos remete à possibilidade de desistência. Três institutos jurídicos nos trazem os meios judiciais de se desistir de uma queixa crime: a renúncia, o perdão e a perempção.

A renúncia é a desistência pré-processual:

Art. 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá.

O perdão retrata a desistência processual, bilateral e pessoal:

Art. 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia,

efeito em relação ao que o recusar.

Já a perempção poderia ser conceituada como uma “autodestruição”, uma verdadeira demonstração de falta de interesse da ação penal tendo em vista o descaso do polo ativo:

Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:

I – quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos;

II – quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36;

III – quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;

IV – quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.

Concluindo, vale frisar que nessas modalidades a substituição processual é possível, ou seja, no caso de morte, ausência, os substitutos processuais poderão prosseguir com a demanda. Vejamos quem são os substitutos processuais:

Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

§ 1.º No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Art. 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Seguindo adiante, veremos as modalidades individuais das respectivas ações penais privadas, tendo em vista que tudo que foi falado acima se aplica, desde já, a todas.

2.2.2.6 Ação penal privada personalíssima

Temos apenas um único exemplo de tal modalidade.

A diferença que reside entre esta ação e as demais modalidades privadas é que nesta não cabe a substituição processual, ou seja, no caso de morte ou ausência do autor da ação penal, ela não perdurará. Vejamos a única hipótese:

Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento

Art. 236. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento.

2.2.2.7 Ação penal privada subsidiária da pública

Com disposição constitucional, esta ação penal, também chamada de queixa supletiva ou queixa subsidiária, de certa maneira, nos intriga, pois, na prática, ela é dificilmente encontrada.

Art. 5.º (...)

LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

Conceituando-a, seria a possibilidade de fiscalização por parte do ofendido em relação à atuação ministerial. Caso aquele titular da ação penal pública por excelência não a ajuíze no prazo legal (art. 46 do CPP – 5 dias réu preso ou 15 dias réu solto), o ofendido poderá fazê-lo. Claramente visualizamos tal possibilidade no art. 29 do CPP a seguir transcrito:

Art. 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

Deixemos claro que, apesar do nome privada subsidiária da pública, esta ação penal continua com sua essência pública, visto que o Ministério Público poderá

retomar a titularidade a qualquer instante.

2.3 COMPETÊNCIA

Apresentemos o tema com a disposição legal referente:

Art. 69 do CPP. Determinará a competência jurisdicional:

I – o lugar da infração;

II – o domicílio ou residência do réu;

III – a natureza da infração;

IV – a distribuição;

V – a conexão ou continência;

VI – a prevenção;

VII – a prerrogativa de função.

Esse artigo, relativamente simples, nos traz um perigo na determinação da competência, importante tema para os futuros endereçamentos que veremos em capítulo específico.

A ordem colocada no referido art. 69 do CPP não nos ajuda na determinação da competência, pois ela não está constitucionalmente adequada. Assim iremos desenvolver uma metodologia para colocarmos os respectivos incisos em ordem, e assim obtermos uma maior tranquilidade na determinação da competência penal.

O inciso que colocaríamos em primeiro lugar, numa análise didática e preocupada tão somente numa determinação correta da competência, seria o inciso V:

V – a conexão ou continência;

Direto ao ponto, as regras de conexão e continência têm um único e só objetivo: nos casos de concurso de agentes e concurso de crimes, o primordial objetivo da competência penal é a reunião processual.

Essa regra citada é basilar para que encontremos corretamente o foro competente. As regras processuais referentes à conexão e continência estão dispostas a partir do art. 76 do CPP.

Evidentemente tal regra não é absoluta, trazendo inúmeras situações excepcionais

em que os processos deverão ser desmembrados, mas a tendência é a caminhada junta para se garantir uma maior economia processual e assegurar uma efetiva segurança jurídica em julgamentos unos, imparciais e simultâneos.

Um dos maiores enfrentamentos que vemos na atualidade quanto a unidade processual, envolvendo competências originárias nos tribunais superiores, é a regra insculpida na Súmula 704 do STF e a disposição do Pacto de San José da Costa Rica, referente ao duplo grau de jurisdição. Vejamos:

Súmula 704 do STF: Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados.

Vs.

Art. 8.º Pacto San José da Costa Rica – Garantias judiciais:

2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: (...)

h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior.

O que presenciamos em nossos tribunais atualmente é um verdadeiro caldeirão de opiniões conflitantes acerca do tema. Julgados que desmembram, outros não, gerando, assim, uma instabilidade natural.

Seguindo a análise do art. 69 do CPP, poderíamos afirmar que o inciso mais importante, constitucionalmente falando, é o último, por se tratar de uma competência constitucional, absoluta e especial:

VII – a prerrogativa de função.

O tema recentemente mereceu uma nova roupagem com a decisão proferida na Ação Penal 937 do Supremo Tribunal Federal, todavia, antes de adentrarmos nessa decisão, vejamos as razões de ainda termos no Brasil a garantia da prerrogativa de função.

Constitucional porque está na lei suprema do País, absoluta, pois esta competência não poderá ser prorrogada, evitar o deslocamento, e, especial, pois

somente se aplica a determinadas pessoas detentoras de determinados cargos públicos.

Prerrogativa de função traduz uma garantia, um privilégio para pessoas que ostentam determinados cargos públicos. A doutrina chama essa competência em razão da pessoa. Tal terminologia não traduz uma verdade, pois, como veremos, a garantia é do cargo exercido. Esse privilégio é configurado por meio do foro privilegiado, que seria a possibilidade de a persecução criminal iniciar-se em tribunais e até mesmo em tribunais superiores. Seria uma forma de proteção. Primeiro por serem as investigações e os processos presididos por pessoas, teoricamente, mais experientes na arte de conduzir uma investigação e julgar, e, em segundo lugar, mais protegidas das influências midiáticas que determinados casos podem exercer sobre o julgamento de um juiz de 1.^a instância. Sobre o tema, a recente Lei 12.019/2009 permite a delegação por parte de tribunais superiores de atos de instrução.

Vejamos respectiva disposição legal:

Art. 1.º Esta Lei acrescenta inciso III ao art. 3.º da Lei n.º 8.038, de 28 de maio de 1990, para permitir ao relator, nos processos penais de competência originária do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, delegar poderes instrutórios.

Art. 2.º O art. 3.º da Lei n.º 8.038, de 28 de maio de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 3.º ...

III – convocar desembargadores de Turmas Criminais dos Tribunais de Justiça ou dos Tribunais Regionais Federais, bem como juízes de varas criminais da Justiça dos Estados e da Justiça Federal, pelo prazo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até o máximo de 2 (dois) anos, para a realização do interrogatório e de outros atos da instrução, na sede do tribunal ou no local onde se deva produzir o ato”.

Quais seriam os cargos detentores desses foros privilegiados?

Em linhas gerais, poderíamos dizer que seriam os cargos públicos essenciais ao bom andamento de uma Democracia. Exemplificando, temos como foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal deputados e senadores federais, no Superior Tribunal de Justiça, governadores de Estado e, nos Tribunais de Justiça, os juízes estaduais de 1.º grau e promotores de justiça. Representantes, portanto, dos Poderes Executivo,

Legislativo e Judiciário.

Não poderíamos deixar de comentar o art. 84 do Diploma Processual Penal, referente ao tema:

Art. 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. (Redação dada pela Lei n.º 10.628, de 24.12.2002.)

§ 1.º A competência especial por prerrogativa de função, relativa a atos administrativos do agente, prevalece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da função pública. (Incluído pela Lei n.º 10.628, de 24.12.2002.) (Vide ADIN n.º 2797.)

§ 2.º A ação de improbidade, de que trata a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, será proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública, observado o disposto no § 1.º. (Incluído pela Lei n.º 10.628, de 24.12.2002.) (Vide ADIN n.º 2797.)

Impossível não nos surpreendermos com a Lei 10.628, datada, pasmem, de 24 de dezembro de 2002. Lei esta atualmente declarada inconstitucional para nossa felicidade, de efeitos concretos. Simples e absurdamente estendia o foro privilegiado para ex-ocupantes de cargos públicos e equiparava a improbidade administrativa a delito para efeitos de persecução e consequentemente perpetuação do foro privilegiado. No julgamento da ADIN 2797/DF estabeleceu-se que a data de 15 de setembro de 2005 é o termo inicial dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1.º e 2.º do art. 84 do CPP, preservando-se, assim, a validade dos atos processuais até então praticados e devendo as ações ainda não transitadas em julgado seguirem na instância adequada.

Nesse sentido que criticamos parte da doutrina que convencionou chamar competência “em razão da pessoa”, melhor seria em razão do cargo.

Transcrevemos parte da decisão que declarou os §§ 1.º e 2.º do art. 84 do CPP inconstitucionais, trazidos por meio do Informativo de Jurisprudência do STF, 362:

O Tribunal iniciou julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP e pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB contra os §§ 1.º e 2.º do art. 84 do Código de Processo Penal, inseridos pelo art. 1.º da Lei

10.628/2002. Alega-se ofensa aos artigos 2.º; 102, I; 105, I; 108, I, e 125, § 1.º, da CF. (...)

Em relação ao mérito, o Min. Sepúlveda Pertence, relator, julgou procedente o pedido de ambas as ações. Salientou que o § 1.º do art. 84 do CPP constitui reação legislativa ao cancelamento da Súmula 394, ocorrido no julgamento do Inq 687 QO/SP (*DJU* de 09.11.2001), cujos fundamentos a lei nova estaria a contrariar, e no qual se entendera que a tese sumulada não se refletiria na CF/88 (Enunciado 394 da Súmula: ‘Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício’). Asseverou ser improcedente a alegação de que o cancelamento da Súmula 394 se dera por inexistir, à época, previsão legal que a consagrasse, já que tanto a súmula quanto a decisão no Inq 687 QO/SP teriam derivado de interpretação direta e exclusiva da Constituição Federal. Declarou a inconstitucionalidade do § 1.º do art. 84 do CPP por considerar que o mesmo, além de ter feito interpretação autêntica da Carta Magna, o que seria reservado à norma de hierarquia constitucional, teria usurpado a competência do STF como guardião da Constituição Federal ao inverter a leitura por ele já feita de norma constitucional, o que, se admitido, implicaria sujeitar a interpretação constitucional do STF ao referendo do legislador ordinário. Declarou, também, a inconstitucionalidade do § 2.º do art. 84 do CPP. Disse que esse parágrafo veiculou duas regras: a que estende a competência especial por prerrogativa de função para inquérito e ação penais à ação de improbidade administrativa e a que manda aplicar, em relação à mesma ação de improbidade, a previsão do § 1.º do citado artigo. Esta última regra, segundo o relator, estaria atingida por arrastamento pela declaração de inconstitucionalidade já proferida. E a primeira implicaria declaração de competência originária não prevista no rol taxativo da Constituição Federal. Ressaltou que a ação de improbidade administrativa é de natureza civil, conforme se depreende do § 4.º do art. 37 da CF. (“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”) E que o STF jamais entendeu ser competente para o conhecimento de ações civis, por ato de ofício, ajuizadas contra as autoridades para cujo processo penal o seria. Salientou, ainda, que a Constituição Federal reservou às constituições estaduais, com exceção do disposto nos artigos 29, X e 96, III, a definição da competência dos seus tribunais (CF, art. 125, § 1.º), o que afastaria, por si só, a possibilidade da alteração dessa previsão por lei federal ordinária. Concluiu que o eventual acolhimento, no julgamento da Rcl 2138/DF, da tese de que a competência constitucional para julgar crimes de responsabilidade se estenderia às ações de improbidade, não prejudicaria nem seria prejudicado pela declaração de inconstitucionalidade do § 2.º do art. 84, já que a competência dos tribunais para julgar crimes de responsabilidade é bem mais restrita que aquela para julgar os crimes comuns. (...)

Entendeu-se que o § 1.º do art. 84 do CPP, além de ter feito interpretação autêntica da Carta Magna, o que seria reservado à norma de hierarquia constitucional, usurpou a competência do STF como guardião da Constituição Federal ao inverter a leitura por ele já feita de norma constitucional, o que, se admitido, implicaria submeter a interpretação constitucional do Supremo ao referendo do legislador ordinário. Considerando, ademais, que o § 2.º do art. 84 do CPP veiculou duas regras – a que estende, à ação de improbidade administrativa, a competência especial por prerrogativa de função para inquérito e ação penais e a que manda aplicar, em relação à mesma ação de improbidade, a previsão do § 1.º do citado artigo –, concluiu-se que a primeira resultaria na criação de nova hipótese de competência originária não

prevista no rol taxativo da Constituição Federal, e, a segunda estaria atingida por arrastamento. Ressaltou-se, ademais, que a ação de improbidade administrativa é de natureza civil, conforme se depreende do § 4.º do art. 37 da CF, e que o STF jamais entendeu ser competente para o conhecimento de ações civis, por ato de ofício, ajuizadas contra as autoridades para cujo processo penal o seria. Vencidos os Ministros Eros Grau, Gilmar Mendes e Ellen Gracie que afastavam o vício formal, ao fundamento de que o legislador pode atuar como intérprete da Constituição, discordando de decisão do Supremo, exclusivamente quando não se tratar de hipótese em que a Corte tenha decidido pela inconstitucionalidade de uma lei, em face de vício formal ou material, e que, afirmando a necessidade da manutenção da prerrogativa de foro mesmo depois de cessado o exercício da função pública, a natureza penal da ação de improbidade e a convivência impossível desta com uma ação penal correspondente, por crime de responsabilidade, ajuizadas perante instâncias judiciais distintas, julgavam parcialmente procedente o pedido formulado, para conferir aos artigos impugnados interpretação conforme no sentido de que: a) o agente político, mesmo afastado da função que atrai o foro por prerrogativa de função, deve ser processado e julgado perante esse foro, se acusado criminalmente por fato ligado ao exercício das funções inerentes ao cargo; b) o agente político não responde a ação de improbidade administrativa se sujeito a crime de responsabilidade pelo mesmo fato; c) os demais agentes públicos, em relação aos quais a improbidade não consubstancia crime de responsabilidade, respondem à ação de improbidade no foro definido por prerrogativa de função, desde que a ação de improbidade tenha por objeto ato funcional (ADI 2797/DF e ADI 2860/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 15.09.2005).

Alertemos, mais uma vez, que a Lei 8.038/1990, que regula os processos de competência originária dos tribunais superiores, alterado pela recente Lei 12.019/2009, permite que o relator delegue determinados atos da instrução a juízes de instâncias inferiores, tendo em vista estar mais perto dos acusados e por também em decorrência do exorbitante número de processos que chegam até os Tribunais Superiores. Vejamos tal disposição da Lei 8.038/1990, observando que já vimos a momentos atrás a alteração trazida pela Lei 12.019/2009, que retrata uma tendência de postura das mais altas cortes desse País:

Art. 9.º A instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal.

§ 1.º O relator poderá delegar a realização do interrogatório ou de outro ato da instrução ao juiz ou membro de tribunal com competência territorial no local de cumprimento da carta de ordem.

Em conclusão, o foro privilegiado, como vimos, era aplicado para o detentor de cargo público definido, em regra, na Constituição Federal no caso de cometimento de crime comum. Assim, investigação e processo tramitava sob a presidência do foro

privilegiado, o que ocasionava uma lentidão natural e uma sensação de impunidade em todos os jurisdicionados. Ainda, em caso de perda do cargo, perdia-se o foro, e ao se adquirir o cargo, adquiria-se o foro. Essa postura se transformou, ao longo dos anos, numa verdadeira manobra para ocasionar a lentidão persecutória.

Com isso, o Supremo Tribunal Federal, após algumas tentativas infrutíferas, via Ação Penal 937, deu novo tratamento à matéria. Para ser aplicado o foro privilegiado, o detentor de cargo público deve cometer o crime em razão da função e durante o mandato. E, na intenção clara de evitar manobras, uma vez da intimação de memoriais, mesmo com a perda do cargo, perpetua-se a competência originária, mantendo-se assim a regular velocidade do julgamento que vem a seguir a este momento processual. Esta importante decisão se deu em âmbito da mais alta corte do país e apenas mencionou os cargos de Deputado Federal e Senador. Somos da corrente de que tal decisão, em um verdadeiro efeito cascata, se aplica para os demais detentores de cargos públicos insculpidos em nossa CF/88 (arts. 29, X, 96, III, 102, 105 e 108).

Encerrada a análise do inciso do art. 69, vejamos o terceiro dispositivo em grau de importância constitucional. Trata-se do inciso III, configurando competência constitucional, absoluta e geral.

III – a natureza da infração;

Seguindo a mesma linha de motivos, constitucional por sua disposição, absoluta por não podermos deslocar tal competência, apenas havendo uma regra especial acima desta, e geral, por se tratar de uma competência aplicável a todos indiscriminadamente, eis a competência do inciso III, por natureza da infração.

Doutrinariamente chamada de competência em razão da matéria, vislumbramos as seguintes em âmbito constitucional:

- a) 5.º, XXXVIII, CF – Tribunal do Júri, que julga os crimes dolosos contra a vida;

Art. 5.º (...)

XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

- a) a plenitude de defesa;
- b) o sigilo das votações;
- c) a soberania dos veredictos;
- d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

b) 109, CF – Justiça Federal, que julga os crimes de âmbito federal, muito exigida, diga-se de passagem, em exames de 2.^a fase;

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

II – as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;

III – as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V – os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

V-A – as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5.º deste artigo;

VI – os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;

VII – os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII – os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

IX – os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;

X – os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o “exequatur”, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;

XI – a disputa sobre direitos indígenas.

§ 1.º As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.

§ 2.º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

§ 3.º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4.º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

§ 5.º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Atualização moderna e considerável referente à competência da Justiça Federal diz respeito ao terrorismo. Apenas em 2016, com o advento da Lei 13.260/2016, o legislador infraconstitucional definiu o que seria o crime de terrorismo, pois a Constituição Federal, desde 1988, no art. 5.º, XLIII, já abordava esse assunto.

Assim, se definido:

Art. 2.º O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.

Sobre o tema de competência, o art. 11 nos esclarece o órgão competente, além de atribuições investigativas. Vejamos:

Art. 11. Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta Lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal, em sede de inquérito policial, e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento, nos termos do inciso IV do art. 109 da Constituição Federal.

Sabemos, ainda, que o tema de competência é extremamente delicado, todavia não podemos deixar de ilustrar um julgado interessantíssimo e atual que consagrou a competência da Justiça Federal para o julgamento do crime de pedofilia. Vejamos a introdução da ementa do RE 628624/MG do STF:

Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir

material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (ECA, arts. 241, 241-A e 241-B), quando praticados por meio da rede mundial de computadores. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, negou provimento a recurso extraordinário em que se discutia a competência processual para julgamento de tais crimes. O Tribunal entendeu que a competência da Justiça Federal decorreria da incidência do art. 109, V, da CF.

c) 98, I, CF – Juizados Especiais Criminais, que julgam os chamados crimes de menor potencial ofensivo;

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

Art. 61, Lei 9.099/1995. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Uma alteração óbvia recente foi a inserção do princípio da simplicidade dentre os já conhecidos oralidade, informalidade, economia processual e celeridade como princípio norteador da persecução penal por meio do procedimento sumaríssimo do Juizado Especial Criminal. Vejamos nova redação dada pela Lei 13.603/18:

Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.

d) 118, CF – Justiça Eleitoral, que julga os crimes eleitorais;

Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral:

I – o Tribunal Superior Eleitoral;

II – os Tribunais Regionais Eleitorais;

III – os Juízes Eleitorais;

IV – as Juntas Eleitorais.

E, finalizando nossa organização do art. 69 do CPP, em quarta e última posição, a competência em razão do local, colocados conjugados nos incisos I e II:

I – o lugar da infração:

II – o domicílio ou residência do réu;

Hipóteses estas de competências infraconstitucionais, relativas e gerais. Um, por estarem em âmbito ordinário; segundo, por ser possível a sua prorrogação, ou seja, seu deslocamento; e ainda gerais, por serem aplicadas as regras a todos.

Os demais artigos para efeitos de determinação de uma correta competência serão conjuntamente vistos numa análise objetiva e sistemática.

Ordem	Artigo	Competência em razão	Objetivo	Característica
1.º	Art. 69, inc. V	Conexão ou Continência	Reunião processual nos casos de concursos de agentes e de crimes	Regra Geral em nome da economia processual e segurança jurídica
2.º	Art. 69, inc. VII	Prerrogativa de Função	Foro Privilegiado	Constitucional, Absoluta, Especial
3.º	Art. 69, inc. III	Natureza da Infração	Justiça Especializada	Constitucional, Absoluta, Geral
4.º	Art. 69, incs. I, II	Local	Justiça Comum	Infraconstitucional, Relativa, Geral
5.º	Art. 69, incs. IV, VI	Distribuição e Prevenção	Residuais	Residuais

Organizado o art. 69 poderíamos definir a competência da seguinte forma:

Em primeiro lugar indagar acerca da existência ou não de concurso de agentes e concurso de crimes, pois existindo, a tendência é partirmos do pressuposto de que eles serão julgados conjuntamente. Tendência não significa ser uma regra absoluta, pois atualmente o que vemos, principalmente quando do envolvimento de concurso de pessoas e detentores de foro privilegiado, é a cisão processual. Modernamente, a alta corte do País vem prestigiando, para aqueles que não possuem prerrogativa de função, o respeito ao duplo grau de jurisdição consagrado no Pacto de San José da Costa Rica.

Vejamos o art. 8.º, 2, alínea “h”:

h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior.

Em segundo lugar aferir a existência de alguma competência constitucional, pois esta prevalece sobre a infraconstitucional. Nesse momento devemos verificar a existência de competências por prerrogativa de função e competências constitucionais em razão da natureza da infração (Júri, Federal, Juizado Especial Criminal, Justiça Eleitoral e Justiça Militar).

Em terceiro lugar havendo duas ou mais competências constitucionais, prevalecer a competência constitucional especial (prerrogativa de função) em detrimento da competência constitucional geral (natureza da infração).

Exemplos de objetivo serão comentados neste instante, encerrando assim o presente capítulo, para que consigamos visualizar toda a sistemática de aferição da competência sugerida.

1.º exemplo: imaginemos um Senador do Estado da Bahia acusado por um crime de estelionato (art. 171 do CP) no Rio Grande do Sul.

Temos concurso de crimes e concurso de pessoas? Não.

Competência constitucional? Sim, a prerrogativa de função do Senador que traz o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal (art. 53, § 1.º, CF).

Existe mais de uma competência constitucional? Não, apenas a vista

anteriormente.

Portanto, a resposta correta seria o Supremo Tribunal Federal; todavia, com a decisão da AP 937/STF, só será do Supremo a competência se o crime foi durante o mandato e em razão da função. Em caso negativo, primeira instância como qualquer cidadão.

2.º exemplo: imaginemos um Promotor de Justiça de São Paulo que comete um crime de homicídio (art. 121 do CP) no interior do Estado em relação a outro promotor em razão do cargo que ambos exercem.

Temos concurso de crimes e concurso de pessoas? Não.

Competência constitucional? Sim, duas. A prerrogativa de função do Promotor de Justiça que tem foro privilegiado no Tribunal de Justiça de São Paulo (art. 96, III, da CF) e o crime de homicídio cuja competência constitucional é do Tribunal do Júri.

Existe mais de uma competência constitucional? Sim, portanto a especial prevalece sobre a geral.

Nesse caso deixamos claro que o crime se deu em razão da função.

2.4 PRISÕES E MEDIDAS CAUTELARES

2.4.1 Introdução e a reforma da Lei 12.403/2011

“A regra é a liberdade, a exceção é a prisão”, com este dogma constitucional iniciamos o polêmico tema acerca das prisões no Processo Penal brasileiro. A força das palavras deste pilar constitucional é a sustentação de todo e qualquer estudo que se faça do tema na seara penal, todavia a cultura e muitas convicções prematuras dificultam sua aplicabilidade prática, isso sem falar em resquícios do autoritarismo de 1941, ano de nossa legislação, que ressurgue cada vez mais nos dias atuais. Deixando de lado questionamentos acerca da efetividade da prisão, analisaremos a seguir os aspectos práticos do tema, por ser o objetivo desta obra.

Inicialmente a divisão entre prisões cautelares e prisões pena é de necessária diferenciação:



Prisão cautelar	Prisão pena
• Anterior ao trânsito em julgado • Durante a investigação e/ou processo penal • Sob a égide do princípio constitucional da não culpabilidade • Com objetivo de assegurar o bom andamento da persecução penal, de protegê-la • Modalidades: prisão em flagrante (medida pré-cautelar), prisão temporária e prisão preventiva.	• Efeito de condenação à pena privativa de liberdade • Após o trânsito em julgado da decisão penal à uma pena privativa de liberdade • Estado exercendo o direito de punir ("ius puniendi"). • Figura do condenado

É de se registrar também o advento da Lei 12.403/2011, que por sua vez possui os seguintes objetivos com suas alterações já incorporadas no CPP:

a) Alteração do contexto carcerário no Brasil:

Pesquisas realizadas ao longo dos anos pelos mais diversos órgãos oficiais, como o conselho nacional de justiça, constataam que a prisão cautelar hoje representa quase 45% do total da população carcerária brasileira. Isto significa que milhares de pessoas estão encarceradas sem uma manifestação jurisdicional definitiva. Além disso, este índice mostra o que todos já sabíamos, que a prisão cautelar é utilizada atualmente como uma antecipação da pena. A Lei 12.403/11 não tem a pretensão de resolver integralmente os problemas do sistema penitenciário brasileiro, entretanto quer iniciar uma mudança, começando com a diminuição das prisões não definitivas.

b) Proporcionalidade:

Em várias situações a resposta estatal não condiz com o crime a ser investigado e

apurado, é o que constatamos com algumas prisões cautelares em relação a crimes que não possuem como pena a privação da liberdade. Isso demonstra uma falta de harmonização legislativa tremenda em nosso código. Sendo assim, tal impedimento foi trazido com a Lei 12.403/2011 e ainda o princípio da proporcionalidade recebe tratamento legal, no que diz respeito à necessidade e adequação de alguma medida adotada durante a persecução penal. Vejamos os arts. 282 e 283, § 1.º, do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a:

I – Necessidade para aplicação da Lei Penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II – Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Art. 283, § 1.º As medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade.

c) Constitucionalização da legislação infraconstitucional:

Ideal seria ter uma legislação codificada integralmente em sintonia com nossa Carta Magna, todavia, enquanto isso não acontece, com projeto de lei de um novo código estacionado no congresso nacional, as leis pontuais vão, aos poucos, inserindo dispositivos constitucionais na legislação ordinária. A este fenômeno dá-se o nome de constitucionalização.

Com a Lei 12.403/2011 isso não foi diferente. Vejamos exemplos de garantias constitucionais que se repetem integralmente em nossa legislação na tentativa de solidificar ainda mais a Carta Magna de 1988:

Art. 283 do CPP. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude

Art. 5.º, LXI, da CF – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em

de prisão temporária ou prisão preventiva.	lei;
Art. 306 do CPP. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao ministério público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. § 1.º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. § 2.º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.	Art. 5.º, LXII, da CF – a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; Art. 5.º, LXIII, da CF – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

d) Aproximação com a prática/realidade:

Interessante postura do legislador em se aproximar do cotidiano. A evolução ainda precisa ser maior, todavia artigos como a possibilidade de retenção do passaporte (art. 320 do CPP) e as possibilidades que o juiz tem ao receber o auto de prisão em flagrante para aferir sua legalidade (art. 310 do CPP) são demonstrações de que o caminho está sendo percorrido, todavia com lentidão. As chamadas audiências de custódia, ao que tudo indica, fazem parte desta evolução normativa.

e) Inovações naturais:

As leis são produzidas para inovar no mundo jurídico, e evidente isso não passou despercebido com a Lei 12.403/2011.

Os destaques são em três inovações. Senão vejamos:

e.1) Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)

Como verdadeiras alternativas à medida de prisão, a intenção do legislador é aplicá-las isolada ou cumulativamente antes de se decidir pela prisão propriamente dita. A tentativa é diminuir os altos índices de prisões desnecessárias e autoritárias criando alternativas ao encarceramento. Frise-se que tais medidas não querem impedir condenações, mas apenas criar uma alternativa durante a persecução penal.

Vejamos quais são elas:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I – Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II – Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III – Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV – Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V – Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI – Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII – Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII – Fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX – Monitoração eletrônica.

e.2) Prisão domiciliar

Como substituição à prisão preventiva, os arts. 317 e 318 do CPP trouxeram tal possibilidade em casos extremamente específicos.

Merece todo o cuidado do operador do direito a natural confusão que pode ocorrer entre prisão domiciliar, regime domiciliar e recolhimento domiciliar. Nosso legislador traz diferenças significativas que merecem todo nosso cuidado com a análise que será feita a seguir de forma esquematizada:

Prisão domiciliar	Recolhimento domiciliar	Regime domiciliar
Arts. 317-318 do CPP	Art. 319, V, do CPP	Art. 117 da Lei 7.210/1984 – LEP
Substitutiva da prisão preventiva em casos específicos	Medida cautelar diversa da prisão	Modalidade de cumprimento de pena
Possível nos seguintes casos: I – Maior de 80 (oitenta) anos; II – Extremamente debilitado por motivo de doença grave; III – Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV – gestante; V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de	Possível nos seguintes casos: No período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado	Possível nos seguintes casos: Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – Condenado maior de 70 (setenta) anos;

idade incompletos; VI – homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. * Inciso IV alterado pela Lei 13.257/2016. ** Incisos V e VI acrescentados pela Lei 13.257/2016.	tenha residência e trabalho fixos;	II – Condenado acometido de doença grave; III – Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – Condenada gestante.
--	------------------------------------	--

Sobre o tema, inspirado na decisão do HC coletivo 143.641 da 2.^a Turma do Supremo Tribunal Federal, o legislador produziu a Lei 13.769/2018, criando exceções para a concessão de prisão domiciliar para as mulheres gestantes e com filhos de até 12 anos incompletos que estejam presas preventivamente. Importante a colação:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei 13.769, de 2018).

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei 13.769, de 2018).

II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei 13.769, de 2018).

e.3) Fiança

A primeira inovação é sobre a possibilidade de o delegado de polícia arbitrar a

fiança em determinados crimes, desde que não se ultrapasse a pena máxima em abstrato em quatro anos conforme art. 322 do CPP. Caso isso ocorra, tão somente o magistrado poderá arbitrá-la no prazo de 48 horas (parágrafo único do mesmo dispositivo legal).

No mais, no art. 323 temos as impossibilidades de se arbitrar a fiança, inclusive algumas proibições já conhecidas na Constituição, como é o caso do crime de racismo (art. 5.º, XLII, da CF e inciso I do art. 323 do CPP).

Curiosa postura é a do art. 337, que transcrevemos integralmente pela sua inovação:

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.

Registrando a alteração trazida pela Lei 13.434/2017 que veda o uso de algemas em mulheres grávidas. Vejamos:

Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas.

Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. (Redação dada pela Lei 13.434, de 2017)

2.4.2 Quadro de modalidades de prisão cautelar

Prisão em flagrante	Prisão temporária	Prisão preventiva	Prisão domiciliar
Art. 301 e seguintes do CPP	Lei 7.960/1989	Art. 311 e seguintes do CPP	Arts. 317 e 318 do CPP
Modalidades:	Particularidades:		

Art. 301, 1. ^a Parte: Facultativo	1) Somente durante Inquérito Policial	Requisitos (Art. 312 do CPP):	
Art. 301, 2. ^a Parte: Obrigatório ou Compulsório	2) Crimes do art. 1. ^o , inc. III e hediondos (8.072/1990)	– Garantia da ordem pública	
Art. 302, I, II – Próprio, Perfeito ou Real	3) Prazo certo e determinado. Art. 2. ^o , 7.960/1989 – 5 dias prorrogáveis por igual período ou art. 2. ^o , § 4. ^o , 8.072/1990 – 30 dias prorrogáveis por igual período	– Garantia da ordem econômica	Consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo nela ausentar-se com autorização judicial.
Art. 302, III – Irreal, Impróprio ou Imperfeito		– Assegurar a aplicação da lei penal	
Art. 302, IV – presumido ou ficto		– Conveniência da instrução criminal	
Situações:		– Indícios de autoria	
Preparado (Súm. 145 STF) – ilegal	4) Mandado de prisão serve como nota de culpa	– Materialidade do fato	
Forjado – ilegal		*2 Últimos obrigatórios conjugados com os demais	
Esperado – legal	5) Independe de alvará de soltura		
Retardado ou diferido – legal			
	Legitimados:	Legitimados: Delegado de polícia Ministério público	Hipóteses: - Maior de 80 anos; – Extremamente debilitado por

Art. 304 do CPP – Recibo de Entrega Art. 306 – Obrigações do Delegado de Polícia após a lavratura do APF – Retrato Fiel dos incisos LXII, LXIII, LXIV do art. 5.º da CF	Delegado de polícia	Querelante	motivo de doença grave;
	Ministério Público	Assistente	– Imprescindível
	Requisitos (art. 1.º da Lei 7.960/1989):	Juiz de ofício, durante a ação penal somente.	aos cuidados especiais de menor de 6 anos de idade ou com deficiência;
	I+III ou II+III ou I+II+III	Art. 313: I – apenas para crimes dolosos com pena superior a 4 anos.	– gestante;
	Momentos (art.1.º, inc. I da Lei 7.960/1989):	Demais casos na lei.	– mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
	Somente durante o inquérito policial	Momentos (art. 311 do CPP):	– homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
		Durante o inquérito policial e a ação penal	

2.4.3 Prisão em flagrante

Considerada hoje uma medida pré-cautelares, a ainda chamada prisão em flagrante é, sem sombra de dúvidas, a mais conhecida dentro do tema.

Dividida em quatro momentos – captura, condução, lavratura do auto de prisão em flagrante e recolhimento –, esta prisão tem por objetivo primordial impedir a consumação do crime.

São hipóteses de prisão em flagrante:

- a) Facultativo (art. 301, 1.ª parte, do CPP) – Quando qualquer pessoa do povo

poderá prender.

- b) Obrigatório ou compulsório (art. 301, 2.^a parte, do CPP) – Quando a autoridade policial e seus agentes devem prender.
- c) Próprio, real ou perfeito (art. 302, incs. I-II, do CPP) – Quando o agente está cometendo ou acaba de cometê-la. Esse seria o flagrante em sua essência.
- d) Impróprio, irreal ou imperfeito (art. 302, inc. III, do CPP) – Nos casos de perseguição ininterrupta, também conhecida esta hipótese como quase flagrante.
- e) Presumido ou ficto (art. 302, inc. IV, do CPP) – Nos casos em que o agente é encontrado logo depois com instrumentos do crime que fazem presumir ser o autor da infração.

E ainda as famosas situações de flagrância, objeto de inúmeras questões em provas e exames.

- f) Preparado – Situação em que se encontra a figura do agente provocador. Uma verdadeira instigação e mecanismos de incentivo são utilizados para que se efetue a prisão. Esta conduta se reveste de ilegalidade, conforme Súmula 145 STF (não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.), impedindo logicamente a formalização da prisão. Caso esta ocorra, cabe relaxamento de prisão, tendo em vista sua gritante impossibilidade.
- g) Forjado – Situação arrepiante de criação, de materialização de situação criminosa inexistente. Forjar significa inventar. Nesta horripilante situação, o agente com intuito maldoso cria situação com o objetivo de forjar uma situação flagrancial.
- h) Esperado – Situação de legalidade com a marca registrada da inteligência por parte de seus executores. Com a devida paciência e estratégia, os responsáveis pela futura prisão esperam, sem nenhum tipo de influência, o início do cometimento do crime. Percebendo-se essa situação, os executores da prisão agem rapidamente e são brindados com a legalidade da prisão.

- i) Retardado ou diferido ou postergado – Embrionária em nosso Estado Democrático de Direito, essa situação excepcional e cinematográfica traduz a possibilidade de determinado policial se infiltrar em certa organização criminosa com o intuito de desmembrá-la. O policial disfarçado agirá sorrateiramente dentro da legalidade. Atualmente, só duas leis permitem o flagrante retardado. São elas: a Lei de Drogas (art. 53, I, da Lei 11.343/2006) e a Lei de Organização Criminosa (art. 10 da Lei 12.850/2013). Vejamos esta última possibilidade de forma mais precisa:

Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites.

Após a efetiva prisão em flagrante, algumas formalidades exigidas em lei precisam ser respeitadas. Conforme o art. 304 do CPP, os condutores da prisão, ao chegarem à unidade policial, receberão a nota de entrega ou recibo de entrega, que é uma inovação desde 2005 para agilizar o procedimento ainda burocrático da formalização do auto de prisão em flagrante. Logo após seu relato do ocorrido, recebem o documento e estão liberados.

A recente Lei 13.257/2016, que regula a primeira infância, também se preocupou com a situação dos dependentes de eventual preso em flagrante, acrescentando o § 4.º ao art. 304 do CPP. Vejamos:

§ 4.º Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

Entretanto, as formalidades não param por aqui. As garantias constitucionais do preso jamais podem ser esquecidas pelos envolvidos, sob pena de abuso de autoridade e ilegalidade da prisão.

O primeiro cuidado diz respeito ao uso excepcional das algemas, conforme Súmula Vinculante 11:

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

Significa que, se tal excepcionalidade não for respeitada, poderá ser alegada ilegalidade da prisão. Diga-se de passagem, a polêmica súmula vinculante encontra bastante resistência na prática.

Num segundo momento, o art. 306 do CPP, já visto como uma tradução do espírito constitucional, deve ser sumariamente respeitado, também sob pena de ilegalidade. Exige o dispositivo legal a comunicação da prisão ao juiz, ao Ministério Público, ao advogado ou defensor público, à família ou algum conhecido e ainda a entrega da nota de culpa, esta consistente em documento-padrão com informações esclarecedoras sobre a prisão. Frise-se que qualquer um desses desrespeitos gerará a ilegalidade da prisão, passível, claro, de relaxamento de prisão, conforme art. 5.º, LXV, da CF.

2.4.4 Prisão temporária

A prisão temporária, aquela em que se prende para investigar, recebe algumas críticas de setores da doutrina por seu cunho autoritário e pelas lembranças obscuras da antiga prisão para averiguação. Todavia, trata-se de uma realidade legalmente inserida por meio da Lei 7.960/1989.

Somente possível ser decretada durante o inquérito policial e tão somente para os crimes do art. 1.º, inciso III, da Lei 7.960/1989 e para crimes hediondos. Observe-se que, com a revogação do crime de quadrilha, a melhor interpretação é a de que não cabe prisão temporária para a associação criminosa, do novo art. 288 do CP, por ausência de expressa menção em lei especial da viabilidade de prisão temporária para esse crime inserido pela Lei 12.850/2013.

Ainda, somente autoridade policial e Ministério Público poderão solicitar essa prisão ao juízo competente, que possui prazo certo e determinado (5 dias prorrogáveis por mais 5 dias em caso de extrema necessidade e fundamentação exigida em casos de crime da lei e no caso dos crimes hediondos, 30 dias

prorrogáveis por mais 30 dias, conforme art. 2.º, § 4.º, da Lei 8.072/1990 também se exigindo fundamentação em caso de prorrogação).

2.4.5 Prisão preventiva

Considerada a prisão mais abrangente de todas, podendo ser determinada tanto durante a investigação, quanto durante a ação penal (art. 311 do CPP). Além disso, possui o maior número de legitimados para solicitar a medida ao juízo competente. São eles: delegado de polícia, assistente, querelante, ministério público e, ainda, o juiz de direito, de ofício, somente durante a ação penal (art. 311 do CPP).

Desafio acerca desta prisão está na precisão conceitual dos requisitos da prisão preventiva. Segundo o art. 312 do CPP, poderíamos dividir o dispositivo legal em pressupostos, aqueles que são obrigatórios, e requisitos, em que bastaria um deles para se vislumbrar uma prisão preventiva. Seriam pressupostos os indícios suficientes de autoria e a materialidade do delito. Superando a análise destes pressupostos, passaríamos à análise extremamente subjetiva dos seus requisitos. O que seria, por exemplo, garantia da ordem pública?

Com a palavra, Ministro Gilmar Mendes, no HC 124180, vinculado no Informativo de Jurisprudência 773. Observe-se que tal destaque realça a importância da Lei 12.403/2011 nos dias atuais, largamente trabalhada neste capítulo:

Salientou que a prisão preventiva, para ser decretada, deveria estar embasada na conduta concretamente realizada, nas circunstâncias que a envolvessem, e não num modelo genérico de periculosidade. Ressaltou que a configuração da grave ameaça ainda estaria sob discussão e seria definida quando do julgamento do recurso de apelação. Diante dessas circunstâncias, reputou que seria frágil a fundamentação da prisão preventiva com base nos requisitos do art. 312 do CPP. Além disso, a situação causaria maiores perplexidades ante as modificações promovidas no CPP pela Lei 12.403/2011, que dispõe sobre matérias pertinentes a prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares. Ademais, ainda que se fizessem presentes de forma indiscutível os requisitos acautelatórios dispostos na lei processual penal, a prisão cautelar, atualmente, revelar-se-ia medida desproporcional. Em cálculo rápido, seria fácil perceber que o paciente já permanecera, em razão da preventiva, preso há mais de um ano em regime fechado, já ultrapassado, portanto, um sexto de sua reprimenda. Assim, se sua pena já fosse definitiva, teria ele direito à progressão para o regime semiaberto. Todavia, atualmente sua situação não seria de condenado definitivo, visto que em seu favor ainda militaria o princípio constitucional da presunção de inocência, pendente julgamento de recurso defensivo no qual se discutiria inclusive a

tipificação legal da conduta a ele atribuída.

Percebe-se nitidamente que o requisito da garantia da ordem pública se reveste de extrema subjetividade, em que o julgador terá importância redobrada quando da decretação da prisão por este motivo, sob pena de autoritarismo. Além da garantia da ordem pública, são requisitos para a prisão preventiva a garantia da ordem econômica, específica para crimes específicos, conveniência da instrução criminal, utilizada para quando se percebe uma intromissão na investigação ou na colheita de provas, ou seja, quando há uma verdadeira intenção de atrapalhar a persecução penal, como ameaçar testemunhas, e, ainda, a aplicação da lei penal, requisito famoso e utilizado quando há uma verdadeira suspeita de fuga do País.

Como ressaltamos, a intenção da Lei 12.403/2011 é dificultar a decretação da prisão, e tal postura pode ser visivelmente sentida com o novo art. 313 do CPP que cria condições específicas para a possibilidade da prisão preventiva. Senão, vejamos:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II – Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV – (Revogado.)

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

2.4.6 Contracautelas

Prisão ilegal	Relaxamento de prisão (art. 5.º, LXV, CF c/c o art. 310, I, CPP)
---------------	--

Prisão em flagrante legal, porém não necessária a manutenção na prisão	Liberdade provisória (art. 5.º, LXVI, CF c/c o art. 310, III, c/c o art. 321 do CPP)
Prisão preventiva desnecessária, argumentando-se contrariamente ao mérito de sua decretação	Revogação da prisão preventiva (art. 316 do CPP)

2.5 DAS NULIDADES (ART. 564 DO CPP)¹

Esta separação entre nulidades absolutas e relativas a seguir merece cuidados extremamente especiais, pois tal diferenciação é feita com base no art. 572 do CPP. O tema é alvo de muitas alterações jurisprudenciais e uma pesquisa constante de decisões se faz necessária regularmente. Por ora, vejamos tais diferenças no quadro sistematizado das nulidades.

Nulidades absolutas	Nulidades relativas
“I – por incompetência, suspeição ou suborno do juiz; II – por ilegitimidade de parte; III – por falta das fórmulas ou dos termos seguintes	“III – por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública;
a) denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante; b) exame do corpo de delito nos crimes	

que deixam vestígios, ressalvado o disposto no art.167;

c) a nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 anos;

(...)

e) 1.ª parte – a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente;

f) da sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, nos processos perante o Tribunal do Júri;

(...)

i) a presença pelo menos de 15 jurados para a constituição do júri;

j) o sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade;

k) os quesitos e as respectivas respostas;

l) a acusação e a defesa, na sessão de julgamento;

m) a sentença;

e) 2.ª parte – os prazos concedidos à acusação e à defesa;

(...)

g) a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia;

h) a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei;

(...)

IV – por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.”

n) o recurso de ofício, nos casos em que a lei o tenha estabelecido;

o) intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso;

p) no Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais de Apelação, o quorum legal para o julgamento.”

2.5.1 Princípios que regem as nulidades

- a) Princípio do Prejuízo (art. 563, CPP) – Toda e qualquer nulidade só será determinada se houver prejuízo. Geralmente a doutrina distingue a nulidade absoluta quando o prejuízo é evidente, temerário ao bom andamento do processo e relativa à nulidade quando se exige, pelas partes, a demonstração do prejuízo.
- b) Princípio de que ninguém poderá se aproveitar da própria torpeza (art. 565, CPP) – O dispositivo legal autoexplicativo impede que uma das partes, propositadamente, busque uma nulidade e obtenha vantagem da mesma.
- c) Princípio da Verdade Substancial (art. 566, CPP) – Esse princípio traz uma verdadeira agilidade ao processo, tendência, inclusive hoje, em nossos tribunais, já que o tempo é uma das grandes preocupações do processo penal. Se uma determinada nulidade não interferir no mérito da causa, esta não precisará ser declarada.
- d) Princípio da Sanabilidade (art. 572, *caput*, CPP) – Se as nulidades relativas não forem arguidas em momento oportuno, em resposta do acusado após o recebimento da ação e da citação válida, considerar-se-ão sanadas, pois, ao que parece, com o silêncio não foi sentido prejuízo pela parte.

- e) Princípio da Instrumentalidade das Formas (art. 572, II, CPP) – A formalidade excessiva impede a marcha processual como sabemos, sendo assim, modernizando o processo penal, não devemos nos prender a formalismos exagerados. Esse princípio hoje é bastante utilizado em julgamentos pelo País para que se diminua aos poucos a incidência excessiva de crimes prescritos.

2.5.2 Rol das nulidades

Analisemos passo a passo o significativo art. 564 do Diploma Processual Penal em que se encontra o rol das nulidades:

- a) Inciso I: por incompetência, suspeição ou suborno do juiz

A nulidade acerca da competência é uma das mais comuns em nossos tribunais. Envolvido em várias polêmicas, o assunto altamente discutido requer muitos cuidados. Remetemos o leitor para o tema de competência neste mesmo capítulo, onde são demonstradas as regras de competência.

Já os casos de suspeição e suborno são facilmente identificados com aquela determinada em lei, conforme art. 254 do CPP, tais como amizade íntima e inimizade capital.

- b) Inciso II: por ilegitimidade da parte

Hipótese bem mais rara que o inciso I, já que no processo penal é altamente perceptível a legitimidade, por exemplo, do Ministério Público quando do ajuizamento da denúncia.

- c) Inciso III, alínea “a”: a denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante.

Neste inciso é importante notar que a nulidade não se limita a denúncia ou a queixa, respectivamente ação penal pública e privada. Existem, no próprio texto legal, outros atos que podem ser suscetíveis de nulidades.

Quando se fala de nulidade na ação, estamos diante de algum desrespeito aos

requisitos da ação penal do art. 41 do CPP, principalmente. Já quando se fala de auto de prisão em flagrante, as formalidades devem seguir o disposto no art. 304 do CPP, senão vejamos:

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.

Lembrando que Portaria Administrativa é o ato pelo qual a autoridade policial inicia o inquérito policial.

- d) Inciso III, letra “b”: o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no art. 167;

Conforme já vimos no tema de prova penal, exame de corpo de delito é a análise pericial dos crimes que deixam vestígios, os crimes materiais.

As nulidades deste inciso podem ocorrer na produção do exame, desde a falta de respeito às suas formalidades ou até mesmo a ausência do exame quando se tratar de conduta material que gera sua imprescindibilidade.

- e) Inciso III, letra “c”: a nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ao ausente, e de curador ao menor de 21 anos;

Esta nulidade se reveste de importância maior desde a minirreforma de 2008 quando foi criada a resposta do acusado e o próprio diploma legal, no art. 396-A, § 2.º, exige sua apresentação.

Por óbvio, o Processo Penal brasileiro é regido por dogmas constitucionais, e um deles é o princípio da ampla defesa (art. 5.º, LV, CF), que jamais poderá ser desrespeitado. Vejamos famoso entendimento sumular:

Súmula 523: No Processo Penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

- f) Inciso III, letra “d”: a intervenção do Ministério Público em todos os termos c

ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública;

Segundo a Constituição Federal, art. 129, o Ministério Público possui inúmeras funções vitais ao bom andamento do estado democrático de direito.

- g) Inciso III, letra “e”: a citação do réu para ver se processar, o seu interrogatório quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa;

Nosso Processo Penal brasileiro, regido pelo devido processo legal (art. 5.º, LIV, CF), exige regras soberanas durante a marcha processual, e uma delas é o ato de comunicação mais importante, a citação, primeiro ato pelo qual o acusado é chamado para se defender e conhecer o inteiro teor da acusação.

Seguindo as exigências do art. 351 do CPP, a regra é a citação pessoal, feita por oficial de justiça, por meio de mandado judicial. Todavia, em caso de réu que se oculta, segundo o art. 362 do CPP, proceder-se-á à citação por hora certa, mantendo-se, ainda, em nosso ordenamento jurídico a citação por edital quando o réu não for encontrado (art. 361 do CPP).

Destaque-se que esse inciso em comento não aborda tão somente a citação, pois, em continuidade a sua redação, menciona ainda o interrogatório e os prazos.

O interrogatório, já abordado em tema anterior acerca da prova penal, é meio de prova e meio de defesa pela qual o indiciado ou acusado irá ser indagado sobre os fatos. Inicialmente, duas formalidades exigem preocupação: a presença da defesa técnica e o alerta acerca do direito ao silêncio (arts. 185 e 186 do CPP).

No tocante aos prazos, a regra do art. 798 do CPP deve ser respeitada, lembrando que a contagem do prazo penal tem diferenças com o prazo processual, em que aquele conta o primeiro dia e exclui o último.

- h) Inciso III, Letra “f”: a sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, nos processos perante o Tribunal do Júri;

Inicialmente uma ponderação merece ser feita. Pronúncia (art. 413 do CPP)

tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa.

Da letra “f” até a letra “l” do art. 564, inciso iii, a matéria de júri é destaque. Inicia-se a preocupação com o procedimento dos crimes dolosos contra a vida pela pronúncia, que consiste na decisão que reconhece os indícios de autoria e materialidade, ou seja, a probabilidade de que é o autor do crime. A pronúncia, uma vez transitada em julgado, permite a marcação do plenário do júri, essência e marca registrada deste procedimento.

Outro reparo que merece ser feito neste inciso é a extinção, desde 2008, do libelo crime acusatório, não gerando quaisquer nulidades, portanto.

- i) Inciso III, letra “g”: a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia;

A partir do art. 453 do CPP o tema é abordado, merecendo destaque o chamado julgamento de cadeira vazia, permitido desde 2008 no Tribunal do Júri brasileiro. Senão, vejamos:

Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado.

- j) Inciso III, letra “h”: a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei;

Com a extinção do libelo e da contrariedade ao libelo, este inciso está prejudicado. Atualmente, sobre a intimação das testemunhas, destacamos os arts. 422, 458 e 459 do CPP:

Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.

Art. 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe-á a multa prevista no § 2.º do art. 436 deste Código.

Art. 459. Aplicar-se-á às testemunhas a serviço do Tribunal do Júri o disposto no art. 441 deste Código.

- k) Inciso III, letra “i”: a presença pelo menos de 15 jurados para a constituição do Júri;

Regra determinada pelo art. 463 do CPP:

Art. 463. Comparecendo, pelo menos, 15 (quinze) jurados, o juiz presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento.

- l) Inciso III, letra “j”: o sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade;

Regras dos arts. 466 e 467 do CPP:

Art. 466. Antes do sorteio dos membros do conselho de sentença, o juiz presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos arts. 448 e 449 deste Código.

§ 1.º O juiz presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho e multa, na forma do § 2.º do art. 436 deste Código.

§ 2.º A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça.

Art. 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz presidente sorteará 7 (sete) dentre eles para a formação do conselho de sentença.

- m) Inciso III, letra “k”: os quesitos e as respectivas respostas;

O legislador ressalta o importante momento da quesitação a partir do art. 482 do CPP. Destaque para a ordem dos quesitos no art. 483 do CPP que deve ser sumariamente respeitada sob pena de nulidade.

- n) Inciso III, letra “l”: a acusação e a defesa, na sessão de julgamento;

O comportamento dos atores em plenário do Tribunal do Júri pode ser surpreendente dentro dos limites legais. a acusação, por exemplo, jamais poderá mencionar o silêncio do réu (art. 478, II, do CPP), não poderá fazer alusões à pronúncia (art. 478, I, do CPP), mencionar eventuais algemas (art. 478, I, do CPP c/c a SV 11). Por sua vez, a defesa, baseando-se no princípio constitucional da plenitude de defesa, atuará também dentro dos ditames

legais.

Observa-se também que a exibição de documentos segue a regra de alerta com três dias úteis de antecedência para que não haja surpresa em plenário (art. 479 do CPP).

o) Inciso III, letra “m”: a sentença;

O grande objetivo do Processo Penal, o ato final, proferido por juiz de direito, evidentemente requer formalidades dispostas em lei conforme art. 381 do CPP.

A formação deste ato jurídico por excelência possui regras próprias, tais como o respeito aos itens que compõem uma sentença (art. 381 do CPP). Lembrando que, em sede de juizado especial criminal, dispensa-se o relatório.

Outros institutos jurídicos que merecem cuidados são os da *emendatio libelli* e *mutatio libelli*, conforme arts. 383 e 384 do CPP, respectivamente.

p) Inciso III, letra “n”: o recurso de ofício, nos casos em que a lei o tenha estabelecido;

Defendemos a posição doutrinária de que o recurso de ofício é uma das maiores anomalias do CPP, inclusive com sua não recepção pela Constituição Federal de 1988. Todavia, o mesmo se mantém no inciso I do art. 574, já que o inciso II fora prejudicado com a reforma de 2008.

O que a legislação chama de recurso de ofício leia-se condição de eficácia e produção de efeitos da decisão, ou seja, o legislador entende que, em tais hipóteses, as mencionadas decisões só produzirão efeitos se confirmadas em 2.^a instância.

q) Inciso III, letra “o”: a intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso;

Intimação, ato de comunicação, tem suas regras definidas a partir do art. 370

do CPP.

- r) Inciso III, letra “p”: no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação *quorum* legal para o julgamento;

A Lei 8.038/1990 é o procedimento escolhido para reger as ações penais originárias nos tribunais superiores. Já tribunal de apelação é termo em desuso, substituindo-o, atualmente, por tribunais de 2.º grau.

- s) Inciso IV: por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Inciso residual que é utilizado para mencionar uma nulidade que não fora abordada pelo legislador no inciso III. Deve o operador do direito, sempre, em primeiro lugar, pesquisar a nulidade no inciso III, mantendo este inciso apenas para situações residuais.

2.6 A DEFESA NO PROCESSO PENAL

Uma das maiores dificuldades percebidas durante a preparação é a relutância em se adotar uma postura defensiva. Evidentemente que a atuação da advocacia no processo penal não se restringe à atuação defensiva, pois, desde a investigação até durante a fase processual, como acusação ou assistente de acusação, o advogado se faz presente e imprescindível também na parte acusatória. Basta imaginarmos o advogado que ajuíza uma queixa-crime, a ação penal privada.

Entretanto, é na postura defensiva que presenciamos as maiores dificuldades. Dizer que o Direito Penal é complicado ou intrigante nos faz avançar cada vez mais no estudo desta ciência. Em muitas das vezes um determinado fato pode ter diversas análises e capitulações jurídicas. Assim, se um determinado agente munido de uma faca a coloca no pescoço de uma vítima, muito provavelmente teremos capitulações no sentido de uma tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do CP) ou simplesmente uma tentativa de lesão corporal (art. 129 c/c art. 14, II, do CP), além de eventuais teses no sentido de uma tentativa de extorsão (art. 158 c/c art. 14, II, do CP), constrangimento ilegal (art. 146 do CP) e até mesmo atipicidade, tendo em vista

se tratar de uma intenção de susto. Esse simples evento foi apenas elucidativo para mostrar que o fato não se altera, ou seja, a colocação de uma faca no pescoço de outrem pode gerar capitulações jurídicas das mais diversas, extremadas. Justamente nesse aspecto reside a beleza e a dificuldade do Direito Penal, pois a correta capitulação jurídica dependerá da intenção, do dolo, da vontade livre e consciente desse agente que resolve sacar uma arma branca e colocá-la no pescoço da vítima. A mente humana, todos nós sabemos, é de difícil análise e, inevitavelmente, para estudarmos a ciência criminal com maestria, precisamos estudar teorias, causas que incentivam o cometimento de determinado delito, finalidades da ação. Em suma, por que o agente resolveu agir gerando a forma mais grave de quebra do ordenamento jurídico? Atacar um bem jurídico penalmente relevante é essência para a configuração de um fato típico, ilícito e culpável.

O caminho não é fácil e jamais nos esquivaremos de tal desafio. A dificuldade se inicia com a cultura latino-americana de sermos influenciados por políticas criminais sensacionalistas, políticas de tolerância zero e de lei e ordem. Em um minuto, já se imaginou o quanto se dá credibilidade ao sistema penal somente quando ocorre uma prisão? O quanto nos impressionamos com a confissão e demonizamos o direito ao silêncio?

Pensar e atuar como defesa começa com uma postura cultural.

Devemos pensar que, acima de tudo, se defende a Constituição da República Federativa do Brasil. Jamais esquecemos seu preâmbulo:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

É fácil defender enquanto tudo e todos estão contra?

Equiparmos eventual agressividade do homem, eventual brutalidade do ser comum não é característica de um Estado DEMOCRÁTICO de DIREITO. O Estado deve dar

o exemplo. Críticas à democracia podem ser feitas, desde que com coerência e sugestões de mudanças estruturais. Cientistas políticos comungam que democracia requer desafios e cuidados. É preciso lembrar que esse é apenas um deles. Respeitar as garantias fundamentais de todos, sem distinção.

Abrir os horizontes e se influenciar por Cesare Beccaria, em seu clássico *Dos delitos e das penas*, é um ótimo começo.

Tentativa de convencimento sugerida, passemos às questões práticas profissionais que enfrentaremos durante um certame.

O primeiro passo é justamente nos posicionarmos, ou seja, o examinador nos coloca na posição de acusação, como querelante ou assistente, ou nos coloca como defesa?

Sem rodeios, a atuação defensiva é eivada de maiores dificuldades, sendo justamente esse o assunto do presente capítulo. Costumamos afirmar que a arte está na defesa.

Se estivermos na posição de polo ativo, de acusação, evidentemente a postura deverá ser de proporcionar ao cliente uma análise jurídica mais impiedosa, se nos permitem dizer assim. Analisemos crimes mais graves, eventuais concursos de crimes e apresentemos as análises jurídicas mais radicais. Em nenhum momento se poderá colocar o absurdo, algo de difícil análise jurídica. Um dos primordiais fundamentos para a realização de uma boa prova é a razoabilidade, o bom senso do candidato. Por mais vontade que tenhamos em colocar o maior número de artigos legais, o importante é trabalhar dentro da proporcionalidade, da coerência. Mas é inegável que, como acusação, os olhos são voltados para os crimes mais graves, cujas penas são maiores. A acusação geralmente os apresenta desta forma e cabe à outra parte, a defesa, combater, contraditar, relutar acerca do narrado pela acusação. Nesse momento se fazem presentes dois princípios de extrema importância para uma persecução criminal justa: o princípio da paridade das armas, que impõe uma igualdade de medidas para ambos os lados, e o do contraditório, já visto em capítulo próprio.

Do outro lado, rebatendo as acusações, está a defesa técnica, patrocinada pelo advogado ou pelo defensor público. É nessa hora que toda a criatividade, o empenho

e a intimidade com as teses defensivas vão dar o tom para uma boa peça processual. O advogado criminalista não é um mágico, uma espécie de “Mandrake” do Direito que de uma hora para outra conseguirá a absolvição do seu cliente. Aliás, essa uma das errôneas posturas que percebemos em sala de aula: o candidato numa tentativa sonhadora de obter uma absolvição. Cuidado, pois muitas questões apresentadas trazem a realização de um fato criminoso pelo cliente e todos sabemos que os fatos narrados na questão apresentada não podem ser alterados, tampouco podem ser criados argumentos sonhadores, fictícios ou ideais para se conseguir uma eventual absolvição. Devemos trabalhar sempre em cima dos dados fornecidos. Lembrem-se: nem sempre a absolvição é possível, assim, devemos conjecturar acerca das famosas teses defensivas.

Iniciemos nossa postura defensiva.

A nosso ver, começar pela identificação de eventual prescrição é uma postura inicial adequada.

Geralmente quando a prova nos fornece dados referentes à data do cometimento do crime ou referentes ao oferecimento da ação penal ou publicação da sentença penal, o candidato tende a achar que se trata de uma das mais famosas causas de extinção da punibilidade: a prescrição. Concordamos que, sem sombra de dúvidas, é uma das teses mais interessantes para a defesa. Outrossim, um cuidado se faz necessário. Será que foram fornecidos dados suficientes para verificarmos tal prescrição? Para termos uma análise correta, recomendamos sempre a elaboração da linha que se segue e a inserção dos dados fornecidos para termos subsídios suficientes para uma arguição correta.

Senão vejamos:

(1)------(2)------(3)------(4)------(5)

(1) data do crime

(2) recebimento da ação penal

(3) publicação da sentença penal

(4) trânsito em julgado da sentença penal

(5) início da execução

Tais pontos são os momentos de interrupção do prazo prescricional, quando teremos que zerar a contagem e reiniciá-la. Com essa análise didática a visualização fica mais fácil e menos suscetível a erro.

Não sendo hipótese de prescrição, passemos a um segundo cuidado.

Nos casos de ação penal privada, em que vigoram os princípios da oportunidade e da disponibilidade, vale verificar se temos outras causas de extinção da punibilidade, tais como a renúncia (art. 107, V, do CP c/c art. 49 do CPP), a desistência pré-processual, o perdão (art. 107, V, do CP c/c art. 51 do CPP), a desistência processual, bilateral e pessoal, e a decadência, que exige do ofendido a propositura da ação penal em seis meses, contados a partir do conhecimento da autoria (art. 38 do CPP), além da perempção que, didaticamente falando, retrata um descaso da queixa-crime por parte do querelante ou de seus substitutos processuais (art. 107, IV, do CP c/c art. 60 do CPP).

Ainda, se for caso de ação penal pública condicionada a representação, devemos nos atentar se houve ou não retratação da representação, que, seguindo a regra geral, pode ser retirada até o oferecimento (e não recebimento!) da ação penal (art. 25 do CPP).

Seguindo adiante em nosso roteiro defensivo, mais duas teses, muitas vezes conjugadas, devem ser analisadas num primeiro plano: A violação aos princípios constitucionais e as nulidades. Passemos às breves considerações.

Sabemos da importância dos aspectos constitucionais que protegem o indiciado e o acusado durante a persecução criminal. Assim, o destaque que já fizemos em nossa constituição poderá nos ajudar profundamente. Será que as garantias constitucionais foram respeitadas? Os princípios orientaram e protegeram a persecução criminal? Sabemos que qualquer desrespeito ao devido processo legal (art. 5.º, LIV, da CF), ao contraditório e ampla defesa (art. 5.º, LV, da CF) e ao juiz natural (art. 5.º, LIII, da CF) geram nulidades absolutas que podem ser arguidas a qualquer instante.

Conjugando as devidas análises constitucionais, as nulidades precisam ser verificadas. Sua incidência ou não precisam ser aferidas (art. 563 e seguintes do CPP). Lembrando sempre que as nulidades são regidas pelo princípio do prejuízo (art. 563 do CPP), assim, se, porventura, durante a leitura tivermos a percepção de algum prejuízo, provavelmente estaremos falando das nulidades. Um artigo que pode nos ajudar bastante para sabermos o tipo de nulidade, é analisarmos o art. 572 do CPP, que traz a possibilidade de algumas medidas serem sanadas e sabemos que tão somente as nulidades relativas podem ser sanadas. Vale lembrar a ressalva de que tal artigo precisa ser conjugado com aspectos constitucionais e decisões jurisprudenciais. A matéria de nulidade é bem vacilante em nossos tribunais.

Em suma, nosso roteiro jurídico se inicia com as causas de extinção da punibilidade (art. 107 do CP), partindo para os princípios constitucionais (art. 5.º da CF) e concluindo com as nulidades (art. 564 do CPP).

Devemos fazer um alerta procedimental antes de passarmos adiante. Em situações iniciais de resposta do acusado (art. 396-A ou 406, § 3.º, do CPP), é interessante verificar a incidência ou não de uma exceção. Uma das mais comuns é a de incompetência do juízo (art. 95, II, do CPP), em que há uma deflagração da ação penal ao juízo incompetente, se fazendo necessária esta arguição logo nos primeiros momentos procedimentais.

Num segundo momento, devemos adentrar no mérito dos fatos, nos acontecimentos narrados, na postura adotada pela acusação. Termos em mente a classificação tripartida do crime é essencial. Como não temos um conceito analítico de crime no Código Penal, devemos analisar todos os elementos que compõem a estrutura TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL.

Desconfiemos da capitulação dada pelo titular da ação penal. Em processo, a defesa é feita em cima dos fatos e não em cima de capitulações jurídicas. Será que o fato X é o crime Y, como quer a acusação? Por que deveríamos aceitar passivamente a capitulação jurídica dada pela acusação quando de sua titularidade da pretensão punitiva? Lutemos.

Perguntas frequentes deverão ser feitas, tais como acerca da atipicidade do fato,

se o crime foi consumado ou tentado (art. 14 do CP), se houve alguma interrupção voluntária nos atos de execução, configurando a desistência voluntária e o arrependimento eficaz (art. 15 do CP), se houve intenção, vontade (art. 18, I, do CP), ou falta do dever de cuidado (art. 18, II, do CP), e se houve erro.

Lembre-se também acerca das excludentes de ilicitude, tais como legítima defesa (art. 23, II c/c o art. 25 do CP), estado de necessidade (art. 23, I c/c o art. 24 do CP), estrito cumprimento do dever legal (art. 23, III, do CP), exercício regular do direito (art. 23, III, do CP) e a causa supralegal de excludente de ilicitude, que é o consentimento do ofendido, em raros e poucos casos.

Da mesma forma, merece atenção a estrutura da culpabilidade, com as famosas excludentes para se aferir imputabilidade penal, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.

Ainda, devemos estar atentos a uma das mais famosas teses de defesa no campo prático penal: a desclassificação.

Sugerirmos um crime menos grave, retirarmos qualificadoras e até mesmo reconhecimentos de causas de diminuição, são, em muitas das vezes, verdadeiras vitórias para a defesa. Dependendo da complexidade do caso, essas teses são altamente comemoradas. Lembremos que nem sempre a absolvição é possível.

A defesa técnica deve ficar atenta ao panorama dos tipos penais da parte especial. É preferível responder por homicídio doloso ou por roubo seguido de morte? Pela pena em si abstrata, o homicídio (art. 121 do CP) vai de 6 a 20 anos, se qualificado (art. 121, § 2.º, do CP), de 12 a 30 anos, e o latrocínio, roubo seguido de morte (art. 157, § 3.º, do CP), vai de 20 a 30 anos. Essa análise abstrata pode ser importante.

Passear pelos capítulos da parte especial do diploma penal é essencial.

Também não deixemos de verificar se eventual desclassificação gerará uma remessa para outro juízo competente, pois esse requerimento deverá ser inserido ao final da peça processual.

Enfim, trata-se ou não de uma arte?

Acreditamos veementemente que tal postura ocasiona o risco de construirmos o

sucesso em nossa árdua empreitada de advocacia e defesa criminal.

Estudarmos de forma roteirizada, organizada, valendo-nos de toda uma metodologia e inteligência, nos faz percorrer um caminho menos doloroso para a vitória.

Vale salientar que essa postura evidentemente não esgota todas as teses de defesa do direito brasileiro. Cada caso particular nos traz uma análise individual, mas é inegável que a postura deva se iniciar seguindo uma ordem de melhores teses defensivas, e foi exatamente o que tentamos fazer neste presente capítulo.

2.6.1 Apresentação das peças

Este item foi criado para termos uma breve noção das peças que serão objeto da presente obra com seus respectivos e mais comuns momentos da persecução criminal.

2.6.1.1 Fase investigatória até a propositura da ação penal (atualização pela Lei 12.403/2011)

→ Notícia-Crime (art. 5.º, II, do CPP):

Art. 5.º Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:

I – de ofício;

II – mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

§ 1.º O requerimento a que se refere o n.º II conterà sempre que possível:

a) a narração do fato, com todas as circunstâncias;

b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer;

c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência.

→ Relaxamento de Prisão (art. 5.º, LXV, da CF):

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

Observemos que muitos dos artigos referentes à prisão cautelar foram alterados pela recente Lei 12.403/2011, decorrente do Projeto de Lei 4.208-C.

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I – relaxar a prisão ilegal; ou

II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

→ Liberdade Provisória (art. 5.º, LXVI, da CF c/c arts. 310, 321 e 322 do CPP)

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

Art. 310 do CPP. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I – relaxar a prisão ilegal; ou

II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

Art. 321 do CPP. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

I – Revogado

II – Revogado

Art. 322 do CPP. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.

Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito) horas.

→ **Revogação da Prisão Preventiva (art. 316 do CPP):**

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

→ **Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP):**

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 647 do CPP. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

2.6.1.2 Fase da propositura da ação penal

→ **Ação Penal Privada, Queixa-Crime (arts. 30, 41 e 44 do CPP):**

Art. 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada.

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

- Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, Queixa Supletiva ou Queixa Subsidiária (art. 5.º, LIX, da CF c/c o art. 29 do CPP):

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

Art. 29 do CPP. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

- Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP):

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 647 do CPP. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

2.6.1.3 Da ação penal até a sentença penal

- Resposta do Acusado (art. 396 c/c o art. 396-A do CPP):

Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei 11.719, de 2008).

Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. (Redação dada pela Lei 11.719, de 2008).

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (Incluído pela Lei 11.719, de 2008).

→ **Exceções (art. 95 do CPP):**

Art. 95. Poderão ser opostas as exceções de:

I – suspeição;

II – incompetência de juízo;

III – litispendência;

IV – ilegitimidade de parte;

V – coisa julgada.

→ **Alegações Finais Escritas (art. 403, § 3.º c/c o art. 404, parágrafo único, do CPP):**

Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.

(...)

§ 3.º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença.

Art. 404. Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. (Redação dada pela Lei 11.719, de 2008).

Parágrafo único. Realizada, em seguida, a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, suas alegações finais, por memorial, e, no prazo de 10 (dez) dias, o juiz proferirá a sentença. (Incluído pela Lei 11.719, de 2008).

→ **Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP):**

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I – que não receber a denúncia ou a queixa;

II – que concluir pela incompetência do juízo;

III – que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu; (Redação dada pela Lei 11.689, de 2008)

V – que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

VI – Revogado

VII – que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII – que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX – que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X – que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI – que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII – que conceder, negar ou revogar livramento condicional;²

XIII – que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV – que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV – que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI – que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII – que decidir sobre a unificação de penas;³

XVIII – que decidir o incidente de falsidade;

XIX – que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX – que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI – que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art.774;

XXII – que revogar a medida de segurança;

XXIII – que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;⁴

XXIV – que converter a multa em detenção ou em prisão simples.⁵

→ *Habeas Corpus* (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP):

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 647 do CPP. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

2.6.1.4 Da sentença penal

→ *Apelação* (art. 593 do CPP):

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias

I – das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

II – das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

§ 1.º Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação.

§ 2.º Interposta a apelação com fundamento no n.º III, c, deste artigo, o tribunal ad quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança.

§ 3.º Se a apelação se fundar no n.º III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.

§ 4.º Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra.

→ **Embargos de Declaração (art. 382 do CPP):**

Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

→ **Carta Testemunhável (art. 639 do CPP):**

Art. 639. Dar-se-á carta testemunhável:

I – da decisão que denegar o recurso;

II – da que, admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo ad quem.

→ **Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP):**

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 647 do CPP. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

2.6.1.5 Das decisões interlocutórias

→ **Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP):**

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I – que não receber a denúncia ou a queixa;

II – que concluir pela incompetência do juízo;

III – que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu; (Redação dada pela Lei 11.689, de 2008)

V – que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

VI – Revogado

VII – que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII – que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX – que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X – que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI – que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII – que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII – que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV – que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV – que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI – que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII – que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII – que decidir o incidente de falsidade;

XIX – que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX – que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI – que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII – que revogar a medida de segurança;

XXIII – que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV – que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

→ **Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP):**

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 647 do CPP. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

2.6.1.6 Do acórdão na 2.^a Instância

→ Embargos de Declaração (art. 619 do CPP):

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

→ Embargos Infringentes e de Nulidade (art. 609, parágrafo único, do CPP):

Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.

→ Recurso Especial (art. 105, III, da CF c/c o art. 1.029 do CPC):

Art. 105 da CF. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

III – julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 2004)

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça: (Redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 2004)

I – a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional 45, de 2004)

II – o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. (Incluído pela Emenda Constitucional 45, de 2004)

Art. 1.029 do CPC. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

I – a exposição do fato e do direito;

II – a demonstração do cabimento do recurso interposto;

III – as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.

§ 1.º Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

→ **Recurso Extraordinário (art. 102, III, da CF c/c o art. 1.029 do NCPC):**

Art. 102 da CF. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição;

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (Incluída pela Emenda Constitucional 45, de 2004)

§ 1.º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. (Transformado em § 1.º pela Emenda Constitucional 3, de 1993)

§ 2.º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada

pela Emenda Constitucional 45, de 2004)

§ 3.º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. (Incluída pela Emenda Constitucional 45, de 2004)

Art. 1.029 do CPC. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

I – a exposição do fato e do direito;

II – a demonstração do cabimento do recurso interposto;

III – as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.

§ 1.º Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

→ *Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP):*

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 647 do CPP. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

2.6.1.7 Do trânsito em julgado

→ *Revisão Criminal (art. 621 do CPP):*

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos

comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

→ *Habeas Corpus* (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP):

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 647 do CPP. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

2.6.1.8 Da fase de execução

→ *Agravo em Execução* (art. 66 c/c o art. 197 da Lei 7.210/1984):

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I – aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

II – declarar extinta a punibilidade;

III – decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

d) suspensão condicional da pena;

e) livramento condicional;

f) incidentes da execução.

IV – autorizar saídas temporárias;

V – determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;

e) a revogação da medida de segurança;

f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;

g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;

h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1.º, do artigo 86, desta Lei.

VI – zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;

VII – inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;

VIII – interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei;

IX – compor e instalar o Conselho da Comunidade;

X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir. (Incluído pela Lei 10.713, de 13.8.2003)

Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

→ *Habeas Corpus* (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP):

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 647 do CPP. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

2.6.1.9 No Juizado Especial Criminal

→ *Queixa-crime* (art. 77, § 3.º c/c o art. 78 da Lei 9.099/1995):

Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis.

(...)

§ 3.º Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao Juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do art. 66 desta Lei.

Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado,

que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

→ **Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, Queixa Supletiva ou Queixa Subsidiária (art. 5.º, LIX, da CF c/c o art. 29 do CPP):**

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

Art. 29 do CPP. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

→ **Apelação (art. 82 da Lei 9.099/1995):**

Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 1.º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 2.º O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias.

§ 3.º As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o § 3.º do art. 65 desta Lei.

§ 4.º As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa.

§ 5.º Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

→ **Embargos de Declaração (art. 83 da Lei 9.099/1995):**

Art. 83. Caberão embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

§ 1.º Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

§ 2.º Quando opostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para o recurso.

§ 3.º Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

→ *Habeas Corpus* (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP):

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 647 do CPP. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

2.6.1.10 No Tribunal do Júri

→ *Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, Queixa Supletiva ou Queixa Subsidiária* (art. 5.º, LIX, da CF c/c o art. 29 do CPP):

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

Art. 29 do CPP. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

→ *Resposta do Acusado* (art. 406 c/c o art. 406, § 3.º, do CPP):

Art. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei 11.689, de 2008)

(...)

§ 3.º Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (Incluído pela Lei 11.689, de 2008)

→ **Exceções (art. 407 c/c o art. 95 do CPP):**

Art. 407. As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. (Redação dada pela Lei 11.689, de 2008)

Art. 95. Poderão ser opostas as exceções de:

I – suspeição;

II – incompetência de juízo;

III – litispendência;

IV – ilegitimidade de parte;

V – coisa julgada.

→ **Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP):**

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I – que não receber a denúncia ou a queixa;

II – que concluir pela incompetência do juízo;

III – que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu; (Redação dada pela Lei 11.689, de 2008)

V – que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; (Redação dada pela Lei 7.780, de 22.6.1989)

VI – Revogado

VII – que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII – que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX – que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X – que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI – que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII – que conceder, negar ou revogar livramento condicional;⁶

XIII – que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV – que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;
XV – que denegar a apelação ou a julgar deserta;
XVI – que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;
XVII – que decidir sobre a unificação de penas;⁷
XVIII – que decidir o incidente de falsidade;
XIX – que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;
XX – que impuser medida de segurança por transgressão de outra;
XXI – que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;
XXII – que revogar a medida de segurança;
XXIII – que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;⁸
XXIV – que converter a multa em detenção ou em prisão simples.⁹

→ **Apelação (art. 593, III, do CPP):**

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:

- a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;*
- b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;*
- c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;*
- d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.*

§ 1.º Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação.

§ 2.º Interposta a apelação com fundamento no n.º III, c, deste artigo, o tribunal ad quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança.

§ 3.º Se a apelação se fundar no n.º III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.

§ 4.º Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra.

→ **Embargos de Declaração (art. 382 do CPP):**

Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

→ **Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP):**

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 647 do CPP. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

2.6.1.11 Nos Tribunais Superiores

→ Ação Penal Privada, Queixa-Crime (arts. 30, 41 e 44 do CPP):

Art. 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada.

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

→ Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, Queixa Supletiva ou Queixa Subsidiária (art. 5.º, LIX, da CF c/c o art. 29 do CPP)

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

Art. 29 do CPP. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

→ Defesa Preliminar (art. 4.º da Lei 8.038/1990):

Art. 4.º Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.

→ Defesa Prévia (art. 8.º da Lei 8.038/1990):

Art. 8.º O prazo para defesa prévia será de cinco dias, contado do interrogatório ou da intimação do defensor dativo.

→ Reclamação (art. 988 do NCPC):

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei 13.256, de 2016.)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

→ Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP c/c o art. 23 da Lei 8.038/1990):

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 647 do CPP. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Art. 23 da Lei 8.038/1990. Aplicam-se ao Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça as normas do Livro III, Título II, Capítulo X do Código de Processo Penal.

→ Recurso Ordinário em Habeas Corpus (art. 30 da Lei 8.038/1990):

Art. 30. O recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, das decisões denegatórias de Habeas Corpus, proferidas pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, será interposto no prazo de cinco dias, com as razões do pedido de reforma.

→ Agravado (art. 39 da Lei 8.038/1990):

Art. 39. Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias.

2.6.1.12 No procedimento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos (art. 513 do CPP)

→ Ação Penal Privada, Queixa-Crime (arts. 30, 41, 44 e 513 do CPP):

Art. 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada.

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

Art. 513. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas.

→ Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, Queixa Supletiva ou Queixa Subsidiária (art. 5.º, LIX, da CF c/c o art. 29 do CPP):

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

Art. 29 do CPP. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada

no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

→ Defesa Preliminar (art. 514 do CPP):

Art. 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de quinze dias.

Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar.

→ Resposta do Acusado (art. 396-A do CPP):

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

→ Exceções (art. 95 do CPP):

Art. 95. Poderão ser opostas as exceções de:

I – suspeição;

II – incompetência de juízo;

III – litispendência;

IV – ilegitimidade de parte;

V – coisa julgada.

→ Alegações Finais Escritas (art. 404, parágrafo único, do CPP):

Art. 404. Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. (Redação dada pela Lei 11.719, de 2008)

Parágrafo único. Realizada, em seguida, a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, suas alegações finais, por memorial, e, no prazo de 10 (dez) dias, o juiz proferirá a sentença. (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

→ Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP):

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I – que não receber a denúncia ou a queixa;

II – que concluir pela incompetência do juízo;

III – que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu; (Redação dada pela Lei 11.689, de 2008)

V – que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

VI – Revogado

VII – que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII – que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX – que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X – que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI – que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII – que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII – que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV – que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV – que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI – que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII – que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII – que decidir o incidente de falsidade;

XIX – que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX – que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI – que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII – que revogar a medida de segurança;

XXIII – que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV – que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

→ *Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP):*

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 647 do CPP. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

2.6.1.13 No procedimento dos crimes contra a honra (art. 519 do CPP)

→ Ação Penal Privada, Queixa-Crime (arts. 30, 41 e 44 do CPP):

Art. 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada.

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

→ Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, Queixa Supletiva ou Queixa Subsidiária (art. 5.º, LIX, da CF c/c art. 29 do CPP):

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

Art. 29 do CPP. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

→ Exceção da Verdade (art. 523 do CPP):

Art. 523. Quando for oferecida a exceção da verdade ou da notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de dois dias, podendo ser inquiridas as testemunhas arroladas na queixa, ou outras indicadas naquele prazo, em substituição às primeiras, ou para completar o máximo legal.

→ Resposta do Acusado (art. 396-A do CPP):

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

→ **Exceções (art. 95 do CPP):**

Art. 95. Poderão ser opostas as exceções de:

I – suspeição;

II – incompetência de juízo;

III – litispendência;

IV – ilegitimidade de parte;

V – coisa julgada.

→ **Alegações Finais Escritas (art. 404, parágrafo único, do CPP):**

Art. 404. Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. (Redação dada pela Lei 11.719, de 2008)

Parágrafo único. Realizada, em seguida, a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, suas alegações finais, por memorial, e, no prazo de 10 (dez) dias, o juiz proferirá a sentença. (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

→ **Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP):**

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I – que não receber a denúncia ou a queixa;

II – que concluir pela incompetência do juízo;

III – que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu; (Redação dada pela Lei 11.689, de 2008)

V – que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

VI – Revogado

VII – que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII – que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX – que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X – que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI – que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII – que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII – que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;
XIV – que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;
XV – que denegar a apelação ou a julgar deserta;
XVI – que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;
XVII – que decidir sobre a unificação de penas;
XVIII – que decidir o incidente de falsidade;
XIX – que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;
XX – que impuser medida de segurança por transgressão de outra;
XXI – que manter ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;
XXII – que revogar a medida de segurança;
XXIII – que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;
XXIV – que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

→ *Habeas Corpus* (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP):

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 647 do CPP. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

2.6.1.14 No procedimento da Lei de Tóxicos (Lei 11.343/2006)

→ Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, Queixa Supletiva ou Queixa Subsidiária (art. 5.º, LIX, da CF c/c o art. 29 do CPP):

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

Art. 29 do CPP. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada

no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

→ **Defesa Preliminar (art. 55 da Lei 11.343/2006):**

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1.º Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.

→ **Exceções (art. 95 do CPP c/c o art. 55, § 2.º, da Lei 11.343/2006):**

Art. 95 do CPP. Poderão ser opostas as exceções de:

I – suspeição;

II – incompetência de juízo;

III – litispendência;

IV – ilegitimidade de parte;

V – coisa julgada.

Art. 55 da Lei 11.343/2006. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

(...)

§ 2.º As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-Lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal.

→ **Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP):**

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I – que não receber a denúncia ou a queixa;

II – que concluir pela incompetência do juízo;

III – que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu; (Redação dada pela Lei 11.689, de 2008)

V – que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

VI – Revogado

VII – que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII – que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;
IX – que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;
X – que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;
XI – que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;
XII – que conceder, negar ou revogar livramento condicional;¹⁰
XIII – que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;
XIV – que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;
XV – que denegar a apelação ou a julgar deserta;
XVI – que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;
XVII – que decidir sobre a unificação de penas;¹¹
XVIII – que decidir o incidente de falsidade;
XIX – que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;
XX – que impuser medida de segurança por transgressão de outra;
XXI – que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;
XXII – que revogar a medida de segurança;
XXIII – que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;¹²
XXIV – que converter a multa em detenção ou em prisão simples.¹³

→ *Habeas Corpus* (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP):

Art. 5.º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 647 do CPP. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

→ *Mandado de segurança* (art. 5.º, LXIX da CF) – Do direito líquido e certo:

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado

por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

2.6.1.15 Quadro sistemático das peças processuais penais

Momento Procedimental	Peças
Fase Investigatória até a Propositura da Ação Penal	– Notícia-Crime (art. 5.º, II, do CPP) – Relaxamento de Prisão (art. 5.º, LXV, da CF) – Liberdade Provisória (art. 5.º, LXVI, da CF c/c arts. 310 e 321 do CPP) – Revogação da Prisão Preventiva (art. 316 do CPP) – Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP)
Fase da Propositura da Ação Penal	– Ação Penal Privada, Queixa-Crime (arts. 30, 41 e 44 do CPP) – Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, Queixa Supletiva ou Queixa Subsidiária (arts. 5.º, LIX, da CF c/c o art. 29 do CPP) – Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP)
Da Ação Penal até a Sentença Penal	– Resposta do Acusado (art. 396-A do CPP) – Exceções (art. 95 do CPP) – Alegações Finais Escritas (art. 404, parágrafo único, do CPP)

	– Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP) – Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP)
Da Sentença Penal	– Apelação (art. 593 do CPP) – Embargos de Declaração (art. 382 do CPP) – Carta Testemunhável (art. 639 do CPP) – Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP)
Das Decisões Interlocutórias	– Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP) – Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP)
Do Acórdão na 2.ª Instância	– Embargos de Declaração (art. 619 do CPP) – Embargos Infringentes e de Nulidade (art. 609, parágrafo único, do CPP) – Recurso Especial (art. 105, III, da CF c/c o art. 1.029 do NCPC) – Recurso Extraordinário (art. 102, III, da CF c/c o art. 1.029 do NCPC) – Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP)
Do Trânsito em Julgado	– Revisão Criminal (art. 621 do CPP) – Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP)

Da Fase de Execução	– Agravo em Execução (art. 66 c/c o art. 197 da Lei 7.210/1984) – Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP)
No Juizado Especial Criminal	– Queixa-crime (art. 77, § 3.º c/c o art. 78 da Lei 9.099/1995) – Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, Queixa Supletiva ou Queixa Subsidiária (art. 5.º, LIX, da CF c/c o art. 29 do CPP) – Apelação (art. 82 da Lei 9.099/1995) – Embargos de Declaração (art. 83 da Lei 9.099/1995) – Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP)
No Tribunal do Júri	– Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, Queixa Supletiva ou Queixa Subsidiária (art. 5.º, LIX, da CF c/c o art. 29 do CPP) – Resposta do Acusado (art. 406, § 3.º, do CPP) – Exceções (art. 407 c/c o art. 95 do CPP) – Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP) – Apelação (art. 593, III, do CPP) – Embargos de Declaração (art. 382 do CPP) – Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP)

Nos Tribunais Superiores	– Ação Penal Privada, Queixa-Crime (arts. 30, 41 e 44 do CPP) – Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, Queixa Supletiva ou Queixa Subsidiária (art. 5.º, LIX, da CF c/c o art. 29 do CPP) – Defesa Preliminar (art. 4.º da Lei 8.038/1990) – Defesa Prévia (art. 8.º da Lei 8.038/1990) – Alegações Escritas (art. 11 da Lei 8.038/1990) – Reclamação (art. 988 do NCPC) – Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c arts. 647 do CPP e 23 da Lei 8.038/1990) – Recurso Ordinário em Habeas Corpus (art. 30 da Lei 8.038/1990) – Agravo (art. 39 da Lei 8.038/1990)
No Procedimento dos Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos	– Ação Penal Privada, Queixa-Crime (arts. 30, 41 e 44 do CPP) – Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, Queixa Supletiva ou Queixa Subsidiária (art. 5.º, LIX, da CF c/c o art. 29 do CPP) – Defesa Preliminar (art. 514 do CPP) – Resposta do Acusado (art. 396-A do CPP) – Exceções (art. 95 do CPP) – Alegações Finais Escritas (art. 404, parágrafo

	único, do CPP) – Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP) – Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP)
No Procedimento dos Crimes contra a Honra	– Ação Penal Privada, Queixa-Crime (arts. 30, 41 e 44 do CPP) – Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, Queixa Supletiva ou Queixa Subsidiária (art. 5.º, LIX, da CF c/c o art. 29 do CPP) – Exceção da Verdade (art. 523 do CPP) – Resposta do Acusado (art. 396-A do CPP) – Exceções (art. 95 do CPP) – Alegações Finais Escritas (art. 404, parágrafo único, do CPP) – Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP) – Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP)
No Procedimento da Lei de Tóxicos (Lei 11.343/2006)	– Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, Queixa Supletiva ou Queixa Subsidiária (art. 5.º, LIX, da CF c/c o art. 29 do CPP) – Defesa Preliminar (art. 55 da Lei 11.343/2006) – Exceções (art. 95 do CPP c/c o art. 55, § 2.º, da Lei 11.343/2006)

	– Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP) – Habeas Corpus (art. 5.º, LXVIII, da CF c/c o art. 647 do CPP)
Do Direito Líquido e Certo	– Mandado de Segurança (art. 5.º, LXIX, da CF)

2.6.1.16 Quadro sistemático das contracautelas

Prisão Ilegal	Contracautela
	Relaxamento de Prisão (art. 5.º, LXV, da CF) ¹⁴

Prisão Legal	Contracautela
– Em Flagrante	Liberdade Provisória (arts. 5.º, LXVI, da CF, e 310 c/c o art. 321 do CPP)
– Prisão Preventiva	Revogação da Prisão Preventiva (art. 316 do CPP)
Prisão Temporária Lei 7.960/1989	Não possui, pois é a única prisão cautelar que tem prazo certo e determinado e independe de alvará de soltura. Art. 2º da Lei 7.960/1989: A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Art. 2.º, § 4.º, da Lei 8.072/1990: A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei n.º 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso

	de extrema e comprovada necessidade. (Incluído pela Lei 11.464, de 2007)
Habeas Corpus	Remédio Jurídico Constitucional que serve para todas as situações acima expostas.

2.6.2 Endereçamentos

a) para o Delegado de Polícia:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA TITULAR DA DELEGACIA DE _____ DO ESTADO _____

b) para Juízes de 1.^a Instância:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA _____ DO ESTADO _____

c) para o Juizado Especial Criminal:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO ____ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA _____ DO ESTADO _____

d) para as Turmas Recursais:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA ____ TURMA RECURSAL DA COMARCA _____ DO ESTADO _____

e) para o Tribunal do Júri:

e.1) 1.^a Fase do Júri: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DO ____ TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA _____ DO ESTADO

e.2) 2.^a Fase do Júri: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ-PRESIDENTE DO ____ TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA _____ DO ESTADO

f) para o Juiz da Vara de Execuções Penais:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA _____ VARA DE EXECUÇÕES PENAS

g) para o Juiz do Juizado de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO ____ JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA _____ DO ESTADO _____

h) para o Tribunal de Justiça:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO _____

i) para o Juiz Federal:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA __VARA CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO _____ DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL _____REGIÃO

j) para o Tribunal Regional Federal:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA _____REGIÃO

k) para o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

l) para o Supremo Tribunal Federal (STF):

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

2.6.3 Termos empregados

Em geral:

autor → requerente ou demandante

réu → requerido, demandado, acusado

Queixa-crime:

autor → querelante

réu → querelado

Recursos em geral:

polo ativo → recorrente

polo passivo → recorrido

Apelação:

polo ativo → apelante

polo passivo → apelado

Embargos:

polo ativo → embargante

polo passivo → embargado

Exceções:

polo ativo → excipiente

polo passivo → excepto

Habeas Corpus:

autor → Impetrante

sofre a coação → paciente

quem exerce a coação → coator

2.6.4 Prazos no processo penal

Artigo	Tema	Prazo
Art. 10 do CPP	Prazo de duração do inquérito policial – regra geral	10 dias preso / 30 dias solto
Art. 51 da Lei 11.343/2006	Prazo de duração do inquérito policial na Lei de Tóxicos	30 dias preso / 90 dias solto
Art. 66 da Lei 5.010/1966	Prazo de duração do inquérito policial na Justiça Federal	15 dias preso / 30 dias solto
Art. 38 do CPP	Prazo para propositura da queixa-crime	6 meses, a contar da data do conhecimento da autoria
Art. 38 do CPP	Prazo para a representação	6 meses, a contar da data do conhecimento da autoria
	Prazo para oferecimento da	

Art. 38 c/c 29 do CPP	ação penal privada subsidiária da pública	6 meses, a contar da inércia do Ministério Público
Art. 46 do CPP	Prazo para oferecimento da denúncia	5 dias preso / 15 dias solto
Art. 46, § 2.º, do CPP	Prazo para aditamento da queixa	3 dias
Art. 58 do CPP	Prazo para o aceite do perdão	3 dias
Art. 60, I, do CPP	Prazo para a perempção quando o querelante deixa de promover o andamento do processo	30 dias
Art. 60, II, do CPP	Prazo para a perempção quando o querelante morrer ou se ausentar e os substitutos não retomarem a ação	60 dias
Art. 100 do CPP	Resposta do não aceite da exceção de suspeição por parte do juiz	3 dias
Art. 131 do CPP	Levante do sequestro, caso a ação penal não tenha sido intentada	60 dias
Art. 150, § 1.º, do CPP	Duração do exame de insanidade mental	45 dias, prorrogáveis, se necessário
Art. 160, parágrafo único, do CPP	Prazo de elaboração do laudo oficial	10 dias, podendo ser prorrogado

Art. 159, § 5.º, I, do CPP	Resposta dos quesitos ao perito oficial	10 dias com antecedência
Art. 168, § 2.º, do CPP	Laudo complementar para efeitos de classificação da lesão corporal (art. 129 do CP)	30 dias após a data do crime
Art. 185, § 3.º, do CPP	Intimação do interrogatório por video-conferência	10 dias com antecedência
Art. 364 do CPP	Citação por edital	de 15 a 90 dias
Art. 396 do CPP	Prazo para apresentação da resposta do acusado	10 dias
Art. 400 do CPP	Marcação da AIJ no procedimento ordinário	60 dias
Art. 531 do CPP	Marcação da AIJ no procedimento sumário	30 dias
Art. 403 do CPP	Alegações finais orais	20min + 10min
Art. 404, parágrafo único, do CPP	Alegações finais por memoriais	5 dias
Art. 404, parágrafo único, do CPP	Proferir sentença no caso de apresentação de alegações finais por memoriais	10 dias
Art. 409 do	Oitiva do MP no júri após a	

CPP	resposta do acusado	5 dias
Art. 412 do CPP	Prazo do procedimento da 1. ^a fase do júri	90 dias
Art. 477 do CPP	Sustentação oral no júri	1h30 para cada, e 1h de réplica e tréplica. Obs.: mais de um acusador ou defensor dividirão o tempo. Havendo mais de um acusado, + 1h (art. 477, § 2.º, do CPP)
Art. 479 do CPP	Leitura de documento em plenário	3 dias
Art. 514 do CPP	Defesa preliminar nos crimes funcionais	15 dias
Art. 55 da Lei 11.343/2006	Defesa preliminar nos crimes da Lei de Tóxico	10 dias
Art. 2.º da Lei 7.960/1989	Prisão temporária	5 dias + 5 dias, e, se for hediondo, 30 dias + 30 dias (art. 2.º da Lei 8.072/1990)
	Recursos	
Art. 586 c/c 588 do CPP	Recurso em sentido estrito	5 dias / 2 dias (razões)
Art. 593 c/c 600, caput e § 4.º, do CPP	Apelação	5 dias / 8 dias (razões)
Art. 82 da Lei		

9.099/1995	Apelação no Jecrim	10 dias
Art. 609, parágrafo único, do CPP	Embargos infringentes e de nulidade	10 dias
Art. 382 c/c 619 do CPP	Embargos de declaração	2 dias
Art. 83 da Lei 9.099/1995	Embargos de declaração no Jecrim	5 dias
Art. 1.072, IV, do NCPC	Recursos especial e extraordinário	15 dias
Art. 30 da Lei 8.038/1990	Recurso ordinário em HC	5 dias
Art. 640 do CPP	Carta testemunhável	48h

2.6.5 Ressalvas no processo penal

Artigo	Tema	Disposição Legal
Art. 44	Ação penal	Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.
		Art. 74. A competência pela natureza da infração

Art. 74	Competência	será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.
Art. 74, § 2.º	Competência	§ 2.º Se, iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada.
Art. 82	Competência	Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Nesse caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas.
Art. 96	Exceção	Art. 96. A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente.
Art. 116, § 5.º	Competência	§ 5.º Recebidas as informações, e depois de ouvido o procurador-geral, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência.
Art. 119	Restituição de coisas apreendidas	Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Art. 149, § 2.º	Exame de insanidade mental	§ 2.º O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.
Art. 150, § 1.º	Exame de insanidade mental	§ 1.º O exame não durará mais de 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo.
Art. 157, § 1.º	Prova penal	§ 1.º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.
Art. 162	Exame de corpo de delito	Art. 162. A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto.
Art. 184	Exame de corpo de delito	Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.
Art. 206	Testemunha	Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou

		o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.
Art. 207	Testemunha	Art. 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho.
Art. 213	Testemunha	Art. 213. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato.
Art. 231	Documentos	Art. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.
Art. 243, § 2.º	Busca e apreensão	§ 2.º Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito.
Art. 245	Busca e apreensão	Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.
		Art. 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado

Art. 255	Impedimento e suspeição	causa, salvo sobrevivendo descendentes; mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo.
Art. 264	Acusado e defensor	Art. 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de cem a quinhentos mil-réis, a prestar seu patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo Juiz.
Art. 277	Perito	Art. 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de cem a quinhentos mil-réis, salvo escusa atendível.
Art. 284	Prisão e medidas cautelares	Art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso.
Art. 295, X	Prisão especial	X – os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função.
Art. 313, parágrafo único	Prisão preventiva	Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra

		hipótese recomendar a manutenção da medida.
Art. 337	Fiança	Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.
Art. 392, § 2.º	Sentença – intimação	§ 2.º O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo.
Art. 394, § 2.º	Procedimento	§ 2.º Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial.
Art. 397, II	Absolvição sumária	II – a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade.
Art. 411, § 7.º	Júri	§ 7.º Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível à prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer.
Art. 415, parágrafo único	Absolvição sumária no júri	Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.

Art. 427, § 4.º	Desaforamento no júri	§ 4.º Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Art. 429	Organização da pauta no júri	Art. 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência:
Art. 457, § 1.º	Adiamento no júri	§ 1.º Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz presidente do Tribunal do Júri.
Art. 457, § 2.º	Adiamento no júri	§ 2.º Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor.
Art. 461	Adiamento no júri	Art. 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização.
		§ 3.º Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer

Art. 474, § 3.º	Algemas no júri	no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.
Art. 476, § 2.º	Debates no júri	§ 2.º Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação, na forma do art. 29 deste Código.
Art. 535	Procedimento sumário	Art. 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer.
Art. 544	Procedimento autos extraviados	Art. 544. Realizadas as diligências que, salvo motivo de força maior, deverão concluir-se dentro de vinte dias, serão os autos conclusos para julgamento.
Art. 571, II	Nulidades	II – as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e VII do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500.
Art. 579	Fungibilidade dos recursos	Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.
Art. 581, III	Recurso em sentido estrito	III – que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição.

Art. 597	Apelação	Art. 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no art. 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (arts. 374 e 378), e o caso de suspensão condicional de pena.
Art. 600	Razões de apelação	Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias.
Art. 601	Razões de apelação	Art. 601. Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 (cinco) dias, salvo no caso do art. 603, segunda parte, em que o prazo será de trinta dias.
Art. 601, § 2.º	Despesas do traslado	§ 2.º As despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público.
Art. 622	Revisão criminal	Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.
Art. 647	Habeas Corpus	Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.
		§ 2.º Não cabe o habeas corpus contra a prisão administrativa, atual ou iminente, dos

Art. 650, § 2.º	Habeas Corpus	responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à Fazenda Pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal.
Art. 655	Habeas Corpus	Art. 655. O carcereiro ou o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou a autoridade judiciária ou policial que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e apresentação do paciente, ou a sua soltura, será multado na quantia de duzentos mil-réis a um conto de réis, sem prejuízo das penas em que incorrer. As multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor as multas.
Art. 657	Habeas Corpus	Art. 657. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo escusará a sua apresentação, salvo: I – grave enfermidade do paciente; II – não estar ele sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção; III – se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal.
Art. 660, § 1.º	Habeas Corpus	§ 1.º Se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, salvo se por outro

		motivo dever ser mantido na prisão.
Art. 798, § 5.º	Prazos	§ 5.º Salvo os casos expressos, os prazos correrão: a) da intimação; b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte; c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.
Art. 800, § 2.º	Prazo para MP	§ 2.º Os prazos do Ministério Público contar-se-ão do termo de vista, salvo para a interposição do recurso (art. 798, § 5.º).
Art. 803	Prazos	Art. 803. Salvo nos casos expressos em lei, é proibida a retirada de autos do cartório, ainda que em confiança, sob pena de responsabilidade do escrivão.
Art. 806	Custas	Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas.
Art. 806, § 1.º	Custas	§ 1.º Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre.

2.7 A INFLUÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NA PRÁTICA PENAL

2.7.1 Introdução

Com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), em vigor desde 18.03.2016, alguns impactos foram sofridos no Código de Processo Penal. O objetivo nesse momento é delimitar e jamais esgotar as influências na Prática Penal. Algumas, inclusive, são expressas, como é o caso da citação por hora certa, que o próprio CPP nos remete ao CPC.

Não restam dúvidas de tal possibilidade de aplicação subsidiária de normas estranhas ao CPP. Vejamos o art. 3.º do Diploma Processual Penal:

Art. 3.º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

2.7.2 Emendar a inicial

Como sempre estudamos, é consagrada no Processo Civil a possibilidade de emendar a inicial (art. 284 do CPC/1973; art. 321 do novo CPC). Já no Processo Penal, por imposição dos fundamentos do Sistema Acusatório, tal medida sempre fora repudiada, pois o titular da ação penal, o Ministério Público (art. 129, I, da CF), não poderia receber esse “auxílio” ou “ajuda” do juiz de direito, porque, para a qualidade do processo penal, o juiz imparcial é uma imposição. Particularmente, achamos que não merece ser alterada. A luta por um processo penal imparcial não pode sofrer exceções, pois, diferentemente do processo civil, o que está em jogo no processo penal é o bem jurídico mais importante que o ser humano possui, a liberdade. Permitir essa intromissão do magistrado seria transformá-lo em um “amigo” da acusação.

Entretanto, sabemos que a matéria é polêmica e divergente, pois muitos estudiosos ainda acreditam na busca da verdade real, que, para nós, é uma verdadeira utopia, um sonho inalcançável, diríamos. Reproduzir no processo penal o que efetivamente aconteceu é impossível, pois nossa persecução penal é falha, falta contribuição do Poder Público e da própria sociedade em ajudar na apuração de um crime. Basta indagarmos: quem tem prazer ou estímulo para ser testemunha em um processo penal? O orgulho de contribuir com a elucidação do crime é estranho à sociedade como a nossa, o que, diga-se de passagem, é compreensível, pois o próprio Poder Público

esqueceu do Programa Nacional de Proteção às Testemunhas, por exemplo.

Surpreendentemente, não foi essa postura a adotada no RHC 37.587/SC, julgado em 16.2.2016, no Superior Tribunal de Justiça, cuja relatoria foi do Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Percebemos com a análise que fora autorizado o órgão de acusação que apresentou a denúncia a emendar a inicial juntando o rol de testemunhas não arrolado inicialmente. Vejamos:

Pela importância do tema, a transcrição do julgado faz-se necessária:

A intimação do Ministério Público para que indique as provas que pretende produzir em Juízo e a juntada do rol de testemunhas pela acusação, após a apresentação da denúncia, mas antes da formação da relação processual, não são causas, por si sós, de nulidade absoluta. Isso porque, a despeito da previsão legal do momento processual adequado para o arrolamento das testemunhas tanto para a acusação (art. 41 do CPP) quanto para a defesa (arts. 396 e 396-A), aspectos procedimentais devem ser observados pelas partes, devendo-se proceder a uma visão global do todo previsto, interpretando sistematicamente o CPP. E, nos termos do art. 284 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, por força do art. 3.º do Diploma Processual Penal, “Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 dias”, e, acaso se mantenha inerte a parte autora, deverá o magistrado, aí sim, nos termos do parágrafo único do art. 284 do CPC, indeferir a petição inicial. Referida previsão legal foi aprimorada no Novo CPC, o qual dispõe no seu art. 319 que o juiz tem o dever de, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais dos arts. 319 e 320 ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinar ao autor que emende a inicial ou a complemente, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, quando, tão somente após, estará legitimado a indeferir a petição inicial, caso o vício não seja suprimido. Com efeito, o nosso sistema processual é informado pelo princípio da cooperação, sendo pois, o processo, um produto da atividade cooperativa triangular entre o juiz e as partes, no qual todos devem buscar a justa aplicação do ordenamento jurídico no caso concreto, não podendo o magistrado se limitar a ser mero fiscal de regras, devendo, ao contrário, quando constatar deficiências postulatórias das partes, indicá-las, precisamente, a fim de evitar delongas desnecessárias e a extinção do processo sem a análise de seu mérito. Assim, ainda que não observado o referido momento processual adequado para a indicação das provas que pretendia produzir, o que, em tese, pode levar ao reconhecimento da preclusão na prática do referido ato processual, o certo é que o magistrado, verificando a irregularidade na denúncia que pode levar ao seu indeferimento por ser inepta, tem o poder-dever de determinar a intimação da parte para que proceda à correção da petição inicial, sob pena de, não o fazendo, ter que reconhecer nulidade posterior, ensejando o desnecessário ajuizamento de nova ação penal. Vale observar, igualmente, que não se verifica violação do

sistema acusatório, pois, como já ressaltado anteriormente, o juiz, no caso, verificando irregularidade na denúncia que poderia ensejar o reconhecimento de sua inépcia por ausência de condição da ação, intimou o Parquet para que este esclarecesse sua pretensão de produzir provas em juízo, devendo indicá-las em caso positivo, não tendo, em nenhum momento, indicado precisamente qual(is) prova(s) seria(m) esta(s). Logo, sua atividade foi de prevenção de extinção do processo sem julgamento de mérito, e não de substituição da atividade probatória das partes. Ademais, o art. 563 do CPP determina que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar nenhum prejuízo para a acusação ou para a defesa”. E, no caso em análise, a determinação de correção da petição inicial acusatória pelo magistrado, sem a indicação das provas que deveriam ser requeridas pelo Ministério Público, não ensejou qualquer prejuízo ao réu, pois, como já ressaltado, o juiz de primeiro grau abriu vista ao Parquet antes mesmo da intimação e citação do acusado para o oferecimento de resposta à acusação, tendo a defesa amplas possibilidades de contraditar os elementos probatórios até então requeridos, situação que demonstra a inexistência de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa e de qualquer prejuízo ao réu. Vale observar especificamente quanto ao rol de testemunhas que, ainda que o Parquet não tivesse indicado nenhuma testemunha, o juiz, nos termos do art. 209 do CPP, poderia determinar, a qualquer momento do processo, a oitiva daquelas que julgasse necessárias. Além do mais, no sistema processual penal brasileiro, o órgão jurisdicional é o destinatário da prova produzida no processo, uma vez que será o competente para o processo e o julgamento do delito, nos termos preconizados pelo art. 155. Entendimento em sentido diverso viola o próprio princípio do impulso oficial, pois o magistrado, ainda que verifique alguma irregularidade em atos processuais praticados pelas partes, estaria impedido de determinar o seu saneamento, só lhe restando, ao final, reconhecer a nulidade do ato e provocar o desnecessário e evitável ajuizamento de nova ação penal. Por fim, ressalte-se que, de modo distinto, a Sexta Turma, por maioria de votos, nos autos do RHC 45.921/SP (DJe 29.5.2015), reconheceu a impossibilidade do Juiz determinar a intimação do Parquet para que procedesse à inclusão das testemunhas quando verificada a ausência de indicação do respectivo rol e do protesto pela produção das provas na denúncia, sob pena de violação do sistema acusatório e de subversão das fases procedimentais previstas no Diploma Processual.

2.7.3 Princípio da identidade física do juiz

No CPP, a regra do art. 399, § 2.º, é de uma radicalidade admirável. Vejamos: “O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”. A excelente postura legislativa, tardiamente inserida no Código, visa proteger ainda mais o bom andamento do processo penal. Impor que o mesmo juiz coordene a audiência e profira a decisão é, no mínimo, trazer humanidade ao processo penal. Explicamos. Na prática criminal, muitos juízes, assoberbados de trabalho, conhecem e se interagem da causa, na própria audiência, além de avaliar aspectos emocionais, psicológicos e reativos de

todos os depoentes e personagens da causa. Isso, definitivamente, consagrará ainda mais a qualidade de sua decisão final.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça mitigou a imposição legal que não vislumbra exceções. Vejamos:

Reclamação 19873, de 22.06.2016:

Este Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que o antigo art. 132 do Código de Processo Civil aplica-se por analogia ao processo penal, por regras de interpretação que mesmo atualmente permanecem aplicáveis.

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 908462/MG, de 21.06.2016:

O princípio da identidade física do juiz deve ser interpretado sob a ótica do art. 132 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é possível relativizá-lo por motivo de licença, afastamento, promoção, aposentadoria ou outro motivo legal que obste o magistrado que presidiu a instrução de sentenciar a ação penal.

Segundo entendimento desta Corte, a remoção do magistrado está dentro das hipóteses do art. 132 do Código de Processo Civil, configurando exceção à obrigatoriedade de ser o processo-crime julgado pelo juiz que presidiu a instrução.

O detalhe principal é que o mencionado art. 132 do CPC não existe mais com o Novo Código de Processo Civil. Sendo assim, acreditamos que nos próximos julgados veremos a jurisprudência permitir as exceções à identidade física do juiz no processo penal por simples entendimento, para nossa particular tristeza, respeitando-se, evidentemente, opiniões em contrário.

Sobre neutralidade, que não devemos confundir com imparcialidade, destacamos obra do nobre professor Daniel Amorim Assumpção Neves, *Manual de direito processual civil* – Volume Único – Editora JusPodivm – 8ª edição, que assim nos propicia sábias reflexões:

Tampouco deve se esperar a neutralidade do juiz, até porque tal condição é impossível de ser

obtida. O juiz neutro é aquele que não leva para seus julgamentos suas experiências de vida e que não sofre qualquer influência, lícita obviamente, de fora do processo. Tal juiz robótico, além de não existir, não parece ser o mais recomendável. Afinal, somos a soma de nossas experiências pessoais, e carregá-las para os julgamentos torna as decisões mais humanas, proferidas por um magistrado com mais experiência de vida. Por outro lado, o juiz é um ser social, e, como tal, está incluído como membro da coletividade, sendo inevitável que sofra influências de circunstâncias extraprocessos em seus julgamentos.

2.7.4 Prazos

A comunidade foi alegremente surpreendida com a mudança de contagem de prazos no art. 129 do novo CPC. Vejamos:

Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

Infelizmente, tal postura não será aplicada ao processo penal, pois o Diploma Processual possui norma expressa (art. 798 do CPP) no mesmo sentido, não gerando qualquer tipo de lacuna no assunto, aplicando-se, assim, regramento próprio.

Isso posto, no Processo Penal continua-se contando os prazos processuais, ou seja, em síntese: não pode começar, nem terminar aos sábados/domingos/feriados, podendo ser contados no curso de um prazo normalmente, de forma corrida.

Vejamos o regramento próprio:

Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

§ 1.º Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.

§ 2.º A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr.

§ 3.º O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.

§ 4.º Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária.

§ 5.º Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

a) da intimação;

- b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;*
- c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.*

Importante concluir observando que os prazos penais são considerados de forma diferente, contando-se o primeiro dia e excluindo-se o último, por exemplo, nas contagens da prescrição e da queixa-crime.

2.7.5 Citação por hora certa

Assim determina o Código de Processo Penal, em artigo alterado pela reforma processual penal de 2008:

Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.

Percebemos que o art. 362 do CPP nos remete ao Código de 1973 – arts. 227 a 229. Será que a regra com o Novo CPC continua a mesma? Verificaremos que não, já disponibilizando a seguir o novo artigo da citação da hora certa no novo CPC:

Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Verificamos que na antiga redação eram três tentativas; agora são duas. Essa substituição, leia-se atualização, de artigos no CPP é perfeitamente possível, inclusive com autorização legal do novo CPC:

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

2.7.6 Embargos de declaração no Juizado Especial Criminal

O art. 83 da Lei 9.099/1995 passa a ter uma nova redação onde se exclui a possibilidade de embargos de declaração no caso de dúvida da sentença penal. Tal mudança consagra a insegurança trazida na redação original do que seria “dúvida”,

excluindo tal possibilidade.

Art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. (Redação dada pela Lei 13.105, de 2015.)

§ 1.º Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

§ 2.º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. (Redação dada pela Lei 13.105, de 2015.)

§ 3.º Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

2.7.7 Alterações na Lei 8.038/1990

Disposições referentes à reclamação constitucional (arts. 13 e seguintes), recurso extraordinário e especial (arts. 26 e seguintes) da Lei 8.038/1990 foram revogadas pelo novo Código de Processo Civil, aplicando-se a partir de sua vigência os artigos desse diploma.

Vejamos:

Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

I – a exposição do fato e do direito;

II – a demonstração do cabimento do recurso interposto;

III – as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.

§ 1.º Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

§ 2.º (Revogado.)

§ 3.º O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave.

§ 4.º Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão federal constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional, até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto.

§ 5.º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:

I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; (Redação dada pela Lei 13.256/2016.)

II – ao relator, se já distribuído o recurso;

III – ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. (Redação dada pela Lei 13.256, de 2016.)

Já a reclamação, em seu art. 988 do NCPC:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei 13.256, de 2016.)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei 13.256, de 2016.)

§ 1.º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2.º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3.º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4.º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5.º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei 13.256, de 2016.)

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei 13.256, de 2016.)

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei 13.256, de 2016.)

§ 6.º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

-
- 1 Vale observar que tal divisão é feita pelo legislador do Código de Processo Penal segundo o art. 572. tema precisa de uma releitura constitucional e de análises jurisprudenciais, já que o tema de nulidade é um dos que mais vacilam e se alteram em nossos tribunais superiores.
- 2 Após a Lei 7.210/1984 tais decisões são passíveis de Agravo em Execução (art. 66 c/c o art. 197 da 7.210/1984).
- 3 Após a Lei 7.210/1984 tais decisões são passíveis de Agravo em Execução (art. 66 c/c o art. 197 da 7.210/1984).
- 4 Após a Lei 7.210/1984 tais decisões são passíveis de Agravo em Execução (art. 66 c/c o art. 197 da 7.210/1984).
- 5 Inciso revogado pela Reforma Penal de 1984.
- 6 Após a Lei 7.210/1984 tais decisões são passíveis de Agravo em Execução (art. 66 c/c art. 197 da Lei 7.210/1984).
- 7 Após a Lei 7.210/1984 tais decisões são passíveis de Agravo em Execução (art. 66 c/c o art. 197 da 7.210/1984).
- 8 Após a Lei 7.210/1984 tais decisões são passíveis de Agravo em Execução (art. 66 c/c o art. 197 da 7.210/1984).
- 9 Revogado pela Reforma Penal de 1984.
- 10 Após a Lei 7.210/1984 tais decisões são passíveis de Agravo em Execução (art. 66 c/c o art. 197 da Lei 7.210/1984).
- 11 Após a Lei 7.210/1984 tais decisões são passíveis de Agravo em Execução (art. 66 c/c o art. 197 da Lei 7.210/1984).
- 12 Após a Lei 7.210/1984 tais decisões são passíveis de Agravo em Execução (art. 66 c/c o art. 197 da Lei 7.210/1984).
- 13 Revogado pela Reforma Penal de 1984.
- 14 A doutrina e a prática penal vêm interligando o Relaxamento aos casos de Prisões em Flagrante Ilegais.

PROCEDIMENTOS

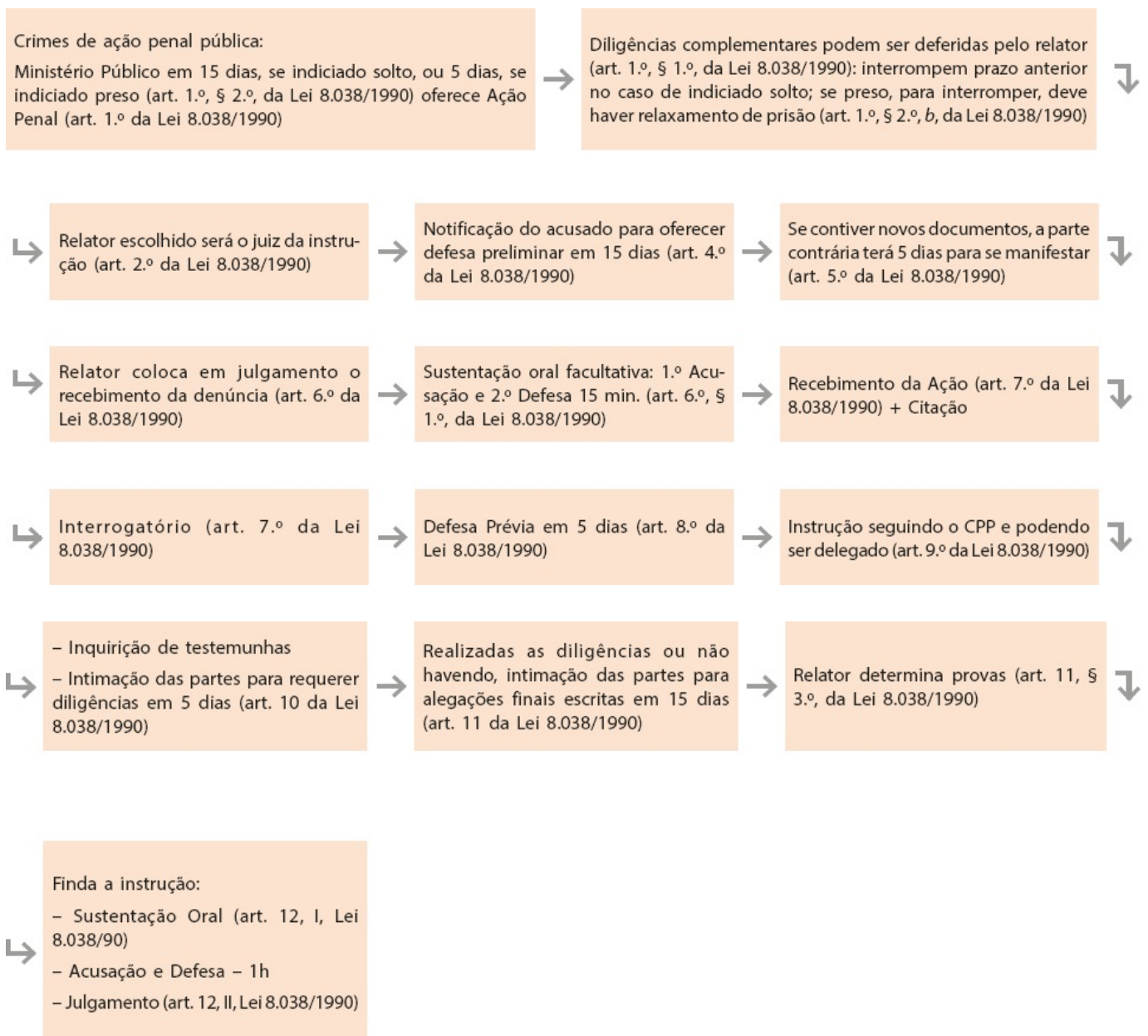
Visualizemos os procedimentos em razão da grande importância deles para o respectivo trabalho, sem antes determinarmos quando serão utilizados e destacando desde já, conforme a nova Lei 13.285/2016, a prioridade para os crimes hediondos, acrescentado pelo novo art. 394-A no Código de Processo Penal. Vejamos:

Art. 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias.

Procedimento – Lei 8.038/1990 STF-STJ	Detentores de Foro Privilegiado – Ações penais originárias
Procedimento do Tribunal do Júri (art. 406 e seguintes do CPP)	Crimes dolosos contra a vida (tentados e conexos)
Procedimento Sumaríssimo do Juizado Especial Criminal (art. 69 e seguintes da Lei 9.099/1995)	Crimes de menor potencial ofensivo (pena máxima em abstrato até dois anos)
Procedimento Especial dos Crimes Praticados por Funcionário Público (art. 513 e seguintes do CPP)	Funcionários públicos (art. 327 do CP) cometendo crimes funcionais (art. 312 e seguintes do CP)
Procedimento Especial dos Crimes contra a Honra (art. 519 e seguintes do CPP)	Crimes contra a honra que extrapolam a pena máxima abstrata em dois anos
Procedimento Especial da Lei de Tóxicos (Lei 11.343/2006)	Crimes da Lei 11.343/2006

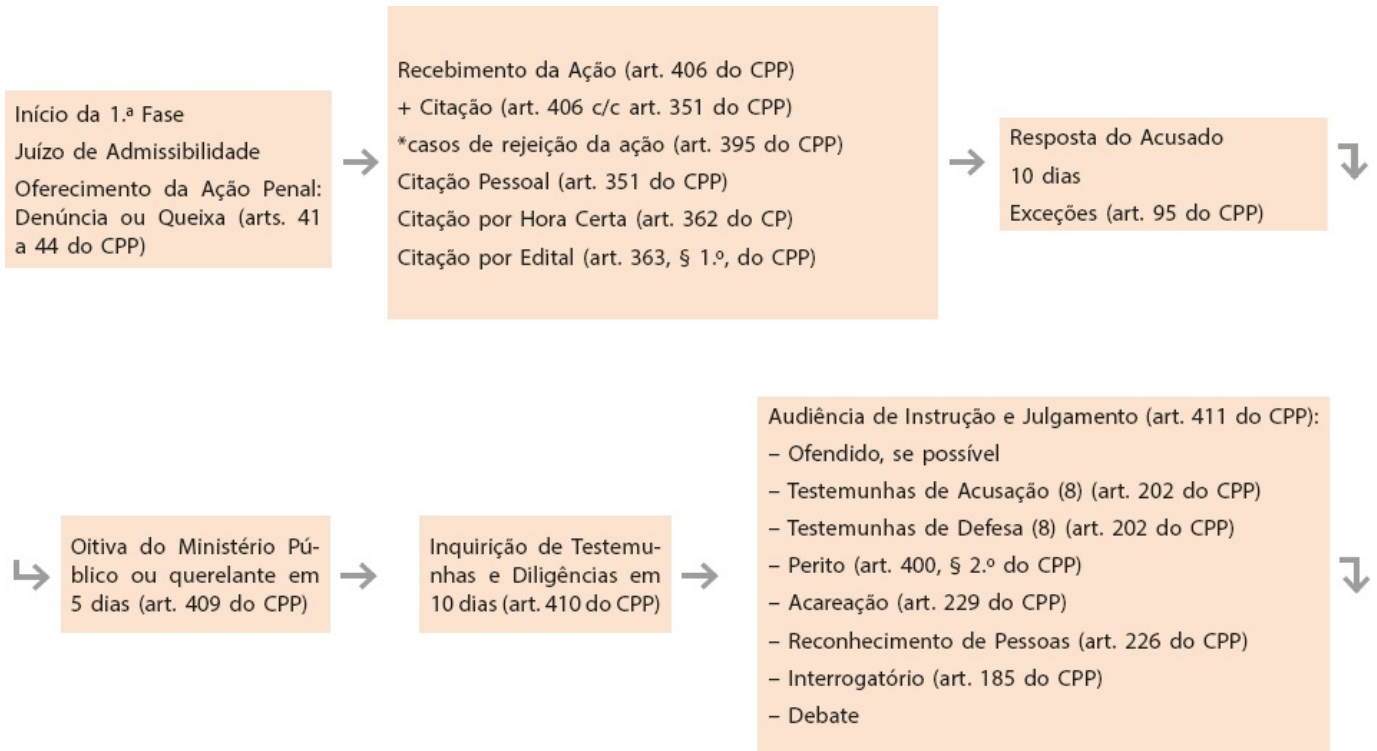
Procedimento Ordinário (art. 394 e seguintes do CPP)	Crimes cuja pena máxima em abstrato seja igual ou superior a quatro anos
Procedimento Sumário (art. 531 e seguintes do CPP)	Crimes cuja pena máxima em abstrato seja inferior a quatro anos

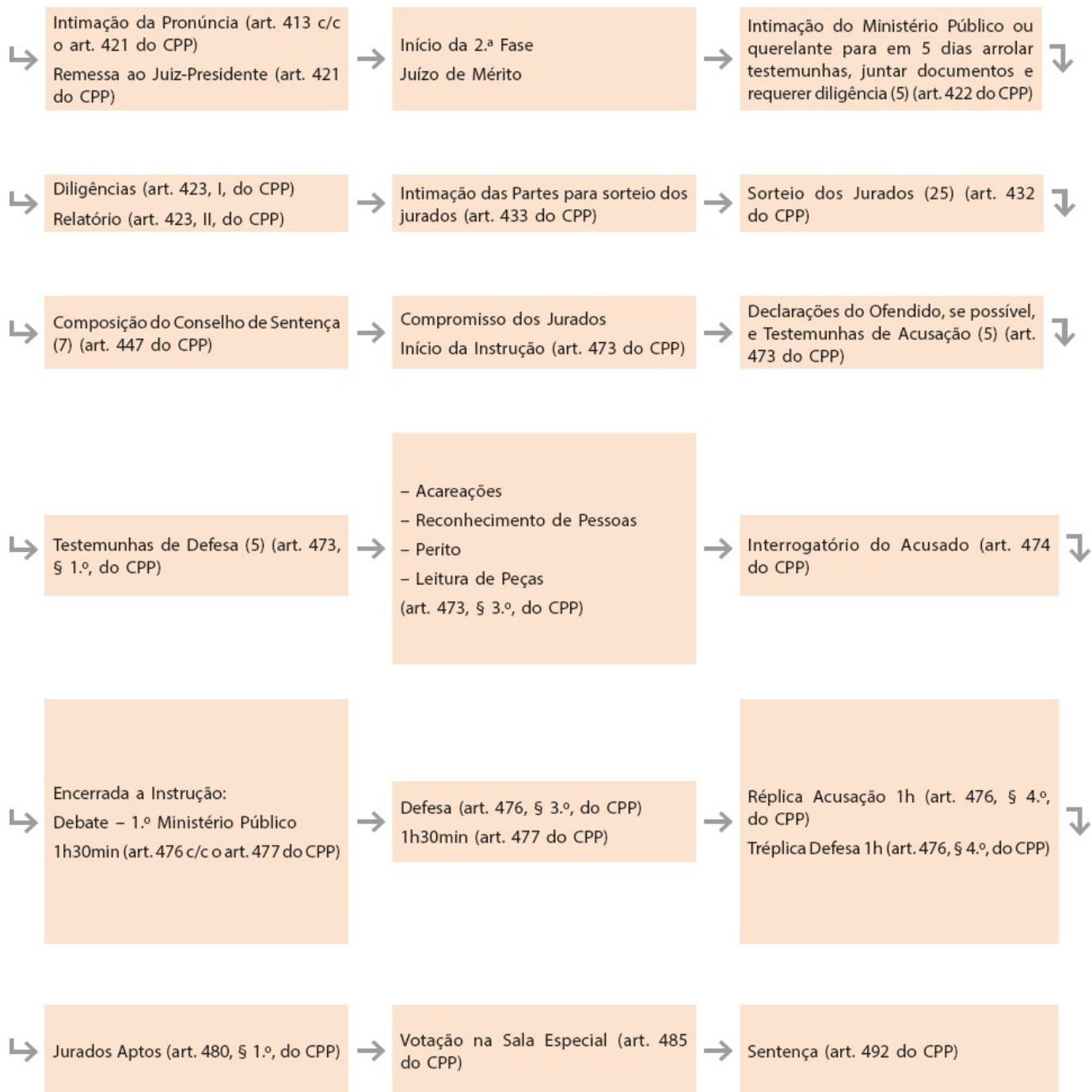
PROCEDIMENTO DOS CRIMES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PERANTE O STJ E O STF – LEI 8.038/1990



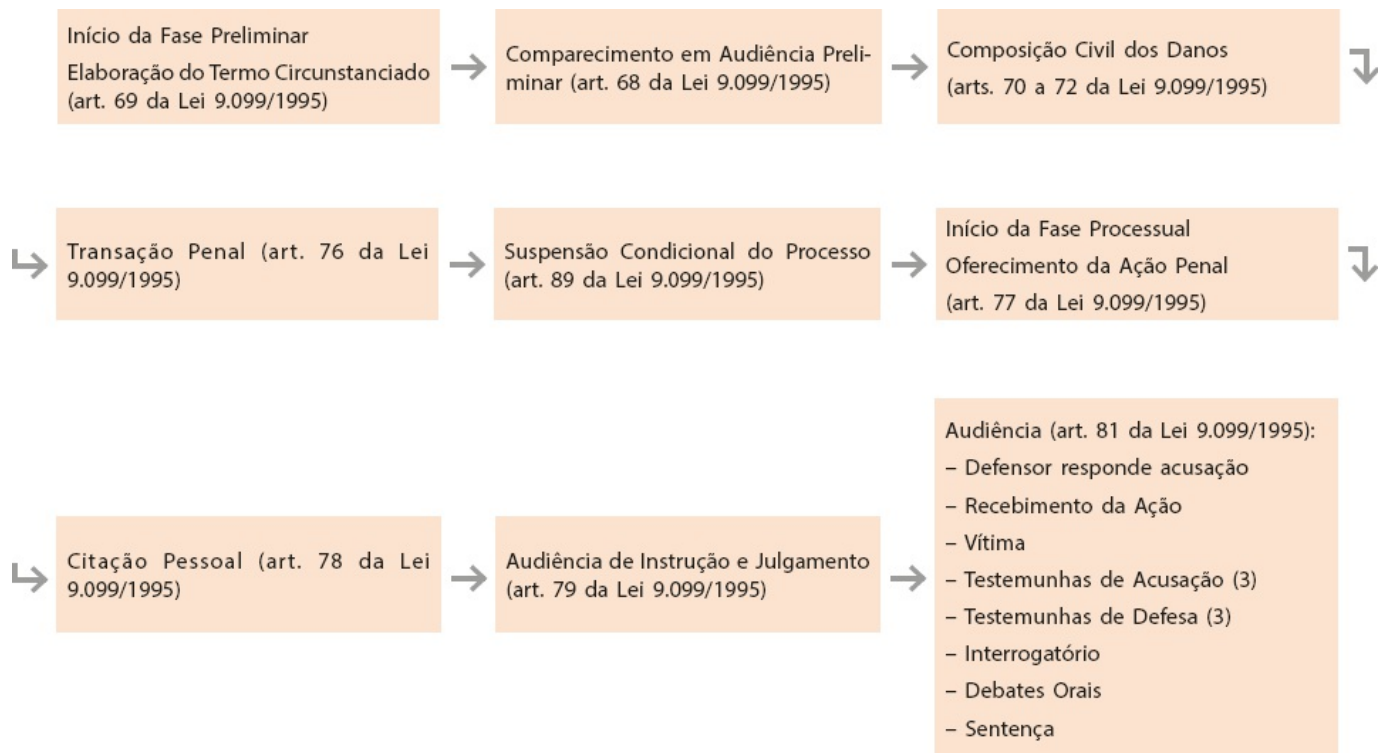
PROCEDIMENTO TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 5.º, XXXVIII, DA CF C/C ART. 406 DO CPP

(Aplica-se aos crimes dolosos contra a vida – Art. 121 e seguintes do CP)



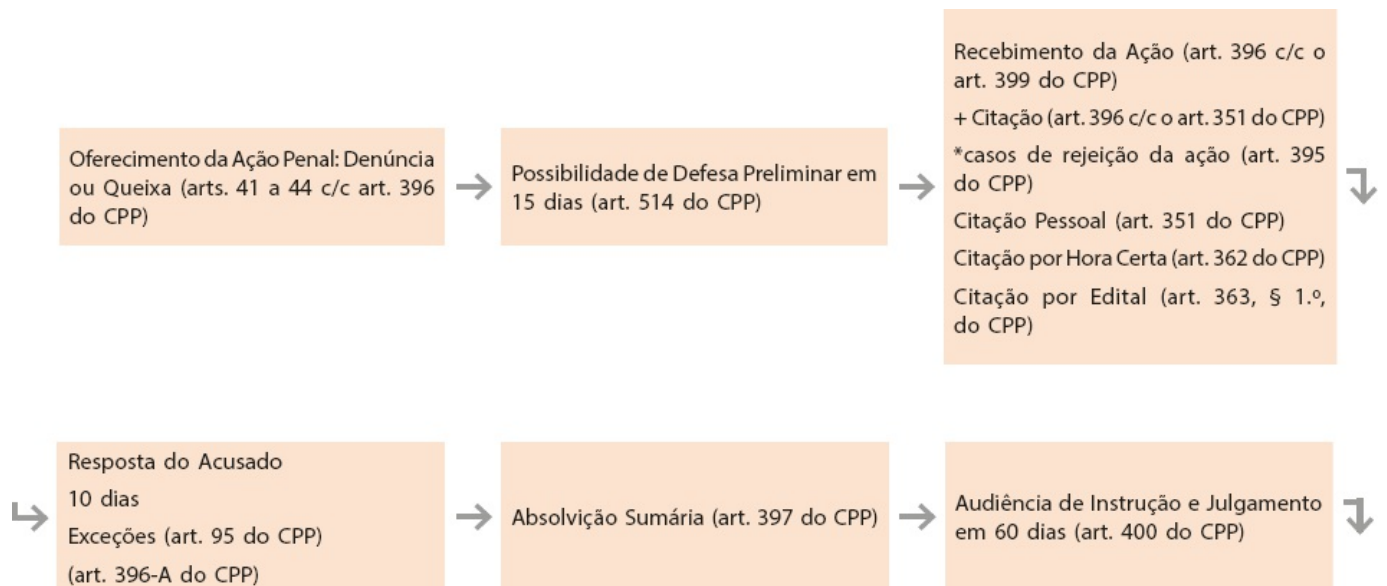


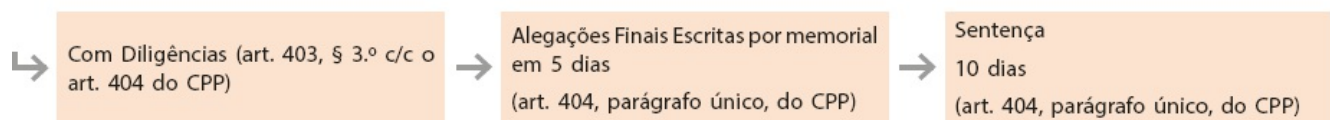
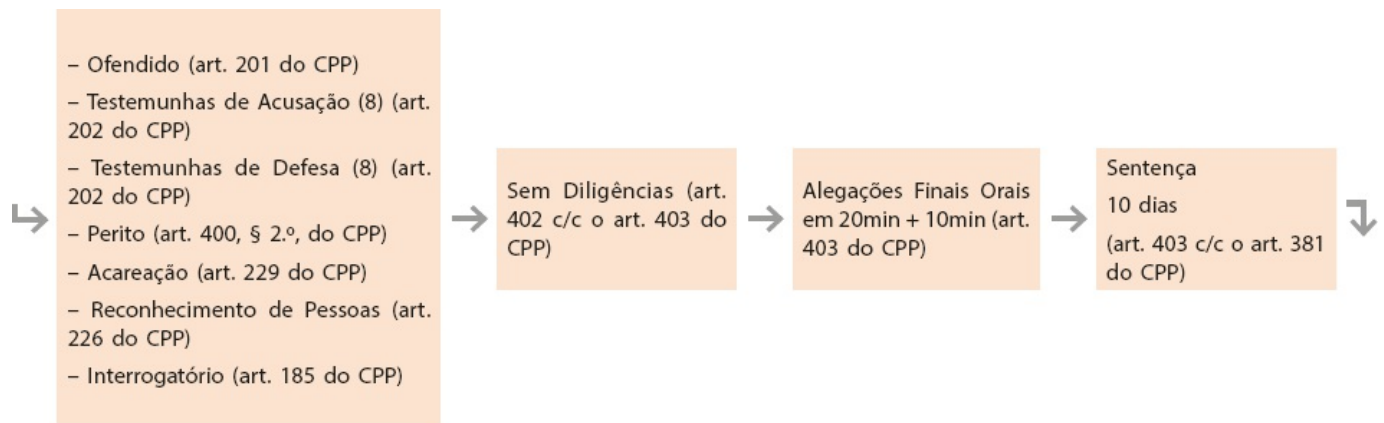
PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO – ART. 98, I, DA CF C/C ART. 394, § 1.º, III, DO CPP
(Aplica-se aos crimes de menor potencial ofensivo – Lei 9.099/1995)



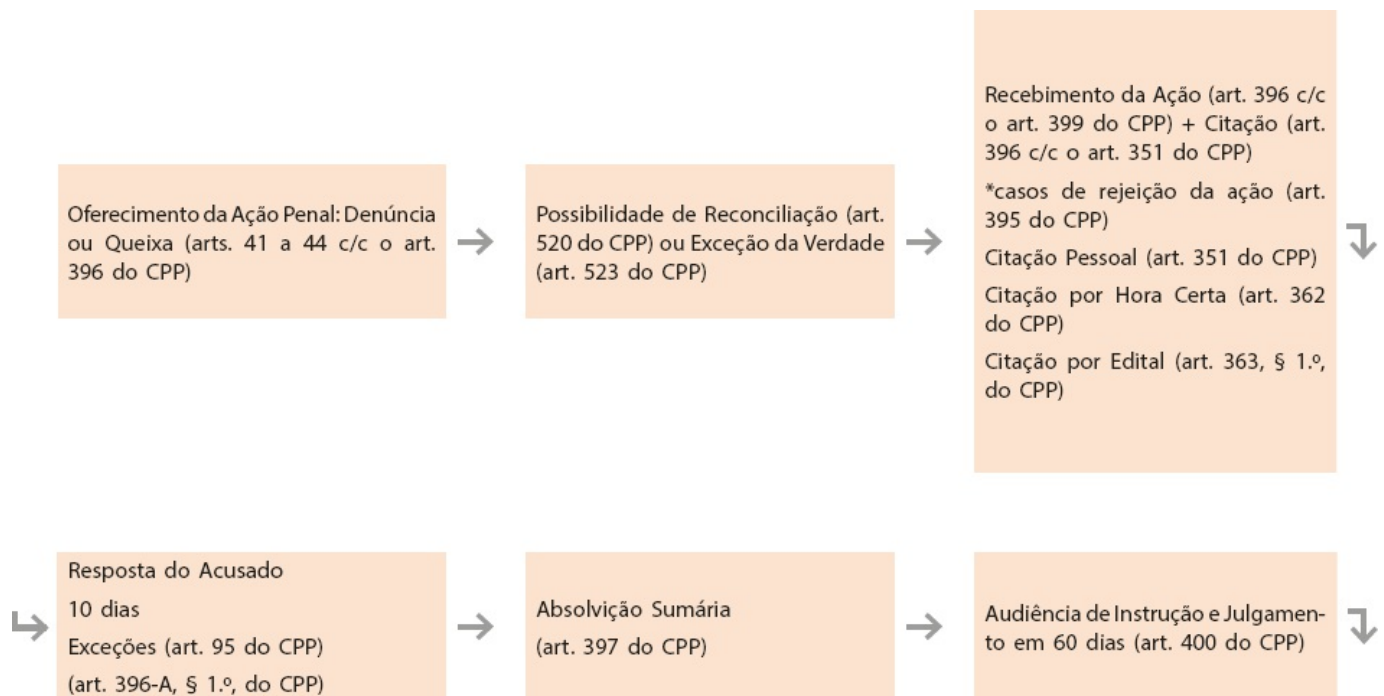
PROCEDIMENTO DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS – ART. 513 DO CPP

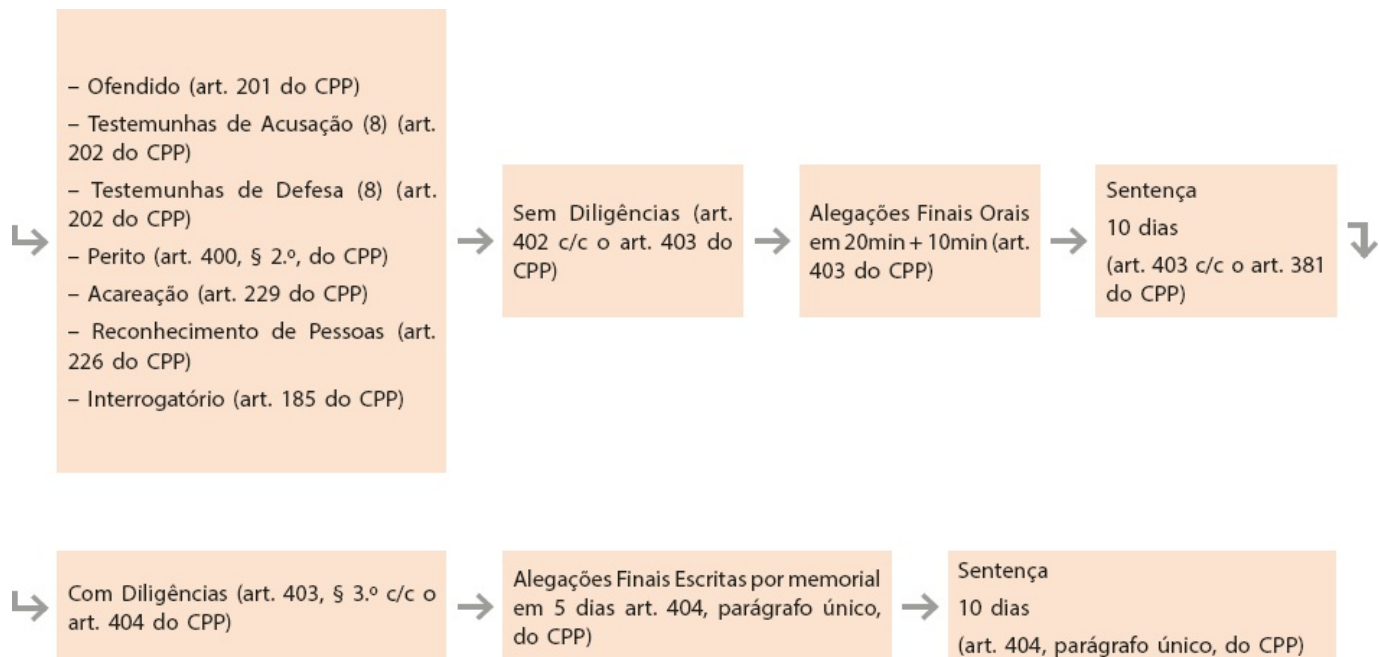
(Aplica-se aos crimes funcionais afiançáveis – art. 312 e seguintes do CP)



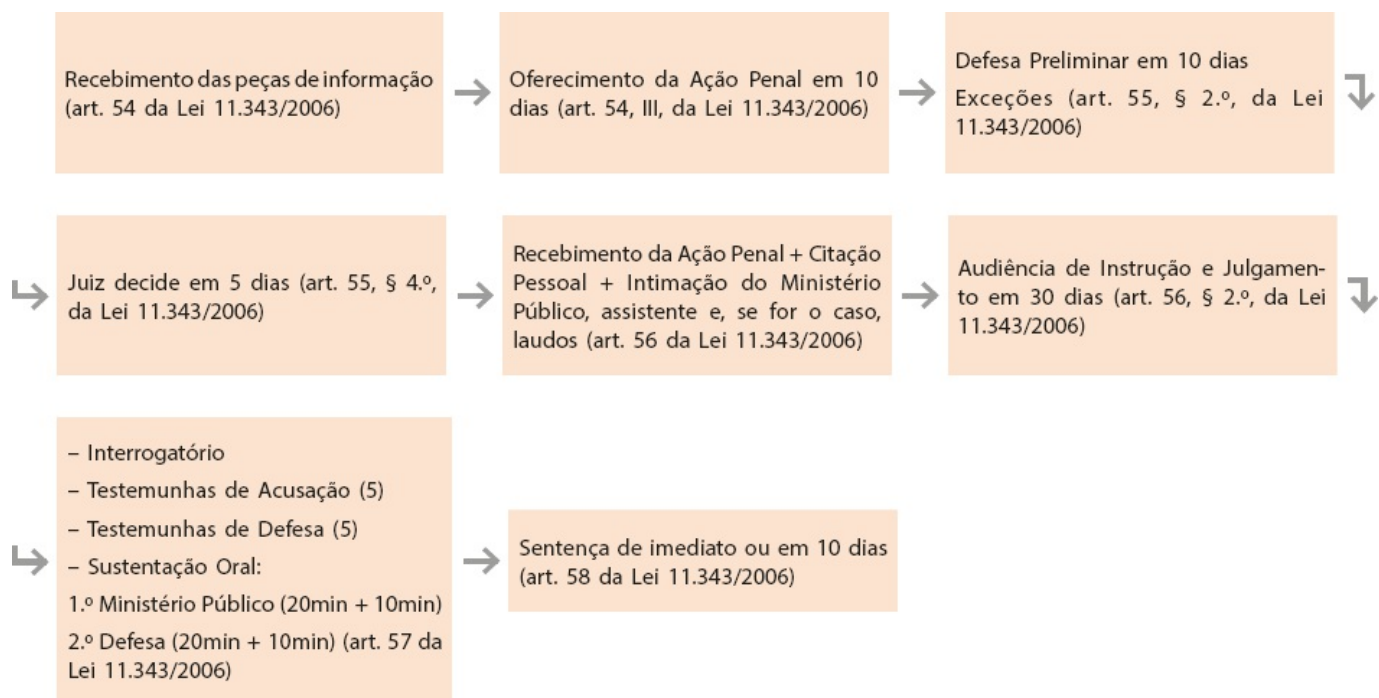


PROCEDIMENTO DOS CRIMES CONTRA A HONRA – ART. 519 DO CPP (Aplica-se aos arts. 138, 139, 140 e seguintes do CP)



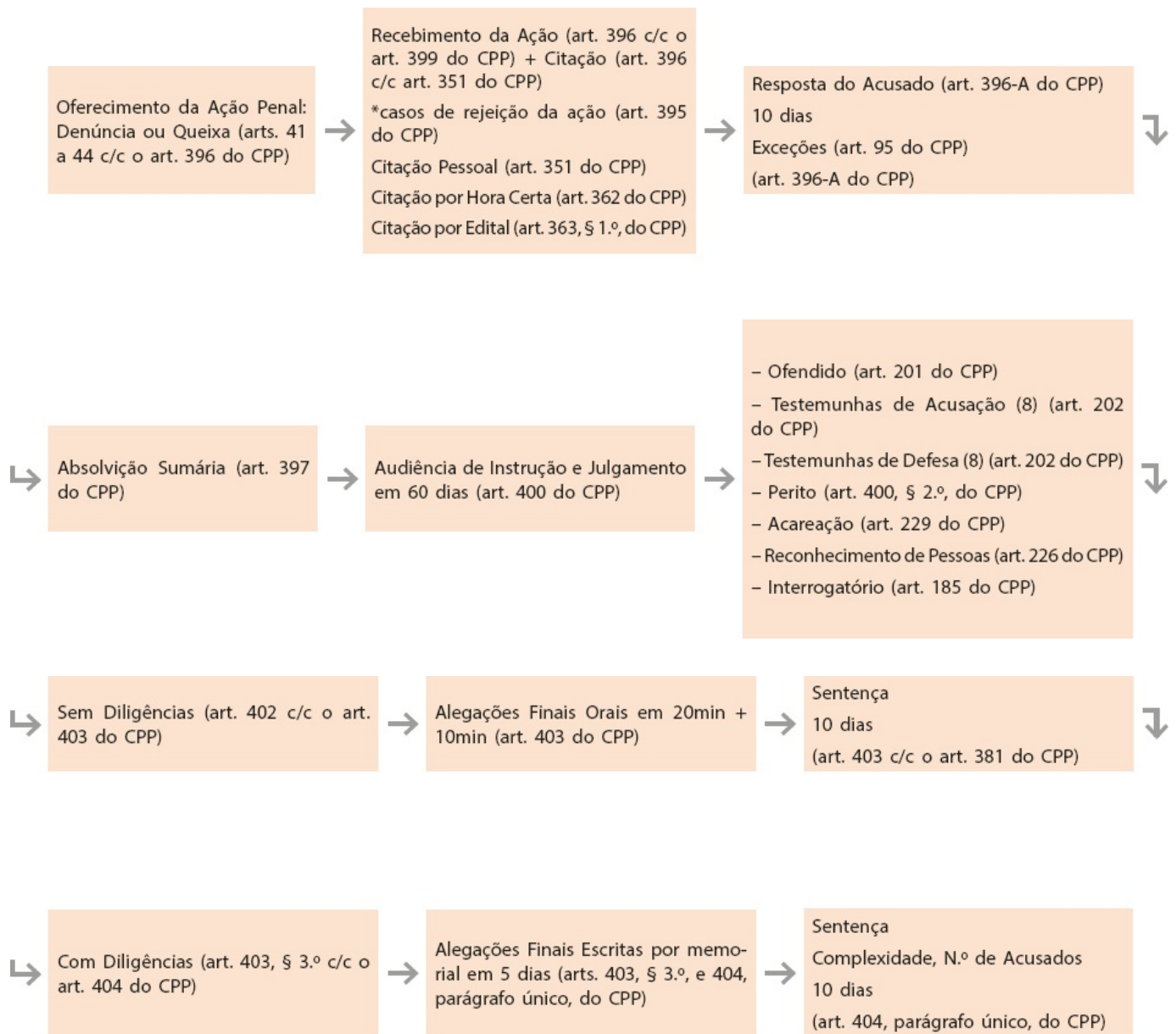


PROCEDIMENTO DOS CRIMES DA LEI DE TÓXICOS – LEI 11.343/2006¹

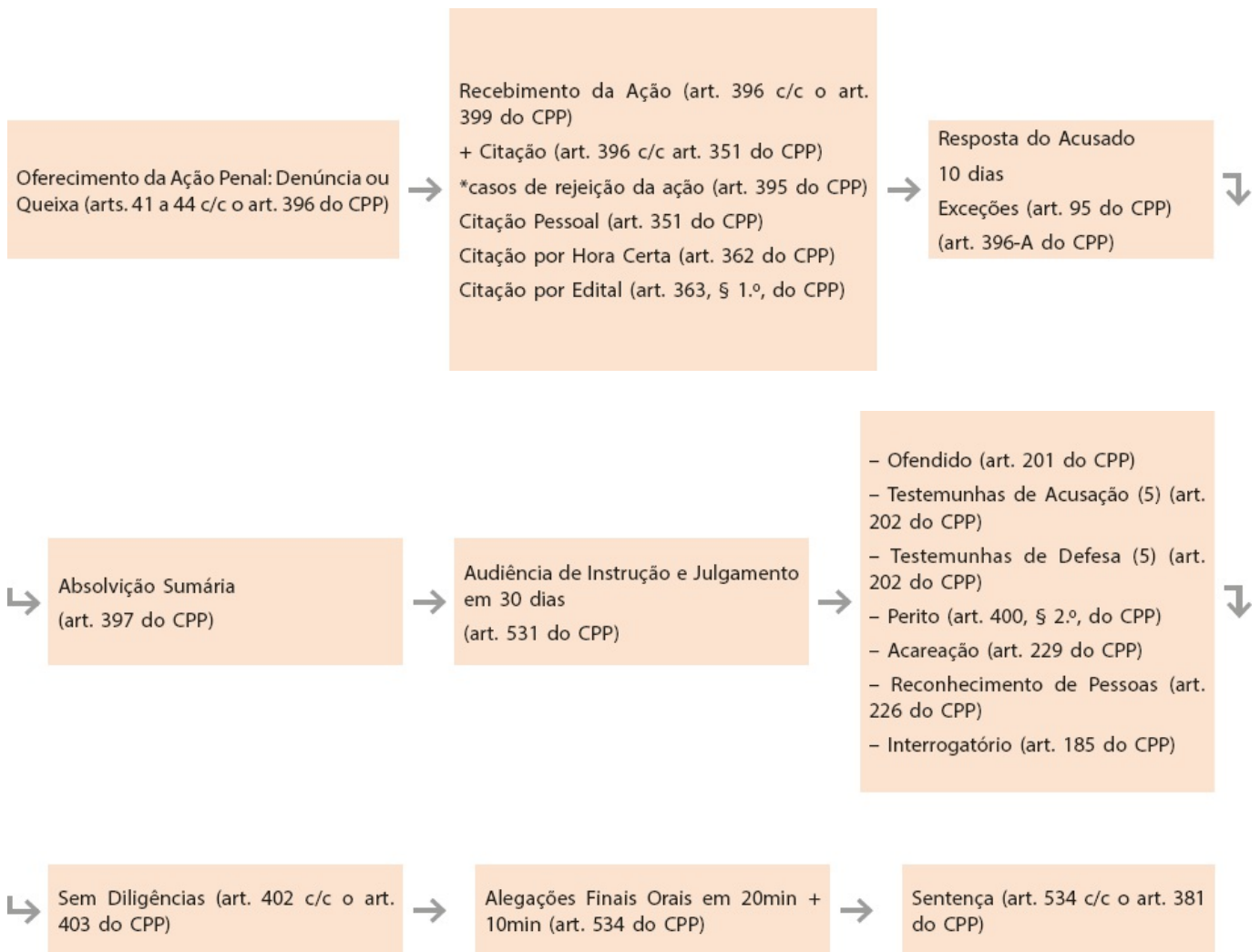


PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – ART. 394, § 1.º, I, DO CPP

(Aplica-se aos crimes cuja pena máxima for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade)



PROCEDIMENTO SUMÁRIO – ART. 394, § 1.º, II, DO CPP
(Aplica-se aos crimes cuja pena máxima seja inferior a quatro anos de pena privativa de liberdade)



¹ Importante destacar quanto ao procedimento da lei de drogas, no Informativo 816 do Supremo Tribunal Federal, em 03.03.2016, HC 127900/AM, que a Corte permitiu, também nesse procedimento, o deslocamento do interrogatório para o final da instrução, por influência lógica da reforma de 2008 e, sem dúvidas, para prestigiar o bom andamento da persecução penal.

COMO IDENTIFICAR A PEÇA

A estrutura de nossa obra se orienta por roteiros e acreditamos veementemente que a boa técnica exige calma, paciência, serenidade e organização, demonstrada nesse instante por meio do seguinte roteiro para identificação da peça prático-profissional:

1.º	Identificação do Procedimento
2.º	Visualização do Procedimento
3.º	Leitura Acompanhada do Procedimento
4.º	Peça Identificada
5.º	Acusação ou Defesa?
6.º	Elaboração do Endereçamento, Titularidade e Dos Fatos
7.º	Investigação das Preliminares
8.º	Pesquisa dos Fundamentos
9.º	Nem sempre absolvição é o objetivo
10.º	Colocação da Data, se exigido

1.º ☒ **Identificação do Procedimento**

Nossa metodologia está, basicamente, enraizada na identificação da peça com base nos procedimentos penais. Além disso, iremos, num primeiro momento de leitura da questão apresentada, nos ater apenas à identificação do procedimento. Senão

vejam.

A primeira leitura tem apenas o intuito de identificar o procedimento. Nesse momento o candidato não deve se preocupar, ainda, com eventuais teses e estudos do direito material. O confronto de ideias pode ser prejudicial à realização da prova.

A identificação do procedimento é feita por exclusão.

Estamos diante de uma eventual competência originária? Algum dos envolvidos possui prerrogativa de função? Atente-se às carreiras cujas atribuições estão na Constituição e que garantem ao seu detentor o chamado foro privilegiado, já visto. O procedimento dos Tribunais Superiores tem disposição na Lei 8.038/1990, que será objeto de exame nos próximos capítulos.

Na negativa da primeira indagação, verificaremos se é caso ou não de um crime doloso contra a vida. Só avançaremos nos estudos dos procedimentos tendo em vista a negativa de indagações anteriores. Assim, estamos diante de um feito, de um delito cuja competência é do Tribunal do Júri (art. 5.º, XXXVIII, da CF c/c o art. 406 e seguintes do CPP)?

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Por ser uma competência constitucional, devemos nos cercar desse cuidado num primeiro momento. Lembre-se de que estamos falando dos crimes cujas disposições legais estão a seguir transcritas:

Homicídio simples

Art. 121. Matar alguém:

Pena – reclusão, de seis a vinte anos.

Caso de diminuição de pena

§ 1.º Se o agente comete o crime impellido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Homicídio qualificado

Feminicídio

§ 2.º Se o homicídio é cometido:

I – mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II – por motivo fútil;

III – com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

V – para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;

VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:

VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição:

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

§ 2.º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I – violência doméstica e familiar;

II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Homicídio culposo

§ 3.º Se o homicídio é culposo:

Pena – detenção, de um a três anos.

Aumento de pena

§ 4.º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

§ 5.º Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

§ 6.º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.

§ 7.º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado:

I – durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;

II – contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência;

III – na presença de descendente ou de ascendente da vítima.

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.

Parágrafo único. A pena é duplicada:

Aumento de pena

I – se o crime é praticado por motivo egoístico;

II – se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência.

Infanticídio

Art. 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após:

Pena – detenção, de dois a seis anos.

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento

Art. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque:

Pena – detenção, de um a três anos.

Aborto provocado por terceiro

Art. 125. Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:

Pena – reclusão, de três a dez anos.

Art. 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante:

Pena – reclusão, de um a quatro anos.

Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.

Forma qualificada

Art. 127. As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte.

Art. 128. Não se pune o aborto praticado por médico:

Aborto necessário

I – se não há outro meio de salvar a vida da gestante;

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro

II – se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.

Vale ressaltar, lembrando regra principal de competência, que eventuais crimes

cuja competência não seria do Tribunal do Júri podem ser julgados por esse tribunal baseadas nas regras de conexão e continência. O Tribunal do Júri, muita das vezes, é considerado foro de atração de demais delitos.

Posteriormente, e não sendo caso de crime doloso contra a vida, veremos se a questão nos apresenta um crime de menor potencial ofensivo. A competência do Juizado Especial Criminal também é constitucional, segundo o art. 98, I, da CF:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

O conceito de crime de menor potencial ofensivo tem disposição infraconstitucional e foi sacramentada com alteração ordenada pela Lei 11.313/2006 na própria Lei 9.099/1995, em seu art. 61:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei 11.313, de 2006)

Além disso, sobre esta competência, outra confirmação das mais interessantes por parte da Lei 11.313/2006 foi a certeza de que todos os crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, cuja pena máxima não ultrapasse dois anos, serão de competência do Juizado Especial Criminal, seguindo, portanto, o procedimento sumaríssimo trazido pela Lei 9.099/1995.

Finalizando com a terceira novidade da Lei 11.313/2006, num eventual concurso de crimes ou num eventual confronto de competências constitucionais, a competência constitucional mais abrangente prevalecerá sobre esta do Juizado, todavia não se esquecendo de institutos despenalizadores da Lei 9.099/1995. Essa regra está disposta no art. 60, parágrafo único, da Lei 9.099/1995:

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem

competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. (Redação dada pela Lei 11.313, de 2006)

Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. (Incluído pela Lei 11.313, de 2006)

Assim, respeitamos a segurança jurídica da reunião processual, não se esquecendo das medidas despenalizadoras, essência do procedimento sumaríssimo.

Da mesma forma que passamos pelas análises procedimentais dos Tribunais Superiores, do Tribunal do Júri e do Juizado Especial Criminal, competências essas constitucionais, o candidato só deve analisar os procedimentos infraconstitucionais caso a questão não traga nenhuma das competências *supra*.

Ressalte-se que o art. 109 da CF também deve ser analisado para efeitos de competência, pois a competência da Justiça Federal também é constitucional absoluta geral, mas, para efeitos de identificação da peça, essa análise fica em segundo plano, importando mesmo na questão do endereçamento.

Passemos às análises infraconstitucionais.

Primeiramente, devemos nos preocupar com os procedimentos especiais. Vejamos:

- Procedimento dos Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos: arts. 513 e seguintes do CPP.
- Procedimento dos Crimes contra a Honra: arts. 519 e seguintes do CPP.
- Procedimento Especial da Lei de Tóxicos: Lei 11.343/2006.

Em relação aos crimes contra a honra devemos ter cuidado. Isso porque os crimes contra a honra, em suas modalidades simples, são de menor potencial ofensivo, prevalecendo, portanto, a competência constitucional do Juizado Especial Criminal. Vejamos os respectivos crimes em todas as suas particularidades legais.

Calúnia

Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

§ 1.º Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.

§ 2.º É punível a calúnia contra os mortos.

Exceção da verdade

§ 3.º Admite-se a prova da verdade, salvo:

I – se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível;

II – se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no n.º I do art. 141;

III – se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.

Difamação

Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Exceção da verdade

Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

Injúria

Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1.º O juiz pode deixar de aplicar a pena:

I – quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;

II – no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

§ 2.º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 3.º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Redação dada pela Lei 10.741, de 2003)

Pena – reclusão de um a três anos e multa.

Disposições comuns

Art. 141. As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

I – contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;

II – contra funcionário público, em razão de suas funções;

III – na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria;

IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. (Incluído pela Lei 10.741, de 2003)

Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a

pena em dobro.

Exclusão do crime

Art. 142. Não constituem injúria ou difamação punível:

I – a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador;

II – a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar;

III – o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício.

Parágrafo único. Nos casos dos ns. I e III, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade.

Retratação

Art. 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena.

Art. 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.

Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2.º, da violência resulta lesão corporal.

Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3.º do art. 140 deste Código. (Redação dada pela Lei 12.033, de 2009)

Assim, em se tratando de crime contra a honra, será obedecido o procedimento especial do Código de Processo Penal quando superar, em sua pena máxima abstrata conjugada com alguma causa de aumento ou com algum outro crime contra a honra, mais de 2 anos.

A calúnia (art. 138 do CP), com qualquer causa de aumento (art. 141 do CP), seria um primeiro caso, pois, juntando os dois anos de pena máxima em abstrato com as causas de aumento, a competência do Juizado deve ser descartada.

A injúria qualificada (art. 140, § 3.º, do CP), cuja pena máxima em abstrato é de três anos, também seria uma outra hipótese.

E, seguindo a doutrina majoritária, num eventual concurso de crimes cuja soma das penas em abstrato exorbite os dois anos exigidos para a configuração do crime de menor potencial ofensivo.

Não sendo nenhuma das competências constitucionais, com seus respectivos procedimentos, e não sendo os procedimentos especiais acima elencados, partimos para a análise dos procedimentos ordinário e sumário.

O procedimento ordinário é o mais abrangente de todos. Para sabermos qual procedimento adotar, merece aplausos novidade trazida pela Lei 11.719/2008. O legislador seguiu a tese vencedora ao determinar o procedimento com base na pena máxima em abstrato. Vejamos o art. 394 do CPP:

Art. 394. O procedimento será comum ou especial. (Redação dada pela Lei 11.719, de 2008)

§ 1.º O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo: (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

I – ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade; (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

II – sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade; (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

III – sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

§ 2.º Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial. (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

§ 3.º Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos arts. 406 a 497 deste Código. (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

§ 4.º As disposições dos arts. 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

§ 5.º Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

Assim, identificado o procedimento, vamos ao segundo passo. Evidentemente que, se ainda não tivermos processo instaurado, estaremos diante da fase de investigação ou de propositura de ação penal, cujos momentos reduzem bastante o número de peças exigidas.

2.º ☒ Procedimento

Vale a pena colocarmos na folha de rascunho, de forma resumida, a ordem procedimental que poderá ser perfeitamente visualizada com a abertura da legislação. Nesse ponto, a linha do tempo com pontos procedimentais destacados facilita a

identificação da peça.

3.º ☒ Leitura Acompanhando a Linha do Tempo Procedimental

Ainda não é o momento de se preocupar com teses defensivas. Acompanhando o enunciado com o procedimento à frente, o candidato terá perfeitamente noção do caminho percorrido pelo examinador e que o levará à peça correta, ou seja, o ponto futuro, o que fazer. Por isso o candidato deve ter consciência de que a análise dos procedimentos é de extrema necessidade para a identificação correta da peça. Todos os procedimentos abordados serão colocados a seguir.

4.º ☒ Peça Identificada

Com a peça identificada, um grande passo é dado rumo à excelência de realização da prova. Com o respectivo artigo referente à peça jurídica, o candidato já começa a refletir acerca dos mandamentos, dos requisitos gerais e de eventuais particularidades de determinadas medidas judiciais.

5.º ☒ Defesa ou Acusação?

A atuação da advocacia criminal não se restringe apenas à defesa. Assistência de acusação ou acusação nas ações penais privadas são possíveis no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, identificar o polo da demanda é importante para não incidirmos em erro fatal.

6.º ☒ Elaboração de Parte da Peça

Vimos também que a divisão de preocupações no momento da prova é importante para ganharmos tempo e para não esquecermos detalhes que tiram ponto. Com o procedimento e a peça identificados, sem nos preocupar ainda com argumentos jurídicos, passaremos a redigir a peça jurídica diretamente na folha oficial.

Notemos que a preocupação agora é com endereçamento, espaços, qualificações, artigos jurídicos e em descrever os fatos de forma jurídica, em parágrafos, de maneira organizada e sistemática.

Assim, grande parte da peça já estará na folha original, dando-se atenção em não copiar literalmente os fatos e jamais inventar.

7.º ✕ Pesquisa das Preliminares

Adotarmos uma postura constitucional já é um bom começo para sabermos se o problema nos trouxe uma preliminar ou não. No caso da resposta à acusação, dos arts. 396 e 396-A do CPP e 406, § 3.º, do CPP no Júri, deve-se inicialmente verificar se temos alguma exceção (art. 95 do CPP). Explicamos. É nesse momento que a defesa deve apresentar essa medida defensiva.

Num segundo plano, se forem Alegações Finais Escritas por Memoriais, Apelações ou Recursos em Sentido Estrito, seguiremos, de forma objetiva, as seguintes análises: extinções da punibilidade (art. 107 do CP), principalmente a prescrição, as garantias constitucionais (art. 5.º da CF) e o instituto das nulidades (art. 563 do CPP).

Tivemos preocupação em nossa obra em apresentar um capítulo específico sobre as preliminares.

8.º ✕ Pesquisa de Mérito

Seguindo, logicamente, nossa diretriz dos melhores argumentos em ordem de preferência, o rascunho agora deve ser utilizado para uma melhor visualização dos fundamentos encontrados. Colocar em forma de tópicos pode ser uma ótima alternativa, além de visualizar antes no rascunho a melhor forma de concordância e regência para ser colocada na folha original.

Esse é o momento em que o candidato, muito provavelmente, perderá um pouco mais de tempo. É o cerne da questão, o que vale mais, e por isso merece atenção redobrada. Utilizar o maior tempo da prova nos fundamentos é a postura mais inteligente, todavia, conseguimos verificar muitas perdas de tempo no que chamamos de parte mecânica da peça, ou seja, endereçamento, titularidade, nome da peça, fundamento legal e fatos. Tal parte é mecânica, sem invenções e hesitações, e, por isso, deve ser feita diretamente na folha original de forma certa.

9.º ☒ Nem sempre absolvição é a solução

Deve-se ter razoabilidade, bom senso e proporcionalidade nas argumentações. O impossível não pode ser alcançado na vida profissional do advogado criminalista.

10.º ☒ Colocação de Data na Prova

Vale observar que em determinadas situações o examinador exige a contagem do prazo por parte do candidato. Geralmente pede para que a peça seja protocolada no último dia do prazo. Assim, merece atenção por parte do candidato esse detalhe.

Remetemos o leitor ao capítulo referente aos prazos existentes em processo penal.

REQUISITOS E ESTRUTURA DAS PEÇAS

O que não pode faltar em nenhuma peça jurídica em âmbito criminal? Qual seria a estrutura nuclear para toda e qualquer medida cabível? Vejamos, com os respectivos comentários a seguir.

1.º	Endereçamento
2.º	Titularidade
3.º	Fundamento Legal
4.º	Nome da Peça
5.º	Fatos
6.º	Mérito
7.º	Pedido
8.º	Autenticação
9.º Para os Recursos, em regra	Folha de Rosto = Juízo de Admissibilidade e Folha de Razões = Juízo de Mérito
10.º Para algumas peças	Preliminares

1.º ☒ Endereçamento

Acreditamos que a colocação do endereçamento sem abreviações é a melhor

medida a ser adotada numa prova. Mostra sobriedade, preocupação e organização. Demonstramos tal preocupação em capítulo anterior, colocando todos os endereçamentos padrões na forma completa. Todavia, alertamos que, em determinados enunciados fornecidos nos casos prático-profissionais, a questão já nos oferece o endereçamento. Nesse caso, a sua cópia é exigida para que se evite uma eventual identificação da resposta.

2.º ☒ Titularidade

Tal informação, polos ativo e passivo da ação, é fornecida no enunciado, não trazendo nenhuma dificuldade, bastando apenas copiá-la.

Uma ressalva! Nas ações penais inaugurais é sempre prudente colocarmos a qualificação completa. Neste ponto acreditamos em duas possibilidades à escolha do candidato: após o nome, mencionar a qualificação completa ou inserir todas as qualificações possíveis numa peça exordial. Eis as hipóteses:

- a) Fulano de Tal (qualificação completa) vem, ...
- b) Fulano de Tal, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da carteira de identidade n.º _____, inscrito sob o CPF/MF n.º _____, residente e domiciliado à _____.

É evidente que, se os dados forem fornecidos, para não identificarmos a resposta, a cópia literal será, sem sombra de dúvidas, a postura mais segura. Jamais devemos inventar numa resposta.

Já em relação ao polo passivo, adotemos a seguinte postura, muito simétrica em relação à que foi vista acima: colocar apenas a qualificação ou inserir todos os dados qualificatórios. A ressalva é que, segundo o art. 41 do CPP, não precisamos, nesse momento inaugural, ter todos os dados de qualificação. Inclusive, o dispositivo nos permite colocar apenas sinais característicos para a identificação. Vejamos o mencionado artigo com as respectivas formas de titularidade.

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

- c) Fulano de Tal (qualificação) vem, ...
- d) Fulano de Tal, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da carteira de identidade n.º _____, inscrito sob o CPF/MF n.º _____, residente e domiciliado à _____.

Outrossim, se já estivermos após o momento da propositura da ação, podemos optar pelo “já devidamente qualificado”. Assim:

- e) Fulano de Tal, já devidamente qualificado, vem, ...

Todavia, acreditamos que, em qualquer caso, se o examinador nos fornecer dados qualificatórios, independentemente do momento processual, estes deverão ser colocados.

3.º ☒ **Fundamento Legal**

Toda peça prático-profissional possui um artigo legal correspondente a ela, e obrigatoriamente deve ser inserido no corpo da peça em seu início.

4.º ☒ **Nome da Peça**

Destacar o nome da peça não significa escrever de forma diferenciada. Escreva em letra maiúscula centralizado e dê um espaço de duas linhas para cima e duas linhas para baixo. Nada mais do que isso.

(linha)

(linha)

NOME DA PEÇA

(linha)

(linha)

Após esta última linha, a redação continua sem dar parágrafo.

5.º ☒ **Fatos**

Todos os dados são fornecidos; sendo assim, com base neles desenvolveremos

nossa peça.

Cada um adota a melhor forma de apresentação. Eis alguns exemplos:

Dos Fatos:

1 – Dos Fatos;

I – Dos Fatos;

A) Dos Fatos;

Tal postura de organização facilita a correção, por isso deve ser desenvolvida.

Em seguida, iniciemos a redação, que, como já vimos, para se ganhar tempo, deve ser feita diretamente na folha original. O rascunho será utilizado para a elaboração dos fundamentos jurídicos a seguir.

Recomendamos utilizar parágrafos enxutos, objetivos, com uma informação única. Não estamos diante de uma redação ou escrevendo um romance. A melhor técnica jurídica exige que coloquemos os fatos narrados de forma sucinta, separando em cada parágrafo uma ideia fornecida. Bem interessante também utilizarmos uma linha temporal, uma cronologia na disposição dos fatos. Primeiro os fatos, que chamamos de fatos propriamente ditos, ou seja, a descrição da conduta criminosa e todas as circunstâncias trazidas. Em seguida, ainda no campo “Dos Fatos”, iniciemos os fatos processuais caso eles estejam na leitura da questão.

Outra possibilidade seria informarmos primeiro, em parágrafo inicial, a acusação para depois passar a dispor sobre os fatos propriamente ditos e os fatos processuais.

Lembre-se de que estamos trazendo no presente capítulo os requisitos comuns a todas as peças, assim, é exigido que sigamos a disposição correta dos fatos.

Evite cópia literal dos fatos narrados. Isso demonstra falta de vocabulário e de objetividade. Talvez algumas informações desnecessárias sejam colocadas na questão. Saiba identificá-las para não perder preciosos minutos. O candidato deve ter em mente que, se tiver que perder tempo na questão prática, que seja na análise dos fundamentos, primeiro porque geralmente são difíceis de serem encontrados e, segundo, porque são atribuídos mais pontos pelo corretor. Os fatos são fornecidos,

por isso quanto maior o enunciado, maior será a exigência em relação ao poder de síntese do candidato.

6.º ☒ Mérito

Chegamos ao coração da questão. O ponto mais valioso da peça jurídica. Todos os conhecimentos jurídicos devem ser trazidos nesse instante. Nossa única preocupação agora é analisarmos juridicamente os dados. A caneta foi deixada de lado, metade da peça já foi colocada na folha original e nossa única preocupação agora é fundamentar. Os espaços já foram colocados, a peça já foi identificada, os titulares devidamente inseridos, os fatos objetivamente narrados, a letra está legível e com uma apresentação, por que não, agradável?

Com o rascunho, iniciemos o esboço de nossa investigação. Em capítulo anterior, quando vimos a postura do advogado criminalista, pudemos perceber melhores teses que deverão ser vistas inicialmente.

Estrutura Típica
Estrutura Ilícita – Excludentes
Estrutura Culpável – Excludentes
Desclassificação

Evidentemente, cada questão tem suas particularidades, mas já é um bom começo.

Em relação à disposição dos fundamentos, aplica-se aqui o mesmo que foi dito para os fatos. Seguem exemplos de como apresentar esse tópico na sua peça jurídica:

Dos Fundamentos Jurídicos:

2 – Dos Fundamentos;

B – Dos Fundamentos;

II – Dos Fundamentos;

Do Direito.

Novamente, parágrafos enxutos, sóbrios, simples, escrita clara, precisa. Caso seja necessário colocarmos algum artigo transcrito nesta parte, fica ao alvedrio de cada um. Pode ser continuamente, na linha seguinte ou até mesmo, como alguns sugerem para uma boa apresentação, da metade da folha em diante, gerando, assim, um maior destaque.

É nesse momento que devemos demonstrar toda a capacidade de raciocínio jurídico que está sendo avaliada pelo examinador. Colocar os melhores fundamentos jurídicos inicialmente é regra obrigatória no campo prático penal. Talvez a análise de um argumento inicial impeça o magistrado de analisar o restante, tendo em vista o reconhecimento deste fundamento, que poderíamos chamar de “mais forte”. Colocá-los no rascunho pode nos ajudar a identificar um argumento melhor antes do outro. Paciência e bom senso nessa hora são fundamentais.

Pode ser que a pesquisa torne a questão difícil, assim, recomendamos que, na dúvida entre colocar um argumento duvidoso ou não, fiquemos com esta última medida. Errar na ausência é uma tática mais inteligente do que errar no excesso e, talvez, não corramos o risco de arruinar a questão.

Além disso, a língua portuguesa deve ser cuidadosamente respeitada. Nos fundamentos, como a redação é livre, gerando uma maior possibilidade de erros gráficos e gramaticais, o cuidado deve ser redobrado. Esboçar no rascunho a frase é medida das mais acertadas. A concordância e a regência deverão ser, todos eles, motivo de preocupação.

7.º ☒ Pedido

Deve-se escrever o que se quer, o quanto se quer, o mais direto possível, sem rodeios, sem explicações, sem delongas, sem prolongar a escrita. “Isto Posto Requer” é a melhor opção.

O pedido é o espelho das argumentações jurídicas colocadas nos fundamentos. A colocação dos pedidos na ordem dos fundamentos demonstra organização e estrutura jurídica. Vale observar que nesse momento as explicações devem ser deixadas de lado, pois já foram inseridas durante as fundamentações. Nesse instante, o pedido

direto é o mais acertado.

Vejamos algumas fórmulas de disposição:

Do Pedido:

3 – Do Pedido;

C) Do Pedido;

III – Do Pedido;

Isto posto requer:

8.º ☒ Autenticação

Momento oportuno para finalizarmos a peça. Quando o examinador não nos fornece nenhum dado, o ideal é que sejamos o mais neutro possível, ou seja, não devemos colocar nenhuma informação que possa comprometer a identificação da peça. Vejamos:

Nestes Termos,

Pede Deferimento,

Município, Data

Advogado

Outrossim, se for informado o local da conduta delitiva, ou até mesmo exigido que se determine algum prazo, as informações corretas devem ser inseridas.

Jamais se deve assinar a prova ou colocar nomes fictícios.

9.º ☒ Para os recursos, folha de rosto e folha de razões

Este último requisito geral é específico da maioria dos recursos. Maioria, pois, caso as razões recursais sejam impetradas diretamente no juízo julgador, não se faz necessário apresentação de folha de rosto. Outrossim, o recurso de Embargos de Declaração não é necessário por um simples motivo: o juízo que irá julgá-lo é o mesmo que prolatou a decisão obscura, contraditória, ambígua, duvidosa (arts. 382 e

619 do CPP e art. 83 da Lei 9.099/1995).

Juridicamente falando, a folha de rosto tem o objetivo de cumprir com o juízo de admissibilidade do recurso, ou seja, verificar se aquele recurso será conhecido ou não, se naquela situação específica cabe o recurso interposto. Analisado sempre pelo juízo que prolatou a decisão, daí reside o endereçamento na folha de rosto para este juízo determinado.

Conforme os graus de jurisdição vão avançando, os juízos de admissibilidade vão ficando cada vez mais rigorosos. No recurso em sentido estrito (art. 581 do CPP), por exemplo, basta verificarmos se a decisão impugnada está dentre as 24 decisões dispostas no mencionado artigo. Na verdade, alguns incisos desse artigo atualmente são impugnados via Agravo em Execução (art. 66 da Lei 7.210/1984) e o inciso XXIV foi revogado pela Reforma Penal de 1984. Todavia, esse juízo de admissibilidade se reveste de simplicidade.

Já quando estamos falando de Recurso Especial (art. 105, III, da CF), por exemplo, devemos demonstrar o prequestionamento, que poderíamos conceituar como a exigibilidade em se provar que a matéria já foi motivo de análise judiciária nas instâncias inferiores. A matéria a ser levada ao Superior Tribunal de Justiça, via Recurso Especial, não pode inovar no campo decisório, necessariamente será um novo reexame.

Geralmente, durante a elaboração da prova, o candidato utiliza a primeira página como folha de rosto e as demais como folha de razões. Essa é, aliás, a melhor forma, a nosso ver, de apresentação de um recurso.

Nas folhas de razões, seguiremos a mesma linha vista páginas atrás. Começaremos pelo endereçamento, passando pelos fatos, dispondo acerca dos fundamentos e concluindo com pedido e autenticação. Por isso, requisitos comuns e gerais.

Devemos nos atentar para um detalhe, o endereçamento na folha de razões não segue o endereçamento da folha de rosto. Nesta, o endereçamento se demonstra mais simples, geralmente fazendo referência às Câmaras, Tribunais, Ministros, Desembargadores. Vejamos exemplo ilustrativo de folha de razões de um Recurso Extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Em todos os recursos

colocaremos o número do processo, da origem, do recorrente e do recorrido, informações essas, que, se conhecidas, precisam ser colocadas.

Essa apresentação inicial da folha de razões recursais deve ser finalizada com um simples parágrafo explicativo sobre a decisão e o inconformismo em relação a ela. Nada muito elaborado.

Egrégio Tribunal,

Colenda Turma,

Excelentíssimos Ministros,

Processo n.º: _____

Origem: _____

Recorrente: _____

Recorrido: _____

RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Parágrafo Explicativo

10.º ☒ Preliminares, para algumas peças

Preliminares são matérias que devem chegar ao conhecimento do magistrado antes da análise do mérito, pois em alguns casos estas podem impedir a análise dos fundamentos. Vejamos quais são as mais comuns:

Exceções (art. 95 do CPP), nos casos de Resposta do Acusado

Extinção da Punibilidade (art. 107 do CP)

Princípios Constitucionais (art. 5.º da CF)

Nulidades (art. 563 do CPP)

As peças mais comuns que apresentam preliminares são:

- a) Resposta do Acusado ou Resposta à Acusação (arts. 396 e 396-A do CPP);¹
- b) Alegações Finais Escritas por Memoriais (arts. 403, § 3.º, e 404, parágrafo único, do CPP);
- c) Apelação (art. 593 do CPP);
- d) Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP).

5.1 PRELIMINARES

A pesquisa das preliminares é uma das principais medidas que devem ser adotadas inicialmente quando da elaboração de uma peça prático-profissional. Poderíamos conceituá-las como questões que não fazem parte do mérito subjetivo da matéria. São situações prévias que determinarão a sorte ou não do julgamento da causa em si.

A matéria processual exige um roteiro, sendo assim, norteando a nossa obra, vejamos breves comentários sobre tais teses anteriores ao coração da questão.

a) Exceções:

Tal incidente de defesa deve ser arguido no momento exclusivo da resposta do acusado, conforme o art. 396-A, § 1.º, do CPP. Com base no princípio da instrumentalidade das formas, tais exceções podem ser inseridas no corpo da resposta do acusado, logo após os fatos, sem o menor desvio de determinação legal.

Vejamos como elas aparecem no Código de Processo Penal:

Art. 95. Poderão ser opostas as exceções de:

I – suspeição;

II – incompetência de juízo;

III – litispendência;

IV – ilegitimidade de parte;

V – coisa julgada.

As duas exceções mais famosas são a de incompetência e a de suspeição. A de incompetência ocorre quando o titular da ação penal ajuíza a demanda em juízo

incompetente. Seria o caso, por exemplo, de um feito que deveria ser ajuizado perante a Justiça Federal (art. 109 da CF) e fora interposto perante a Justiça Comum Ordinária ou até mesmo um caso de menor potencial ofensivo que não fora ajuizado corretamente perante o Juizado Especial Criminal.

Nesse ponto interessante verificamos o crime e suas implicações, além do bem jurídico violado, para sabermos corretamente o juízo competente.

Em um segundo plano, teríamos a exceção de suspeição, tratando-se de uma verdadeira desconfiância pelas partes da imparcialidade do magistrado. Os casos de suspeição estão dispostos no art. 254 do CPP e são facilmente identificados numa peça prático-profissional.

Senão vejamos:

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I – se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II – se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III – se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV – se tiver aconselhado qualquer das partes;

V – se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

VI – se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

b) Extinções da punibilidade (art. 107 do CP):

Iniciemos com as hipóteses de extinção da punibilidade previstas no Código Penal:

Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

I – pela morte do agente;

II – pela anistia, graça ou indulto;

III – pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV – pela prescrição, decadência ou preempção;

V – pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI – pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII – (Revogado pela Lei 11.106, de 2005)

VIII – (Revogado pela Lei 11.106, de 2005)

IX – pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Em capítulo sobre Direito Penal e Processo Penal tivemos a oportunidade de dissertar sobre as extinções de punibilidade, razão pela qual remetemos o leitor ao capítulo próprio.

c) Princípios constitucionais (art. 5.º da CF):

As ofensas constitucionais, em regra, geram nulidades absolutas, pois são matérias públicas, insanáveis, podem ser arguidas a qualquer momento e ofendem a alma da justiça processual.

Deve-se dar atenção especial ao princípio do devido processo legal (art. 5.º, LIV, da CF) e ao da ampla defesa e do contraditório (art. 5.º, LV, da CF), além dos famosos princípios do juiz natural (art. 5.º, LIII, da CF) e da não culpabilidade, também chamado de presunção de inocência (art. 5.º, LVII, da CF).

Tais conceitos e delimitações também foram objeto de análise doutrinária em capítulo próprio referente aos temas de Direito Processual Penal.

d) Nulidades (art. 563 do CPP):

Para entendermos o tema das nulidades, preliminarmente se faz necessário conceituá-las e diferenciarmos ato irregular e ato inexistente.

Ato inexistente seria quando um dos elementos essenciais à formação de um determinado ato jurídico não foi produzido. Uma sentença sem fundamentação é um ato inexistente. Já ato irregular é aquele que determinado desrespeito à formação do ato não gera prejuízo. Este é, inclusive, a principal orientação que devemos ter em relação ao ato nulo. Para se declarar nulidade, deve haver prejuízo, justificativa seja feita com a redação do próprio art. 563 do CPP. Sendo assim, ato nulo é aquele desrespeito na formação do ato que gera prejuízo, tanto para o bom andamento e regularidade processual, quanto para as partes. Imaginemos uma sentença que se fundamenta pela absolvição, mas com dispositivo optando pela condenação.

As nulidades devem ser arguidas em uma peça prático-profissional da forma mais

objetiva possível, sem maiores necessidades de argumentações doutrinárias. Apresentar a nulidade e suplicar pela sua decretação é a postura mais adequada. O art. 564 do CPP deve ser analisado com bastante cuidado, pois o perigo do inciso IV é evidente. Naturalmente, o examinando é movido a mencionar esse dispositivo. Todavia, caso a nulidade seja específica do inciso III e de uma de suas letras, tal preciosismo será exigido. Assim, a pesquisa deve ser feita em duas etapas. Primeiramente, pelo inciso III e suas respectivas letras, e, em caso de ausência do determinado momento, deve-se optar pelo inciso IV.

Finalizemos:

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

I – por incompetência, suspeição ou suborno do juiz;

II – por ilegitimidade de parte;

III – por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

a) a denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante;

b) o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no art.167;

c) a nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 anos;

d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública;

e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa;

f) a sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, nos processos perante o Tribunal do Júri;

g) a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia;

h) a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei;

i) a presença pelo menos de 15 jurados para a constituição do júri;

j) o sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade;

k) os quesitos e as respectivas respostas;

l) a acusação e a defesa, na sessão de julgamento;

m) a sentença;

n) o recurso de ofício, nos casos em que a lei o tenha estabelecido;

o) a intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso;

p) no Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais de Apelação, o quorum legal para o julgamento;
IV – por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.

Parágrafo único. Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas.

¹ Lembrando que tais artigos se referem ao procedimento ordinário, mais amplo e genérico do CPP.

CASOS PRÁTICOS INTRODUTÓRIOS

Neste capítulo, selecionamos as cinco peças mais conhecidas. Serão demonstrados os modelos completos e toda a trajetória de elaboração das seguintes peças prático-profissionais:

- a) Queixa-crime
- b) Resposta do Acusado
- c) Memoriais
- d) Recurso em Sentido Estrito
- e) Apelação
- f) Revisão Criminal
- g) Embargos de Declaração
- h) Agravo em Execução

1.º Enunciado – Queixa-crime:

Em 10 de fevereiro de 2013, um grupo de amigos resolve assistir a uma final de campeonato na casa de Alan e Márcia, um casal que adora receber os amigos. Um dos amigos de Alan, Adriano, traz ao evento o casal Anderson e Aline sem avisar os anfitriões. Coincidência ou não, o “intruso” casal torce para o time adversário de Alan.

Antes do jogo, Anderson e Aline são bem-educados, agradecem a hospitalidade e se mostram ansiosos para a partida. Adriano havia advertido que o anfitrião Alan é um torcedor que não aceita brincadeiras durante o jogo.

Começa a partida e logo no primeiro minuto o time de Alan sofre um gol, fato este

que gera comemoração acalorada por parte de Anderson.

Ao final do 1.º tempo, o time de Alan já perdia por 4x0. Anderson não aguenta e pula, grita e comemora. Alan pede, calmamente, respeito.

Anderson rebate dizendo que só seu pai pode lhe dizer isso e, visivelmente alterado, bate na mesa de centro da sala e a quebra, deixando-a em pedaços, espalhando bebida em vários convidados.

Alan não acredita, já que a mesa era um presente de casamento e pede que Anderson se retire de sua casa, todavia, Anderson, furioso, o xinga de “fresco”. Os amigos retiram imediatamente Anderson e a namorada do recinto.

Adriano, que presenciou tudo com os demais, constrangido, se retira também.

Não foi uma tarde feliz.

Alan o procura, como advogado, para tomar a medida cabível no último dia do prazo.

Resolução do 1.º Enunciado:

Nesta questão apresentada, a primeira percepção é quanto à ausência de procedimento criminal instaurado. Este, como já vimos, é o primeiro passo para identificarmos uma eventual ação penal privada, também chamada de queixa-crime, peça esta que inicia o procedimento.

Entretanto, apenas essa informação não é suficiente para atestarmos com certeza que se trata de uma queixa-crime. Devemos analisar a existência de autorias e vítimas envolvidas, pois a exordial privada é ajuizada em face de alguém determinado. Com a simples leitura, verificamos este segundo sintoma da queixa-crime. Houve uma reunião de amigos e nela se percebe claramente a existência de um autor e de uma vítima.

No mais, finalizando a pesquisa de identificação, percebemos nitidamente a presença de crime contra a honra, o qual é passível de ação penal privada.

Identificada a peça, o momento agora é de leitura atenta para verificar a existência de mais algum crime contra a honra, se há alguma qualificadora ou causa de aumento,

pois o dever da acusação, dentro da razoabilidade e dos limites da questão, é imputar corretamente as condutas perpetradas.

Um cuidado extremamente interessante quando da elaboração da queixa é verificarmos o endereçamento, se para Juizado Especial Criminal, quando se tratar de crimes de menor potencial ofensivo, ou Vara Criminal.

Queixa-crime elaborada:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO ... JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA ... DO ESTADO ...

ALAN, qualificação completa, vem, por seu advogado infra-assinado, cuja procuração com poderes especiais nos moldes do art. 44 CPP segue anexa, oferecer, com base nos arts. 30 e 41 do CPP c/c o art. 100, § 2.º, do CP, tempestivamente, a presente

QUEIXA-CRIME

em face de ANDERSON, qualificação completa, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos:

I – Dos Fatos

Em 10 de fevereiro de 2013, Alan, ora querelante, recebe em sua casa vários amigos para assistirem a uma partida de futebol, dentre eles Anderson, ora querelado.

Durante a partida, Alan se aborrece com Anderson, pois, além de torcerem por times diferentes, Anderson se exaltou e quebrou, propositadamente, uma mesa de centro de propriedade do querelante.

Calmamente, o querelante pede calma e respeito ao querelado, que, ainda assim, o xinga de “fresco” na frente de várias pessoas.

II – Dos Fundamentos

a) Do Crime de Dano (art. 163 do CP):

Narrada acima a postura inadequada de Anderson, querelado, ao destruir a mesa de centro de propriedade de Alan, querelante.

Tal ação configura, claramente, o crime de dano do art. 163 do CP, pois houve destruição da coisa alheia móvel, assim como reza o mencionado tipo penal.

b) Do Crime de Injúria (art. 140 do CP):

A atitude de Anderson não se esgotou no crime comprovado acima, pois houve por parte deste um xingamento contra a honra subjetiva de Alan. Durante a partida de futebol, o querelante foi xingado de “fresco” pelo querelado.

c) Da Causa de Aumento do Crime de Injúria (art. 141, III, do CP):

A injustificada ofensa acima narrada fora produzida na frente de várias pessoas, entre elas

Márcia, Adriano e Aline.

III – Dos Pedidos

Diante do exposto, tendo o acusado infringido o(s) art.(s) 163 e 140 c/c o art. 141, III, da Lei Penal Brasileira, requer a Vossa Excelência:

- a) recebimento da presente ação;
- b) que seja dada vista ao representante do Ministério Público;
- c) seja o mesmo citado para oferecimento de resposta;
- d) seja processado e ao final condenado criminalmente;
- e) que se determine a indenização a título do art. 387, IV, do CPP;
- f) notificação das testemunhas abaixo arroladas.

Termos em que,
Pede Deferimento,

Município, 9 de agosto de 2013.

Advogado
Inscrição n.º

ROL DE TESTEMUNHAS:

Márcio, qualificação

Adriano, qualificação

Aline, qualificação

2.º Enunciado – Resposta do Acusado

Aderbal é enfermeiro em famoso hospital do centro de Florianópolis, Santa Catarina, trabalhando há mais de dez anos no setor de Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Recentemente, dá entrada no hospital Edith, famosa atriz, bela e jovem, em estado crítico, vítima de grave acidente de trânsito. Após intervenções emergenciais, a vítima Edith é colocada na UTI coordenada pelo enfermeiro Aderbal.

Coincidências do destino à parte, Aderbal sempre admirou o trabalho de Edith e nutre uma paixão platônica pela atriz.

Em uma noite relativamente tranquila no hospital, Aderbal entra no quarto onde se encontra Edith e com intenção livre e consciente começa a praticar atos libidinosos e

conjunção carnal com o corpo de Edith que se encontrava imóvel pela aparente, até então, situação de coma.

Já se retirando do corpo da vítima, Aderbal é surpreendido por outro colega enfermeiro que fica extremamente chocado com a situação, começa a gritar e chama os seguranças do hospital.

Aderbal é detido primeiramente pela segurança privada do hospital, que comunica à Polícia, que prende Aderbal, levando-o imediatamente à Delegacia de Polícia. O Delegado adota todas as medidas legais pertinentes ao caso e abre o Inquérito Policial para as devidas investigações, liberando Aderbal para que possa responder em liberdade, já que as suas condições pessoais e circunstâncias peculiares do caso o permitiam.

Ao cabo das investigações, com a devida perícia feita no corpo de Edith, que realmente identifica sêmen do investigado no corpo da vítima, uma constatação chama atenção dos peritos e investigadores:

- a) vítima Edith, no momento do ato, já se encontrava morta com horário de morte em torno de duas horas antes do ato praticado por Aderbal;

Relatório policial feito, o promotor de justiça denuncia Aderbal pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1.º, do CP) perante a Décima Terceira Vara Criminal daquela comarca da capital. O juiz Nelson Nunes, titular daquele cartório, recebe a ação penal, mesmo sendo amigo íntimo de Aderbal desde infância. Comenta inclusive para a esposa que recebeu a ação penal por gostar muito de Aderbal e que a justiça poderá lhe fazer refletir sobre o crime cometido. Ordena, em seguida, primeiramente, a citação por hora certa conforme art. 362, CPP.

Aderbal, preocupado, o contrata como advogado, informando que dois médicos, Carlos e Newton, além da enfermeira Andréia, podem auxiliar na defesa, pois presenciaram tudo e o conhecem desde que entrou no hospital, para apresentar a peça processual cabível, privativa de advogado, ao caso em tela, expondo todas as circunstâncias fáticas e jurídicas possíveis.

Resolução do 2.º Enunciado:

Após a leitura inicial da questão proposta, devemos primeiramente verificar qual o crime imputado ao personagem Aderbal, pois tal informação será preciosa para determinação do procedimento penal, ocasionando assim uma precisão na identificação da peça prático-profissional.

O crime imputado ao acusado é o Estupro de Vulnerável, com disposição no art. 217-A, § 1.º, do CP cuja pena é de 8 a 15 anos. Neste instante, não se deve questionar a imputação feita, já que ainda estamos no processo de identificação da peça prático-profissional.

Com a pena máxima em abstrato em 15 anos e a ausência de procedimento especial para o crime imputado, não restam dúvidas se tratar do Procedimento Comum Ordinário.

Em nossa legislação, o procedimento se encontra a partir do art. 394 do CPP, mencionados inclusive os critérios diferenciadores entre os procedimentos comum ordinário, sumário e sumaríssimo. Vale salientar a interessante postura do legislador com a minirreforma processual de 2008 com as Leis 11.689, 11.690 e 11.719.

Procedimento definido, a leitura agora tem o objetivo de identificar o momento procedimental. As informações fornecidas nos enunciados foram de propositura da ação, do respectivo recebimento e da citação, momento comunicativo este de maior importância na seara penal.

A leitura do art. 396 do Diploma Processual Penal é infalível para identificação da peça prático-profissional, a resposta do acusado, primeira peça defensiva no procedimento comum ordinário, logo após o recebimento e citação:

Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Para elaboração de obrigatória peça, visto que, se não apresentada, será nomeado defensor para sua confecção, conforme art. 396-A, § 2.º, do CPP, devemos, atentamente, elaborar um roteiro conforme o art. 396-A c/c o § 1.º do CPP.

As pesquisas têm a seguinte ordem:

- Exceções (art. 95 do CP);
- Pelo não recebimento da Ação Penal (art. 395 do CPP), seguindo a tendência nossos tribunais superiores, principalmente o STJ, que permite uma verdadeira retratação do recebimento neste instante. Tal permissão pode ser confirmada com a análise do Informativo 522 de Jurisprudência daquela Corte, que transcrevemos em capítulo do modelo desta peça prática;
- Preliminares, consagradas por meio das extinções da punibilidade do art. 107 CP e das nulidades, conforme art. 563 do CPP, que podem se manifestar ou por meio de ofensas constitucionais ou desrespeitos às formalidades exigidas em atos jurídicos;
- No mérito, a busca única e possível pela absolvição sumária do art. 397 do C
- Provas, em especial a testemunhal, já que normalmente nos enunciados verificamos nomes fornecidos.

Assim, seguindo adiante na elaboração, é manifesta a suspeição do magistrado que recebera a denúncia, já que é amigo íntimo do acusado. Esta quebra de imparcialidade deverá ser suscitada em primeiro lugar por meio da exceção de suspeição, conforme art. 95, I c/c o art. 254, I do CPP.

Superando a análise do art. 395 do CPP, as preliminares merecem atenção redobrada, pois são comuns preliminares a partir deste momento procedimental. E uma nulidade aparece de forma evidente. Após o recebimento da ação penal, determina a legislação pátria que a citação inicial, em regra, seja pessoal, realizada por oficial de justiça, por meio de mandado judicial (art. 351 do CPP).

No presente caso, sem justificativa alguma, fora ordenada a citação por hora certa (art. 362 do CPP), sendo possível tão somente em casos em que o réu se oculta para não ser citado. Configurada, portanto, a nulidade.

Adentrando no mérito, a busca por um dos incisos do art. 397 é crucial. Vejamos

o dispositivo:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

I – a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

II – a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;

III – que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

IV – extinta a punibilidade do agente.

Sem opções quanto a excludentes de ilicitude, culpabilidade e extinções da punibilidade, a pesquisa se concentra no inciso III, da atipicidade do crime.

Aderbal tinha a vontade livre e consciente de estuprar uma pessoa viva, apesar de debilitada. Todavia, se descobriu que estava morta, fato este que foi descoberto só depois do ato, excluindo qualquer dolo em relação a crimes que envolvam cadáver, por exemplo.

Sendo assim, a tese a ser sustentada e que gera atipicidade, por absoluta impropriedade do objeto, é a de crime impossível do art. 17 do CP.

Resposta do Acusado elaborada:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 13.^a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Processo nº: _____

Aderbal, qualificação completa, vem, por seu advogado infra-assinado, cuja procuração com poderes especiais nos moldes do art. 44 do CPP, segue anexa, com base no art. 396 c/c o art. 396-A do CPP, tempestivamente, apresentar à Vossa Excelência

RESPOSTA À ACUSAÇÃO

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos:

I – Dos fatos

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou denúncia em face de Aderbal, por supostamente ter cometido a conduta descrita no art. 217-A, § 1.º, do CP.

Segundo a exordial, o acusado, enfermeiro de famoso hospital, aproveitando-se da condição de coma de Edith, ora vítima, a estuprou durante a noite.

Recebida a ação penal e citado para apresentação da defesa, o acusado passa a expor que tal conduta não poderá ser imputada a ele.

II – Da Exceção de Suspeição (art. 95, I c/c o art. 254, I do CPP)

Ultrapassados os fatos narrados, é de se observar que um dos pilares do ordenamento jurídico pátrio é a imparcialidade do julgador.

No presente caso, não poderia o magistrado da 13.^a Vara Criminal receber a presente ação, por ser amigo íntimo de Aderbal, de infância, inclusive, evidenciando-se, assim, típico caso de suspeição.

Assim, a exceção merece ser reconhecida.

III – Das Preliminares

a) Da nulidade de citação por hora certa em primeiro lugar (art. 351 c/c o art. 564, III, do CPP)

O princípio do devido processo legal exige, no início do processo judicial, após o recebimento, a citação real, pessoal, feita por oficial de justiça, seguindo as orientações do art. 351 do CPP.

Surpreendentemente, não foi isso que aconteceu no processo em trâmite na 13.^a Vara Criminal de Florianópolis. A citação por hora certa, possível no processo penal desde a minirreforma de 2008, só é possível quando o réu se oculta para não ser citado.

Com tal desrespeito na formalidade do presente meio comunicativo, a nulidade merece ser reconhecida.

IV – Do mérito

a) Da absolvição sumária por atipicidade (art. 397, III do CPP c/c o art. 17 do CP).

Imputar ao acusado o crime de estupro de vulnerável é demasiadamente exagerado e não condiz com a realidade dos fatos.

Apesar da intenção do acusado em praticar ato libidinoso com a vítima, sua vontade não gerou nenhum tipo de lesividade ao bem jurídico, já que no momento do ato, conforme perícia médico-legal demonstrada, a vítima já estava morta há duas horas.

A absolvição sumária se torna medida prudente e necessária com o acolhimento da tese de crime impossível, conforme art. 17 do CP, por absoluta impropriedade do objeto.

Demonstrada, assim, a atipicidade da conduta.

V – Das Provas

Requer, outrossim, a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, em especial a testemunhal, cujo rol segue.

VI – Dos Pedidos

Isto posto, requer:

O acolhimento da exceção de suspeição, conforme art. 95, I c/c o art. 254, I, do CPP;

Em preliminar, o reconhecimento da nulidade por falta de citação pessoal, conforme art. 564, III, e c/c o art. 351 do CPP;

No mérito, a absolvição sumária por atipicidade da conduta pela tese do crime impossível (art. 397, III do CPP c/c o art. 17 do CP);

A oitiva das testemunhas arroladas.

Nestes Termos,
Pede Deferimento,
Florianópolis, data

Advogado
Inscrição nº

ROL DE TESTEMUNHAS:

- 01. Carlos, qualificação
- 02. Newton, qualificação
- 03. Andréia, qualificação

3.º Enunciado: Memoriais (Alegações Finais Escritas)

Julio Cesar, nascido em 19 de julho de 1994, foi flagrado praticando atos sexuais dentro do carro de sua propriedade, numa praia deserta do município de Búzios na região litorânea do Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 2015. Abordado pelos policiais militares, afirmou que estava dentro do carro, pois não conhecia bem a região e que a acabara de conhecer Joana, jovem que o acompanhava, num bar da região e depois de beberem um pouco de vinho juntos, a convite dela, ela propôs que ele pagasse 200,00 (duzentos reais) para praticar sexo com ele no carro. Após o pagamento, ela indicou o local para que estacionassem e iniciou a prática dos atos.

Os policiais confirmaram a história com a jovem e, desconfiados dos documentos de identificação apresentados por elas, conduziram os dois a Delegacia de Polícia do local, onde descobriram que a jovem é menor e tem apenas 16 anos, embora sua aparência seja de uma mulher adulta. Foi realizada a prisão em flagrante e instaurado inquérito policial, comunicada a prisão ao juiz da comarca, foi mantida sob o argumento de tratar-se de crime hediondo, não sendo admitida a liberdade provisória, em razão do entendimento, o agente continua preso.

Denunciado pelo Ministério Público por crime de prostituição infantojuvenil previsto no art. 218-B, § 2.º, I, do CP com a agravante da embriaguez preordenada,

art. 61, II, I), do CP, em concurso material com o crime de fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, previsto no art. 243 do ECA, foi citado regularmente e apresentou a resposta a acusação.

Em audiência, Julio Cesar compareceu sem seu advogado dizendo que não precisava de defensor por ser inocente, fato este permitido pelo magistrado. Tendo em vista a complexidade do caso, o juiz abriu vista ao Ministério Público que se manifestou no sentido da condenação. Na qualidade de que advogado apresente a peça defensiva cabível, com todos os fundamentos aplicáveis.

Resolução do 3.º Enunciado:

Trata-se de alegação final por memorial, conforme se percebe pelo desenvolvimento do procedimento ordinário, a questão deixa claro que, após as diligências, o MP apresentou suas alegações finais e a defesa deverá apresentar as dela.

Há perceptíveis duas preliminares:

- 1 – Um pedido de concessão de liberdade provisória, possível mesmo se tratando de crimes hediondos, desde a alteração realizada pela Lei 11.464/2006 no art. 2.º, II, da Lei de Crimes Hediondos, devendo ser concedida de imediato.
- 2 – Ausência do advogado na audiência de instrução com violação do art. 400 do CPP, art. 5.º, LV, da CF e da Súmula 523 do STF.

No mérito, há uma série de questões a serem analisadas e requeridas ao final:

- 1) Tese principal de erro de tipo essencial – art. 20, *caput*, do CP, o que exclui o dolo e torna o fato atípico, uma vez que ele não sabia a idade da Joana, nem era previsível, pois ela aparentava ser mais velha e estava num bar bebendo bebidas alcoólicas, o que é proibido para menores.
- 2) O crime do art. 243 do ECA prevê o oferecimento ou fornecimento da bebida alcoólica ao menor; não houve essa conduta, na verdade foi ela quem

ofereceu a bebida a ele, e não o contrário, portanto o fato é atípico. Outrossim, ele não sabia a idade real dela.

- 3) Afastar a agravante da embriaguez preordenada, que somente se configura quando o agente se embriaga para praticar o crime, o que não houve na situação apresentada, pois ele não tinha dolo de praticar crime algum.
- 4) Reconhecer a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, em razão de ele ter menos de 21 anos na data do fato.
- 5) Fixar o regime de cumprimento de pena de acordo com o art. 33, § 2.º, do CP, afastando a obrigatoriedade do regime integralmente fechado previsto pela lei de crimes hediondos no art. 2.º, § 1.º, por violação do princípio da individualização da pena, conforme entendimento do STF.

Alegações finais por memoriais elaborada:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA...VARA CRIMINAL DA COMARCA.....DO ESTADO.....

Julio Cesar, já devidamente qualificado, vem por seu advogado infra-assinado, com base no art. 403, § 3.º, do CPP, apresentar, tempestivamente, perante Vossa Excelência

MEMORIAIS

pelos fatos e fundamentos jurídicos que passa a expor.

I. Dos Fatos

Julio Cesar, nascido em 19 de julho de 1994, foi flagrado praticando atos sexuais dentro do carro de sua propriedade, numa praia deserta do município de Búzios.

Abordado pelos policiais militares, afirmou que estava dentro do carro, pois não conhecia bem a região e que acabara de conhecer Joana, jovem que o acompanhava, num bar da região e depois de beberem um pouco de vinho juntos, a convite dela, ela propôs que ele pagasse R\$ 200,00 (duzentos reais) para praticar sexo com ele no carro.

Denunciado pelo Ministério Público por crime de prostituição infantojuvenil previsto no art. 218-B, § 2.º, I, do CP com a agravante da embriaguez preordenada, art. 61, II, I, do CP, em concurso material com o crime de fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, previsto no art. 243 do ECA.

Após pedido de condenação pelo órgão acusatório em Memoriais, a defesa, no presente momento, se manifesta pelos fatos e fundamentos a seguir.

II. Do Pedido de Liberdade Provisória (art. 5.º, LXVI, da CF c/c o art. 321 do CPP c/c o art. 2.º, II, da Lei 8.072/1990)

Por ser matéria de ordem constitucional e medida de inteira justiça, requer, inicialmente a concessão de liberdade provisória, visto que desde a alteração realizada pela Lei 11.464/2006 no art. 2.º, II, da Lei de Crimes Hediondos, é possível a liberdade durante a tramitação do processo penal.

Razão alguma assiste a necessidade de cautelar, haja vista ausência de pressupostos que gerariam a decretação de prisão (art. 321 do CPP).

III. Das Preliminares

A) Da Nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento pela ausência de Defesa Técnica do Acusado (art. 5.º, LV, da CF c/c a Súmula 523 do STF c/c o art. 400 do CPP)

Conforme se percebe na narrativa dos fatos, a ausência de advogado no momento importante da audiência inegavelmente gera prejuízo, fazendo com que a nulidade seja reconhecida.

Conforme art. 400 CPP, que consagrou o princípio da concentração dos atos de instrução, o interrogatório, por exemplo, meio de prova e meio de defesa, é realizado nesse momento processual e, evidentemente, a presença do advogado é essencial para proteção de direitos e garantias fundamentais.

Sendo assim, a nulidade deve ser reconhecida, em preliminar.

IV. Do Mérito

A) Da Absolvição pelo crime de Prostituição Infantil pelo reconhecimento do erro de tipo (art. 386, III, do CPP c/c o art. 20 do CP)

Após análise fática, não restam dúvidas da atipicidade da conduta do injustamente acusado.

Trata-se de fato atípico, uma vez que ele não sabia a idade da Joana, nem era previsível, pois ela aparentava ser mais velha e estava num bar bebendo bebidas alcoólicas, o que é proibido para menores.

Conforme a melhor doutrina, o “homem médio” se enganaria perfeitamente na situação narrada. Sendo assim, com base no art. 20 do CP, a absolvição é a medida apta a gerar justiça ao caso concreto.

B) Da Absolvição pelo crime de fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos (art. 386, III, do CPP)

Por sua vez, ainda em fase de mérito, não deve prosperar tese acusatória imputando ao réu o crime do art. 243 do ECA, pois não houve essa conduta; na verdade foi ela quem ofereceu a bebida a ele, e não o contrário, portanto o fato é atípico. Outrossim, ele não sabia a idade real dela.

C) Pelo afastamento da agravante da embriaguez preordenada (art. 61, II, I, do CP)

.....

.....

.....
Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda pelas teses acima expostas, que afaste a agravante da embriaguez preordenada, que somente se configura quando o agente se embriaga para praticar o crime, o que não houve na situação apresentada, pois ele não tinha dolo de praticar crime algum.

D) Pelo reconhecimento da atenuante de menoridade (art. 65, I, do CP)

Ainda, que se reconheça a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, em razão de ele ter menos de 21 anos na data do fato.

E) Da Fixação do Regime (art. 33, § 2.º, CP)

Que se fixe o regime de cumprimento de pena de acordo com o art. 33, § 2.º, do CP, afastando a obrigatoriedade do regime integralmente fechado previsto pela lei de crimes hediondos no art. 2.º, § 1.º, por violação do princípio da individualização da pena, conforme entendimento do STF.

V. Dos Pedidos

Isto posto, requer:

A) O deferimento do Pedido de Liberdade Provisória (art. 5.º, LXVI, da CF c/c o art. 321 CPP c/c o art. 2.º, II, da Lei 8.072/1990);

B) Em preliminar, a Nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento pela ausência de Defesa Técnica do Acusado (art. 5.º, LV, da CF c/c a Súmula 523 do STF c/c o art. 400 do CPP);

C) No mérito, pela Absolvição pelo crime de Prostituição Infantil pelo reconhecimento do erro de tipo (art. 386, III, do CPP c/c o art. 20 do CP);

D) Pela Absolvição pelo crime de fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos (art. 386, III, do CPP);

E) Subsidiariamente, pelo afastamento da agravante da embriaguez preordenada (art. 61, II, I, do CP);

F) Pelo reconhecimento da atenuante de menoridade (art. 65, I, do CP).

Nestes Termos,
Pede Deferimento,

Município, data

Advogado
Inscrição nº

4.º Enunciado: Recurso em Sentido Estrito:

Uma mulher, ao ser estuprada por Euclides, passou a gritar pedindo socorro. Euclides, então, cobriu-lhe o rosto com um travesseiro.

Ao encerrar a relação sexual, Euclides verificou que a mulher havia morrido por asfixia, embora não fosse essa sua intenção.

Denunciado, mesmo sem a manifestação da vítima, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2.º, inciso I, CP), foi pronunciado para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri.

Interponha o recurso cabível contra a decisão de pronúncia.

Advogado: Paulo Souza

OAB/RJ nº 0001

Resolução do 4.º Enunciado:

Seguindo a linha de análise da peça prático-profissional, a partir da conduta tipificada, determinamos o procedimento penal e chegamos a conclusão de que o caso Euclides tramita perante o Tribunal do Júri. Sendo assim, a peça se encontra em seu procedimento.

O enunciado não traz muitas informações procedimentais, apenas a informação da denúncia oferecida e da decisão de pronúncia oferecida pelo magistrado. Ainda, o enunciado favorece a identificação exigindo que se interponha o recurso cabível.

Insta observar que o procedimento do Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida (art. 5.º, XXXVIII, *d*, da CF, nas modalidades tentadas ou consumadas (art. 74, *caput* e § 1.º, do CPP). Pelas regras de competência, os crimes conexos também são atraídos perante o Júri, por força de competência constitucional.

Tal procedimento é bifásico, dividido em duas fases. A primeira fase, chamada de admissibilidade da acusação, é iniciada com a denúncia e vai até a pronúncia (arts. 406 a 413 do CPP). Já a segunda fase, de mérito, regida pela oralidade, consiste no plenário, essência deste tão famoso procedimento.

A natureza jurídica da pronúncia é de decisão interlocutória mista não terminativa e passível de Recurso em Sentido Estrito, conforme art. 581, IV, do CPP, peça que

deverá ser elaborada.

Recurso em Sentido Estrito elaborado:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA...VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA...DO ESTADO....

Euclides, já devidamente qualificado nos autos do processo nº....., vem, com base no art. 581, IV, do CPP, tendo em vista a decisão de pronúncia proferida, respeitosamente, apresentar, por seu advogado infra-assinado

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

pelos fatos e fundamentos jurídicos das anexas razões:

Caso Vossa Excelência não entenda em reformar a decisão ora atacada, conforme art. 589 do CPP, que se remeta as anexas razões ao Tribunal de Justiça competente.

Nestes Termos,
Pede Deferimento,

Município, data

Advogado: Paulo Souza
OAB/RJ nº 0001

RAZÕES DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo nº: _____

Origem: _____

Recorrente: Euclides

Recorrido: Ministério Público

Egrégio Tribunal de Justiça,

Colenda Câmara,

Excelentíssimos Desembargadores,

Trata-se de decisão de pronúncia que imputa a Euclides os crimes de homicídio qualificado e estupro e, inconformado, vem dela recorrer em sentido estrito esperando, assim, a reforma da decisão.

I – Dos Fatos

O Ministério Público, dentro de suas atribuições constitucionais, conforme art. 129, I, da CF, denuncia Euclides, ora recorrente, na prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e estupro em concurso material.

Segundo a narrativa, Euclides, na intenção de estuprar a vítima, ao ouvi-la gritando, colocou um travesseiro em seu rosto e ao final do ato, sem sua intenção, percebeu que a mesma se encontrava morta.

A decisão interlocutória de pronúncia merece ser reformada, conforme passa a expor.

II – Do Mérito

A) Da Desclassificação do crime de homicídio qualificado para crime de estupro seguido de morte (art. 419 do CPP)

O caso apresentado jamais pode configurar a conduta de homicídio, tendo em vista que não houve vontade livre e consciente em matar alguém, como exige o tipo penal do art. 121 do CP.

O dolo de Euclides era de estuprar, ou seja, constranger alguém a ter conjunção carnal, sendo assim, na impossibilidade de crime doloso contra a vida, a decisão de pronúncia merece ser reformada para de desclassificação, remetendo-se o feito ao juízo competente.

Resta ainda observar que o resultado morte ocorreu a título de culpa, hipótese esta evidente de crime preterdoloso, em que ocorre dolo no antecedente e culpa no consequente.

B) Da Retirada de Qualificadora por Motivo Torpe (art. 121, § 2.º, I, do CP):

Subsidiariamente, requer ainda o recorrente que, caso Vossa Excelência entenda pelo crime de homicídio, pela retirada da qualificadora motivo torpe, por ausência de demonstração cabal desta intenção por parte de Euclides.

III – Dos Pedidos

Isto posto, requer:

A reforma da decisão de pronúncia para a de desclassificação (art. 419 do CPP) do crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2.º I, do CP) para o crime de estupro seguido de morte (art. 213, § 2.º, do CP) com a consequente remessa ao juízo competente;

Subsidiariamente, a retirada de qualificadora do homicídio, caso se entenda pela manutenção deste crime.

Nestes Termos,
Pede Deferimento,

Município, data

Advogado: Paulo Souza
OAB/RJ nº 0001

5.º Enunciado: Apelação

João, funcionário público, surpreende-se na manhã de 05.03.2004 ao ler panfleto distribuído no seu bairro, chamando-o de corrupto. Extremamente ofendido, inicia

investigação para apurar a autoria, descobrindo em 20.04.2004 ter sido seu vizinho Ariosvaldo o responsável pela ofensa. Em 05.10.2004, oferece queixa-crime no II Juizado Especial Criminal, em face de Ariosvaldo, imputando-lhe o crime de injúria, art. 140 do Código Penal.

Na audiência preliminar, não foi possível conciliação, sendo rejeitada também proposta de transação penal.

Na audiência de instrução e julgamento, após manifestação da defesa de Ariosvaldo e do representante do Ministério Público, o juiz, embora reconhecendo estar a queixa devidamente instruída com prova da materialidade do delito e indícios de autoria, rejeitou a inicial, pelos seguintes fundamentos:

- a) decadência do direito de queixa, uma vez que o fato ocorreu em 05.03.2004 e queixa foi proposta em 05.10.2004;
- b) ilegitimidade de João para o oferecimento da ação penal privada, por tratar-se imputação de crime de ação penal pública condicionada a representação, nos termos do art. 145, parágrafo único, do Código Penal. Como advogado de João, e pautando-se no entendimento jurisprudencial dominante, elabore a peça processual conveniente a permitir que seu cliente possa satisfazer sua pretensão, com as respectivas razões, destinando-a à autoridade judiciária competente. Advogado: Edmar Lopes. Insc. nº 1.100.

Resolução do 5.º Enunciado:

Analisemos a questão passo a passo:

Inicialmente nos deparamos com questão relativa aos crimes contra a honra, pois João, funcionário público, foi chamado de corrupto. Cabe-nos analisar os arts. 138 *usque* 145 do CP. Chamar alguém de corrupto não é atribuir determinado fato a alguém, fazendo com que já eliminemos os crimes de calúnia e difamação. O crime cometido foi o de injúria (art. 140 do CP), tendo em vista a ofensa feita à dignidade ou decoro de João por meio de palavras depreciativas. Além disso, não podemos esquecer sua condição de funcionário público.

Adiante, o examinador nos fornece a data do descobrimento de autoria por parte de João. O art. 145 do CP preceitua que a ação penal competente de grande parte dos crimes contra a honra é de iniciativa privada, ou seja, estão todas sujeitas ao prazo decadencial de seis meses, a contar da data do conhecimento da autoria (art. 38 do CPP). Em 20.04.2004, João descobriu que o autor do crime de injúria era Ariosvaldo.

Fazendo as contas, o prazo para o ajuizamento da respectiva ação penal iria até 19.10.2004.

Em 05.10.2004, respeitando-se, portanto, o prazo decadencial, a questão nos informa que houve o ajuizamento da queixa-crime, nome este dado à ação penal privada. Em decorrência de figurar hipótese de crime de menor potencial ofensivo, pois a pena para o crime de injúria é de detenção de um a seis meses, ou multa, a ação foi proposta em um dos Juizados Especiais Criminais. Vale relembrar que o conceito de menor potencial ofensivo é para crimes cuja pena máxima não supere dois anos (art. 61 da Lei 9.099/1995 c/c o art. 2.º da Lei 10.259/2001).

Confirmando o que foi exposto acima, o crime imputado por João, na ação penal, foi o de injúria.

Nesse instante, o candidato deve estar atento ao procedimento da Lei 9.099/1995, principalmente no tocante às medidas despenalizadoras. Possuem esse nome, pois o grande objetivo do procedimento do JEC é tentar obstaculizar o prosseguimento de uma eventual ação penal. Configuram-se essas medidas: a composição civil dos danos (art. 72 da Lei 9.099/1995), a transação penal (art. 76 da Lei 9.099/1995), a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/1995) e a necessidade de representação no caso de crimes de lesão corporal leve e culposa (art. 88 da Lei 9.099/1995).

Pela redação da questão, a primeira tentativa foi inócua, pois em audiência preliminar nossos dois personagens não entraram em consenso. A proposta de transação penal também não foi aceita pelo indignado Ariosvaldo.

Consequentemente, o processo foi instaurado e, para nossa surpresa, rejeitado pelo juiz pelos fundamentos que iremos rebater.

Como estamos nos deparando com procedimento de Juizado Especial, é natural que analisemos o que a lei nos fala a respeito do problema de João. O art. 82, de forma expressa e cristalina, nos dá a resposta de muitas inquietações. Analisemos o art. 82 da lei supramencionada:

*Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá **apelação**, que poderá ser **julgada** por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado (grifo nosso).*

Mãos à obra. Recurso de Apelação dirigido às Turmas Recursais.

Acredita-se que eventual confusão com Recurso em Sentido Estrito (art. 581, I, do CPP) deva ser afastada. Este seria o caminho correto se estivéssemos diante do procedimento comum ordinário. Todavia, o procedimento do Juizado é especial e sua competência é absoluta, razão esta que nos obriga a respeitarmos o seu procedimento legal.

Fica clara a importância de visualização do crime com o devido procedimento. Essa pesquisa salva e identifica corretamente a peça.

Antes de iniciarmos a elaboração da peça, alguns detalhes são importantes. Primeiramente não devemos inventar nada que o examinador não forneceu. É essencial que não identifiquemos nossa prova. Não assinemos nada. Elaboraremos a peça tão somente com elementos fornecidos. Em segundo lugar, nada de invenções, de doutrinar, de escrever em demasia. Deixemos de expressar nosso vasto conhecimento jurídico nesse instante. O momento agora é de simplicidade. Concluindo, iremos rebater em nosso recurso somente as questões que o examinador nos pediu para enfrentar.

Apelação elaborada:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO II JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA
COMARCA _____ DO ESTADO _____

Processo n.º: _____

JOÃO, já devidamente qualificado nos presentes autos, por seu advogado infra-assinado, vem, com fulcro nos arts. 98, I, da Constituição Federal e 82 da Lei 9.099/1995, interpor, tempestivamente,

RECURSO DE APELAÇÃO

por entender, data venia, que a decisão de fls.... merece ser reformada por ser contrária à prova dos autos, com base nas seguintes razões que se seguem.

N. Termos,
P. Deferimento,

Local, data
Edmar Lopes
Insc. n.º 1.100

RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO

Apelante: João
Apelado: Ariosvaldo
Origem: II Juizado Especial Criminal
Processo n.º: _____

Egrégia Turma Recursal,
Excelentíssimos Juízes,

Inconformado com respeitável decisão que não recebeu a presente ação, vem o apelante recorrer apresentando razões de fato e de direito a seguir demonstradas:

Dos Fatos:

- 1 – Trata-se de crime de injúria cometido por Ariosvaldo, ora apelado, em face de João, ora apelante. O conhecimento da autoria do presente crime, apesar de ter sido cometido em 05.03.2004, foi em seguida, mais precisamente em 20.04.2004.
- 2 – Foram vinculados em panfletos distribuídos por Ariosvaldo dizeres tais como “corrupto”, em detrimento da imagem de João, funcionário público.
- 3 – O nobre magistrado não recebeu a ação penal pelos motivos da decadência e da ilegitimidade da parte, razão essa, que, respeitosamente, o apelante não concorda e vem dela recorrer pelos fundamentos que se seguem.

Dos Fundamentos:

- 1 – Preceitua o art. 38 do CPP que o prazo decadencial para o ajuizamento da ação penal privada é de seis meses contados do dia em que vier a saber quem é o autor do crime.
- 2 – Assim sendo, do dia em que o recorrente tomou conhecimento em 20.04.2004 até a data do ajuizamento da respectiva queixa-crime, em 05.10.2004, não se verifica o esgotamento do prazo decadencial, que só aconteceria no dia 19 do corrente mês, ou seja, seis meses após o conhecimento de que foi Ariosvaldo o autor da injúria.

3 – Ademais, a razão de que João seria ilegítimo para o oferecimento da ação penal privada não se coaduna com o entendimento jurisprudencial de nossos tribunais superiores. Senão vejamos o que dispõe a Súmula 714 do Supremo Tribunal Federal:

“É CONCORRENTE A LEGITIMIDADE DO OFENDIDO, MEDIANTE QUEIXA, E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO, PARA A AÇÃO PENAL POR CRIME CONTRA A HONRA DE SERVIDOR PÚBLICO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES.”

Dos Pedidos:

Isto posto, requer o recorrente o conhecimento do presente recurso a fim de que no mérito seja a decisão reformada, com a consequente condenação do recorrido, nos termos do art. 82, § 1.º, da Lei 9.099/1995.

N. Termos,
P. Deferimento,
Local, data
Edmar Lopes
Ins. n.º 1.100

6.º Enunciado: Revisão Criminal

Jaime, mais conhecido como Jaiminho em sua região, vive de pequenos delitos e resolveu “investir” no roubo de carros para poder viver melhor, segundo seu entendimento. Começa a espalhar pela região que o primeiro carro que irá roubar será uma Mercedes, já que quer provar para a comunidade que é um “ladrão de respeito”. Coincidentemente, no dia seguinte, a Polícia recebe uma notícia-crime de um famoso jogador de futebol de que, com uma arma na cabeça, teve que entregar sua Mercedes a um assaltante. Na Delegacia, o famoso jogador descreve o fato, mostra para a autoridade policial onde foi e fornece uma descrição superficial do assaltante. A autoridade policial inaugura as investigações e como primeira diligência ouve os moradores da região perto do local do assalto, região onde mora Jaiminho. Uma moradora, defensora da moral e dos bons costumes, categoricamente informa aos policiais que “deve ter sido Jaiminho”. Preso, Jaiminho durante o seu interrogatório fica calado, uma busca e apreensão determinada pelo juiz encontra uma arma em sua casa e com mais testemunhas que confirmam que Jaiminho queria roubar carros, o inquérito é concluído. Denunciado pelo Ministério Público, Jaime é condenado pelo

crime de roubo qualificado (art. 157, § 2.º inciso I, CP) a uma pena de 12 anos de prisão. Apresentado recurso de apelação, o mesmo é indeferido no Tribunal e apresentado Recurso Especial, logo em seguida, ao Tribunal Superior competente, também indefere o pleito por unanimidade, onde Jaiminho e sua defesa desistem e o acórdão transita em julgado. Já se passaram 3 anos e surge a notícia de que o jogador de futebol, dono da Mercedes, mentiu que seu carro tinha sido roubado. Apura-se que, com o intuito de enganar a seguradora, queria obter a quantia do seguro para pagamento de dívidas em decorrência de jogos e apostas. Assume que sumiu com o carro que está na fazenda de um amigo. Com esta notícia, você advogado é procurado pela família de Jaiminho para interpor a peça processual cabível ao fato narrado.

Resolução do 6.º Enunciado:

O caso apresentado tem como cerne principal o fato de o processo já ter uma decisão transitada em julgado, mais especificamente um acórdão no Superior Tribunal de Justiça, foro competente para o julgamento dos Recursos Especiais, conforme o art. 105 da CF. Tal informação será vital para o endereçamento correto da peça prático-profissional.

Com a decisão transitada em julgado, pode surgir uma eventual dúvida entre peças de execução penal (pedidos isolados ou até mesmo um agravo em execução) e a ação autônoma de impugnação, a revisão criminal. Façamos por eliminação. Para ser um pedido incidental na fase executória, o enunciado deveria ter trazido alguma informação de benefício garantido na Lei de Execução Penal, fato este que não ocorreu. O art. 66 da LEP delimita quais os pedidos que podem ser feitos e nenhum se encaixa no caso concreto. Absurdo ainda seria o agravo em execução, que é um recurso cabível de decisão interlocutória proferida pelo juiz da Vara de Execuções Penais. Para tanto, precisaríamos de uma manifestação do juiz, pois só cabe recurso quando existem decisões e inconformidades.

Assim, chegamos à Revisão Criminal do art. 621, e em seu inciso III temos a consagração da peça a ser realizada. Fato novo que surge depois da condenação, motivo crucial para a elaboração dessa ação autônoma de impugnação.

Destaca-se que a competência da Revisão Criminal segue a regra do art. 624 do CPP, sendo delimitado pelo órgão onde foi gerada a coisa julgada, ou seja, onde transitou em julgado. Isso posto, se no STF, endereçamento para o STF (art. 624 I, CPP), nos demais casos (decisão de primeira instância e Tribunal de 2.º grau), no próprio Tribunal. No entanto, como fica quando a decisão transita em julgado no Superior Tribunal de Justiça, que curiosamente é o caso? A ausência de menção expressa ao STJ no CPP é compreensível, pois em 1941, ano do CPP, não tínhamos ainda este tribunal. Vejamos artigo constitucional que nos responde a pergunta:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO DA.....TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Jaime, mais conhecido como Jaiminho, qualificação completa, vem, por seu advogado que a esta subscreve, apresentar, com fulcro no art. 621, inciso III, do Diploma Processual Penal, tendo em vista o surgimento de provas novas após a condenação criminal, apresentar

REVISÃO CRIMINAL

pelos fatos e fundamentos jurídicos que passa a expor:

I – Da Competência da presente ação:

Inicialmente, com base no art. 105, I, alínea e, da Constituição Federal, insta asseverar que a presente ação deve ser encaminhada ao Douto Superior Tribunal de Justiça, já que decisão penal que condenou o requerente transitou em julgado no presente tribunal.

II – Dos Fatos:

Jaime, ora recorrente, fora injustamente condenado pela suposta prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2.º, do CPP) a uma pena de 12 anos de prisão.

Narrou a inicial e confirmado após a condenação que Jaime havia roubado um carro da marca Mercedes de um famoso jogador de futebol. Pelas narrativas apresentadas, ficou claro que tal provimento injusto somente se deu com informações imprecisas e nada contundentes.

Após três anos de condenação, a nova informação, que demonstra claramente a injustiça cometida, é a de que o proprietário do carro havia dado um sumiço neste para aplicar um golpe na seguradora, já que passava por momentos de dívidas financeiras.

III – Do Mérito:

Com o surgimento da prova nova, art. 621, III, do CPP, é de suma importância que o Poder Judiciário diminua todo o sofrimento que uma injusta condenação gera na vida de um ser humano.

Tal prova nova é traduzida com o proprietário do veículo, objeto de eventual crime de roubo supostamente perpetrado por Jaime, reconhecendo que sumiu com o carro para pagar dívidas financeiras.

A injustiça precisa ser diminuída! Observe-se ainda que toda a instrução probatória se baseou em provas intensamente frágeis.

IV – Dos Pedidos:

Isto posto, requer:

- a) O conhecimento e provimento da presente ação;
- b) Com base no art. 626 do CPP, a absolvição do réu;
- c) O restabelecimento de todos os direitos, conforme o art. 627 do CPP;
- d) A viabilidade de uma justa indenização, conforme o art. 630 do CPP.

Nestes Termos,
Pede Deferimento,

Município, data

Advogado
Inscrição nº

7.º Enunciado: Embargos de Declaração

Anna Carolina resolve emprestar R\$ 5.000,00 para sua amiga Camila que, prestes a casar, não tem dinheiro para comprar um vestido de noiva. Anna é amiga de infância de Camilla e resolve ajudá-la. O casamento transcorre maravilhosamente bem e Anna está muito feliz de ver sua amiga casando, entretanto, após o casamento Camila muda drasticamente com Anna, ignora a amiga e frequenta a alta sociedade, já que seu marido é um empresário bem-sucedido no ramo de calçados. Anna entra em depressão e começa a ter problemas financeiros, já que perdeu o emprego e seu namorado lhe deixou. Resolve então ligar para Camila pedindo-lhe que pague o dinheiro emprestado à época do casório. Camila, surpreendida, disse que não iria devolver, já que à época aquilo tinha sido um presente.

Anna então resolve ir ao apartamento de Camila, na cobertura e ao encontrá-la dá uma cusparada em Camila e pega a chave do carro de sua amiga e vai a garagem, no

térreo do prédio dizendo: “Vou levar seu carro, já que você não quer pagar o vestido que te dei, sua ingrata!”. Parte com o veículo.

Camila contrata um advogado que apresenta a competente ação penal pelos crimes de exercício arbitrário das próprias razões, injúria e a contravenção de vias de fato.

O processo transcorre normalmente no órgão jurisdicional competente e em sua defesa derradeira, Anna argumenta que não poderia o advogado apresentar ação penal pela contravenção de vias de falta por falta de legitimidade, além de alegar que agira acobertada pela excludente de ilicitude conhecida como “exercício regular do direito”.

Em sentença publicada no dia 2 de maio de 2017, terça-feira, o magistrado condena Anna a todos os crimes, não menciona nada sobre a falta de legitimidade do advogado no que diz respeito a contravenção de vias de fato e de forma bem confusa, em sua sentença, não deixa claro a exclusão da tese do exercício regular do direito, menciona estado de necessidade, mas não argumenta os motivos pela não aplicabilidade, gerando perplexidade ao advogado constituído por Anna que precisa entender melhor a sentença para tomar a medida judicial cabível. Ainda sobre a injúria não fundamenta os motivos de condenação.

Na condição de advogado constituído, apresente a peça processual cabível, diversa de *habeas corpus*, no último dia do prazo.

Resolução do 7.º Enunciado:

O enunciado narra hipóteses de crimes de menor potencial ofensivo e de uma contravenção penal, todas sendo julgadas pelo Juizado Especial Criminal, órgão este competente para julgamento e processamento dos crimes apenados com até dois anos em sua pena máxima em abstrato. Após essa importante constatação, verifica-se que estamos diante de uma sentença penal e em face da mesma são cabíveis, em sede de Jecrim, dois recursos: o de apelação (art. 82 da Lei 9.099/1995) e os embargos de declaração (art. 83 da Lei 9.099/1995).

Por estarmos do lado defensivo, importante primeiramente analisar a viabilidade dos embargos de declaração, que teve sua redação levemente alterada pelo Novo

Código de Processo Civil. Vejamos a nova redação do art. 83 da Lei 9.099/1995: “Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.”

Analizando em detalhes o enunciado, percebemos claramente a omissão, pela falta de abordagem da legitimidade das vias de fato e a obscuridade ou omissão da sentença com argumentos nada claros, gerando, portanto, a possibilidade dos embargos de declaração, que devem ser dirigidos ao próprio juiz da sentença em peça única.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO....JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA.....DO ESTADO

Processo º:.....

Anna Carolina, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por intermédio de seu advogado infra-assinado, opor, tempestivamente, com fulcro no art. 83 da Lei 9.099/1995, os presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos:

I – Dos Fatos:

Anna, ora embargante, emprestou R\$ 5.000,00 para sua amiga Camila, ora embargada, que iria casar e precisa deste montante para adquirir um vestido de noiva.

Após o casório, Anna, desempregada, resolve solicitar o reembolso da quantia por parte de Camila, entretanto é surpreendida com a negativa de que a quantia era o presente e não devolveria.

A embargante toma atitudes severas contra Camila e é condenada, em juízo, através de sentença penal, pelos crimes de exercício arbitrário das próprias razões, injúria e vias de fato pelo juiz competente.

Entretanto, o magistrado em sentença não esclarece alguns pontos e é confuso em determinados momentos, gerando, assim, a possibilidade do presente recurso.

II – Das Preliminares:

a) Da Nulidade por Ausência de Fundamentação pelo Crime de Injúria (art. 564, IV, do CPP c/c o art. 93, IX, da CF c/c o art. 140, do CP).

Reza o mandamento constitucional que todas as decisões judiciais merecem ser fundamentadas, fato este que não ocorreu no tocante à fundamentação pelo crime de injúria.

Tal perplexidade em um Estado Democrático de Direito precisa ser reconhecida como nulidade.

III – Do Mérito:

a) Por omissão, pela falta de abordagem da legitimidade das vias de fato (art. 83 da Lei 9.099/1995 c/c o art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 – Contravenções Penais)

Observa-se que a contravenção de vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 é de ação penal pública, não podendo ser intentada por patrono privado.

Tal argumentação, absurdamente, passou despercebida pelo ilustre magistrado, que deve elaborar nova sentença penal abordando a falta de legitimidade ativa do advogado em intentar a presente ação referente a esta contravenção.

b) Por obscuridade ou omissão da sentença com argumentos nada claros (art. 83 da Lei 9.099/1995)

Ainda, a sentença penal proferida gera perplexidade no ora embargante por estar visível a sua obscuridade e omissão, permitindo ainda mais a propositura e o provimento do presente recurso.

O magistrado se confunde com aspectos importantes das teses de excludentes de ilicitude, gerando, portanto, instabilidade no provimento jurisdicional, que requer a maior clareza possível.

IV – Dos Pedidos:

Isto posto, requer:

Pelo conhecimento e provimento do presente recurso;

Pelo reconhecimento da nulidade por falta de fundamentação quanto ao crime de injúria (art. 564, IV, do CPP c/c o art. 93, IX, da CF);

Pelo reconhecimento da omissão quanto à legitimidade ativa para ação penal pela contravenção de vias de fato (art. 83 da Lei 9.099/1995 c/c o art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 – Contravenções Penais);

Pelo reconhecimento da obscuridade e omissão da sentença com argumentos nada claros (art. 83 da Lei 9.099/1995).

Nestes Termos,
Pede Deferimento,

Município, 8 de maio de 2017.

Advogado
Inscrição Número

8.º Enunciado: Agravo em Execução

Nilton cumpre pena em regime fechado pela prática do crime de roubo e durante o cumprimento em estabelecimento prisional, decidiu se dedicar aos estudos para completar o 2.º grau visando ter novas oportunidades ao término da pena com a consequente extinção da punibilidade. O Estado oferecia, dentro do estabelecimento

prisional, com videoaulas e professores voluntários o curso supletivo e Nilton matriculou-se efetivando um período de 212 dias de estudo, divididos em 12 horas por dia, conseguindo com brilhante êxito, ao final, o diploma de ensino médio.

Sabendo de tal possibilidade por informações de outros detentos, através da Defensoria Pública do Estado, apresentou pedido ao juízo competente para obter o benefício da remição da pena pelo estudo, já que conseguiu concluir o ensino médio e ainda alcançou várias horas de estudo, fazendo jus, portanto, ao benefício legal.

O magistrado analisando todas as circunstâncias sobre o crime que Nilton fora condenado indefere o pedido informando que a gravidade de execução do delito impediria o benefício.

De tal decisão, Nilton é intimado no dia 03/03/2017, segunda-feira e constitui você como advogado para apresentar no último dia do prazo a medida judicial cabível, diversa de *Habeas Corpus* para o caso narrado. Apresente todas as teses de direito relativas ao caso.

Resolução do 8.º Enunciado:

Inicialmente devemos nos preocupar com o momento procedimental que o enunciado nos coloca. Não restam dúvidas se tratar do momento de execução penal, pois nosso personagem Nilton está cumprindo pena em estabelecimento prisional. Após o trânsito em julgado de uma decisão condenatória, independente da instância, os autos são encaminhados à Vara de Execuções Penais. Neste ponto, registramos, à título de estudo, o Verbete Sumular nº 192 do Superior Tribunal de Justiça:

Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual.

Retornando ao enunciado, um pedido de remição de pena é feito ao juízo da Vara de Execuções Penais e incrivelmente indeferido, o que gera, naturalmente uma insatisfação, nos mostrando o caminho de um recurso, que é o meio impugnativo voluntário que demonstra insatisfação em relação a uma decisão. Das decisões

interlocutórias proferidas pelo juízo da Vep, caberá Agravo em Execução, conforme art. 197 da Lei 7.210/1984 – LEP. Registra-se ainda que no art. 66, inciso III, alínea c, da Lei 7.210/1984 define que quem decide sobre remição da pena é o juiz da execução penal, reforçando a certeza de que devemos elaborar um Agravo em Execução, com prazo de cinco dias conforme Súmula 700 do STF, que possui a seguinte redação: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.”

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA.....DO ESTADO.....

Processo nº.....

Nilton, já devidamente qualificado, vem, por seu advogado infra-assinado, com base no art. 197 c/c o art. 66, III, c, da Lei 7.210/1984 c/c a Súmula 700 do STF, apresentar, tempestivamente

AGRAVO EM EXECUÇÃO

pelos fatos e fundamentos jurídicos que seguem nas anexas razões.

Caso Vossa Excelência não entenda pela reforma da decisão, com base no art. 589 do CPP, que se remetam as anexas razões ao Tribunal julgador competente.

Nestes Termos,
Pede Deferimento,
Município, 10 de março de 2017.
Advogado

Inscrição nº.....

RAZÕES DE AGRAVO EM EXECUÇÃO

Processo nº:.....

Origem:.....

Agravante: Nilton

Agravado: Ministério Público

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado.....,

Colenda ... Câmara Criminal,

Excelentíssimos Julgadores.

Trata-se de decisão interlocutória proferida pelo juízo da execução penal e, inconformado com a

presente decisão, vem dela recorrer com base nas razões de fato e de direito abaixo.

I – Dos Fatos:

Nilton, ora agravante, está cumprindo pena em estabelecimento prisional e resolve estudar para completar o ensino médio.

Com a conclusão e diploma em mãos, Nilton, através da Defensoria Pública, requer o benefício da remissão da pena, entretanto o juiz competente indefere tal direito sem qualquer justificativa.

Inconformado, passemos ao mérito onde será demonstrado que Nilton faz jus ao benefício.

II – Das Preliminares:

a) Da Nulidade por Ausência de Fundamentação Idônea (art. 564, IV, do CPP c/c o art. 93, IX, da CF)

Inicialmente é de observar a temerária ausência de fundamentação da decisão interlocutória proferida pelo juiz da Execução Penal, desrespeitando assim o mandamento constitucional que exige fundamentação nas decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

Apenas mencionar que o crime é grave jamais pode ser forma de fundamentação racional para indeferir qualquer que seja o pedido, gerando assim nulidade, cujo reconhecimento requer, conforme o art. 564, inciso IV, do CPP.

III – Do Mérito:

a) Pela Remição da Pena pelo Estudo (art. 126, § 1.º, inciso I, da Lei 7.210/1984 c/c a Súmula 341 do STJ).

Superada a análise preliminar de nulidade, passemos a analisar a real possibilidade que Nilton, ao estudar, faz jus à remição da pena, consistente no abatimento da pena não só pelo trabalho, mas também pelo estudo.

Tal entendimento fora consolidado, após decisões reiteradas de nossos tribunais superiores, gerando, conseqüentemente, súmula do Superior Tribunal de Justiça, de número 341, tamanha a importância do tema. Segundo o enunciado, a frequência a curso é causa de remição.

No mais, nosso preocupado legislador, com alteração trazida pela Lei 12.433/2011 diretamente no corpo da Lei de Execução Penal, estabelece tal possibilidade em seu art. 126, § 1.º, inciso I. O próprio texto legal, preocupado com a educação básica que todo ser humano faz jus, menciona o ensino médio.

Sendo assim, em nome dos direitos e benefícios trazidos na LEP, Nilton, sem sombra de dúvidas, faz jus ao benefício da remição da pena.

IV – Dos Pedidos:

Isto posto, requer:

Pelo conhecimento e provimento do presente recurso;

Em preliminar, pelo reconhecimento da nulidade por ausência de fundamentação idônea (arts. 564, IV, c/c o art. 93, IX, da CF);

No Mérito, pela concessão do benefício da remição da pena (art. 126, § 1.º, I, c/c a Súmula 341 do STJ).

Nestes Termos,
Pede Deferimento,
Município, 10 de março de 2017.
Advogado
Inscrição nº.....

MODELOS DAS PEÇAS PRÁTICO-PROFISSIONAIS

Um dos momentos mais aguardados da obra são os modelos das peças com seus devidos comentários.

Neste capítulo seguiremos a presente estrutura padrão.

- Peça práctico-profissional;
- Comentários sobre a peça;
- Modelo padrão;
- Peça práctico-profissional oficial da banca examinadora (se houver);
- Comentários ao gabarito da peça práctico-profissional oficial;
- Peça práctico-profissional inédita proposta pelos autores (gabarito e comentário em capítulo separado ao final da obra).

Tal estrutura foi pensada e planejada para, também, transformarmos a obra numa ferramenta de treinamento. Esse foi o real motivo de colocação dos gabaritos dos autores ao final.

7.1 NOTÍCIA-CRIME

Nome	Notícia-Crime
Artigo	Art.5.º do CPP:Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: I – de ofício;

	II – mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
Prazo	–
Serve para	Iniciar o Inquérito Policial
Observações	Peça das mais simples, que não precisa ser elaborada por advogado e que tem o único intuito de comunicar um eventual delito para que a Polícia Judiciária tenha condições mínimas de iniciar as investigações. Trata-se de um requerimento de abertura de inquérito policial e que não gera obrigatoriedade na autoridade policial em iniciar o procedimento investigativo. Sua forma de elaboração não segue rigores muito técnicos, inclusive sendo possível na prática a sua apresentação oral. Não é essencial para a investigação de crimes de ação penal pública, tendo em vista a possibilidade de o delegado iniciar as investigações de ofício. Entretanto, pode funcionar como representação nos crimes de ação penal pública condicionada a representação e fazer o papel de anuência da vítima nos crimes de ação penal privada. As testemunhas serão arroladas, evidentemente, se tivermos subsídios para inserirmos. A capitulação jurídica pode ser colocada, apesar de não ser exigido pelo noticiante conhecimento jurídico.

7.1.1 Modelo de peça

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA TITULAR DA DELEGACIA DE
 _____ DO ESTADO _____

(linhas)

_____ (nome + qualificação completa), vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento no artigo 5.º, II,¹ do Código de Processo Penal apresentar,

NOTÍCIA-CRIME

pelos motivos a seguir aduzidos:

I – Dos Fatos

(...)

→ narrar os fatos de forma simples e reduzida.

II – Do Direito

(...)

→ adaptação do que ocorreu no mundo dos fatos com preceitos legais. Colocar dispositivo de lei.

III – Do Pedido

Diante do exposto, requer a abertura do Inquérito Policial com intuito de se iniciarem as devidas investigações com o objetivo de se obter os indícios de autoria e a materialidade do delito.

Requer ainda a notificação das testemunhas abaixo arroladas.

Termos em que,
Pede Deferimento,

Município, data

Advogado
Inscrição n.º

ROL DE TESTEMUNHAS:

7.1.2 Exercício²

Peça Prático-Profissional Inédita:

Peça 01:

Lourdes e sua família resolvem passar o feriado da semana santa em sua casa de

verão no litoral fluminense na cidade de Búzios. Sua casa é lindíssima, bem localizada, perto da Rua das Pedras. A viagem transcorre com bastante tranquilidade, todos bem animados para curtir praias, piscina e esportes. Entretanto, ao chegarem perto da casa, notam 2 pessoas saindo correndo da mesma. Por ser noite, Lourdes e sua família não possuem condições de identificar quem seriam. Aproximam-se da casa e percebem que ela está arrombada. O marido de Lourdes é o primeiro a entrar e nota a casa revirada. No quarto do casal algumas joias que Lourdes havia deixado no final de semana anterior sumiram e seu marido nota que sumiram R\$ 2.000,00 de seu armário.

Inconformados, Lourdes e o marido ligam para você, advogado, a adotar a medida escrita inicial cabível para o fato apresentado.

7.2 RELAXAMENTO DE PRISÃO

Nome	Relaxamento de Prisão
Artigo	Art. 5.º, LXV, da CF: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária; Art. 310, I, do CPP: Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal;
Prazo	–
Serve para	Contracautela específica de uma prisão ilegal
Observações	Peça jurídica interposta ao magistrado, na qual deve ser apenas demonstrada a ilegalidade da prisão. Muito utilizada para flagrantes considerados ilegais, tais como o forjado ou até mesmo em desrespeito ao art. 306 do Diploma Processual Penal. Nesse instante não se deve analisar o mérito da questão, e sim

apenas o título prisional. Seu objetivo é o alvará de soltura.

7.2.1 Modelo de peça

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA
____ DO ESTADO _____

_____ (nome + qualificação completa), vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento no art. 5.º, LXV, da Constituição da República c/c art. 310, I, do CPP, requerer, por ser medida de justiça, com base nos fatos e fundamentos abaixo

RELAXAMENTO DE PRISÃO,

I – Dos Fatos

(...)

II – Dos Fundamentos

(demonstração da ilegalidade da prisão)

(...)

III – Do Pedido

Isto posto, requer, imediatamente, que seja reconhecida a ilegalidade da prisão e, concedido o presente Relaxamento de Prisão, nos termos do já citado artigo constitucional, com a consequente expedição de Alvará de Soltura.

N. Termos

P. Deferimento,

Município, Data

Advogado

7.2.2 Exercícios

Peça Prático-Profissional Oficial (VI Exame Unificado):

No dia 10 de março de 2011, após ingerir um litro de vinho na sede de sua fazenda, José Alves pegou seu automóvel e passou a conduzi-lo ao longo da estrada que tangencia sua propriedade rural. Após percorrer cerca de dois quilômetros na estrada absolutamente deserta, José Alves foi surpreendido por uma equipe da Polícia Militar que lá estava a fim de procurar um indivíduo foragido do presídio da localidade. Abordado pelos policiais, José Alves saiu de seu veículo trôpego e

exalando forte odor de álcool, oportunidade em que, de maneira incisiva, os policiais lhe compeliram a realizar um teste de alcoolemia em aparelho de ar alveolar. Realizado o teste, foi constatado que José Alves tinha concentração de álcool de um miligrama por litro de ar expelido pelos pulmões, razão pela qual os policiais o conduziram à Unidade de Polícia Judiciária, onde foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei 9.503/1997, c/c art. 2.º, inciso II, do Decreto 6.488/2008, sendo-lhe negado no referido Auto de Prisão em Flagrante o direito de entrevistar-se com seus advogados ou com seus familiares.

Dois dias após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, em razão de José Alves ter permanecido encarcerado na Delegacia de Polícia, você é procurado pela família do preso, sob protestos de que não conseguiam vê-lo e de que o delegado não comunicara o fato ao juízo competente, tampouco à Defensoria Pública.

Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, na qualidade de advogado de José Alves, redija a peça cabível, exclusiva de advogado, no que tange à liberdade de seu cliente, questionando, em juízo, eventuais ilegalidades praticadas pela Autoridade Policial, alegando para tanto toda a matéria de direito pertinente ao caso.

Gabarito Oficial:

Peça	Relaxamento de prisão
Endereçamento	Juiz de Direito da Vara Criminal
Fundamento Legal	Art. 5.º, LXV ou art. 310, I, do CPP
Preliminares	–
	O auto de prisão em flagrante é nulo por violação ao direito à não autoincriminação compulsória (princípio do nemo tenetur se detegere), previsto no art. 5.º, LXIII, da CRFB/1988 ou no

Fundamentos	art. 8.º, 2, “g”, do Decreto 678/1992. A prova é ilícita em razão da colheita forçada do exame de teor alcoólico, por força do art. 5.º, LVI, da CRFB/1988 ou art. 157 do CPP. O auto de prisão em flagrante é nulo pela violação à exigência de comunicação da medida à Autoridade Judiciária, ao Ministério Público e à Defensoria Pública dentro de 24 horas, nos termos do art. 306, § 1.º, do CPP ou art. 5.º, LXII, da CRFB/1988, ou art. 6.º, V, c/c art. 185, ambos do CPP (a banca também convencionou aceitar como fundamento o art. 306, caput, do CPP, considerando-se a legislação da época dos fatos). O auto de prisão é nulo por violação ao direito à comunicação entre o preso e o advogado, bem como familiares, nos termos do art. 5.º, LXIII, da CRFB ou art. 7.º, III, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil ou art. 8.º, 2, “d”, do Decreto 678/1992.
Pedidos	Ao final, o examinando deverá formular pedido de relaxamento de prisão em razão da nulidade do auto de prisão em flagrante, com a consequente expedição de alvará de soltura.
Autenticação	Padrão
	Fica clara nesta questão a preocupação do examinador em avaliar os aspectos constitucionais que envolvem o tema prisional. Peça que se reveste de certa simplicidade, pois em peças de relaxamento de prisão só se ataca a ilegalidade da prisão. Percebemos claramente com os fundamentos exigidos que tão somente esses aspectos merecem ser abordados.

Comentários

Destaque para os aspectos do Pacto de São José da Costa Rica, que impede a produção de prova contra si mesmo, tema este dos mais discutidos na atualidade e que não fugiu da exigência do exame. Além disso, insta concluirmos com as garantias que o preso tem, após a lavratura do auto de prisão em flagrante. Segundo o art. 306 do CPP, o delegado de polícia, em até 24h, deve entregar a nota de culpa, comunicar ao juiz de direito, notificar o membro do Ministério Público, permitir a comunicação ao advogado ou defensor e ainda a família ou algum conhecido. Apesar da novidade da Lei 12.403/2011 em comunicar ao Ministério Público, essa exigência já era sentida na LC 75/1993.

Peça Prático-Profissional Inédita:³

Peça 02:

Vitinho, famoso assaltante de carros na área do Batel em Curitiba – Paraná, está sendo procurado pela polícia local. Ao que tudo indica, em todos os finais de semana o famoso gatuno ataca perto da área de bares e restaurantes. O Delegado com atribuição na área, pressionado pelo Governo do Estado, adota algumas medidas urgentes para prender o assaltante o mais rápido possível. Destaca dois agentes de sua equipe para montarem uma operação na área. Primeiramente utilizam um carro importado dos mais caros que se localiza apreendido no pátio da delegacia com a intenção de colocá-lo em uma das ruas do Batel com a luz interna ligada com a intenção única e exclusiva de motivar a ação criminosa. Em segundo lugar, os dois agentes, disfarçados, se colocam em pontos estratégicos da localidade com uma boa visão do carro importado e de toda a área.

No segundo dia de operação, o famoso assaltante aparece no local e, sem pestanejar, se interessa pelo carro importado colocado pelos policiais. Já dentro do carro, tentando fazer a famosa ligação direta, Vitinho é abordado e preso pelos policiais. Encaminhado ao Distrito Policial, todas as formalidades são cumpridas,

inclusive a comunicação ao advogado. Você, nesta condição, qual medida, exclusiva de advogado, adotaria?

7.3 LIBERDADE PROVISÓRIA

Nome	Liberdade Provisória
Artigo	Art. 5.º, LXVI, da CF: ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança; Art. 310, III, do CPP: Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: (...) III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código. I – Revogado

	II – Revogado Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito) horas.
Prazo	–
Serve para	Contracautela específica de uma prisão em flagrante legal, porém não necessária.
Observações	Mais uma peça jurídica direcionada ao magistrado e que tem por objetivo possibilitar que o indiciado ou acusado possa responder em liberdade. Não uma liberdade plena, mas uma liberdade vinculada, principalmente com o comprometimento de comparecer a todos os atos processuais. Esta peça também se reveste de certa simplicidade em sua feitura, pois se exige apenas a demonstração dos requisitos autorizadores da medida de liberdade provisória. Não se enfrenta o mérito da questão. Vale a pena lembrarmos que temos duas espécies de Liberdade Provisória: com e sem fiança. Esta última é muito mais utilizada.
	Cabimento nos casos do art. 321 CPP: Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código. I – Revogado

Liberdade Provisória sem Fiança	II – Revogado Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4.º).
Liberdade Provisória e Crimes hediondos	Permitido, tendo em vista a Lei 11.464/2007, que alterou o art. 2.º, II, da Lei 8.072/1990.
	Vale mencionar, quanto à possível inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas, recentíssima decisão proferida pelo eminente Ministro Eros Grau, Relator do HC 100.872-MC/MG: “A vedação da liberdade provisória ao preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, veiculada pelo art. 44 da Lei 11.343/2006, é expressiva de afronta aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana (arts. 1.º, III, e 5.º, LIV e LVII da Constituição do Brasil). (...). A inconstitucionalidade do preceito legal me parece inquestionável”. Essa repulsa a preceitos legais, como esses que venho de referir, também encontra apoio em autorizado magistério doutrinário (Luiz Flávio Gomes, em obra escrita com Raúl Cervini, Crime Organizado, 2. ed., São Paulo, RT, 1997, p. 171-178, item n. 4;

Geraldo Prado e William Douglas, Comentários à Lei contra o Crime Organizado, Belo Horizonte, Del Rey, 1995, p. 87-91; Roberto Delmanto Junior, As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração, 2. ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 142-150, item n. 2, "c", e Alberto Silva Franco, Crimes Hediondos, 5. ed., São Paulo, RT, 2005, p. 489/500, item n. 3.00, v.g.).

Vê-se, portanto, que o Poder Público, especialmente em sede processual penal, não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal, ainda mais em tema de liberdade individual, acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade.

Como se sabe, a exigência de razoabilidade traduz limitação material à ação normativa do Poder Legislativo. O exame da adequação de determinado ato estatal ao princípio da proporcionalidade, exatamente por viabilizar o controle de sua razoabilidade, com fundamento no art. 5.º, LV, da Carta Política, inclui-se, por isso mesmo, no âmbito da própria fiscalização de constitucionalidade das prescrições normativas emanadas do Poder Público.]

Esse entendimento é prestigiado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, por mais de uma vez, já advertiu que o Legislativo não pode atuar de maneira imoderada, nem formular regras legais cujo conteúdo revele deliberação absolutamente divorciada dos padrões de razoabilidade.

Coloca-se em evidência, neste ponto, o tema concernente ao princípio da proporcionalidade, que se qualifica – enquanto coeficiente de aferição da razoabilidade dos atos estatais (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 4. ed., São Paulo, Malheiros, 1993, p. 56-57, itens ns. 18/19; Lúcia Valle Figueiredo, Curso de Direito Administrativo, 2. ed., São Paulo,

**Liberdade
Provisória e
Lei de
Tóxicos (Lei
11.343/2006)**

Malheiros, 1995, p. 46, item n. 3.3) – como postulado básico de contenção dos excessos do Poder Público.

Essa é a razão pela qual a doutrina, após destacar a ampla incidência desse postulado sobre os múltiplos aspectos em que se desenvolve a atuação do Estado – inclusive sobre a atividade estatal de produção normativa –, adverte que o princípio da proporcionalidade, essencial à racionalidade do Estado Democrático de Direito e imprescindível à tutela mesma das liberdades fundamentais, proíbe o excesso e veda o arbítrio do Poder, extraindo a sua justificação dogmática de diversas cláusulas constitucionais, notadamente daquela que veicula, em sua dimensão substantiva ou material, a garantia do “due process of law” (Raquel Denize Stumm, Princípio da Proporcionalidade no Direito Constitucional Brasileiro, Porto Alegre, Livraria do Advogado, p. 159-170, 1995; Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Direitos Humanos Fundamentais, São Paulo, Saraiva, 1995, p. 111-112, item n. 14; Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, 4. ed., São Paulo, Malheiros, 1993, p. 352-355, item n. 11).

Como precedentemente enfatizado, o princípio da proporcionalidade visa a inibir e neutralizar o abuso do Poder Público no exercício das funções que lhe são inerentes, notadamente no desempenho da atividade de caráter legislativo. Dentro dessa perspectiva, o postulado em questão, enquanto categoria fundamental de limitação dos excessos emanados do Estado, atua como verdadeiro parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. Isso significa, dentro da perspectiva da extensão da teoria do desvio de poder ao plano das atividades legislativas do Estado, que este não dispõe de competência para legislar ilimitadamente, de forma

imoderada e irresponsável, gerando, com o seu comportamento institucional, situações normativas de absoluta distorção e, até mesmo, de subversão dos fins que regem o desempenho da função estatal.

A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, bem por isso, tem censurado a validade jurídica de atos estatais, que, desconsiderando as limitações que incidem sobre o poder normativo do Estado, veiculam prescrições que ofendem os padrões de razoabilidade e que se revelam destituídas de causa legítima, exteriorizando abusos inaceitáveis e institucionalizando agravos inúteis e nocivos aos direitos das pessoas (RTJ 160/140-141, Rel. Min. Celso de Mello – RTJ 176/578-579, Rel. Min. Celso de Mello – ADI 1.063/DF, Rel. Min. Celso de Mello, v.g.).

Daí a advertência de que a interdição legal “in abstracto”, vedatória da concessão de liberdade provisória, como na hipótese prevista no art. 44 da Lei n.º 11.343/2006, incide na mesma censura que o Plenário do Supremo Tribunal Federal estendeu ao art. 21 do Estatuto do Desarmamento, considerados os múltiplos postulados constitucionais violados por semelhante regra legal, eis que o legislador não pode substituir-se ao juiz na aferição da existência, ou não, de situação configuradora da necessidade de utilização, em cada situação concreta, do instrumento de tutela cautelar penal.

O Supremo Tribunal Federal, de outro lado, tem advertido que a natureza da infração penal não se revela circunstância apta a justificar, só por si, a privação cautelar do “status libertatis” daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado. Essa orientação vem sendo observada em sucessivos julgamentos proferidos no âmbito desta Corte, mesmo que se trate de réu

processado por suposta prática de crimes hediondos ou de delitos a estes equiparados (HC 80.064/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Sepúlveda Pertence – HC 92.299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio – HC 93.427/PB, Rel. Min. Eros Grau – RHC 71.954/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence – RHC 79.200/BA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, v.g.) (...)

Tenho por inadequada, desse modo, por tratar-se de fundamento insuficiente à manutenção da prisão cautelar do ora paciente, a mera invocação do art. 44 da Lei 11.343/2006 ou do art. 2.º, inciso II, da Lei 8.072/1990, especialmente depois de editada a Lei 11.464/2007, que excluiu, da vedação legal de concessão de liberdade provisória, todos os crimes hediondos e os delitos a eles equiparados, como o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

Em suma: a análise dos fundamentos invocados pela parte ora impetrante leva-me a entender que a decisão judicial de primeira instância não observou os critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou em tema de prisão cautelar.

Sendo assim, tendo presentes as razões expostas, defiro o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, garantir, cautelarmente, ao ora paciente, a liberdade provisória que lhe foi negada nos autos do Processo n.º 2009.0006.5546-0 (4.ª Vara Criminal da comarca de Palmas/TO), expedindo-se, imediatamente, em favor desse mesmo paciente, se por al não estiver preso, o pertinente alvará de soltura.

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 147.579/TO), ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (HC 5.883/09) e ao Juízo de Direito da 4.ª Vara Criminal da comarca de Palmas/TO

(Processo n.º 2009.0006.5546-0).

7.3.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA
____ DO ESTADO _____

_____ (nome + qualificação completa), vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento no art. 5.º, LXVI, da Constituição da República combinado com o art. 321 do Código de Processo Penal, requerer, com base nos fatos e fundamentos abaixo

LIBERDADE PROVISÓRIA,

I – Dos Fatos

II – Dos Fundamentos

(demonstração da possibilidade de responder em liberdade provisória)

III – Do Pedido

Isto posto, requer, imediatamente, que seja concedida a liberdade provisória, nos termos do já citado artigo constitucional, com a consequente expedição de Alvará de Soltura.

Caso V. Exa. entenda cabível, que se determine também a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 CPP.

N. Termos
P. Deferimento,

Município, Data
Advogado
Inscrição n.º

7.3.2 Exercício⁴

Peça Prático-Profissional Inédita:

Peça 03:

Anderson é muito nervoso e quando ingere bebidas alcoólicas fica muito agressivo. Certa noite resolve sair para dançar com sua namorada em famosa boate de

Belo Horizonte. A noite transcorria maravilhosamente bem até que, ao retornar do bar, vê sua namorada conversando com outro homem. Inconsequente, Anderson empurra o homem e quebra a garrafa de cerveja no braço da vítima, a deixando levemente sangrando. Os seguranças da boate levam os dois para fora do estabelecimento e chamam a polícia. Ambos dirigem-se ao distrito policial mais próximo e no caminho Anderson descobre que a vítima era amigo de infância de sua namorada. Mesmo assim é feito o relato do ocorrido com a vítima se mostrando interessada na persecução penal e Anderson é preso em flagrante com todas as formalidades cumpridas pelo ilustríssimo Delegado de Polícia. Anderson não se conforma com a prisão, informa a autoridade policial que nunca se envolveu em nenhum crime, tem bons antecedentes, é trabalhador de uma grande multinacional, tem residência fixa e ainda informa que cumprirá a qualquer intimação do Delegado. Anderson não imagina passar um minuto sequer no cárcere e está arrependido. Você, advogado, é acordado de madrugada para tomar a medida jurídica, exclusiva de advogado, mais urgente possível segundo recomendação de Anderson.

7.4 REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Nome	Revogação da Prisão Preventiva
Artigo	Art. 316 do CPP: O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Prazo	—
Serve para	Contracautela específica de uma prisão preventiva legal, porém desnecessária, tendo em vista o desaparecimento dos requisitos desta.
	Utilizada para demonstrar que os requisitos ensejadores da prisão preventiva desapareceram. Este, na verdade, é o único objetivo

Observações

dessa medida judicial, que também tem como consequência o pedido de alvará de soltura. Mais uma vez não se questiona o mérito da questão e sim apenas o título prisional. Transcrevemos os requisitos da prisão preventiva:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4.º).

Seriam fundamentais para a decretação da prisão preventiva a prova de existência do crime e os indícios suficientes de autoria. Preenchidos esses dois fundamentos, o magistrado tem liberdade em comungar tais fundamentos com os demais requisitos. Exemplificando, nos casos de crimes tributários, a garantia da ordem econômica.

7.4.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA
____ DO ESTADO _____

_____ (nome + qualificação completa), vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento no art. 310, II c/c art. 316 do Código de Processo Penal, requerer, com base nos fatos e fundamentos abaixo

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,

I – Dos Fatos

II – Dos Fundamentos

(demonstração do desaparecimento dos requisitos da prisão preventiva)

III – Do Pedido

Isto posto, requer, imediatamente, que seja concedida Revogação da Prisão Preventiva, nos termos do já citado artigo constitucional, com a consequente expedição de Alvará de Soltura.

Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário e adequado que se adotem medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art. 319 do Diploma Processual Penal.

N. Termos
P. Deferimento,

Município, Data
Advogado
Inscrição n.º

7.4.2 Exercício⁵

Peça Prático-Profissional Inédita:

Peça 04:

Rafael resolve entrar no mundo do crime. Sem esperança e sem emprego, entende que a única solução é falsificar notas de reais e colocá-las em circulação o mais rápido possível. Usa toda sua experiência de gráfico, desenhista e engenheiro. Adquire maquinário e monta, em sua residência, num dos cômodos, uma verdadeira sala de falsificações. As primeiras notas são idênticas, Rafael começa a gastá-las e seu comportamento extravagante começa a chamar a atenção de vizinhos que não o veem trabalhar e mesmo assim desfilando com carros importados e roupas novas.

O fato é noticiado à polícia e a investigação começa. O ilustre Delegado procede com algumas diligências sigilosas, ouve testemunhas, recebe informações da receita federal e as suspeitas se tornam veementes. Lojistas e vendedores são ouvidos. Em um determinado dia, ao sair de uma loja de uma grife masculina famosa, um dos policiais se identifica à atendente e pergunta como Rafael pagou as mercadorias. A atendente informa que a compra alta foi toda paga em dinheiro vivo. Uma das notas é trocada pelo policial e este a leva para perícia. O resultado sai em alguns dias e é de

falsificação quase perfeita de notas de R\$ 100, R\$ 50 e R\$ 20.

Munido desta informação, com base no art. 311 do CPP, o Delegado requer a imediata prisão preventiva de Rafael com base nos indícios de autoria, de materialidade, de garantia da ordem econômica, da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

A ordem é deferida e o mandado judicial é expedido pelo juízo competente, mencionando-se inclusive que Rafael pode ser perigoso e integrar organização criminosa internacional de falsificadores. Rafael é preso em casa por volta das 12h do dia seguinte, levado à Delegacia e confessa ao Delegado informando que irá contribuir com as investigações.

Você, contratado por Rafael, interponha medida jurídica cabível específica, diversa de *Habeas Corpus*, abordando todos os fatos e fundamentos jurídicos pertinentes.

7.5 QUEIXA-CRIME (AÇÃO PENAL PRIVADA PROPRIAMENTE DITA)

Nome	Queixa-Crime
Artigo	Art. 38 do CPP:Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Art.41 do CPP:A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Art.44.A queixa poderá ser dada por procurador com poderes

	especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.
Prazo	6 meses a contar do conhecimento da autoria. Art.38 do CPP. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.
Serve para	Iniciar a fase processual da persecução criminal para aqueles crimes passíveis de ação penal privada.
Observações	Peça privativa do advogado para os crimes de ação penal privada, ou seja, aqueles que expressamente o legislador informa somente procederem mediante queixa. Sua elaboração é bem simples (art. 41 do CPP), pois se trata de uma breve apresentação dos fatos narrados com sua devida demonstração da capitulação jurídica e final pedido de condenação. Exige-se, ainda, a menção da procuração com poderes especiais (art. 44 do CPP) e, se possível, o rol de testemunhas, pois esse é o momento oportuno para a acusação. Vale ainda observar que é possível, na queixa-crime, no caso de concursos de crimes, mencionar, no mérito da peça, a modalidade de concurso, ou seja, material, formal ou crime continuado (arts. 69, 70 e 71 do CP). Já se a queixa-crime for de competência do Juizado Especial

	Criminal, muito comum também se pedir designação de audiência.
Exemplos	Calúnia (art. 138 do CP), difamação (art. 139 do CP), injúria (art. 140 do CP), esbulho possessório em propriedade particular sem violência (art. 161, II, do CP), dano por motivo egoístico (arts. 163, IV, e 167 do CP), abandono de animais (arts. 164 a 167 do CP), fraude à execução (art. 179 do CP), violação aos direitos do autor (arts. 184 a 186 do CP), exercício arbitrário das próprias razões sem violência (art. 345 do CP).
Queixa-Crime Personalíssima	Único exemplo em nossa legislação desse tipo de ação penal, que não admite substituição processual (art. 31 do CPP). Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento Art. 236 do CP: Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior: Pena – detenção, de seis meses a dois anos. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento.

7.5.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ _____ DA(O) ____ DA COMARCA _____ DO ESTADO _____

(linhas)

_____ (nome + qualificação completa), vem, por seu advogado infra-assinado, cuja

procuração com poderes especiais nos moldes do art. 44 do CPP se apresenta, com fundamento nos arts. 30 e 41 do Código de Processo Penal combinado com o art. 100, § 2.º, do Código Penal, oferecer, tempestivamente, a presente

QUEIXA-CRIME

em face de _____ (qualificação do acusado) pelos motivos a seguir aduzidos:

I – Dos Fatos

(...)

→ narrar os fatos de forma simples, reduzida, com descrição de todas as circunstâncias em que o crime ocorreu fornecidas no enunciado da questão.

II – Do Direito⁶

(...)

→ adaptação do que ocorreu no mundo dos fatos com preceitos legais. Colocar dispositivo de lei.

III – Dos Pedidos⁷

Diante do exposto, tendo o acusado infringido o(s) art.(s) ____ da Lei Penal Brasileira, requer a Vossa Excelência:

- a) recebimento da presente ação;
- b) que seja dada vista ao representante do Ministério Público;
- c) seja o mesmo citado para oferecimento de resposta;
- d) processado e ao final condenado criminalmente;
- e) que se determine a indenização a título do art. 387, IV, do CPP;
- f) notificação das testemunhas abaixo arroladas.

Termos em que,
Pede Deferimento,

Município, data

Advogado
Inscrição n.º

ROL DE TESTEMUNHAS:

7.5.2 Exercício⁸

Peça Prático-Profissional Oficial (XV Exame Unificado):

Enrico, engenheiro de uma renomada empresa da construção civil, possui um perfil em uma das redes sociais existentes na Internet e o utiliza diariamente para entrar em contato com seus amigos, parentes e colegas de trabalho. Enrico utiliza constantemente as ferramentas da Internet para contatos profissionais e lazer, como o fazem milhares de pessoas no mundo contemporâneo.

No dia 19.04.2014, sábado, Enrico comemora aniversário e planeja, para a ocasião, uma reunião à noite com parentes e amigos para festejar a data em uma famosa churrascaria da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Na manhã de seu aniversário, resolveu, então, enviar o convite por meio da rede social, publicando postagem alusiva à comemoração em seu perfil pessoal, para todos os seus contatos.

Helena, vizinha e ex-namorada de Enrico, que também possui perfil na referida rede social e está adicionada nos contatos de seu ex, soube, assim, da festa e do motivo da comemoração. Então, de seu computador pessoal, instalado em sua residência, um prédio na praia de Icaraí, em Niterói, publicou na rede social uma mensagem no perfil pessoal de Enrico.

Naquele momento, Helena, com o intuito de ofender o ex-namorado, publicou o seguinte comentário: *“não sei o motivo da comemoração, já que Enrico não passa de um idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha!”*, e, com o propósito de prejudicar Enrico perante seus colegas de trabalho e denegrir sua reputação acrescentou, ainda, *“ele trabalha todo dia embriagado! No dia 10 do mês passado, ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio, inclusive, estava tão bêbado no horário do expediente que a empresa em que trabalha teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo!”*.

Imediatamente, Enrico, que estava em seu apartamento e conectado à rede social por meio de seu *tablet*, recebeu a mensagem e visualizou a publicação com os comentários ofensivos de Helena em seu perfil pessoal. Enrico, mortificado, não sabia o que dizer aos amigos, em especial a Carlos, Miguel e Ramirez, que estavam

ao seu lado naquele instante. Muito envergonhado, Enrico tentou disfarçar o constrangimento sofrido, mas perdeu todo o seu entusiasmo, e a festa comemorativa deixou de ser realizada. No dia seguinte, Enrico procurou a Delegacia de Polícia Especializada em Repressão aos Crimes de Informática e narrou os fatos à autoridade policial, entregando o conteúdo impresso da mensagem ofensiva e a página da rede social na Internet onde ela poderia ser visualizada. Passados cinco meses da data dos fatos, Enrico procurou seu escritório de advocacia e narrou os fatos acima. Você, na qualidade de advogado de Enrico, deve assisti-lo. Informa-se que a cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, possui Varas Criminais e Juizados Especiais Criminais.

Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redija a peça cabível, excluindo a possibilidade de impetração de *habeas corpus*, sustentando, para tanto, as teses jurídicas pertinentes. (Valor: 5,00 pontos)

A peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão.

Gabarito Oficial:

Peça	Queixa-Crime
Endereçamento	Juizado Especial Criminal de Niterói
Fundamento Legal	Art. 41 CPP ou 100, § 2.º, do CP c/c o art. 30 CPP.
Preliminares	–
	Os crimes contra a honra narrados no enunciado são de menor potencial ofensivo (Art. 61 da Lei 9.099/1995). Não obstante a incidência de causa especial de aumento de pena e do concurso formal, a resposta penal não ultrapassa o patamar de 2 anos. Ainda em relação à competência, segue o entendimento da 3ª

Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, no caso de crime contra a honra praticado por meio da Internet, em redes sociais, ausentes as hipóteses do art. 109, IV e V, da CRFB/88, sendo as ofensas de caráter exclusivamente pessoal, e a conduta, dirigida a pessoa determinada e não a uma coletividade, afastam-se as hipóteses do dispositivo constitucional e, via de consequência, a competência da Justiça Federal.

No campo do processo penal, como é cediço, o direito de punir pertence ao Estado, que o exerce ordinariamente por meio do Ministério Público. Extraordinariamente, porém, a lei autoriza que o ofendido proponha a ação penal (ação penal privada); nesse caso, o direito de punir não deixa de ser do Estado, que apenas transfere ao particular o exercício do direito de ação, como no caso dos crimes contra a honra (art. 145, do CP). Nesse sentido, entende-se que a queixa-crime deve apresentar as condições para o regular exercício do direito de ação.

A queixa-crime, como petição inicial de uma ação penal, assim como o é a denúncia, deve conter os mesmos requisitos que esta (art. 41 do CPP). Como principal diferença, destaca-se que, enquanto a denúncia é subscrita por membro do Ministério Público, a queixa-crime será proposta pelo ofendido ou seu representante legal (querelante), patrocinado por advogado, sendo exigida para esse ato processual capacidade postulatória, de tal sorte que, da procuração, devem constar poderes especiais (art. 44 do CPP).

O examinando deveria, assim, redigir a queixa-crime de acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, observando, necessariamente, os requisitos ali estabelecidos, a saber: “a

exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Quanto à qualificação, deveria o examinando propor a queixa-crime em face da querelada, Helena.

Em relação à estrutura, deveria o examinando, ainda, apresentar breve relato dos fatos descritos no enunciado, com exposição dos fatos criminosos (injúria e difamação) e todas as suas circunstâncias (causa de aumento de pena), bem como a tipificação dos delitos, praticados em concurso formal (arts. 139 e 140, c/c o art. 141, III, n/f art. 70, todos do CP). Além disso, também é observado na estrutura da peça o respeito às formalidades técnico-jurídicas pertinentes, tais como: existência de endereçamento, divisão das partes, aposição de local, data e assinatura, entre outros.

Acerca da ocorrência de concurso formal de delitos, cumpre destacar que o enunciado da questão, de modo expresso, indicou que Helena publicou, em sua rede social “uma mensagem no perfil pessoal de Enrico”. Com efeito, a questão narra a existência de desígnios autônomos (dolo de injúria e dolo de difamação), razão pela qual trata-se de concurso formal imperfeito. Apenas para ratificar a existência de uma única mensagem publicada por Helena, o próprio enunciado, mais uma vez de modo expresso, indica que Enrico “recebeu a mensagem e visualizou a publicação” e mais a frente acrescenta: “Enrico procurou a delegacia de polícia (...) entregando o conteúdo impresso da mensagem ofensiva”. Sendo assim, percebe-se que houve uma única conduta de

	Helena, qual seja, uma única publicação, sendo certo que em tal publicação, com desígnios autônomos, Helena praticou dois crimes, a saber: injúria e difamação.
Pedidos	a) a designação de audiência preliminar ou de conciliação; b) a citação da querelada; c) o recebimento da queixa-crime; d) a oitiva das testemunhas arroladas; e) a procedência do pedido, com a consequente condenação da querelada nas penas dos artigos 139 e 140 c/c o art. 141, III, n/f com o art. 70, todos do CP; f) a fixação de valor mínimo de indenização, nos termos do artigo 387, IV, do CP.
Autenticação	Padrão Deveria, ainda, apresentar o rol de testemunhas, indicando expressamente os nomes das testemunhas apontadas no próprio enunciado, a saber: Carlos, Miguel e Ramirez. Levando em conta o enunciado da prova, que não exigia data determinada, não se fazia necessário que o examinando datasse sua peça com o último dia do prazo decadencial de seis meses.
	Nesta queixa-crime, nome mais conhecido da ação penal privada, de tranquila identificação, por ausência de procedimento penal instaurado, narrativa sem tipificação jurídica, menção a ofensas que nos levam a crer se tratar de crimes contra a honra, típico caso de queixa-crime e ainda nomes de testemunhas, a única dificuldade em si é justamente

Comentários

tipificar corretamente as condutas.

Evidente que o examinador, neste caso, queria aferir por parte do candidato a diferença entre honra objetiva, inerente aos crimes de calúnia e difamação, e a honra subjetiva, marca do crime de injúria. Outro detalhe que não pode passar despercebido nesta questão é a causa de aumento do art. 141, inciso III, do CP, que gera aumento de 1/3 da pena. Para esse cálculo, a sugestão é a transformação de anos em meses, tornando assim mais fácil a contagem. Senão vejamos: Pena máxima da injúria: 6 meses. Somando-se aos 12 meses da difamação, temos 18 meses. 1/3 de 18 meses são 6 meses. Soma final, 18 mais 6, 24 meses, configurando 2 anos, portanto, competência do juizado especial criminal.

Na questão, dois crimes contra a honra são cometidos. Num primeiro momento, a injúria, com os xingamentos que ofendem a honra subjetiva e que não descrevem nenhum fato. Em seguida, ao descrever a embriaguez no trabalho, a ambulância que teve que ser chamada, narrando um fato, a honra objetiva foi atacada, configurando assim a difamação.

Vale observar que num primeiro momento, a Ordem, em seu espelho de correção, exigiu o prazo na peça, o que espantou muitos candidatos, pois o enunciado não exige expressamente a apresentação da queixa no último dia do prazo. Tal equívoco foi consertado no momento do anúncio dos aprovados, em que não foi exigida a colocação do prazo.

Peça Prático-Profissional Inédita:

Peça 05:

Renata, idealizando o sonho de que um dia exerceria a profissão de advogada, se inscreve no famoso exame da “OAB”.

A bacharel, empolgada, conta para seu pai Reynaldo, que residia com ela e que pagava seus estudos, sobre a expectativa com a futura prova.

O dia tão esperado chegou e como corolário Renata não obteve êxito no exame. Isso aconteceu por mais duas vezes. Renata não seguia as dicas dos professores para se acalmar e, achando que sabia demais, não fazia a linha do tempo do procedimento sugerida pela maioria dos professores. Quando o professor dizia que era para visualizar o procedimento, Renata achava que não precisava fazer isso.

No dia 24 de janeiro de 2013, Renata foi numa festa sem a aprovação de seu pai, pois ele havia aconselhado a filha a não sair, pois deveria estudar.

Desobedecendo-o, Renata saiu com os amigos André e Felipe, de forma sorrateira enquanto seu pai dormia.

No meio da madrugada o pai descobriu que a filha não estava em casa.

Em seguida se dirigiu ao local da festa, num badalado Hotel praiano, mandando parar a música e dizendo em alto e bom som: “Renata, sua vagabunda, você não trabalha, eu te sustento, você depende de mim, eu que mando em você”. A bacharel assustada e muito envergonhada com a presença do pai, tenta se esconder, não adiantando muito, pois seu pai se voltara para todo o público presente na ocasião dizendo: “É assim que vocês querem ficar? Reprovados na OAB? Eu faço de tudo para essa menina. Os melhores cursos, eles corrigem peças, são pacientes com os alunos, fazem monitoria, respondem e-mails e essa infeliz só quer saber de badalar, ficar no ‘facebook’ e comprar maquiagem. Chega bêbada em casa e diz que um dia vai ser juíza. O Brasil está perdido. Ouviram? Ela chega em casa transtornada e no dia seguinte fica o dia inteiro na cama dormindo e reclamando de dor de cabeça”.

Enquanto todos riam, André e Felipe, que presenciaram tudo, levam Renata embora e procuram você, que foi amigo dela na época de faculdade e já possui habilitação da categoria tanto sonhada na ilustração acima. Foi inclusive colega dela de sala no curso preparatório, mas fez todas as peças, possuía letra boa e seguia as

recomendações dos professores de não inventar e fazer a linha do procedimento para saber exatamente o que pedir nas peças.

Assim, após ouvir o relato do que ocorrera, adote a medida judicial cabível no último dia do prazo.

7.6 QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA OU SUPLETIVA OU SUBSTITUTIVA (AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA)

Nome	Queixa-Crime Subsidiária ou Supletiva ou Ação Penal Privada Subsidiária da Pública
Artigo	Art. 5.º, LIX, da CF: será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal; Art.29 do CPP:Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Art.41 do CPP:A denúncia ou queixa conterà a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Art.44 do CPP:A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

	Art. 100 do CP: A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. (...) § 3.º A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal.
Prazo	6 meses a contar da inércia do Ministério Público. Art.38 do CPP. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.
Serve para	Iniciar a fase processual da persecução criminal.
Observações	Cabível quando o Ministério Público, na pessoa do Promotor de Justiça fica inerte tendo em vista sua obrigação em ajuizar a ação penal no prazo legal (princípio da obrigatoriedade). Eis o prazo: Art.46 do CPP:O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Quanto à elaboração, a única diferença em relação à queixa-crime vista no capítulo anterior é colocarmos um parágrafo referente à

perda de prazo por parte do órgão oficial da pretensão punitiva estatal.

7.6.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA _____ DO ESTADO _____

(linhas)

_____ (nome + qualificação completa), vem por seu advogado infra-assinado, tempestivamente, com fundamento no art. 5.º, LIX, da Constituição Federal, e nos arts. 41 e 44 do Código de Processo Penal combinado com o art. 100, § 3.º, do Código Penal, oferecer a presente, cuja procuração com poderes especiais anexada

QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA

em face de _____ qualificação do acusado pelos motivos a seguir aduzidos:

DA PERDA DE PRAZO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Preliminarmente vale expor que a presente ação se justifica, tendo em vista a inércia do órgão oficial da pretensão punitiva estatal, que neste instante não cumpre com sua obrigação institucional.

O prazo oficial, seguindo diretriz do art. 46 do CPP, é de 5 dias para o réu preso e de 15 dias para o réu solto.

(Destacar dia do conhecimento dos indícios de autoria pelo Ministério Público, geralmente com o recebimento de peças de informação)

DOS FATOS

(...)

→ narrar os fatos de forma simples, reduzida, com descrição de todas as circunstâncias em que o crime ocorreu, tais como hora, modo de ação e o mal produzido.

DO DIREITO

(...)

→ adaptação do que ocorreu no mundo dos fatos com preceitos legais. Colocar dispositivo de lei. Mencionar se o crime é consumado ou tentado.

DO PEDIDO

Diante do exposto, tendo o acusado (ou querelado) infringido o(s) art.(s) ____ da Lei Penal Brasileira, requer a Vossa Excelência que, recebida esta queixa-crime, o representante ministerial tenha vista da presente ação, seja o mesmo citado para oferecimento de resposta, processado e ao final condenado criminalmente, dispondo, inclusive, da indenização, conforme o art. 387, IV, do CPP.

Requer ainda a notificação das testemunhas abaixo arroladas.

Termos em que,
Pede Deferimento,

Município, data

Advogado
Inscrição n.º

ROL DE TESTEMUNHAS:

7.6.2 Exercício⁹

Peça Prático-Profissional Inédita:

Peça 06:

Liliane, solteira, 40 anos, técnica em informática, acredita que encontrou sua alma gêmea nas redes sociais. Depois de muito conversarem, o suposto bom partido informa que está trabalhando em Londres, na Inglaterra, e que em semanas estará retornando ao Brasil. Liliane cria expectativas e se vê totalmente envolvida na situação. Já se falam pelo telefone e em certa ocasião Liliane é informada pelo namorado virtual de que precisa de R\$ 5.000,00 para voltar ao Brasil, senão ele terá que ficar mais 6 meses. Liliane, perdidamente apaixonada, deposita a quantia em conta-corrente no Brasil fornecida pelo interlocutor.

O dia tão esperado chega, Liliane vai ao aeroporto e ninguém com as descrições previamente traçadas chega. Liliane, abatida, comenta com uma amiga a situação e ambas se dirigem ao posto policial do próprio aeroporto. O Delegado de Plantão informa que, muito provavelmente, Liliane fora vítima de famoso golpe.

A notícia-crime é enviada à Delegacia Especializada e são iniciadas as investigações, inclusive procedendo-se com a perícia nos computadores e telefones de Liliane. A polícia consegue identificar alguns números, que são confrontados com

números previamente estudados pelo setor de inteligência e se chega à conclusão de que Ciro é o principal suspeito. Mais investigações são feitas até que é obtido um mandado judicial de busca e apreensão na casa de Ciro e realmente são descobertas provas que o caracterizam como o golpista procurado.

Concluídas as investigações, feito o relatório conforme o art. 10, § 1.º, do CPP, os autos são enviados ao Ministério Público para deflagrar a competente ação penal. Mais de 30 dias se passaram e Liliane atesta que nada fez o Ministério Público. Você, advogado habilitado e com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, é procurado pela vítima Liliane a adotar medida judicial, diversa de *Habeas Corpus*, no caso em tela.

7.7 RESPOSTA DO ACUSADO OU RESPOSTA À ACUSAÇÃO

Nome	Resposta do Acusado
Artigo	Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei n.º 11.719, de 2008) Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (Incluído pela Lei n.º 11.719, de 2008)
	10 dias. Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei n.º

Prazo	11.719, de 2008) Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. (Redação dada pela Lei n.º 11.719, de 2008)
Serve para	Responder à acusação formalizada na inicial acusatória (denúncia ou queixa-crime).
	Novidade trazida pela Lei 11.719/2008. Sobre a sua terminologia, entendemos ser necessário abandonar o termo defesa prévia por uma série de motivos. Senão vejamos: a) antiga defesa prévia era num momento procedimental distinto, após o interrogatório; b) o prazo era de 3 dias; c) era dispensável, servindo apenas para informar o rol de testemunhas; d) defesa prévia não se abordava nenhuma tese defensiva. Ora, com tantas diferenças, acreditamos que o melhor é se deixar de lado a antiga terminologia e adotar "Resposta do Acusado". Peça essencial para a defesa, em que deverão ser abordadas TODAS as teses defensivas, seguindo sempre aquela linha já estipulada da melhor tese em primeiro lugar. A melhor orientação no momento de elaboração desta peça processual é analisarmos se temos exceções (art. 95 do CPP) e preliminares. Observemos que as exceções na prática podem e devem vir em apartado, como reza o art. 396-A, § 1.º, do CPP. Entretanto, para efeitos desta elaboração, elas deverão ser inseridas antes das

Observações

preliminares.

Vimos que configuram as preliminares as extinções da punibilidade (art. 107 do CP), as nulidades (art. 563 do CPP) e as proteções constitucionais do art. 5.º da CF.

No art. 396-A do CPP, temos a exata profundidade desta peça, quando o próprio legislador informa que tudo deve ser colocado, além de oferecimento de documentos e justificações, especificar provas e arrolar testemunhas.

Todavia, o ideal é que apresentemos subsídios necessários para que o magistrado no momento seguinte possa absolver sumariamente. Explica-se:

O momento procedimental seguinte é o da absolvição sumária, assim, se conseguirmos demonstrar alguns dos geradores dessa absolvição, melhor será para o acusado. Vejamos o artigo mencionado:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: (Redação dada pela Lei n.º 11.719, de 2008)

I – a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (Incluído pela Lei n.º 11.719, de 2008)

II – a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimizabilidade; (Incluído pela Lei n.º 11.719, de 2008)

III – que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (Incluído pela Lei n.º 11.719, de 2008)

IV – extinta a punibilidade do agente. (Incluído pela Lei n.º 11.719, de 2008)

Assim, o acusado deve demonstrar, no mérito, causas excludentes de ilicitude (art. 23 do CP – legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal), excludentes de culpabilidade (doença mental, embriaguez, erro de proibição, coação moral irresistível e obediência hierárquica), atipicidade, desclassificação, tentativa, desistência voluntária ou arrependimento eficaz etc.

7.7.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA
____ DO ESTADO ____

(linhas)

Proc. n.º ____

____ (nome), já qualificado, vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento nos arts. 396 e 396-A do CPP, apresentar

RESPOSTA DO ACUSADO

pelos motivos a seguir aduzidos.

1 – Dos Fatos

(...)

2 – Das Exceções (art. 95, CPP)

(...)

3 – Pelo Não Recebimento da Ação Penal (art. 395, CPP)¹⁰

(...)

4 – Das Preliminares

(...)

5 – Do Direito

(...)

6 – Das Provas

(...)

7 – Do Pedido

(...)

8 – Das Testemunhas

(...)

Termos em que,
Pede Deferimento,

Município, data

Advogado
Inscrição n.º

7.7.2 Exercícios

Peça Prático-Profissional Oficial (II Exame Unificado):

A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul recebe notícia-crime identificada, imputando a Maria Campos a prática de crime, eis que mandaria crianças brasileiras para o estrangeiro com documentos falsos. Diante da notícia-crime, a autoridade policial instaura inquérito policial e, como primeira providência, representa pela decretação da interceptação das comunicações telefônicas de Maria Campos, “dada a gravidade dos fatos noticiados e a notória dificuldade de apurar crime de tráfico de menores para o exterior por outros meios, pois o ‘modus operandi’ envolve sempre atos ocultos e exige estrutura organizacional sofisticada, o que indica a existência de uma organização criminosa integrada pela investigada Maria”. O Ministério Público opina favoravelmente e o juiz defere a medida, limitando-se a adotar, como razão de decidir, “os fundamentos explicitados na representação policial”.

No curso do monitoramento, foram identificadas pessoas que contratavam os serviços de Maria Campos para providenciar expedição de passaporte para viabilizar viagens de crianças para o exterior. Foi gravada conversa telefônica de Maria com um funcionário do setor de passaportes da Polícia Federal, Antônio Lopes, em que

Maria consultava Antônio sobre os passaportes que ela havia solicitado, se já estavam prontos, e se poderiam ser enviados a ela. A pedido da autoridade policial, o juiz deferiu a interceptação das linhas telefônicas utilizadas por Antônio Lopes, mas nenhum diálogo relevante foi interceptado.

O juiz, também com prévia representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, deferiu a quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, tendo sido identificado um depósito de dinheiro em espécie na conta de Antônio, efetuado naquele mesmo ano, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). O monitoramento telefônico foi mantido pelo período de quinze dias, após o que foi deferida medida de busca e apreensão nos endereços de Maria e Antônio. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “diante da gravidade dos fatos e da real possibilidade de serem encontrados objetos relevantes para investigação, defiro requerimento de busca e apreensão nos endereços de Maria (Rua dos Casais, 213) e de Antônio (Rua Castro, 170, apartamento 201)”. No endereço de Maria Campos foi encontrada apenas uma relação de nomes, que, na visão da autoridade policial, seriam clientes que teriam requerido a expedição de passaportes com os nomes de crianças que teriam viajado para o exterior. No endereço indicado no mandado de Antônio Lopes nada foi encontrado. Entretanto, os policiais que cumpriram a ordem judicial perceberam que o apartamento 202 do mesmo prédio também pertencia ao investigado, motivo pelo qual nele ingressaram, encontrando e apreendendo a quantia de cinquenta mil dólares em espécie. Nenhuma outra diligência foi realizada.

Relatado o inquérito policial, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia nos seguintes termos: “o Ministério Público vem oferecer denúncia contra Maria Campos e Antônio Lopes, pelos fatos a seguir descritos: Maria Campos, com o auxílio do agente da polícia federal Antônio Lopes, expediu diversos passaportes para crianças e adolescentes, sem observância das formalidades legais. Maria tinha a finalidade de viabilizar a saída dos menores do país. A partir da quantia de dinheiro apreendida na casa de Antônio Lopes, bem como o depósito identificado em sua conta bancária, evidente que ele recebia vantagem indevida para efetuar a liberação dos passaportes. Assim agindo, a denunciada Maria Campos está incurso

nas penas do artigo 239, parágrafo único, da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e nas penas do art. 333, parágrafo único, c/c o art. 69, ambos do Código Penal. Já o denunciado Antônio Lopes está incurso nas penas do art. 239, parágrafo único, da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e nas penas do art. 317, § 1.º, c/c art. 69, ambos do Código Penal”.

O juiz da 15.^a Vara Criminal de Porto Alegre, RS, recebeu a denúncia, nos seguintes termos: “compulsando os autos, verifico que há prova indiciária suficiente da ocorrência dos fatos descritos na denúncia e do envolvimento dos denunciados. Há justa causa para a ação penal, pelo que recebo a denúncia. Citem-se os réus, na forma da lei”. Antônio foi citado pessoalmente em 27.10.2010 (quarta-feira) e o respectivo mandado foi acostado aos autos dia 01.11.2010 (segunda-feira). Antônio contratou você como Advogado, repassando-lhe nomes de pessoas (Carlos de Tal, residente na Rua 1, n. 10, nesta capital; João de Tal, residente na Rua 4, n. 310, nesta capital; Roberta de Tal, residente na Rua 4, n. 310, nesta capital) que prestariam relevantes informações para corroborar com sua versão. Nessa condição, redija a peça processual cabível desenvolvendo TODAS AS TESES DEFENSIVAS que podem ser extraídas do enunciado com indicação de respectivos dispositivos legais. Apresente a peça no último dia do prazo.

Gabarito Oficial:

Peça	Resposta do Acusado
Endereçamento	Juiz de Direito 15. ^a Vara Criminal de Porto Alegre, RS
Fundamento Legal	Art. 396 c/c art. 396-A do CPP
	A primeira questão preliminar que deverá ser arguida é incompetência da Justiça Estadual para processar o feito, eis que o crime é de competência federal, nos termos do que prevê o art. 109, V, da Constituição Federal. Relativamente a esse

tema, admitiu-se também a arguição de incompetência com base no inciso IV do art. 109 da Constituição. Em ambos os casos, será considerada válida a indicação da transnacionalidade do crime ou a circunstância de ser uma acusação de crime supostamente praticado por funcionário público federal no exercício das funções e com estas relacionadas. Admite-se também a simples referência ao dispositivo da Constituição, ou até mesmo à Súmula 254, do extinto mas sempre Egrégio Tribunal Federal de Recursos. Não será aceita, por outro lado, a referência ao art. 109, I, da Constituição nem às Súmulas 122 e/ou 147 do STJ.

A segunda questão preliminar que deverá ser arguida é nulidade na interceptação telefônica. Aqui, foram pontuados separadamente os dois argumentos para sustentar a nulidade: (a) falta de fundamentação da decisão nos termos do que disciplina o art. 5.º da Lei 9.296/1996 e o art. 93, IX, da Constituição da República; no mesmo sentido; (b) impossibilidade de se decretar a medida de interceptação telefônica como primeira medida investigativa, não respeitando o princípio da excepcionalidade, violando o previsto no art. 2.º, II, da Lei 9.296/1996. Na nulidade da interceptação não se aceitará o argumento do art. 4.º, acerca da ausência de indicação de como seria implementada a medida. Também não se aceitará a nulidade decorrente da incompetência para a decretação, eis que o argumento da incompetência era objeto de pontuação específica.

A terceira questão preliminar que deverá ser arguida é a nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão nula, eis que genérica e sem fundamentação, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição da República.

Preliminares

A quarta questão preliminar que deverá ser arguida é a nulidade da apreensão dos cinquenta mil dólares, eis que o ingresso no outro apartamento de Antônio, onde estava a quantia, não estava autorizado judicialmente. Relativamente a este ponto, era indispensável que se associasse a ilegalidade ao conceito de prova ilícita e conseqüentemente requerendo-se a desconsideração do dinheiro lá apreendido.

A quinta questão preliminar que deverá ser arguida é a inépcia da inicial acusatória, eis que a conduta é genérica, sem descrever as elementares do tipo de corrupção passiva e sem imputar fato determinado. Isso viola o previsto no art. 8.º, 2, "b", do Decreto 678/1992, o qual prevê como garantia do acusado a comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada. Além disso, limita o exercício do direito de defesa, em desrespeito ao previsto no art. 5.º, LV, da Constituição da República. Por fim, há violação ao art. 41 do Código de Processo Penal.

Em relação ao crime de corrupção passiva, previsto no art. 317, § 1.º, do Código Penal, o candidato deverá apontar a falta de justa causa para a ação penal. Afirmativas genéricas de falta de justa causa não serão consideradas suficientes para obtenção da pontuação. Com efeito, é preciso que o candidato faça um cotejo entre o tipo penal (com seus elementos normativos, objetivos e subjetivos) e os fatos narrados no enunciado da questão. São exemplos de argumentos: não há prova suficiente de que o réu recebia vantagem indevida para emissão de passaportes de forma irregular; não há nenhuma prova de que os passaportes fossem emitidos de forma irregular; nenhum passaporte foi apreendido ou periciado na fase de inquérito

Fundamentos

policial; não há prova de que os passaportes supostamente requeridos por Maria na ligação telefônica foram, efetivamente, emitidos; não há prova de que houve o exaurimento do crime, nos termos do que prevê o § 1.º do art. 317, do Código Penal, ou seja, que Antônio tenha efetivamente praticado ato infringindo dever funcional.

No que tange ao crime previsto no art. 239, parágrafo único, da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), não há qualquer indício da prática delituosa por parte de Antônio, eis que não há sequer referência de que ele tivesse ciência da intenção de Maria. Em outras palavras, o candidato deverá indicar que não havia consciência de que Antônio estivesse colaborando para a prática do crime supostamente praticado por Maria, inexistindo, dessa forma, dolo. Assim como no caso do crime anterior, afirmações genéricas de falta de justa causa não serão consideradas suficientes para obtenção da pontuação. Com efeito, é preciso que o candidato faça um cotejo entre o tipo penal (com seus elementos normativos, objetivos e subjetivos) e os fatos narrados no enunciado da questão. Dessa forma, relativamente à atipicidade do crime do art. 239, é indispensável que o candidato apontasse a ausência de dolo ou falasse do elemento subjetivo do tipo. Argumentos relacionados exclusivamente ao nexo causal não serão considerados aptos.

Ao final, o candidato deverá especificar provas, indicando rol de testemunhas. Os requerimentos devem ser de declaração das nulidades, absolvição sumária e, alternativamente, instrução processual com produção da prova requerida pela defesa. Para pontuar o pedido não é necessário que o candidato faça todos os pedidos constantes do gabarito, mas que seus pedidos

Pedidos	estejam coerentes com a argumentação desenvolvida na peça. Por outro lado, se houver argumentos flagrantemente equivocados em maior número do que adequados, o pedido deixará de ser pontuado. No pedido, não foi admitida absolvição com fulcro nos arts. 386 e 415 do Código de Processo Penal, já que eles tratam das hipóteses de absolvição após o transcurso do processo, e não na fase de resposta.
Autenticação	O último dia do prazo é 08.11.2010, eis que a contagem inicia na data da intimação pessoal. Não serão aceitas datas como 06 ou 07 de novembro, pois o enunciado é claro ao especificar que a petição deveria ser protocolada no último dia do prazo, o qual se prorrogou até o dia útil subsequente. Erros como 08 de outubro e 08 de setembro (ou qualquer outra data) serão considerados insuscetíveis de pontuação.
	Merece destaque o gabarito bem trabalhado da banca examinadora nesta questão. O maior cuidado seria na identificação da peça. Não poderíamos nos seduzir pela presença do funcionário público e elaborarmos uma defesa preliminar do art. 514 do CPP, já que esta peça é antes do recebimento da ação e a questão nos remete para um momento posterior, com o devido recebimento e a citação. Portanto, a peça a se elaborar é a resposta à acusação do art. 396 c/c art. 396-A do CPP. Outro destaque que merece essa questão é relativo à competência da Justiça Federal, conforme o art. 109 da CF. A falsificação de passaporte afronta diretamente interesses da UF, razão pela qual a justiça estadual é incompetente para tal julgamento. Este detalhe deve ser arguido por meio de exceção no corpo da resposta, visto que este é o momento

Comentários

procedimental oportuno para tanto.

No mais, enfatizando que o gabarito está muito bem elaborado, destacamos a nulidade e preliminar que envolve a interceptação telefônica. Segundo a Lei 9.296/1996 que rege a matéria, só será possível a gravação de duas pessoas que não sabem da gravação por um terceiro obedecendo-se os seguintes requisitos:

- Mandado judicial;
- Indícios de autoria e materialidade;
- Para fins criminais;
- Somente para crimes apenados com reclusão;
- Em último caso;
- Fato certo e determinado.

Percebemos claramente o desrespeito de tais requisitos, motivos estes que levaram à argumentação preliminar.

Peça Prático-Profissional Oficial (VIII Exame Unificado):

Visando abrir um restaurante, José pede vinte mil reais emprestados a Caio, assinando, como garantia, uma nota promissória no aludido valor, com vencimento para o dia 15 de maio de 2010. Na data mencionada, não tendo havido pagamento, Caio telefona para José e, educadamente, cobra a dívida, obtendo do devedor a promessa de que o valor seria pago em uma semana. Findo o prazo, Caio novamente contata José, que, desta vez, afirma estar sem dinheiro, pois o restaurante não apresentara o lucro esperado. Indignado, Caio comparece no dia 24 de maio de 2010 ao restaurante e, mostrando para José uma pistola que trazia consigo, afirma que a dívida deveria ser saldada imediatamente, pois, do contrário, José pagaria com a própria vida. Aterrorizado, José entra no restaurante e telefona para a polícia, que,

entretanto, não encontra Caio quando chega ao local.

Os fatos acima referidos foram levados ao conhecimento do delegado de polícia da localidade, que instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido. Ao final da investigação, tendo Caio confirmado a ocorrência dos eventos em sua integralidade, o Ministério Público o denuncia pela prática do crime de extorsão qualificada pelo emprego de arma de fogo. Recebida a inicial pelo juízo da 5.^a Vara Criminal, o réu é citado no dia 18 de janeiro de 2011.

Procurado apenas por Caio para representá-lo na ação penal instaurada, sabendo-se que Joaquim e Manoel presenciaram os telefonemas de Caio cobrando a dívida vencida, e com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redija, no último dia do prazo, a peça cabível, invocando todos os argumentos em favor de seu constituinte.

Gabarito Oficial:

Peça	Resposta do Acusado
Endereçamento	Juiz da 5. ^a Vara Criminal
Fundamento Legal	Art. 396 c/c art. 396-A do CPP
Preliminares e Fundamentos	Na referida peça, o examinando deverá demonstrar que a conduta descrita pelo Ministério Público caracterizaria apenas o crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do CP, uma vez que, para a configuração do delito de extorsão, seria imprescindível que a vantagem fosse indevida, sendo a conduta, com relação ao delito do art. 158, atípica. Outrossim, o examinando deverá esclarecer que o Ministério Público não é parte legítima para figurar no polo ativo de processo criminal pelo delito de exercício arbitrário das próprias

	razões, pois não houve emprego de violência, sendo este perseguível por ação penal privada. Em razão disso, o examinando deverá afirmar que caberia a José ajuizar queixa-crime dentro do prazo decadencial de seis meses, contados a partir do dia 24 de maio de 2010 e, uma vez não tendo sido oferecida a queixa-crime até o dia 23 de novembro de 2010, incidiu sobre o feito o fenômeno da decadência, restando extinta a punibilidade de Caio.
Pedidos	O examinando deverá pedir a absolvição sumária de Caio, com fundamento no art. 397, III (pela atipicidade do delito de extorsão) e IV (pela incidência da decadência), do CPP. Além de tais pedidos, com base no princípio da eventualidade, deverá requerer a produção de prova testemunhal, com a oitiva de Joaquim e Manoel.
Autenticação	28 de janeiro de 2011
Comentários	Peça com gabarito oficial de certa forma confuso, visto que não foi cobrada e exigida a separação das preliminares dos fundamentos. Identificamos a resposta pelo momento processual após a citação do réu. Atentos à vara criminal já determinada no enunciado e com a contagem do prazo de 10 dias para oferecimento da resposta. Sem exceções, o candidato teria que adivinhar que, partindo-se da premissa de que o crime narrado não era de extorsão, e sim de exercício arbitrário das próprias razões, as outras fundamentações viriam conseqüentemente. Assim, o MP não seria parte legítima, o juízo competente seria o Juizado Especial

Criminal e a parte havia perdido o prazo decadencial de 6 meses. Uma tese gerando todas as outras demais. Em respeito ao ilustre examinador, deixemos nossas críticas ao gabarito de lado.

Peça Prático-Profissional Oficial (XXI Exame Unificado):

Gabriela, nascida em 28 de abril de 1990, terminou relacionamento amoroso com Patrick, não mais suportando as agressões físicas sofridas, sendo expulsa do imóvel em que residia com o companheiro em comunidade carente na cidade de Fortaleza, Ceará, juntamente com o filho do casal de apenas dois anos. Sem ter familiares no Estado e nem outros conhecidos, passou a pernoitar com o filho em igrejas e outros locais de acesso público, alimentando-se a partir de ajudas recebidas de desconhecidos. Nessa época, Gabriela fez amizade com Maria, outra mulher em situação de rua que frequentava os mesmos espaços que ela. No dia 24 de dezembro de 2010, não mais aguentando a situação e vendo o filho chorar e ficar doente em razão da ausência de alimentação, após não conseguir emprego ou ajuda, Gabriela decidiu ingressar em um grande supermercado da região, onde escondeu na roupa dois pacotes de macarrão, cujo valor totalizava R\$ 18,00 (dezoito reais). Ocorre que a conduta de Gabriela foi percebida pelo fiscal de segurança, que a abordou no momento em que ela deixava o estabelecimento comercial sem pagar pelos bens, e apreendeu os dois produtos escondidos. Em sede policial, Gabriela confirmou os fatos, reiterando a ausência de recursos financeiros e a situação de fome e risco físico de seu filho. Juntado à Folha de Antecedentes Criminais sem outras anotações, o laudo de avaliação dos bens subtraídos confirmando o valor, e ouvidos os envolvidos, inclusive o fiscal de segurança e o gerente do supermercado, o auto de prisão em flagrante e o inquérito policial foram encaminhados ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em face de Gabriela pela prática do crime do art. 155, *caput*, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, além de ter opinado pela liberdade da acusada. O magistrado em atuação perante o juízo competente, no dia 18 de janeiro de 2011, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, concedeu liberdade

provisória à acusada, deixando de converter o flagrante em preventiva, e determinou que fosse realizada a citação da denunciada. Contudo, foi concedida a liberdade para Gabriela antes de sua citação e, como ela não tinha endereço fixo, não foi localizada para ser citada. No ano de 2015, Gabriela consegue um emprego e fica em melhores condições. Em razão disso, procura um advogado, esclarecendo que nada sabe sobre o prosseguimento da ação penal a que respondia. Disse, ainda, que Maria, hoje residente na rua X, na época dos fatos também era moradora de rua e tinha conhecimento de suas dificuldades. Diante disso, em 16 de março de 2015, segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país, Gabriela e o advogado compareceram ao cartório, onde são informados que o processo estava em seu regular prosseguimento desde 2011, sem qualquer suspensão, esperando a localização de Gabriela para citação. Naquele mesmo momento, Gabriela foi citada, assim como intimada, junto ao seu advogado, para apresentação da medida cabível. Cabe destacar que a ré, acompanhada de seu patrono, já manifestou desinteresse em aceitar a proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo Ministério Público. Considerando a situação narrada, apresente, na qualidade de advogado(a) de Gabriela, a peça jurídica cabível, diferente do *habeas corpus*, apresentando todas as teses jurídicas de direito material e processual pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo. (Valor: 5,00) Obs.: a peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

Gabarito Oficial:

Peça	Resposta à Acusação
Endereçamento	Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da... Vara Criminal da Comarca de Fortaleza do Estado do Ceará
Fundamentação	Arts. 396 c/c 396-A do CPP
	Em um primeiro momento, é possível perceber a

existência de causa de extinção da punibilidade, qual seja, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. Isso porque os fatos ocorreram em 24 de dezembro de 2010, ocasião em que Gabriela tinha apenas 20 anos, já que nascida em 28 de abril de 1990. Nos termos do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional do menor de 21 anos na data dos a causa de extinção da punibilidade como hipótese de absolvição sumária, nos termos do art. 397, inciso IV, do CPP. Ademais, deveria o(a) advogado(a) alegar que o fato narrado evidentemente não constitui crime, porque adequado ao caso o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. A jurisprudência e a doutrina pátrias, de maneira absolutamente majoritárias, reconhecem que a tipicidade é formada por um caráter formal e por um caráter material. A tipicidade formal é adequação da conduta praticada àquela prevista no tipo. No caso, Gabriela subtraiu coisa alheia móvel; logo, sua conduta é formalmente típica. Já a tipicidade material seria a significativa lesão ao bem jurídico protegido pela norma. Nesse contexto, as lesões ínfimas, insignificantes, não seriam suficientes para atingir o bem jurídico protegido e, com base no princípio da lesividade, tais condutas sequer seriam materialmente típicas. Como conclusão, a aplicação do princípio da bagatela leva ao reconhecimento da atipicidade da conduta. Gabriela subtraiu dois pacotes de macarrão que totalizavam R\$ 18,00 (dezoito reais). O valor subtraído por Gabriela permite a aplicação do princípio da bagatela, afastando a tipicidade material da conduta e justificando sua absolvição sumária com base no art. 397, inciso III, do

Preliminares e Mérito

CPP. Cabe mencionar as circunstâncias do caso: poderia Gabriela subtrair mais bens; o valor era ínfimo para um grande supermercado da cidade; e a autora nunca praticara tais fatos anteriormente. Se isso não fosse suficiente, ainda deveria o advogado destacar a existência de manifesta causa de exclusão de ilicitude, qual seja, o estado de necessidade. Prevê o art. 24 do Código Penal que atua em estado de necessidade aquele que pratica fato descrito como crime para salvar de perigo atual, que não causou por sua conduta, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir fatos deverá ser computado pela metade, sendo tal disposição aplicável ao caso concreto. Foi imputada a Gabriela a prática do crime de furto simples em sua modalidade tentada. A pena máxima em abstrato prevista para o delito imputado é de quatro anos (com a causa de diminuição, seria de dois anos e oito meses de reclusão); logo, o prazo prescricional de oito anos, previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal, cairá para quatro anos na hipótese. Desde a data do último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, o recebimento da denúncia em 18 de janeiro de 2011, já se passaram mais de quatro anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal. Menciona-se que o Código de Processo Penal trata naquelas circunstâncias. Claramente, Gabriela estava com seu direito e de seu filho em situação de risco atual e concreto, em especial porque a criança estava ficando doente em razão da ausência de alimentação. Ademais, a situação de perigo não fora por

	ela criada, já que expulsa do imóvel por seu ex-companheiro que lhe agredia, além de não conseguir emprego ou ajuda financeira de outras pessoas. Por fim, não era razoável exigir que Gabriela sacrificasse a integridade física de seu filho em detrimento de lesão de ínfimo valor para grande supermercado da região.
Pedidos	Assim, diante do estado de necessidade, deve ser formulado pedido de absolvição sumária com fundamento no art. 397, inciso I, do CPP. Após os pedidos, deve o(a) examinando(a) apresentar rol de testemunhas, indicando Maria para o caso de não acolhimento do requerimento de absolvição sumária.
Autenticação	O prazo para elaboração da peça processual, nos termos do art. 396 do CPP, é de 10 dias, sendo que a citação/intimação da ré e de seu advogado ocorreu em 16 de março de 2015, iniciando-se o prazo em 17 de março de 2015 e terminando em 26 de março de 2015.
Comentários	Uma resposta do acusado clássica, muito bem elaborada pela Fundação Getulio Vargas que, mais uma vez, exigiu dos candidatos o estudo da prescrição, tema recorrente nas suas provas. No mérito, como se trata de uma resposta do acusado, só se pode alegar teses referentes à absolvição sumária do art. 397 do CPP e nesta peça apareceram mais de uma, o que gerou um trabalho minucioso na confecção da peça. Observamos mais uma vez, que a resposta do acusado é daquelas peças que devemos, estrategicamente, pensar nas etapas, uma de cada vez.

Peça Prático-Profissional Oficial (XXV Exame):

Patrick, nascido em 04.06.1960, tio de Natália, jovem de 18 anos, estava na varanda de sua casa em Araruama, em 05.03.2017, no interior do Estado do Rio de Janeiro, quando vê o namorado de sua sobrinha, Lauro, agredindo-a de maneira violenta, em razão de ciúmes. Verificando o risco que sua sobrinha corria com a agressão, Patrick gritou com Lauro, que não parou de agredi-la. Patrick não tinha outra forma de intervir, porque estava com uma perna enfaixada devido a um acidente de trânsito. Ao ver que as agressões não cessavam, foi até o interior de sua residência e pegou uma arma de fogo, de uso permitido, que mantinha no imóvel, devidamente registrada, tendo ele autorização para tanto. Com intenção de causar lesão corporal que garantisse a debilidade permanente de membro de Lauro, apertou o gatilho para efetuar disparo na direção de sua perna. Por circunstâncias alheias à vontade de Patrick, a arma não funcionou, mas o barulho da arma de fogo causou temor em Lauro, que empreendeu fuga e compareceu à Delegacia para narrar a conduta de Patrick. Após meses de investigações, com oitiva dos envolvidos e das testemunhas presenciais do fato, quais sejam, Natália, Maria e José, estes dois últimos sendo vizinhos que conversavam no portão da residência, o inquérito foi concluído, e o Ministério Público ofereceu denúncia, perante o juízo competente, em face de Patrick como incurso nas sanções penais do art. 129, § 1.º, inciso III, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Juntamente da denúncia, vieram as principais peças que constavam do inquérito, inclusive a Folha de Antecedentes Criminais, na qual constava outra anotação por ação penal em curso pela suposta prática do crime do art. 168 do Código Penal, bem como o laudo de exame pericial na arma de Patrick apreendida, o qual concluiu pela total incapacidade de efetuar disparos. Em busca do cumprimento do mandado de citação, o oficial de justiça comparece à residência de Patrick e verifica que o imóvel se encontrava trancado. Apenas em razão desse único comparecimento no dia 26.02.2018, certifica que o réu estava se ocultando para não ser citado e realiza, no dia seguinte, citação por hora certa, juntando o resultado do mandado de citação e intimação para defesa aos autos no mesmo dia. Maria, vizinha que presenciou a conduta do oficial de justiça, se assusta e liga para o advogado de

Patrick, informando o ocorrido e esclarecendo que ele se encontra trabalhando e ficará embarcado por 15 dias. O advogado entra em contato com Patrick por e-mail e este apenas consegue encaminhar uma procuração para adoção das medidas cabíveis, fazendo uma pequena síntese do ocorrido por escrito. Considerando a situação narrada, presente, na qualidade do advogado de Patrick, a peça jurídica cabível, diferente do habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas de direito material e processual pertinentes. A peça deverá ser datada do último dia do prazo.

Gabarito Oficial:

Peça	Resposta à Acusação
Endereçamento	A peça deveria ser encaminhada para a Vara Criminal da Comarca de Araruama, Rio de Janeiro, local onde o delito imputado teria sido praticado.
Fundamentação	Art. 396 c/c o art. 396-A do CPP
	Já de início, preliminarmente, deveria o advogado requerer o reconhecimento da nulidade do ato de citação. O Código de Processo Penal, em seu art. 362, prevê a chamada “citação por hora certa”, que será admitida na hipótese de o réu estar se ocultando para não ser citado, devendo tal informação ser devidamente certificada por oficial de justiça. Ocorre que, no caso, não seria possível a citação por hora certa, já que não havia nenhum indício concreto de que o acusado estaria se ocultando para não ser citado. Simplesmente a residência de Patrick encontrava-se fechada porque ele estava trabalhando em embarcação, sendo prematura a conclusão do oficial de justiça apenas com base em um único comparecimento na residência daquele que pretendia citar. Dessa forma, a citação foi inválida e certamente houve prejuízo ao exercício do direito

Preliminares e Mérito

de defesa, tendo em vista que o advogado não conseguiu conversar com o réu sobre os fatos antes de apresentar resposta à acusação. Superada tal questão, diante das informações constantes do enunciado, caberia ao advogado do denunciado pleitear a absolvição sumária de seu cliente, tendo em vista que o fato evidentemente não constitui infração penal e ocorreu causa manifesta de exclusão da ilicitude. O fato narrado evidentemente não constitui crime. De acordo com o art. 17 do Código Penal, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o delito. Trata-se de aplicação do instituto do crime impossível, onde se valoriza mais a vertente objetiva em detrimento da subjetiva. No crime impossível, o agente age com dolo na prática do crime e efetivamente este não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Todavia, a tentativa não é punida pelo fato de ser impossível a consumação, logo o bem jurídico não seria colocado em risco suficiente para justificar a intervenção do Direito Penal. Na situação apresentada, Patrick buscou praticar um crime de lesão corporal grave mediante disparo de arma de fogo. Ocorre que aquela arma era totalmente incapaz de efetuar disparos, conforme consta do laudo pericial acostado, logo houve ineficácia absoluta do meio utilizado, impedindo a punição da tentativa. O reconhecimento do crime impossível gera a atipicidade da conduta e, conseqüentemente, cabível a absolvição sumária pelo fato evidentemente não constituir crime, com fulcro no art. 397, inciso III, do CPP. Por outro lado, diante da legítima defesa, deveria ser formulado pedido de absolvição sumária com fundamento no art. 397, inciso I, do CPP. Consta do enunciado que Patrick somente agiu com intenção de lesionar Lauro para resguardar a integridade física

	de sua sobrinha. De acordo com o art. 25 do Código Penal, haverá legítima defesa quando alguém, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sendo esta causa de exclusão da ilicitude, nos termos do art. 23, inciso II, do Código Penal. Patrick agiu para proteger direito de terceiro (sua sobrinha) e para repelir injusta agressão, já que Lauro estava agredindo Natália de maneira relevante e exagerada em razão de ciúmes. Os meios utilizados foram moderados e necessários, já que Patrick encontrava-se imobilizado na perna e no braço, impedindo que entrasse em luta corporal sem utilizar outro meio que não a arma de fogo. Ademais, Patrick não pretendia matar Lauro, mas apenas lesionar.
Pedidos	Após os pedidos de absolvição sumária e de nulidade, deveria o examinando apresentar rol de testemunhas, indicando Maria, José e Natália, no máximo de 08.
Autenticação	O prazo para elaboração da peça processual, nos termos do art. 396 do CPP, é de 10 dias, sendo que a intimação do réu ocorreu em 27 de fevereiro de 2018, iniciando-se o prazo em 28 de fevereiro de 2018 e terminando em 9 de março de 2018. A petição deveria ter indicação de local, data, assinatura, advogado e nº OAB.
Comentários	Trata-se de uma peça muito bem elaborada pela banca examinadora onde se exige do candidato a estratégia necessária para uma boa elaboração de resposta à acusação. Pesquisa de exceções e pelo não recebimento, que não teve na peça, as famosas preliminares (Art. 107 CP e art. 564 CPP) e, em seguida, o único mérito cabível que é a absolvição sumária

do art. 397 CPP. No mérito, a banca prestigiou tese conhecida de crime impossível do art. 17 CP.

Peça Prático-Profissional Inédita:¹¹

Peça 07:

Durval está enfurecido por ter sido demitido de seu emprego de carteiro da Agência de Correios e Telégrafos. Trabalhou durante anos e em sua visão era um ótimo funcionário. Com quase 50 anos, está sem emprego e resolve se vingar. Perto de onde mora, em sua humilde comunidade, existe uma agência dos correios comunitária onde toda a vizinhança faz uso dos serviços postais.

Com uma máscara ninja, para não ser reconhecido pelos moradores, Durval primeiramente assalta munido de um facão Anderson, novo carteiro que ficara em seu lugar. Anderson, com 65 anos, é adorado na comunidade e os Correios lhe dão essa oportunidade de novo emprego, seguindo, assim, política institucional. Rouba corrente, relógio e todas as cartas. Logo em seguida, dirige-se à agência comunitária, agora munido de coquetéis molotov, e com uma arma de brinquedo leva pânico à agência.

Rende funcionários, grita ferozmente e ainda agride superficialmente alguns clientes da agência. O fogo se espalha com os coquetéis lançados e todo o pouco dinheiro da agência comunitária é levado por Durval.

O delegado abre inquérito policial e todos os presentes naquela tarde na agência são ouvidos e demonstram intenção na apuração dos fatos. Teresinha, ex-amante de Durval, o identifica pelo fato de ele estar usando uma das camisas que foram dadas de presente por ela em um dos aniversários na época do relacionamento.

Durante o inquérito, a polícia invade, por volta das 20h, a simples casa de Durval na comunidade e realiza uma busca domiciliar e pessoal.

Durval, primário e de bons antecedentes, é denunciado com base na diligência efetuada e pelas demais informações colhidas. Segundo o ilustre membro do Ministério Público, estaria incurso nos crimes de roubo qualificado, incêndio, sequestro e lesão corporal grave em concurso material. O Ministério Público apenas

menção em sua exordial os tipos penais.

O magistrado da 12.^a Vara Criminal da Comarca da Capital recebe a denúncia cujo número recebido fora 2012.098.098-32 e cita Durval para apresentar a medida jurídica cabível. Durval recebe o mandado em 10.09.2012, uma quinta-feira, todavia foi juntada aos autos somente na terça-feira seguinte. Apresente no primeiro dia do prazo a medida cabível exclusiva de quem possui capacidade postulatória.

7.8 EXCEÇÕES

Nome	Exceção
Artigo	Art.95. Poderão ser opostas as exceções de: I – suspeição; II – incompetência de juízo; III – litispendência; IV – ilegitimidade de parte; V – coisa julgada.
Prazo	10 dias. Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei 11.719, de 2008) Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando

	necessário. (Incluído pela Lei 11.719, de 2008) § 1.º A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)
Serve para	Meio de defesa para impedir ou retardar a ação penal.
	Inicialmente, cumpre destacar que numa prova prático-profissional as exceções geralmente são inseridas na resposta do acusado. Na prática forense, o advogado pode optar por apresentar em apartado, assim como autoriza o código. Temos, segundo o art. do 95 CPP anteriormente exposto, cinco hipóteses de exceções que podem ser arguidas no mesmo momento da Resposta do Acusado. A boa técnica forense exige que ambas sejam apresentadas à parte, todavia num Exame não conseguimos vislumbrar tal hipótese. As exceções podem ser divididas em peremptórias, quando são utilizadas para encerrar o processo ou dilatórias, quando visam postergar a duração do processo. Entre as que extinguem estão as de litispendência e a coisa julgada. Entre as que “atrasam” o curso do processo estão a suspeição, a ilegitimidade e a incompetência. Os casos de suspeição servem para proteger a imparcialidade e, consequentemente, proteger e garantir ainda mais o princípio acusatório. Apesar de estarem apenas vislumbrados para o juiz, segundo o art. 254 do CPP a seguir, são aplicados também aos promotores de justiça, peritos, oficiais de justiça, ou seja, todos aqueles que de certa forma atuam no processo. Vejamos os casos de suspeição: Art.254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

Observações

I – se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II – se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III – se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV – se tiver aconselhado qualquer das partes;

V – se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

VI – se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Art. 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevivendo descendentes; mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo.

Art. 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la.

Num segundo plano, temos o caso de exceção de competência do juízo, que, na verdade, é hipótese de exceção dilatória, que visa que o feito seja processado no foro competente. O estudo da competência foi largamente visto em capítulo próprio.

A de litispendência acontece quando duas ações simétricas estão

em curso: mesma causa de pedir e mesma parte no polo passivo.

Já a de ilegitimidade da parte é utilizada quando a ação penal não está sendo ajuizada pelo respectivo titular da ação penal.

Por último, coisa julgada é a decisão que transitou em julgado, de que não cabe mais recurso. Imutabilidade dentro e fora do processo. Nesta exceção deve ser demonstrado que já temos uma decisão transitada em julgado sobre o caso presente.

7.8.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA

(linhas)

_____ (nome), já qualificado nos autos do processo n.º _____, vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento no art. 95, inciso _____, do CPP, opor

EXCEÇÃO DE _____

pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido

*Depende da modalidade de Exceção:

- (1) Suspeição: reconhecimento e remessa ao juiz substituto (art. 99 do CPP);
- (2) Incompetência: reconhecimento e remessa ao juízo competente (art. 108 do CPP);
- (3) Litispendência: reconhecimento e extinção (art. 110 do CPP);
- (4) Ilegitimidade da Parte: reconhecimento e anulação (art. 110 do CPP);
- (5) Coisa Julgada: reconhecimento e extinção (art. 110 do CPP).

Termos em que,
Pede Deferimento,

Município, data

Advogado
Inscrição n.º

7.8.2 Exercício¹²

Peça Prático-Profissional Inédita:

Peça 08:

Antônio está sendo acusado, com base em inquérito policial, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo crime de apropriação indébita, conforme o art. 168 do Diploma Penal. A exordial foi distribuída ao juízo da 23.^a Vara Criminal, juízo este em que trabalha o magistrado Dr. Pedro Carvalho, seu amigo íntimo, de infância, e que frequenta sua casa periodicamente, inclusive as esposas sendo muito amigas. Mesmo assim, este recebe a presente ação penal no dia 06.04.2013 e ordena a citação com cumprimento em 07.04.2013. Exclusivamente nas informações trazidas, interponha a medida específica diversa de *habeas corpus*, no último dia do prazo que avalia a imparcialidade do juízo da 23.^a Vara Criminal.

7.9 ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS POR MEMORIAIS

Nome	Alegações Finais
	Art. 403, § 3.º, do CPP: O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença. (Incluído pela Lei n.º 11.719, de 2008)
Artigo	Art. 404. Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. (Redação dada pela Lei n.º 11.719, de 2008)

	Parágrafo único. Realizada, em seguida, a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, suas alegações finais, por memorial, e, no prazo de 10 (dez) dias, o juiz proferirá a sentença. (Incluído pela Lei n.º 11.719, de 2008)
Prazo	5 dias (art. 403, § 3.º c/c art. 404, parágrafo único, do CPP).
Serve para	Exposição final das teses de acusação e defesa.
Observações	A Lei 11.719/2008, recente reforma do CPP, alterou de forma significativa as Alegações Finais. Primeiramente, surge uma certa dúvida e preocupação com a terminologia. Seria apenas Alegações Finais ou Alegações Finais por Memoriais? Acreditamos que esta é uma preocupação desnecessária. Ambos os termos, a nosso ver, são corretamente utilizados. A principal mudança foi trazer as Alegações Finais, como regra, orais. Uma das intenções dessa recente reforma processual penal foi em relação à celeridade processual, assim, temos a possibilidade de apresentar de forma escrita, quando tivermos diligências, peça fundamentada pelo art. 404, parágrafo único, e quando o fato for considerado complexo ou pelo número de acusados, fundamentada a peça pelo art. 403 § 3.º, do CPP. Essas hipóteses possibilitam a apresentação das Alegações Finais por escrito em cinco dias. No mais, é uma peça final, de último momento antes da sentença penal e que serve para demonstrar e condensar todas as teses acusatórias e defensivas. É importante colocarmos em sua elaboração o maior número de teses possível, alternativas, se for o caso, e, logicamente, demonstrando em primeiro plano a melhor tese.

Vale observar, ainda, que, nos demais procedimentos (sumário, sumaríssimo, júri etc.), as alegações finais serão somente orais, todavia a prática jurídica vem permitindo a aplicação por analogia do procedimento ordinário, conforme o art. 394, § 1.º, II, do CPP – sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade; (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

7.9.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA
____ DO ESTADO ____

Processo n.º ____

____ (nome), já qualificado nos autos do processo crime em epígrafe, vem respeitosamente, por seu advogado infra-assinado, com fundamento no art. 404 e seu parágrafo único¹³ do Código de Processo Penal, apresentar

ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS,

pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

1 – Dos Fatos

(...)

2 – Das Preliminares¹⁴

3 – Do Direito

(colocação das teses defensivas, sempre começando pela melhor tese em forma de títulos e com dispositivos de lei)

(...)

4 – Do Pedido

Diante do exposto, requer-se:

- I) O Reconhecimento (...) com a consequente (...);
- II) Caso V. Exa. não entenda pela tese acima exposta que (...);
- III) Ainda, se, porventura, as teses acima expostas não prosperem que (...).

Termos em que

Pede Deferimento.

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

7.9.2 Exercícios

Peça Prático-Profissional Oficial (IX Exame Unificado):

Gisele foi denunciada, com recebimento ocorrido em 31.10.2010, pela prática do delito de lesão corporal leve, com a presença da circunstância agravante, de ter o crime sido cometido contra mulher grávida. Isso porque, segundo narrou a inicial acusatória, Gisele, no dia 01.04.2009, então com 19 anos, objetivando provocar lesão corporal leve em Amanda, deu um chute nas costas de Carolina, por confundi-la com aquela, ocasião em que Carolina (que estava grávida) caiu de joelhos no chão, lesionando-se.

A vítima, muito atordoada com o acontecido, ficou por um tempo sem saber o que fazer, mas foi convencida por Amanda (sua amiga e pessoa a quem Gisele realmente queria lesionar) a noticiar o fato na delegacia. Sendo assim, tão logo voltou de um intercâmbio, mais precisamente no dia 18.10.2009, Carolina compareceu à delegacia e noticiou o fato, representando contra Gisele. Por orientação do delegado, Carolina foi instruída a fazer exame de corpo de delito, o que não ocorreu, porque os ferimentos, muito leves, já haviam sarado. O Ministério Público, na denúncia, arrolou Amanda como testemunha. Em seu depoimento, feito em sede judicial, Amanda disse que não viu Gisele bater em Carolina e nem viu os ferimentos, mas disse que poderia afirmar com convicção que os fatos noticiados realmente ocorreram, pois estava na casa da vítima quando esta chegou chorando muito e narrando a história. Não foi ouvida mais nenhuma testemunha e Gisele, em seu interrogatório, exerceu o direito ao silêncio. Cumpre destacar que a primeira e única audiência ocorreu apenas em 20.03.2012, mas que, anteriormente, três outras audiências foram marcadas; apenas não se realizaram porque, na primeira, o magistrado não pôde comparecer, na segunda o Ministério Público não compareceu e a terceira não se realizou porque, no dia

marcado, foi dado ponto facultativo pelo governador do Estado, razão pela qual todas as audiências foram redesignadas. Assim, somente na quarta data agendada é que a audiência efetivamente aconteceu. Também merece destaque o fato de que na referida audiência o *parquet* não ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, pois, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos, em 30.03.2009, Gisele, em processo criminal onde se apuravam outros fatos, aceitou o benefício proposto.

Assim, segundo o promotor de justiça, afigurava-se impossível formulação de nova proposta de suspensão condicional do processo, ou de qualquer outro benefício anterior não destacado, e, além disso, tal dado deveria figurar na condenação ora pleiteada para Gisele como outra circunstância agravante, qual seja, reincidência.

Nesse sentido, considere que o magistrado encerrou a audiência e abriu prazo, intimando as partes, para o oferecimento da peça processual cabível. Como advogado de Gisele, levando em conta tão somente os dados contidos no enunciado, elabore a peça cabível.

Gabarito Oficial:

Peça	Alegações Finais por Memoriais
Endereçamento	Juizado Especial Criminal
Fundamento Legal	Art. 403, § 3.º, do CPP
	Preliminarmente, deve ser alegada a decadência do direito de representação. Os fatos ocorreram em 01.04.2009 e a representação apenas foi feita em 18.10.2009 (art. 38 do CPP). Também em caráter preliminar deve ser alegada a nulidade do processo pela inobservância do rito da Lei 9.099/1995, anulando-se o recebimento da denúncia, com a consequente

Preliminares	prescrição da pretensão punitiva. Isso porque os fatos datam de 01.04.2009 e a pena máxima em abstrato prevista para o crime de lesão corporal leve é de um ano, que prescreve em quatro anos (art. 109, V, do CP). Como se trata de acusada menor de 21 anos de idade, o prazo prescricional reduz-se pela metade (art. 115 do CP), totalizando dois anos. Com a anulação do recebimento da denúncia, este marco interruptivo desaparece e, assim, configura-se a prescrição da pretensão punitiva.
Fundamentos	No mérito, deve ser requerida absolvição por falta de prova. A materialidade do delito não restou comprovada, tal como exige o art. 158 do CPP. O delito de lesão corporal é não transeunte e exige perícia, seja direta ou indireta, o que não foi feito. Note-se que não foi realizado exame pericial direto e nem a perícia indireta pôde ser feita, pois a única testemunha não viu nem os fatos e nem mesmo os ferimentos. Também no mérito, deve ser alegado que não incide nenhuma das circunstâncias agravantes aventadas pelo Ministério Público. Levando em conta que Gisele agiu em hipótese de erro sobre a pessoa (art. 20, § 3.º, do CP), devem ser consideradas apenas as características da vítima pretendida (Amanda) e não da vítima real (Carolina), que estava grávida. Além disso, não incide a agravante da reincidência, pois a aceitação da proposta de suspensão condicional do processo não acarreta condenação e muito menos reincidência; Gisele ainda é primária.
	Ao final, deve elaborar os seguintes pedidos: a extinção de punibilidade pela decadência do direito de representação; a

Pedidos	declaração da nulidade do processo com a consequente extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva; a absolvição da ré com fundamento na ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, em caso de condenação, deverá pleitear a não incidência da circunstância agravante de ter sido, o delito, cometido contra mulher grávida; a não incidência da agravante da reincidência; a atenuação da pena como consequência à aplicação da atenuante da menoridade relativa da ré.
Autenticação	Padrão
Comentários	Peça que merece cuidado, pois legalmente, segundo a Lei 9.099/1995, não teríamos a possibilidade de alegações escritas no procedimento sumaríssimo. Todavia, após a instrução e não havendo ainda condenação, nos resta apenas elaborarmos, por analogia, com base no art. 394, § 5.º, do CPP, os memoriais. Cuidado e sensibilidade em perceber a pretérita instrução e, ainda, a não existência de sentença penal. Peça identificada, endereçamento ao juizado, a pesquisa se inicia com as preliminares mais famosas, as extinções de punibilidade e a violação constitucional. Decadência do direito de representação, desrespeito ao princípio do devido processo legal (art. 5.º, LIV, da CF) e prescrição deveriam ser alegados. Nos fundamentos, não foi mencionada na questão a existência da materialidade, fato que gerou pontuação para os que perceberam esse detalhe, além da também famosa questão do erro sobre a pessoa (art. 20, § 3.º, do CP). Já os pedidos são consequências lógicas das preliminares e dos fundamentos.

Peça Prático-Profissional Oficial (XIV Exame Unificado):

Felipe, com 18 (dezoito) anos de idade, em um bar com outros amigos, conheceu Ana, linda jovem, por quem se encantou.

Após um bate-papo informal e troca de beijos, decidiram ir para um local mais reservado. Nesse local trocaram carícias, e Ana, de forma voluntária, praticou sexo oral e vaginal com Felipe.

Depois da noite juntos, ambos foram para suas residências, tendo antes trocado telefones e contatos nas redes sociais.

No dia seguinte, Felipe, ao acessar a página de Ana na rede social, descobre que, apesar da aparência adulta, esta possui apenas 13 (treze) anos de idade, tendo Felipe ficado em choque com essa constatação.

O seu medo foi corroborado com a chegada da notícia, em sua residência, da denúncia movida por parte do Ministério Público Estadual, pois o pai de Ana, ao descobrir o ocorrido, procurou a autoridade policial, narrando o fato.

Por Ana ser inimputável e contar, à época dos fatos, com 13 (treze) anos de idade, o Ministério Público Estadual denunciou Felipe pela prática de dois crimes de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. O *Parquet* requereu o início de cumprimento de pena no regime fechado, com base no art. 2.º, § 1.º, da Lei 8.072/1990, e o reconhecimento da agravante da embriaguez preordenada, prevista no art. 61, II, alínea “I”, do CP.

O processo teve início e prosseguimento na XX.^a Vara Criminal da cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, local de residência do réu.

Felipe, por ser réu primário, ter bons antecedentes e residência fixa, respondeu ao processo em liberdade.

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima afirmou que aquela foi a sua primeira noite, mas que tinha o hábito de fugir de casa com as amigas para frequentar bares de adultos.

As testemunhas de acusação afirmaram que não viram os fatos e que não sabiam das fugas de Ana para sair com as amigas.

As testemunhas de defesa, amigos de Felipe, disseram que o comportamento e a vestimenta da Ana eram incompatíveis com uma menina de 13 (treze) anos e que qualquer pessoa acreditaria ser uma pessoa maior de 14 (quatorze) anos, e que Felipe não estava embriagado quando conheceu Ana. O réu, em seu interrogatório, disse que se interessou por Ana, por ser muito bonita e por estar bem vestida. Disse que não perguntou a sua idade, pois acreditou que no local somente pudessem frequentar pessoas maiores de 18 (dezoito) anos. Corroborou que praticaram o sexo oral e vaginal na mesma oportunidade, de forma espontânea e voluntária por ambos.

A prova pericial atestou que a menor não era virgem, mas não pôde afirmar que aquele ato sexual foi o primeiro da vítima, pois a perícia foi realizada longos meses após o ato sexual.

O Ministério Público pugnou pela condenação de Felipe nos termos da denúncia.

A defesa de Felipe foi intimada no dia 10 de abril de 2014 (quinta-feira).

Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redija a peça cabível, no último dia do prazo, excluindo a possibilidade de impetração de *habeas corpus*, sustentando, para tanto, as teses jurídicas pertinentes.

Gabarito Oficial:

Peça	Memoriais
Endereçamento	XX. ^a Vara Criminal da cidade de Vitória – Estado do Espírito Santo
Fundamento Legal	Art. 403, § 3.º, CPP
Preliminares	–
	O examinando deveria abordar em suas razões a necessidade de absolvição do réu diante do erro de tipo escusável, que

Fundamentos

colimou na atipicidade da conduta. Conforme ficou narrado no texto da peça prático-profissional, o réu praticou sexo oral e vaginal com uma menina de 13 (treze) anos, que pelas condições físicas e sociais aparentava ser maior de 14 (quatorze) anos.

O tipo penal descrito no art. 217-A do CP, estupro de vulnerável, exige que o réu tenha ciência de que se trata de menor de 14 (quatorze) anos. É certo que o consentimento da vítima não é considerado no estupro de vulnerável, que visa tutelar a dignidade sexual de pessoas vulneráveis. No entanto, tal reforma penal não exclui a alegação de erro de tipo essencial, quando verificada, no caso concreto, a absoluta impossibilidade de conhecimento da idade da vítima. Na leitura da realidade, o réu acreditou estar praticando ato sexual com pessoa maior de 14 (quatorze) anos, incidindo, portanto, a figura do erro de tipo essencial, descrita no art. 20, caput, do CP. Como qualquer pessoa naquela circunstância incidiria em erro de tipo essencial e como não há previsão de estupro de vulnerável de forma culposa, não há outra solução senão a absolvição do réu, com base no art. 386, III, do CPP. Por sua vez, o examinando deveria desenvolver que no caso de condenação haveria a necessidade do reconhecimento de crime único, sendo excluído o concurso material de crimes. A prática de sexo oral e vaginal no mesmo contexto configura crime único, pois a reforma penal oriunda da Lei 12.015/2009 uniu as figuras típicas do atentado violento ao pudor e o estupro numa única figura, sendo, portanto, um crime misto alternativo. Prosseguindo em sua argumentação, o examinando deveria rebater o pedido de reconhecimento da agravante da embriaguez preordenada, pois não foram produzidas provas no

sentido de que Felipe se embriagou com intuito de tomar coragem para a prática do crime, também indicando a presença da atenuante da menoridade. Por fim, por ser o réu primário, de bons antecedentes e por existir crime único e não concurso material de crimes, o examinando deveria requerer a fixação da pena-base no mínimo legal, com a consequente fixação do regime semiaberto. Apesar de o crime de estupro de vulnerável, art. 217-A do CP, estar elencado como infração hedionda na Lei 8.072/1990, conforme art. 1.º, VI, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 2.º, § 1.º, desta lei, sendo certo que o juiz, ao fixar o regime inicial para o cumprimento de pena, deve analisar a situação em concreto, e não o preceito em abstrato. Assim, diante da ocorrência de crime único, cuja pena será fixada em 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu primário e de bons antecedentes, o regime semiaberto é a melhor solução para o réu, pois o art. 33, § 2.º, alínea "a", do CP, impõe o regime fechado para crimes com penas superiores a 8 (oito) anos, o que não é o caso.

Pedidos

Ao final, o examinando deveria formular os seguintes pedidos:

a) Absolvição do réu, com base no art. 386, III, do CPP, por ausência de tipicidade.

Diante da condenação, de forma subsidiária:

b) Afastamento do concurso material de crimes, sendo reconhecida a existência de crime único.

c) Fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante da embriaguez preordenada e a incidência da atenuante da menoridade.

d) Fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de

	pena, com base no art. 33, § 2.º, “b”, do CP, diante da inconstitucionalidade do art. 2.º, § 1.º, da Lei 8.072/1990.
Autenticação	15 de abril de 2014
Comentários	Peça de fácil identificação no procedimento ordinário, pois, após alguns momentos de audiência de instrução e julgamento, o examinador informa que o órgão acusatório pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Assim, a peça prático-profissional antes da sentença são os memoriais. A única dúvida que poderia surgir seria no artigo da fundamentação, pois o enunciado menciona uma perícia, criando uma impressão de que o fundamento seria no art. 404, parágrafo único, do CPP. Essa impressão é imediatamente descartada com uma leitura mais atenta, pois este artigo só seria possível se no enunciado estivesse claro que tal perícia fora realizada logo após a audiência, o que realmente não aconteceu. O mérito da peça estava muito claro, trata-se de uma tese defensiva clássica, o erro de tipo essencial, previsto no art. 20, caput, do CP, uma vez que o agente desconhecia a idade da vítima, como narra o enunciado, nas circunstâncias em que estava era impossível notar sua idade real. Assim, houve erro de tipo essencial escusável, que torna o fato atípico, devendo ser absolvido. Quanto a eventuais pedidos subsidiários, dois se faziam claros: primeiro, o afastamento da embriaguez preordenada, pois o agente não se embriagou para praticar o crime, não há provas disso nos autos, devendo ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, I). Outrossim, também deveria pedir o afastamento do concurso material de crimes, previsto no art. 69, pois, ainda que o agente tenha praticado dois atos sexuais, o contexto fático era único, o que caracterizaria, em

tese, apenas um estupro de vulnerável, por tratar-se de tipo penal misto alternativo. Por último, o candidato deveria requerer que, em caso de condenação, a pena fosse fixada no mínimo legal, devendo o regime ser fixado, na forma do art. 33, § 2.º, “b”, do CP, no regime semiaberto, devendo o candidato argumentar sobre a inconstitucionalidade do regime inicial fechado obrigatório nos crimes hediondos, fixado no art. 2.º, § 1.º, da Lei 8.072/1990.

Peça Prático-Profissional Oficial (XVII Exame Unificado):

Daniel, nascido em 2 de abril de 1990, é filho de Rita, empregada doméstica que trabalha na residência da família Souza. Ao tomar conhecimento, por meio de sua mãe, que os donos da residência estariam viajando para comemorar a virada de ano, vai até o local, no dia 2 de janeiro de 2010, e subtrai o veículo automotor dos patrões de sua genitora, pois queria fazer um passeio com sua namorada.

Desde o início, contudo, pretende apenas utilizar o carro para fazer um passeio pelo quarteirão e, depois, após encher o tanque de gasolina novamente, devolvê-lo no mesmo local de onde o subtraiu, evitando ser descoberto pelos proprietários. Ocorre que, quando foi concluir seu plano, já na entrada da garagem para devolver o automóvel no mesmo lugar em que o havia subtraído, foi surpreendido por policiais militares, que, sem ingressar na residência, perguntaram sobre a propriedade do bem.

Ao analisarem as câmeras de segurança da residência, fornecidas pelo próprio Daniel, perceberam os agentes da lei que ele havia retirado o carro sem autorização do verdadeiro proprietário. Foi, então, Daniel denunciado pela prática do crime de furto simples, destacando o Ministério Público que deixava de oferecer proposta de suspensão condicional do processo por não estarem preenchidos os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/1995, tendo em vista que Daniel responde a outra ação penal pela prática do crime de porte de arma de fogo.

Em 18 de março de 2010, a denúncia foi recebida pelo juízo competente, qual seja, da 1.^a Vara Criminal da Comarca de Florianópolis. Os fatos acima descritos são

integralmente confirmados durante a instrução, sendo certo que Daniel respondeu ao processo em liberdade. Foram ouvidos os policiais militares como testemunhas de acusação, e o acusado foi interrogado, confessando que, de fato, utilizou o veículo sem autorização, mas que sua intenção era devolvê-lo, tanto que foi preso quando ingressava na garagem dos proprietários do automóvel. Após, foi juntada a Folha de Antecedentes Criminais de Daniel, que ostentava apenas aquele processo pelo porte de arma de fogo, que não tivera proferida sentença até o momento, o laudo de avaliação indireta do automóvel e o vídeo da câmera de segurança da residência. O Ministério Público, em sua manifestação derradeira, requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa de Daniel é intimada em 17 de julho de 2015, sexta-feira. Com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redija a peça cabível, excluía a possibilidade de *habeas corpus*, no último dia do prazo para interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. **(Valor: 5,00)**

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

Peça	Alegações finais por Memoriais
Endereçamento	1. ^a Vara Criminal da Comarca de Florianópolis
Fundamento Legal	Art. 403, § 3.º, CPP
	Preliminarmente, deve o examinando requerer a extinção da punibilidade do fato em favor de Daniel pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Daniel foi denunciado como incurso nas sanções penais do art. 155, caput, do Código Penal; logo, a pena máxima a ser aplicada para o caso é de 4 anos. Na forma do art. 109, inciso IV, do Código Penal, sendo a pena máxima superior a 2 anos e não excedendo 4 anos, o prazo prescricional será de 8 anos. Ocorre que Daniel era menor

Preliminares

de 21 anos na data dos fatos, pois nascido em 02.04.1990, e os fatos ocorreram em 02.01.2010. Assim, impõe o art. 115 do Código Penal que o prazo prescricional seja contado pela metade, ou seja, 4 anos no caso concreto. O último marco interruptivo do prazo prescricional ocorreu em 18 de março de 2010, data do recebimento da denúncia. Desde então, passaram-se mais de 5 anos e não foi proferida sentença condenatória. Diante disso, o advogado de Daniel deve pleitear, preliminarmente, a extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva do Estado.

No mérito, a defesa de Daniel deve defender sua absolvição, sob o fundamento de que não houve prática de crime de furto. Estamos diante do que a doutrina e a jurisprudência costumam chamar de “furto de uso”, que, na verdade, não configura crime de furto.

Prevê o art. 155 do Código Penal que é crime subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Uma das elementares do crime é a intenção de subtrair a coisa para si, chamado pela doutrina de *animus furandi* ou *animus rem sibi habendi*. No caso, está narrado de maneira clara que Daniel não tinha o dolo de ter a coisa para si ou para outrem; ele não tinha a vontade de se assenhorar do bem subtraído. O interesse era, apenas, de usar a coisa alheia e devolvê-la sem qualquer prejuízo ao proprietário, sendo certo que até mesmo se preocupou em repor a gasolina utilizada. Ademais, quando foi abordado por policiais, a coisa estava sendo devolvida exatamente nas mesmas condições e no mesmo lugar em que fora subtraída, preenchendo, assim, todas os requisitos para que sua conduta possa ser considerada um indiferente penal.

Subsidiariamente, para a eventualidade de condenação do denunciado, deve o advogado analisar eventual pena a ser aplicada a Daniel. De início, deverá ser requerida a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ações em curso não podem justificar o reconhecimento de maus antecedentes, nos termos do enunciado 444 da Súmula do STJ, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.

Na segunda fase, ausente qualquer agravante e presente a atenuante da menoridade relativa, com fulcro no art. 65, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que Daniel era menor de 21 anos na data dos fatos. Em caso de condenação, deverá ser reconhecida, ainda, a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", uma vez que Daniel confessou os fatos.

Não existem causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas.

O regime adequado para cumprimento de pena é o aberto, pois a pena final não ultrapassará 4 anos, o acusado é primário e não existem circunstâncias do art. 59 do Código Penal prejudiciais.

Caberá, ainda, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Em conclusão, deve o examinando formular os seguintes pedidos:

a) preliminarmente, o reconhecimento da extinção de punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva do

Pedidos	Estado, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP, OU no art. 109, inciso IV, c/c o art. 115, ambos do CP; b) no mérito: a absolvição de Daniel pela atipicidade de sua conduta, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP; c) subsidiariamente: aplicação da pena-base no mínimo legal, pois ações penais em curso não podem funcionar como maus antecedentes, na forma do enunciado 444 da Súmula do STJ; d) reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; e) aplicação do regime aberto para início do cumprimento de pena; f) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Autenticação	A data a ser indicada é o dia 24 de julho de 2015, tendo em vista que o prazo para Alegações Finais é de 5 dias, mas este somente se iniciará na segunda-feira, dia 20 de julho de 2015.
	Peça de extrema simplicidade quanto à sua identificação, pois já superada a fase de recebimento e de audiência de instrução sem a sentença penal condenatória. O enunciado ainda diz que o órgão ministerial “em sua manifestação derradeira, requereu a condenação”. Os memoriais, apresentados sucessivamente pelas partes, configuram o último momento processual antes da sentença. Um detalhe neste enunciado precisa ser enfatizado com clareza. Os memoriais podem ser fundamentados com base no art. 403, § 3.º, do CPP, ou no art. 404, parágrafo único, do CPP. Este dispositivo legal existe quando alguma diligência, que consiste

numa postura ativa, complementar de realizar algo novo ou subsidiário após a audiência. Havendo alguma inovação probatória em audiência ou restando dúvidas, o magistrado poderá, a requerimento das partes ou de ofício, realizar uma nova inquirição de testemunhas, ouvir um novo perito, por exemplo, sempre com a intenção de buscar a verdade processual. No caso em tela, o que aconteceu foram juntadas de documentos que comprovavam o que já estava sendo abordado, não configurando diligência. Sendo assim, o fundamento correto é com base no art. 403, § 3.º, do CPP no caso de complexidade ou número de acusados.

Em preliminar, buscando-se hipóteses do art. 107 do CP e as nulidades do art. 564 CPP, encontramos, neste enunciado, a prescrição, famosa extinção da punibilidade quando o Estado perde o direito de punir.

Houve prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a pena máxima do furto é de 4 anos, conforme art. 109, IV, prescreve em 8 anos. Entretanto, como o agente era menor de 21, a prescrição sofre uma redução de metade, conforme art. 115 do CP. Assim, levando em conta a data do recebimento da denúncia e a data das alegações finais, já houve prescrição da pretensão punitiva.

Comentários

Quanto ao mérito, como tese principal, já que a busca deve ser pelo art. 386 do CPP nos memoriais, o crime de furto, previsto no art. 155 do CP, exige como elemento subjetivo especial o ânimo de tornar-se proprietário da coisa, expresso no elemento para si ou para outrem, o caso concreto exposto retrata situação de furto de uso, quando a coisa é subtraída com a intenção de utilização e devolução nas mesmas condições da

retirada. Assim, o fato narrado não se adéqua ao tipo penal do furto, devendo o agente ser absolvido por Atipicidade do Furto de Uso. Sendo atípico formalmente o furto de uso, enquadra-se na situação do art. 386, III, do CPP.

Em segundo plano, as alegações finais neste rito são famosas pelas teses subsidiárias, assim:

O agente era na data do fato menor de 21 anos, portanto, faz jus à atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

O agente confessou a prática do crime, em razão disso também faz jus ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do CP;

Também em caso de condenação a pena deve ser fixada no mínimo legal, conforme o art. 68 do CP, uma vez que não há circunstâncias judiciais do art. 59 desfavoráveis ao agente, nem mesmo os maus antecedentes, pois conforme súmula 444 do STJ, o processo em curso não pode ser considerado como maus antecedentes. Também não há agravantes ou causas de aumento de pena.

e) fixada a pena no mínimo legal, que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2.º, "c", do CP, uma vez que todas as circunstâncias do art. 59 são favoráveis ao agente;

f) como o agente cumpre os requisitos legais, a pena privativa de liberdade deve ser substituída pela pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CP.

Peça Prático-Profissional Oficial (XX Exame Unificado):

Astolfo, nascido em 15 de março de 1940, sem qualquer envolvimento pretérito

com o aparato judicial, no dia 22 de março de 2014, estava em sua casa, um barraco na comunidade conhecida como Favela da Zebra, localizada em Goiânia/GO, quando foi visitado pelo chefe do tráfico da comunidade, conhecido pelo vulgo de Russo. Russo, que estava armado, exigiu que Astolfo transportasse 50 g de cocaína para outro traficante, que o aguardaria em um Posto de Gasolina, sob pena de Astolfo ser expulso de sua residência e não mais poder morar na Favela da Zebra. Astolfo, então, se viu obrigado a aceitar a determinação, mas quando estava em seu automóvel, na direção do Posto de Gasolina, foi abordado por policiais militares, sendo a droga encontrada e apreendida. Astolfo foi denunciado perante o juízo competente pela prática do crime previsto no art. 33, *caput*, da Lei 11.343/2006. Em que pese tenha sido preso em flagrante, foi concedida liberdade provisória ao agente, respondendo ele ao processo em liberdade. Durante a audiência de instrução e julgamento, após serem observadas todas as formalidades legais, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu confirmaram os fatos narrados na denúncia, além de destacarem que, de fato, o acusado apresentou a versão de que transportava as drogas por exigência de Russo. Asseguraram que não conheciam o acusado antes da data dos fatos. Astolfo, em seu interrogatório, realizado como último ato da instrução por requerimento expresso da defesa do réu, também confirmou que fazia o transporte da droga, mas alegou que somente agiu dessa forma porque foi obrigado pelo chefe do tráfico local a adotar tal conduta, ainda destacando que residia há mais de 50 anos na comunidade da Favela da Zebra e que, se fosse de lá expulso, não teria outro lugar para morar, pois sequer possuía familiares e amigos fora do local. Disse que nunca respondeu a nenhum outro processo, apesar já ter sido indiciado nos autos de um inquérito policial pela suposta prática de um crime de falsificação de documento particular. Após a juntada da Folha de Antecedentes Criminais do réu, apenas mencionando aquele inquérito, e do laudo de exame de material, confirmando que, de fato, a substância encontrada no veículo do denunciado era “cloridrato de cocaína”, os autos foram encaminhados para o Ministério Público, que pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Em seguida, você, advogado(a) de Astolfo, foi intimado(a) em 6 de março de 2015, uma sexta-feira. Com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto,

redija a peça cabível, excluída a possibilidade de *Habeas Corpus*, no último dia do prazo, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. (Valor: 5,00) Obs.: O examinando deve indicar todos os fundamentos e dispositivos legais cabíveis. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

Gabarito Oficial:

Peça	Alegações Finais Escritas Por Memoriais ou simplesmente Memoriais
Endereçamento	Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da... Vara Criminal da Comarca de Goiânia do Estado de Goiás
Fundamentação	Art. 403, § 3.º, do CPP c/c o art. 394, § 5.º, do CPP
	No mérito, deveria o candidato pleitear, em um momento inicial, a absolvição do acusado por inexigibilidade de conduta diversa. Para que determinada conduta seja considerada crime, deve ela ser típica, ilícita e culpável. Um dos elementos da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa, sendo, portanto, a inexigibilidade de conduta diversa uma causa de exclusão da culpabilidade. Deveria o examinando alegar que Russo, estando armado, ao exigir o transporte das substâncias entorpecentes por parte de Astolfo, um senhor de 74 anos de idade, sob pena de expulsá-lo de sua casa e da comunidade da Favela da Zebra, sem ele ter outro local para residir, praticou uma coação moral irresistível. Diante das circunstâncias e das particularidades do caso concreto, em especial considerando a idade de Astolfo e o fato de não ter familiares para lhe dar abrigo, não seria possível exigir outra conduta do acusado. Conforme previsão do art. 22 do Código Penal, no caso de coação irresistível, somente deve responder pela infração o

Preliminares e Mérito

autor da coação. Assim, na forma do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, deveria o réu ser absolvido.

Caso se entenda que o fato foi típico, ilícito e culpável e que a coação foi resistível, o examinando, com base no princípio da eventualidade, deveria passar a enfrentar eventual sanção penal a ser aplicada. Inicialmente deveria solicitar a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, pois, na forma do enunciado 444 da Súmula de jurisprudência do STJ, a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não são suficientes para fundamentar circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como desfavoráveis. Na fixação da pena intermediária, deveria o examinando requerer o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, já que o réu era maior de 70 anos na data da sentença, e a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, cabendo destacar que a chamada confissão qualificada, ou seja, quando, apesar de confessar o fato, o acusado alega a existência de causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, vem sendo reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça como suficiente para justificar o seu reconhecimento como atenuante. Deveria, ainda, ser alegada a atenuante da coação resistível, já que o crime somente foi praticado por exigência de Russo (art. 65, inciso III, c, do CP). Considerando que o acusado é primário, de bons antecedentes, e que não consta em seu desfavor qualquer indício de envolvimento com organização criminosa ou dedicação às atividades criminosas, cabível a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343.

As circunstâncias da infração tornam até mesmo possível a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo. Em

	sendo reconhecida a existência do tráfico privilegiado do art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, cabível o requerimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não mais subsiste a vedação trazida pelo dispositivo. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dessa vedação em abstrato, por violação ao princípio da individualização, além de a Resolução 05 do Senado, publicada em 15 de fevereiro de 2012, suspender a eficácia da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direito” do parágrafo acima citado. Da mesma forma, o STF também reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da aplicação do regime inicial fechado para os crimes hediondos ou equiparados trazida pelo art. 2.º, § 1.º, da Lei 8.072 por violação do princípio da individualização da pena, de modo que nada impede a fixação do regime inicial aberto de cumprimento da reprimenda penal.
Pedidos	Diante do exposto, deveriam ser formulados os seguintes pedidos: (a) absolvição do crime de tráfico, na forma do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal; (b) subsidiariamente, aplicação da pena-base no mínimo legal; (c) reconhecimento das atenuantes do art. 65, incisos I e III, alíneas c e d, do Código Penal; (d) aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei 11.343; (e) aplicação do regime inicial aberto de cumprimento da pena; (f) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Autenticação	A peça deveria ser assinada, além de constar como data 13 de março de 2015, pois o prazo só se iniciou na segunda-feira seguinte à intimação.
	Interessante Memorial onde o candidato deverá ter a habilidade

Comentários

necessária para verificar que na Lei de Drogas, em seu rito, não existe expressamente tal modalidade de alegações finais escritas. No entanto, por aplicação por analogia, conforme art. 394, § 5.º, do CPP, é possível a elaboração da mesma.

Peça sem preliminar (art. 107 do CP e art. 564 do CPP) e com uma razoável quantidade de teses de mérito e subsidiárias.

Peça Prático-Profissional Oficial (XX Exame Unificado – Reaplicação Porto Velho/RO):

Bruno Silva, nascido em 10 de janeiro de 1997, enquanto adolescente, aos 16 anos, respondeu perante a Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, sendo julgada procedente a ação socioeducativa e aplicada a medida de semiliberdade. No dia 10 de janeiro de 2015, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Bruno se encontrava no interior de um ônibus, quando encontrou um relógio caído ao lado do banco em que estava sentado. Estando o ônibus vazio, Bruno aproveitou para pegar o relógio e colocá-lo dentro de sua mochila, não informando o ocorrido ao motorista. Mais adiante, porém, 15 minutos após esse fato, o proprietário do relógio, Bernardo, já na companhia de um policial, ingressou no coletivo procurando pelo seu pertence, que havia sido comprado apenas duas semanas antes por R\$ 100,00 (cem reais). Verificando que Bruno estava sentado no banco por ele antes utilizado, revistou sua mochila e encontrou o relógio. Bernardo narrou ao motorista de ônibus o ocorrido, admitindo que Bruno não estava no coletivo quando ele o deixou. Diante de tais fatos, Bruno foi denunciado perante o juízo competente pela prática do crime de furto simples, na forma do art. 155, *caput*, do Código Penal. A denúncia foi recebida e foi formulada pelo Ministério Público a proposta de suspensão condicional do processo, não sendo aceita pelo acusado, que respondeu ao processo em liberdade. No curso da instrução, o policial que efetivou a prisão do acusado, Bernardo, o motorista do ônibus e Bruno foram ouvidos e todos confirmaram os fatos acima narrados. Com a juntada do laudo de avaliação do bem arrecadado, confirmando o valor de R\$ 100,00 (cem reais), os autos foram encaminhados ao

Ministério Público, que se manifestou pela procedência do pedido nos termos da denúncia, pleiteando reconhecimento de maus antecedentes, em razão da medida socioeducativa antes aplicada. Você, advogado(a) de Bruno, foi intimado(a), em 23 de março de 2015, segunda-feira, sendo o dia subsequente útil. Com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redija a peça cabível, excluía a possibilidade de *Habeas Corpus*, no último dia do prazo, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. (Valor: 5,00 pontos) Obs.: O examinando deve indicar todos os fundamentos e dispositivos legais cabíveis. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

Gabarito Oficial:

Peça	Memoriais
Endereçamento	Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte do Estado de Minas Gerais
Fundamentação	Art. 403, § 3.º, do CPP
	No mérito, deve o examinando defender a absolvição de Bruno, tendo em vista que nenhum crime de furto foi praticado. Prevê o art. 155 do Código Penal que configura furto a subtração de coisa alheia móvel. A doutrina leciona que a coisa perdida, conhecida como <i>res desperdicta</i> , em princípio, não pode ser objeto do crime de furto, pois ela não está na posse de outra pessoa para ser subtraída. Cabe destacar, porém, que a coisa só é considerada perdida quando está em local público ou de uso público, como efetivamente ocorreu com o relógio de Bernardo. O relógio por Bruno encontrado no interior do coletivo e guardado em sua mochila era uma coisa perdida, tendo em vista que encontrado no chão do transporte público

Preliminares e Mérito

e que o seu proprietário, Bernardo, sequer estava no interior do ônibus quando Bruno nele ingressou. Não houve subtração. Em tese, quando uma pessoa se apodera de uma coisa perdida, possivelmente será configurado o crime de apropriação de coisa achada, previsto no art. 169, inciso II, do Código Penal. Contudo, na hipótese, nem mesmo cabível a desclassificação para esse delito, mas tão só a absolvição de Bruno, tendo em vista que uma das elementares do art. 169, inciso II, do Código Penal não foi realizada. Isso porque o crime de apropriação de coisa achada somente se configura após o agente não restituir a coisa apropriada ao dono ou ao legítimo possuidor após 15 dias. Trata-se de infração penal conhecida como delito a prazo. Como Bruno havia pegado o relógio poucos minutos antes, não estava configurado o delito do art. 169, inciso II, do Código Penal, pois ele ainda poderia decidir por devolver o bem ao seu proprietário ou na Delegacia dentro do prazo previsto em lei. Diante disso, deve ser requerida, nas Alegações Finais, a absolvição de Bruno. Além disso, deve o candidato, com base no princípio da eventualidade, caso se entenda que houve subtração, alegar a atipicidade material da conduta por força do princípio da insignificância, eis que bastante reduzido o valor da coisa e da lesão (1/8 do salário mínimo, aproximadamente). Ainda com base na subsidiariedade, o examinando deve enfrentar eventual pena a ser aplicada em caso de condenação do réu. Na aplicação da pena-base, deve o examinando destacar que deve ser fixada no mínimo legal, tendo em vista que o agente é primário e de bons antecedentes, não tendo como assim não ser, já que havia acabado de completar 18 anos na data em que foi preso em flagrante. O fato de o réu já ter sido punido com medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime

de tráfico não permite o reconhecimento de maus antecedentes ou qualquer outra circunstância judicial desfavorável. Na determinação da pena intermediária, deveria ser solicitado o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, assim como da menoridade relativa, com base no art. 65, inciso I, do CP, uma vez que Bruno era menor de 21 anos na data dos fatos. Já na terceira fase de aplicação da reprimenda penal, o advogado deveria solicitar o reconhecimento do furto privilegiado, pois Bruno era primário e a coisa furtada era de pequeno valor, já que o relógio foi adquirido pela quantia de R\$ 100,00 (cem reais) apenas. Assim, poderia o examinando pleitear a aplicação de alguma das medidas previstas no art. 155, § 2.º, do Código Penal, quais sejam, substituição da pena de reclusão pela de detenção, diminuição de 1/3 a 2/3 da reprimenda penal ou aplicação somente da pena de multa. Em caso de aplicação de pena privativa de liberdade, deveria ser, ainda, requerida a substituição desta por restritiva de direitos, pois preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. O regime inicial de cumprimento de pena a ser buscado é o aberto. Por fim, em caso de não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender não preenchidos seus requisitos, deve o examinando solicitar a aplicação da suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal

Pedidos

Diante do exposto, deve ser formulado pedido requerendo: (a) absolvição do crime de furto, na forma do art. 386, inciso III, do CPP; (b) aplicação da pena-base no mínimo legal; (c) reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; (d) aplicação da forma privilegiada do

	furto, prevista no art. 155, § 2.º, do Código Penal; (e) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (f) aplicação do regime aberto; (g) subsidiariamente, suspensão condicional da pena.
Autenticação	A data a ser indicada é 30 de março de 2015, tendo em vista que o prazo para Alegações Finais é de cinco dias, mas o dia 28 de março de 2015 é um sábado.
Comentários	De uma clareza ímpar o enunciado, mais uma vez a banca prestigia os crimes patrimoniais e as teses de mérito subsidiárias. Vale observar que é na apelação e nos memoriais, principalmente, que vemos a incidência das teses subsidiárias no tocante à aplicação da pena.

Peça Prático-Profissional Oficial (XXIII Exame Unificado):

No dia 23 de fevereiro de 2016, Roberta, 20 anos, encontrava-se em um curso preparatório para concurso na cidade de Manaus/AM. Ao final da aula, resolveu ir comprar um café na cantina do local, tendo deixado seu notebook carregando na tomada. Ao retornar, retirou um notebook da tomada e foi para sua residência. Ao chegar em casa, foi informada de que foi realizado registro de ocorrência na Delegacia em seu desfavor, tendo em vista que as câmeras de segurança da sala de aula captaram o momento em que subtraiu o notebook de Cláudia, sua colega de classe, que havia colocado seu computador para carregar em substituição ao de Roberta, o qual estava ao lado. No dia seguinte, antes mesmo de qualquer busca e apreensão do bem ou atitude da autoridade policial, Roberta restituiu a coisa subtraída. As imagens da câmera de segurança foram encaminhadas ao Ministério Público, que denunciou Roberta pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, *caput*, do Código Penal. O Ministério Público deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, destacando que o delito de furto não é de menor potencial ofensivo, não se sujeitando à aplicação da Lei 9.099/1995, tendo a defesa se insurgido. Recebida a denúncia, durante a instrução, foi ouvida Cláudia, que

confirmou ter deixado seu notebook acoplado à tomada, mas que Roberta o subtraía, somente havendo restituição do bem com a descoberta dos agentes da lei. Também foram ouvidos os funcionários do curso preparatório, que disseram ter identificado a autoria a partir das câmeras de segurança. Roberta, em seu interrogatório, confirma os fatos, mas esclarece que acreditava que o notebook subtraído era seu e, por isso, levava-o para casa. Foi juntada a Folha de Antecedentes Criminais da ré sem qualquer outra anotação, o laudo de avaliação do bem subtraído, que constatou seu valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), e o CD com as imagens captadas pela câmera de segurança. O Ministério Público, em sua manifestação derradeira, requereu a condenação da ré nos termos da denúncia. Você, como advogado(a) de Roberta, é intimado(a) no dia 24 de agosto de 2016, quarta-feira, sendo o dia seguinte útil em todo o país, bem como todos os dias da semana seguinte, exceto sábado e domingo. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado(a) de Roberta, redija a peça jurídica cabível, diferente de *habeas corpus*, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição. (Valor: 5,00) Obs.: O examinando deve indicar todos os fundamentos e dispositivos legais cabíveis. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

Gabarito Oficial:

Peça	Memoriais
Endereçamento	Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da ... Vara Criminal da Comarca de Manaus do Estado do Amazonas
Fundamentação	Art. 403, § 3.º, do CPP
	De início, deveria o examinando, na condição de advogado, requerer a nulidade dos atos processuais realizados durante a instrução probatória, tendo em vista que não foi oferecida proposta de suspensão condicional do processo. Prevê o art. 89 da Lei 9.099/1995 que caberá ao Ministério Público oferecer

Preliminares e Mérito

proposta de suspensão condicional do processo quando a pena mínima cominada ao delito imputado for de até um ano, abrangida ou não por esta Lei, preenchidos os demais requisitos legais, dentre os quais se destacam a primariedade e a presença dos requisitos do art. 77 do Código Penal. Roberta era primária, de bons antecedentes e as circunstâncias do crime não justificam a recusa na formulação da proposta de suspensão condicional do processo. Ademais, o delito de furto simples tem pena mínima prevista em abstrato de um ano, logo irrelevante o fato da infração não ser de menor potencial ofensivo. Assim, não estamos diante de mera faculdade do Promotor de Justiça, mas sim de um poder-dever limitado pela lei, de modo que deveria ter sido oferecida a proposta do instituto despenalizador. Em seguida, quanto ao mérito, deveria o examinando alegar a ocorrência de erro de tipo. Prevê o art. 155 do Código Penal que pratica crime de furto aquele que subtrai coisa alheia móvel. Ocorre que Roberta estava em erro em relação a uma das elementares do tipo, qual seja, a coisa alheia, tendo em vista que acreditava estar levando para casa o seu próprio notebook, o que não configuraria crime. De acordo com o art. 20 do Código Penal, o erro sobre elemento constitutivo do tipo exclui o dolo, mas permite a punição do agente a título de culpa, caso previsto em lei. Inicialmente deve ser destacado que o erro de tipo, na hipótese, era escusável, de modo que não há que se falar em dolo ou culpa. Ademais, ainda que assim não fosse, não existe previsão da modalidade culposa do furto, logo, ainda assim, Roberta deveria ser absolvida. Com base no princípio da eventualidade, o examinando deveria enfrentar eventual pena a ser aplicada em caso de condenação da ré. Na aplicação da pena-base, deveria o candidato destacar que deveria ser fixada no mínimo legal,

	tendo em vista que a agente possui bons antecedentes e as circunstâncias do art. 59 do CP são favoráveis. Na determinação da pena intermediária, deveria ser solicitado o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, assim como da menoridade relativa, uma vez que Roberta era menor de 21 anos na data dos fatos, conforme o art. 65, inciso I, do CP. Não havia causas de aumento a serem reconhecidas. Todavia, considerando que houve restituição do bem subtraído antes do recebimento da denúncia, que tal ato decorreu de conduta voluntária da denunciada e que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, cabível o reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior, prevista no art. 16 do CP. Em caso de aplicação de pena privativa de liberdade, deveria ser requerida a substituição desta por restritiva de direitos, pois preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. O regime inicial de cumprimento de pena a ser buscado é o aberto.
Pedidos	Diante do exposto, deveriam ser formulados os seguintes pedidos, requerendo: (a) Nulidade da instrução, com oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo; (b) Absolvição do crime de furto, na forma do art. 386, inciso III, do CPP; (c) Aplicação da pena-base no mínimo legal; (d) Reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea; (e) Aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior; (f) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (g) Aplicação do regime aberto.
Autenticação	A data a ser indicada é 29 de agosto de 2016, tendo em vista que o prazo para Alegações Finais é de cinco dias.

Comentários

Memoriais de crimes patrimoniais. Alguma novidade? Nenhuma! Sem reparos a peça que nos apresenta uma nulidade no tocante ao não oferecimento da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/1995), que pode ser apresentada além do rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal e hoje, segundo o Supremo Tribunal Federal consiste em poder-dever do Ministério Público. No restante, teses de mérito e subsidiárias previsíveis.

Peça Prático-Profissional Oficial (XXVI Exame Unificado):

Em 3 de outubro de 2016, na cidade de Campos, no Estado do Rio de Janeiro, Lauro, 33 anos, que é obcecado por Maria, estagiária de uma outra empresa que está situada no mesmo prédio em que fica o seu local de trabalho, não mais aceitando a rejeição dela, decidiu que a obrigaria a manter relações sexuais com ele, independentemente da sua concordância. Confiante em sua decisão, resolveu adquirir arma de fogo de uso permitido, considerando que tinha autorização para tanto, e a registrou, tornando-a regular. Precisando que alguém o substituisse no local do trabalho no dia do crime, narrou sua intenção criminosa para José, melhor amigo com quem trabalha, assegurando-lhe que comprou a arma exclusivamente para ameaçar Maria a manter com ele conjunção carnal, mas que não a lesionaria de forma alguma. Ainda esclareceu a José, que alugara um quarto em um hotel e comprara uma mordaca para evitar que Maria gritasse e os fatos fossem descobertos. Quando Lauro saía de casa, em seu carro, para encontrar Maria, foi surpreendido por viatura da Polícia Militar, que havia sido alertada por José sobre o crime prestes a acontecer, sendo efetuada a prisão de Lauro em flagrante. Em sede policial, Maria foi ouvida, afirmando, apesar de não apresentar documentos, que tinha 17 anos e que Lauro sempre manteve comportamento estranho com ela, razão pela qual tinha interesse em ver o autor dos fatos responsabilizado criminalmente. Após receber os autos e considerando que o detido possuía autorização para portar arma de fogo, o Ministério Público denunciou Lauro apenas pela prática do crime de estupro qualificado,

previsto no art. 213, § 1.º, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea f, todos do Código Penal. O processo teve regular prosseguimento, mas, em razão da demora para realização da instrução, Lauro foi colocado em liberdade. Na audiência de instrução e julgamento, a vítima Maria foi ouvida, confirmou suas declarações em sede policial, disse que tinha 17 anos, apesar de ter esquecido seu documento de identificação para confirmar, apenas apresentando cópia de sua matrícula escolar, sem indicar data de nascimento, para demonstrar que, de fato, era Maria. José foi ouvido e também confirmou os fatos narrados na denúncia, assim como os policiais. O réu não estava presente na audiência por não ter sido intimado e, apesar de seu advogado ter-se mostrado inconformado com tal fato, o ato foi realizado, porque o interrogatório seria feito em outra data. Na segunda audiência, Lauro foi ouvido, confirmando integralmente os fatos narrados na denúncia, mas demonstrou não ter conhecimento sobre as declarações das testemunhas e da vítima na primeira audiência. Na mesma ocasião, foi, ainda, juntado o laudo de exame do material apreendido, o laudo da arma de fogo demonstrando o potencial lesivo e a Folha de Antecedentes Criminais, sem outras anotações. Encaminhados os autos para o Ministério Público, foi apresentada manifestação requerendo condenação nos termos da denúncia. Em seguida, a defesa técnica de Lauro foi intimada, em 4 de setembro de 2018, terça-feira, sendo quarta-feira dia útil em todo o país, para apresentação da medida cabível.

Peça	Memoriais
Endereçamento	Petição ser direcionada ao juiz de uma das Varas Criminais da Comarca de Campos, RJ.
Fundamentação	Art. 403, § 3.º, CPP
	Preliminarmente, deveria o examinando, na condição de advogado, requerer a nulidade dos atos processuais realizados durante a instrução probatória, a partir da realização da primeira audiência de instrução e julgamento, tendo em vista

que Lauro não foi intimado para comparecimento e sua defesa técnica manifestou o inconformismo com o ato. O princípio da ampla defesa, assegurado pelo art. 5.º, inciso LV, da CRFB/1988, garante ao acusado não somente o direito a sua defesa técnica, mas também a autodefesa, que, por sua vez, inclui o direito de presença.

A não intimação de Lauro para realização da audiência de instrução e julgamento, ainda que não tenha ocorrido o interrogatório, certamente causa prejuízo a sua defesa, pois não estava o réu presente quando toda a prova da acusação foi produzida. Assim, a nulidade dos atos praticados desde a primeira audiência de instrução e julgamento deve ser reconhecida. Após a preliminar, deveria o examinando passar a analisar o mérito. No mérito, caberia ao examinando pleitear a absolvição de Lauro, na forma do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois o fato narrado não constitui crime. Isso porque não foi iniciada a execução do crime imputado na denúncia, havendo meros atos preparatórios, que, em regra, são impuníveis. Os atos preparatórios constituem atividades materiais ou morais de organização prévia dos meios ou instrumentos para o cometimento do crime. A compra de uma arma e a reserva do quarto configuram atos preparatórios e não início de execução. Em respeito ao princípio da lesividade, prevaleceu na doutrina brasileira o entendimento de que, salvo quando expressamente previsto em lei, os atos preparatórios não são puníveis, pois não colocariam em risco, de maneira concreta, o bem jurídico protegido. Ainda que presente o elemento subjetivo, não haveria crime em razão de objetivamente não haver risco próximo ao bem jurídico. Diante disso, não há tentativa de estupro, já que não havia sido

Preliminares e Mérito

iniciada a execução do delito, devendo o agente ser absolvido, porque sua conduta não configura crime. O porte de arma de fogo por si só não configura infração penal, já que Lauro possuía autorização para tanto, nos termos do enunciado. Pela eventualidade do caso de condenação, deveria o examinando analisar eventual pena a ser aplicada. Já de início, deveria o examinando defender que eventual condenação de Lauro deveria ser pela prática do crime do art. 213, caput, do CP e não por seu parágrafo primeiro, já que não havia nos autos prova da idade da vítima. Prevê o art. 155, parágrafo único, do CPP que, quanto ao estado das pessoas, serão observadas as restrições estabelecidas pela lei civil. Ademais, o Enunciado 74 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê que a prova da menoridade do réu requer prova com documento hábil. Assim, a mesma ideia deve ser aplicada para comprovação da idade da vítima. No caso, não foi feito qualquer exame pericial, já que o ato não chegou a se consumar. A vítima não apresentou qualquer documento que comprovasse sua idade, sendo certo que a mera alegação em audiência não é suficiente para provar a idade, em especial porque a vítima já possuía 17 anos, logo não há como se ter certeza, por sua aparência física, se maior de 18 anos. Em razão disso, deve ser afastada a qualificadora do art. 213, § 1.º, do CP. Necessário ao examinando buscar afastar o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do CP, descrita na denúncia. Isso porque, apesar de a vítima ser mulher, não há que se falar em violência na forma da Lei 11.340/2006, já que não existia relação familiar, de coabitação ou qualquer outro relacionamento anterior entre as partes. Não basta para o reconhecimento da agravante a simples situação de vítima do sexo feminino. Ademais, deveria o examinando

	requerer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, pois, apesar de a conduta não ser crime, Lauro confessou integralmente os fatos descritos na denúncia. Na terceira fase, a diminuição em razão da tentativa deveria ser do máximo, em razão de o delito ter ficado longe da consumação, adotando-se o entendimento pacificado de que o quantum de redução deve considerar o iter criminis percorrido. Por fim, o regime de pena a ser aplicado seria o aberto ou semiaberto, considerando a pena mínima e a redução aplicável.
Pedidos	Diante do exposto, deveria ser formulado pedido requerendo: a) preliminarmente, reconhecimento da nulidade dos atos praticados desde a primeira audiência de instrução e julgamento; b) no mérito, absolvição de Lauro, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP; c) na eventualidade de condenação, afastamento da qualificadora do art. 213, § 1.º, do CP e aplicação da pena base no mínimo legal; d) afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do CP; e) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; f) redução máxima em razão da tentativa; e g) Aplicação do regime aberto ou semiaberto.
Autenticação	A data a ser indicada é 10 de setembro de 2018, tendo em vista que o prazo para Alegações Finais é de 5 dias, mas o prazo se encerraria em um domingo, devendo ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.
	Memoriais é uma peça que requer muitos cuidados e exige do candidato um estudo bem interessante acerca da teoria da pena, pois, em seu mérito, quanto a subsidiariedade, são exigidos conhecimentos de atenuantes, regime de cumprimento

Comentários

de pena, pena mínima e substituição. Outro ponto que merece destaque numa peça extensa como essa é o cuidado que se deve ter com a administração do tempo. Uma boa estratégia é colocar ponto a ponto na folha original, que será entregue ao final do certame.

Peça Prático-Profissional Inédita:¹⁵

Peça 09:

Bia resolveu voltar sozinha de uma festa a duas quadras de sua casa. Com medo de que suas amigas adentrassem a madrugada, resolveu voltar para casa caminhando sozinha. Percebeu que estava sendo seguida e apressou os passos, todavia, como estava de salto alto, rapidamente dois homens a abordaram, com as mãos dentro da camisa, afirmando que queriam dinheiro e telefone. Assustada, Bia entregou seus pertences, momento este em que os homens caminharam em direção oposta.

Minutos depois passa uma viatura policial e Bia consegue informar aos policiais que acabara de ser assaltada por dois rapazes de porte médio, pele clara e cabelos curtos.

Os policiais, cerca de 500 metros adiante, encontram dois rapazes nas mesmas características e os prendem.

Em seguida, os policiais os conduzem à Delegacia, onde é lavrado o auto de flagrante. João Marcos e Edgar são denunciados como incursos na prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, I e II, c/c art. 29, todos do Código Penal. A denúncia é recebida. Ambos, primários, com residência fixa e com bons antecedentes, foram liberados pelo juiz. Constituíram advogados distintos.

Já em audiência de instrução e julgamento conforme o art. 400 do CPP, João Marcos em interrogatório, com a presença de seu advogado, relata que o autor do crime é Edgar, que não fora intimado para o ato.

No dia seguinte, em seu interrogatório, Edgar, na presença de seu advogado e de João Marcos, nega que tenha realizado o roubo. Bia é ouvida em seguida aos

interrogatórios e não sabe afirmar se eram João Marcos e Edgar os autores do crime.

Configurada a complexidade, o Ministério Público apresenta tese pela condenação de João Marcos e Edgar pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, I e II, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Considerando a situação hipotética descrita, procurado por Edgar, já que destituiu seu antigo advogado, formule, na condição de advogado recém-contratado, a peça a ser apresentada no processo.

7.10 Procuração

Nome	Procuração
Artigo	Art. 44 do CPP: "A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal."
Prazo	Não tem prazo
Serve para	Outorgar poderes ao advogado
Observações	A procuração em âmbito processual penal requer poderes especiais, ou seja, deve se descrever no corpo da procuração detalhes fáticos, impedindo, assim, procurações genéricas. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de não ser possível apenas a menção de artigos, todavia não há necessidade de se descrever minuciosamente todos os detalhes do ocorrido. Portanto, uma descrição razoável. Vale lembrar que a procuração para uma representação, em determinada ação penal pública condicionada à representação, dirigida à autoridade policial ou ao membro do parquet também deve ser específica (art. 39 do CPP).

Em conclusão, para todos os efeitos, apesar de o art. 44 do CPP mencionar expressamente queixa-crime, é sabido que este artigo pode ser utilizado para qualquer procuração, como por exemplo quando da contratação de um advogado para elaboração de recurso.

7.10.1 Modelo

PROCURAÇÃO

Outorgante: _____ (nome completo), nacionalidade, profissão, estado civil, nascimento, portador da carteira de identidade nº _____, inscrita no CPF nº _____, residência _____.

Outorgado: _____ (nome completo do advogado), nacionalidade, estado civil, advogado, portador da cédula de identidade nº _____ OAB nº _____, CPF nº _____, endereço do escritório.

Poderes e finalidades: A **Outorgante** confere ao **Outorgado** todos os poderes da cláusula ***ad judicia et extra*** para o fim _____ (descritivo dos fatos), conferindo ao advogado os poderes também de, podendo, ainda requerer revogação de prisão preventiva, relaxamento de prisão, impetrar *habeas corpus*, apresentar defesa, alegações finais, recorrer, produzir provas, ter vistas de autos judiciais e administrativos, fazer requerimentos perante órgãos públicos municipais, estaduais e federais, requerer certidões e cópias, substabelecer com ou sem reservas, podendo, para tanto, praticar todos os demais atos necessários ao cumprimento do mandato.

Local, Data

-
- 1 Se for o ofendido a vítima do delito, pois se for qualquer pessoa do povo, fundamentar com o art. 5.º, 3.º, do CPP.
- 2 Confira o gabarito ao final da obra.
- 3 Confira o gabarito ao final da obra.
- 4 Confira o gabarito ao final da obra.
- 5 Confira o gabarito ao final da obra.
- 6 Observa-se que é interessante, quando do concurso de crimes, mencionar tal modalidade no mérito queixa-crime, seguindo as hipóteses dos artigos 69, 70 ou 71, CP.
- 7 Se por acaso a queixa-crime for de competência do Juizado Especial Criminal, recomenda-se pedir também a observância do rito da Lei 9.099/1995 com a designação de audiência.
- 8 Confira o gabarito ao final da obra.
- 9 Confira o gabarito ao final da obra.
- 10 Na busca de modernização da peça prática profissional da Resposta do Acusado, o STJ permitiu que nesse momento, mesmo após o recebimento da ação penal, o acusado suscite causas que gerariam o não recebimento da ação penal. Deve a defesa, caso seja possível, mencionar as causas do art. 395 do CPP pedindo ao final pela retratação do recebimento. Vejamos decisão jurisprudencial vinculada no informativo 522 do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. POSSIBILIDADE DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA APÓS A DEFESA PRÉVIA DO RÉU.
- O fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, prevista nos arts. 396 e 396-A do CPP, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do CPP, suscitada pela defesa. Nos termos do art. 396, se não for verificada de plano a ocorrência de alguma das hipóteses do art. 395, a peça acusatória deve ser recebida e determinada a citação do acusado para responder por escrito à acusação. Em seguida, na apreciação da defesa preliminar, segundo o art. 397, o juiz deve absolver sumariamente o acusado quando verificar uma das quatro hipóteses descritas no dispositivo. Contudo, nessa fase, a cognição não pode ficar limitada às hipóteses mencionadas, pois a melhor interpretação do art. 397, considerando a reforma feita pela Lei 11.719/2008, leva à possibilidade não apenas de o juiz absolver sumariamente o acusado, mas também de fazer novo juízo de recebimento da peça acusatória. Isso porque, se a parte pode arguir questões preliminares na defesa prévia, cai por terra o argumento de que o anterior recebimento da denúncia tornaria sua análise preclusa para o juiz de primeiro grau. Ademais, não há por que dar início à instrução processual, se o magistrado verifica que não lhe será possível analisar o mérito da ação penal, em razão de defeito que macula o processo. Além de ser desarrazoada essa solução, ela também não se coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais. Sob outro aspecto, se é admitido o afastamento das questões preliminares suscitadas na defesa prévia, no momento processual definido no art. 397 do CPP, também deve ser considerado admissível o seu acolhimento, com a extinção do processo sem julgamento do mérito por aplicação analógica do art. 267, § 3.º, CPC. Precedentes citados: HC 150.925/PE, 5.ª Turma, DJe 17.05.2010; HC 232.842/RJ, 6.ª Turma, DJe 30.10.2012 (REsp

1.318.180/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16.05.2013).

- 11 Confira o gabarito ao final da obra.
- 12 Confira o gabarito ao final da obra.
- 13 Fundamentar com o art. 404, parágrafo único, no caso de diligências. Se for o caso de número de acusados ou complexidade, fundamentar pelo art. 403, § 3.º, do CPP.
- 14 Podem ou não existir. Vale observar que a apresentação das exceções deve ser feita no momento anterior da resposta do acusado, todavia, se a situação surgir depois, permite-se a alegação, por exemplo, de uma suspeição nesse momento.
- 15 Confira o gabarito ao final da obra.

COMO ELABORAR RECURSOS E AÇÕES AUTÔNOMAS DE IMPUGNAÇÃO

8.1 INTRODUÇÃO

Antes de verificarmos todos os recursos com seus respectivos modelos, se faz necessária uma breve consideração a respeito.

Os recursos em processo penal têm disposição legal a partir do art. 574 do Diploma Processual Penal. Em capítulo seguinte, segue quadro sistemático de todos os recursos. Vale observar que, caminhando pelos artigos referentes ao Capítulo I do Título II – Dos recursos, encontramos duas falhas do legislador: inserir a Revisão Criminal (art. 621 do CPP) e o *Habeas Corpus* (art. 647 do CPP) no presente capítulo. Isso porque suas respectivas naturezas jurídicas são de ações autônomas de impugnação. Vejamos algumas diferenças entre os recursos e essas ações.

Características e Diferenças:

Recursos	Ações Autônomas
Taxativos	Taxativos
Tempestivos	Sem Prazo
Voluntários	HC pode ser de ofício
Inconformismo	HC preventivo nem sempre acontece uma constrição à liberdade
Impedem o trânsito em julgado	Revisão Criminal só após o trânsito em julgado

Mero desdobramento da mesma relação processual	Uma nova relação processual
Reexame de decisão	Possibilidade de um novo objeto jurídico sendo discutido
Interposição no Juízo que proferiu a decisão	Regras de competências próprias
Elaboração de Folha de Rosto (juízo de admissibilidade) e Folha de Razões (juízo de mérito), salvo embargos de declaração e carta testemunhável	Peça única

Relativamente à elaboração dos recursos, é importante seguirmos a orientação de que para todos eles iremos sempre fazer uma folha de rosto, de apresentação e uma folha de razões recursais. Os dois únicos recursos que não devem nos preocupar nesse sentido são os Embargos de Declaração e a Carta Testemunhável, pois são interpostos, respectivamente, ao mesmo juízo que proferiu a decisão e ao escrivão ou secretário do tribunal.

Essa padronização tem um motivo específico. Além de demonstrarmos organização, facilitaremos o estudo, pois as folhas de rosto, que traduzem o juízo de admissibilidade, sempre serão dirigidas, endereçadas aos juízos que prolatam a decisão atacada. Por sua vez, as razões recursais serão sempre direcionadas, nesses casos, aos juízos julgadores, ou seja, àqueles que irão reexaminar a decisão.

Outra obrigatoriedade à qual iremos nos ater no momento da elaboração do recurso é com relação ao início da folha de razões, que deverá conter o seguinte enunciado:

Recorrente: _____

Recorrido: _____

Origem: _____

Processo n.º: _____

Vale ainda observar que, se a questão já nos colocar no juízo julgador da decisão, muito provavelmente o examinador está solicitando ao candidato apenas a apresentação das razões recursais e, evidentemente, nesses casos, a folha de rosto se faz desnecessária. São geralmente situações de recurso de apelação que seguem o rito do art. 600 do CPP.

A título de orientação, alertamos o leitor para o fato de que, em nome da didática, os modelos de recurso serão colocados apenas uma vez, independentemente do procedimento, tendo em vista ter sua elaboração semelhante, mudando, logicamente, apenas os respectivos endereçamentos.

E nunca é demais avisar. Devemos ficar sempre atentos aos respectivos endereçamentos. O estudo do procedimento e da competência é fundamental!¹

8.1.1 Quadro sistemático dos endereçamentos recursais

Recursos	Folha de Rosto	Razões
	Peça de Interposição direcionada ao próprio juízo que proferiu a decisão. É por meio desta peça que é feito o juízo de admissibilidade.	Peça de Mérito do Recurso onde serão colocados os Fatos, Fundamentos e Pedido. É por meio desta peça que é feito o juízo de mérito do recurso.
Recurso em sentido estrito	Vara Criminal, Vara Criminal do Tribunal do Júri, Vara Federal (1. ^a instância)	Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal (2. ^a instância)

Agravo em execução	Vara de Execuções Penais	Tribunal de Justiça, (2.ª instância)
Apelação	Vara Criminal, Vara Criminal do Tribunal do Júri, Juiz Presidente, Vara Federal (1.ª instância), Juizado Especial Criminal	Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal (2.ª instância), Turma Recursal
Embargos de declaração	Vara Criminal, Vara Federal, Juiz-Presidente, Câmara, Turma, Juizado Especial Criminal	Vara Criminal, Vara Federal, Juiz-Presidente, Câmara, Turma, Juizado Especial Criminal, Turma Recursal
Embargos infringentes	Câmara, Turma, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal	Câmara, Turma, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal (podendo ser Grupo de Câmaras)
Recurso especial	Câmara, Turma, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal	STJ
Recurso extraordinário	Câmara, Turma, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, STJ	STF
Recurso ordinário constitucional	Câmara, Turma, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, STJ	STJ STF
Carta testemunhável	Escrivão, Secretário do Tribunal	Escrivão, Secretário do Tribunal

8.1.2 Quadro sistemático dos recursos no processo penal

Recurso	Artigo	Prazo	Em face de
Recurso em sentido estrito	Art. 581 do CPP	5 dias (art. 586) 5 dias por instrumento + 2 dias para razões (arts. 587 e 588)	Decisões interlocutórias
Apelação	Art. 593 do CPP Art. 82 da Lei 9.099/1995	5 dias (art. 593) 5 dias por termo + 8 para razões (art. 600) 10 dias (art. 82, Lei 9.099/1995)	Sentença penal
Embargos infringentes e de nulidade	Art. 609, parágrafo único, do CPP	10 dias (art. 609, parágrafo único)	Acórdão não unânime
Embargos de declaração	Arts. 382 e 619 do CPP e art. 83 da Lei 9.099/1995	2 dias (arts. 382 e 619) 5 dias (art. 83, § 1.º, da Lei 9.099/1995)	Sentença penal ambígua, obscura, omissa, contraditória
Recurso especial	Art. 105, III, da CF	–	Acórdão que desrespeita lei federal

Recurso extraordinário	Art. 102, III, da CF	–	Acórdão que desrespeita a Constituição
Carta testemunhável	Art. 639 do CPP	48 horas	Decisões que denegam recurso e/ou de não prosseguimento dos recursos
Agravo em execução	Art. 197 da Lei 7.210/1984 Súmula 700 do STF	5 dias (segue o rito procedimental do Recurso em Sentido Estrito – art. 586 do CPP)	Incidentes na execução Penal
Recurso ordinário em habeas corpus	Art. 30 da Lei 8.038/1990	5 dias (art. 30 da Lei 8.038/1990)	Decisões denegatórias de habeas corpus nos Tribunais

8.2 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Nome	Recurso em Sentido Estrito
	Art.581 do CPP:Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I – que não receber a denúncia ou a queixa; II – que concluir pela incompetência do juízo; III – que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

Artigo

IV – que pronunciar ou impronunciar o réu;

IV – que pronunciar o réu; (Redação dada pela Lei n.º 11.689, de 2008)

V – que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

VI – Revogado;

VII – que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII – que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX – que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X – que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI – que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII – que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII – que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV – que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV – que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI – que ordenar a suspensão do processo, em virtude

	de questão prejudicial; XVII – que decidir sobre a unificação de penas; XVIII – que decidir o incidente de falsidade; XIX – que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado; XX – que impuser medida de segurança por transgressão de outra; XXI – que manter ou substituir a medida de segurança, nos casos do art.774; XXII – que revogar a medida de segurança; XXIII – que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação; XXIV – que converter a multa em detenção ou em prisão simples.
Prazo	5 dias ou por instrumento 5 + 2 razões Art. 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de cinco dias. Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a

	oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Art. 588. Dentro de dois dias, contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo.
Serve para	Impugnar as decisões interlocutórias do art. 581 do CPP.
Observações	Recurso cuja particularidade é a possibilidade do juízo de retratação por parte do juízo que proferiu a decisão. Vejamos o art. 589 do CPP: Art. 589 do CPP: Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Além disso, algumas decisões do art. 581 atualmente são impugnadas por outro recurso, o Agravo em Execução, que segue, na verdade, o mesmo rito procedimental do Recurso em Sentido Estrito. Isso ocorre porque nossa legislação acerca do tema de Execução Penal é posterior ao antigo Código datado de 1941. A LEP (Lei 7.210) é de 1984. Vejamos quais seriam essas decisões: Incisos XI, XII, XVII, XIX-XXIII. No mais, alertamos para uma recente novidade trazida pela reforma do CPP, Lei 11.689/2008, que alterou a sistemática recursal para as decisões de impronúncia e absolvição sumária no Tribunal do Júri, agora atacadas

pelo recurso de apelação, conforme o art. 416 do CPP:

“Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação.”

8.2.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA
____ DO ESTADO _____

(linhas)

_____ (nome), já qualificado nos autos do processo crime n.º _____ se
fornecido em epígrafe, vem por seu advogado infra-assinado, tempestivamente, não se conformando,
data venia, com a r. decisão de fls. _____, que _____ descrever o teor da decisão, com
fundamento no artigo 581, inciso _____, do CPP, interpor

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,

pelos fatos e fundamentos jurídicos que se seguem nas anexas razões:

Isto posto, se porventura Vossa Excelência entenda que deva manter a decisão, requer o
recorrente que este recurso seja remetido ao Tribunal competente, com base no art. 589 do CPP.

Termos em que, requerendo seja ordenado o processamento do presente recurso, com as
anexas razões, pede deferimento.

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

RAZÕES DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Recorrente: _____

Recorrido: _____

Origem: _____

Processo n.º: _____

Egrégio Tribunal,

Colenda _____

Excelentíssimos Senhores Desembargadores,

No caso em tela, _____ (transcrição da decisão), é necessária a reforma da decisão, conseqüentemente vem dela recorrer em sentido estrito, esperando que ao final seja reformada pelas razões ora expostas:

I – Dos fatos

(...)

II – Das Preliminares

(...)

III – Do Direito

(...)

IV – Dos Pedidos

Ante o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso, para tornar sem efeito a decisão impugnada.²

Nestes Termos,

Pede Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

8.2.2 Exercícios

Peça Prático-Profissional Oficial (III Exame Unificado):

No dia 17 de junho de 2010, uma criança recém-nascida é vista boiando em um córrego e, ao ser resgatada, não possuía mais vida. Helena, a mãe da criança, foi localizada e negou que houvesse jogado a vítima no córrego. Sua filha teria sido, segundo ela, sequestrada por um desconhecido. Durante a fase de inquérito, testemunhas afirmaram que a mãe apresentava quadro de profunda depressão no

momento e logo após o parto. Além disso, foi realizado exame médico legal, o qual constatou que Helena, quando do fato, estava sob influência de estado puerperal. À míngua de provas que confirmassem a autoria, mas desconfiada de que a mãe da criança pudesse estar envolvida no fato, a autoridade policial representou pela decretação de interceptação telefônica da linha de telefone móvel usado pela mãe, medida que foi decretada pelo juiz competente. A prova constatou que a mãe efetivamente praticara o fato, pois, em conversa telefônica com uma conhecida, de nome Lia, ela afirmara ter atirado a criança ao córrego, por desespero, mas que estava arrependida. O delegado intimou Lia para ser ouvida, tendo ela confirmado, em sede policial, que Helena de fato havia atirado a criança, logo após o parto, no córrego. Em razão das aludidas provas, a mãe da criança foi então denunciada pela prática do crime descrito no art. 123 do Código Penal perante a 1.^a Vara Criminal (Tribunal do Júri). Durante a ação penal, é juntado aos autos o laudo de necropsia realizada no corpo da criança. A prova técnica concluiu que a criança já nascera morta. Na audiência de instrução, realizada no dia 12 de agosto de 2010, Lia é novamente inquirida, ocasião em que confirmou ter a denunciada, em conversa telefônica, admitido ter jogado o corpo da criança no córrego. A mesma testemunha, no entanto, trouxe nova informação, que não mencionara quando ouvida na fase inquisitorial. Disse que, em outras conversas que tivera com a mãe da criança, Helena contara que tomara substância abortiva, pois não poderia, de jeito nenhum, criar o filho. Interrogada, a denunciada negou todos os fatos. Finda a instrução, o Ministério Público manifestou-se pela pronúncia, nos termos da denúncia, e a defesa, pela impronúncia, com base no interrogatório da acusada, que negara todos os fatos. O magistrado, na mesma audiência, prolatou sentença de pronúncia, não nos termos da denúncia, e sim pela prática do crime descrito no art. 124 do Código Penal, punido menos severamente do que aquele previsto no art. 123 do mesmo código, intimando as partes no referido ato.

Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, na condição de advogado(a) de Helena, redija a peça cabível à impugnação da mencionada decisão, acompanhada das razões pertinentes, as quais devem apontar os argumentos para o provimento do recurso, mesmo que em

caráter sucessivo.

Gabarito Oficial:

Peça	Recurso em Sentido Estrito
Endereçamento	Juiz da 1. ^a Vara Criminal do Tribunal do Júri
Fundamento Legal	Art. 581, IV, do CPP
Preliminares	Em preliminar, o desentranhamento das provas ilícitas. Isso porque o crime investigado, infanticídio (art. 123 do Código Penal), é punido com pena de detenção. Em razão disso, não era admissível a interceptação telefônica prevista na Lei 9.296/1996, pois a lei em tela não admite a medida quando o crime só é punido com pena de detenção (art. 2.º, III). É de ressaltar que o crime de aborto, previsto no art. 124, também só é punido com pena de detenção. Além disso, o enunciado indica não existir indícios suficientes de autoria, uma vez que o delegado representou pela decretação da quebra com base em meras suspeitas. Finalmente, não foram esgotados todos os meios de investigação, condição sine qua non para que a medida seja decretada. Por outro lado, o examinando deverá registrar também que o testemunho de Lia, embora seja prova realizada de modo lícito, será ilícito por derivação, na forma do art. 157, § 1.º, do Código de Processo Penal e, portanto, imprestável. Ainda em preliminar, deverá o examinando suscitar a nulidade do processo por violação do art. 411, § 3.º, do

	Código de Processo Penal, c/c art. 384 do Código de Processo Penal. Com efeito, diante das regras acima referidas, o Juiz, vislumbrando a possibilidade de nova definição do fato em razão de prova nova, surgida durante a instrução, deverá abrir vista dos autos para que o Ministério Público, se for o caso, adite a denúncia, mesmo que a pena prevista para a nova definição jurídica seja menor, conforme a nova redação do art. 384 do Código de Processo Penal, dada pela Lei 11.719/2008.
Fundamentos	O candidato deverá, ainda, sustentar que não restou provada a materialidade do crime de aborto, uma vez que nenhuma perícia foi feita no sentido de comprovar que a criança faleceu em decorrência da ingestão de substância abortiva. Finalmente, deveria requerer, em caráter sucessivo, a impronúncia da acusada, uma vez que, retiradas as provas ilícitas dos autos, nenhuma prova de autoria existiria contra a denunciada.
Pedidos	Desentranhamento das provas ilícitas; Reconhecimento também da ilicitude do depoimento; Nulidade do processo por violação do art. 411, § 3.º, do Código de Processo Penal, c/c art. 384 do Código de Processo Penal; Falta de materialidade; Impronúncia, conforme o art. 414 do CPP.
Autenticação	Padrão

Comentários

Tratando-se de decisão interlocutória com previsão no art. 581 do CPP, caberá Recurso em Sentido Estrito.

Lembrando que algumas decisões, que, atualmente, são proferidas pelo juízo da execução penal, são passíveis de Agravo em Execução.

No caso apresentado, da pronúncia cabe RESE (art. 581, IV, do CPP) sem dúvida alguma. Folha de interposição feita ao juízo que proferiu a decisão, já que no procedimento do tribunal do júri temos um procedimento bifásico, ou seja, tal decisão fora proferida pelo juízo da 1.^a fase de admissibilidade, o juízo sumariante.

O juízo de retratação se faz presente na folha de interposição, conforme o art. 589 do CPP.

Já nas razões depois das formalidades exigidas, passemos à análise das preliminares. A lei de interceptação telefônica, nesta questão, precisou ser analisada principalmente no tocante à possibilidade única de ser decretada a intervenção tecnológica tão somente nos crimes apenados com reclusão. Senão vejamos o art. 2.º da mencionada lei:

Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

III – o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Note-se que no caso em tela a interceptação foi justamente feita para um crime impossibilitado de tal

medida.

Outra interessante preliminar foi a abordagem da teoria dos frutos da árvore envenenada do art. 157, § 1.º, do CPP, que traduz a contaminação da ilicitude da prova originária às demais derivadas.

Mais complicada seria a percepção da regra da *mutatio libelli* em respeito aos princípios da correlação, congruência e ampla defesa. O magistrado não poderia proferir sua decisão com base em fatos que ainda não foram objeto de manifestação defensiva, por isso se impõe o aditamento, que nada mais significa do que inserir as circunstâncias novas.

Concluindo quanto aos fundamentos, devemos tão somente nos preocupar com a tese da impronúncia, que retrata falta de provas.

Peça Prático-Profissional Oficial (XI Exame Unificado):

Jerusa, atrasada para importante compromisso profissional, dirige seu carro bastante preocupada, mas respeitando os limites de velocidade. Em uma via de mão dupla, Jerusa decide ultrapassar o carro à sua frente, o qual estava abaixo da velocidade permitida. Para realizar a referida manobra, entretanto, Jerusa não liga a respectiva seta luminosa sinalizadora do veículo e, no momento da ultrapassagem, vem a atingir Diogo, motociclista que, em alta velocidade, conduzia sua moto no sentido oposto da via. Não obstante a presteza no socorro que veio após o chamado da própria Jerusa e das demais testemunhas, Diogo falece em razão dos ferimentos sofridos pela colisão.

Instaurado o respectivo inquérito policial, após o curso das investigações, o Ministério Público decide oferecer denúncia contra Jerusa, imputando-lhe a prática do delito de homicídio doloso simples, na modalidade dolo eventual (art. 121 c/c o art. 18, I, parte final, ambos do CP). Argumentou o ilustre membro do *Parquet* a

imprevisão de Jerusa acerca do resultado que poderia causar ao não ligar a seta do veículo para realizar a ultrapassagem, além de não atentar para o trânsito em sentido contrário. A denúncia foi recebida pelo juiz competente e todos os atos processuais exigidos em lei foram regularmente praticados. Finda a instrução probatória, o juiz competente, em decisão devidamente fundamentada, decidiu pronunciar Jerusa pelo crime apontado na inicial acusatória. O advogado de Jerusa é intimado da referida decisão em 2 de agosto de 2013 (sexta-feira).

Atento ao caso apresentado e tendo como base apenas os elementos fornecidos, elabore o recurso cabível e date-o com o último dia do prazo para a interposição.

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

Gabarito Oficial:

Peça	Recurso em Sentido Estrito
Endereçamento	Juiz da Vara Criminal do Tribunal do Júri Razões para o Tribunal de Justiça
Fundamento Legal	Art. 581, IV, CPP
Juízo de Retratação	Art. 589, CPP, inserido na folha de interposição
Preliminares	—
Fundamentos	No mérito, o examinando deve alegar que Jerusa não agiu com dolo, e sim com culpa. Isso porque o dolo eventual exige, além da previsão do resultado, que o agente assuma o risco pela ocorrência do mesmo, nos termos do art. 18, I (parte final), do CP, que adotou, em relação ao dolo eventual, a teoria do consentimento. Nesse sentido, a conduta de Jerusa amolda-se àquela descrita no art. 302 do CTB, razão pela qual ela deve

	responder pela prática, apenas, de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Em consequência, não havendo crime doloso contra a vida, o Tribunal do Júri não é competente para apreciar a questão, razão pela qual deve ocorrer a desclassificação, nos termos do art. 419 do CPP.
Pedidos	Ao final, o examinando deverá elaborar pedido de desclassificação do delito de homicídio simples doloso, para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB).
Autenticação	Levando em conta o comando da questão, que determina datar as peças com o último dia do prazo cabível para a interposição, ambas as petições (interposição e razões do recurso) deverão ser datadas do dia 09.08.2013.
	Nesta peça prático-profissional de tamanha facilidade, o primeiro cuidado diz respeito ao endereçamento da folha de interposição, que tem a função de admissibilidade recursal, que no presente recurso é de extrema simplicidade, pois o juízo a quo apenas verifica a incidência da decisão interlocutória no rol taxativo do art. 581 CPP. Assim, o endereçamento deve ser feito ao juiz de direito da vara criminal do tribunal do júri e jamais, nesse caso, ao juiz-presidente, que só atua na 2.ª fase do júri, no mérito, em plenário. Devemos lembrar que o procedimento do júri, a partir do art. 406 CPP, é um procedimento bifásico, longo e cuidadoso, tendo em vista suas peculiaridades, e ao longo da marcha processual da 1.ª fase quem atua é o juiz de direito da vara criminal do tribunal do júri.

Comentários

No mais, não devemos esquecer o juízo de retratação com base no art. 589, CPP, na folha de interposição. Este juízo de retratação, exclusivo deste recurso e do agravo em execução possibilita ao juiz que proferiu a decisão que se retrate e evite a subida do recurso para o tribunal. Hipótese rara, mas possível, diga-se de passagem.

No tocante ao mérito, as primeiras buscas devem ser feitas em direção à absolvição sumária do art. 415 CPP ou buscando-se a impronúncia do art. 414 CPP. A primeira decisão só deve ser almejada com a total incidência das hipóteses de seus incisos. Já a impronúncia é a falta de provas. O parágrafo único do art. 414 é extremamente eficiente em explicar a diferença dessa decisão para aquela da absolvição sumária. Como essas duas teses estão fora de cogitação com a leitura do enunciado, devemos buscar a tese final da desclassificação do art. 419, CPP.

No mérito é necessário reconhecer que não houve dolo eventual; este exige que o agente preveja o resultado e aceite causá-lo. Para tanto, foi adotada a teoria do consentimento, que impõe a aceitação como elemento do dolo eventual. Portanto, fica claro pela leitura da questão que se trata de crime culposos e não doloso, sendo necessária a desclassificação para o crime previsto no art. 302 do CTB.

Peça Prático-Profissional Oficial (XXVIII Exame Unificado):

Túlio, nascido em 01.01.1996, primário, começa a namorar Joaquina, jovem que recém completou 15 anos. Logo após o início do namoro, ainda muito apaixonado, é

surpreendido pela informação de que Joaquina estaria grávida de seu ex-namorado, o adolescente João, com quem mantivera relações sexuais. Joaquina demonstra toda a sua preocupação com a reação de seus pais diante desta gravidez quando tão jovem e, em desespero, solicita ajuda de Túlio para realizar um aborto. Diante disso, no dia 03.01.2014, em Porto Alegre, Túlio adquire remédio abortivo cuja venda era proibida sem prescrição médica e o entrega para a namorada, que, de imediato, passa a fazer uso dele. Joaquina, então, expelle algo não identificado pela vagina, que ela acredita ser o feto. Os pais presenciam os fatos e levam a filha imediatamente ao hospital; em seguida, comparecem à Delegacia e narram o ocorrido. No hospital, foi informado pelos médicos que, na verdade, Joaquina possuía um cisto, mas nunca estivera grávida, e o que fora expelido não era um feto. Após investigação, no dia 20.01.2014, Túlio vem a ser denunciado pelo crime do art. 126, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, perante o juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre/RS, não sendo oferecido qualquer instituto despenalizador, apesar do reclamo defensivo. A inicial acusatória foi recebida em 22.01.2014. Durante a instrução da primeira fase do procedimento especial, são ouvidas as testemunhas e Joaquina, assim como interrogado o réu, todos confirmando o ocorrido. As partes apresentaram alegações finais orais, e o juiz determinou a conclusão do feito para decisão. Antes de ser proferida decisão, mas após manifestação das partes em alegações finais, foram juntados aos autos o boletim de atendimento médico de Joaquina, no qual consta a informação de que ela não estivera grávida no momento dos fatos, a Folha de Antecedentes Criminais de Túlio sem outras anotações e um exame de corpo de delito, que indicava que o remédio utilizado não causara lesões na adolescente. Com a juntada da documentação, de imediato, sem a adoção de qualquer medida, o magistrado proferiu decisão de pronúncia nos termos da denúncia, sendo publicada na mesma data, qual seja, 18 de junho de 2018, segunda-feira, ocasião em que as partes foram intimadas. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado(a) de Túlio, redija a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição, considerando-se que todos os dias de segunda a sexta-feira são úteis em todo o país.

Peça	Recurso em Sentido Estrito
Endereçamento	Petição de interposição do recurso, que deveria ser direcionada ao Juízo do Tribunal do Júri de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, local onde foi praticado o ato de execução do delito imputado, sendo certo que o crime em questão é considerado doloso contra a vida. Já na petição de interposição, deveria ser formulado pedido de retratação por parte do juízo a quo, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal. Em seguida, caso mantida a decisão de pronúncia, os autos deveriam ser encaminhados para o Tribunal de Justiça, com as respectivas razões recursais. Após a petição de interposição, deveria o examinando apresentar as Razões do Recurso em Sentido Estrito, dessa vez direcionando as mesmas ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Fundamentação	Art. 581, IV, CPP
	Já no início de sua manifestação, a defesa de Túlio deveria requerer o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Isso porque os fatos ocorreram em 03.01.2014, quando o réu era menor de 21 anos. A denúncia foi recebida em 22.01.2014, funcionando como causa de interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 117, inciso I, do CP. Durante a instrução, passaram-se mais de 4 anos sem que houvesse suspensão do prazo prescricional ou nova causa de interrupção. Apenas em 18.06.2018 foi proferida decisão

**Preliminares e
Mérito**

de pronúncia, que funciona como causa de interrupção, nos termos do art. 117, inciso II, do CP.

O crime imputado ao agente possui pena máxima de 4 anos, certo que, ainda que reduzido pela tentativa (mínimo previsto) o prazo prescricional, a princípio, seria de 8 anos, conforme art. 109, inciso IV, do Código Penal. Ocorre que o agente era menor de 21 anos na data dos fatos, logo o prazo deveria ser computado pela metade (art. 115 do CP), fazendo que o prazo prescricional seja de 4 anos, período esse ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a pronúncia. Ainda preliminarmente, deveria o examinando destacar que existia nulidade a ser reconhecida, anulando-se toda a instrução, tendo em vista que o crime imputado ao acusado possui pena prevista de 1 a 4 anos, logo possível a proposta de suspensão condicional do processo. De acordo com o art. 89 da Lei 9.099/1995, independentemente de o crime ser ou não de menor potencial ofensivo, ainda que doloso contra a vida, em sendo a pena mínima prevista de até 1 ano, preenchidos os demais requisitos legais, cabível a proposta de suspensão condicional do processo. No caso, Túlio era primário e não respondia a qualquer outra ação penal, não havendo motivação razoável para que não fosse oferecida a proposta do instituto despenalizador. Com a suspensão condicional do processo, sequer haveria que se falar em instrução e pronúncia, então deveria ser anulada a decisão de pronúncia, encaminhando-se os autos ao Ministério Público para manifestação sobre a proposta do benefício. Superada tal questão, ainda haveria outra nulidade a ser alegada. Após as alegações

finais das partes, foram juntados documentos aos autos relevantes para o julgamento da causa, tendo o magistrado, de imediato, sem dar vistas às partes, proferido decisão de pronúncia considerando a documentação apresentada. Diante disso, houve violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, já que a defesa não teve acesso a provas que foram acostadas ao procedimento. No mérito, o principal argumento a ser apresentado em favor de Túlio é a necessidade de absolvição sumária, tendo em vista que o fato evidentemente não constitui crime, sendo sua conduta atípica. Isso porque estamos diante da hipótese de crime impossível. Prevê o art. 17 do Código Penal que não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar o crime. O legislador brasileiro decidiu, então, valorizar, nesse momento, a efetiva violação/risco do/ao bem jurídico protegido, em detrimento do elemento subjetivo. Na hipótese apresentada, estamos diante de clara situação de impropriedade do objeto, tendo em vista que a intenção do agente era causar aborto em uma pessoa que não estava nem sequer grávida.

Em que pese Túlio acreditar estar praticando o delito e ter dolo de praticá-lo, no mundo fático não havia feto em risco e bem jurídico a ser protegido. Diante disso, ao entregar remédio abortivo para pessoa que não estava grávida, não sendo causada qualquer lesão, a conduta é atípica, devendo ser o agente absolvido de imediato, nos termos do art. 415, inciso III, do CPP.

Pedidos	Em sua conclusão, deveria o examinando formular o pedido de conhecimento e provimento do recurso para: a) ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva; b) anulação da decisão de pronúncia; c) absolvição sumária, nos termos do art. 415, inciso III, do CPP.
Autenticação	O prazo para apresentação do Recurso em Sentido Estrito é de 5 dias, nos termos do art. 586 do CPP, logo se encerra em 25 de junho de 2018, segunda-feira, uma vez que a intimação ocorreu em 18 de junho de 2018, então o prazo se encerraria no sábado, devendo ser estendido até o primeiro dia útil seguinte. No fechamento, deveria o candidato indicar local, data, advogado e nº OAB.
Comentários	Peça conhecidíssima no Exame, o RESE da pronúncia é um clássico. Nessa peça, como no mérito só se deve buscar a absolvição sumária do art. 415 CPP e/ou Impronúncia do art. 414 CPP e/ou Desclassificação do art. 419 CPP, o candidato deve ficar muito atento às preliminares, pois devemos pensar também em como a banca examinadora irá distribuir toda a pontuação. Foi justamente isso que aconteceu. Fora exigido do candidato, por exemplo, a elaboração de preliminar de prescrição, famosa extinção da punibilidade do art. 107 CP.

Peça Prático-Profissional Inédita:³

Peça 10:

Murilo, famoso farmacêutico, é preso em flagrante pelo crime previsto no art. 273, § 1.º-B, I, do CP – importação e posse de medicamento sem registro no órgão competente, durante uma fiscalização da Receita Federal, quando trazia consigo

anabolizantes sem o devido registro da Anvisa, em um ônibus procedente da cidade de Foz do Iguaçu. Confessa que seria o responsável pela aquisição dos medicamentos no Paraguai e por seu ingresso no território nacional.

É impetrado *habeas corpus* em favor de Murilo no juízo competente para que este possa responder em liberdade, já que contribui ativamente para a persecução criminal. O juiz nega a liberdade mencionando que se trata de um crime contra a incolumidade pública e que sua prisão é exemplo para a ilegalidade da conduta. Interponha medida adequada, exclusiva de advogado, capaz de reformar tal decisão judicial.

8.3 APELAÇÃO

Nome	Apelação
	Art. 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação. (Redação dada pela Lei n.º 11.689, de 2008) Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I – das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; II – das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; III – das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena

Artigo

ou da medida de segurança;

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

§ 1.º Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação.

§ 2.º Interposta a apelação com fundamento no n.º III, “c”, deste artigo, o tribunal ad quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança.

§ 3.º Se a apelação se fundar no n.º III, “d”, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.

§ 4.º Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra.

Art. 82 da Lei 9.099/1995. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 1.º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual

	constarão as razões e o pedido do recorrente. § 2.º O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias. § 3.º As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o § 3.º do art. 65 desta Lei. § 4.º As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. § 5.º Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.
Prazo	5 dias (art. 593) 5 dias por termo + 8 para razões (art. 600) 10 dias (art. 82 da Lei 9.099/1995)
Serve para	Reforma de sentença penal
	Recurso por excelência mais amplo e abrangente do Processo Penal. Podendo ser apresentado em sua totalidade na 1.ª instância ou com possibilidade de razões recursais em 2.ª instância, como profetiza o já visto art. 600 do CPP. Observemos que este recurso tem um prazo diferenciado e mais extenso em sede de Juizado Especial Criminal, para onde remetemos o leitor. Prazo este de 10 dias, pois acredita o legislador que, como no procedimento sumaríssimo do juizado vigoram os princípios da celeridade, informalidade e oralidade, o apelante teria que

Observações

ter mais tempo para elaboração do recurso. Além disso, cuidado precisamos ter em endereçar nossas razões recursais não ao Tribunal de 2.^a instância, e sim às Turmas Recursais.

Seguindo os alertas que precisam ser feitos, outra apelação que no momento da elaboração precisa ser feita com um cuidado a mais são aquelas interpostas das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri.

Primeiro a folha de rosto deve ser direcionada ao Juiz-Presidente e, em segundo lugar, em relação ao pedido que, nem sempre, será de um novo julgamento ou de reforma. Nesse sentido, muita atenção ao inciso III do art. 593. Exemplificando, caso a apelação tenha sido fundamentada em decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, a apelação deverá ter como pedido um novo julgamento, pois, com base na soberania dos veredictos, o Tribunal de 2.^a instância não poderá reformar o teor da decisão (art. 593, III, § 3.º, do CPP).

8.3.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA
____ DO ESTADO DO _____

(linhas)

_____ (nome), qualificado nos autos do processo n.º _____, por seu advogado infra-assinado, vem, com fulcro no art. 593, inc. _____, interpor recurso de **APELAÇÃO** por entender, data venia, que a sentença de fls. _____ merece ser reformada porque não espelha a realidade dos fatos.⁴

Desde já, requer remessa dos autos ao Egrégio Tribunal _____ para conhecimento e provimento do presente recurso.⁵

N. Termos,

P. Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

EGRÉGIO TRIBUNAL _____,

COLEDA CÂMARA,

EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES.

Processo n.º: _____

Apelante: _____

Apelado: _____

Origem: _____

RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO

Trata-se de sentença penal proferida pelo i. juízo da ____ vara _____, na qual _____ (transcrição da decisão), que merece ser, data venia, reformada pelas razões e fundamentos de direito expostas a seguir:

I – Dos Fatos⁶

(...)

II – Das Preliminares

(...)

III – Do Direito

(...)

IV – Do Pedido

Isto posto, requer o conhecimento do presente recurso a fim de que no mérito seja a sentença reformada com _____ (motivação do recurso), nos termos do artigo _____.

N. Termos,

P. Deferimento,

Local, data

Nome e Número do Advogado (se fornecido)

8.3.2 Exercícios

Peça Prático-Profissional Oficial (IV Exame Unificado):

Tício foi denunciado e processado, na 1.^a Vara Criminal da Comarca do Município X, pela prática de roubo qualificado em decorrência do emprego de arma de fogo. Ainda durante a fase de inquérito policial, Tício foi reconhecido pela vítima. Tal reconhecimento se deu quando a referida vítima olhou através de pequeno orifício da porta de uma sala onde se encontrava apenas o réu. Já em sede de instrução criminal, nem vítima nem testemunhas afirmaram ter escutado qualquer disparo de arma de fogo, mas foram uníssonas no sentido de assegurar que o assaltante portava uma. Não houve perícia, pois os policiais que prenderam o réu em flagrante não lograram êxito em apreender a arma. Tais policiais afirmaram em juízo que, após escutarem gritos de “pega ladrão!”, viram o réu correndo e foram em seu encalço. Afirmaram que, durante a perseguição, os passantes apontavam para o réu, bem como que este jogou um objeto no córrego que passava próximo ao local dos fatos, que acreditavam ser a arma de fogo utilizada. O réu, em seu interrogatório, exerceu o direito ao silêncio. Ao cabo da instrução criminal, Tício foi condenado a oito anos e seis meses de reclusão, por roubo com emprego de arma de fogo, tendo sido fixado o regime inicial fechado para cumprimento de pena. O magistrado, para fins de condenação e fixação da pena, levou em conta os depoimentos testemunhais colhidos em juízo e o reconhecimento feito pela vítima em sede policial, bem como o fato de o réu ser reincidente e portador de maus antecedentes, circunstâncias comprovadas no curso do processo.

Você, na condição de advogado(a) de Tício, é intimado(a) da decisão. Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redija a peça cabível, apresentando as razões e sustentando as teses

jurídicas pertinentes.

Gabarito Oficial:

Peça	Apelação
Endereçamento	A petição de interposição deve ser endereçada ao juiz de direito da 1. ^a vara criminal da comarca do município X. Nas razões de apelação o candidato deverá dirigir-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Fundamento Legal	Art. 593, I, do CPP
Preliminares	–
Fundamentos	O reconhecimento feito não deve ser considerado para fins de condenação, pois houve desrespeito à formalidade legal prevista no art. 226, II, do Código de Processo Penal. Dessa forma, inexistiria prova suficiente para a condenação do réu, haja vista ter sido feito somente um único reconhecimento, em sede de inquérito policial e sem a observância das exigências legais, o que levaria à absolvição com fulcro no art. 386, VII, do mesmo diploma (também aceita-se como fundamento do pedido de absolvição (art. 386, V, do CPP). Outrossim, de maneira alternativa, deverá postular o afastamento da causa especial de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo, pois esta deveria ter sido submetida a perícia, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, o que não foi feito, de modo que não há como ser comprovada a potencialidade

	lesiva da arma. Ademais, sequer foi possível a perícia indireta (art. 167 do CPP), pois nenhuma das testemunhas disse ter escutado a arma disparar, de modo que o emprego de arma somente poderia servir para configurar a grave ameaça, elementar do crime de roubo.
Pedidos	Absolvição, Redução de Pena, Mudança de Regime, Nulidade da Prova, Afastamento da Agravante.
Autenticação	Padrão
	Mais uma padronização de gabarito que não se preocupou em separar preliminares e fundamentos. Por mais que tal postura não tenha sido exigida, a melhor e mais organizada é de delimitarmos preliminares das questões meritórias. Sendo assim, num primeiro momento, cristalina a nulidade com base no art. 564, IV, do CPP, do reconhecimento feito com violação clara do art. 226, II, do CPP. No mérito devemos mencionar que fatos colhidos em sede inquisitorial, por si só, não podem servir de base para a condenação. As informações colhidas na primeira fase da persecução criminal merecem ser contraditadas em juízo, repetindo-as, quando possível. No tocante à arma de fogo, como é uma peça defensiva, devemos sustentar que, para a comprovação da causa de aumento do uso de arma de fogo, ao menos precisaríamos de sua perícia. Vale observar que essa é uma argumentação frágil em nossos tribunais superiores

Comentários

que vem permitindo a comprovação da causa de aumento por outros meios de prova. Vejamos decisão de 06.03.2012 proferida pela nossa mais alta corte no HC 108.435/RS.

“1. Vigora no Direito brasileiro e no Direito contemporâneo em geral o princípio da livre convicção. 2. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). 3. Habeas corpus denegado”.

Percebemos assim, claramente, a intenção defensiva na argumentação da retirada da presente causa de aumento.

Subsidiariamente, com base no princípio da eventualidade, em caso de condenação, devemos pedir a redução da pena, a mudança de regime e o afastamento da agravante, tendo em vista as circunstâncias pessoais do condenado. É bem verdade que tais pedidos subsidiários são difíceis de perceber ao lermos a questão, pois o enunciado nos coloca situações de reincidência e maus antecedentes.

Peça Prático-Profissional Oficial (V Exame Unificado):

Em 10 de janeiro de 2007, Eliete foi denunciada pelo Ministério Público pela prática do crime de furto qualificado por abuso de confiança, haja vista ter alegado o *Parquet* que a denunciada havia se valido da qualidade de empregada doméstica para subtrair, em 20 de dezembro de 2006, a quantia de R\$ 50,00 de seu patrão Cláudio,

presidente da maior empresa do Brasil no segmento de venda de alimentos no varejo. A denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2007, e, após a instrução criminal, foi proferida, em 10 de dezembro de 2009, sentença penal julgando procedente a pretensão acusatória para condenar Eliete à pena final de dois anos de reclusão, em razão da prática do crime previsto no art. 155, § 2.º, inciso IV, do Código Penal. Após a interposição de recurso de apelação exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça entendeu por bem anular toda a instrução criminal, ante a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento injustificado de uma pergunta formulada a uma testemunha. Novamente realizada a instrução criminal, ficou comprovado que, à época dos fatos, Eliete havia sido contratada por Cláudio havia uma semana e só tinha a obrigação de trabalhar às segundas, quartas e sextas-feiras, de modo que o suposto fato criminoso teria ocorrido no terceiro dia de trabalho da doméstica. Ademais, foi juntada aos autos a comprovação dos rendimentos da vítima, que giravam em torno de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais. Após a apresentação de memoriais pelas partes, em 9 de fevereiro de 2011, foi proferida nova sentença penal condenando Eliete à pena final de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Em suas razões de decidir, assentou o magistrado que a ré possuía circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma vez que se reveste de enorme gravidade a prática de crimes em que se abusa da confiança depositada no agente, motivo pelo qual a pena deveria ser distanciada do mínimo. Ao final, converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, consubstanciada na prestação de 8 (oito) horas semanais de serviços comunitários, durante o período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses em instituição a ser definida pelo juízo de execuções penais. Novamente não houve recurso do Ministério Público, e a sentença foi publicada no Diário Eletrônico em 16 de fevereiro de 2011.

Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redija, na qualidade de advogado de Eliete, com data para o último dia do prazo legal, o recurso cabível à hipótese, invocando todas as questões de direito pertinentes, mesmo que em caráter eventual.

Gabarito Oficial:

Peça	Apelação
Endereçamento	Juiz de Direito, com razões inclusas endereçadas ao Tribunal de Justiça.
Fundamento Legal	Art. 593, I, do CPP
Preliminares	Que a segunda sentença violou a proibição à reformatio in pejus – configurando-se caso de reformatio in pejus indireta –, contida no art. 617 do CPP, de modo que, em razão do trânsito em julgado para a acusação, a pena não poderia exceder dois anos de reclusão, estando prescrita a pretensão punitiva estatal, na forma do art. 109, V, do Código Penal, uma vez que, entre o recebimento da denúncia (12.01.2007) e a prolação de sentença válida (09.02.2011), transcorreu lapso superior a quatro anos.
Fundamentos	Superada a questão, o candidato deverá argumentar que inexistia relação de confiança a justificar a incidência da qualificadora (Eliete trabalhava para Cláudio fazia uma semana) e que a quantia subtraída era insignificante, sobretudo tomando-se como referência o patrimônio concreto da vítima. Em razão disso, o candidato deverá requerer a reforma da sentença, de modo a se absolver a ré por atipicidade material de sua conduta, ante a incidência do princípio da insignificância/bagatela. O candidato deve argumentar, ainda, que, na hipótese de não se reformar a sentença para se absolver a ré, ao menos deveria ser reduzida a pena em razão do furto privilegiado, substituindo-se a sanção por multa. Em razão de tais pedidos, considerando-se a redução de

pena, o candidato deveria requerer a substituição da pena privativa de liberdade por multa, bem como a aplicação da suspensão condicional da pena e/ou suspensão condicional do processo.

Deveria ainda o candidato argumentar sobre a impossibilidade do aumento da pena-base realizado pelo magistrado sob o fundamento da enorme gravidade nos crimes em que se abusa da confiança depositada, pois tal motivo já foi levado em consideração para qualificar o delito, não podendo a apelante sofrer dupla punição pelo mesmo fato – bis in idem.

Por fim, o candidato deveria requerer um dos pedidos possíveis para a questão apresentada, tais como:

- 1 – absolvição;
- 2 – reconhecimento da reformatio in pejus, com a aplicação da pena em no máximo 2 anos e a consequente prescrição;
- 3 – atipicidade da conduta, tendo em vista a aplicação do princípio da bagatela;
- 4 – não incidência da qualificadora do abuso da confiança, com a consequente desclassificação para furto simples;
- 5 – aplicação da Suspensão Condicional do Processo;
- 6 – não sendo afastada a qualificadora, a incidência do § 2.º do art. 155 do CP;
- 7 – a redução da pena pelo reconhecimento do bis in

Pedidos

	idem e a consequente prescrição; 8 – aplicação de sursis; 9 – inadequação da pena restritiva aplicada, tendo em vista o que dispõe o art. 46, § 3.º, do CP. Alternativamente, o candidato poderá elaborar embargos de declaração, abordando os pontos indicados no gabarito 2.
Autenticação	Padrão
Comentários	Uma das teses mais interessantes para a defesa é a da proibição da reformatio in pejus, quando somente a defesa recorre e ocasiona um impedimento natural na piora da condenação proferida. Este é inclusive o mandamento do art. 617 do CPP. Consequentemente, com a devida e correta argumentação, outra preliminar aparece, a tão conhecida extinção da punibilidade da prescrição (art. 107 c/c art. 109 do CPP). O próprio gabarito fornecido teve o cuidado de determinar o lapso temporal em que ocorre a perda do Estado em punir. Após a análise das preliminares, argumenta-se pela ausência de confiança, evidentemente, pois havia pouquíssimos dias de convivência para se instaurar tal qualificadora. Além disso, o valor furtado pode ser perfeitamente considerado insignificante para a vítima. Percebemos o cuidado do examinador em nos fornecer isso, inclusive mencionando os R\$ 50.000 mensais percebidos pela vítima. O que seriam R\$ 50? Subsidiariamente, não se obtendo a absolvição, deve-se

argumentar em favor da redução de pena para furto privilegiado. Partindo-se da premissa, os demais pedidos expostos são consequências lógicas autoexplicáveis no gabarito fornecido.

Peça Prático-Profissional Oficial (XII Exame Unificado):

Rita, senhora de 60 anos, foi presa em flagrante no dia 10.11.2011 (quinta-feira), ao sair da filial de uma grande rede de farmácias, após ter furtado cinco tintas de cabelo. Para subtrair os itens, Rita arrebentou a fechadura do armário onde estavam os referidos produtos, conforme imagens gravadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O valor total dos itens furtados perfazia a quantia de R\$ 49,95 (quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Instaurado inquérito policial, as investigações seguiram normalmente. O Ministério Público, então, por entender haver indícios suficientes de autoria, provas da materialidade e justa causa, resolveu denunciar Rita pela prática da conduta descrita no art. 155, § 4.º, inciso I, do CP (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo). A denúncia foi regularmente recebida pelo juízo da 41.ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado 'X' e a ré foi citada para responder à acusação, o que foi devidamente feito. O processo teve seu curso regular e, durante todo o tempo, a ré ficou em liberdade.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 18.10.2012 (quinta-feira), o Ministério Público apresentou certidão cartorária apta a atestar que no dia 15.05.2012 (terça-feira) ocorrera o trânsito em julgado definitivo de sentença que condenava Rita pela prática do delito de estelionato. A ré, em seu interrogatório, exerceu o direito ao silêncio. As alegações finais foram orais; acusação e defesa manifestaram-se. Finda a instrução criminal, o magistrado proferiu sentença em audiência. Na dosimetria da pena, o magistrado entendeu por bem elevar a pena-base em patamar acima do mínimo, ao argumento de que o trânsito em julgado de outra sentença condenatória configurava maus antecedentes; na segunda fase da dosimetria da pena o magistrado também entendeu ser cabível a incidência da agravante da

reincidência, levando em conta a data do trânsito em julgado definitivo da sentença de estelionato, bem como a data do cometimento do furto (ora objeto de julgamento); não verificando a incidência de nenhuma causa de aumento ou de diminuição, o magistrado fixou a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão no regime inicial semiaberto e 80 (oitenta) dias-multa. O valor do dia-multa foi fixado no patamar mínimo legal. Por entender que a ré não atendia aos requisitos legais, o magistrado não substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Ao final, assegurou-se à ré o direito de recorrer em liberdade.

O advogado da ré deseja recorrer da decisão. Atento ao caso narrado e levando em conta tão somente as informações contidas no texto, elabore o recurso cabível.

Gabarito Oficial:

Peça	Apelação
Endereçamento	Juiz da 41. ^a Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado 'X'. As razões deverão ser endereçadas ao Tribunal de Justiça do Estado X.
Fundamento Legal	Art. 593, I, CPP
Preliminares	—
	I. Atipicidade da conduta pela falta de tipicidade material: a subtração de cinco tintas de cabelo, embora esteja adequada, formalmente, à conduta descrita no tipo penal, não importa em efetiva lesão ao patrimônio da farmácia. Incide, portanto, o princípio da insignificância. Assim, ausente a tipicidade material, a conduta é atípica. II. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a aplicação do privilégio contido no § 2.º do art. 155 do CP, já que a coisa furtada é de pequeno valor (R\$ 49,95),

Fundamentos

bem como Rita seria considerada primária, já que o furto foi cometido antes do trânsito em julgado da condenação do crime de estelionato.

III. Impossibilidade de bis in idem: o magistrado, ao utilizar uma mesma circunstância (trânsito em julgado da sentença condenatória por crime de estelionato) para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria e também para elevar a pena-intermediária na segunda fase da dosimetria, feriu o princípio do ne bis in idem.

IV. Não configuração da reincidência: o art. 63 do Código Penal disciplina que somente haverá reincidência se o novo crime (no caso, o furto) for cometido após o trânsito em julgado definitivo de sentença condenatória de crime anterior. Não foi esse o caso da ré, pois o furto foi cometido antes do trânsito em julgado definitivo da sentença relativa ao estelionato. Não se verifica, portanto, a reincidência.

V. A fixação errada do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena: como a ré não é reincidente, faz jus ao regime aberto, conforme disposto no art. 33, § 2.º, "c", do CP.

VI. A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos: não sendo, a ré, reincidente, encontram-se presentes os requisitos do art. 44 do CP. Assim, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Ao final, o examinando deverá elaborar os seguintes pedidos:

Pedidos	I. Absolvição com base na atipicidade da conduta; II. Subsidiariamente, requer-se a aplicação do § 2.º do art. 155 do CP (furto privilegiado); III. Caso não reconhecida a atipicidade, deverá requerer a diminuição da pena pelo afastamento da circunstância agravante da reincidência; IV. A fixação do regime aberto para o cumprimento da pena; V. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
Autenticação	Padrão
Comentários	Trata-se de evidente caso de incidência do princípio da insignificância, afastando a tipicidade material do fato, que deixa de ser crime, acarretando necessária absolvição. Subsidiariamente o candidato poderia requerer a incidência do furto privilegiado, por tratar-se de subtração de coisa de pequeno valor, por agente primário, mesmo que se trate de crime de furto qualificado no art. 155, § 4.º, I. Esse entendimento, quanto à possibilidade de configurar o furto qualificado privilegiado, atualmente consta inclusive do Enunciado 511 da Súmula do STJ, e numa questão mais atual deveria ser colocado no gabarito. Outro aspecto subsidiário é o reconhecimento do bis in idem, entre a agravante da reincidência e as circunstâncias judiciais de maus antecedentes, ambas levando em conta uma única condenação. Outrossim, não houve reincidência, na forma do art. 63 do CP, pois a condenação definitiva somente ocorreu após o novo

crime. Por fim, a fixação do regime aberto, com base no art. 33, § 2.º, “c”, e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Peça Prático-Profissional Oficial (XIII Exame Unificado):

Diogo está sendo regularmente processado pela prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150 do CP) em concurso material com o crime de furto qualificado pela escalada (art. 155, § 4.º, II, do CP). Isso porque, segundo narrou a inicial acusatória, no dia 10.11.2012 (sábado), Diogo pulou o muro de cerca de três metros que guarnecia a casa da vítima e, então, após ingressar clandestinamente na residência, subtraiu diversos pertences e valores, a saber: três anéis de ouro, dois relógios de ouro, dois aparelhos de telefone celular, um *notebook* e quinhentos reais em espécie, totalizando R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 29.08.2013 (quinta-feira), foram ouvidas duas testemunhas de acusação que, cada uma por seu turno, disseram ter visto Diogo pular o muro da residência da vítima e dali sair, cerca de vinte minutos após, levando uma mochila cheia. A defesa, por sua vez, não apresentou testemunhas. Também na audiência de instrução e julgamento foi exibido um DVD contendo as imagens gravadas pelas câmeras de segurança presentes na casa da vítima, sendo certo que à defesa foi assegurado o acesso ao conteúdo do DVD, mas esta se manifestou no sentido de que nada havia a impugnar. Nas imagens exibidas em audiência ficou constatado (dada a nitidez das mesmas) que fora Diogo quem realmente pulou o muro da residência e realizou a subtração dos bens. Em seu interrogatório o réu exerceu o direito ao silêncio.

Em alegações finais orais, o Ministério Público exibiu cópia de sentença prolatada cerca de uma semana antes (ainda sem trânsito em julgado definitivo, portanto), onde se condenou o réu pela prática, em 25.12.2012 (terça-feira), do crime de estelionato. A defesa, em alegações finais, limitou-se a falar do princípio do estado de inocência, bem como que eventual silêncio do réu não poderia importar-lhe em prejuízo. O Juiz, então, proferiu sentença em audiência condenando Diogo pela

prática do crime de violação de domicílio em concurso material com o crime de furto qualificado pela escalada. Para a dosimetria da pena o magistrado ponderou o fato de que nenhum dos bens subtraídos fora recuperado. Além disso, fez incidir a circunstância agravante da reincidência, pois considerou que a condenação de Diogo pelo crime de estelionato o faria reincidente. O total da condenação foi de 4 anos e 40 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e multa à proporção de um trigésimo do salário mínimo. Por fim, o magistrado, na sentença, deixou claro que Diogo não fazia jus a nenhum outro benefício legal, haja vista o fato de não preencher os requisitos para tanto. A sentença foi lida em audiência.

O(a) advogado(a) de Diogo, atento(a) tão somente às informações descritas no texto, deve apresentar o recurso cabível à impugnação da decisão, respeitando as formalidades legais e desenvolvendo, de maneira fundamentada, as teses defensivas pertinentes. O recurso deve ser datado com o último dia cabível para a interposição.

Gabarito Oficial:

Peça	Apelação
Endereçamento	A petição de interposição deverá ser endereçada ao Juiz da Vara Criminal. As razões do recurso deverão ser endereçadas ao Tribunal de Justiça.
Fundamento Legal	Art. 593, I, CPP
Preliminares	—
	No mérito, o examinando deve alegar que: (i) O crime de violação de domicílio deve ser absorvido pelo delito de furto qualificado, pois configurou um crime-meio, essencial à execução do crime-fim, que era o furto qualificado. Assim, deve ser excluída a condenação pelo delito de violação de domicílio, restando, apenas, o delito

Fundamentos

de furto qualificado;

(ii) Não há que falar em reincidência, nos termos do art. 63 do CP. Note-se que o delito em análise não foi praticado após o trânsito em julgado de condenação anterior. Uma simples sentença condenatória não tem o condão de gerar reincidência;

(iii) Levando em conta o afastamento do delito de violação de domicílio, bem como o afastamento da circunstância agravante da reincidência, o réu fará jus à diminuição da pena e consequente modificação de seu regime de cumprimento, passando do semiaberto para o aberto, nos termos do art. 33, § 2.º, "c", do CP;

(iv) Levando em conta o afastamento da reincidência, verifica-se que o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Pedidos

Ao final, o examinando deverá elaborar os seguintes pedidos:

(i) Absolvição do crime de violação de domicílio;

(ii) Afastamento da circunstância agravante da reincidência;

(iii) Consequente diminuição da pena;

(iv) Consequente fixação do regime aberto para cumprimento de pena;

(v) Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Autenticação	Levando em conta o comando da questão, que determina datar as peças com o último dia do prazo cabível para a interposição, ambas as petições (interposição e razões do recurso) deverão ser datadas do dia 03.09.2013.
Comentários	A peça não apresentava preliminares ou questões processuais a serem atacadas. No aspecto penal, o principal ponto era perceber que o crime de violação de domicílio está absorvido pelo crime de furto, por força do princípio da consunção, numa relação de crime-meio que se exaure no crime-fim. Por outro lado, também era necessário afastar a reincidência, pois, na forma do art. 63, ela só se configura quando a condenação transitada em julgado é anterior ao novo crime, o que não ocorreu na situação em análise; a condenação somente se deu no curso do processo, e não antes do crime. Com esses aspectos reconhecidos pelo Tribunal, a pena seria revista e diminuída, na nova dosimetria, possibilitando a alteração do regime inicial para aberto, conforme art. 33, § 2.º, "c", do CP. Sendo também necessário reconhecer a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, satisfeitos os requisitos do art. 44 do CP.

Peça Prático-Profissional Oficial (XVIII Exame Unificado):

Durante o carnaval do ano de 2015, no mês de fevereiro, a família de Joana resolveu viajar para comemorar o feriado, enquanto Joana, de 19 anos, decidiu ficar em sua residência, na cidade de Natal, sozinha, para colocar os estudos da faculdade em dia. Tendo conhecimento dessa situação, Caio, vizinho de Joana, nascido em 25 de março de 1994, foi até o local, entrou sorrateiramente no quarto de Joana e, mediante

grave ameaça, obrigou-a a praticar com ele conjunção carnal e outros atos libidinosos diversos, deixando o local após os fatos e exigindo que a vítima não contasse sobre o ocorrido para qualquer pessoa.

Apesar de temerosa e envergonhada, Joana contou o ocorrido para sua mãe. A seguir, as duas compareceram à Delegacia e a vítima ofertou representação. Caio, então, foi denunciado pela prática como incurso nas sanções penais do art. 213 do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do Estatuto Repressivo. Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e o réu confessou os fatos. Foi, ainda, juntado laudo de exame de conjunção carnal confirmando a prática de ato sexual violento recente com Joana e a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) do acusado, que indicava a existência de duas condenações, embora nenhuma delas com trânsito em julgado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação de Caio nos termos da denúncia, enquanto a defesa buscou apenas a aplicação da pena no mínimo legal. No dia 25 de junho de 2015, foi proferida sentença pelo juízo competente, qual seja a 1ª Vara Criminal da Comarca de Natal, condenando Caio à pena privativa de liberdade de 10 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Na sentença consta que a pena-base de cada um dos crimes deve ser aumentada em seis meses pelo fato de Caio possuir maus antecedentes, já que ostenta em sua FAC duas condenações pela prática de crimes, e mais 6 meses pelo fato de o acusado ter desrespeitado a liberdade sexual da mulher, um dos valores mais significativos da sociedade, restando a sanção penal da primeira fase em 7 anos de reclusão, para cada um dos delitos.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Afirmou o magistrado que atualmente é o réu maior de 21 anos, logo não estaria presente a atenuante do art. 65, inciso I, do CP. Ao analisar o concurso de crimes, o magistrado considerou a pena de um dos delitos, já que eram iguais, e aumentou de 1/2 (metade), na forma do art. 71 do CP, justificando o acréscimo no fato de ambos os crimes praticados serem extremamente graves. Por fim, o regime inicial para o cumprimento da pena foi o fechado, justificando que, independentemente da pena aplicada, este

seria o regime obrigatório, nos termos do art. 2.º, § 1.º, da Lei 8.072/1990. Apesar da condenação, como Caio respondeu ao processo em liberdade, o juiz concedeu a ele o direito de aguardar o trânsito em julgado da mesma forma.

Caio e sua família o(a) procuram para, na condição de advogado(a), adotar as medidas cabíveis, destacando que estão insatisfeitos com o patrono anterior. Constituído nos autos, a intimação da sentença ocorreu em 7 de julho de 2015, terça-feira, sendo quarta-feira dia útil em todo o País.

Com base nas informações supraexpostas e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redija a peça cabível, excluía a possibilidade de *Habeas Corpus*, no último dia do prazo para interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes.

Gabarito Oficial:

Peça	Apelação
Endereçamento	Peça de interposição endereçada ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN. A petição de interposição deve ser devidamente datada, contendo as expressões “assinatura” e “número da OAB”. Posteriormente, devem ser apresentadas as respectivas razões recursais, peça essa endereçada diretamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.
Fundamento Legal	Art. 593, I, do CPP
Preliminares	—
	Inicialmente, deve o advogado alegar que a conduta de Caio, no caso concreto, configura um único crime de estupro e não dois crimes em concurso. Desde 2009, com a edição da Lei 12.015, a conduta que era prevista como crime autônomo de atentado violento ao pudor passou a

Fundamentos

ser abrangida pelo tipo penal previsto no art. 213 do CP. Hoje, responde pelo crime de estupro aquele que constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso. A jurisprudência entende que, de acordo com a nova redação, o art. 213 do CP passou a prever um tipo misto alternativo. Assim, quando praticada conjunção carnal e outro ato libidinoso diverso em um mesmo contexto e contra a mesma vítima, como exatamente ocorreu no caso concreto narrado, haveria crime único. Dessa forma, deveria o advogado de Caio requerer, em suas razões, o afastamento do concurso de crimes, com o consequente reconhecimento de crime único de estupro, pois a conjunção carnal e os demais atos libidinosos foram praticados em um mesmo contexto fático. Ademais, deve o advogado requerer que seja refeita a dosimetria da pena, pois contém uma série de incorreções. Primeiramente, deve ser requerida a fixação da pena-base no mínimo legal. A fundamentação do magistrado para incrementar a pena-base pela existência de maus antecedentes foi inadequada, pois as ações penais em curso não podem justificar o reconhecimento prejudicial dessa circunstância judicial, nos termos do Enunciado 444 da Súmula de Jurisprudência do STJ, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.

O fato de existirem sentenças condenatórias não afasta o que foi aqui defendido, tendo em vista que estas não são definitivas, não ostentando trânsito em julgado. Ademais, o aumento pelo fato de o acusado ter desrespeitado a liberdade sexual da vítima também deve ser afastado,

tendo em vista que é inerente ao tipo penal.

Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Além disso, incorreto o magistrado ao afirmar que não aplicaria a atenuante da menoridade relativa pelo fato de o réu, hoje, ser maior de 21 anos. O que deve ser considerada é a data do fato, e não da sentença. Em caso de ser mantida a decisão pela existência de dois crimes de estupro em concurso, subsidiariamente deve o advogado pleitear a redução do quantum de aumento pela continuidade delitiva. Isso porque o magistrado aplicou o aumento de metade (1/2) em razão da gravidade dos delitos praticados. Ocorre que é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a fração a ser adotada pelo concurso de crimes deverá considerar o número de delitos praticados, e não outros critérios em abstrato. No caso, foram dois os crimes de estupro, no entendimento do magistrado, logo o aumento de pena pela aplicação do art. 71 do CP deveria ser de 1/6, ou seja, do mínimo legal. Por fim, sendo reduzida a pena aplicada para até 8 anos, o regime aplicado deveria ser o semiaberto. Apesar de o crime de estupro, de fato, ser hediondo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade, reiteradamente vem decidindo que é inconstitucional a imposição em abstrato de regime inicial fechado trazida pelo art. 2.º, § 1.º, da Lei 8.072/1990, devendo o magistrado justificar o regime aplicado com base em fatores concretos.

Pedidos	Diante do exposto, deve o examinando formular os seguintes pedidos: a) reconhecimento do crime único de estupro; b) aplicação da pena base no mínimo legal; c) reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa; d) em caso de manutenção da condenação pela prática de dois crimes de estupro em continuidade, redução da fração de aumento do art. 71 do CP para o mínimo legal; e) aplicação de regime semiaberto.
Autenticação	O prazo a ser indicado é o dia 13 de julho de 2015. O prazo para interposição de apelação é de 5 dias. Ocorre que o dia 12 de julho é domingo, logo o prazo é prorrogado para segunda-feira, dia 13.07.2015.
Comentários	Medalha de ouro no Exame de Ordem o recurso de apelação. Festejada, por ser bem tranquila sua identificação, já que todos nós sabemos que cabe sentença penal de 1.º grau. A curiosidade nesta peça prático-profissional é a ausência de preliminares e a de um pedido expresso de absolvição, com base no art. 386 do CPP. A própria banca fez questão de ressaltar tal incomum hipótese: "No conteúdo das Razões Recursais, não haveria necessidade de o examinando pleitear a absolvição de Caio, tendo em vista que os fatos foram provados, assim como houve confissão em juízo dos mesmos por parte do réu em seu

Peça Prático-Profissional Oficial (XXII Exame Unificado):

Desejando comprar um novo carro, Leonardo, jovem com 19 anos, decidiu praticar um crime de roubo em um estabelecimento comercial, com a intenção de subtrair o dinheiro constante do caixa. Narrou o plano criminoso para Roberto, seu vizinho, mas este se recusou a contribuir. Leonardo decidiu, então, praticar o delito sozinho. Dirigiu-se ao estabelecimento comercial, nele ingressou e, no momento em que restava apenas um cliente, simulou portar arma de fogo e o ameaçou de morte, o que fez com ele saísse, já que a intenção de Leonardo era apenas a de subtrair bens do estabelecimento. Leonardo, em seguida, consegue acesso ao caixa onde fica guardado o dinheiro, mas, antes de subtrair qualquer quantia, verifica que o único funcionário que estava trabalhando no horário era um senhor que utilizava cadeiras de rodas. Arrependido, antes mesmo de ser notada sua presença pelo funcionário, deixa o local sem nada subtrair, mas, já do lado de fora da loja, é surpreendido por policiais militares. Estes realizam a abordagem, verificam que não havia qualquer arma com Leonardo e esclarecem que Roberto narrara o plano criminoso do vizinho para a Polícia. Tomando conhecimento dos fatos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva e denunciou Leonardo como incurso nas sanções penais do art. 157, § 2.º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Após decisão do magistrado competente, qual seja, o da 1ª Vara Criminal de Belo Horizonte/MG, de conversão da prisão e recebimento da denúncia, o processo teve seu prosseguimento regular. O homem que fora ameaçado nunca foi ouvido em juízo, pois não foi localizado, e, na data dos fatos, demonstrou não ter interesse em ver Leonardo responsabilizado. Em seu interrogatório, Leonardo confirma integralmente os fatos, inclusive destacando que se arrependeu do crime que pretendia praticar. Constavam no processo a Folha de Antecedentes Criminais do acusado sem qualquer anotação e a Folha de Antecedentes Infracionais, ostentando uma representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, com decisão definitiva de procedência da ação socioeducativa. O magistrado concedeu prazo para as partes se manifestarem em alegações finais por memoriais. O Ministério Público requereu a

condenação nos termos da denúncia. O advogado de Leonardo, contudo, renunciou aos poderes, razão pela qual, de imediato, o magistrado abriu vista para a Defensoria Pública apresentar alegações finais. Em sentença, o juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal. No momento de fixar a pena-base, reconheceu a existência de maus antecedentes em razão da representação julgada procedente em face de Leonardo enquanto era inimputável, aumentando a pena em seis meses de reclusão. Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, incrementou o magistrado em 1/3 a pena, justificando ser desnecessária a apreensão de arma de fogo, bastando a simulação de porte do material diante do temor causado à vítima. Com a redução de 1/3 pela modalidade tentada, a pena final ficou acomodada em 4 (quatro) anos de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena foi o fechado, justificando o magistrado que o crime de roubo é extremamente grave e que atemoriza os cidadãos de Belo Horizonte todos os dias. Intimado, o Ministério Público apenas tomou ciência da decisão. A irmã de Leonardo o procura para, na condição de advogado, adotar as medidas cabíveis. Constituída nos autos, a intimação da sentença pela defesa ocorreu em 8 de maio de 2017, segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país.

Com base nas informações expostas acima e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redija a peça cabível, excluída a possibilidade de *habeas corpus*, no último dia do prazo para interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. (Valor: 5,00) Obs.: A peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

Gabarito Oficial:

Peça	Apelação
	Em um primeiro momento, deve ser redigida a petição de interposição do recurso, direcionada ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, requerendo o encaminhamento do feito para instância superior. A

Endereçamento	petição de interposição deve ser devidamente datada, contendo as expressões “assinatura” e “número da OAB”. Posteriormente, devem ser apresentadas as respectivas razões recursais, peça essa endereçada diretamente ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Fundamentação	Art. 593, I, do CPP
	No conteúdo das Razões Recursais, preliminarmente, deveria o advogado alegar a nulidade da sentença, devendo os atos desde a apresentação das alegações finais pela defesa serem anulados. Isso porque Leonardo tinha advogado constituído nos autos que veio a renunciar. Diante disso, deveria o magistrado intimar o réu, que estava preso, para informar se tinha interesse em constituir novo advogado ou ser assistido pela Defensoria Pública. A decisão do juiz de, de imediato, encaminhar os autos para Defensoria Pública viola o princípio da ampla defesa na vertente da defesa técnica. Certamente houve prejuízo, pois as Alegações Finais foram apresentadas sem qualquer contato do Defensor com o acusado e este foi condenado. Superada a preliminar, no mérito deve o advogado requerer a absolvição de Leonardo com fundamento na desistência voluntária. Prevê o art. 15 do Código Penal que o agente que, voluntariamente, desistir de prosseguir na execução só responde pelos atos já praticados. A desistência voluntária não se confunde com a tentativa. Nesta, o agente inicia atos de execução, mas não consuma o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Naquela, por sua vez, o agente tem

Preliminares e Mérito

possibilidade de prosseguir na empreitada criminosa, mas antes de esgotar todos os meios que tem à sua disposição, desiste voluntariamente de prosseguir e consumir o delito. A particularidade da desistência voluntária é que ela é uma chamada “ponte de ouro” de volta para legalidade, pois o agente somente responderá pelos atos já praticados e não pela tentativa do crime que pretendia cometer originariamente. No caso, claramente Leonardo poderia prosseguir na empreitada criminosa, mas optou por desistir. Iniciada a execução, teve acesso ao caixa do estabelecimento comercial contendo dinheiro, mas, ao verificar que o funcionário do local possuía dificuldades de locomoção, se arrependeu e abandonou a empreitada criminosa. Leonardo nem mesmo tinha sido visto pelo funcionário, logo poderia prosseguir. Restaria, apenas, os atos já praticados, no caso uma ameaça ao cliente que estava no local. Ocorre que o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação e como esta nunca ocorreu, não poderia Leonardo ser por este delito condenado neste momento. Diante do exposto, Leonardo deve ser absolvido do roubo que lhe foi imputado. Com base na eventualidade, em sendo mantida a condenação, deve o examinando, como advogado, requerer revisão da dosimetria da pena. Em um primeiro momento, deve requerer a aplicação da pena-base em seu mínimo legal. A existência de representação pela prática de ato infracional não justifica o reconhecimento de maus antecedentes, pois a punição de Leonardo quando inimputável não pode prejudicá-lo penalmente, gerando o aumento de sua pena. Na segunda fase, deve ser considerada a atenuante da

menoridade relativa, pois Leonardo era menor de 21 anos na data dos fatos, assim como a atenuante da confissão, nos termos dos arts. 65, inciso I e inciso III, alínea d, do CP. Na terceira fase, o advogado deve pleitear o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, tendo em vista que não há prova de sua utilização. O enunciado apenas narra que o agente simulou estar portando arma de fogo, sendo certo que a vítima nem mesmo foi ouvida e não foi apreendida qualquer arma de fogo com o mesmo. O objetivo do legislador ao prever a punição mais severa em caso de emprego de arma foi que a integridade física da vítima é colocada em maior risco. A simulação de porte de arma, contudo, não traz este incremento do risco, além de nem mesmo se adequar ao princípio da legalidade, já que não houve prova de emprego de arma de fogo, mas tão só Leonardo simulou estar armado para configurar a grave ameaça. Deve, ainda, o examinando requerer a redução máxima da tentativa, o que permitiria aplicação do sursis da pena. Por fim, deve requerer a aplicação do regime aberto ou semiaberto a depender da pena aplicada, pois a fundamentação do magistrado para aplicação do regime fechado foi insuficiente. Nos termos dos Enunciados 718 e 719 da Súmula de Jurisprudência do STF (ou 440 do STJ), a gravidade em abstrato do crime não justifica o reconhecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais severo do que aquele de acordo com a pena aplicada.

Pedidos

Por fim, deve o advogado pleitear o provimento do recurso, com consequente expedição do alvará de soltura.

Autenticação	Em relação ao prazo, deve a peça ser datada em 15 de maio de 2017, tendo em vista que o prazo para apelação é de cinco dias, mas o dia 13 de maio de 2017 é um sábado, logo o prazo é prorrogado para segunda-feira.
Comentários	Peça com maior incidência em exames, a Apelação é o recurso em seu mais alto grau de excelência e que merece ser, cuidadosamente, analisada no que diz respeito à sentença atacada, pois é ela que orienta a elaboração do recurso. Em seu gabarito oficial, não foram discriminados todos os pedidos, entretanto devemos pontuá-los um a um conforme eles vão aparecendo nas preliminares e no mérito.

Peça Prático-Profissional Oficial (XXV Exame – Reaplicação em Porto Alegre/RS):

Breno, nascido em 7 de junho de 1945, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, falsifica uma assinatura em uma folha de cheque e a apresenta em loja de eletrodomésticos localizada no bairro de sua residência, com a intenção de realizar compras no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Após a apresentação do cheque, apesar de a falsificação não ser grosseira e ser apta a enganar, o gerente do estabelecimento comercial percebe que aquele cheque não fora assinado pelo verdadeiro correntista do banco, já que o nome que constava do título de crédito era de um grande amigo seu. Descoberta a fraude, o referido gerente aciona a polícia, e Breno é preso em flagrante antes de obter a vantagem pretendida. Com o recebimento dos autos, o Ministério Público opina pela liberdade de Breno e oferece denúncia pela prática dos crimes do art. 171, caput, e art. 297, § 2.º, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Após concessão da liberdade provisória e recebimento da denúncia, houve juntada do laudo pericial do cheque, constatando a falsidade e a capacidade para iludir terceiros, bem como da Folha de Antecedentes Criminais, no qual consta uma condenação definitiva pela prática, no ano anterior, do crime de

homicídio culposo na direção de veículo automotor, além de uma ação em curso pela suposta prática de crime de furto. Durante a instrução, todos os fatos acima descritos são confirmados pelas testemunhas, não tendo sido o réu interrogado, já que, apesar de intimado, apresentou problemas de saúde no dia e não pôde comparecer à audiência. Ainda durante a audiência de instrução e julgamento, após a instrução, as partes apresentaram suas alegações, sendo consignado pela defesa o inconformismo com a ausência do réu, já que foi apresentado atestado médico, e, em seguida, o juiz proferiu sentença condenatória nos termos da denúncia, condenando o agente pela prática dos dois delitos em suas modalidades consumadas. No momento de fixar a pena-base, aumentou o magistrado a pena do estelionato em 2 meses, destacando que o comportamento de Breno não deixa qualquer dúvida de que agiu com dolo. Já a pena do uso de documento falso foi aplicada em seu patamar mínimo. Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes, mas foi reconhecida a agravante da reincidência, aumentando a pena de cada um dos delitos em mais 2 meses de reclusão. No terceiro momento, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição. Assim, foi fixada a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, no que tange ao crime de estelionato, e 2 anos e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa para o crime de falsificação de documento equiparado ao público, restando a pena final em 3 anos e 6 meses de reclusão e 26 dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena aplicado pelo magistrado foi o semiaberto e não houve substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tudo fundamentado na reincidência do agente. Intimado da decisão, o Ministério Público apenas tomou ciência de seu teor, não apresentando qualquer medida. Já a defesa técnica de Breno foi intimada de seu teor em 06 de dezembro de 2017, quarta-feira, sendo quinta-feira dia útil em todo o país. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado(a) de Breno, redija a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus e embargos de declaração, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição.

Peça	Apelação

Endereçamento	Petição de interposição acompanhada das respectivas razões recursais. A peça de interposição deveria ser direcionada para o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS, enquanto as razões recursais deveriam ser endereçadas para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A data indicada deveria ser o dia 11 de dezembro de 2017, tendo em vista o prazo de 5 dias para interposição da apelação.
Fundamentação	Art. 593, inciso I, CPP
	Em suas razões recursais, inicialmente deveria o advogado buscar o reconhecimento da nulidade dos atos praticados a partir da audiência de instrução e julgamento e da sentença, tendo em vista que o ato foi realizado na ausência do réu, que não pôde comparecer justificadamente, inclusive sendo apresentado atestado médico pela defesa técnica. Dessa forma, houve violação ao princípio da ampla defesa, em seu elemento autodefesa (direito de presença), de modo que configurado cerceamento de defesa, pois o réu não foi interrogado. Em seguida, como tese principal de mérito, deveria o examinando defender a impossibilidade de condenação do agente pela prática de dois crimes autônomos, tendo em vista que a falsificação do cheque foi apenas um meio para prática do crime de estelionato, de modo que o delito previsto no art. 297, § 2.º, do Código Penal deveria ser absorvido pelo delito do art. 171, caput, do Código Penal. Em princípio, quando um delito é praticado apenas como meio para a prática de outro delito, aquele deve ficar absorvido por este, em

**Preliminares e
Mérito**

respeito ao princípio da consunção. Trata-se de um dos princípios que soluciona o conflito aparente de normas. Uma das elementares do crime de estelionato é exatamente a fraude, a intenção de enganar. Quando a fraude é utilizada através da falsificação de um documento cuja falsidade se exaure no estelionato, o delito autônomo de falsificação ficará absorvido pelo estelionato, pois aquele foi apenas um crime meio para a prática do mesmo e o potencial lesivo do crime meio foi exaurido. Consagrando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado 17 de sua Súmula de Jurisprudência, prevendo que “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”. Na hipótese apresentada, não há dúvidas de que a intenção do agente era praticar um crime de estelionato. Ademais, o falso no caso (folha de cheque com assinatura falsificada) se exaure no estelionato, não mais tendo potencialidade lesiva, de modo que o crime do art. 297, § 2.º, do Código Penal deveria ser absorvido, restando apenas o crime de estelionato. Ressalta-se ser desnecessário encaminhamento dos autos para análise de proposta de suspensão condicional do processo, tendo em vista que o réu responde a outros processos, não preenchendo os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/1990, não havendo prejuízo, porém, caso o examinando elabore tal requerimento. Após, deveria o examinando questionar a pena aplicada em relação ao crime de estelionato, especialmente. No momento de fixar a pena base do delito, o magistrado entendeu por aumentá-la, de acordo com as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, sob o

fundamento de que o denunciado agiu com dolo. Ocorre que o delito de estelionato somente é punido em razão de comportamento doloso, não havendo previsão de punição em caso de conduta culposa, de modo que o elemento subjetivo dolo já é inerente ao tipo, não podendo o magistrado incrementar a pena sob esse fundamento. Na segunda fase, deveria ter sido reconhecida a atenuante em razão da idade do autor do fato, tendo em vista que o agente era maior de 70 anos na data da sentença, pois nascido em 7 de junho de 1945, e a sentença foi proferida no ano de 2017. Já na terceira fase, deveria ser reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa. Isso porque o crime de estelionato é delito classificado pela doutrina como de natureza material, ou seja, existe um resultado naturalístico previsto no tipo e ele precisa ocorrer para a consumação do crime. Na hipótese apresentada, Breno pretendia pagar suas compras através de cheque de terceiro, falsificando a assinatura do mesmo. Diante disso, pretendia obter vantagem patrimonial em prejuízo alheio. Todavia, quando buscava realizar, mediante fraude, compras no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), o gerente do estabelecimento descobriu o ocorrido e acionou a polícia, permitindo a prisão em flagrante de Breno e impedindo a consumação do delito. Assim, necessária a aplicação do art. 14, inciso II, do Código Penal, com redução da pena aplicada. Após a dosimetria da pena, deveria o examinando defender a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque a condenação anterior do agente, em que pese, de fato, configure reincidência,

	não impede a substituição, uma vez que o art. 44 do Código Penal apenas veda a medida para o condenado reincidente na prática de crime doloso. Na hipótese, a pena aplicada foi inferior a 4 anos e o agente apenas tinha uma condenação anterior pela prática de crime culposo, logo possível a substituição. Caso não acolhido o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo que mantida a pena aplicada em primeira instância, caberia o pedido de suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, § 2.º, do Código Penal, tendo em vista que a sanção aplicada foi inferior a 04 anos e o réu é maior de 70 anos, logo aplicável o sursis etário.
Pedidos	Em razão do exposto, deveria o examinando formular o pedido de conhecimento e provimento do recurso, com os seguintes fundamentos: a) reconhecimento de nulidade em razão da ausência do réu em audiência e não realização de interrogatório; b) afastamento do delito autônomo de falsificação de documento equiparado ao público; c) aplicação da pena base no mínimo legal, tendo em vista que o dolo é elemento inerente ao tipo penal; d) reconhecimento da atenuante pelo fato de o réu ser maior de 70 anos na data da sentença; e) reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa; f) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que a condenação anterior era por crime culposo; g) subsidiariamente, aplicação da suspensão condicional da pena.
	O prazo a ser indicado na petição de interposição da apelação era o dia 11 de dezembro de 2017, já que o

Autenticação	prazo previsto para a interposição do recurso de apelação é de 5 dias. No fechamento, deveria o examinando indicar local, data, advogado e OAB.
Comentários	Peça extremamente densa onde, mais uma vez, exigir-se-á por parte do candidato um estudo preciso da teoria da pena do Direito Penal.

Peça Prático-Profissional Inédita:⁷

Peça 11:

Hugo foi denunciado por ter, no dia 5 de junho de 2010, por volta das 23h30, em frente ao Shopping Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, desferido, com intenção de matar, disparos de arma de fogo contra Andressa, sua namorada que estava voltando da faculdade com seu amigo, Rafael Jorge. Hugo suspeitava de uma traição e por isso, sem hesitar, disparou em direção a Andressa. Rafael nada pode fazer e saiu em disparada. Os disparos foram a causa eficiente da morte da vítima, razão pela qual Hugo estaria incurso nas penas do art. 121, *caput*, do Código Penal (CP).

Após regular trâmite, sobreveio decisão de pronúncia, determinando que Hugo fosse submetido a júri popular e preso em decorrência desta decisão.

Em pronúncia, a magistrada Lílían Priscila afirmou que Hugo tinha tendência ao crime e que já tinha um histórico de perseguição em relação às suas namoradas, conforme o que foi colhido em fase probatória. Afirmou, ainda, que era chamado de louco e desequilibrado no bairro onde morava, inclusive por sua ex-namorada Vanessa Cristina, ouvida em audiência.

No dia do julgamento, terminada a inquirição das testemunhas, o promotor de justiça Josef deu início à produção da acusação. Durante sua explanação perante o conselho de sentença, com o fito de influenciar o ânimo dos julgadores quanto à conduta pretérita de Hugo, o promotor Josef mostrou aos jurados, sem a concordância da defesa, documentos relativos a outro processo, no qual o réu Hugo era acusado de crime de homicídio qualificado praticado em 02.05.2005. Salientou, ainda, o órgão

ministerial que os jurados deveriam “pensar o que quisessem” acerca da recusa, pela defesa, da produção da nova prova.

Finda a acusação, foi dada a palavra ao defensor, que pediu ao magistrado o registro, em ata, de que o promotor de justiça Josef havia mostrado aos jurados documentos relativos a outro processo a que respondia o réu, a despeito da discordância da defesa. O pleito defensivo foi deferido. Ademais, tratou a defesa das questões de mérito, bem como advertiu os jurados acerca da primariedade do réu.

Encerrada a fase instrutória em plenário, a magistrada Lílian Priscila indagou aos jurados se estavam aptos a julgar. Com a afirmativa, foram levados à Sala Secreta e elaborados os quesitos acerca do feito. Primeiramente responderam sobre a autoria do delito e em seguida sobre a existência do crime. Com o resultado, foi publicada em 5 de dezembro de 2010 a sentença do IV Tribunal do Júri. Hugo foi condenado como incurso no art. 121, § 2.º, II, do CP, à pena de 12 anos de reclusão, que deveria ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Considerando a situação hipotética descrita, formule, na condição de advogado(a) (Felipe adv. n.º 123.456) contratado(a) por Hugo, a peça – diversa de *habeas corpus* – que deve ser apresentada no processo no último dia do prazo.

8.4 APELAÇÃO SUPLETIVA

Nome	Apelação Supletiva
Artigo	Art.598 do CPP. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo.
	15 dias

Prazo	Art. 598. (...) Parágrafo único.O prazo para interposição desse recurso será de quinze dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público.
Serve para	Da sentença não impugnada pelo Ministério Público.
Observações	O assistente no processo penal tem a possibilidade de apresentar a chamada Apelação Supletiva. Vejamos o que o assistente pode fazer durante o processo penal: Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no art. 31. Art.269.O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Art.270.O corréu no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Art.271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, §1.º, e 598. § 1.º O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. § 2.º O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do

julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado.

Art.272.O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente.

Art.273. Do despacho que admitir, ou não, o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão.

Lembrando que, se o assistente ainda não tiver se habilitado como tal, teremos que colocar na redação das folhas de rosto a respectiva qualificação completa ou inserir os dados fornecidos pelo examinador.

8.4.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA
____ DO ESTADO DO _____

(linhas)

_____ (nome), qualificado nos autos do processo n.º_____, (ou qualificação completa), na qualidade de ofendido ou assistente, com base no art. 598 do CPP, por seu advogado infra-assinado, vem, com fulcro no art. 593, inc._____, do CPP, interpor recurso de

APELAÇÃO SUPLETIVA,

por entender, data venia, que a sentença de fls._____ merece ser reformada porque não espelha a realidade dos fatos.

Desde já, requer remessa dos autos ao Egrégio Tribunal _____ para conhecimento e provimento do presente recurso.

Outrossim, requer a habilitação de assistente conforme arts. 31 e 268, CPP, por estar configurado o interesse na presente causa.

N. Termos,

P. Deferimento,

Local, data

Nome e Número do Advogado (se fornecido)

EGRÉGIO TRIBUNAL _____,

COLEDA _____ CÂMARA,

EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES,

Processo n.º: _____

Apelante: _____

Apelado: _____

Origem: _____

RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO

I – Da Admissibilidade

(Informar a não interposição do recurso por parte do Ministério Público e que se encaixa na situação de ofendido ou em algum dos substitutos profissionais do art. 31 do CPP)

II – Dos Fatos

III – Das Preliminares

IV – Do Direito

V – Do Pedido

Isto posto, requer a defesa o conhecimento do presente recurso a fim de que no mérito seja a sentença reformada com _____ (motivação do recurso), nos termos do artigo _____

N. Termos,

P. Deferimento,

Local, data

Nome e Número do Advogado (se fornecido)

8.4.2 Exercícios

Peça Prático-Profissional Oficial (VII Exame Unificado):

Grávida de nove meses, Ana entra em trabalho de parto, vindo dar à luz um menino saudável, o qual é imediatamente colocado em seu colo. Ao ter o recém-nascido em suas mãos, Ana é tomada por extremo furor, bradando aos gritos que seu filho era um “monstro horrível que não saiu de mim” e bate por seguidas vezes a cabeça da criança na parede do quarto do hospital, vitimando-a fatalmente. Após ser dominada pelos funcionários do hospital, Ana é presa em flagrante delito.

Durante a fase de inquérito policial, foi realizado exame médico-legal, o qual atestou que Ana agira sob influência de estado puerperal. Posteriormente, foi denunciada, com base nas provas colhidas na fase inquisitorial, sobretudo o laudo do *expert*, perante a 1.^a Vara Criminal/Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, haja vista ter sustentado o *Parquet* que Ana fora movida por motivo fútil, empregara meio cruel para a consecução do ato criminoso, além de se utilizar de recurso que tornou impossível a defesa da vítima. Em sede de Alegações Finais Orais, o Promotor de Justiça reiterou os argumentos da denúncia, sustentando que Ana teria agido impelida por motivo fútil ao decidir matar seu filho em razão de tê-lo achado feio e teria empregado meio cruel ao bater a cabeça do bebê repetidas vezes contra a parede, além de impossibilitar a defesa da vítima, incapaz, em razão da idade, de defender-se.

A Defensoria Pública, por sua vez, alegou que a ré não teria praticado o fato e, alternativamente, se o tivesse feito, não possuiria plena capacidade de autodeterminação, sendo inimputável. Ao proferir a sentença, o magistrado competente entendeu por bem absolver sumariamente a ré em razão de inimputabilidade, pois, ao tempo da ação, não seria ela inteiramente capaz de se autodeterminar em consequência da influência do estado puerperal. Tendo sido intimado o Ministério Público da decisão, em 11 de janeiro de 2011, o prazo recursal transcorreu *in albis* sem manifestação do *Parquet*.

Em relação ao caso acima, você, na condição de advogado(a), é procurado pelo pai da vítima, em 20 de janeiro de 2011, para habilitar-se como assistente da acusação e impugnar a decisão.

Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas

pelo caso concreto acima, redija a peça cabível, sustentando, para tanto, as teses jurídicas pertinentes, datando do último dia do prazo.

Gabarito Oficial:

Peça	Apelação supletiva
Endereçamento	A petição de interposição deve ser endereçada ao Juiz de Direito da 1.^a Vara Criminal/Tribunal do Júri. Na petição de interposição da apelação, o candidato deverá requerer a habilitação do pai da criança como assistente de acusação. No tocante às razões recursais, as mesmas deverão ser dirigidas ao Tribunal de Justiça.
Fundamento Legal	Arts. 593, I, do CPP (ou art. 416 do CPP) c/c art. 598 do CPP.
Preliminares	–
Fundamentos	O examinando deve argumentar que o juiz não poderia ter absolvido sumariamente a ré em razão da inimputabilidade, porque o Código de Processo Penal, em seu art. 415, parágrafo único, veda expressamente tal providência, salvo quando for a única tese defensiva, o que não é o caso, haja vista que a defesa também apresentou outra tese, qual seja, a de negativa de autoria. Também deverá argumentar que a incidência do estado puerperal não é considerada causa excludente de culpabilidade fundada na ausência de capacidade de autodeterminação. O estado puerperal configura

	elementar do tipo de infanticídio e não causa excludente de imputabilidade/culpabilidade.
Pedidos	Do mesmo modo, deverá o examinando, em seus pedidos, requerer a reforma da decisão com o fim de se pronunciar a ré pela prática do delito de infanticídio, de modo que seja ela levada a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Autenticação	A petição de interposição deverá ser datada de 31.01.2011 ou 01.02.2011.
Comentários	Uma das questões oficiais mais infelizes já presenciadas. O principal motivo é o abismo existente em tal peça com a prática do cotidiano forense. O espanto não pode nos deixar argumentar que fora exigida a menção a habilitação de assistente mesmo com o art. 598 do CPP não exigindo. Senão vejamos com grifo nosso: “Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo”. Outra crítica se faz em relação à duplicidade de prazo. No mais, o gabarito é autoexplicativo.

8.5 RAZÕES OU CONTRARRAZÕES RECURSAIS

Nome	Razões ou Contrarrazões Recursais
	Apelação:

Artigo	Art.600 do CPP:Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias. § 1.º Se houver assistente, este arrazoará, no prazo de três dias, após o Ministério Público. § 2.º Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos, no prazo do parágrafo anterior. § 3.º Quando forem dois ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. § 4.º Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial.
Prazo	Apelação: 8 dias (art. 600 do CPP).
Serve para	Apresentar as razões ou contraditar o recurso interposto.
Observações	As razões e/ou contrarrazões podem ser apresentadas de duas formas. Num primeiro momento, ainda na primeira instância, quando o juízo de 1.º grau abre vista para as partes apresentarem respectivamente razões e contrarrazões. Tal peça tem fundamento no art. 600 CPP. Num segundo momento, com base no art. 600, § 4.º, do CPP, as razões e/ou contrarrazões podem ser apresentadas diretamente no tribunal ad quem. Vejamos

as duas possibilidades, por meio dos modelos que seguem.

8.5.1 Modelos

a) Razões e/ou Contrarrazões em 1.^a Instância

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA
____ DO ESTADO DO _____

(linhas)

_____ (nome), qualificado nos autos do processo n.º _____, por seu advogado infra-assinado, vem, com fulcro no art. 600 CPP _____, apresentar RAZÕES (ou CONTRARRAZÕES), tendo em vista o interesse já manifestado em recorrer da sentença.

Desde já, requer remessa dos autos ao Egrégio Tribunal _____ para conhecimento e provimento do presente recurso.⁸

N. Termos,

P. Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

EGRÉGIO TRIBUNAL _____,

COLENDIA _____ CÂMARA,

EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES,

Processo n.º: _____

Apelante: _____

Apelado: _____

Origem: _____

RAZÕES (ou CONTRARRAZÕES) RECURSAIS DE APELAÇÃO

I – Da Admissibilidade

II – Dos Fatos

III – Das Preliminares

IV – Do Direito

V – Do Pedido

Isto posto, requer o conhecimento e provimento das presentes razões (ou contrarrazões).

N. Termos,

P. Deferimento,

Local, data

Nome e Número do Advogado (se fornecido)

b) Razões e/ou Contrarrazões em 2ª Instância

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR DA ____ CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO _____

(linhas)

_____ (nome), qualificado nos autos do processo n.º _____, por seu advogado infra-assinado, vem, com fulcro no art. ____ do CPP, apresentar as devidas

RAZÕES DE _____,

OU CONTRARRAZÕES DE _____

com base nos fatos e fundamentos jurídicos abaixo aduzidos:

I – Dos Fatos

II – Das Preliminares

III – Do Direito

IV – Dos Pedidos

(se forem razões, o pedido será de provimento recursal)

(se forem contrarrazões, o pedido será de não conhecimento do recurso, de não provimento do recurso)

N. Termos,

P. Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

8.5.2 Exercício

Peça Prático-Profissional Oficial (XIX Exame Unificado):

No dia 24 de dezembro de 2014, na cidade do Rio de Janeiro, Rodrigo e um amigo não identificado foram para um bloco de rua que ocorria em razão do Natal, onde passaram a ingerir bebida alcoólica em comemoração ao evento festivo. Na volta para casa, ainda em companhia do amigo, já um pouco tonto em razão da quantidade de cerveja que havia bebido, subtraiu, mediante emprego de uma faca, os pertences de uma moça desconhecida que caminhava tranquilamente pela rua. A vítima era Maria, jovem de 24 anos que acabara de sair do médico e saber que estava grávida de um mês. Em razão dos fatos, Rodrigo foi denunciado pela prática de crime de roubo duplamente majorado, na forma do art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal. Durante a instrução, foi juntada a Folha de Antecedentes Criminais de Rodrigo, onde constavam anotações em relação a dois inquéritos policiais em que ele figurava como indiciado e três ações penais que respondia na condição de réu, apesar de em nenhuma delas haver sentença com trânsito em julgado. Foram, ainda, durante a Audiência de Instrução e Julgamento ouvidos a vítima e os policiais que encontraram Rodrigo, horas após o crime, na posse dos bens subtraídos. Durante seu interrogatório, Rodrigo permaneceu em silêncio. Ao final da instrução, após alegações finais, a pretensão punitiva do Estado foi julgada procedente, com Rodrigo sendo condenado a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime

semiaberto, e 13 dias-multa. O juiz aplicou a pena-base no mínimo legal, além de não reconhecer qualquer agravante ou atenuante. Na terceira fase da aplicação da pena, reconheceu as majorantes mencionadas na denúncia e realizou um aumento de 1/3 da pena imposta. O Ministério Público foi intimado da sentença em 14 de setembro de 2015, uma segunda-feira, sendo terça-feira dia útil. Inconformado, o Ministério Público apresentou recurso de apelação perante o juízo de primeira instância, acompanhado das respectivas razões recursais, no dia 30 de setembro de 2015, requerendo:

i) O aumento da pena-base, tendo em vista a existência de diversas anotações na Folha de Antecedentes Criminais do acusado;

ii) O reconhecimento das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas *h* e *l*, do Código Penal;

iii) A majoração do *quantum* de aumento em razão das causas de aumentos previstas no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, exclusivamente pelo fato de serem duas as majorantes;

iv) Fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, pois o roubo com faca tem assombrado a população do Rio de Janeiro, causando uma situação de insegurança em toda a sociedade.

A defesa não apresentou recurso. O magistrado, então, recebeu o recurso de apelação do Ministério Público e intimou, no dia 19 de outubro de 2015 (segunda-feira), sendo terça-feira dia útil em todo o País, você, advogado(a) de Rodrigo, para apresentar a medida cabível. Com base nas informações expostas na situação hipotética e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redija a peça cabível, excluindo a possibilidade de *habeas corpus*, no último dia do prazo, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes.

Gabarito Oficial:

Peça	Contrarrazões de Apelação
	Deve ser redigida a petição de juntada das contrarrazões,

Endereçamento	direcionada ao Juízo da Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, requerendo o encaminhamento do feito para instância superior. Posteriormente, devem ser apresentadas as respectivas razões do apelado (e não razões de apelação) ou contrarrazões de apelação, peça essa endereçada diretamente ao Tribunal de Justiça.
Fundamento Legal	Art. 600 do CPP
Preliminares	No conteúdo das contrarrazões, o examinando, em preliminar, deve requerer o não conhecimento do recurso apresentado pelo Ministério Público, tendo em vista ser intempestivo. Na forma do art. 593 do CPP, o prazo para interposição de apelação é de 5 dias. O Ministério Público foi intimado, no caso concreto, em 14 de setembro de 2015, somente vindo a interpor recurso no dia 30 de setembro de 2015, ou seja, mais de 15 dias após sua intimação. O enunciado deixa claro que a petição de interposição foi apresentada com as razões recursais, logo, apesar de o magistrado de 1.^a instância ter conhecido do recurso, o Tribunal, ao realizar nova análise, deverá não conhecer do recurso interposto.
	De início, em relação à pena-base, deverá ser destacado que a existência de ações penais em curso, sem sentença condenatória com trânsito em julgado, e de inquéritos policiais não justificam um aumento da pena-base, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. Antes do trânsito em julgado, não pode um acusado ou indiciado ser considerado culpado, logo não há que falar em maus antecedentes. Ademais, o Enunciado 444 da Súmula de Jurisprudência do STJ impede que ações em

curso sejam consideradas não somente como maus antecedentes, mas valoradas de qualquer forma na pena-base. Posteriormente, deverá o examinando enfrentar os argumentos apresentados pelo Ministério Público para aumento da pena na segunda fase do critério trifásico. Em relação à agravante da gravidez, deverá ser afirmado que ela não deve ser reconhecida, sob pena de configurar responsabilidade penal objetiva. Apesar de a vítima ser Maria, que tinha acabado de descobrir que estava grávida, para que uma circunstância prejudicial ao réu seja reconhecida, é preciso que ele tenha conhecimento do fato ou, ao menos, que fosse possível a ele ter conhecimento da situação. No caso concreto, Rodrigo não conhecia Maria e ela estava grávida apenas de um mês, logo não havia como o acusado ter conhecimento de que a vítima era mulher grávida. Assim, para evitar a responsabilidade penal objetiva, a agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal não deve ser aplicada. Da mesma forma, não deve ser reconhecida a agravante da embriaguez preordenada.

Fundamentos

Não existe qualquer prova nos autos de que Rodrigo se embriagou para tomar coragem para prática do crime. A embriaguez preordenada não se confunde com a culposa ou voluntária. Nos dois últimos casos, existe imputabilidade, mas não justificam, por si só, o reconhecimento da agravante. Na embriaguez preordenada o agente se embriaga exatamente para fins de reduzir sua censura pessoal e realizar um crime doloso determinado e pretendido. Rodrigo ingeriu bebida para comemorar o Natal, não para tomar coragem e praticar o

	crime de roubo. No terceiro momento, deverá o examinando rebater a pretensão do Ministério Público de incrementar o aumento da pena em razão do número de majorantes. Pacificado o entendimento atual, inclusive com a edição do Enunciado 443 da Súmula de Jurisprudência do STJ, no sentido de que a mera indicação do número de majorantes não configura fundamentação idônea para justificar a aplicação da fração de aumento acima do mínimo previsto em lei. É necessária fundamentação concreta. Por fim, em relação aos argumentos do Promotor de Justiça, deverá o examinando afirmar que o regime de pena aplicado foi adequado, não se justificando a aplicação do regime fechado pelo fundamento apresentado no recurso de apelação, pois a gravidade em abstrato do delito não pode justificar um regime de pena mais gravoso do que o cabível de acordo com a pena aplicada. Tal entendimento é trazido pelos Enunciados 718 e 719 da Súmula do STF e pelo Enunciado 440 da Súmula do STJ.
Pedidos	Assim, ao final, deverá o candidato formular os seguintes pedidos: a) Não conhecimento do recurso de apelação em razão da intempestividade; b) Caso seja conhecido o recurso, pelo seu não provimento, mantendo-se, integralmente, a sentença.
Autenticação	A data a ser indicada ao final na peça é o dia 27 de outubro de 2015. A intimação ocorreu em 19 de outubro de 2015, uma segunda-feira, iniciando-se o prazo de 8 dias, previsto no art. 600 do CPP, no dia seguinte.

Comentários

Definitivamente o enunciado mais infeliz da história recente da banca examinadora. Um enunciado confuso e que foge à realidade forense. Basta imaginar que a intempestividade do recurso de apelação do Ministério Público já seria certificado em cartório, impedindo assim seu regular trâmite.

Peça Prático-Profissional Oficial (XIX Exame Unificado):

João, 22 anos, no dia 4 de maio de 2018, caminhava com o adolescente Marcelo, cada um deles trazendo consigo uma mochila nas costas. Realizada uma abordagem por policiais, foi constatado que, no interior da mochila de cada um, havia uma certa quantidade de drogas, razão pela qual elas foram, de imediato, encaminhadas para a Delegacia. Realizado laudo de exame de material entorpecente, constatou-se que João trazia 25 g de cocaína, acondicionados em 35 pinos plásticos, enquanto, na mochila do adolescente, foram encontrados 30 g de cocaína, quantidade essa distribuída em 50 pinos. Após a oitiva das testemunhas em sede policial, da juntada do laudo e da oitiva do adolescente e de João, que permaneceram em silêncio com relação aos fatos, foram lavrados o auto de prisão em flagrante em desfavor do imputável e o auto de apreensão em desfavor do adolescente. Toda a documentação foi encaminhada aos Promotores de Justiça com atribuição. O Promotor de Justiça, junto à 1.^a Vara Criminal de Maceió/AL, órgão competente, ofereceu denúncia em face de João, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos com a causa de aumento do art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006. Foi concedida a liberdade provisória ao denunciado, aplicando-se as medidas cautelares alternativas. Após a notificação, a apresentação de resposta prévia e o recebimento da denúncia e da citação, foi designada a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação. Estas confirmaram a apreensão de drogas em poder de Marcelo e João, bem como que eles estariam juntos, esclarecendo que não se conheciam anteriormente e nem tinham informações pretéritas sobre o adolescente e o denunciado. O adolescente, ouvido, disse que conhecera João no dia anterior ao

de sua apreensão e que nunca o tinha visto antes vendendo drogas. Em seguida à oitiva das testemunhas de acusação e defesa, foi realizado o interrogatório do acusado, sendo que nenhuma das partes questionou o momento em que este foi realizado. Na ocasião, João confirmou que o material que ele e Marcelo traziam seria destinado à ilícita comercialização. Ele ainda esclareceu que conhecera o adolescente no dia anterior, que era a primeira vez que venderia drogas e que tinha a intenção de praticar o ato junto com o adolescente somente aquela vez, com o objetivo de conseguir dinheiro para comprar uma moto. Foi acostado o laudo de exame definitivo de material entorpecente confirmando o laudo preliminar e a Folha de Antecedentes Criminais de João, onde constava uma anotação referente a crime de furto, ainda pendente de julgamento. O juiz, após a devida manifestação das partes, proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. Em um primeiro momento, absolveu o acusado do crime de associação para o tráfico por insuficiência probatória. Em seguida, condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, ressaltando que o réu confirmou a destinação das drogas à ilícita comercialização. No momento de aplicar a pena, fixou a pena-base no mínimo legal, reconhecendo a existência da atenuante da confissão espontânea; aumentou a pena em razão da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 e aplicou a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, restando a pena final em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 195 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. Entendeu o magistrado pela substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O Ministério Público, ao ser intimado pessoalmente em 22 de outubro de 2018, apresentou o recurso cabível, em 25 de outubro de 2018, acompanhado das respectivas razões recursais, requerendo: a) nulidade da instrução, porque o interrogatório não foi o primeiro ato, como prevê a Lei 11.343/2006; b) condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico, já que ele estaria agindo em comunhão de ações e desígnios com o adolescente no momento da prisão, e o art. 35 da Lei 11.343/2006 fala em “reiteradamente ou não”; c) aumento da pena-base em relação ao crime de tráfico diante das consequências graves que vem causando para a saúde pública e a sociedade brasileira; d) afastamento da atenuante da confissão, já que ela teria sido parcial; e) afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da

Lei 11.343/2006, independentemente da condenação pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, considerando que o réu seria portador de maus antecedentes, já que responde a ação penal em que se imputa a prática do crime de furto; f) aplicação do regime inicial fechado, diante da natureza hedionda do delito de tráfico; g) afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da vedação legal do art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006. Já o acusado e a defesa técnica, intimados do teor da sentença, mantiveram-se inertes, não demonstrando interesse em questioná-la. O magistrado, então, recebeu o recurso do Ministério Público e intimou, no dia 5 de novembro de 2018 (segunda-feira), sendo terça-feira dia útil em todo o país, você, advogado(a) de João, a apresentar a medida cabível. Com base nas informações expostas na situação hipotética e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redija a peça cabível, excluídas as possibilidades de habeas corpus e embargos de declaração, no último dia do prazo, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes.

Peça	Contrarrazões de Apelação
Endereçamento	Em um primeiro momento, deve ser redigida a petição de juntada das contrarrazões, direcionada ao Juízo da 1. ^a Vara Criminal da Comarca de Maceió/Alagoas, juízo competente, requerendo o encaminhamento do feito para instância superior. Posteriormente, devem ser apresentadas as respectivas razões do apelado (e não razões de apelação) ou contrarrazões de apelação, peça essa endereçada diretamente ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.
Fundamentação	Art. 600, CPP
	Não haveria que se falar na interposição de recurso de apelação, tendo em vista que consta expressamente a informação de que tanto a defesa técnica quanto o

acusado foram intimados, se mantiveram inertes e não manifestaram interesse em confrontar o teor da sentença. Nas Contrarrazões de Apelação, caberia ao examinando rebater todas as teses apresentadas pelo Ministério Público em busca de prejudicar a situação do réu. Inicialmente, caberia ao examinando destacar que não haveria que se falar em nulidade da instrução e, consequentemente, da sentença. Em que pese, de fato, o art. 57 da Lei 11.343/2006 preveja o interrogatório como primeiro ato da instrução, a realização do mesmo como último ato da audiência de instrução e julgamento não gera nulidade. Importante recordar que a Lei 11.343/2006, que previu o procedimento dos crimes previstos neste diploma legal, foi publicada em 2006, período em que o próprio Código de Processo Penal ainda previa o interrogatório como primeiro ato da instrução. Em 2008, todavia, houve mudança do procedimento previsto no Código de Processo Penal, que, valorizando o fato de que o interrogatório poderia ser visto não somente como meio de prova, mas também como instrumento de defesa, passou a prever sua realização como último ato, após oitiva das testemunhas e produção das demais provas. Diante disso, atualmente a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem defendendo a adequação do rito da Lei 11.343/2006 àquele previsto no Código de Processo Penal, possibilitando a realização do interrogatório como último ato, no interesse da defesa. Não haveria, então, nulidade. Ademais, todo requerimento de nulidade depende da demonstração de prejuízo e da alegação em momento oportuno. No caso, em momento algum o Ministério Público questionou ou requereu que o

Preliminares e Mérito

interrogatório fosse realizado como primeiro ato, logo não poderia agora, em sede de apelação, buscar a nulidade da instrução. Quanto aos pedidos de mérito do Ministério Público, caberia ao examinando defender a manutenção da absolvição de João em relação ao crime de associação para o tráfico. Em que pese o art. 35 da Lei 11.343/2006 afirme que haveria associação quando duas ou mais pessoas associarem-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, crimes previstos na lei, pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o crime de associação não se confunde com a prática de tráfico por dois agentes em comunhão de ações e desígnios. É necessário, para a condenação, que fique demonstrada a existência de uma conduta permanente por parte dos agentes, ainda que esses efetivamente só venham a praticar um crime de tráfico. No caso, os policiais disseram que não conheciam João e nem Marcelo, destacando que não tinham informações pretéritas sobre o vínculo deles com o tráfico de drogas. Da mesma forma, tanto João quanto Marcelo também asseguraram que se conheceram no dia anterior ao da prisão em flagrante, não havendo relação de estabilidade e permanência. Dessa forma, deve ser mantida a absolvição. Em relação ao crime de tráfico, deveria o examinando combater o requerimento de aplicação da pena base acima do mínimo, já que os argumentos do Ministério Público são abstratos, não se valendo de peculiaridades da hipótese. Ademais, argumentar em violação à saúde pública representa bis in idem, já que este já é o bem jurídico protegido pela norma. No tocante à atenuante da confissão, incorreto o requerimento do

órgão ministerial. Durante muito tempo houve controvérsia sobre o reconhecimento ou não da confissão parcial ou qualificada como atenuante. Pacificando a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 545, prevendo que sempre que a confissão for valorada pelo magistrado na sentença, deverá ser reconhecida a redução da pena em razão da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do CP. Na situação apresentada, o juiz valorizou o fato de que o réu disse que o material seria destinado à ilícita comercialização, logo a atenuante deve ser mantida. Deveria, ainda, o candidato enfrentar o pedido de afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006. Quis a lei beneficiar com a figura do “tráfico privilegiado” o “traficante de primeira viagem”, aquele que não se dedica ao crime de tráfico de drogas, exigindo, ainda, a primariedade e bons antecedentes, além de não integrar organização criminosa. No caso, não há informações sobre o envolvimento pretérito de João com o tráfico de drogas, seja a partir das informações dos policiais seja das declarações do adolescente e do próprio denunciado. O fato de responder a ação penal por crime de furto, sem condenação definitiva, não justifica o reconhecimento de maus antecedentes, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade. Poderia ser aplicada, por analogia, a Súmula 444 do STJ, que diz que ações em curso não podem justificar o incremento da pena base em razão de supostos maus antecedentes. Em consequência, deveria ser mantido o regime aberto aplicado, não somente diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o crime do art. 33, § 4.º, da Lei

	11.343/2006 não seria de natureza hedionda, mas também porque, mesmo que fosse hediondo, a previsão do art. 2.º, § 1.º, da Lei 8.072, é inconstitucional por violação ao princípio da individualização da pena. Por fim, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que, também sob o fundamento de violação ao princípio da individualização da pena, o STF considerou inconstitucional a vedação trazida pelo art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, inclusive havendo a Resolução 05 do Senado suspenso a eficácia de tal expressão.
Pedidos	Assim, ao final, deveria o candidato formular o pedido de não provimento do recurso, mantendo-se, integralmente, a sentença.
Autenticação	A data a ser indicada ao final na peça é o dia 13 de novembro de 2018. A intimação ocorreu em 5 de novembro de 2018, uma segunda-feira, iniciando-se o prazo de 8 dias, previsto no art. 600 do CPP, no dia seguinte.
Comentários	Para identificar essa peça a linha do tempo após a sentença continua, com a apresentação de razões da parte adversa, ainda em primeiro grau, abertura de vista e a consequente apresentação de contrarrazões de apelação. A leitura do art. 600 do CPP é fundamental, inclusive para se verificar a contagem de prazo em oito dias. No mais, deve-se rebater, ponto a ponto, as razões apresentadas pela outra parte.

8.6 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nome	Embargos de Declaração
Artigo	Art. 382 do CPP: Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Art. 619 do CPP: Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Art. 83 da Lei 9.099/1995: Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. (Alteração dada pela Lei 13.105/2015.) § 1.º Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. § 2.º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. (Redação dada pela Lei 13.105, de 2015.) § 3.º Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.
Prazo	2 dias (arts. 382 e 619 do CPP) 5 dias (art. 83 da Lei 9.099/1995)
Serve para	Sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão de sentença penal ou acórdão.

Observações

Único recurso em que não precisamos nos preocupar com a elaboração de uma folha de rosto e uma folha de razões, já que é recurso interposto ao mesmo julgador que proferiu a decisão ambígua ou contraditória etc.

8.6.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR _____ CRIMINAL DO ESTADO

_____ (nome), já amplamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, onde figura como condenado,⁹ por seu advogado, instrumento procuratório anexo, inscrito regularmente na Ordem dos Advogados do Brasil, sob o n.º_____, vem, com fundamento nos arts. 619 e 620¹⁰ do CPP, à presença de Vossa Excelência, dentro do prazo legal opor os presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

para dirimir os questionamentos seguintes:

I – Dos Fatos

(...)

→ Apontar a omissão ou ambiguidade ou contradição ou obscuridade. Se for JECRIM, apontar dúvida ou contradição ou obscuridade ou omissão.

II – Do Direito

(...)

→ tese e justificativa. Neste caso específico, a tese é sanar o vício e explicitar o gravame que este vem causando.

III – Do Pedido

Isto posto, demonstrado _____ (motivação do recurso), espera que os embargos sejam recebidos e julgados procedentes.

N. Termos,

P. Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

8.6.2 Exercício¹¹

Peça Prático-Profissional Inédita:

Peça 12:

Ciro, famoso comerciante no interior de Minas Gerais, fora acusado pelo crime de receptação (art. 180 do CP), roubo (art. 157 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). Segundo o Ministério Público, *Ciro* rouba cargas em outros Estados e as revende, além de frequentemente comprar equipamentos eletrônicos roubados.

Durante a instrução, o Ministério Público consegue provar a receptação com as provas testemunhal e documental, todavia não consegue demonstrar os crimes de roubo e associação criminosa. Em alegações finais, o membro do *Parquet* reitera seus argumentos e pede a condenação nos três crimes. Já a defesa apresenta argumentos sólidos e consistentes, além de pedidos subsidiários, tais como eventual condenação exclusiva na receptação e o deferimento da suspensão condicional do processo, segundo o art. 89 da Lei 9.099/1995.

O juiz da 18.^a Vara Criminal profere sentença em 14 de junho de 2013, condenando e abordando apenas que *Ciro* fora condenado a pena mínima de 1 (um) ano.

Somente com os fatos narrados acima, interponha a medida mais célere, no último dia do prazo, exclusiva de advogado, para o caso.

8.7 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE

Nome	Embargos Infringentes e de Nulidade
	Art. 609 do CPP. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária.
	Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de

Artigo	segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art.613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.
Prazo	10 dias (art. 609, parágrafo único, do CPP)
Serve para	Demonstrar o inconformismo de acórdão não unânime.
Observações	Trata-se do único recurso privativo da defesa hoje no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista a revogação do Protesto por Novo Júri. Recurso impetrado no mesmo tribunal que proferiu o acórdão com o intuito de que o voto vencido, num reexame, prevaleça sobre os demais votos. Assim, somente pode ser interposto por decisões por maioria, que não sejam unâimes. Indaga-se a respeito de ser um recurso único ou dois recursos distintos, o infringente e o de nulidade. Majoritariamente entende-se que é um recurso único cuja terminologia mais adequada é mesmo de Embargos Infringentes e de Nulidade.

8.7.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR DA ____ CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO _____

(linhas)

_____ (nome), qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, não se conformando, data venia, com o respeitável acórdão, publicado em _____, que _____ (motivo), com fundamento no artigo _____, opor

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE,

tempestivamente, ao Tribunal competente, pelos fatos e fundamentos ora anexados.

N. Termos,

P. Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

RAZÕES DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE

Embargante: _____

Embargado: _____

Processo n.º: _____

Origem: _____

Egrégio Tribunal,

Colenda _____

Excelentíssimos Senhores Desembargadores,

Impõe-se a reforma do acórdão _____ (teor do acórdão) proferido pela ____
Turma, por _____ (especificar o motivo do inconformismo), pelas razões que se
seguem:

I – Dos Fatos

II – Das Preliminares

III – Do Direito

IV – Dos Pedidos

Isto posto, demonstrado _____ (motivação do recurso), requer-se seja o presente
recurso conhecido e provido, para tornar sem efeito a decisão que _____ (objeto da
decisão).

N. Termos,

P. Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

8.7.2 Exercício¹²

Peça Prático-Profissional Inédita:

Peça 13:

Isabel foi condenada a pena de dois anos de reclusão e multa pela prática do crime previsto no art. 171, § 3.º, do Código Penal, porque teria recebido, fraudulentamente, benefício previdenciário, no valor de R\$ 25.000,00, em prejuízo do INSS.

A sentença determinou o cumprimento da pena em regime aberto, negando expressamente a sua substituição por pena restritiva de direitos. O apelo interposto pela defesa de Isabel teve provimento negado pela 1.ª Turma do Tribunal por decisão não unânime. Restou vencido o voto do desembargador Soares que acolhia a preliminar de nulidade da sentença pela ausência de exame pericial no documento utilizado e no mérito, reformava a sentença condenatória para absolver Isabel por insuficiência de provas para a condenação.

Redija a peça processual adequada à situação descrita, invocando todos os fundamentos jurídicos pertinentes.

8.8 RECURSO ESPECIAL

Nome	Recurso Especial
	Art. 105 da CF. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) III – julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

Artigo	a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 2004) c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Art. 1.029 NCPC: O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
Prazo	Art. 1.003 NCPC: O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 5.º Excetuada os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Serve para	Reforma de Acórdão que contrarie tratado ou lei federal, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
	O Recurso Especial é um recurso interposto no próprio tribunal que proferiu o acórdão, com as razões direcionadas ao Superior Tribunal de Justiça. Por ser um recurso dirigido a Tribunal Superior, seu juízo de

Observações

admissibilidade tende a ser mais rigoroso. Neste diapasão reside a necessidade de demonstrarmos o prequestionamento, configurada como a demonstração de que a matéria já fora analisada nas instâncias inferiores, ou seja, já tivemos uma manifestação jurisdicional a respeito da decisão atacada.

8.8.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO¹³ _____

(linhas)

_____ (nome), já qualificado nos autos do processo-crime n.º _____ (se fornecido), vem, respeitosamente, por seu advogado infra-assinado, não se conformando com o acórdão de fls. _____, que _____ (teor do acórdão), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea _____ (verificar no caso apresentado), da Constituição Federal, combinado com o art. 1.029 do NCPC, interpor

RECURSO ESPECIAL

ao colendo Superior Tribunal de Justiça.

Termos em que, requerendo seja ordenado o processamento do recurso, ora interposto, com as anexas razões, pede deferimento.

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL

Origem:

Processo n.º:

Recorrente:

Recorrido:

Colendo STJ,

Douta Turma,

Excelentíssimos Ministros,

Impõe-se a reforma do acórdão _____ (teor do acórdão) proferido pela ____ Turma, por _____ (especificar o motivo do inconformismo), pelas razões que se seguem:

I – Da Admissibilidade do Recurso ou Do Prequestionamento

(...)

DISSÍDIO, se for fornecida pelo examinador tal informação.

(...)

II – Dos Fatos

(...)

III – Do Direito

(...)

IV – Do Pedido

Isto posto, demonstrado _____ (motivação do recurso), requer-se seja o presente recurso conhecido e provido, para tornar sem efeito a decisão que _____ (objeto da decisão).

N. Termos,

P. Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

8.8.2 Exercício¹⁴

Peça Prático-Profissional Inédita:

Peça 14:

Jaílton é um famoso empresário do ramo alimentício, mas entende que para conseguir sobreviver no mercado empresarial e demasiadamente concorrido não deve declarar tudo que ganha, pois assim o imposto recolhido o impede de sobreviver e aferir lucros. Todavia, aquele sentimento de impunidade que desfrutava acaba. É

aberto um procedimento fiscal pela Receita Federal e constatado o desencontro de informações em sua declaração de imposto de renda. Todas as informações colhidas são enviadas ao Ministério Público e mesmo assim Jaílton acha, comentando com os amigos, “que não vai dar em nada e nesse país ninguém é preso por isso”.

O membro do *parquet* formaliza a denúncia e Jaílton é denunciado pelo crime do art. 1.º, inciso I, da Lei 8.137/1990: “Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;”

Ainda despreocupado, Jaílton trabalha como se nada tivesse acontecido, contrata um advogado qualquer e o inevitável acontece. É condenado em primeira instância. Com a condenação, Jaílton começa a se preocupar e vê os documentos da empresa começarem a ficar com pendências administrativas e fiscais. Resolve então propor um pagamento integral da dívida que já chega em R\$ 300.000,00. Apresenta o pedido e um recurso de apelação. Durante o trâmite no tribunal, apresenta recibo de quitação integral dos débitos, todavia sua condenação por unanimidade é confirmada em 2.ª instância, que não reconhece o pagamento feito após o recebimento da denúncia.

Jaílton destitui o antigo patrono e contrata você, advogado especialista na área penal tributária, para adotar a medida jurídica pertinente ao caso.

8.9 RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Nome	Recurso Extraordinário
	Art. 102 da CF. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

Artigo

- a) contrariar dispositivo desta Constituição;
 - b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
 - c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição;
 - d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (Incluída pela Emenda Constitucional 45, de 2004)
- (...)

§ 3.º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. (Incluída pela Emenda Constitucional 45, de 2004)

Art. 1.029 NCPC: O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...)

Art. 1.003 NCPC: O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5.º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15

Prazo	(quinze) dias. I – exposição do fato e do direito; II – a demonstração do cabimento do recurso interposto; III – as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Parágrafo único. Quando o recurso se fundar em dissídio entre a interpretação da lei federal adotada pelo julgado recorrido e a que lhe haja dado outro Tribunal, o recorrente fará a prova da divergência mediante certidão, ou indicação do número e da página do jornal oficial, ou do repertório autorizado de jurisprudência, que o houver publicado.
Serve para	Reforma de Acórdão que contrarie dispositivo da Constituição, declare a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgue válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição e que julgue válida lei local contestada em face de lei federal.

8.9.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO _____¹⁵

(linhas)

_____ (nome), já qualificado nos autos do processo-crime n.º _____ (se fornecido) em epígrafe, vem por seu advogado infra-assinado, não se conformando com o acórdão de fls. _____, que _____ (teor do acórdão), com fundamento nos artigos 102, inciso III, alínea _____ (verificar no caso apresentado), da Constituição Federal, combinado com o art. 1.029, do NCPC,

RECURSO EXTRAORDINÁRIO,

ao Supremo Tribunal Federal.

Termos em que, requerendo seja ordenado o processamento do recurso, ora interposto, com as anexas razões, pede deferimento.

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Origem: _____

Recorrente: _____

Recorrido: _____

Processo n.º: _____

Colendo STF,

Douta Turma,

Excelentíssimos Ministros,

Impõe-se a reforma do acórdão _____ (teor do acórdão) proferido pela ____ Turma, por _____ (especificar o inconformismo), pelas razões que se seguem:

I – Da Admissibilidade do Recurso ou Do Prequestionamento

(...)

II – Da Repercussão Geral – art. 102, § 3.º, da CF

(...)

DISSÍDIO, se for fornecida pelo examinador tal informação.

(...)

III – Dos Fatos

(...)

IV – Do Direito

(...)

V – Do Pedido

Isto posto, demonstrado _____ (motivação do recurso), requer-se seja o presente recurso conhecido e provido, para tornar sem efeito a decisão que _____ (objeto da decisão).

N. Termos,
P. Deferimento,
Município, data
Advogado
Inscrição n.º

8.9.2 Exercício¹⁶

Peça Prático-Profissional Inédita:

Peça 15:

Eduarda é condenada à pena de 30 anos pelo crime bárbaro de extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2.º, do CP). Seu histórico de violência, sua reincidência e maus comportamentos carcerários anteriores levaram o magistrado a condená-la à pena máxima e em regime integralmente fechado por se tratar de crime hediondo segundo a Lei 8.072/1990.

A condenação é confirmada de forma unânime pelo tribunal de 2.º Grau, todavia, pela omissão em relação ao regime de cumprimento de pena, são apresentados embargos de declaração. Colocados os embargos em mesa, confirma-se o cumprimento de regime de pena em regime integralmente fechado a ser cumprido em estabelecimento de segurança máxima no interior do Paraná. Suspeita-se, ainda, que Eduarda chefia uma organização criminosa internacional.

Com a situação apresentada, interponha medida jurídica cabível à espécie, privativa de advogado.

8.10 CARTA TESTEMUNHÁVEL

Nome	Carta Testemunhável
Artigo	Art.639 do CPP. Dar-se-á carta testemunhável: I – da decisão que denegar o recurso;

	II – da que, admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo ad quem.
Prazo	48 horas
Serve para	Decisão que denegar recurso e, embora admitido, obste seu seguimento.
Observações	Recurso de difícil interposição, de carácter residual e dirigido ao escrivão ou secretário do tribunal.

8.10.1 Modelo

ILUSTRÍSSIMO SENHOR ESCRIVÃO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA ____ DO ESTADO ____

_____ (nome + qualificação completa), vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento no art. 639 do Código de Processo Penal, requerer, em face do despacho que lhe denegou o recurso de _____, extração da presente

CARTA TESTEMUNHÁVEL,

arrolando as seguintes peças anexas para traslado.

N. Termos,

P. Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

RAZÕES DA CARTA TESTEMUNHÁVEL

Origem: _____

Recorrente: _____

Recorrido: _____

Processo n.º: _____

Excelentíssimos Desembargadores,

A decisão do juízo a quo indeferindo recurso não pode subsistir pelos seguintes fatos e fundamentos jurídicos.

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido

Diante do exposto, foi requerida a presente carta testemunhável, a fim de que esse Egrégio Tribunal determine o processamento do recurso, ou, salvo melhor juízo, julgue o mérito, com base no art. 644 do Código de Processo Penal.

N. Termos,

P. Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

8.11 AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nome	Agravo em Execução
Artigo	Art. 197 da Lei 7.210/1984: Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
Prazo	5 dias Súmula 700 do STF: É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.
	Impugnar decisões interlocutórias durante a Execução Penal.

Serve para

Art. 66 da Lei 7.210/1984: Compete ao Juiz da execução:

I – aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

II – declarar extinta a punibilidade;

III – decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

d) suspensão condicional da pena;

e) livramento condicional;

f) incidentes da execução.

IV – autorizar saídas temporárias;

V – determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;

e) a revogação da medida de segurança;

	f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1.º, do artigo 86, desta Lei. VI – zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; VII – inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; VIII – interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei; IX – compor e instalar o Conselho da Comunidade; X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir. (Incluído pela Lei 10.713, de 13.8.2003)
Observações	Recurso que segue a mesma forma procedimental do Recurso em Sentido Estrito para onde remetemos o leitor. Lembrando acerca da particularidade do juízo de retratação, nos moldes do art. 589 do CPP.

8.11.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA ____ VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA

COMARCA _____ DO ESTADO _____

(linhas)

_____ (nome), já qualificado nos autos do processo-crime n.º _____ (se fornecido), vem por seu advogado infra-assinado, à presença de Vossa Excelência, não se conformando com a r. decisão de fls. _____, que _____ (descrever o teor da decisão), com fundamento no art. 66, inciso _____ c/c art. 197 da Lei 7.210/1984, interpor

AGRAVO EM EXECUÇÃO,

pelos fatos e fundamentos jurídicos que se seguem nas anexas razões:

Isto posto, se porventura Vossa Excelência entenda que deva manter a decisão, requer o recorrente que este recurso seja remetido ao Tribunal competente, nos moldes do art. 589 do CPP.

Termos em que, requerendo seja ordenado o processamento do presente recurso, com as anexas razões, pede deferimento.

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

RAZÕES DE AGRAVO EM EXECUÇÃO

Agravante: _____

Agravado: _____

Origem: _____

Processo n.º: _____

Egrégio Tribunal,

Colenda _____

Excelentíssimos Senhores Desembargadores,

No caso em tela, onde _____ (transcrição da decisão), é necessária a reforma da decisão, conseqüentemente vem dela agravar, esperando que ao final seja reformada pelas razões ora expostas:

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido

Ante o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso, para tornar sem efeito a decisão impugnada.

Nestes Termos,

Pede Deferimento,

Local, data

Nome e Número do Advogado (se fornecido)

8.11.2 Exercícios¹⁷

Peça Prático-Profissional Oficial (XVI Exame Unificado):

Gilberto, quando primário, apesar de portador de maus antecedentes, praticou um crime de roubo simples, pois, quando tinha 20 anos de idade, subtraiu de Renata, mediante grave ameaça, um aparelho celular. Apesar de o crime restar consumado, o telefone celular foi recuperado pela vítima. Os fatos foram praticados em 12 de dezembro de 2011. Por tal conduta, foi Gilberto denunciado e condenado como incurso nas sanções penais do art. 157, *caput*, do Código Penal a uma pena privativa de liberdade de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado e 12 dias-multa, tendo a sentença transitado em julgado para ambas as partes em 11 de setembro de 2013. Gilberto havia respondido ao processo em liberdade, mas, desde o dia 15 de setembro de 2013, vem cumprindo a sanção penal que lhe foi aplicada regularmente, inclusive obtendo progressão de regime. Nunca foi punido pela prática de falta grave e preenchia os requisitos subjetivos para obtenção dos benefícios da execução penal.

No dia 25 de fevereiro de 2015, você, advogado(a) de Gilberto, formulou pedido de obtenção de livramento condicional junto ao Juízo da Vara de Execução Penal da comarca do Rio de Janeiro/RJ, órgão efetivamente competente. O pedido, contudo, foi indeferido, apesar de, em tese, os requisitos subjetivos estarem preenchidos, sob os seguintes argumentos: a) o crime de roubo é crime hediondo, não tendo sido cumpridos, até o momento do requerimento, 2/3 da pena privativa de liberdade; b) ainda que não fosse hediondo, não estariam preenchidos os requisitos objetivos para o benefício, tendo em vista que Gilberto, por ser portador de maus antecedentes,

deveria cumprir metade da pena imposta para obtenção do livramento condicional; c) indispensabilidade da realização de exame criminológico, tendo em vista que os crimes de roubo, de maneira abstrata, são extremamente graves e causam severos prejuízos para a sociedade. Você, advogado(a) de Gilberto, foi intimado dessa decisão em 23 de março de 2015, uma segunda-feira.

Com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redija a peça cabível, excluía a possibilidade de *habeas corpus*, no último dia do prazo para sua interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. (Valor: 5,00)

Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

Gabarito Oficial:

Peça	Agravo em Execução
Endereçamento	Petição de interposição, direcionada ao Juiz da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, acompanhada das respectivas Razões, estas endereçadas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, órgão competente para o julgamento do recurso.
Fundamento Legal	Art. 197 da Lei 7.210/1984 Pedido de Retratação na folha de interposição nos moldes do art. 589 CPP. Quanto ao prazo, a Súmula 700 do STF determina que será de 5 dias.
Preliminares	—
	Em um primeiro momento, deveria ser destacado que o crime de roubo simples não é hediondo, tendo em vista

Fundamentos

que não está previsto no rol trazido pelo art. 1.º da Lei 8.072/1990. Assim, não há que se falar em cumprimento de 2/3 da pena para concessão do benefício previsto no art. 83 do Código Penal.

Posteriormente, deveria ser rebatido o fundamento apresentado pelo magistrado, no sentido de que Gilberto deveria cumprir metade da pena privativa de liberdade aplicada, pois seria portador de maus antecedentes. Isso porque o princípio da legalidade afasta qualquer conclusão nesse sentido.

O princípio da legalidade, previsto no texto constitucional em matéria penal, tem como um de seus subprincípios a vedação da aplicação da analogia prejudicial ao réu em matéria penal. O art. 83 do Código Penal prevê que apenas o condenado reincidente na prática do crime doloso tem que cumprir mais de metade da pena aplicada para fazer jus ao livramento condicional. Apesar de o art. 83, inciso I, do Código Penal falar em cumprimento de 1/3 da pena pelo condenado não reincidente e portador de bons antecedentes, deve essa fração ser também aplicada caso o acusado seja portador de maus antecedentes, além de não reincidente. Houve uma omissão do legislador ao não prever o requisito objetivo para concessão do livramento condicional para o condenado primário, mas portador de maus antecedentes. Diante da omissão, deve ser aplicado o percentual que seja mais favorável ao acusado, pois não cabe analogia in malam partem. Diante do exposto, a jurisprudência pacificou o entendimento de que o condenado não reincidente, ainda que portador de maus antecedentes,

	deverá observar o requisito objetivo para o livramento condicional após cumprimento de 1/3 da pena. Por fim, também inadequado o argumento do juiz pela indispensabilidade da realização do exame criminológico. Desde a Lei 10.792/2003 que não existe mais obrigatoriedade da realização de exame criminológico para fins de obtenção da progressão de regime ou do livramento condicional. Basta, para o livramento, que seja atestado comportamento satisfatório durante a execução da pena. Apesar disso, nada impede que, no caso concreto, entenda o magistrado pela necessidade de sua realização. Contudo, deverá a decisão que o determina ser fundamentada nas particularidades da hipótese concreta, não sendo suficiente a simples afirmação da gravidade em abstrato do delito, na forma da Súmula 439 do STJ. No caso, não houve fundamentação idônea, pois simplesmente foi mencionado que o crime de roubo é grave. Além do fato de o delito ser de roubo simples, Gilberto nunca foi punido pela prática de falta grave dentro do estabelecimento prisional, de modo que desnecessária a realização do exame.
Pedidos	Por todas as razões anteriormente expostas, na conclusão, deveria o candidato formular pedido de concessão do livramento condicional em favor de Gilberto, eis que, quando do recurso, já preenchia todos os requisitos.
Autenticação	30 de março de 2015
	Excelente enunciado elaborado pelo examinador sobre

Comentários

execução penal. Inicialmente, vale observar que, apesar da legislação processual mencionar no art. 581 XII CPP a possibilidade de recurso em sentido estrito para a decisão de negatória de livramento condicional, desde 1984, com o surgimento da Lei de Execução Penal, o recurso cabível é o Agravo em Execução.

As decisões interlocutórias passíveis de Agravo em Execução podem ser encontradas no art. 66 da LEP, artigo que o examinador não exigiu em seu gabarito oficial, que poderia ser perfeitamente inserido na peça prática.

Peça Prático-Profissional Oficial (XXIV Exame Unificado):

Lucas, 22 anos, foi denunciado e condenado, definitivamente, pela prática de crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, sendo, em razão das circunstâncias do crime, aplicada a pena de seis anos de reclusão em regime inicial semiaberto, entendendo o juiz de conhecimento que o crime não seria hediondo, não tendo sido reconhecida a presença de qualquer agravante ou atenuante.

No mês seguinte, após o início do cumprimento da pena, Lucas vem a sofrer nova condenação definitiva, dessa vez pela prática de crime de ameaça anterior ao de associação, sendo-lhe aplicada exclusivamente a pena de multa, razão pela qual não foi determinada a regressão de regime.

Após cumprir um ano da pena aplicada pelo crime de associação, o defensor público que defende os interesses de Lucas apresenta requerimento de progressão de regime, destacando que o apenado não sofreu qualquer sanção disciplinar.

O magistrado em atuação perante a Vara de Execução Penal da Comarca de Belo Horizonte/MG, órgão competente, indefere o pedido de progressão, sob os seguintes fundamentos:

- a) o crime de associação para o tráfico, no entender do magistrado, é crime*

hediondo, tanto que o livramento condicional somente poderá ser deferido após o cumprimento de 2/3 da pena aplicada;

- b) o apenado é reincidente, diante da nova condenação pela prática de crime e ameaça;*
- c) o requisito objetivo para a progressão de regime seria o cumprimento de 3/5 da pena aplicada e, caso ele não fosse reincidente, seria de 2/5, períodos esses ainda não ultrapassados;*
- d) em relação ao requisito subjetivo, é indispensável a realização de exame criminológico, diante da gravidade dos crimes de associação para o tráfico em geral.*

Ao tomar conhecimento, de maneira informal, da decisão do magistrado, a família de Lucas procura você, na condição de advogado(a), para a adoção das medidas cabíveis. Após constituição nos autos, a defesa técnica é intimada da decisão de indeferimento do pedido de progressão de regime em 24 de novembro de 2017, sexta-feira, sendo certo que, de segunda a sexta-feira da semana seguinte, todos os dias são úteis em todo o território nacional.

Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado(a) de Lucas, redija a peça jurídica cabível, diferente de *habeas corpus* e embargos de declaração, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes.

A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição. **(Valor: 5,00)**

Obs.: A peça processual deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

Gabarito Oficial:

Peça	Agravo em Execução
	Petição de interposição, direcionada ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belo Horizonte/MG. Em

Endereçamento	caso de não acolhimento, deve haver requerimento de encaminhamento do feito para instância superior, com as respectivas razões recursais. Após, o examinando deveria apresentar Razões do Recurso, direcionadas ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com a fundamentação necessária para rebater a decisão do magistrado de primeira instância.
Fundamento Legal	Art. 197 da Lei 7.210/1984 Pedido de Retratação na folha de interposição nos moldes do art. 589 CPP. Quanto ao prazo, a Súmula 700 do STF determina que será de cinco dias.
Preliminares	–
	Lucas foi condenado pela prática de crime de associação para o tráfico, delito este previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, à pena de seis anos de reclusão em regime inicial semiaberto, destacando o magistrado do conhecimento que o delito não teria natureza hedionda. Após cumprimento de 1/6 da pena, não havendo notícia de não atendimento aos requisitos subjetivos, já que não sofreu qualquer sanção disciplinar, faria jus o apenado à progressão para o regime aberto. O advogado de Lucas deveria combater todos os fundamentos apresentados pelo magistrado para indeferir o requerimento de progressão de regime. A priori deveria ser destacado que o delito praticado por

Fundamentos

Lucas não tem natureza de crime hediondo. Em que pese a Constituição e a Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) tenham equiparado o crime de tráfico, tortura e terrorismo aos crimes hediondos, o mesmo não o fez em relação ao delito de associação para o tráfico. Da mesma forma, o rol de delitos de natureza hedionda trazido pelo art. 1.º da Lei 8.072/1990 não menciona o crime de associação para o tráfico. Exatamente em razão disso a jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, não considera o delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 como de natureza hedionda ou equiparado. Ademais, o próprio juízo de conhecimento havia decidido que o delito não teria natureza hedionda.

Conforme vem sendo destacado pela jurisprudência, o simples fato de o art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006 exigir para a concessão do livramento condicional o cumprimento de mais de 2/3 da pena não tem o condão de transformar o crime de associação para o tráfico em hediondo, de modo que o livramento exige o cumprimento de 2/3 da pena, enquanto que para progressão de regime basta o cumprimento de 1/6 da pena aplicada.

Além disso, não há que se falar em reincidência na hipótese, tendo em vista que a condenação pela prática do crime de ameaça ocorreu após o trânsito em julgado da decisão que condenou Lucas pela prática do crime de associação para o tráfico. De acordo com o art. 63 do Código Penal, configura-se a reincidência quando o agente vem a ser condenado pela prática de crime cometido após condenação anterior, com trânsito em

julgado, pela prática de delito pretérito. Assim, não há que se falar em reincidência na hipótese.

Exatamente em razão da natureza não hedionda do crime e da ausência de reincidência, o requisito objetivo para Lucas fazer jus à progressão de regime é o cumprimento de 1/6 da pena, período esse já atendido pelo apenado, que cumpriu em regime semiaberto mais de um ano de uma sanção penal de seis anos.

Por fim, deveria o examinando rebater o argumento do magistrado em relação ao requisito subjetivo, que, segundo a decisão questionada, exigiria a realização de exame criminológico. Desde a Lei 10.792/2003 que não mais existe obrigatoriedade da realização de exame criminológico para obtenção de progressão de regime, bastando o atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Certo é que não existe vedação à requisição de realização de exame criminológico para análise de eventual progressão de regime ou livramento condicional. Todavia, a justificativa para tal requerimento deverá ser embasada em fundamentos sólidos de acordo com o caso concreto, não bastando a mera alegação da gravidade em abstrato do delito. Assim, a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo não foi idônea, nos termos do Enunciado 439 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF).

Pedidos

Na conclusão, deveria o examinando apresentar pedido de conhecimento e provimento do recurso, com requerimento de progressão de regime.

Peça Prático Profissional (XXIX Exame)

Guilherme foi condenado definitivamente pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, sendo aplicada a pena de seis anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão das circunstâncias do fato. Após cumprir um ano da pena aplicada, Guilherme foi beneficiado com progressão para o regime semiaberto. Na unidade penitenciária, o apenado trabalhava internamente em busca da remição. Durante o cumprimento da pena nesse regime, veio a ser encontrado escondido em seu colchão um aparelho de telefonia celular. O diretor do estabelecimento penitenciário, ao tomar conhecimento dos fatos por meio dos agentes penitenciários, de imediato reconheceu na ficha do preso a prática de falta grave, apenas afirmando que a conduta narrada pelos agentes, e que teria sido praticada por Guilherme, se adequava ao art. 50, inciso VII, da Lei 7.210/1984. O reconhecimento da falta pelo diretor foi comunicado ao Ministério Público, que apresentou promoção ao juízo da Vara de Execuções Penais de São Paulo, juízo esse competente, requerendo a perda de benefícios da execução por parte do apenado. O juiz competente, analisando o requerimento do Ministério Público, decidiu que, “considerando a falta grave reconhecida pelo diretor da unidade, impõe-se: a) a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado; b) perda da totalidade dos dias remidos; c) reinício da contagem do prazo de livramento condicional; d) reinício da contagem do prazo do indulto”. Ao ser intimado do teor da decisão, em 9 de julho de 2019, terça-feira, Guilherme entra em contato, de imediato, com seu advogado, esclarecendo que nunca fora ouvido sobre a aplicação da falta grave, apenas tendo conhecimento que a Defensoria se manifestou no processo de execução após o requerimento do Ministério Público. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado(a) de Guilherme, redija a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus e embargos de declaração, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição, considerando que, em todos os locais do país, de segunda a sexta-feira são dias úteis.

Peça	Agravo em Execução
Endereçamento	Apesar de o art. 197 da LEP trazer a previsão de que o recurso cabível é o de agravo, não estabelece a Lei 7.210/1984 qual seria o procedimento a ser seguido, de modo que a doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que seria o mesmo do recurso em sentido estrito. Diante disso, primeiramente deveria o examinando apresentar petição de interposição, direcionada ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de São Paulo/SP, com formulação de pedido de retratação por parte do juízo a quo, na forma do art. 589 do CPP, por analogia. Em caso de não acolhimento, deveria haver requerimento de encaminhamento do feito para instância superior, com as respectivas razões recursais. Após, o examinando deveria apresentar razões do recurso, direcionadas ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a fundamentação necessária para rebater a decisão do magistrado de primeira instância.
Fundamento Legal	Art. 197 da Lei 7.210/1984
Preliminares	Inicialmente, deveria o examinando destacar que o reconhecimento da falta grave não observou as formalidades legais. Nos termos do art. 50 da Lei 7.210/1984, realmente como mencionado pelo diretor do estabelecimento penitenciário, a conduta de esconder celular configura prática de falta grave. Todavia, para assegurar o direito ao exercício do princípio da ampla defesa e do princípio do contraditório, pacificou a jurisprudência o entendimento de que o reconhecimento de falta grave depende de regular procedimento

administrativo disciplinar, devidamente assegurado o acompanhamento de defesa técnica. Nesse sentido é o teor da Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça. Na situação apresentada, o diretor do estabelecimento reconheceu a prática de falta grave sem observar as exigências antes mencionadas, ou seja, sem instaurar procedimento administrativo e sem garantir o direito de defesa. Dessa forma, não pode aquele reconhecimento ser considerado pelo juízo da execução.

Fundamentos

Não sendo válido o reconhecimento da prática de falta grave, sequer seria possível a regressão do cumprimento da pena para o regime fechado, apesar de, abstratamente, essa ser uma sanção possível na hipótese de reconhecimento válido de falta grave, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP da e Súmula 534 do STJ. Superada a invalidade no reconhecimento da falta grave, deveria o examinando destacar que, ainda que o reconhecimento da falta grave fosse considerado válido, impossível seria a sanção de perda da integralidade dos dias remidos. O art. 127 da LEP admite que a punição por falta grave gere perda dos dias remidos. Todavia, o mesmo dispositivo assegura um limite de perda de até 1/3, sendo incorreta a decisão do magistrado que determina a perda de TODOS os dias remidos. Da mesma forma, incorreta a decisão que determinou o reinício da contagem do prazo para fins de obtenção de livramento condicional e indulto. A explicação é simples: em que pese muitos defendam que o ideal seria o reinício da contagem desses prazos, fato é que a execução penal está sujeita ao princípio da legalidade, sendo certo que

	tais sanções não estão previstas na lei. Diante da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impor o reinício da contagem do prazo do livramento condicional, nos termos da Súmula 441 do STJ. Pelas mesmas razões, foi editada a Súmula 535 do STJ, prevendo que a prática de falta grave não interrompe o prazo para fins de comutação de pena ou indulto, sem prejuízo de esta ser considerada no momento de analisar o preenchimento dos requisitos subjetivos deste benefício.
Pedidos	Na conclusão, após o mérito, deveria o examinando apresentar pedido de conhecimento e provimento do recurso, afastando-se o reconhecimento da falta grave e suas consequências.
Autenticação	Em relação ao prazo, absolutamente pacificado o entendimento de que seria de 5 dias, na forma do Enunciado 700 da Súmula de Jurisprudência do STF. Considerando que a intimação ocorreu em 9 de julho de 2019, terça-feira, o prazo se iniciou em 10 de julho de 2019, quarta-feira, encerrando-se em 15 de julho de 2019, porque 14 de julho de 2019 seria domingo. O examinando deve, ainda, concluir sua peça, indicando local, data, advogado e número de OAB.
Comentários	Peça extremamente fácil de identificar, apesar de hipótese inédita de decisão proveniente de pedido do Ministério Público. Lembramos que o agravo em execução cabe de decisão interlocutória do juiz da VEP, independente de quem tenha feito o pedido gerador da decisão. No mais, a peça se tornou de fácil elaboração, pois no

enunciado está limitado o que deve ser abordado na peça.

Peça Prático-Profissional Inédita:

Peça 16:

Percival, brasileiro, casado, pintor, atualmente preso na Penitenciária de Segurança Máxima de Bangu – Rio de Janeiro, foi condenado, pelo juiz da 1.^a Vara Criminal, a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso III, por ter cometido tal crime numa operação cinematográfica que rendeu vigilantes e carros-fortes.

Progrediu de regime, mas ainda não faz jus ao regime aberto.

Percival, que já cumpriu quase a totalidade da pena, tem profissão e está trabalhando na construção civil, com carteira assinada. Ficou noivo recentemente e espera o mais rápido possível constituir uma família. Com toda essa nova situação que se apresenta, constitui você, como advogado, para apresentar o pedido de livramento condicional ao juízo competente.

Surpreendentemente, o magistrado indefere tal pedido visto que no relatório carcerário Percival anos atrás fora pego com um telefone celular em sua cela. Na época não fora demonstrado exatamente de quem era o aparelho, restando dúvida sobre todos os companheiros de cela.

Desconsiderando o bom comportamento carcerário e a única condenação de Percival, o juiz mantém o indeferimento.

Interponha a peça processual cabível ao caso, diversa de *habeas corpus*.

8.12 REVISÃO CRIMINAL

Nome	Revisão Criminal
	Art. 621 do CPP. A revisão dos processos findos será admitida:

Artigo	I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
Prazo	Sem prazo. Art. 622: A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.
Serve para	Reconhecimento de erros judiciários.
	Ao lado do Habeas Corpus, a Revisão Criminal é a outra ação autônoma de impugnação. Trata-se de meio de impugnação privativo da defesa que somente poderá ser ajuizada após o trânsito em julgado da decisão e em processos findos. Em relação à competência desta ação, devemos ficar atentos não só ao art. 624 do CPP, como também a alguns artigos constitucionais. Senão vejamos: Art. 102 da CF: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente:

Observações

(...)

j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;

Art. 105 da CF: Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

(...)

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

Art. 624 do CPP: As revisões criminais serão processadas e julgadas:

I – pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas;

II – pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.

§ 1.º No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno.

§ 2.º Nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno.

§ 3.º Nos tribunais onde houver quatro ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos dois ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno.

8.12.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR _____ DO EGRÉGIO

(linhas)

_____ (nome + qualificação completa), vem por seu advogado abaixo assinado, com procuração anexa, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 621, inciso _____, do Diploma Processual Penal, requerer

REVISÃO CRIMINAL,

nos feitos do processo-crime n.º _____ que motivou a sentença, já transitada em julgado, prolatada pelo _____, pelos motivos abaixo alinhados:

I – Dos Fatos

(...)

→ narração dos motivos que ensejaram a presente ação autônoma.

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido

Diante do exposto, requer desse Egrégio Tribunal de Justiça anular o processo *ex tunc*, reconhecer o erro judiciário cometido, para futuro ingresso de justa indenização.

Termos em que,

Pede Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

8.12.2 Exercícios

Peça Prático-Profissional Oficial (X Exame Unificado):

Jane, no dia 18 de outubro de 2010, na cidade de Cuiabá – MT, subtraiu veículo automotor de propriedade de Gabriela. Tal subtração ocorreu no momento em que a

vítima saltou do carro para buscar um pertence que havia esquecido em casa, deixando-o aberto e com a chave na ignição. Jane, ao ver tal situação, aproveitou-se e subtraiu o bem, com o intuito de revendê-lo no Paraguai. Imediatamente, a vítima chamou a polícia e esta empreendeu perseguição ininterrupta, tendo prendido Jane em flagrante somente no dia seguinte, exatamente quando esta tentava cruzar a fronteira para negociar a venda do bem, que estava guardado em local não revelado.

Em 30 de outubro de 2010, a denúncia foi recebida. No curso do processo, as testemunhas arroladas afirmaram que a ré estava, realmente, negociando a venda do bem no país vizinho e que havia um comprador, terceiro de boa-fé arrolado como testemunha, o qual, em suas declarações, ratificou os fatos. Também ficou apurado que Jane possuía maus antecedentes e reincidente específica nesse tipo de crime, bem como que Gabriela havia morrido no dia seguinte à subtração, vítima de enfarte sofrido logo após os fatos, já que o veículo era essencial à sua subsistência. A ré confessou o crime em seu interrogatório.

Ao cabo da instrução criminal, a ré foi condenada a cinco anos de reclusão no regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo sido levados em consideração a confissão, a reincidência específica, os maus antecedentes e as consequências do crime, quais sejam, a morte da vítima e os danos decorrentes da subtração de bem essencial à sua subsistência.

A condenação transitou definitivamente em julgado, e a ré iniciou o cumprimento da pena em 10 de novembro de 2012. No dia 5 de março de 2013, você, já na condição de advogado(a) de Jane, recebe em seu escritório a mãe de Jane, acompanhada de Gabriel, único parente vivo da vítima, que se identificou como filho desta.

Ele informou que, no dia 27 de outubro de 2010, Jane, acolhendo os conselhos maternos, lhe telefonou, indicando o local onde o veículo estava escondido. O filho da vítima, nunca mencionado no processo, informou que no mesmo dia do telefonema foi ao local e pegou o veículo de volta, sem nenhum embaraço, bem como que tal veículo estava em seu poder desde então.

Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas

pelo caso concreto acima, redija a peça cabível, excluindo a possibilidade de impetração de *habeas corpus*, sustentando, para tanto, as teses jurídicas pertinentes.

Gabarito Oficial:

Peça	Revisão Criminal
Endereçamento	Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Fundamento Legal	Art. 621, III, CPP com aceitação do inciso I
Preliminares	–
Fundamentos	Deverá argumentar que, após a sentença, foi descoberta causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 16 do Código Penal, qual seja, arrependimento posterior. O agente, anteriormente ao recebimento da denúncia, por ato voluntário, restituiu a res furtiva, sendo certo que tal restituição foi integral e que, portanto, faz jus ao máximo de diminuição. Assim, deverá pleitear, com base no art. 626 do Código de Processo Penal, a modificação da pena imposta, para que seja considerada referida causa de diminuição de pena. Além disso, o fato novo comprova que o veículo não chegou a ser transportado para o exterior, não tendo se iniciado qualquer ato de execução referente à qualificadora prevista no § 5.º do art. 155 do Código Penal. Por isso, cabível a desclassificação do furto qualificado para o furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). Como consequência da aplicação da causa especial de

	diminuição de pena prevista no art. 16 do CP e da desclassificação do delito, o examinando deverá desenvolver raciocínio no sentido de que, em que pese a reincidência da revisionanda, o STJ tem entendimento sumulado no sentido de que poderá haver atribuição do regime semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade (Verbete 269 da Súmula do STJ). Além disso, o fato de a revisionanda ter reparado o dano de forma voluntária prepondera sobre os maus antecedentes e demonstra que as circunstâncias pessoais lhe são favoráveis. Por isso, a fixação do regime fechado se mostra medida desproporcional e infundada, devendo ser abrandado o regime para o semiaberto, com base no Verbetes 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Pedidos	Ao final, o examinando deverá elaborar, com base no art. 626 do CPP, os seguintes pedidos: i. a desclassificação da conduta, de furto qualificado para furto simples; ii. a diminuição da pena da pena privativa de liberdade; iii. a fixação do regime semiaberto (ou a mudança para referido regime) para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Autenticação	Padrão
	Peça altamente criticada por todos aqueles que fizeram esse exame. A primeira crítica diz respeito à confusão geográfica do enunciado, em que a narrativa é confusa e de certa forma equivocada. Superando esse obstáculo inicial, devemos tomar cuidado com a identificação da peça, pois o simples fato de o enunciado abordar a fase

Comentários

de execução penal não nos dá a possibilidade de elaboração de agravo em execução (art. 197 da Lei 7.210/1984). Lembramos que tal recurso só é possível com a existência de uma decisão interlocutória durante a execução, com disposição no art. 66 da Lei 7.210/1984, algo que não existe no caso em tela.

Sobre a competência da Revisão Criminal, a análise do art. 624 CPP se faz necessária incidindo o inciso II do presente artigo para a correta elaboração do endereçamento.

Outrossim, as críticas a esse exame não param por aqui. No mérito, exigir do candidato a tese da desclassificação é, no mínimo, inusitada por ser um pedido não viável na revisão criminal. Além disso, a tese da desclassificação tinha que ser adivinhada pelo candidato, pois o examinador não informou a modalidade de furto (simples ou qualificado) em que Jane foi incurso e também não dizia onde o carro foi devolvido, o que tornava mais difícil constatar a desclassificação. Mas era isso que a banca queria; o candidato, a partir da pena de 5 anos fixada na sentença, deveria imaginar que o crime imputado era o do art. 155, § 5.º, devendo ser solicitada a desclassificação, pois, se o carro foi devolvido é porque não saiu do Estado onde houve o furto.

Justamente por isso deveria também requerer a aplicação do arrependimento posterior, na forma do art. 16, pois a agente voluntariamente restituiu a coisa, atendidos os demais requisitos do art. 16. Consequentemente, fixar o regime semiaberto, pois em condenações abaixo de 4

anos, mesmo que reincidente o condenado, é possível fixá-lo na forma do Enunciado 269 da Súmula do STJ.

Peça Prático-Profissional Inédita:¹⁸

Peça 17:

Roberto nunca teve uma vida fácil. Abandonado pelos pais, se viu sem saída a não ser optar pela vida criminosa. Hábil e rápido, invadia casas nos bairros ricos de várias cidades e começou a conquistar fama, fato este que levava a polícia a procurá-lo desenfreadamente.

Preso, processado e condenado pelo crime de furto qualificado, Roberto é condenado em 10 anos. Depois de cumprida a pena em regime integralmente fechado, o processo transita em julgado e só depois de esperar 1 ano de burocracia, finalmente Roberto é colocado em liberdade.

Já reabilitado e com emprego fixo, 3 anos após, em conversa com você, advogado, sabe que teria um mecanismo capaz de reconhecer as não concessões de benefícios durante a execução da pena, além do tempo de 1 ano que ficou esperando para ser solto.

Isto posto, adote medida jurídica, exclusiva dos possuidores de capacidade postulatória, em favor de Roberto.

8.13 HABEAS CORPUS

Nome	Habeas Corpus
Artigo	Art. 5.º, LXVIII, da CF: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; Art.647 do CPP: Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência

	ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.
Prazo	–
Serve para	Proteção à liberdade.
	Ação Autônoma de Impugnação, Remédio Jurídico Constitucional que serve para proteger o bem jurídico mais importante, a liberdade. Evidentemente que o habeas corpus não é somente utilizado na fase procedimental, de investigação, ou seja, apesar de estar sendo visto neste momento, fica a ressalva de que ele pode ser impetrado a qualquer momento e em qualquer fase procedimental ou processual. Cabe liminar, não precisa ser advogado para impetrar e sua competência se dá em razão da proveniência da coação. Se de um delegado, HC na 1.^a instância, se um juiz, HC na 2.^a instância. Segue essa linha de competência e, portanto, de endereçamento. Uma boa orientação na feitura do habeas corpus pode ser vista seguindo o art. 654 do Diploma Processual Penal: Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 1.º A petição de habeas corpus conterá: a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a

Observações

violência, coação ou ameaça;

b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor;

c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.

§ 2.º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

Em relação à dúvida existente em impetrar ou não o remédio constitucional nos momentos das respectivas contracautelas vistas supra, poderíamos tecer vantagens e desvantagens concomitantes. Usemos o exemplo de uma prisão ilegal, mas podendo ser também uma prisão em flagrante legal ou até mesmo uma preventiva. Em todos esses casos cabe HC, todavia a celeridade das contracautelas é bem maior, configurando uma vantagem, tendo em vista que o HC deve ser impetrado no Tribunal, tendo, logicamente, um desgaste temporal maior. E muitas das vezes o tempo é fundamental. Por outro lado, o HC se configura uma vantagem pelo fato de serem outros julgadores que irão analisar a medida. Como vimos, as contracautelas são apresentadas aos magistrados de 1.ª instância, muitas vezes não voltando atrás de uma decretação prisional. Assim, o HC se torna eficaz por termos uma maior chance de reversão da medida.

	No momento do exame, é bom o candidato se certificar de que o enunciado impede a impetração do habeas corpus, pois em muitos editais somente são exigidas peças privativas de advogado, excluindo, assim, a possibilidade de redigirmos HC.
Modalidades	Habeas corpus preventivo Art.660 do CPP:Efetuada as diligências, e interrogado o paciente, o juiz decidirá, fundamentadamente, dentro de 24 (vinte e quatro) horas. (...) §4.º Se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz. Habeas corpus propriamente dito Art.654 do CPP:O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Habeas corpus de ofício Art.654 do CPP:O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. (...) §2.ºOs juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de

processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

8.13.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR _____ DA _____

(linhas)

_____ (impetrante + qualificação completa) vem, respeitosamente, com base no art. 5.º, LXVIII, da Constituição Federal, impetrar o presente

HABEAS CORPUS,

com pedido de liminar, em favor de _____ nome paciente, identificável pelo agente coator, o _____, que em exercício _____ (descrição do ato realizado), sendo este ato ilegal e abusivo pelas seguintes razões:

A – Dos Fatos

(...)

B – Do Direito

→ Seguem abaixo alguns modelos de início de parágrafos:

Não assiste razão, porém, ao julgador, ora autoridade coatora, ao indeferir o pedido, uma vez que _____ (artigos legais) determinam o contrário.

C – Da Liminar

→ tese do cabimento de liminar¹⁹

D – Do Direito

(...)

E – Do Pedido

Diante do exposto, vem requerer que, depois de solicitadas as informações à autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada, para _____ (descrever o ato).^{20 21}

Termos em que

Pede Deferimento.

Município, data

Advogado

8.13.2 Exercício²²

Peça Prático-Profissional Inédita:

Peça 18:

Júlio, famoso lobista em Brasília, dono de construtora, é convocado para se apresentar no mês seguinte à famosa Comissão Parlamentar de Inquérito (art. 58, § 3.º, da CF) para apurar supostos desvios públicos federais da área da saúde. Estão sendo investigados nesta CPI alguns senadores da República, deputados federais e governadores. A mídia noticia o fato fervorosamente e Júlio teme sofrer represálias e ataques à sua liberdade individual durante seu depoimento.

Com base nos fatos narrados, você, advogado, é contratado pelo famoso construtor a adotar a medida cabível para que se protejam todas as garantias fundamentais da testemunha Júlio.

¹ SÚMULA N.º 192, STJ: Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual.

² Trata-se do pedido padrão. Todavia, conforme o enunciado da questão, é interessante colocarmos o real motivo do recurso, ou seja, qual seria seu objetivo.

³ Confira o gabarito ao final da obra.

⁴ Outra forma de se colocar este final: “porque é contrária a prova dos autos”.

⁵ Este final é utilizado quando da assinatura do termo de apelação descrito no art. 600 do CPP.

⁶ Exemplo: “A sentença de fls.____ merece ser reformada por encontrar-se, totalmente, divorciada das provas dos autos, em que pese o brilho e a competência de seu prolator”.

⁷ Confira o gabarito ao final da obra.

⁸ Este final é utilizado quando da assinatura do termo de apelação descrito no art. 600 do CPP.

⁹ Verificar tal condição. Na dúvida, não coloque!

¹⁰ Artigos utilizados para embargos de declaração em face de acórdão. Se for caso de sentença penal, o dispositivo legal será o art. 382 do CPP.

¹¹ Confira o gabarito ao final da obra.

¹² Confira o gabarito ao final da obra.

¹³ Outro exemplo: “... Desembargador Federal do Egrégio Tribunal Regional Federal da ____ Região”.

¹⁴ Confira o gabarito ao final da obra.

¹⁵ Fiquemos atentos se for competência da Justiça Federal, caso em que o Tribunal será o Regional Federal.

¹⁶ Confira o gabarito ao final da obra.

¹⁷ Confira o gabarito ao final da obra.

¹⁸ Gabarito ao final da obra.

¹⁹ Assim assevera o professor Hélio Tornaghi: “Conquanto a lei não se refira à concessão de liminar em processo de *habeas corpus*, alguns acórdãos vão insinuando essa medida em nossa vida judiciária. Necessidades de ordem prática e semelhança com o Mandado de Segurança, em que a providência aparece como medida acautelatória, servem de base a essa prática”.

²⁰ Exemplo: “... para revogar o despacho a fim de conceder a liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura em seu favor”.

²¹ Se for HC preventivo, requerer a expedição de salvo-conduto.

²² Confira o gabarito ao final da obra.

PEÇAS DA FASE DE EXECUÇÃO

Neste capítulo, serão vistas tão somente as peças referentes a pedidos feitos durante a execução penal, já que o recurso de Agravo em Execução se encontra no capítulo referente aos recursos.

9.1 LIVRAMENTO CONDICIONAL

Nome	Livramento Condicional
Artigo	Art. 83, CP, c/c art. 66, III, e c/c art. 131, Lei 7.210/1984
Prazo	—
Serve para	Pleitear o benefício do livramento condicional durante a execução penal
Observações	Acerca do tema, verificar nesta obra, no capítulo Direito Penal, os comentários feitos acerca do livramento condicional

9.1.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA DE EXECUÇÃO PENAL
DA COMARCA _____ DO ESTADO _____

(linhas)

_____ (qualificação completa), vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento nos arts.83 CP c/c art. 66 III e c/c art. 131 da Lei 7.210/1984, requerer pedido de

LIVRAMENTO CONDICIONAL

tendo em vista a possibilidade de concessão conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e

subjetivos que serão expostos abaixo, conforme fatos e fundamentos jurídicos:

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido

Isto posto, requer:

A concessão do livramento condicional com a consequente expedição do alvará de soltura.

Termos em que,

Pede Deferimento,

Local, data

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

9.2 PROGRESSÃO DE REGIME

Nome	Progressão de Regime
Artigo	Art. 66, III, “b”, c/c art. 112 da Lei 7.210/1984
Prazo	–
Serve para	Possibilitar a execução da pena em regime mais favorável
Observações	Acerca do tema, verificar nesta obra, no capítulo Direito Penal, os comentários feitos sobre a teoria da pena

9.2.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA DE EXECUÇÃO PENAL

DA COMARCA _____ DO ESTADO _____

(linhas)

_____ (qualificação completa), vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento nos arts. 66, III, “b”, c/c art. 112 da Lei 7.210/1984, requerer pedido de

PROGRESSÃO DE REGIME

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos:

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido

Isto posto, requer:

A progressão do regime _____ para o _____ conforme demonstrado.

Termos em que,

Pede Deferimento,

Local, data

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

9.3 REMIÇÃO DA PENA

Nome	Remição da Pena
Artigo	Art. 66, III, “c”, c/c art. 126 da Lei 7.210/1984
Prazo	–
Serve para	Remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena

Observações

Súmula 341 STJ: A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Mais comentários no capítulo Direito Penal desta obra

9.3.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA DE EXECUÇÃO PENAL
DA COMARCA _____ DO ESTADO _____

(linhas)

_____ (qualificação completa), vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento nos arts.66 III c c/c Art. 126 da Lei 7.210/84, requerer pedido de

REMIÇÃO DA PENA

tendo em vista _____(trabalho e/ou estudo) demonstrado abaixo nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos:

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido

Isto posto, requer:

A remição da pena em respeito aos mandamentos legais.

Termos em que,

Pede Deferimento,

Local, data

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

9.4 DETRAÇÃO DA PENA

Nome	Detração da Pena
Artigo	Art. 66, III, "c", da Lei 7.210/1984, c/c art. 42, CP
Prazo	–
Serve para	Abater o tempo de prisão cautelar, aquela durante a investigação e/ou processo criminal do tempo de condenação
Observações	Assunto trabalhado no capítulo Direito Penal

9.4.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA DE EXECUÇÃO PENAL
DA COMARCA _____ DO ESTADO _____

(linhas)

_____ (qualificação completa), vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento no art. 66, III, "c", da Lei 7.210/1984, c/c art. 42, CP, requerer pedido de

DETRAÇÃO PENAL

tendo em vista _____ (trabalho e/ou estudo) demonstrado nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos:

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido

Isto posto, requer:

A detração da pena em respeito aos mandamentos legais.

Termos em que,

Pede Deferimento,

Local, data

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

9.5 PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Nome	Pedido de Extinção da Punibilidade
Artigo	Art. 66, II, da Lei 7.210/1984, c/c art. 107____, CP
Prazo	–
Serve para	Pleitear a extinção da punibilidade, com a consequente perda do Estado no direito de punir
Observações	Assunto trabalhado no capítulo Direito Penal

9.5.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA DE EXECUÇÃO PENAL
DA COMARCA _____ DO ESTADO _____

(linhas)

_____ (qualificação completa), vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento
no art. 66, II, da Lei 7.210/1984, c/c art. 107____, CP, requerer pedido de

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

pela _____ (causa da extinção) pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos:

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido

Isto posto, requer:

A extinção da punibilidade pela_____, conforme art._____

Termos em que,

Pede Deferimento,

Local, data

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

PEÇAS DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

A partir deste capítulo iniciaremos a pesquisa e demonstração de algumas peças específicas referentes aos procedimentos especiais. Evidentemente, serão colocadas apenas peças que se diferem das já vistas anteriormente de forma completa e substancial.

10.1 QUEIXA-CRIME (AÇÃO PENAL PRIVADA) NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

Nome	Queixa-Crime
	Art. 77 da Lei 9.099/1995: Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. (...) § 3.º Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao Juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do art. 66 desta Lei. Art. 78 da Lei 9.099/1995: Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente

Artigo	cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados. Art.41 do CPP.A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Art.44 do CPP.A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.
Prazo	6 meses a contar do conhecimento da autoria Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.
Serve para	Inaugurar a persecução criminal processual nos casos de crimes de menor potencial ofensivo
	Segundo a Lei 9.099/1995, alterada pela Lei 11.313/2006, crime de menor potencial ofensivo é definido legalmente:

Observações

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei 11.313, de 2006)

O procedimento a ser seguido é o sumaríssimo:

Art. 394 do CPP. O procedimento será comum ou especial. (Redação dada pela Lei 11.719, de 2008)

§ 1.º O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo: (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

(...)

III – sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

Assim, quando o crime for de menor potencial ofensivo, a ação penal deverá ser dirigida ao Juizado Especial Criminal. Vale lembrar que, dependendo das regras de competência, o feito pode ser deslocado para um foro constitucionalmente especial ou mais abrangente.

10.1.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO ____ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
DA COMARCA _____ DO ESTADO _____

(linhas)

_____ (nome + qualificação completa), vem por seu advogado infra-assinado, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 41 e 44 do Código de Processo Penal, combinados com o art. 100, § 2.º, do Código Penal, oferecer a presente

QUEIXA-CRIME

em face de _____ (qualificação do acusado) pelos motivos a seguir aduzidos:

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido

Diante do exposto, tendo o acusado (ou querelado) infringido o(s) art. (s) _____ da Lei Penal Brasileira, requer a Vossa Excelência que, seguindo o procedimento da Lei 9.099/1995, seja recebida esta queixa-crime, seja o mesmo citado para audiência de instrução e julgamento, processado e ao final condenado criminalmente.

Requer ainda a notificação das testemunhas abaixo arroladas.

Termos em que,

Pede Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

ROL DE TESTEMUNHAS:

10.2 APELAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

Nome	Apelação
	Art. 82 da Lei 9.099/1995: Da decisão de rejeição da

Artigo	denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. § 1.º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 2.º O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias. § 3.º As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o § 3.º do art. 65 desta Lei. § 4.º As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. § 5.º Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.
Prazo	10 dias (art. 82 da Lei 9.099/1995)
Serve para	Reforma de sentença penal.
Observações	Este recurso tem um prazo diferenciado e mais extenso em sede de Juizado Especial Criminal. Prazo este de 10 dias, pois acredita o legislador que, como no procedimento sumaríssimo do juizado vigoram os princípios da celeridade, informalidade e oralidade, o apelante teria que ter mais tempo para a elaboração do recurso. Além disso, cuidado precisamos ter em endereçar

nossas razões recursais não ao Tribunal de 2.^a instância,
e sim às Turmas Recursais.

10.2.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO ____ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
DA COMARCA _____ DO ESTADO _____

(linhas)

_____ (nome), qualificado nos autos do processo n.º _____, por seu
advogado infra-assinado, vem, com fulcro no art. 82 da Lei 9.099/1995, interpor recurso de

APELAÇÃO

por entender, *data venia*, que a sentença de fls. _____ merece ser reformada porque não
espelha a realidade dos fatos.

Desde já, requer remessa dos autos a Turma Recursal para conhecimento e provimento do
presente recurso.

N. Termos,

P. Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

Processo n.º: _____

Apelante: _____

Apelado: _____

Origem: _____

RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO

Excelentíssimos Senhores Juízes,

Douta Turma Recursal,

I – Dos Fatos

II – Das Preliminares

III – Do Direito

IV – Do Mérito

Isto posto, requer a defesa o conhecimento do presente recurso a fim de que no mérito seja a sentença reformada com _____ (motivação do recurso), nos termos do artigo _____.

N. Termos,

P. Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

10.3 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

Nome	Embargos de Declaração
Artigo	Art. 83 da Lei 9.099/1995 Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. (Redação dada pela Lei 13.105, de 2015.) § 1.º Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. § 2.º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. (Redação dada pela Lei 13.105, de 2015.) § 3.º Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.
Prazo	5 dias (art. 83 da Lei 9.099/1995)
	Sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão

Serve para	de sentença penal ou acórdão.
Observações	Único recurso em que não precisamos nos preocupar com a elaboração de uma folha de rosto e uma folha de razões, visto que é um recurso interposto ao mesmo julgador que proferiu a decisão ambígua ou contraditória etc.

10.3.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO ____ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA _____ DO ESTADO _____

_____ (nome), já amplamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado, vem, com fundamento no art. 83 da Lei 9.099/1995, tempestivamente opor os presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

para dirimir os questionamentos seguintes:

I – Dos Fatos

(...)

→ Apontar contradição ou obscuridade ou omissão.

II – Do Direito

(...)

→ tese e justificativa. Neste caso específico, a tese é sanar o vício e explicitar o gravame que este vem causando.

III – Do Pedido

Isto posto, demonstrado _____ (motivação do recurso), espera que os embargos sejam recebidos e julgados procedentes.

N. Termos,

P. Deferimento,

Município, data

Advogado

10.4 RESPOSTA DO ACUSADO OU RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI

Nome	Resposta do Acusado
Artigo	Art. 406 do CPP. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei 11.689, de 2008) § 1.º O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento, em juízo, do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. (Redação dada pela Lei 11.689, de 2008) § 2.º A acusação deverá arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), na denúncia ou na queixa. § 3.º Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (Incluído pela Lei 11.689, de 2008)
Prazo	10 dias (art. 406 do CPP)
Serve para	Responder à Acusação formalizada na inicial acusatória (denúncia ou queixa-crime).
	Novidade trazida pela Lei 11.719/2008, conforme

Observações

observamos nos artigos acima expostos.

Peça essencial para a defesa, em que deverão ser abordadas TODAS as teses defensivas, seguindo sempre aquela linha já estipulada da melhor tese em primeiro lugar.

Segue a mesma forma de elaboração da resposta já vista, mudando o endereçamento e os dispositivos legais (arts. 406, caput e § 3.º do CPP), todavia temos uma polêmica nesta peça, já que, após a mesma, no procedimento do júri, não se faz presente absolvição sumária. No procedimento bifásico e mais extenso do júri, a possibilidade de absolvição sumária, neste particular com disposição legal no art. 415 do CPP, é encontrada ao final da 1.ª Fase de admissibilidade. Após a resposta temos a oitiva do MP.

Acerca da polêmica sobre essa peça, percebemos na doutrina prático-profissional, três correntes sobre ela, senão vejamos:

1.ª: Com base na lei, essa peça se restringe a alegar exceções, hipóteses de não recebimento, preliminares e especificar provas. Peça extremamente estratégica em nome da boa defesa. Não seria interessante demonstrar teses nesse momento. Essa corrente seria por nós defendida.

2.ª: Possibilidade de pedir absolvição sumária do art. 415, CPP. Além do roteiro-padrão, no mérito, poderíamos buscar a absolvição sumária do art. 415, CPP, caso esteja evidenciada uma das hipóteses. Lembramos que tal

pedido, tecnicamente falando, é mais acertado ser feito em sede de memoriais.

3.^a: Possibilidade de pedir absolvição sumária do art. 397, CPP, por analogia ao procedimento comum ordinário. Baseando-se no art. 394, § 5.º, CPP, o mérito dessa peça seria buscar as hipóteses do art. 397, CPP, transformando tal peça em modelo idêntico ao do procedimento ordinário.

10.4.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DO ____ TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA _____ DO ESTADO _____

Proc. n.º _____

_____ (nome), já qualificado, vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento no artigo 406, *caput* e § 3.º do CPP, apresentar

RESPOSTA DO ACUSADO

pelos motivos a seguir aduzidos.

I – Dos Fatos

(...)

II – Das Exceções (art. 95, CPP)

(...)

III – Pelo Não Recebimento da Ação Penal (art. 395, CPP)

(...)

IV – Das Preliminares

(...)

V – Do mérito¹

(...)

VI – Das Provas

(...)

VII – Dos Pedidos

Termos em que,

Pede Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

10.5 DEFESA PRELIMINAR NO PROCEDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Nome	Defesa Preliminar nos Tribunais Superiores
Artigo	Art. 4.º da Lei 8.038/1990: Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias. § 1.º Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados. § 2.º Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á à sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.
Prazo	15 dias (art. 4.º da Lei 8.038/1990)
Serve para	Evitar o recebimento da ação penal
	Esta Defesa Preliminar, por alguns chamados de Alegação

Observações

Preliminar ou até mesmo de Resposta Preliminar, é cabível nos procedimentos de competência originária nos Tribunais Superiores, regidos pela Lei 8.038/1990. É utilizada, assim, quando se tratar de ação penal originária no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.

Tem a função precípua de impedir o recebimento da ação penal, configurando, assim, uma garantia ou privilégio a mais quando estamos diante de competências originárias nos Tribunais Superiores.

10.5.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO DO _____

Proc. n.º _____

_____ (nome), já qualificado, vem por seu advogado infra-assinado, respeitosamente, com fundamento no art. 4.º da Lei 8.038/1990, tempestivamente, apresentar

DEFESA PRELIMINAR

com base nos fatos e fundamentos jurídicos abaixo.

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido (genérico)

Isto posto, requer que a ação penal não seja recebida.

Termos em que,

Pede Deferimento,

Município, data

Advogado

10.6 DEFESA PRÉVIA NO PROCEDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Nome	Defesa Prévia nos Tribunais Superiores
Artigo	Art. 8.º da Lei 8.038/1990: O prazo para defesa prévia será de cinco dias, contado do interrogatório ou da intimação do defensor dativo.
Prazo	5 dias (art. 8.º da Lei 8.038/1990)
Serve para	Peça da Defesa que objetiva responder a acusação formalizada e já recebida.
Observações	Depois do recebimento da ação penal no Tribunal Superior, o relator designará data para interrogatório. Após este meio de prova e meio de defesa, o acusado é intimado para apresentar a atual defesa prévia, em 5 dias. Esse prazo também poderá começar da intimação do defensor dativo, como vimos anteriormente no art. 8.º da Lei 8.038/1990.

10.6.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO DO _____

(linhas)

_____ (nome), já qualificado nos autos do processo n.º _____, vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento no art. 8.º da Lei 8.038/1990, tempestivamente, apresentar

DEFESA PRÉVIA,

pelos motivos a seguir aduzidos.

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido

(...)

Rol de Testemunhas:

(...)

Termos em que,

Pede Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

10.7 ALEGAÇÕES ESCRITAS NO PROCEDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Nome	Alegação Escrita nos Tribunais Superiores
	Art. 10 da Lei 8.038/1990: Concluída a inquirição de testemunhas, serão intimadas a acusação e a defesa, para requerimento de diligências no prazo de cinco dias. Art. 11. Realizadas as diligências, ou não sendo estas requeridas nem determinadas pelo relator, serão intimadas a acusação e a defesa para, sucessivamente, apresentarem, no prazo de quinze dias, alegações escritas.
Artigo	§ 1.º Será comum o prazo do acusador e do assistente, bem como o dos corréus.

	§ 2.º Na ação penal de iniciativa privada, o Ministério Público terá vista, por igual prazo, após as alegações das partes. § 3.º O relator poderá, após as alegações escritas, determinar de ofício a realização de provas reputadas imprescindíveis para o julgamento da causa.
Prazo	15 dias (art. 11 da Lei 8.038/1990)
Serve para	Peça de apresentação final das teses das partes.
Observações	Antes da apresentação das Alegações Escritas, após a inquirição das testemunhas, as partes podem requerer diligências no prazo de 5 dias. Peça essa simples, de puro requerimento. Não havendo esse requerimento, as partes serão intimadas para apresentar as alegações finais escritas. Notemos que o procedimento da Lei 8.038/1990, dos Tribunais Superiores, é bem diferente dos procedimentos vistos no Código de Processo Penal.

10.7.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO DO _____

(linhas)

Processo n.º: _____

_____ (nome), já qualificado nos autos do processo-crime em epígrafe, vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento no art. 11 da Lei 8.038/1990, apresentar

ALEGAÇÕES ESCRITAS,

pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido (genérico)

Isto posto, requer a (procedência ou improcedência) da presente ação penal.

Termos em que

Pede Deferimento.

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

10.8 RECLAMAÇÃO NO PROCEDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Nome	Reclamação nos Tribunais Superiores
	Art. 102 da CF: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: (...) I) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; Art. 105 da CF: Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I – processar e julgar, originariamente: (...)

Artigo	f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; Art. 988 do NCPC: Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei 13.256, de 2016.) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei 13.256, de 2016.)
Prazo	–
Serve para	Preservar e garantir a competência dos Tribunais Superiores e a autoridade de suas decisões.
Observações	Peça única dirigida ao Presidente do Tribunal que objetiva preservar e garantir, precipuamente, as decisões dos tribunais superiores. Em relação à natureza jurídica desta peça processual, reside uma interminável discussão doutrinária. Verificamos três correntes sem podermos definir uma corrente majoritária. Seria um recurso? Uma ação autônoma? Ou um incidente processual? Se entendermos ser ação autônoma, deveremos preencher os requisitos e

condições da ação, evitando assim qualquer tipo de erro em relação à elaboração da mesma.

10.8.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO _____

(linhas)

_____ (nome + qualificação completa), vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento nos arts. ____ da CF, combinados com o art. 988 do NCPC, apresentar

RECLAMAÇÃO,

pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido (genérico)

Isto posto, requer:

Que seja preservada a competência do presente Tribunal ou

Que seja garantida a preservação da decisão proferida por este Eminentíssimo Tribunal.

Termos em que

Pede Deferimento.

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

10.9 RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL NO PROCEDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Nome	Recurso Ordinário nos Tribunais Superiores

Artigo

Art. 102 da CF: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

II – julgar, em recurso ordinário:

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

b) o crime político;

Art. 105 da CF: Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

II – julgar, em recurso ordinário:

a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória;

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País;

Art. 30 da Lei 8.038/1990: O recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, das decisões denegatórias de

	Habeas Corpus, proferidas pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, será interposto no prazo de cinco dias, com as razões do pedido de reforma.
Prazo	5 dias (art. 30 da Lei 8.038/1990)
Serve para	Recurso que serve para se tentar reformar decisões dos chamados remédios constitucionais (Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Habeas Data e Mandado de Injunção), de sentença por crime político e causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País.
Observações	Recurso que pode ser interposto tanto no STF quanto no STJ. Esta competência deverá ser aferida com a análise dos arts. 102 e 105 da CF. Por se tratar de um recurso, deverá seguir a regra geral com a elaboração de peça de interposição de razões.

10.9.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDO

(linhas)

_____ (nome), já qualificado nos autos do processo n.º _____ (se fornecido) em epígrafe, vem por seu advogado infra-assinado, à presença de Vossa Excelência, não se conformando com o acórdão de fls. _____, que _____ (teor do acórdão), com fundamento nos artigos ____, inciso ____, alínea_____, da Constituição Federal, combinado com os arts. 30 e 32 da Lei 8.038/1990, interpor

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL

ao colendo_____.

Termos em que, requerendo seja ordenado o processamento do recurso, ora interposto, com as anexas razões, pede deferimento.

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO-CONSTITUCIONAL

Paciente (se for HC) ou Impetrante (se for MS): _____

HC ou MS n.º: _____

Origem: _____

Processo n.º: _____

Colendo _____,

Douta Turma,

Excelentíssimos Ministros,

Impõe-se a reforma do acórdão _____ (teor do acórdão) proferido pela ____
Turma contra o _____ (paciente), pelas razões que se seguem:

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido

Isto posto, demonstrado _____ (motivação do recurso), requer-se seja o presente recurso conhecido e provido, para tornar sem efeito a decisão que _____ (objeto da decisão).

N. Termos,

P. Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

10.10 AGRAVO NO PROCEDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Nome	Agravo nos Tribunais Superiores
Artigo	Art. 39 da Lei 8.038/1990: Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias. Art. 1.042 NCPC: Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. § 2.º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. (Redação dada pela Lei 13.256, de 2016.) § 3.º O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. § 4.º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente. § 5.º O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se,

	ainda, o disposto no regimento interno do tribunal respectivo. § 6.º Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. § 7.º Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. § 8.º Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado.
Prazo	15 dias (art. 1.003, § 5.º, do novo CPC)
Serve para	Decisões do Presidente do Tribunal Superior que cause gravame à parte.
Observações	Folha de rosto dirigida ao Presidente do Tribunal e folha de razões dirigida ao Órgão Especial, Seção ou Turma conforme o caso.

10.10.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDO

(linhas)

_____ (nome), já qualificado nos autos do processo n.º _____ (se fornecido) em epígrafe, vem por seu advogado infra-assinado, tendo em vista o gravame causado com a r. decisão de fls. _____, com fundamento no art. 39 da Lei 8.038/1990, interpor

AGRAVO

À (ao) (Órgão Especial, Turma ou Seção) do Colendo _____.

Termos em que, requerendo seja ordenado o processamento do recurso, ora interposto, com as anexas razões, pede deferimento.

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

RAZÕES DE AGRAVO

Agravante: _____

Agravado: _____

Origem: _____

Processo n.º: _____

Colendo _____,

Douta _____,

Excelentíssimos Ministros,

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido

Isto posto, demonstrado _____ (gravame), requer-se seja o presente recurso conhecido e provido, para tornar sem efeito a decisão que _____ (objeto da decisão).

N. Termos,

P. Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

10.11 DEFESA PRELIMINAR NO PROCEDIMENTO DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Nome	Defesa Preliminar
Artigo	Art. 514 do CPP: Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de quinze dias. Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar. Art. 515 do CPP: No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor. Parágrafo único. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações.
Prazo	15 dias (art. 514 do CPP)
Serve para	Impedir o recebimento da ação penal nos crimes funcionais.
	Preliminarmente, recente Súmula do STF a respeito dos crimes funcionais e o conceito jurídico penal de funcionário público: Súmula 714 do STF: É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação

penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.

Art. 327 do CP: Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1.º Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

§ 2.º A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

Sobre esta defesa preliminar, como já vimos e podemos concluir, trata-se de meio de defesa que tem a função de impedir o recebimento da ação penal. Geralmente nesta defesa preliminar, também chamada de alegação preliminar, apesar de preferirmos a primeira terminologia, o candidato deverá colocar em sua peça o maior número de razões que demonstrem o não preenchimento das condições da ação por parte do autor da ação penal. Lembrando que são condições da ação (art. 395 do CPP) a legitimidade da parte, a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a justa causa.

Além disso, essa defesa preliminar é utilizada apenas nos

Observações

crimes funcionais afiançáveis conforme dispõe o art. 514 do CPP. Os crimes funcionais, a cuja tabela sistemática remetemos o leitor, estão dispostos a partir do art. 312 do Código Penal. Dentre os crimes funcionais, próprios, que admitem coautoria por quem não é funcionário público, temos duas hipóteses de crimes inafiançáveis, não aplicando, portanto, a necessidade de notificação à defesa preliminar. São eles: Excesso de Exação (art. 316, parágrafo único, do CP) e Facilitação de Contrabando ou Descaminho (art. 318 do CP).

Divergência no mais alto escalão jurisprudencial em relação ao tema. O Superior Tribunal de Justiça editou o seguinte verbete sumular:

Súmula 330 do STJ: É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial.

Concluindo, se a ação penal tiver como justa causa, àquele conjunto informativo mínimo que dá ensejo a propositura da ação penal, o inquérito policial, segundo o STJ, não há necessidade de notificação para a defesa preliminar. Segundo a Corte, havendo investigação preliminar, o funcionário público já está ciente das investigações realizadas e das informações obtidas. Não seria surpreendido com a futura propositura da ação penal.

Entretanto, não pensa assim a mais alta Suprema Corte de nosso país. Alguns julgados do STF informam que, independentemente de haver ou não 1.^a fase da persecução criminal, traduzida pelo inquérito policial, o

art. 514 do CPP, que obriga a notificação à defesa preliminar na maioria dos crimes funcionais, deve ser sumariamente respeitada. Vale observar que, em julgamentos mais recentes, o STF vem entendendo também que a ausência da defesa preliminar gera tão somente a nulidade relativa, exigindo-se, assim, demonstração efetiva e cabal do prejuízo.

Destacamos a seguir a melhor tese para a defesa neste polêmico e perigoso caso:

Habeas Corpus. Processual penal. Necessidade de defesa prévia. Art. 514 do CPP. Denúncia que imputa ao paciente, além de crimes funcionais, crimes de quadrilha e de usurpação de função pública. Procedimento restrito aos crimes funcionais típicos. Ordem denegada. I – A partir do julgamento do HC 85.779/RJ, passou-se a entender, nesta Corte, que é indispensável a defesa preliminar nas hipóteses do art. 514 do Código de Processo Penal, mesmo quando a denúncia é lastreada em inquérito policial (Informativo 457/STF). II – O procedimento previsto no referido dispositivo da lei adjetiva penal cinge-se às hipóteses em que a denúncia veicula crimes funcionais típicos, o que não ocorre na espécie. Precedentes. III – Habeas corpus denegado.

10.11.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA

(linhas)

n.º _____, vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento no art. 514 do CPP,

apresentar

DEFESA PRELIMINAR,

pelos motivos a seguir aduzidos.

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido

Isto posto, requer o não recebimento da presente ação penal.

Termos em que,

Pede Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

10.11.2 Exercício²

Peça Prático-Profissional Inédita:

Peça 19:

Geisa, funcionária pública de certa prefeitura municipal, está sendo acusada de corrupção passiva e advocacia administrativa, crimes dos arts. 317 e 321 do CP. Seus bens não são condizentes com o salário que recebe e isso chamou a atenção do Ministério Público que a denunciou, em 10.01.2013, com base exclusivamente em informações de outras investigações em relação ao Município.

Inconformada, Geisa lhe procura para adotar medida exclusiva de advogado ao caso em tela no último dia do prazo.

10.12 EXCEÇÃO DA VERDADE NO PROCEDIMENTO DOS CRIMES CONTRA A HONRA

Nome	Exceção da Verdade
Artigo	Art. 520 do CPP: Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as, separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando termo. Art.523 do CPP: Quando for oferecida a exceção da verdade ou da notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de dois dias, podendo ser inquiridas as testemunhas arroladas na queixa, ou outras indicadas naquele prazo, em substituição às primeiras, ou para completar o máximo legal.
Prazo	5 dias (decisão no HC 92.616/STF)
Serve para	Demonstrar a notoriedade das supostas ofensas.
	Cabe na calúnia (art. 138 do CP) e na difamação (art. 139 do CP), quando for em relação a funcionário público. Art. 138 do CP: Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: (...) § 3.º Admite-se a prova da verdade, salvo: I – se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível; II – se o fato é imputado a qualquer das pessoas

Observações

indicadas no n.º I do art. 141;

III – se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.

Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

A exceção da verdade é um meio de defesa possível apenas nos casos de abordagem da honra objetiva, pois as veracidades de um eventual fato podem ser objetivamente demonstradas, assim, não estaríamos suscetíveis a opiniões subjetivas, como no caso da injúria que protege a honra subjetiva.

Vale observar que esse procedimento será utilizado nos crimes contra a honra que não se encaixam no perfil de crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse dois anos. Assim, a calúnia com causa de aumento e a injúria qualificada seguiriam esse procedimento especial a partir do art. 519 do CPP.

10.12.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA

(linhas)

_____ (nome + qualificação completa) ou já qualificado nos autos do processo n.º

_____, vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento no art. 523 do CPP, apresentar

EXCEÇÃO DA VERDADE,

pelos motivos a seguir aduzidos.

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido

Isto posto, requer a improcedência da presente ação, tendo em vista que os dizeres proferidos condizem com a mais pura verdade.

Termos em que,

Pede Deferimento,

Município, Data

Advogado

Inscrição n.º

10.13 DEFESA PRELIMINAR NO PROCEDIMENTO DOS CRIMES DA LEI 11.343/2006 – LEI DE TÓXICOS

Nome	Defesa Preliminar
	Art. 55 da Lei 11.343/2006: Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. § 1.º Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.

Artigo	§ 2.º As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal. Art. 55 da Lei 11.343/2006: Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. § 1.º Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas. § 2.º As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal. § 3.º Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação. § 4.º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 (cinco) dias. § 5.º Se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de 10 (dez) dias, determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias.
Prazo	10 dias (art. 55 c/c art. 55, § 1.º, da Lei 11.343/2006)
Serve para	Impedir o recebimento da ação penal e apresentar todas as teses de defesa.

Observações

Peça da defesa com dois objetivos bem definidos. Primeiro, tentar impedir o recebimento da ação penal. Para isso, devem ser colocadas razões de não preenchimento das condições da ação. Em segundo plano, serve para colocar todas as teses defensivas.

Uma das principais teses defensivas no caso pode ser a desclassificação do tráfico (art. 33 da Lei 11.343/2006) para o uso (art. 28 da Lei 11.343/2006). Parâmetros diferenciadores podem ser visualizados no seguinte artigo:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2.º Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

10.13.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA
____ DO ESTADO _____

(linhas)

_____ (nome), já qualificado nos autos do processo n.º _____, vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento no art. 55 c/c art. 55, § 1.º, da Lei 11.343/2006, apresentar

DEFESA PRELIMINAR,

pelos motivos a seguir aduzidos.

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

a) Pelo não recebimento da Ação Penal:

(...)

b) Pela improcedência da Ação:

(...)

III – Do Pedido

Isto posto, requer o não recebimento da presente ação penal.

Caso Vossa Excelência entenda pelo recebimento da presente ação penal, que esta não seja procedente pelas razões defensivas acima expostas. (pedido genérico)

Termos em que,

Pede Deferimento,

Município, Data

Advogado

Inscrição n.º

10.13.2 Exercício³

Peça Prático-Profissional Inédita:

Peça 20:

Lili Estrela, brasileira, solteira, 50 anos, ex-atriz e modelo, atualmente professora de inglês, residente e domiciliada em Curitiba, no Paraná, na Rua Sete de Setembro, 404, apartamento 201, no Centro da Cidade, portadora da carteira de identidade 12131415-2, inscrita sob o CPF número 324.567.987-56, foi, no dia 10 de fevereiro do ano em curso, preparando-se para ir a Balneário Camboriú em uma famosa boate de música eletrônica, presa em flagrante numa blitz feita pela Polícia Militar na

região de saída da cidade, portando 14 comprimidos de *ecstasy*, substância entorpecente proscrita no Brasil, de acordo com normas regulamentares.

Lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, acostado laudo preliminar de constatação, com a devida comunicação ao Juiz competente, viu-se Lili em uma enrascada. Nunca tinha ido à delegacia nem ao menos presa em flagrante.

Conforme o art. 310, III, do CPP, o juiz a liberou logo em seguida.

Todavia, Lili estava desesperada e receosa de que sua família soubesse do ocorrido. Queria apenas se divertir com as amigas no famoso litoral catarinense e, seduzida e influenciada por outras amigas, resolveu levar os comprimidos para experimentar pela primeira vez a chamada droga do amor. Encontrava-se Lili num momento de libertação, já que estava recém-separada do marido Arnaldo Constelação.

O Delegado Firmino Nascimento, que conduziu o IP, realizou algumas diligências e em interrogatório, onde foi acompanhada de seu advogado e com direito ao silêncio alertado, a indiciada afirmou que nunca em sua vida tinha experimentado drogas. Todavia, nobre e conservador Delegado, não acreditou em sua versão, já que, sendo ex-atriz, houve uma desconfiança natural por parte do Delegado de tanto abalo para uma pessoa só. “Estaria ela representando?”, imaginou a autoridade policial.

Durante o trâmite investigativo, foi inserida ficha de antecedentes criminais de Lili que confirmaram a ausência de antecedentes criminais. Além disso, foram juntados, pelos representantes legais da indiciada, comprovantes bancários, relações de bens, exames laboratoriais que atestaram a ausência de substância ilegal nas últimas 24 horas após sua saída da delegacia e comprovantes de imposto de renda, que atestaram realmente ser a indiciada uma pessoa de muitos bens e investimentos, tendo em vista seu passado de sucesso nas passarelas internacionais.

Feito o relatório pela autoridade policial, os autos foram remetidos à Justiça, onde, em 10 de abril do mesmo ano, o representante do Ministério Público apresentou denúncia por tráfico de entorpecentes.

Vale observar que, embora tenha sido o flagrante se dado em época de feriado

com notório conhecimento de que existem muitos usuários de drogas em boates de música eletrônica, as amigas, Jorgina e Carlinha, não souberam dizer se Lili tinha algum contato com drogas.

Oferecida a ação penal, você, advogado recém-formado, aprovado no difícil Exame de Ordem, é contratado para apresentar a medida judicial cabível abordando todos os aspectos pertinentes favoráveis à sua cliente.

10.14 MANDADO DE SEGURANÇA

Nome	Mandado de Segurança
	Art. 5.º da CF: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Art. 1.º da Lei 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
Artigo	

	categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1.º Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2.º Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3.º Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. 120 dias
Prazo	Art. 23 da Lei 12.016/2009: O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Súmula 632 do STF: É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para impetração de mandado de segurança.
Serve para	Garantir o direito líquido e certo.
	Novidade legislativa referente ao tema: Lei 12.016/2009. Largamente utilizada para se conseguir vista de eventuais inquéritos policiais sigilosos, todavia, com a nova Súmula

Observações

Vinculante 14, perdeu um pouco sua utilização. Diz a Súmula Vinculante 14: “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Pode, ainda, ser utilizada para se garantir uma entrevista com o cliente, para acompanhar uma perícia, contra não admissão do assistente dentre outras possibilidades, que não são protegidas por habeas corpus ou habeas data.

10.14.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA
____ DO ESTADO ____

(linhas)

____ (nome + qualificação completa), vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento no art. 5.º, LXIX, da CF c/c art. 1.º da Lei 12.016/2009, impetrar

MANDADO DE SEGURANÇA,

com pedido de liminar, contra ato praticado ____ (coator) pelos motivos a seguir demonstrados.

I – Dos Fatos

(...)

II – Da Liminar

Vide os seguintes artigos da Lei 12.016/2009:

Art. 7.º (...)

§ 1.º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.

§ 2.º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3.º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4.º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5.º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei 5.869, de 11 janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.

Art. 8.º Será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar *ex officio* ou a requerimento do Ministério Público quando, concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou deixar de promover, por mais de 3 (três) dias úteis, os atos e as diligências que lhe cumprirem.

Art. 9.º As autoridades administrativas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da notificação da medida liminar, remeterão ao Ministério ou órgão a que se acham subordinadas e ao Advogado-Geral da União ou a quem tiver a representação judicial da União, do Estado, do Município ou da entidade apontada como coatora cópia autenticada do mandado notificador, assim como indicações e elementos outros necessários às providências a serem tomadas para a eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo de poder.

(...)

III – Do Direito

(...)

IV – Do Pedido

Isto posto, requer:

- a) A concessão da liminar, com base no art. 7.º, § 1.º, da Lei 12.016/2009;
- b) Notificação do coator, com base no art. 7.º, I, da Lei 12.016/2009;
- c) Ciência ao representante da pessoa jurídica, com base no art. 7.º, II, da Lei 12.016/2009;
- d) Vista ao órgão do Ministério Público;
- e) Procedência da Ordem.

Termos em que,

Pede Deferimento,

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

10.15 AÇÃO CIVIL EX DELICTO

Nome	Ação Civil Ex Delicto
Artigo	Art. 63 do CPP
Prazo	–
Serve para	Pleitear na esfera cível valor indenizatório.
Observações	Com a mudança dada pela reforma processual de 2008, o valor de indenização é um dos efeitos da sentença penal condenatória, ou seja, o juiz, em sentença criminal, estipula um valor a ser pago pelo condenado à vítima, entretanto, tal medida não impede o ingresso no juízo cível.

10.15.1 Modelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CÍVEL DA COMARCA
____ DO ESTADO _____

(linhas)

_____ (qualificação completa), vem por seu advogado infra-assinado, com fundamento no art. 63 do CPP, apresentar

AÇÃO CIVIL EX DELICTO

tendo em vista a sentença penal condenatória já transitada em julgado nos autos do processo n.º _____, em face de _____ (acusado), pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos.

I – Dos Fatos

(...)

II – Do Direito

(...)

III – Do Pedido

(...)

Termos em que,

Pede Deferimento,

Local, data

Município, data

Advogado

Inscrição n.º

-
- 1 Atenção à polêmica acerca das possibilidades de arguições nos fundamentos.
 - 2 Confira o gabarito ao final da obra.
 - 3 Confira o gabarito ao final da obra.

11.1 QUESTÕES DISCURSIVAS OFICIAIS

11.1.1 Exame OAB Unificado – 2010.2 – FGV

QUESTÃO 1

José da Silva foi preso em flagrante pela polícia militar quando transportava em seu carro grande quantidade de drogas. Levado pelos policiais à delegacia de polícia mais próxima, José telefonou para seu advogado, o qual requereu ao delegado que aguardasse sua chegada para lavrar o flagrante. Enquanto esperavam o advogado, o delegado de polícia conversou informalmente com José, o qual confessou que pertencia a um grupo que se dedicava ao tráfico de drogas e declinou o nome de outras cinco pessoas que participavam desse grupo. Essa conversa foi gravada pelo delegado de polícia.

Após a chegada do advogado à delegacia, a autoridade policial permitiu que José da Silva se entrevistasse particularmente com seu advogado e, só então, procedeu à lavratura do auto de prisão em flagrante, ocasião em que José foi informado de seu direito de permanecer calado e foi formalmente interrogado pela autoridade policial. Durante o interrogatório formal, assistido pelo advogado, José da Silva optou por permanecer calado, afirmando que só se manifestaria em juízo.

Com base na gravação contendo a confissão e delação de José, o Delegado de Polícia, em um único ato, determina que um de seus policiais atue como agente infiltrado e requer, ainda, outras medidas cautelares investigativas para obter provas em face dos demais membros do grupo criminoso: 1. quebra de sigilo de dados telefônicos, autorizada pelo juiz competente; 2. busca e apreensão, deferida pelo juiz competente, a qual logrou apreender grande quantidade de drogas e armas; 3. prisão preventiva dos cinco comparsas de José da Silva, que estavam de posse das drogas e armas. Todas as provas coligidas na investigação corroboraram as informações fornecidas por José em seu depoimento.

Relatado o inquérito policial, o promotor de justiça denunciou todos os envolvidos por associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006) e quadrilha armada (art. 288, parágrafo único).

Considerando tal narrativa, excluindo eventual pedido de aplicação do instituto da delação premiada, indique quais as teses defensivas, no plano do direito material e processual, que podem ser arguidas a partir do enunciado anterior, pela defesa de José. Indique os dispositivos legais aplicáveis aos argumentos apresentados.

QUESTÃO 2

Caio, funcionário público, ao fiscalizar determinado estabelecimento comercial, exige vantagem indevida.

A qual delito corresponde o fato narrado:

- I. se a vantagem exigida servir para que Caio deixe de cobrar tributo devido;
- II. se a vantagem, advinda de cobrança de tributo que Caio sabia não ser devida, for desviada para proveito de Caio?

QUESTÃO 3

Pedro, almejando a morte de José, contra ele efetua disparo de arma de fogo, acertando-o na região torácica. José vem a falecer, entretanto, não em razão do disparo recebido, mas porque, com intenção suicida, havia ingerido dose letal de veneno momentos antes de sofrer a agressão, o que foi comprovado durante instrução processual. Ainda assim, Pedro foi pronunciado nos termos do previsto no art. 121, *caput*, do Código Penal.

Na condição de Advogado de Pedro:

- I. indique o recurso cabível;
- II. o prazo de interposição;
- III. a argumentação visando à melhoria da situação jurídica do defendido. Indique, ainda, para todas as respostas, os respectivos dispositivos legais.

QUESTÃO 4

Aurélio, tentando defender-se da agressão a faca perpetrada por Berilo, saca de seu revólver e efetua um disparo contra o agressor. Entretanto, o disparo efetuado por Aurélio, em vez de acertar Berilo, atinge Cornélio, que se encontrava muito próximo de Berilo. Em consequência do tiro, Cornélio vem a falecer. Aurélio é acusado de homicídio.

Na qualidade de advogado de Aurélio, indique a tese de defesa que melhor se adéqua ao fato. Justifique sua resposta.

QUESTÃO 5

Lucas, processado em liberdade, foi condenado na 1.^a instância à pena de cinco anos em regime integralmente fechado, pelo crime de tráfico de drogas, cometido em setembro de 2006. Interpôs Recurso de Apelação, o qual foi parcialmente provido. O Tribunal alterou apenas o dispositivo da sentença que fixava o regime em integralmente fechado para inicialmente fechado. Após o trânsito em julgado, Lucas deu início ao cumprimento de pena em 10 de fevereiro de 2009. O juízo da execução, em 10 de outubro de 2010, negou a progressão de regime sob o fundamento de que Lucas ainda não havia cumprido 2/5 da pena, em que pese os demais requisitos tenham sido preenchidos.

Diante dos fatos e da decisão exposta, sendo que sua intimação, na condição de Advogado de Lucas, ocorreu em 11.10.2010:

- I. indique o recurso cabível;

II. apresente a argumentação adequada, indicando os respectivos dispositivos legais.

11.1.2 Exame OAB Unificado – 2010.3 – FGV

QUESTÃO 1

Caio, na qualidade de diretor financeiro de uma conhecida empresa de fornecimento de material de informática, se apropriou das contribuições previdenciárias devidas dos empregados da empresa e por esta descontadas, utilizando o dinheiro para financiar um automóvel de luxo. A partir de comunicação feita por Adolfo, empregado da referida empresa, tal fato chegou ao conhecimento da Polícia Federal, dando ensejo à instauração de inquérito para apurar o crime previsto no art. 168-A do Código Penal. No curso do aludido procedimento investigatório, a autoridade policial apurou que Caio também havia praticado o crime de sonegação fiscal, uma vez que deixara de recolher ICMS relativamente às operações da mesma empresa. Ao final do inquérito policial, os fatos ficaram comprovados também pela confissão de Caio em sede policial. Nessa ocasião, ele afirmou estar arrependido e apresentou comprovante de pagamento exclusivamente das contribuições previdenciárias devidas ao INSS, pagamento realizado após a instauração da investigação, ficando não paga a dívida relativa ao ICMS. Assim, o delegado encaminhou os autos ao Ministério Público Federal, que denunciou Caio pelos crimes previstos nos arts. 168-A do Código Penal e 1.º, I, da Lei 8.137/1990, tendo a inicial acusatória sido recebida pelo juiz da vara federal da localidade. Após analisar a resposta à acusação apresentada pelo advogado de Caio, o aludido magistrado entendeu não ser o caso de absolvição sumária, tendo designado audiência de instrução e julgamento.

Com base nos fatos narrados no enunciado, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Qual é o meio de impugnação cabível à decisão do Magistrado que não o absolvera sumariamente? (Valor: 0,2)
- b) A quem a impugnação deve ser endereçada? (Valor: 0,2)
- c) Quais fundamentos devem ser utilizados? (Valor: 0,6)

QUESTÃO 2

Caio, residente no município de São Paulo, é convidado por seu pai, morador da cidade de Belo Horizonte, para visitá-lo. Ao dirigir-se até Minas Gerais em seu carro, Caio dá carona a Maria, jovem belíssima que conhecera na estrada e que, ao saber do destino de Caio, o convence a subtrair pertences da casa do genitor do rapaz, chegando a sugerir que ele aguardasse o repouso noturno de seu pai para efetuar a subtração. Ao chegar ao local, Caio janta com o pai e o espera adormecer, quando então subtrai da residência uma televisão de plasma, um aparelho de som e dois mil reais. Após encontrar-se com Maria no veículo, ambos se evadem do local e são presos quando chegavam ao município de São Paulo.

Com base no relatado, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Caio pode ser punido pela conduta praticada e provada? (Valor: 0,4)
- b) Maria pode ser punida pela referida conduta? (Valor: 0,4)
- c) Em caso de oferecimento de denúncia, qual será o juízo competente para processamento da ação penal? (Valor: 0,2)

QUESTÃO 3

Jeremias é preso em flagrante pelo crime de latrocínio, praticado contra uma idosa que acabara de sacar o valor relativo à sua aposentadoria dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal e presenciado por duas funcionárias da referida instituição, as quais prestaram depoimento em sede policial e confirmaram a prática do delito. Ao oferecer denúncia perante o Tribunal do Júri da Justiça Federal da localidade, o Ministério Público Federal requereu a decretação da prisão preventiva de Jeremias para a garantia da ordem pública, por ser o crime gravíssimo e por conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas seriam mulheres e poderiam se sentir amedrontadas caso o réu fosse posto em liberdade antes da colheita de seus depoimentos judiciais. Ao receber a inicial, o magistrado decretou a prisão preventiva de Jeremias, utilizando-se dos argumentos apontados pelo *Parquet*.

Com base no caso relatado, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso, indique os argumentos defensivos para atacar a decisão judicial que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva.

QUESTÃO 4

Caio, professor do curso de segurança no trânsito, motorista extremamente qualificado, guiava seu automóvel tendo Madalena, sua namorada, no banco do carona. Durante o trajeto, o casal começa a discutir asperamente, o que faz com que Caio empreenda altíssima velocidade ao automóvel. Muito assustada, Madalena pede insistentemente para Caio reduzir a marcha do veículo, pois àquela velocidade não seria possível controlar o automóvel. Caio, entretanto, respondeu aos pedidos dizendo ser perito em direção e refutando qualquer possibilidade de perder o controle do carro. Todavia, o automóvel atinge um buraco e, em razão da velocidade empreendida, acaba se desgovernando, vindo a atropelar três pessoas que estavam na calçada, vitimando-as fatalmente. Realizada perícia no local, que constatou o excesso de velocidade, e ouvidos Caio e Madalena, que relataram à autoridade policial o diálogo travado entre o casal, Caio foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de homicídio na modalidade de dolo eventual, três vezes em concurso formal. Recebida a denúncia pelo magistrado da vara criminal vinculada ao Tribunal do Júri da localidade e colhida a prova, o Ministério Público pugnou pela pronúncia de Caio, nos exatos termos da inicial.

Na qualidade de advogado de Caio, chamado aos debates orais, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Qual(is) argumento(s) poderia(m) ser deduzidos em favor de seu constituinte? (Valor: 0,4)
- b) Qual pedido deveria ser realizado? (Valor: 0,3)
- c) Caso Caio fosse pronunciado, qual recurso poderia ser interposto e a quem a peça de interposição

deveria ser dirigida? (Valor: 0,3)

QUESTÃO 5

Em 22 de julho de 2008, Caio foi condenado à pena de dez anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática, no dia 10 de novembro de 2006, do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Iniciada a execução da sua pena em 7 de janeiro de 2009, a Defensoria Pública, em 10 de fevereiro de 2011, requereu a progressão do cumprimento da sua pena para o regime semiaberto, tendo o pedido sido indeferido pelo juízo de execuções penais ao argumento de que, para tanto, seria necessário o cumprimento de 2/5 da pena.

Considerando ter sido procurado pela família de Caio para advogar em sua defesa, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Qual(is) o(s) meio(s) de impugnação da decisão que indeferiu o pedido da Defensoria Pública? (Valor: 0,3)
- b) Qual(is) argumento(s) jurídico(s) poderia(m) ser usado(s) em defesa da progressão de regime de Caio? (Valor: 0,7)

11.1.3 IV Exame OAB Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Maria, jovem extremamente possessiva, comparece ao local em que Jorge, seu namorado, exerce o cargo de auxiliar administrativo e abre uma carta lacrada que havia sobre a mesa do rapaz. Ao ler o conteúdo, descobre que Jorge se apropriara de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), que recebera da empresa em que trabalhava para efetuar um pagamento, mas utilizara tal quantia para comprar uma joia para uma moça chamada Júlia. Absolutamente transtornada, Maria entrega a correspondência aos patrões de Jorge.

Com base no relatado, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Jorge praticou crime? Em caso positivo, qual(is)? (Valor: 0,35)
- b) Se o Ministério Público oferecesse denúncia com base exclusivamente na correspondência aberta por Maria, o que você, na qualidade de advogado de Jorge, alegaria? (Valor: 0,9)

QUESTÃO 2

Caio é denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil. De acordo com a inicial, em razão de rivalidade futebolística, Caio teria esfaqueado Mévio quarenta e três vezes, causando-lhe o óbito. Pronunciado na forma da denúncia, Caio recorreu com o objetivo de ser impronunciado, vindo o Tribunal de Justiça da localidade a manter a pronúncia, mas excluindo a qualificadora, ao argumento de que Mévio seria arruaceiro e, portanto, a motivação não poderia ser

considerada fútil. No julgamento em plenário, ocasião em que Caio confessou a prática do crime, a defesa lê para os jurados a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no que se refere à caracterização de Mévio como arruaceiro. Respondendo aos quesitos, o Conselho de Sentença absolve Caio.

Sabendo-se que o Ministério Público não recorreu da sentença, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) A esposa de Mévio poderia buscar a impugnação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença? Em caso positivo, de que forma e com base em que fundamento? (Valor: 0,65)
- b) Caso o Ministério Público tivesse interposto recurso de apelação com fundamento exclusivo no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, poderia o Tribunal de Justiça declarar a nulidade do julgamento por reconhecer a existência de nulidade processual? (Valor: 0,6)

QUESTÃO 3

Na cidade de Arsenal, no Estado Z, residiam os deputados federais Armênio e Justino. Ambos objetivavam matar Frederico, rico empresário que possuía valiosas informações contra eles. Frederico morava na cidade de Tirol, no Estado K, mas seus familiares viviam em Arsenal. Sabendo que Frederico estava visitando a família, Armênio e Justino decidiram colocar em prática o plano de matá-lo. Para tanto, seguiram Frederico quando este saía da casa de seus parentes e, utilizando-se do veículo em que estavam, bloquearam a passagem de Frederico, de modo que a caminhonete deste não mais conseguia transitar. Ato contínuo, Armênio e Justino desceram do automóvel. Armênio imobilizou Frederico e Justino desferiu tiros contra ele, Frederico. Os algozes deixaram rapidamente o local, razão pela qual não puderam perceber que Frederico ainda estava vivo, tendo conseguido salvar-se após socorro prestado por um passante. Tudo foi noticiado à polícia, que instaurou o respectivo inquérito policial. No curso do inquérito, os mandatos de Armênio e Justino chegaram ao fim, e eles não conseguiram se reeleger. O Ministério Público, por sua vez, munido dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, ofereceu denúncia contra Armênio e Justino, por tentativa de homicídio, ao Tribunal do Júri da Justiça Federal com jurisdição na comarca onde se deram os fatos, já que, à época, os agentes eram deputados federais. Recebida a denúncia, as defesas de Armênio e Justino mostraram-se conflitantes. Já na fase instrutória, Frederico teve seu depoimento requerido. A vítima foi ouvida por meio de carta precatória em Tirol. Na respectiva audiência, os advogados de Armênio e Justino não compareceram, de modo que juízo deprecado nomeou um único advogado para ambos os réus. O juízo deprecante, ao final, emitiu decreto condenatório em face de Armênio e Justino. Armênio, descontente com o patrono que o representava, destituiu-o e nomeou você como novo advogado.

Com base no cenário relatado, indique duas nulidades que podem ser arguidas em favor de Armênio.

Justifique com base no CPP e na CRFB. (Valor: 1,25)

QUESTÃO 4

João e Maria, casados desde 2007, estavam passando por uma intensa crise conjugal. João, visando tornar insuportável a vida em comum, começou a praticar atos para causar dano emocional a Maria, no intuito de ter uma partilha mais favorável. Para tanto, passou a realizar procedimentos de manipulação,

de humilhação e de ridicularização de sua esposa.

Diante disso, Maria procurou as autoridades policiais e registrou ocorrência em face dos transtornos causados por seu marido. Passados alguns meses, Maria e João chegam a um entendimento e percebem que foram feitos um para o outro, como um casal perfeito. Maria decidiu, então, renunciar à representação.

Nesse sentido e com base na legislação pátria, responda fundamentadamente:

- a) Pode haver renúncia (retratação) à representação durante a fase policial, antes de o procedimento ser levado a juízo? (0,65)
- b) Pode haver aplicação de pena consistente em prestação pecuniária? (0,6)

11.1.4 V Exame OAB Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Antônio, pai de um jovem hipossuficiente preso em flagrante delito, recebe de um serventuário do Poder Judiciário Estadual a informação de que Jorge, defensor público criminal com atribuição para representar o seu filho, solicitara a quantia de dois mil reais para defendê-lo adequadamente. Indignado, Antônio, sem averiguar a fundo a informação, mas confiando na palavra do serventuário, escreve um texto reproduzindo a acusação e o entrega ao juiz titular da vara criminal em que Jorge funciona como defensor público. Ao tomar conhecimento do ocorrido, Jorge apresenta uma gravação em vídeo da entrevista que fizera com o filho de Antônio, na qual fica evidenciado que jamais solicitara qualquer quantia para defendê-lo, e representa criminalmente pelo fato. O Ministério Público oferece denúncia perante o Juizado Especial Criminal, atribuindo a Antônio o cometimento do crime de calúnia, praticado contra funcionário público em razão de suas funções, nada mencionando acerca dos benefícios previstos na Lei 9.099/1995. Designada Audiência de Instrução e Julgamento, recebida a denúncia, ouvidas as testemunhas, interrogado o réu e apresentadas as alegações orais pelo Ministério Público, na qual pugnou pela condenação na forma da inicial, o magistrado concede a palavra a Vossa Senhoria para apresentar alegações finais orais.

Em relação à situação relatada, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) O Juizado Especial Criminal é competente para apreciar o fato em tela? (Valor: 0,30)
- b) Antônio faz jus a algum benefício da Lei 9.099/1995? Em caso afirmativo, qual(is)? (Valor: 0,30)
- c) Antônio praticou crime? Em caso afirmativo, qual? Em caso negativo, por que razão? (Valor: 0,65)

QUESTÃO 2

Joaquina, ao chegar à casa de sua filha, Esmeralda, deparou-se com seu genro, Adailton, mantendo relações sexuais com sua neta, a menor F. M., de 12 anos de idade, fato ocorrido no dia 2 de janeiro de 2011. Transtornada com a situação, Joaquina foi à delegacia de polícia, onde registrou ocorrência do fato criminoso. Ao término do Inquérito Policial instaurado para apurar os fatos narrados, descobriu-se que Adailton vinha mantendo relações sexuais com a referida menor desde novembro de 2010. Apurou-se,

ainda, que Esmeralda, mãe de F. M., sabia de toda a situação e, apesar de ficar enojada, não comunicava o fato à polícia com receio de perder o marido que muito amava.

Na condição de advogado(a) consultado(a) por Joaquina, avó da menor, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Adailton praticou crime? Em caso afirmativo, qual? (Valor: 0,3)
- b) Esmeralda praticou crime? Em caso afirmativo, qual? (Valor: 0,5)
- c) Considerando que o Inquérito Policial já foi finalizado, deve a avó da menor oferecer queixa-crime? (Valor: 0,45)

QUESTÃO 3

Jaime, brasileiro, solteiro, nascido em 10.11.1982, praticou, no dia 30.11.2000, delito de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4.º, II, do CP). Devidamente denunciado e processado, Jaime foi condenado à pena de quatro anos e dois meses de reclusão. A sentença transitou definitivamente em julgado no dia 15.01.2002, e o término do cumprimento da pena se deu em 20.03.2006. No dia 24.03.2006, Jaime subtraiu um aparelho de telefone celular que havia sido esquecido por Lara em cima do balcão de uma lanchonete. Todavia, sua conduta fora filmada pelas câmeras do estabelecimento, o que motivou o oferecimento de denúncia, por parte do Ministério Público, pela prática de furto simples (art. 155, *caput*, do CP). A denúncia foi recebida em 14.04.2006 e, em 18.10.2006, Jaime foi condenado à pena de um ano de reclusão e dez dias-multa. Foi fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com sentença publicada no mesmo dia.

Com base nos dados descritos, bem como atento às informações a seguir expostas, responda fundamentadamente:

- a) Suponha que a acusação tenha se conformado com a sentença, tendo o trânsito em julgado para es ocorrido em 24.10.2006. A defesa, por sua vez, interpôs apelação no prazo legal. Todavia, em virtude de sucessivas greves, adiamentos e até mesmo perda dos autos, até a data de 20.10.2010, o recurso da defesa não tinha sido julgado. Nesse sentido, o que você, como advogado, deve fazer? (Valor: 0,60)
- b) A situação seria diferente se ambas as partes tivessem se conformado com o decreto condenatório, de modo que o trânsito em julgado definitivo teria ocorrido em 24.10.2006, mas Jaime, temeroso de ficar mais uma vez preso, tivesse se evadido tão logo teve ciência do conteúdo da sentença, somente tendo sido capturado em 25.10.2010? (Valor: 0,65)

QUESTÃO 4

João e Maria iniciaram uma paquera no Bar X na noite de 17 de janeiro de 2011. No dia 19 de janeiro do corrente ano, o casal teve uma séria discussão, e Maria, nitidamente enciumada, investiu contra o carro de João, que já não se encontrava em bom estado de conservação, com três exercícios de IPVA inadimplentes, a saber: 2008, 2009 e 2010. Além disso, Maria proferiu diversos insultos contra João no dia de sua festa de formatura, perante seu amigo Paulo, afirmando ser ele “covarde”, “corno” e “frouxo”. A requerimento de João, os fatos foram registrados perante a Delegacia Policial, onde a testemunha foi

ouvida. João comparece ao seu escritório e contrata seus serviços profissionais, a fim de serem tomadas as medidas legais cabíveis. Você, como profissional diligente, após verificar não ter passado o prazo decadencial, interpõe Queixa-Crime ao juízo competente no dia 18.07.11.

O magistrado ao qual foi distribuída a peça processual profere decisão rejeitando-a, afirmando tratar-se de clara decadência, confundindo-se com relação à contagem do prazo legal. A decisão foi publicada dia 25 de julho de 2011.

Com base somente nas informações fornecidas, responda:

- a) Qual é o recurso cabível contra essa decisão? (0,30)
- b) Qual é o prazo para a interposição do recurso? (0,30)
- c) A quem deve ser endereçado o recurso? (0,30)
- d) Qual é a tese defendida? (0,35)

11.1.5 VI Exame OAB Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Ao chegar a um bar, Caio encontra Tício, um antigo desafeto que, certa vez, o havia ameaçado de morte. Após ingerir meio litro de uísque para tentar criar coragem de abordar Tício, Caio partiu em sua direção com a intenção de cumprimentá-lo. Ao aproximar-se de Tício, Caio observou que seu desafeto bruscamente pôs a mão por debaixo da camisa, momento em que achou que Tício estava prestes a sacar uma arma de fogo para vitimá-lo. Em razão disso, Caio imediatamente munuiu-se de uma faca que estava sobre o balcão do bar e desferiu um golpe no abdome de Tício, o qual veio a falecer. Após análise do local por peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, descobriu-se que Tício estava tentando apenas pegar o maço de cigarros que estava no cós de sua calça.

Considerando a situação descrita, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Levando-se em conta apenas os dados do enunciado, Caio praticou crime? Em caso positivo, qual? Em caso negativo, por que razão? (Valor: 0,65)
- b) Supondo que, nesse caso, Caio tivesse desferido 35 golpes na barriga de Tício, como deveria ser analisada a sua conduta sob a ótica do Direito Penal? (Valor: 0,6)

QUESTÃO 2

Hugo é inimigo de longa data de José e há muitos anos deseja matá-lo. Para conseguir seu intento, Hugo induz o próprio José a matar Luiz, afirmando falsamente que Luiz estava se insinuando para a esposa de José. Ocorre que Hugo sabia que Luiz é pessoa de pouca paciência e que sempre anda armado. Cego de ódio, José espera Luiz sair do trabalho e, ao vê-lo, corre em direção dele com um facão em punho, mirando na altura da cabeça. Luiz, assustado e sem saber o motivo daquela injusta agressão, rapidamente saca sua arma e atira justamente no coração de José, que morre instantaneamente. Instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte de José, ao final das investigações, o Ministério Público formou sua *opinio* no seguinte sentido: Luiz deve responder pelo

excesso doloso em sua conduta, ou seja, deve responder por homicídio doloso; Hugo, por sua vez, deve responder como partícipe de tal homicídio. A denúncia foi oferecida e recebida.

Considerando que você é o advogado de Hugo e Luiz, responda:

- a) Qual peça deverá ser oferecida, em que prazo e endereçada a quem? (Valor: 0,3)
- b) Qual a tese defensiva aplicável a Luiz? (Valor: 0,5)
- c) Qual a tese defensiva aplicável a Hugo? (Valor: 0,45)

QUESTÃO 3

Caio, Mévio, Tício e José, após se conhecerem em um evento esportivo de sua cidade, resolveram praticar um estelionato em detrimento de um senhor idoso. Logrando êxito em sua empreitada criminoso, os quatro dividiram os lucros e continuaram a vida normal. Ao longo da investigação policial, apurou-se a autoria do delito por meio dos depoimentos de diversas testemunhas que presenciaram a fraude. Em decorrência de tal informação, o promotor de justiça denunciou Caio, Mévio, Tício e José, alegando se tratar de uma quadrilha de estelionatários, tendo requerido a decretação da prisão temporária dos denunciados. Recebida a denúncia, a prisão temporária foi deferida pelo juízo competente.

Com base no relatado, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Qual(is) o(s) meio(s) de se impugnar tal decisão e a quem deverá(ão) ser endereçado(s)? (Valor: 0,6)
- b) Quais fundamentos deverão ser alegados? (Valor: 0,65)

QUESTÃO 4

Carlos Alberto, jovem recém-formado em Economia, foi contratado em janeiro de 2009 pela ABC Investimentos S. A., pessoa jurídica de direito privado que tem como atividade principal a captação de recursos financeiros de terceiros para aplicar no mercado de valores mobiliários, com a função de assistente direto do presidente da companhia, Augusto César. No primeiro mês de trabalho, Carlos Alberto foi informado de que sua função principal seria elaborar relatórios e portfólios da companhia a serem endereçados aos acionistas com o fim de informá-los acerca da situação financeira da ABC. Para tanto, Carlos Alberto baseava-se, exclusivamente, nos dados financeiros a ele fornecidos pelo presidente Augusto César. Em agosto de 2010, foi apurado, em auditoria contábil realizada nas finanças da ABC, que as informações mensalmente enviadas por Carlos Alberto aos acionistas da companhia eram falsas, haja vista que os relatórios alteravam a realidade sobre as finanças da companhia, sonhando informações capazes de revelar que a ABC estava em situação financeira periclitante.

Considerando-se a situação descrita, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) É possível identificar qualquer responsabilidade penal de Augusto César? Se sim, qual(is) seria(m) a conduta(s) típica(s) a ele atribuída(s)? (Valor: 0,45)
- b) Caso Carlos Alberto fosse denunciado por qualquer crime praticado no exercício das suas funções enquanto assistente da presidência da ABC, que argumentos a defesa poderia apresentar para o

caso? (Valor: 0,8)

11.1.6 VII Exame OAB Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Ricardo foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 1.º da Lei 8.137/1990, em concurso material com o crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP). Isso porque, conforme narrado na inicial acusatória e confessado pelo réu no interrogatório, obteve, em determinado estado da federação, licenciamento de seu veículo de modo fraudulento, já que indicou endereço falso. Assim agiu porque queria pagar menos tributo, haja vista que a alíquota do IPVA seria menor. Ao cabo da instrução criminal, Ricardo foi condenado nos exatos termos da denúncia, sendo certo que todo o conjunto probatório dos autos era significativo e apontava para a responsabilização do réu. No entanto, atento às particularidades do caso concreto, o magistrado fixou as penas de ambos os delitos no patamar mínimo previsto nos tipos penais, resultando a soma em três anos de pena privativa de liberdade.

Como advogado(a) de Ricardo, você deseja recorrer da sentença. Considerando apenas os dados descritos na questão, indique o(s) argumento(s) que melhor atenda(m) aos interesses de seu cliente.

(Valor: 1,25)

QUESTÃO 2

Larissa, senhora aposentada de 60 anos, estava na rodoviária de sua cidade quando foi abordada por um jovem simpático e bem vestido. O jovem pediu-lhe que levasse para a cidade de destino uma caixa de medicamentos para um primo, que padecia de grave enfermidade. Inocente, e seguindo seus preceitos religiosos, a Sra. Larissa atende ao rapaz: pega a caixa, entra no ônibus e segue viagem. Chegando ao local da entrega, a senhora é abordada por policiais que, ao abrirem a caixa de remédios, verificam a existência de 250 gramas de cocaína em seu interior. Atualmente, Larissa está sendo processada pelo crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Considerando a situação descrita e empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente, responda: qual a tese defensiva aplicável a Larissa? (Valor: 1,25)

QUESTÃO 3

Há muito tempo Maria encontra-se deprimida, nutrindo desejos de acabar com a própria vida. João, sabedor dessa condição, e querendo a morte de Maria, resolve instigá-la a se matar. Pondo seu plano em prática, João visita Maria todos os dias e, quando ela toca no assunto que não tem mais razão para viver, que deseja se matar, pois a vida não faz mais sentido, João a estimula e a encoraja a pular pela janela.

Um dia, logo após ser instigada por João, Maria salta pela janela de seu apartamento e, por pura sorte, sofre apenas alguns arranhões, não sofrendo qualquer ferimento grave.

Considerando apenas os fatos apresentados, responda, de forma justificada, os seguintes questionamentos:

- a) João cometeu algum crime? (Valor: 0,65)
- b) Caso Maria viesse a sofrer lesões corporais de natureza grave em decorrência da queda, a condição jurídica de João seria alterada? (Valor: 0,60)

QUESTÃO 4

Maurício, jovem de classe alta, rebelde e sem escrúpulos, começa a namorar Joana, menina de boa família, de classe menos favorecida e moradora de área de risco em uma das maiores comunidades do Brasil. No dia do aniversário de 18 anos de Joana, Maurício resolve convidá-la para jantar num dos restaurantes mais caros da cidade e, posteriormente, levá-la para conhecer a suíte presidencial de um hotel considerado um dos mais luxuosos do mundo, onde passa a noite com ela. Na manhã seguinte, Maurício e Joana resolvem permanecer por mais dois dias. Ao final da estada, Maurício contabiliza os gastos daqueles dias de prodigalidade, apurando o total de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Todos os pagamentos foram realizados em espécie, haja vista que, na noite anterior, Maurício havia trocado com sua mãe um cheque de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dinheiro em espécie, cheque que Maurício sabia, de antemão, não possuir fundos.

Considerando apenas os fatos descritos, responda, de forma justificada, os questionamentos a seguir.

- a) Maurício e Joana cometeram algum crime? Em caso positivo, tipifique as condutas atribuídas a cada um dos personagens, desenvolvendo a tese de defesa. (Valor: 0,70)
- b) Caso Maurício tivesse invadido a casa de sua mãe com uma pistola de brinquedo e a ameaçado, a fim de conseguir a quantia de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), sua situação jurídica seria diferente? (Valor: 0,55)

11.1.7 VIII Exame OAB Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Em determinada ação fiscal procedida pela Receita Federal, ficou constatado que Lucile não fez constar quaisquer rendimentos nas declarações apresentadas pela sua empresa nos anos de 2009, 2010 e 2011, omitindo operações em documentos e livros exigidos pela lei fiscal.

Iniciado processo administrativo de lançamento, mas antes de seu término, o Ministério Público entendeu por bem oferecer denúncia contra Lucile pela prática do delito descrito no art. 1.º, inciso II, da Lei 8.137/1990, combinado com o art. 71 do Código Penal. A inicial acusatória foi recebida e a defesa, intimada a apresentar resposta à acusação.

Atento(a) ao caso apresentado, bem como à orientação dominante do STF sobre o tema, responda, fundamentadamente, o que pode ser alegado em favor de Lucile.

(Valor: 1,25)

QUESTÃO 2

Abel e Felipe observavam diariamente um restaurante com a finalidade de cometer um crime. Sabendo que poderiam obter alguma vantagem sobre os clientes que o frequentavam, Abel e Felipe, sem qualquer combinação prévia, conseguiram, cada um, uniformes semelhantes aos utilizados pelos manobristas de tal restaurante.

No início da tarde, aproveitando a oportunidade em que não havia nenhum funcionário no local, a dupla, vestindo os uniformes de manobristas, permaneceu à espera de suas vítimas, mas agindo de modo separado.

Tércio, o primeiro cliente, ao chegar ao restaurante, iludido por Abel, entrega de forma voluntária a chave de seu carro. Abel, ao invés de conduzir o veículo para o estacionamento, evade-se do local. Narcísio, o segundo cliente, chega ao restaurante e não entrega a chave de seu carro, mas Felipe a subtrai sem que ele o percebesse. Felipe também se evade do local.

Empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso, responda às questões a seguir.

- a) Qual a responsabilidade jurídico-penal de Abel ao praticar tal conduta? (responda motivando sua imputação) (Valor: 0,65)
- b) Qual a responsabilidade jurídico-penal de Felipe ao praticar tal conduta? (responda motivando sua imputação) (Valor: 0,60)

QUESTÃO 3

João e José foram denunciados pela prática da conduta descrita no art. 316 do CP (concussão). Durante a instrução, percebeu-se que os fatos narrados na denúncia não corresponderiam àquilo que efetivamente teria ocorrido, razão pela qual, ao cabo da instrução criminal e após a respectiva apresentação de memoriais pelas partes, apurou-se que a conduta típica adequada seria aquela descrita no art. 317 do CP (corrupção passiva). O magistrado, então, fez remessa dos autos ao Ministério Público para fins de aditamento da denúncia, com a nova capitulação dos fatos.

Nesse sentido, atento(a) ao caso narrado e considerando apenas as informações contidas no texto, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) Estamos diante de hipótese de *mutatio libelli* ou de *emendatio libelli*? Qual dispositivo legal deve ser aplicado? (Valor: 0,50)
- b) Por que o próprio juiz, na sentença, não poderia dar a nova capitulação e, com base nela, condenar o réus? (Valor: 0,50)
- c) É possível que o Tribunal de Justiça de determinado estado da federação, ao analisar recurso de apelação, proceda à *mutatio libelli*? (Valor: 0,25)

QUESTÃO 4

João foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 299, *caput* e parágrafo único, do Código Penal. A inicial acusatória foi recebida em 30.10.2000 e o processo teve seu curso normal. A sentença

penal, publicada em 29.07.2005, condenou o réu à pena de um ano, 11 meses e dez dias de reclusão, em regime semiaberto, mais pagamento de 16 dias-multa. Irresignada, somente a defesa interpôs apelação. Todavia, o Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo, ao argumento de que não haveria que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição, haja vista o fato de que o réu era reincidente, circunstância devidamente comprovada mediante certidão cartorária juntada aos autos.

Nesse sentido, considerando apenas os dados narrados no enunciado, responda aos itens a seguir.

- a) Está extinta a punibilidade do réu pela prescrição? Em caso positivo, indique a espécie; em caso negativo, indique o motivo. (Valor: 0,75)
- b) O disposto no art. 110, *caput*, do CP é aplicável ao caso narrado? (Valor: 0,50)

11.1.8 IX Exame OAB Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Raimundo, já de posse de veículo automotor furtado de concessionária, percebe que não tem onde guardá-lo antes de vendê-lo para a pessoa que o encomendara. Assim, resolve ligar para um grande amigo seu, Henrique, e após contar toda sua empreitada, pede-lhe que ceda a garagem de sua casa para que possa guardar o veículo, ao menos por aquela noite. Como Henrique aceita ajudá-lo, Raimundo estaciona o carro na casa do amigo. Ao raiar do dia, Raimundo parte com o veículo, que seria levado para o comprador.

Considerando as informações contidas no texto, responda, justificadamente, os itens a seguir.

- a) Raimundo e Henrique agiram em concurso de agentes? (Valor: 0,75)
- b) Qual o delito praticado por Henrique? (Valor: 0,50)

QUESTÃO 2

Wilson, extremamente embriagado, discute com seu amigo Junior na calçada de um bar já vazio pelo avançado da hora. A discussão torna-se acalorada e, com intenção de matar, Wilson desfere quinze facadas em Junior, todas na altura do abdômen. Todavia, ao ver o amigo gritando de dor e esvaindo-se em sangue, Wilson, desesperado, pega um taxi para levar Junior ao hospital. Lá chegando, o socorro é eficiente e Junior consegue recuperar-se das graves lesões sofridas.

Analise o caso narrado e, com base apenas nas informações dadas, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) É cabível responsabilizar Wilson por tentativa de homicídio? (Valor: 0,65)
- b) Caso Junior, mesmo tendo sido socorrido, não se recuperasse das lesões e viesse a falecer no dia seguinte aos fatos, qual seria a responsabilidade jurídico-penal de Wilson? (Valor: 0,60)

QUESTÃO 3

Mário está sendo processado por tentativa de homicídio, uma vez que injetou substância venenosa em Luciano, com o objetivo de matá-lo. No curso do processo, uma amostra da referida substância foi

recolhida para análise e enviada ao Instituto de Criminalística, ficando comprovado que, pelas condições de armazenamento e acondicionamento, a substância não fora hábil para produzir os efeitos a que estava destinada. Mesmo assim, arguindo que o magistrado não estava adstrito ao laudo, o Ministério Público pugnou pela pronúncia de Mário nos exatos termos da denúncia.

Com base apenas nos fatos apresentados, responda justificadamente.

- a) O magistrado deveria pronunciar Mário, impronunciá-lo ou absolvê-lo sumariamente? (Valor: 0,65)
- b) Caso Mário fosse pronunciado, qual seria o recurso cabível, o prazo de interposição e a quem deveri ser endereçado? (Valor: 0,60)

QUESTÃO 4

Laura, empresária do ramo de festas e eventos, foi denunciada diretamente no Tribunal de Justiça do Estado “X”, pela prática do delito descrito no art. 333 do CP (corrupção ativa). Na mesma inicial acusatória, o Procurador-Geral de Justiça imputou a Lucas, Promotor de Justiça estadual, a prática da conduta descrita no art. 317 do CP (corrupção passiva).

A defesa de Laura, então, impetrou *habeas corpus* ao argumento de que estariam sendo violados os princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; arguiu, ainda, que estaria ocorrendo supressão de instância, o que não se poderia permitir.

Nesse sentido, considerando apenas os dados fornecidos, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) Os argumentos da defesa de Laura procedem? (Valor: 0,75)
- b) Laura possui direito ao duplo grau de jurisdição? (Valor: 0,50)

11.1.9 X Exame de Ordem Unificado – FGV¹

QUESTÃO 1

O Ministério Público, tomando conhecimento da prática de falta grave no curso de execução penal, pugna pela interrupção da contagem do prazo para efeitos de concessão do benefício do livramento condicional, fundamentando seu pleito em interpretação sistemática do art. 83, do CP, e dos arts. 112 e 118, I, ambos da Lei 7.210/1984.

Levando em conta apenas os dados contidos no enunciado, com base nos princípios do processo penal e no entendimento mais recente dos Tribunais Superiores, responda à seguinte questão:

O Ministério Público está com a razão? (Valor: 1,25)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 2

Maria, mulher solteira de 40 anos, mora no Bairro Paciência, na cidade Esperança. Por conta de seu comportamento, Maria sempre foi alvo de comentários maldosos por parte dos vizinhos; alguns até

chegavam a afirmar que ela tinha “cara de quem cometeu crime”. Não obstante tais comentários, nunca houve prova de qualquer das histórias contadas, mas o fato é que Maria é pessoa conhecida na localidade onde mora por ter má índole, já que sempre arruma brigas e inimizades.

Certo dia, com raiva de sua vizinha Josefa, Maria resolve quebrar a janela da residência desta. Para tanto, espera chegar a hora em que sabia que Josefa não estaria em casa e, após olhar em volta para ter certeza de que ninguém a observava, Maria arremessa com força, na direção da casa da vizinha, um enorme tijolo. Ocorre que Josefa, naquele dia, não havia saído de casa e o tijolo após quebrar a vidraça, atinge também sua nuca. Josefa falece instantaneamente.

Nesse sentido, tendo por base apenas as informações descritas no enunciado, responda justificadamente:

É correto afirmar que Maria deve responder por homicídio doloso consumado? (Valor: 1,25)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 3

José, conhecido em seu bairro por vender entorpecentes, resolve viajar para Foz do Iguaçu (PR). Em sua bagagem, José transporta 500 g de cocaína e 50 ampolas de cloreto de etila. Em Foz do Iguaçu, José foi preso em flagrante pela Polícia Militar em virtude do transporte das substâncias entorpecentes. Na lavratura do flagrante, José afirma que seu objetivo era transportar a droga até a cidade de Porto Vera Cruz (RS), mencionando inclusive a passagem de avião que já havia comprado.

Você é contratado para efetuar um pedido de liberdade provisória e o que mais entender de Direito em favor de José.

Atento somente ao que foi narrado na hipótese, responda aos itens a seguir.

- a) O órgão competente para julgamento é a Justiça Estadual ou a Justiça Federal? Justifique. (Valor: 0,75)
- b) Se José objetivasse apenas traficar drogas em Foz do Iguaçu, o órgão competente seria o mesmo d respondido no item A? Justifique. (Valor: 0,50)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 4

Erika e Ana Paula, jovens universitárias, resolvem passar o dia em uma praia paradisíaca e de difícil acesso (feito por meio de uma trilha), bastante deserta e isolada, tão isolada que não há qualquer estabelecimento comercial no local e nem mesmo sinal de telefonia celular. As jovens chegam bastante cedo e, ao chegarem, percebem que além delas há somente um salva-vidas na praia. Ana Paula decide dar um mergulho no mar, que estava bastante calmo naquele dia. Erika, por sua vez, sem saber nadar, decide puxar assunto com o salva-vidas, Wilson, pois o achou muito bonito. Durante a conversa, Erika e Wilson percebem que têm vários interesses em comum e ficam encantados um pelo outro. Ocorre que, nesse intervalo de tempo, Wilson percebe que Ana Paula está se afogando. Instigado por Erika, Wilson decide não efetuar o salvamento, que era perfeitamente possível. Ana Paula, então, acaba morrendo

afogada.

Nesse sentido, atento(a) apenas ao caso narrado, indique a responsabilidade jurídico-penal de Erika e Wilson. (Valor: 1,25)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

11.1.10 XI Exame de Ordem Unificado – FGV²

QUESTÃO 1

O Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca “Y” converteu a medida restritiva de direitos (que fora imposta em substituição à pena privativa de liberdade) em cumprimento de pena privativa de liberdade imposta no regime inicial aberto, sem fixar quaisquer outras condições. O Ministério Público, inconformado, interpôs recurso alegando, em síntese, que a decisão do referido Juiz da Vara de Execuções Penais acarretava o abrandamento da pena, estimulando o descumprimento das penas alternativas ao cárcere.

O recurso, devidamente contra-arrazado, foi submetido a julgamento pela Corte Estadual, a qual, de forma unânime, resolveu lhe dar provimento. A referida Corte fixou como condição especial ao cumprimento de pena no regime aberto, com base no art. 115 da LEP, a prestação de serviços à comunidade, o que deveria perdurar por todo o tempo da pena a ser cumprida no regime menos gravoso.

Atento ao caso narrado e considerando apenas os dados contidos no enunciado, responda fundamentadamente aos itens a seguir.

- a) Qual foi o recurso interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Juiz da Vara de Execuções Penais? (Valor: 0,50)
- b) Está correta a decisão da Corte Estadual, levando-se em conta entendimento jurisprudencial sumulado? (Valor: 0,75)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 2

Daniel foi denunciado, processado e condenado pela prática do delito de roubo simples em sua modalidade tentada. A pena fixada pelo magistrado foi de dois anos de reclusão em regime aberto. Todavia, atento às particularidades do caso concreto, o referido magistrado concedeu-lhe o benefício da suspensão condicional da execução da pena, sendo certo que, na sentença, não fixou nenhuma condição. Somente a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição de Daniel com base na tese de negativa de autoria e, subsidiariamente, a substituição do benefício concedido por uma pena restritiva de direitos. O Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento da apelação, de forma unânime, negou provimento aos dois pedidos da defesa e, no acórdão, fixou as condições do *sursis*, haja vista o fato de que o magistrado *a quo* deixou de fazê-lo na sentença condenatória.

Nesse sentido, atento apenas às informações contidas no texto, responda, fundamentadamente, aos

itens a seguir:

- a) Qual o recurso cabível contra a decisão do Tribunal de Justiça? (Valor: 0,55)
- b) Qual deve ser a principal linha de argumentação no recurso? (Valor: 0,70)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 3

Ricardo cometeu um delito de roubo no dia 10.11.2007, pelo qual foi condenado no dia 29.08.2009, sendo certo que o trânsito em julgado definitivo de referida sentença apenas ocorreu em 15.05.2010. Ricardo também cometeu, no dia 10.09.2009, um delito de extorsão. A sentença condenatória relativa ao delito de extorsão foi prolatada em 18.10.2010, tendo transitado definitivamente em julgado no dia 07.04.2011. Ricardo também praticou, no dia 12.03.2010, um delito de estelionato, tendo sido condenado em 25.05.2011. Tal sentença apenas transitou em julgado no dia 27.07.2013.

Nesse sentido, tendo por base apenas as informações contidas no enunciado, responda aos itens a seguir:

- a) O juiz, na sentença relativa ao crime de roubo, deve considerar Ricardo portador de bons ou maus antecedentes? (Valor: 0,25)
- b) O juiz, na sentença relativa ao crime de extorsão, deve considerar Ricardo portador de bons ou maus antecedentes? Na hipótese, incide a circunstância agravante da reincidência ou Ricardo ainda pode ser considerado réu primário? (Valor: 0,50)
- c) O juiz, na sentença relativa ao crime de estelionato, deve considerar Ricardo portador de bons ou maus antecedentes? Na hipótese, incide a circunstância agravante da reincidência ou Ricardo ainda pode ser considerado réu primário? (Valor: 0,50)

Utilize os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 4

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Lucile, imputando-lhe a prática da conduta descrita no art. 155, *caput*, do CP. Narrou a inicial acusatória que no dia 18.10.2012 Lucile subtraiu, sem violência ou grave ameaça, de um grande estabelecimento comercial do ramo de venda de alimentos, dois litros de leite e uma sacola de verduras, o que totalizou a quantia de R\$ 10,00 (dez reais). Todas as exigências legais foram satisfeitas: a denúncia foi recebida, foi oferecida suspensão condicional do processo e foi apresentada resposta à acusação.

O magistrado, entretanto, após convencer-se pelas razões invocadas na referida resposta à acusação, entende que a fato é atípico.

Nesse sentido, tendo como base apenas as informações contidas no enunciado, responda, justificadamente, aos itens a seguir.

- a) O que o magistrado deve fazer? Indique o fundamento legal. (Valor: 0,65)
- b) Qual é o elemento ausente que justifica a alegada atipicidade? (Valor: 0,60)

Utilize os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

11.1.11 XII Exame de Ordem Unificado – FGV³

QUESTÃO 1

Carolina foi denunciada pela prática do delito de estelionato, mediante emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos. Narra a inicial acusatória que Carolina emitiu o cheque número 000, contra o Banco ABC S.A., quando efetuou compra no estabelecimento “X”, que fica na cidade de “Y”. Como a conta-corrente de Carolina pertencia à agência bancária que ficava na cidade vizinha “Z”, a gerência da loja, objetivando maior rapidez no recebimento, resolveu lá apresentar o cheque, ocasião em que o título foi devolvido.

Levando em conta que a compra originária da emissão do cheque sem fundos ocorreu na cidade “Y”, o Ministério Público local fez o referido oferecimento da denúncia, a qual foi recebida pelo juízo da 1.^a Vara Criminal da comarca.

Tal magistrado, após o recebimento da inicial acusatória, ordenou a citação da ré, bem como a intimação para apresentar resposta à acusação.

Nesse sentido, atento(a) apenas às informações contidas no enunciado, responda de maneira fundamentada, e levando em conta o entendimento dos Tribunais Superiores, o que pode ser arguido em favor de Carolina. (Valor: 1,25)

QUESTÃO 2

Ricardo é delinquente conhecido em sua localidade, famoso por praticar delitos contra o patrimônio sem deixar rastros que pudessem incriminá-lo. Já cansando da impunidade, Wilson, policial e irmão de uma das vítimas de Ricardo, decide que irá empenhar todos os seus esforços na busca de uma maneira para prender, em flagrante, o facínora.

Assim, durante meses, se faz passar por amigo de Ricardo e, com isso, ganhar a confiança deste. Certo dia, decidido que havia chegado a hora, pergunta se Ricardo poderia ajudá-lo na próxima empreitada. Wilson diz que elaborou um plano perfeito para assaltar uma casa lotérica e que bastaria ao amigo seguir as instruções. O plano era o seguinte: Wilson se faria passar por um cliente da casa lotérica e, percebendo o melhor momento, daria um sinal para que Ricardo entrasse no referido estabelecimento e anunciasse o assalto, ocasião em que o ajudaria a render as pessoas presentes. Confiante nas suas próprias habilidades e empolgado com as ideias dadas por Wilson, Ricardo aceita. No dia marcado por ambos, Ricardo, seguindo o roteiro traçado por Wilson, espera o sinal e, tão logo o recebe, entra na casa lotérica e anuncia o assalto. Todavia, é surpreendido ao constatar que tanto Wilson quanto todos os “clientes” presentes na casa lotérica eram policiais disfarçados. Ricardo acaba sendo preso em flagrante, sob os aplausos da comunidade e dos demais policiais, contentes pelo sucesso do flagrante. Levado à delegacia, o delegado de plantão imputa a Ricardo a prática do delito de

roubo na modalidade tentada.

Nesse sentido, atento tão somente às informações contidas no enunciado, responda justificadamente:

- a) Qual a espécie de flagrante sofrido por Ricardo? (Valor: 0,80)
- b) Qual é a melhor tese defensiva aplicável à situação de Ricardo relativamente à sua responsabilidade jurídico-penal? (Valor: 0,45)

QUESTÃO 3

Félix, objetivando matar Paola, tenta desferir-lhe diversas facadas, sem, no entanto, acertar nenhuma. Ainda na tentativa de atingir a vítima, que continua a esquivar-se dos golpes, Félix, aproveitando-se do fato de que conseguiu segurar Paola pela manga da camisa, empunha a arma. No momento, então, que Félix movimenta seu braço para dar o golpe derradeiro, já quase atingindo o corpo da vítima com a faca, ele opta por não continuar e, em seguida, solta Paola, que sai correndo sem ter sofrido sequer um arranhão, apesar do susto.

Nesse sentido, com base apenas nos dados fornecidos, poderá Félix ser responsabilizado por tentativa de homicídio? Justifique. (Valor: 1,25)

A resposta que contenha apenas as expressões “sim” ou “não” não será pontuada, bem como a mera indicação de artigo legal ou a resposta que apresente teses contraditórias.

QUESTÃO 4

Marcos, jovem inimputável conforme o art. 26 do CP, foi denunciado pela prática de determinado crime. Após o regular andamento do feito, o magistrado entendeu por bem aplicar medida de segurança consistente em internação em hospital psiquiátrico por período mínimo de três anos. Após o cumprimento do período supramencionado, o advogado de Marcos requer ao juízo de execução que seja realizado o exame de cessação de periculosidade, requerimento que foi deferido. É realizada uma rigorosa perícia, e os *experts* atestam a cura do internado, opinando, conseqüentemente, por sua desinternação. O magistrado, então, baseando-se no exame pericial realizado por médicos psiquiatras, exara sentença determinando a desinternação de Marcos. O *Parquet*, devidamente intimado da sentença proferida pelo juízo da execução, interpõe o recurso cabível na espécie.

A partir do caso apresentado, responda, fundamentadamente, os itens a seguir.

- a) Qual o recurso cabível da sentença proferida pelo magistrado determinando a desinternação de Marcos? (Valor: 0,75)
- b) Qual o prazo para interposição desse recurso? (Valor: 0,25)
- c) A interposição desse recurso suspende ou não a eficácia da sentença proferida pelo magistrado? (Valor: 0,25)

11.1.12 XIII Exame de Ordem Unificado – FGV⁴

QUESTÃO 1

Gustavo, retornando para casa depois de ir a uma festa com sua esposa, é parado em uma *blitz* de rotina. Ele fica bastante nervoso, pois sabe que seu carro está com a documentação totalmente irregular (IPVA atrasado, multas vencidas e vistoria não realizada) e, muito provavelmente, o veículo será rebocado para o depósito. Após determinar a parada do veículo, o policial solicita que Gustavo saia do carro e exiba os documentos. Como havia diversos outros carros parados na fiscalização, forma-se uma fila de motoristas. Gustavo, então, em pé, na fila, aguardando sua vez para exibir a documentação, fala baixinho à sua esposa: “Vou ver se tem jogo. Vou oferecer cem reais pra ele liberar a gente. O que você acha? Será que dá?”. O que Gustavo não sabia, entretanto, é que exatamente atrás dele estava um policial que tudo escutara e, tão logo acaba de proferir as palavras à sua esposa, Gustavo é preso em flagrante. Atordoadado, ele pergunta: “O que eu fiz?”, momento em que o policial que efetuava o flagrante responde: “Tentativa de corrupção ativa!”.

Atento(a) ao caso narrado e tendo como base apenas as informações descritas no enunciado, responda justificadamente os itens a seguir.

- a) É correto afirmar que Gustavo deve responder por tentativa de corrupção ativa? (Valor: 0,70)
- b) Caso o policial responsável por fiscalizar os documentos, observando a situação irregular de Gustavo solicitasse quantia em dinheiro para liberá-lo e, Gustavo, por medo, pagasse tal quantia, ele (Gustavo) responderia por corrupção ativa? (Valor: 0,55)

O mero “sim” ou “não”, desprovido de justificativa ou mesmo com a indicação de justificativa inaplicável ao caso, não será pontuado.

QUESTÃO 2

Antônio, auxiliar de serviços gerais de uma multinacional, nos dias de limpeza, passa a observar uma escultura colocada na mesa de seu chefe. Com o tempo, o desejo de ter aquele objeto fica incontrolável, razão pela qual ele decide subtraí-lo.

Como Antônio não tem acesso livre à sala onde a escultura fica exposta, utiliza-se de uma chave adaptável a qualquer fechadura, adquirida por meio de um amigo chaveiro, que nada sabia sobre suas intenções. Com ela, Antônio ingressa na sala do chefe, após o expediente de trabalho, e subtrai a escultura pretendida, colocando-a em sua bolsa.

Após subtrair o objeto e sair do edifício onde fica localizada a empresa, Antônio caminha tranquilamente cerca de 400 metros. Apenas nesse momento é que os seguranças da portaria suspeitam do ocorrido. Eles acham estranha a saída de Antônio do local após o expediente (já que não era comum a realização de horas extras), razão pela qual acionam policiais militares que estavam próximos do local, apontando Antônio como suspeito. Os policiais conseguem alcançá-lo e decidem revistá-lo, encontrando a escultura da sala do chefe na sua bolsa. Preso em flagrante, Antônio é conduzido até a Delegacia de Polícia.

Antônio, então, é denunciado e regularmente processado. Ocorre que, durante a instrução processual, verifica-se que a escultura subtraída, apesar de bela, foi construída com material barato, avaliada em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sendo, portanto, de pequeno valor. A FAC (folha de

antecedentes criminais) aponta que Antônio é réu primário.

Ao final da instrução, em que foram respeitadas todas as exigências legais, o juiz, em decisão fundamentada, condena Antônio a dois anos de reclusão pela prática do crime de furto qualificado pela utilização de chave falsa, consumado, com base no art. 155, § 4.º, III, do CP.

Nesse sentido, levando em conta apenas os dados contidos no enunciado, responda os itens a seguir.

- a) É correto afirmar que o crime de furto praticado por Antônio atingiu a consumação? Justifique. (Valor: 0,40)
- b) Considerando que Antônio não preenche os requisitos elencados pelo STF e STJ para aplicação do princípio da insignificância, qual seria a principal tese defensiva a ser utilizada em sede de apelação? Justifique. (Valor: 0,85)

O examinando deve fundamentar corretamente sua resposta. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 3

Jeremias foi preso em flagrante, no Aeroporto Internacional de Arroiozinho, quando tentava viajar para Madri, Espanha, transportando três tabletas de cocaína. Quando já havia embarcado na aeronave, foi “convidado” por agentes da Polícia Federal a se retirar do avião e acompanhá-los até o local onde se encontravam as bagagens. Lá chegando, foi solicitado a Jeremias que reconhecesse e abrisse sua bagagem, na qual foram encontrados, dentro da capa que acondicionava suas pranchas de *surf*, três tabletas de cocaína. Por essa razão, Jeremias foi processado e, ao final, condenado pela Justiça Federal de Arroiozinho por tráfico internacional de entorpecentes.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi expedido o mandado de prisão e Jeremias foi recolhido ao estabelecimento prisional sujeito à administração estadual, já que em Arroiozinho não há estabelecimento prisional federal. Transcorrido o prazo legal e tendo em vista que Jeremias preenchia os demais requisitos previstos na legislação, seu advogado deseja requerer a mudança para regime prisional menos severo.

Responda de forma fundamentada, de acordo com a jurisprudência sumulada dos Tribunais Superiores: Qual Justiça é competente para processar e julgar o pedido de Jeremias? (Valor: 1,25)

A mera indicação da Súmula não pontua.

QUESTÃO 4

Pedro foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Após a instrução probatória, o juiz ficou convencido de que o réu, por preencher os requisitos do art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, merecia a redução máxima da pena. Na sentença penal condenatória, fixou o regime inicialmente fechado ao argumento de que o art. 2.º, § 1.º, da Lei 8.072/1990 assim determina, vedando a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, com base no próprio art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006. O advogado de Pedro é intimado da sentença.

À luz da jurisprudência do STF, responda os itens a seguir.

- a) Cabe ao advogado de defesa a impugnação da fixação do regime inicial fechado, fixado exclusivamente com base no art. 2.º, § 1.º, da Lei 8.072/1990? (Valor: 0,60)
- b) Com relação ao tráfico privilegiado, previsto na Lei 11.343/2006, art. 33, § 4.º, é possível a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos? (Valor: 0,65)

O examinando deve fundamentar corretamente sua resposta. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

11.1.13 XIV Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Gustavo está sendo regularmente processado, perante o Tribunal do Júri da Comarca de Niterói-RJ, pela prática do crime de homicídio simples, conexo ao delito de sequestro e cárcere privado. Os jurados o consideraram inocente em relação ao delito de homicídio, mas culpado no tocante ao delito de sequestro e cárcere privado. O juiz presidente, então, proferiu a respectiva sentença. Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, sustentando que a decisão dos jurados fora manifestamente contrária à prova dos autos. A defesa, de igual modo, apelou, objetivando também a absolvição em relação ao delito de sequestro e cárcere privado.

O Tribunal de Justiça, no julgamento, negou provimento aos apelos, mas determinou a anulação do processo (desde o ato viciado, inclusive) com base no art. 564, III, “I”, do CPP, porque restou verificado que, para a constituição do Júri, somente estavam presentes 14 jurados.

Nesse sentido, tendo como base apenas as informações contidas no enunciado, responda justificadamente às questões a seguir.

- a) A nulidade apresentada pelo Tribunal é absoluta ou relativa? Dê o respectivo fundamento legal. (Valor 0,40)
- b) A decisão do Tribunal de Justiça está correta? (Valor: 0,85)

Utilize os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

QUESTÃO 2

Mário foi condenado a 24 anos de reclusão no regime inicialmente fechado, com trânsito em julgado no dia 20.04.2005, pela prática de latrocínio (art. 157, § 3.º, parte final, do Código Penal). Iniciou a execução da pena no dia seguinte. No dia 22.04.2009, seu advogado, devidamente constituído nos autos da execução penal, ingressou com pedido de progressão de regime, com fulcro no art. 112 da Lei de Execuções Penais. O juiz indeferiu o pedido com base no art. 2.º, § 2.º, da Lei 8.072/1990, argumentando que o condenado não preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime.

Como advogado de Mário, responda, de forma fundamentada e de acordo com o entendimento sumulado dos Tribunais Superiores, os itens a seguir:

- a) Excetuando-se a possibilidade de *habeas corpus*, qual recurso deve ser interposto pelo advogado de

Mário e qual o respectivo fundamento legal? (Valor: 0,40)

b) Qual a principal tese defensiva? (Valor: 0,85)

O examinando deve fundamentar corretamente sua resposta. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 3

Daniel, Ana Paula, Leonardo e Mariana, participantes da quadrilha “X”, e Carolina, Roberta, Cristiano, Juliana, Flavia e Ralph, participantes da quadrilha “Y”, fazem parte de grupos criminosos especializados em assaltar agências bancárias. Após intensos estudos sobre divisão de tarefas, locais, armas, bancos etc., ambos os grupos, sem ciência um do outro, planejaram viajar até a pacata cidade de Arroizinho com o intuito de ali realizarem o roubo. Cumpre ressaltar que, na cidade de Arroizinho, havia apenas duas únicas agências bancárias, a saber: uma agência do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, e outra da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal. No dia marcado, os integrantes da quadrilha “X” praticaram o crime objetivado contra o Banco do Brasil; os integrantes da quadrilha “Y” o fizeram contra a Caixa Econômica Federal. Cada grupo, com sua conduta, conseguiu auferir a vultosa quantia de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Nesse caso, atento tão somente aos dados contidos no enunciado, responda fundamentadamente de acordo com a Constituição:

a) Qual a justiça competente para o processo e julgamento do crime cometido pela quadrilha “Y”? (Valor 0,65)

b) Qual a justiça competente para o processo e julgamento do crime cometido pela quadrilha “X”? (Valor 0,60)

QUESTÃO 4

Cristiano foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 171 do Código Penal. No curso da instrução criminal, o magistrado que presidia o feito decretou a prisão preventiva do réu, com o intuito de garantir a ordem pública, “já que o crime causou grave comoção social, além de tratar-se de um crime grave, que coloca em risco a integridade social, configurando conduta inadequada ao meio social”.

O advogado de Cristiano, inconformado com a fundamentação da medida constritiva de liberdade, impetrou *habeas corpus* perante o Tribunal de Justiça, no intuito de relaxar tal prisão, já que a considerava ilegal, tendo em vista que toda decisão judicial deve estar amparada em uma fundamentação idônea.

O Tribunal de Justiça, por unanimidade, não concedeu a ordem, entendendo que a decisão que decretou a prisão preventiva estava corretamente fundamentada.

De acordo com a jurisprudência atualizada dos Tribunais Superiores, responda aos itens a seguir.

a) Qual o recurso que o advogado de Cristiano deve manejar visando à reforma do acórdão? (Valor: 0,6

b) Qual o prazo e para qual Tribunal deverá ser dirigido? (Valor: 0,60)

11.1.14 XV Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Miguel foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, V, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de cinco anos e quatro meses de reclusão e 13 dias-multa. Após cumprir quatro anos da reprimenda penal aplicada, foi publicado, no dia 24.12.2013, um Decreto prevendo que caberia indulto para o condenado à pena privativa de liberdade não superior a oito anos que tivesse cumprido 1/3 da pena, se primário, ou 1/2, se reincidente, além da inexistência de aplicação de sanção pela prática de falta grave nos 12 meses anteriores ao Decreto. Cinco dias após a publicação do Decreto, mas antes de apreciado seu pedido de indulto, Miguel praticou falta grave, razão pela qual teve seu requerimento indeferido pelo Juiz em atuação junto à Vara de Execução Penal.

Considerando apenas as informações contidas na presente hipótese, responda aos itens a seguir.

- a) Qual medida processual, diferente do *habeas corpus*, deve ser adotada pelo advogado de Miguel e qual seria o seu prazo? (Valor: 0,75)
- b) Miguel faz jus ao benefício do indulto? (Valor: 0,50)

O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 2

Durante inquérito policial que investigava a prática do crime de extorsão mediante sequestro, esgotado o prazo sem o fim das investigações, a autoridade policial encaminhou os autos para o Judiciário, requerendo apenas a renovação do prazo. O magistrado, antes de encaminhar o feito ao Ministério Público, verificando a gravidade em abstrato do crime praticado, decretou a prisão preventiva do investigado.

Considerando a narrativa apresentada, responda aos itens a seguir.

- a) Poderia o magistrado adotar tal medida? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) A fundamentação apresentada para a decretação da preventiva foi suficiente? Justifique. (Valor: 0,60)

O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 3

A Receita Federal identificou que Raquel possivelmente sonegou Imposto sobre a Renda, causando prejuízo ao erário no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Foi instaurado, então, procedimento administrativo, não havendo, até o presente momento, lançamento definitivo do crédito tributário. Ao mesmo tempo, a Receita Federal expediu ofício informando tais fatos ao Ministério Público Federal, que, considerando a autonomia das instâncias, ofereceu denúncia em face de Raquel pela prática do crime previsto no art. 1.º, I, da Lei 8.137/1990.

Assustada com a ratificação do recebimento da denúncia após a apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública, Raquel o procura para, na condição de advogado, tomar as medidas cabíveis.

Diante disso, responda aos itens a seguir.

- a) Qual a medida jurídica a ser adotada de imediato para impedir o prosseguimento da ação penal? (Valor: 0,60)
- b) Qual a principal tese jurídica a ser apresentada? (Valor: 0,65)

QUESTÃO 4

No dia 06.07.2010, Júlia, nascida em 06.04.1991, aproveitando-se de um momento de distração de Ricardo, subtraiu-lhe a carteira. Após recebimento da denúncia, em 11.08.2011, e regular processamento do feito, Júlia foi condenada a uma pena privativa de liberdade de um ano de reclusão, em sentença publicada em 08.10.2014. Nem o Ministério Público nem a defesa de Júlia interpuseram recurso, tendo o feito transitado em julgado em 22.10.2014.

Sobre esses fatos, responda aos itens a seguir.

- a) Diante do trânsito em julgado, qual a tese defensiva a ser alegada em favor de Júlia para impedir o cumprimento da pena? (Valor: 0,75)
- b) Quais as consequências do acolhimento da tese defensiva? (Valor: 0,50)

O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

11.1.15 XVI Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Carlos foi condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, sendo sua conduta tipificada da seguinte forma: art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal. A pena ficou estabelecida em cinco anos de reclusão em regime fechado para o crime de tráfico e um ano de detenção em regime semiaberto pelo crime de posse de arma de fogo. Apenas a defesa técnica apelou, requerendo a mudança do regime de pena aplicado para o crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo o feito transitado em julgado para a acusação. O recurso foi desprovido. Todavia, de ofício, sem reflexo no *quantum*, que permaneceu em seis anos de pena privativa de liberdade, o Tribunal reclassificou o fato para o art. 33 c/c o art. 40, IV, da Lei 11343/2006, afastando o crime autônomo da lei de armas e aplicando a causa de aumento respectiva.

Considerando as informações narradas na hipótese, responda aos itens a seguir.

- a) Poderia ser aplicado regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, *caput*, da Lei 11.343/2006? (Valor: 0,60)
- b) Poderia o Tribunal de Justiça em sede de recurso da defesa realizar a reclassificação adotada? (Val

0,65)

Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

QUESTÃO 2

No dia 03.05.2008, Luan foi condenado à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão pela prática dos crimes previstos nos arts. 213 e 214 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, pois, no dia 11.07.2007, por volta das 19 horas, constrangeu Carla, mediante grave ameaça, a com ele praticar conjunção carnal e ato libidinoso diverso. Ainda cumprindo pena em razão dessa sentença condenatória, Luan, conversando com outro preso, veio a saber que ele havia sido condenado por fatos extremamente semelhantes a uma pena de sete anos de reclusão. Luan, então, pergunta o nome do advogado do colega de cela, que lhe fornece a informação. Luan entra em contato pelo telefone indicado e pergunta se algo pode ser feito para reduzir sua pena, apesar de sua decisão ter transitado em julgado.

Diante dessa situação, responda aos itens a seguir.

- a) Qual a tese de direito material que poderia ser suscitada pelo novo advogado em favor de Luan? (Val 0,65)
- b) A pretensão deverá ser manejada perante qual órgão? (Valor: 0,60)

Sua resposta deve ser fundamentada. A simples citação do dispositivo legal não será pontuada.

QUESTÃO 3

Em uma discussão de futebol, Rubens e Enrico, em comunhão de ações e desígnios, chamaram Eduardo de “ladrão” e “estelionatário”, razão pela qual Eduardo formulou uma queixa-crime em face de ambos. No curso da ação penal, porém, Rubens procurou Eduardo para pedir desculpas pelos seus atos, razão pela qual Eduardo expressamente concedeu perdão do ofendido em seu favor, sendo esse prontamente aceito e, conseqüentemente, extinta a punibilidade de Rubens. Eduardo, contudo, se recusou a conceder o perdão para Enrico, pois disse que não era a primeira vez que o querelado tinha esse tipo de atitude.

Considerando apenas as informações narradas, responda aos itens a seguir.

- a) Qual o crime praticado, em tese, por Rubens e Enrico? (Valor: 0,60)
- b) Que argumento poderá ser formulado pelo advogado de Enrico para evitar sua punição? (Valor: 0,65)

Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

QUESTÃO 4

Wesley, estudante, foi preso em flagrante no dia 03 de março de 2015 porque conduzia um veículo automotor que sabia ser produto de crime pretérito registrado em Delegacia da área em que residia. Na data dos fatos, Wesley tinha 20 anos, era primário, mas existia um processo criminal em curso em seu

desfavor, pela suposta prática de um crime de furto qualificado. Diante dessa anotação em sua Folha de Antecedentes Criminais, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, afirmando que existiria risco concreto para a ordem pública, pois o indiciado possuía outros envolvimento com o aparato judicial. Você, como advogado(a) indicado por Wesley, é comunicado da ocorrência da prisão em flagrante, além de tomar conhecimento da representação formulada pelo Delegado. Da mesma forma, o comunicado de prisão já foi encaminhado para o Ministério Público e para o magistrado, sendo todas as legalidades da prisão em flagrante observadas.

Considerando as informações narradas, responda aos itens a seguir.

- a) Qual a medida processual, diferente de *habeas corpus*, a ser adotada pela defesa técnica de Wesley (Valor: 0,50)
- b) A representação da autoridade policial foi elaborada de modo adequado? (Valor: 0,75)

Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

11.1.16 XVII Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Rodrigo, primário e de bons antecedentes, quando passava em frente a um estabelecimento comercial que estava fechado por ser domingo, resolveu nele ingressar. Após romper o cadeado da porta principal, subtraiu do seu interior algumas caixas de cigarro. A ação não foi notada por qualquer pessoa. Todavia, quando caminhava pela rua com o material subtraído, veio a ser abordado por policiais militares, ocasião em que admitiu a subtração e a forma como ingressou no comércio lesado. O material furtado foi avaliado em R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), sendo integralmente recuperado. A perícia não compareceu ao local para confirmar o rompimento de obstáculo. O autor do fato foi denunciado como incurso nas sanções penais do art. 155, § 4.º, I, do Código Penal. As únicas testemunhas de acusação foram os policiais militares, que confirmaram que apenas foram responsáveis pela abordagem do réu, que confessou a subtração. Disseram não ter comparecido, porém, ao estabelecimento lesado. Em seu interrogatório, Rodrigo confirmou apenas que subtraiu os cigarros do estabelecimento, recusando-se a responder qualquer outra pergunta. A defesa técnica de Rodrigo é intimada para apresentar alegações finais por memoriais.

Com base na hipótese apresentada, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) Diante da confissão da prática do crime de furto por Rodrigo, qual a principal tese defensiva em relação à tipificação da conduta a ser formulada pela defesa técnica? (Valor: 0,65)
- b) Em caso de acolhimento da tese defensiva, poderá Rodrigo ser, de imediato, condenado nos termos da manifestação da defesa técnica? (Valor: 0,60)

Sua resposta deve ser fundamentada. A simples menção do dispositivo legal não será pontuada.

QUESTÃO 2

Glória, esposa ciumenta de Jorge, inicia uma discussão com o marido no momento em que ele chega do trabalho à residência do casal. Durante a discussão, Jorge faz ameaças de morte à Glória, que, de imediato comparece à Delegacia, narra os fatos, oferece representação e solicita medidas protetivas de urgência. Encaminhados os autos para o Ministério Público, este requer em favor de Glória a medida protetiva de proibição de aproximação, bem como a prisão preventiva de Jorge, com base no art. 313, III, do CPP. O juiz acolhe os pedidos do Ministério Público e Jorge é preso.

Novamente os autos são encaminhados para o Ministério Público, que oferece denúncia pela prática do crime do art. 147 do Código Penal. Antes do recebimento da inicial acusatória, arrependida, Glória retorna à Delegacia e manifesta seu interesse em não mais prosseguir com o feito.

A família de Jorge o procura em busca de orientação, esclarecendo que o autor é primário e de bons antecedentes. Considerando apenas a situação narrada, na condição de advogado(a) de Jorge, esclareça os seguintes questionamentos formulados pelos familiares:

- a) A prisão de Jorge, com fundamento no art. 313, III, do Código de Processo Penal, é válida? (Valor: 0,60)
- b) É possível a retratação do direito de representação por parte de Glória? Em caso negativo, explice as razões; em caso positivo, esclareça os requisitos. (Valor: 0,65)

O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 3

Ruth voltava para sua casa falando ao celular, na cidade de Santos, quando foi abordada por Antônio, que afirmou: “Isso é um assalto! Passa o celular ou verá as consequências!”. Diante da grave ameaça, Ruth entregou o telefone e o agente fugiu em sua motocicleta em direção à cidade de Mogi das Cruzes, consumando o crime. Nervosa, Ruth narrou o ocorrido para o genro Thiago, que saiu em seu carro, junto com um policial militar, à procura de Antônio.

Com base na placa da motocicleta anotada por Ruth, Thiago localizou Antônio, já em Mogi das Cruzes, ainda na posse do celular da vítima e também com uma faca em sua cintura, tendo o policial efetuado a prisão em flagrante. Em razão dos fatos, Antônio foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, I, do Código Penal, perante uma Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes, ficando os familiares do réu preocupados, porque todos da região sabem que o magistrado, em atuação naquela Vara, é extremamente severo. A defesa foi intimada a apresentar resposta à acusação.

Considerando que o flagrante foi regular e que os fatos são verdadeiros, responda, na qualidade de advogado(a) de Antônio, aos itens a seguir.

- a) Que medida processual poderia ser adotada para evitar o julgamento perante a Vara Criminal de Mogi das Cruzes? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) No mérito, caso Antônio confesse os fatos durante a instrução, qual argumento de direito material poderia ser formulado para garantir uma punição mais branda do que a pleiteada na denúncia? Justifique. (Valor: 0,60)

O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere

pontuação.

QUESTÃO 4

No interior de uma casa de festas, Paulo estava bebendo whisky com sua namorada Roberta para comemorar um ano de namoro. Em determinado momento, chegou Flávio ao local, ex-namorado de Roberta, indo de imediato cumprimentá-la. Insatisfeito, Paulo foi em direção a Flávio e desferiu três socos em sua cabeça, causando lesões corporais gravíssimas. Paulo foi denunciado pela prática do crime do art. 129, § 2.º, do Código Penal, sendo absolvido em sentença de primeiro grau, entendendo o magistrado que, apesar de Paulo ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica conscientemente, a embriaguez não foi voluntária, logo, naquele momento, Paulo era inimputável. Flávio procura você na condição de advogado, esclarece que não houve habilitação como assistente de acusação e informa que o prazo de recurso do Ministério Público se esgotou no dia anterior, tendo o Promotor se mantido inerte.

Considerando a situação hipotética, na condição de advogado de Flávio, responda aos itens a seguir.

- a) Qual medida processual deve ser adotada pelo ofendido para superar a decisão do magistrado e em qual prazo? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Qual argumento de direito material a ser alegado para combater a decisão de primeiro grau? Justifique. (Valor: 0,60)

O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

11.1.17 XVIII Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

No dia 2 de março de 2008, Karen, 30 anos, funcionária do caixa do Supermercado Rei, subtraiu para si a quantia de R\$ 700,00 (setecentos reais) do estabelecimento, ao final de seu expediente. No dia seguinte, percebendo a facilidade ocorrida no dia anterior, Karen voltou a subtrair determinada quantia do caixa do supermercado. Ainda na mesma semana, a funcionária, com o mesmo *modus operandi*, subtraiu, por mais duas vezes, valores pertencentes ao estabelecimento comercial. Ocorre que as condutas de Karen foram filmadas e os vídeos foram encaminhados para o Ministério Público, que ofereceu denúncia pela prática do crime descrito no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal. Em 20 de abril de 2008, a denúncia foi recebida, tendo o feito seu regular processamento, até que, em 25 de abril de 2012, foi publicada decisão condenando Karen à pena final de 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias multa, substituída por restritiva de direitos. Para cada um dos crimes foi aplicada a pena mínima de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, mas fixou o magistrado a fração de 1/4 para aumento da pena, em virtude do reconhecimento do crime continuado. As partes não interpuseram recurso de apelação.

Considerando que não existe mais possibilidade de interposição de recurso da decisão, responda os itens a seguir.

- a) Qual a tese defensiva a ser alegada, de modo a impedir que Karen cumpra a pena que lhe foi

aplicada? Fundamente. (Valor: 0,65)

- b) Quais as consequências jurídicas do acolhimento dessa tese? Aquela condenação poderá ser considerada para efeito de reincidência futuramente? (Valor: 0,60)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 2

No dia 10 de fevereiro de 2012, João foi condenado pela prática do delito de quadrilha armada, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Considerando as particularidades do caso concreto, sua pena foi fixada no máximo de 6 anos de reclusão, eis que duplicada a pena base por força da quadrilha ser armada. A decisão transitou em julgado. Enquanto cumpria pena, entrou em vigor a Lei 12.850/2013, que alterou o artigo pelo qual João fora condenado. Apesar da sanção em abstrato, excluídas as causas de aumento, ter permanecido a mesma (reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos), o aumento de pena pelo fato da associação ser armada passou a ser de até a metade e não mais do dobro.

Procurado pela família de João, responda os itens a seguir.

- a) O que a defesa técnica poderia requerer em favor dele? (Valor: 0,65)
- b) Qual o juízo competente para a formulação desse requerimento? (Valor: 0,60) *Obs.: sua resposta de ser fundamentada. A simples citação do dispositivo legal não será pontuada.*

QUESTÃO 3

Fernando foi pronunciado pela prática de um crime de homicídio doloso consumado que teve como vítima Henrique. Em sessão plenária do Tribunal do Júri, o réu e sua namorada, ouvida na condição de informante, afirmaram que Henrique iniciou agressões contra Fernando e que este agiu em legítima defesa. Por sua vez, a namorada da vítima e uma testemunha presencial asseguraram que não houve qualquer agressão pretérita por parte de Henrique.

No momento do julgamento, os jurados reconheceram a autoria e materialidade, mas optaram por absolver Fernando da imputação delitiva. Inconformado, o Ministério Público apresentou recurso de apelação com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do CPP, alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. A família de Fernando fica preocupada com o recurso, em especial porque afirma que todos tinham conhecimento que dois dos jurados que atuaram no julgamento eram irmãos, mas em momento algum isso foi questionado pelas partes, alegado no recurso ou avaliado pelo Juiz Presidente.

Considerando a situação narrada, esclareça, na condição de advogado(a) de Fernando, os seguintes questionamentos da família do réu:

- a) A decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos? Justifique. (Valor: 0,60)
- b) Poderá o Tribunal, no recurso do Ministério Público, anular o julgamento com fundamento em nulidade na formação do Conselho de Sentença? Justifique. (Valor: 0,65)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 4

John, primário e de bons antecedentes, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas. Após a instrução, inclusive com realização do interrogatório, ocasião em que o acusado confessou os fatos, John foi condenado, na forma do art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto. O advogado de John interpôs o recurso cabível da sentença condenatória. Em julgamento pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, a sentença foi integralmente mantida por maioria de votos. O Desembargador revisor, por sua vez, votou no sentido de manter a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, assim como o regime, mas foi favorável à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, no que restou vencido. O advogado de John é intimado do acórdão.

Considerando a situação narrada, responda os itens a seguir.

- a) Qual medida processual, diferente de *habeas corpus*, deverá ser formulada pelo advogado de John para combater a decisão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça? (Valor: 0,65)
- b) Qual fundamento de direito material deverá ser apresentado para fazer prevalecer o voto vencido? (Valor: 0,60)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

11.1.18 XIX Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

João estava dirigindo seu automóvel a uma velocidade de 100 km/h em uma rodovia em que o limite máximo de velocidade é de 80 km/h. Nesse momento, foi surpreendido por uma bicicleta que atravessou a rodovia de maneira inesperada, vindo a atropelar Juan, condutor dessa bicicleta, que faleceu no local em virtude do acidente. Diante disso, João foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 302 da Lei 9.503/1997. As perícias realizadas no cadáver da vítima, no automóvel de João, bem como no local do fato, indicaram que João estava acima da velocidade permitida, mas que, ainda que a velocidade do veículo do acusado fosse de 80 km/h, não seria possível evitar o acidente e Juan teria falecido. Diante da prova pericial constatando a violação do dever objetivo de cuidado pela velocidade acima da permitida, João foi condenado à pena de detenção no patamar mínimo previsto no dispositivo legal.

Considerando apenas os fatos narrados no enunciado, responda os itens a seguir.

- a) Qual o recurso cabível da decisão do magistrado, indicando seu prazo e fundamento legal? (Valor: 0,60)
- b) Qual a principal tese jurídica de direito material a ser alegada nas razões recursais? (Valor: 0,65)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não

confere pontuação.

QUESTÃO 2

Ronaldo foi denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa por fatos praticados em 2014. Até o momento, porém, somente ele foi identificado como membro da organização pelas autoridades policiais, razão pela qual prosseguiu o inquérito em relação aos demais agentes não identificados. Arrepentido, Ronaldo procura seu advogado e afirma que deseja contribuir com as investigações, indicando o nome dos demais integrantes da organização, assim como esclarecendo os crimes cometidos.

Considerando apenas as informações narradas, responda os itens a seguir.

- a) Existe alguma medida a ser buscada pelo advogado de Ronaldo para evitar aplicação ou cumprimento de pena no processo pelo qual foi denunciado? Em caso positivo, qual? Em caso negativo, justifique. (Valor: 0,65)
- b) É possível um dos agentes identificados por Ronaldo ser condenado exclusivamente com base em suas declarações? Fundamente. (Valor: 0,60)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 3

Sabendo que Vanessa, uma vizinha com quem nunca tinha conversado, praticava diversos furtos no bairro em que morava, João resolve convidá-la para juntos subtraírem R\$ 1.000,00 de um cartório do Tribunal de Justiça, não contando para ela, contudo, que era funcionário público nem que exercia suas funções nesse cartório. Praticam, então, o delito, e Vanessa fica surpresa com a facilidade que tiveram para chegar ao cofre do cartório. Descoberto o fato pelas câmeras de segurança, são os dois agentes denunciados, em 10 de março de 2015, pela prática do crime de peculato. João foi notificado e citado pessoalmente, enquanto Vanessa foi notificada e citada por edital, pois não foi localizada em sua residência.

A família de Vanessa constituiu advogado e o processo prosseguiu, mas dele a ré não tomou conhecimento. Foi decretada a revelia de Vanessa, que não compareceu aos atos processuais. Ao final, os acusados foram condenados pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal à pena de 2 anos de reclusão. Ocorre que, na verdade, Vanessa estava presa naquela mesma Comarca, desde 5 de março de 2015, em razão de prisão preventiva decretada em outros dois processos.

Ao ser intimada da sentença, ela procura você na condição de advogado(a).

Considerando a hipótese narrada, responda os itens a seguir.

- a) Qual argumento de direito processual poderia ser apresentado em favor de Vanessa em sede de apelação? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) No mérito, foi Vanessa corretamente condenada pela prática do crime de peculato? Justifique. (Valor 0,60)

Obs.: o mero “sim” ou “não”, desprovido de justificativa ou mesmo com a indicação de justificativa inaplicável ao caso, não será pontuado.

QUESTÃO 4

Carlos foi condenado pela prática de um crime de receptação qualificada à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, sendo fixado o regime semiaberto para início do cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado da decisão, houve início do cumprimento da sanção penal imposta. Cumprido mais de 1/6 da pena imposta e preenchidos os demais requisitos, o advogado de Carlos requer, junto ao Juízo de Execuções Penais, a progressão para o regime aberto. O magistrado competente profere decisão concedendo a progressão e fixa como condição especial o cumprimento de prestação de serviços à comunidade, na forma do art. 115 da Lei 7.210/1984. O advogado de Carlos é intimado dessa decisão.

Considerando apenas as informações apresentadas, responda os itens a seguir.

- a) Qual medida processual deverá ser apresentada pelo advogado de Carlos, diferente do *habeas corpus*, para questionar a decisão do magistrado? (Valor: 0,60)
- b) Qual fundamento deverá ser apresentado pelo advogado de Carlos para combater a decisão do magistrado? (Valor: 0,65)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

11.1.19 XX Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Fausto, ao completar 18 anos de idade, mesmo sem ser habilitado legalmente, resolveu sair com o carro do seu genitor sem o conhecimento do mesmo. No cruzamento de uma avenida de intenso movimento, não tendo atentado para a sinalização existente, veio a atropelar Lídia e suas cinco filhas adolescentes, que estavam na calçada, causando-lhes diversas lesões que acarretaram a morte das seis. Denunciado pela prática de seis crimes do art. 302, § 1.º, incisos I e II, da Lei 9.503/1997, foi condenado nos termos do pedido inicial, ficando a pena final acomodada em quatro anos e seis meses de detenção em regime semiaberto, além de ficar impedido de obter habilitação para dirigir veículo pelo prazo de dois anos. A pena privativa de liberdade não foi substituída por restritivas de direitos sob o fundamento exclusivo de que o seu *quantum* ultrapassava o limite de quatro anos. No momento da sentença, unicamente com o fundamento de que o acusado, devidamente intimado, deixou de comparecer espontaneamente à última audiência designada, que seria exclusivamente para o seu interrogatório, o juiz decretou a prisão cautelar e não permitiu o apelo em liberdade, por força da revelia. Apesar de Fausto estar sendo assistido pela Defensoria Pública, seu genitor o procura, para que você, na condição de advogado(a), preste assistência jurídica. Diante da situação narrada, como advogado(a), responda aos seguintes questionamentos formulados pela família de Fausto:

- a) Mantida a pena aplicada, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? Justifique. (Valor: 0,65)

- b) Em caso de sua contratação para atuar no processo, o que poderá ser alegado para combater, especificamente, o fundamento da decisão que decretou a prisão cautelar? (Valor: 0,60)

QUESTÃO 2

Lúcio, com residência fixa e proprietário de uma oficina de carros, adquiriu de seu vizinho, pela quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) um aparelho celular, que sabia ser produto de crime pretérito, passando a usá-lo como próprio. Tomando conhecimento dos fatos, um inimigo de Lúcio comunicou o ocorrido ao Ministério Público, que requisitou a instauração de inquérito policial. A autoridade policial instaurou o procedimento, indiciou Lúcio pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1.º, do Código Penal), já que desenvolvia atividade comercial, e, de imediato, representou pela prisão temporária de Lúcio, existindo parecer favorável do Ministério Público. A família de Lúcio o procura para esclarecimentos. Na condição de advogado de Lúcio, esclareça os itens a seguir.

- a) No caso concreto, a autoridade policial poderia ter representado pela prisão temporária de Lúcio? (Valor: 0,60)
- b) Confirmados os fatos acima narrados, o crime praticado por Lúcio efetivamente foi de receptação qualificada (art. 180, § 1.º, do CP)? Em caso positivo, justifique. Em caso negativo, indique qual seria o delito praticado e justifique. (Valor: 0,65)

QUESTÃO 3

Andy, jovem de 25 anos, possui uma condenação definitiva pela prática de contravenção penal. Em momento posterior, resolve praticar um crime de estelionato e, para tanto, decide que irá até o portão da residência de Josefa e, aí, solicitará a entrega de um computador, afirmando que tal requerimento era fruto de um pedido do próprio filho de Josefa, pois tinha conhecimento que este trabalhava no setor de informática de determinada sociedade. Ao chegar ao portão da casa, afirma para Josefa que fora à sua residência buscar o computador da casa a pedido do filho dela, com quem trabalhava. Josefa pede para o marido entregar o computador a Andy, que ficara aguardando no portão. Quando o marido de Josefa aparece com o aparelho, Andy se surpreende, pois ele lembrava seu falecido pai. Em razão disso, apesar de já ter empregado a fraude, vai embora sem levar o bem. O Ministério Público ofereceu denúncia pela prática de tentativa de estelionato, sendo Andy condenado nos termos da denúncia. Como advogado de Andy, com base apenas nas informações narradas, responda aos itens a seguir.

- a) Qual tese jurídica de direito material deve ser alegada, em sede de recurso de apelação, para evitar a punição de Andy? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Há vedação legal expressa à concessão do benefício da suspensão condicional do processo a Andy? Justifique. (Valor: 0,60)

QUESTÃO 4

Joana trabalha em uma padaria na cidade de Curitiba. Em um domingo pela manhã, Patrícia, freguesa da padaria, acreditando não estar sendo bem atendida por Joana, após com ela discutir, a chama de “macaca” em razão da cor de sua pele. Inconformados com o ocorrido, outros fregueses

acionam policiais que efetuam a prisão em flagrante de Patrícia por crime de racismo (Lei 7.716/1989 – Lei do Preconceito Racial), apesar de Joana dizer que não queria que fosse tomada qualquer providência em desfavor da pessoa detida. A autoridade policial lavra o flagrante respectivo, independentemente da vontade da ofendida, asseverando que os crimes da Lei 7.716/1989 são de ação penal pública incondicionada. O Ministério Público opina pela liberdade de Patrícia porque ainda existiam diligências a serem cumpridas em sede policial. Patrícia, sete meses após o ocorrido, procura seu advogado para obter esclarecimentos, informando que a vítima foi ouvida em sede policial e confirmou o ocorrido, bem como o desinteresse em ver a autora dos fatos responsabilizada criminalmente. Na condição de advogado de Patrícia, esclareça:

- a) Agiu corretamente a autoridade policial ao indiciar Patrícia pela prática do crime de racismo? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Existe algum argumento defensivo para garantir, de imediato, o arquivamento do inquérito policial? Justifique. (Valor: 0,60)

11.1.20 XX Exame de Ordem Unificado Reaplicação Porto Velho – FGV

QUESTÃO 1

Jorge, com 21 anos de idade, reincidente, natural de São Gonçalo/RJ, entrou em uma briga com seus pais, razão pela qual foi morar na casa de sua tia Marta, irmã de seu pai, na cidade de Maricá/RJ, já que esta tinha apenas 40 anos e “o entenderia melhor”. Após seis meses residindo no mesmo local que sua tia, Jorge subtraiu o carro de Marta, levando-o para uma favela em Niterói, onde pretendia morar no futuro. No começo, Marta não desconfiou da autoria, porém após alguns dias, teve certeza de que o autor do crime era seu sobrinho, mas nada fez para vê-lo responsabilizado criminalmente, em razão do afeto que tinha por ele. Apenas, então, comunicou à seguradora que seu veículo fora furtado. Jorge, um ano após esses fatos, estava na direção do veículo que havia subtraído quando foi abordado por policiais militares que, constatando que aquele bem era produto de crime pretérito, realizaram sua prisão em flagrante. Jorge foi denunciado pela prática do crime de receptação, mas, no curso da instrução, foi descoberto que, na verdade, o acusado era o autor do crime de furto. O Ministério Público aditou a denúncia para adequá-la às novas descobertas e, após manifestação da Defensoria Pública, foi o aditamento recebido. Não houve requerimento de novas provas. Jorge o(a) procura para, na condição de advogado(a), apresentar as Alegações Finais. Considerando as informações extraídas da hipótese, responda aos itens a seguir.

- a) Qual a principal tese defensiva a ser formulada nas Alegações Finais para evitar a condenação de Jorge? (Valor: 0,65)
- b) Na condição de advogado(a) do acusado, o que você alegaria, no campo processual, caso o juiz viesse a condenar Jorge, após o aditamento, de acordo com a imputação original de receptação? (Valor: 0,60)

QUESTÃO 2

Lívia, primária e de bons antecedentes, foi presa em flagrante enquanto transportava 100 g de cocaína a pedido do namorado, conhecido traficante da comunidade em que residiam. Apesar de nunca ter participado de qualquer atividade do tráfico em momento anterior, Lívia atendeu ao pedido do namorado com medo de ele terminar o relacionamento em caso de negativa. Já na viatura da Polícia Militar, os policiais passaram a filmar Lívia e conversar sobre o ocorrido quando de sua prisão, tendo ela confirmado os fatos acima descritos sem que soubesse estar sendo filmada. Lívia, então, foi denunciada como incurso nas sanções penais do art. 33 da Lei 11.343/2006. Durante a instrução, o Ministério Público juntou aos autos o vídeo feito no interior da viatura e dispensou a oitiva dos policiais responsáveis pela prisão, que eram as únicas testemunhas de acusação, tendo em vista que eles foram transferidos para um batalhão de outra comarca. Em seu interrogatório, Lívia permaneceu em silêncio. Insatisfeitos com a defesa técnica que atuava até o momento, a família da acusada, no momento das alegações finais, o(a) contrata na condição de advogado(a). Considerando apenas os fatos narrados, responda, justificadamente, aos itens a seguir.

- a) É possível a condenação de Lívia apenas com base no vídeo acostado aos autos? (Valor: 0,60)
- b) Em caso de condenação de Lívia como incurso nas sanções do art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, é possível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? (Valor: 0,65)

QUESTÃO 3

No curso de uma audiência criminal, João, advogado de Pedro, acusado da prática de um crime de estupro, em sede de alegações finais orais, assevera que o representante do Ministério Público “é arbitrário e tem a sede da condenação, não se importando em acusar uma pessoa comprovadamente inocente”. Atendendo à manifestação do Promotor de Justiça, que se sentiu ofendido, o juiz destituiu o advogado e nomeou Defensor Público para continuar na defesa do acusado, que, na ocasião, não estava presente. O Defensor, então, concluiu as alegações finais orais. Na mesma assentada, o magistrado determinou a extração de peças, com o encaminhamento ao Ministério Público, para apurar possível crime contra a honra praticado por João. Pedro, assistido pela Defensoria Pública, acabou condenado na forma do pedido inicial. João, por sua vez, após representação do Promotor de Justiça vítima, foi denunciado pela prática de crime de injúria. Considerando apenas as informações constantes na hipótese narrada, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) Na condição de advogado(a) de João, qual tese de direito material você alegaria em seu favor para afastar a imputação delitiva? (Valor: 0,60)
- b) Na condição de advogado(a) de Pedro, qual é a tese a ser alegada, em sede de recurso, para anular sentença condenatória? (Valor: 0,65)

QUESTÃO 4

Maria, primária e com bons antecedentes, trabalha há vários anos dirigindo uma van de transporte de crianças. Certo dia, após mudar o itinerário sempre observado, resolve fazer compras em um supermercado, onde permaneceu por duas horas, esquecendo de entregar uma das crianças de três

anos na residência da mesma. Ao retornar ao veículo, encontra a criança desfalecida e, desesperada, leva-a ao hospital, não conseguindo, porém, evitar o óbito. Acabou denunciada e condenada pela prática do injusto do art. 133, § 2.º, do Código Penal (abandono de incapaz com resultado morte) à pena de quatro anos de reclusão em regime aberto. Apesar de ter respondido ao processo em liberdade, não foi permitido à Maria apelar em liberdade, fundamentando o juiz a ordem de prisão na grande comoção social que o fato causou. A família dispensou o advogado anterior e o(a) procurou para que assumisse a defesa de Maria. Considerando apenas as informações narradas na situação hipotética, responda aos itens a seguir.

- a) Qual a tese de direito material a ser alegada em eventual recurso defensivo para evitar a punição de Maria pelo crime pelo qual foi denunciada? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Qual a medida que deve ser adotada na busca da liberdade imediata de Maria e com qual fundament Justifique. (Valor: 0,60)

11.1.21 XXI Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Paulo e Júlio, colegas de faculdade, comemoravam juntos, na cidade de São Gonçalo, o título obtido pelo clube de futebol para o qual o primeiro torce. Não obstante o clima de confraternização, em determinado momento, surgiu um entrevero entre eles, tendo Júlio desferido um tapa no rosto de Paulo. Apesar da pouca intensidade do golpe, Paulo vem a falecer no hospital da cidade, tendo a perícia constatado que a morte decorreu de uma fatalidade, porquanto, sem que fosse do conhecimento de qualquer pessoa, Paulo tinha uma lesão pretérita em uma artéria, que foi violada com aquele tapa desferido por Júlio e causou sua morte. O órgão do Ministério Público, em atuação exclusivamente perante o Tribunal do Júri da Comarca de São Gonçalo, denunciou Júlio pelo crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3.º, do CP). Considerando a situação narrada e não havendo dúvidas em relação à questão fática, responda, na condição de advogado(a) de Júlio:

- a) É competente o juízo perante o qual Júlio foi denunciado? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Qual tese de direito material poderia ser alegada em favor de Júlio? Justifique. (Valor: 0.60)

QUESTÃO 2

No dia 3 de março de 2016, Vinícius, reincidente específico, foi preso em flagrante em razão da apreensão de uma arma de fogo, calibre .38, de uso permitido, número de série identificado, devidamente municiada, que estava em uma gaveta dentro de seu local de trabalho, qual seja, o estabelecimento comercial “Vinícius House”, do qual era sócio-gerente e proprietário. Denunciado pela prática do crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, confessou os fatos, afirmando que mantinha a arma em seu estabelecimento para se proteger de possíveis assaltos. Diante da prova testemunhal e da confissão do acusado, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia em alegações finais, enquanto a defesa afirmou que o delito do art. 14 do Estatuto do Desarmamento não foi praticado, também destacando a falta de prova da materialidade. Após manifestação das partes, houve juntada do

laudo de exame da arma de fogo e das munições apreendidas, constatando-se o potencial lesivo do material, tendo o magistrado, de imediato, proferido sentença condenatória pela imputação contida na denúncia, aplicando a pena mínima de dois anos de reclusão e 10 dias-multa. O advogado de Vinícius é intimado da sentença e apresentou recurso de apelação. Considerando apenas as informações narradas, responda na condição de advogado(a) de Vinícius:

- a) Qual requerimento deveria ser formulado em sede de apelação e qual tese de direito processual poderia ser alegada para afastar a sentença condenatória proferida em primeira instância? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Confirmados os fatos, qual tese de direito material poderia ser alegada para buscar uma condenação penal mais branda em relação ao *quantum* de pena para Vinícius? Justifique. (Valor: 0,60)

QUESTÃO 3

Mário foi surpreendido por uma pessoa que, mediante ameaça verbal de morte, subtraiu seu celular. No dia seguinte, quando passava pelo mesmo local, avistou Paulo e o reconheceu como sendo a pessoa que o roubara no dia anterior. Levado para a delegacia, Paulo admitiu ter subtraído o celular de Mário mediante grave ameaça, mas alegou que estava em estado de necessidade. O celular não foi recuperado e Paulo foi liberado em razão da ausência da situação de flagrante. Oferecida a denúncia pela prática do delito de roubo, Paulo foi pessoalmente citado e manifestou interesse em ser assistido pela Defensoria Pública. No curso da instrução, a vítima, única testemunha arrolada pelo Ministério Público, não foi localizada, assim como Paulo nunca compareceu em juízo, sendo decretada sua revelia. A pretensão punitiva foi acolhida nos termos do pedido inicial, tendo o juiz fundamentado seu convencimento no que foi dito pelo lesado e pelo acusado na fase extrajudicial, aumentando a pena-base pelo fato de o agente ter ameaçado de morte o ofendido e deixando de reconhecer a atenuante da confissão espontânea porque qualificada. Considerando apenas as informações narradas, responda, na condição de advogado(a) de Paulo, aos itens a seguir.

- a) Qual a tese jurídica a ser apresentada nas razões de apelação de modo a buscar a absolvição de Paulo? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Quais as teses jurídicas a serem apresentadas em sede de apelação de modo a buscar a redução da pena aplicada, caso mantida a condenação? Justifique. (Valor: 0,60)

QUESTÃO 4

Diana, primária e de bons antecedentes, em dificuldades financeiras, com inveja das amigas que exibiam seus automóveis recém-adquiridos, resolve comprar joias em loja localizada no Município de Campinas, para usar em uma festa de comemoração de 10 anos de formatura da faculdade. Em razão de sua situação, todavia, no momento do pagamento, entrega no estabelecimento um cheque sem provisão de fundos. Quando a proprietária da loja deposita o cheque, é informada, na cidade de Santos, pelo banco sacado, que inexistiam fundos suficientes, havendo recusa de pagamento, razão pela qual comparece em sede policial na localidade de sua residência, uma cidade do Estado de São Paulo, para narrar o ocorrido. Convidada a comparecer em sede policial para esclarecer o ocorrido, Diana confirma a

emissão do cheque sem provisão de fundos, mas efetua, de imediato, o pagamento do valor devido à proprietária do estabelecimento comercial. Posteriormente, a autoridade policial elabora relatório conclusivo e encaminha o inquérito ao Ministério Público, que oferece denúncia em face de Diana como incurso nas sanções do art. 171, § 2.º, inciso VI, do Código Penal. Considerando a situação narrada, na condição de advogado(a) de Diana, responda aos itens a seguir.

- a) Existe argumento a ser apresentado em favor de Diana para evitar, de imediato, o prosseguimento da ação penal? Em caso positivo, indique; em caso negativo, justifique. (Valor: 0,65)
- b) De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, qual será o foro competente para julgamento do crime imputado a Diana? Justifique. (Valor: 0,60)

11.1.22 XXII Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Chegou ao Ministério Público denúncia de pessoa identificada apontando Cássio como traficante de drogas. Com base nessa informação, entendendo haver indícios de autoria e não havendo outra forma de obter prova do crime, a autoridade policial representou pela interceptação da linha telefônica que seria utilizada por Cássio e que fora mencionada na denúncia recebida, tendo o juiz da comarca deferido a medida pelo prazo inicial de 30 dias. Nas conversas ouvidas, ficou certo que Cássio havia adquirido certa quantidade de cocaína, pela primeira vez, para ser consumida por ele, juntamente com seus amigos Pedro e Paulo, na comemoração de seu aniversário, no dia seguinte. Diante dessa prova, policiais militares obtiveram ordem judicial e chegaram à casa de Cássio quando este consumia e oferecia a seus amigos os seis papetes de cocaína para juntos consumirem. Cássio, portador de maus antecedentes, foi preso em flagrante e autuado pela prática do crime de tráfico, sendo, depois, denunciado como incurso nas penas do art. 33, *caput*, da Lei 11.343/2006. Considerando os fatos narrados, responda, na qualidade de advogado(a) de Cássio, aos itens a seguir.

- a) Qual a tese de direito processual a ser suscitada para afastar a validade da prova obtida? (Valor: 0,65)
- b) Reconhecidos como verdadeiros os fatos narrados, qual a tese de direito material a ser alegada para tornar menos gravosa a tipificação da conduta de Cássio? (Valor: 0,60)

QUESTÃO 2

Em inquérito policial, Antônio é indiciado pela prática de crime de estupro de vulnerável, figurando como vítima Joana, filha da grande amiga da Promotora de Justiça Carla, que, inclusive, aconselhou a família sobre como agir diante do ocorrido. Segundo consta do inquérito, Antônio encontrou Joana durante uma festa de música eletrônica e, após conversa em que Joana afirmara que cursava a Faculdade de Direito, foram para um motel onde mantiveram relações sexuais, vindo Antônio, posteriormente, a tomar conhecimento de que Joana tinha apenas 13 anos de idade. Recebido o inquérito concluído, Carla oferece denúncia em face de Antônio, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, ressaltando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para a configuração do delito, não se deve analisar o passado da vítima, bastando que a

mesma seja menor de 14 anos. Considerando a situação narrada, na condição de advogado(a) de Antônio, responda aos itens a seguir.

- a) Existe alguma medida a ser apresentada pela defesa técnica para impedir Carla de participar do processo? Justifique. (Valor: 0,60)
- b) Qual a principal alegação defensiva de direito material a ser apresentada em busca da absolvição do denunciado? Justifique. (Valor: 0,65)

QUESTÃO 3

Na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Maurício iniciou a execução de determinada contravenção penal que visava atingir e gerar prejuízo em detrimento de patrimônio de entidade autárquica federal, mas a infração penal não veio a se consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público dá início a procedimento criminal perante juízo do Tribunal Regional Federal com competência para atuar no local dos fatos, imputando ao agente a prática da contravenção penal em sua modalidade tentada, oferecendo, desde já, proposta de transação penal. Maurício conversa com sua família e procura um(a) advogado(a) para patrocinar seus interesses, destacando que não tem interesse em aceitar transação penal, suspensão condicional do processo ou qualquer outro benefício despenalizador. Com base apenas nas informações narradas e na condição de advogado(a) de Maurício, responda:

- a) Considerando que a contravenção penal causaria prejuízo ao patrimônio de entidade autárquica federal, o órgão perante o qual o procedimento criminal foi iniciado é competente para julgamento da infração penal imputada? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Qual argumento de direito material deverá ser apresentado para evitar a punição de Maurício? Justifique. (Valor: 0,60)

QUESTÃO 4

Diego e Júlio caminham pela rua, por volta das 21 horas, retornando para suas casas após mais um dia de aula na faculdade, quando são abordados por Marcos, que, mediante grave ameaça de morte e utilizando simulacro de arma de fogo, exige que ambos entreguem as mochilas e os celulares que carregavam. Após os fatos, Diego e Júlio comparecem em sede policial, narram o ocorrido e descrevem as características físicas do autor do crime. Por volta das 5 horas da manhã do dia seguinte, policiais militares em patrulhamento se deparam com Marcos nas proximidades do local do fato e verificam que ele possuía as mesmas características físicas do roubador. Todavia, não são encontrados com Marcos quaisquer dos bens subtraídos, nem o simulacro de arma de fogo. Ele é encaminhado para a Delegacia e, tendo-se verificado que era triplamente reincidente na prática de crimes patrimoniais, a autoridade policial liga para as residências de Diego e Júlio, que comparecem em sede policial e, em observância de todas as formalidades legais, realizam o reconhecimento de Marcos como responsável pelo assalto. O Delegado, então, lavra auto de prisão em flagrante em desfavor de Marcos, permanecendo este preso, e o indícia pela prática do crime previsto no art. 157, *caput*, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal. Diante disso, Marcos liga para seu advogado para informar sua prisão. Este

comparece, imediatamente, em sede policial, para acesso aos autos do procedimento originado do Auto de Prisão em Flagrante. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado de Marcos, responda, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, aos itens a seguir.

- a) Qual requerimento deverá ser formulado, de imediato, em busca da liberdade de Marcos e sob qual fundamento? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Oferecida denúncia na forma do indiciamento, qual argumento de direito material poderá ser apresentado pela defesa para questionar a capitulação delitiva constante da nota de culpa, em busca de uma punição mais branda? Justifique. (Valor: 0,60)

11.1.23 XXIII Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

José Barbosa, nascido em 11 de março de 1998, caminhava para casa após sair da faculdade, às 11 horas da manhã, no dia 7 de março de 2016, quando se deparou com Daniel, ex-namorado de sua atual companheira, conversando com esta. Em razão de ciúmes, retirou a faca que trazia na mochila e aplicou numerosas facadas no peito de Daniel, com a intenção de matá-lo. Daniel recebeu pronto atendimento médico, foi encaminhado para um hospital de Niterói, mas faleceu cinco dias após os golpes de faca. Já no dia 8 de março de 2016, policiais militares, informados sobre o fato ocorrido no dia anterior, comparecem à residência de José Barbosa, já que um dos agentes da lei era seu vizinho. Apesar de não ter ninguém em casa, a janela estava aberta, e os policiais puderam ver seu interior, verificando que havia uma faca suja de sangue escondida junto ao sofá. Diante disso, para evitar que José Barbosa desaparecesse com a arma utilizada, ingressaram no imóvel e apreenderam a arma branca, que foi devidamente apresentada pela autoridade policial. Com base na prova produzida a partir da apreensão da faca, o Ministério Público oferece denúncia em face de José Barbosa, imputando-lhe a prática do crime de homicídio consumado. Considerando a situação narrada, na condição de advogado(a) de José Barbosa, responda aos itens a seguir.

- a) Qual argumento a ser apresentado pela defesa técnica do denunciado para combater a prova decorrente da apreensão da faca? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Existe argumento de direito material a ser apresentado em favor de José Barbosa para evitar o prosseguimento da ação penal? Justifique. (Valor: 0,60)

QUESTÃO 2

Gabriel, condenado pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, obteve livramento condicional quando restava um ano e seis meses de pena privativa de liberdade a ser cumprida. No curso do livramento condicional, após seis meses da obtenção do benefício, vem Gabriel a ser novamente condenado, definitivamente, pela prática de crime de roubo, que havia sido praticado antes mesmo do delito de porte de arma de fogo, mas cuja instrução foi prolongada. Diante da nova condenação, o magistrado competente revogou o livramento condicional concedido e determinou que Gabriel deve cumprir aquele um ano e seis meses de pena restante quando da obtenção do livramento

em relação ao crime de porte, além da nova sanção imposta em razão do roubo. Considerando a situação narrada, na condição de advogado(a) de Gabriel, responda aos itens a seguir.

- a) Qual o recurso cabível da decisão do magistrado que revogou o benefício do livramento condicional e determinou o cumprimento da pena restante quando da obtenção do benefício? É cabível juízo de retratação em tal modalidade recursal? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Qual argumento deverá ser apresentado pela defesa de Gabriel para combater a decisão do magistrado? Justifique. (Valor: 0,60)

QUESTÃO 3

No dia 29 de dezembro de 2011, Cláudio, 30 anos, profissional do ramo de informática, invadiu dispositivo informático alheio, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de obter informações pessoais de famoso ator da televisão brasileira, sem autorização do titular do dispositivo. Após longa investigação e representação da vítima, o fato e a autoria de Cláudio foram identificados no ano de 2014, vindo o autor a ser indiciado e, posteriormente, oferecida pelo Ministério Público proposta de transação penal em razão da prática do crime do art. 154-A do Código Penal, dispositivo este incluído pela Lei 12.737/2012. Cláudio aceitou a proposta de transação penal, mas, em julho de 2015, interrompeu o cumprimento das condições impostas. Temeroso em razão de sua conduta, Cláudio procura seu advogado, informando que não justificou o descumprimento e, diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia por aquele delito, tendo o juiz competente recebido a inicial acusatória em agosto de 2015. Considerando apenas as informações narradas, esclareça, na condição de advogado(a) prestando consultoria jurídica para Cláudio, os seguintes questionamentos.

- a) De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a revogação do benefício de transação penal pelo descumprimento das condições impostas, com posterior oferecimento de denúncia? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Os fatos praticados por Cláudio, de fato, permitem sua responsabilização penal pelo crime do art. 154-A do Código Penal? Justifique. (Valor: 0,60)

QUESTÃO 4

Manoel conduzia sua bicicleta, levando em seu colo, sem qualquer observância às regras de segurança, seu filho de dois anos de idade. Para tornar o passeio do filho mais divertido, Manoel pedalava em alta velocidade, quando, em determinado momento, perdeu o controle da bicicleta e caiu, vindo seu filho a bater a cabeça e falecer de imediato. Após ser instaurado procedimento para investigar os fatos, a perícia constata que, de fato, Manoel estava em alta velocidade e não havia qualquer segurança para o filho em seu colo. O Ministério Público oferece denúncia em face de Manoel, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §§ 3.º e 4.º, do Código Penal, já que a vítima era menor de 14 anos. Durante a instrução, todos os fatos são confirmados por diversos meios de prova. Considerando apenas as informações narradas, responda, na qualidade de advogado(a) de Manoel, aos itens a seguir.

- a) A capitulação delitiva realizada pelo Ministério Público está integralmente correta? Justifique. (Valor:

0,60)

- b) Qual argumento a ser apresentado para evitar a punição de Manoel pelo crime de homicídio culposo? Justifique. (Valor: 0,65)

11.1.24 XXIV Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

No dia 11 de janeiro de 2016, Arnaldo, nascido em 1.º de fevereiro de 1943, primário e de bons antecedentes, enquanto estava em um bar, desferiu pauladas na perna e socos na face de Severino, nascido em 30 de março de 1980, por acreditar que este demonstrara interesse amoroso em sua neta de apenas 16 anos. As agressões praticadas por Arnaldo geraram deformidade permanente em Severino, que, revoltado com o ocorrido, foi morar em outro estado. Denunciado pela prática do crime do art. 129, § 2.º, inciso IV, do Código Penal, Arnaldo confessou em juízo, durante o interrogatório, as agressões; contudo, não foram acostados aos autos boletim de atendimento médico e exame de corpo de delito da vítima, que também não foi localizada para ser ouvida. As testemunhas confirmaram ter visto Arnaldo desferir um soco em Severino, mas não viram se da agressão resultou lesão. Em sentença, diante da confissão, Arnaldo foi condenado à pena de três anos de reclusão, deixando o magistrado de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude da violência. Considerando a situação narrada, na condição de advogado(a) de Arnaldo, responda aos itens a seguir.

- a) Em sede de recurso de apelação, qual argumento poderá ser apresentado em busca da absolvição de Arnaldo? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Ainda em sede de apelação, existe algum benefício legal a ser requerido pela defesa de Arnaldo para evitar a execução da pena, caso sejam mantidas a condenação e a sanção penal imposta? Justifique. (Valor: 0,60)

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 2

No dia 10 de setembro de 2014, Maria conversava na rua com amigas da escola, quando passou pelo local Túlio, jovem de 19 anos, que ficou interessado em conhecer Maria em razão da beleza desta. Um mês após se conhecerem e iniciarem um relacionamento, Túlio e Maria passaram a ter relações sexuais, apesar de Maria ter informado ao namorado que nascera em 9 de julho de 2001. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público denunciou Túlio pela prática do crime do art. 217-A do Código Penal.

Após a instrução e juntada da carteira de identidade de Maria, na qual constava seu nascimento em 9 de julho de 2001, Túlio foi condenado nos termos da denúncia, tendo ocorrido o trânsito em julgado. Dois anos após a sentença condenatória, os pais de Maria procuram os familiares de Túlio e narram que se sentiam mal pelo ocorrido, porque sempre consideraram o condenado um bom namorado para a filha. Afirmaram, ainda, que autorizavam o namoro, porque, na verdade, consideravam sua filha uma jovem, já

que ela nasceu em 9 de julho de 2000, mas somente foi registrada no ano seguinte, pois tinham o sonho de sua filha ser profissional do esporte e entenderam que o registro tardio a beneficiaria profissionalmente.

Diante de tais informações, em posse de fotografias que comprovam que Maria, de fato, nasceu em 9 de julho de 2000 e da retificação no registro civil, os familiares de Túlio procuram você na condição de advogado(a). Na condição de advogado(a) de Túlio, considerando apenas as informações narradas, responda aos itens a seguir.

- a) Diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, existe medida judicial a ser apresentada em favor de Túlio, diferente de *habeas corpus*, em busca da desconstituição da sentença? Justifique e indique, em caso positivo. (Valor: 0,65)
- b) Qual argumento de direito material deverá ser apresentado pelo(a) patrono(a) de Túlio em busca da desconstituição da sentença? Justifique. (Valor: 0,60)

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 3

Aroldo, Bernardo, Caio e David, que se conheceram em razão de todos exercerem a função de pintores de residências, durante diversas quartas-feiras do ano de 2015 encontravam-se na garagem da residência do primeiro para organizarem a prática de crimes de receptação simples. Com o objetivo de receber vantagem financeira, nos encontros, muito bem organizados e que ocorreram por mais de seis meses, era definido como os crimes seriam realizados, havendo plena divisão de funções e tarefas entre os membros do grupo. Um morador da região que tinha conhecimento dos encontros, apresenta *notitia criminis* à autoridade policial, mas informa que acredita que o grupo pretendia realizar a prática de roubos. Diante disso, instaurado o inquérito para apurar o crime de organização criminosa, o delegado de polícia determina diretamente, sem intervenção judicial, a infiltração de agentes de polícia no grupo, de maneira velada, para obtenção de provas. Ao mesmo tempo, realiza outros atos investigatórios e obtém, de forma autônoma, outras provas, que, de fato, confirmam a atividade do grupo; contudo, resta constatado que, verdadeiramente, a pretensão do grupo era apenas a prática de crimes de receptação simples. Após a obtenção das provas necessárias, Aroldo, Bernardo, Caio e David são denunciados pela prática do crime previsto no art. 2.º da Lei 12.850/2013. Na condição de advogado(a) dos denunciados, considerando apenas as informações narradas, responda aos questionamentos a seguir.

- a) A infiltração de agentes determinada pela autoridade policial foi válida? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Qual o argumento de direito material a ser apresentado pela defesa em busca da não condenação dos denunciados da prática do crime imputado? Justifique. (Valor: 0,60)

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 4

Pablo, que possui quatro condenações pela prática de crimes com violência ou grave ameaça à

peessoa, estava no quintal de sua residência brincando com seu filho, quando ingressa em seu terreno um cachorro sem coleira. O animal adota um comportamento agressivo e começa a tentar atacar a criança de cinco anos, que brincava no quintal com o pai. Diante disso, Pablo pega um pedaço de pau que estava no chão e desfere forte golpe na cabeça no cachorro, vindo o animal a falecer.

No momento seguinte, chega ao local o dono do cachorro, que, inconformado com a morte deste, chama a polícia, que realiza a prisão em flagrante de Pablo pela prática do crime do art. 32 da Lei 9.605/1998. Os fatos acima descritos são integralmente confirmados no inquérito pelas testemunhas. Considerando que Pablo é multirreincidente na prática de crimes graves, o Ministério Público se manifesta pela conversão do flagrante em preventiva, afirmando o risco à ordem pública pela reiteração delitiva. Considerando as informações narradas, na condição de advogado(a) de Pablo, que deverá se manifestar antes da decisão do magistrado quanto ao requerimento do Ministério Público, responda aos itens a seguir.

- a) Qual pedido deverá ser formulado pela defesa de Pablo para evitar o acolhimento da manifestação p conversão da prisão em flagrante em preventiva? Justifique. (Valor: 0,60)
- b) Sendo oferecida denúncia, qual argumento de direito material poderá ser apresentado em busca da absolvição de Pablo? Justifique. (Valor: 0,65)

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

11.1.25 XXV Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Bruna, nascida em 30 de março de 1999, e sua irmã Júlia, nascida em 21 de janeiro de 1998, revoltadas com o comportamento de Maria, que, segundo as irmãs, buscava um relacionamento amoroso com o namorado de Júlia, iniciaram uma discussão com esta, no dia 28 de março de 2017. Durante a discussão, descontroladas por Maria ter dito que Júlia não tinha capacidade de manter um namorado, as irmãs pegaram pedaços de ferro que estavam no chão da rua e começaram a agredir Maria com golpes na cabeça, com intenção de matar. Após a fuga de Bruna e Júlia do local, Maria é socorrida e recebe atendimento médico no hospital da região, ficando internada por 05 dias, mas vem a falecer em razão dos golpes sofridos.

Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público oferece denúncia em face de Bruna e Júlia pela prática do crime do art. 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal, requerendo a prisão preventiva apenas de Júlia, considerando que a mesma já seria reincidente. Após citação de Bruna e Júlia, a família das rés o(a) procura na condição de advogado(a), informando que Júlia está grávida de 20 semanas e que temem por sua saúde dentro da prisão.

Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado(a) de Bruna e Júlia, responda aos itens a seguir.

- a) Qual argumento de direito material a ser apresentado em favor de Bruna para evitar o prosseguiment da ação penal em relação a mesma? Justifique. (Valor: 0,65)

- b) Considerando que verdadeiramente estejam presentes os requisitos previstos nos Arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, qual requerimento deveria ser formulado ao juízo para evitar que Julia permaneça no interior do sistema prisional? Justifique. (Valor: 0,60)

QUESTÃO 2

No dia 06 de abril de 2017, João retirou Clara, criança de 11 anos de idade, do interior da residência em que esta morava, sem autorização de qualquer pessoa, vindo a restringir sua liberdade e mantê-la dentro de um quarto trancado e sem janelas. Logo em seguida, João entrou em contato com o pai de Clara, famoso empresário da cidade, exigindo R\$ 200.000,00 para liberar Clara e devolvê-la à sua residência.

Após o pai de Clara pagar o valor exigido, Clara é liberada e, de imediato, a família comparece à Delegacia para registrar o fato. Depois das investigações, João é identificado e os autos são encaminhados ao Ministério Público com relatório final de investigação, indiciando João. Após 90 (noventa) dias do recebimento do inquérito, os autos permanecem no gabinete do Promotor de Justiça, sem que qualquer medida tenha sido adotada.

Considerando as informações narradas, responda, na condição de advogado(a) da família de Clara, aos itens a seguir.

- a) Considerando que o crime é de ação penal pública incondicionada, qual a medida a ser adotada diretamente pela família de Clara e seu advogado em busca da responsabilização criminal de João? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Em caso de inicial acusatória, qual infração penal deve ser imputada a João? Justifique. (Valor: 0,60)
- Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.*

QUESTÃO 3

Carlos, 50 anos, foi condenado, de maneira definitiva, pela prática de crime de roubo, ao cumprimento de pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto em razão das peculiaridades do caso, apesar de naquele momento ser primário. Após o cumprimento de 3 anos e 10 dias da pena aplicada, considerando o período de prisão provisória, Carlos veio a praticar falta grave, em 10.03.2015, dentro do estabelecimento prisional, sendo que, no mesmo dia, empreendeu fuga. Após processo administrativo disciplinar, inclusive com participação da defesa técnica de Carlos, foi reconhecida a prática de falta grave.

O juiz da execução penal, em procedimento regular, ainda no ano de 2015, confirmou o reconhecimento da prática de falta grave e determinou o reinício do prazo para obtenção do livramento condicional. Por falhas cartorárias, a defesa técnica de Carlos somente foi intimada da decisão em 14.03.2018. Com a intimação, Carlos, que nunca mais foi localizado para cumprimento do restante da pena, apesar do mandado de prisão em aberto, procura seu advogado, indaga sobre as medidas cabíveis, esclarecendo que, de fato, houve prática de falta grave, mas assegurando estar ressocializado e que nunca mais se envolveu com a prática de crimes.

Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado de Carlos, responda aos itens a seguir.

- a) Em sede de Agravo à Execução, qual argumento deverá ser apresentado para combater o mérito da decisão do magistrado? Justifique. (Valor: 0,60)
- b) Por meio de *Habeas Corpus*, qual argumento de direito material poderá ser apresentado para evitar a execução do restante da pena de Carlos? Justifique. (Valor: 0,65)

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 4

Vitor efetuou disparos de arma de fogo contra José, com a intenção de causar sua morte. Ocorre que, por erro durante a execução, os disparos atingiram a perna de seu inimigo e não o peito, como pretendido. Esgotada a munição disponível, Vitor empreendeu fuga, enquanto José solicitou a ajuda de populares e compareceu, de imediato, ao hospital para atendimento médico.

Após o atendimento médico, já no quarto com curativos, enquanto dormia, José vem a ser picado por um escorpião, vindo a falecer no dia seguinte em razão do veneno do animal, exclusivamente. Descobertos os fatos, considerando que José somente estava no hospital em razão do comportamento de Vitor, o Ministério Público oferece denúncia em face do autor dos disparos pela prática do crime de homicídio consumado, previsto no art. 121, *caput*, do Código Penal.

Após regular prosseguimento do feito, na audiência de instrução e julgamento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, quando da oitiva das testemunhas, o magistrado em atuação optou por iniciar a oitiva das testemunhas formulando diretamente suas perguntas, sem permitir às partes complementação. Após alegações finais orais das partes, o magistrado proferiu decisão de pronúncia. Apesar da impugnação da defesa quanto à formulação das perguntas pelo juiz, o magistrado esclareceu que não importaria quem fez a pergunta, pois as respostas seriam as mesmas.

Com base apenas nas informações narradas, na condição de advogado(a) de Vitor, responda aos itens a seguir.

- a) Qual o recurso cabível da decisão proferida pelo magistrado e qual argumento de direito processual pode ser apresentado em busca da desconstituição de tal decisão? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Existe argumento de direito material a ser apresentado, em momento oportuno, para questionar a capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público? Justifique. (Valor: 0,60)

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

11.1.26 XXVI Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Insatisfeito com a atividade do tráfico em determinado condomínio de residências, em especial em razão da venda de drogas de relevante valor, o juiz da comarca autorizou, após requerimento do

Ministério Público, a realização de busca e apreensão em todas as centenas de residências do condomínio, sem indicar o endereço de cada uma delas, apesar de estas serem separadas e identificadas, sob o argumento da existência de informações de que, no interior desse condomínio, haveria comercialização de drogas e que alguns dos moradores estariam envolvidos na conduta.

Com base nesse mandado, a Polícia Civil ingressou na residência de Gabriel, 22 anos, sendo apreendidos, no interior de seu imóvel, 15 g de maconha, que, de acordo com Gabriel, seriam destinados a uso próprio. Após denúncia pela prática do crime do art. 28 da Lei 11.343/2006, em razão de anterior condenação definitiva pela prática do mesmo delito, o que impossibilitaria a aplicação de institutos despenalizadores, foi aplicada a Gabriel a sanção de cumprimento de 10 meses de prestação de serviços à comunidade.

Intimado da condenação e insatisfeito, Gabriel procura um advogado para consulta técnica, esclarecendo não ter interesse em cumprir a medida aplicada de prestação de serviços à comunidade.

Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado de Gabriel, esclareça os itens a seguir.

- a) Qual o argumento de direito processual a ser apresentado em sede de recurso para questionar a apreensão das drogas na residência de Gabriel? Justifique. (Valor: 0,60)
- b) Em caso de descumprimento, por Gabriel, da medida de prestação de serviços à comunidade imposta na sentença condenatória pela prática do crime do art. 28 da Lei 11.343/2006, poderá esta ser convertida em pena privativa de liberdade? Justifique. (Valor: 0,65)

QUESTÃO 2

Arthur, Adriano e Junior, insatisfeitos com a derrota do seu time de futebol, saíram à rua, após a partida, fazendo algazarra na companhia de Roberto, que não gostava de futebol. Durante o ato, depararam com Pedro, que vestia a camisa do time rival; simplesmente por isso, Arthur, Adriano e Junior passaram a agredi-lo, tendo ficado Roberto a distância, por não concordar com o ato e não ter intenção de conferir cobertura aos colegas.

Em razão dos atos de agressão, o celular de Pedro veio a cair no chão, momento em que Roberto, aproveitando-se da situação, subtraiu o bem e empreendeu fuga. Com a chegada de policiais, Arthur, Adriano e Junior empreenderam fuga, mas Roberto veio a ser localizado pouco tempo depois na posse do bem subtraído e de seu próprio celular.

Diante das lesões causadas na vítima, Roberto foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Na instrução, as testemunhas confirmaram integralmente os fatos, assim como Roberto reiterou o acima narrado. A família de Roberto, então, procura você para, na condição de advogado(a), adotar as medidas cabíveis, antes da sentença, apresentando nota fiscal da compra do celular de Roberto.

Considerando apenas as informações narradas, responda, na condição de advogado(a) de Roberto, aos itens a seguir.

- a) Existe requerimento a ser formulado pela defesa para reaver, de imediato, o celular de Roberto? Justifique. (Valor: 0,60)

- b) Confessados por Roberto os fatos acima narrados, existe argumento de direito material a ser apresentado em busca da não condenação pelo crime imputado? Justifique. (Valor: 0,65)

QUESTÃO 3

Flávio está altamente sensibilizado com o fato de que sua namorada de infância faleceu. Breno, não mais aguentando ver Flávio sofrer, passa a incentivar o amigo a dar fim à própria vida, pois, assim, nas palavras de Breno, ele “novamente estaria junto do seu grande amor”.

Diante dos incentivos de Breno, Flávio resolve pular do seu apartamento, no 4.º andar do prédio, mas vem a cair em um canteiro de flores, sofrendo apenas arranhões leves no braço. Descobertos os fatos, Breno é denunciado pela prática do crime previsto no art. 122 do Código Penal, na forma consumada, já que ele incentivou Flávio a se suicidar.

Recebida a denúncia, o juiz, perante a Vara Única da Comarca onde os fatos ocorreram, determina que seja observado o procedimento comum ordinário. Durante a instrução, todos os fatos anteriormente narrados são confirmados. Os autos são encaminhados para as partes para apresentação de alegações finais.

A família de Breno procura você para, na condição de advogado(a), prestar os esclarecimentos a seguir.

- a) O procedimento observado durante a ação penal em desfavor de Breno foi o adequado? Justifique. (Valor: 0,60)
- b) Qual o argumento a ser apresentado pela defesa técnica para questionar a capitulação delitiva realizada pelo Ministério Público? Justifique. (Valor: 0,65).

QUESTÃO 4

Larissa, revoltada com o comportamento de Renata, ex-namorada de seu companheiro, foi, em 20 de julho de 2017, até a rua em que esta reside. Verificando que o automóvel de Renata estava em via pública, Larissa quebra o vidro dianteiro do veículo, exatamente com a intenção de deteriorar coisa alheia.

Na manhã seguinte, Renata constatou o dano causado ao seu carro, mas não identificou, em um primeiro momento, quem seria o autor do crime. Solicitou, então, a instauração de inquérito policial, em 25 de julho de 2017. Após diligências, foi identificado, em 23 de outubro de 2017, que Larissa seria a autora do fato e que o prejuízo era de R\$ 150,00, tendo sido a informação imediatamente passada à vítima Renata.

Com viagem marcada, Renata somente procurou seu advogado em 21 de fevereiro de 2018, informando sobre o interesse em apresentar queixa-crime em face da autora dos fatos. Assim, o advogado de Renata apresentou queixa-crime em face de Larissa, imputando o crime do art. 163, *caput*, do Código Penal, em 28 de fevereiro de 2018, perante o Juizado Especial Criminal competente, tendo sido proferida decisão pelo magistrado de rejeição da queixa, em razão da decadência, em 07.03.2018. A defesa técnica é intimada da decisão.

Considerando as informações narradas, na condição de advogado(a) de Renata, responda aos itens a seguir.

- a) Qual o recurso cabível da decisão de rejeição da queixa-crime apresentada por Renata? Indique o fundamento legal e o prazo de interposição. (Valor: 0,65)
- b) Qual o argumento para combater o mérito da decisão do magistrado de rejeição da denúncia? Justifique. (Valor: 0,60)

11.1.27 XXVII Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Rafael subtraiu, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel de Joana juntamente com outro indivíduo não identificado e com restrição da liberdade da vítima. Foi, então, denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, incisos II e V, do Código Penal.

Durante a instrução, quando da oitiva da vítima, esta mencionou que todos os fatos foram presenciados, de longe, por sua amiga Carla, não tendo ela contado em momento anterior para preservar a amiga. Diante dessa menção, o advogado de Rafael requereu ao juízo a oitiva da testemunha Carla, mas o magistrado indeferiu o pedido sob o argumento de que, na resposta à acusação, foram arroladas testemunhas no número máximo permitido pela lei, de modo que não poderia a defesa acrescentar mais uma, apesar de reconhecer a conveniência da oitiva.

O advogado registrou seu inconformismo, foram ouvidas as testemunhas de defesa arroladas e foi realizado o interrogatório, em que o acusado negou o fato. Rafael foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos e 06 meses de reclusão, reconhecendo o magistrado o aumento de 3/8 na terceira fase de aplicação da pena exclusivamente em razão da existência de duas causas de aumento, não tendo a pena-base e a intermediária se afastado do mínimo legal.

Considerando as informações narradas, responda, na condição de advogado(a) de Rafael, na ocasião da apresentação de recurso de apelação:

- a) qual argumento de direito processual poderia ser alegado em busca de desconstituir a sentença condenatória? Justifique. (Valor: 0,60)
- b) qual argumento de direito material deverá ser apresentado em busca de redução da sanção penal aplicada? Justifique. (Valor: 0,65)

QUESTÃO 2

Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, o oficial de justiça Jorge compareceu ao local de trabalho de Lucas, sendo encontradas, no interior do imóvel, duas armas de fogo de calibre .38, calibre esse considerado de uso permitido, devidamente municiadas, ambas com numeração suprimida. Em razão disso, Lucas foi preso em flagrante e denunciado pela prática de dois crimes previstos no art. 16, *caput*, da Lei 10.826/2003, em concurso material, sendo narrado que “Lucas, de forma livre e consciente, guardava, em seu local de trabalho, duas armas de fogo de calibre restrito, devidamente municiadas”.

Após a instrução, em que os fatos foram confirmados, foi juntado o laudo confirmando o calibre .38 das armas de fogo, a capacidade de efetuar disparos, bem como que ambas tinham a numeração suprimida. As partes apresentaram alegações finais, e o magistrado, em sentença, considerando o teor do laudo, condenou Lucas pela prática de dois crimes previstos no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, em concurso formal. Intimada a defesa técnica da sentença condenatória, responda, na condição de advogado(a) de Lucas, aos itens a seguir.

- a) Qual o argumento de direito processual a ser apresentado em busca da desconstituição da sentença condenatória? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Reconhecida a validade da sentença em segundo grau, qual o argumento de direito material a ser apresentado para questionar o mérito da sentença condenatória e, consequentemente, a pena aplicada? Justifique. (Valor: 0,60).

QUESTÃO 3

No interior de um coletivo, Alberto, João, Francisco e Ronaldo, até então desconhecidos, começaram a conversar sobre a crise financeira que assombra o país e sobre as dificuldades financeiras que estavam passando.

Em determinado momento da conversa, Alberto informa que tinha um conhecido seu, Lucas, com intenção de importar uma arma de fogo de significativo potencial ofensivo, que seria um fuzil de venda proibida no Brasil, mas que ele precisava da ajuda de outras pessoas para conseguir a importação. Diante da oferta em dinheiro pelo serviço específico, todos concordaram em participar do plano criminoso, sendo que Alberto iria ao exterior adquirir a arma, João alugaria um barco para trazer o material, Francisco auxiliaria junto à imigração brasileira para que a conduta não fosse descoberta e Ronaldo entregaria o material para Lucas, que era o mentor do plano. Após toda a organização do grupo e divisão de tarefas, assustado com as informações veiculadas na mídia sobre as punições de crime de organização criminosa, Francisco comparece ao Ministério Público com seu advogado e indica a intenção de realizar delação premiada.

Participaram das negociações do acordo Francisco, sua defesa técnica, o membro do Ministério Público com atribuição e o juiz que seria competente para julgamento, sendo acordada a redução de 1/3 da pena em relação ao crime de organização criminosa.

Após ser denunciado junto com Alberto, João, Ronaldo e Lucas pela prática do crime de organização criminosa (art. 2.º, da Lei 12.850/2013), Francisco contrata você, como novo(a) advogado(a), para patrocinar seus interesses.

Na condição de advogado(a) de Francisco, com base apenas nas informações narradas, esclareça os itens a seguir.

- a) Considerando que aquela delação premiada não seria benéfica ao seu cliente, existe argumento a ser apresentado em busca de desconstituir o acordo celebrado quanto ao seu aspecto formal? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Qual argumento de direito material deve ser apresentado para questionar a capitulação jurídica realizada pelo Ministério Público na denúncia? Justifique. (Valor: 0,60).

QUESTÃO 4

Revoltada com o fato de que sua melhor amiga Clara estaria se relacionando com seu ex-companheiro João, Maria a procurou e iniciou uma discussão.

Durante a discussão, Clara, policial militar, afirmou que, se Maria a xingasse novamente, ela a mataria gastando apenas uma munição da sua arma. Persistindo na discussão, Maria voltou a ofender Clara. Esta, então, abriu sua bolsa e pegou um bem de cor preta. Acreditando que Clara cumpriria sua ameaça, Maria desferiu um golpe na cabeça da rival, utilizando um pedaço de pau que estava no chão. A perícia constatou que o golpe foi a causa eficiente da morte de Clara. Posteriormente, também foi constatado que Clara, de fato, estava com sua arma de fogo na bolsa, mas que ela apenas pegara seu telefone celular para ligar para João.

Após denúncia pela prática do crime de homicídio qualificado e encerrada a instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, entendeu o magistrado por pronunciar Maria nos termos da inicial acusatória.

Com base nas informações expostas, responda, na condição de advogado(a) de Maria, aos itens a seguir.

- a) Qual o recurso cabível da decisão proferida pelo magistrado? Caso tivesse ocorrido a impronúncia, o recurso pela parte interessada seria o mesmo? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Qual a tese de direito material a ser apresentada em sede de recurso para combater a decisão de submeter a ré ao julgamento pelo Tribunal do Júri? Justifique. (Valor: 0,60)

11.1.28 XXVIII Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Matheus conduzia seu automóvel em alta velocidade. Em razão de manobra indevida, acabou por atropelar uma vítima, causando-lhe lesões corporais. Com a chegada da Polícia Militar, foi solicitado que Matheus realizasse exame de etilômetro (bafômetro); diante de sua recusa, foi informado pela autoridade policial, que comparecera ao local, que ele seria obrigado a realizar o exame para verificar eventual prática também do crime previsto no art. 306 da Lei 9.503/1997.

Diante da afirmativa da autoridade policial, Matheus, apesar de não desejar, viu-se obrigado a realizar o teste do bafômetro. Após conclusão do inquérito policial, com oitiva e representação da vítima, foi o feito encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu denúncia imputando a Matheus apenas a prática do crime do art. 303 da Lei 9.503/1997, prossequindo as investigações com relação ao crime do art. 306 do mesmo diploma legal. Ainda na exordial acusatória, foi requerida a decretação da prisão preventiva de Matheus, pelo risco de reiteração delitiva, tendo em vista que ele seria reincidente específico, já que a única anotação constante de sua Folha de Antecedentes Criminais, para além do presente processo, seria a condenação definitiva pela prática de outro crime de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. No recebimento da denúncia, o juiz competente decretou a prisão preventiva.

Considerando as informações narradas, na condição de advogado(a) de Matheus, responda aos itens

a seguir.

- a) Poderia Matheus ter sido obrigado a realizar o teste de bafômetro, conforme informado pela autoridade policial, mesmo diante de sua recusa? Justifique. (Valor: 0,60)
- b) Qual requerimento deveria ser formulado, em busca da liberdade de Matheus, diante da decisão do magistrado, que decretou sua prisão preventiva em razão de sua reincidência? Justifique. (Valor: 0,65)

QUESTÃO 2

Após regular processamento em que figurava na condição de réu solto, Hugo foi condenado pela prática de crime de apropriação indébita majorada ao cumprimento da pena de 01 ano e 06 meses de reclusão e 14 dias-multa, sendo reconhecida a agravante da reincidência, tendo em vista que foi juntada aos autos Folha de Antecedentes Criminais a demonstrar trânsito em julgado, no ano anterior ao da prática da apropriação indébita, de condenação pelo crime de lesão corporal dolosa, praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No momento da sentença, considerando a reincidência, o magistrado aplicou o regime inicial fechado de cumprimento da pena. Destacou, ainda, que, apesar de Hugo estar trabalhando e cuidando de filhos menores, não poderia substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por expressa vedação legal no caso de reincidência dolosa.

Intimado da sentença, Hugo procura seu advogado para a adoção das medidas cabíveis.

Considerando apenas o narrado, na condição de advogado(a) de Hugo, responda aos questionamentos a seguir.

- a) Diante da reincidência, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, existe argumento a ser apresentado, em sede de recurso, em busca da aplicação de regime inicial mais benéfico de cumprimento de pena? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) É possível, em sede de recurso, buscar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? Justifique. (Valor: 0,60)

QUESTÃO 3

Leal cumpre pena em regime semiaberto após condenação definitiva pela prática de crime de lesão corporal seguida de morte, ocasião em que foi aplicada pena de 06 anos de reclusão. Após permanecer 11 meses da pena aplicada em regime semiaberto e considerando que trabalhou com autorização judicial, fora do estabelecimento penitenciário, em “serviço extramuros”, por 120 dias, pretende a obtenção de progressão para o regime aberto. Diante disso, em visita realizada pela defesa técnica, demonstra sua intenção para o advogado, informando que não sofreu qualquer punição administrativa no período, mas demonstrou preocupação com o fato de que soube, por meio de outros detentos, que não haveria vagas disponíveis em estabelecimentos de regime aberto no Estado.

Sob o ponto de vista técnico, de acordo com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, na condição de advogado(a) de Leal, esclareça os itens a seguir.

- a) Leal preencheu os requisitos objetivos para a progressão para o regime aberto? Justifique. (Valor: 0,60)

- b) A inexistência de vagas no regime pretendido pelo apenado pode ser considerada fundamento idôneo para a não concessão do benefício por ocasião do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para progressão? Justifique. (Valor: 0,60)

QUESTÃO 4

Na manhã do dia 09 de outubro de 2018, Talles, na cidade de Bom Jesus de Itabapoana, praticou 03 crimes de furto simples em continuidade delitiva, subtraindo, do primeiro estabelecimento, dinheiro e uma arma de brinquedo; do segundo estabelecimento, uma touca ninja e um celular; e, do terceiro estabelecimento, uma motocicleta.

De posse dos bens subtraídos, Talles foi até a cidade de Cardoso Moreira, abordou Joana, que passava pela rua segurando seu celular, e, utilizando-se do simulacro da arma para emprego de grave ameaça e da touca, segurou-a pelos braços e subtraiu o celular de suas mãos. De imediato, Talles empreendeu fuga, mas Joana compareceu em sede policial, narrou o ocorrido e Talles foi localizado e preso em flagrante na cidade de São Fidélis, ainda na posse dos bens da vítima e da motocicleta utilizada.

Assegurado o direito ao silêncio e o acompanhamento da defesa técnica, Talles prestou declarações na delegacia e confessou integralmente os fatos, sendo ele indiciado pela prática dos crimes previstos no art. 155, *caput*, por três vezes, n/f do art. 71 do CP e do art. 157, § 2.º, inciso V, também do CP.

Considerando as informações expostas, responda, na condição de advogado(a) de Talles, aos itens a seguir.

- a) Considerando que os delitos são conexos, de qual cidade será o juízo criminal competente para o julgamento de Talles? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Qual o argumento de direito material para questionar a capitulação delitiva realizada pela autoridade policial? Justifique. (Valor: 0,60)

11.1.29 XXIX Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Caio e Bruno são irmãos e estão em dificuldades financeiras. Caio, que estava sozinho em seu quarto, verifica que a janela da casa dos vizinhos está aberta; então, ingressa no local e subtrai um telefone celular avaliado em R\$ 500,00. Ao mesmo tempo, apesar de não saber da conduta de seu irmão, Bruno percebe que a porta da residência dos vizinhos também ficou aberta. Tendo conhecimento que os proprietários eram um casal de empresários muito rico, ingressa no local e subtrai uma bolsa, avaliada em R\$ 450,00.

Os fatos são descobertos dois dias depois, e Bruno e Caio são denunciados pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4.º, inciso IV, do Código Penal), sendo acostadas as Folhas de Antecedentes Criminais (FAC), contendo, cada uma delas, outra anotação pela suposta prática de crime de estelionato, sem, contudo, haver condenação com trânsito em julgado em ambas.

Após instrução, a pretensão punitiva do Estado é julgada procedente, sendo aplicada pena mínima de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, devidamente substituída por restritiva de direitos.

Com base nas informações expostas, intimado(a) para apresentação de recurso, responda, na condição de advogado(a) de Caio e Bruno, aos itens a seguir.

- a) Existe argumento de direito material a ser apresentado para questionar a capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público e acolhida na sentença? (Valor: 0,60)
- b) Mantida a capitulação acolhida na sentença (art. 155, § 4.º, inciso IV, do Código Penal), existe argumento em busca da redução da pena aplicada? (Valor: 0,65)

QUESTÃO 2

No dia 1.º de janeiro de 2008, após ingerir bebida alcoólica, Caio, 50 anos, policial militar reformado, efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à parede de sua casa vazia, localizada no interior de grande quintal, com arma de sua propriedade, devidamente registrada e com posse autorizada.

Apesar de os tiros terem sido efetuados em direção ao interior do imóvel, vizinhos que passavam pela rua naquele momento, ao ouvirem os disparos, entraram em contato com a Polícia Militar, que compareceu ao local e constatou que as duas munições deflagradas ficaram alojadas na parede do imóvel, sendo a perícia acostada ao procedimento. Caio obteve liberdade provisória e foi denunciado como incurso nas sanções do art. 15 da Lei 10.826/2003, não sendo localizado, porém, por ocasião da citação, por ter mudado de endereço, apesar das diversas diligências adotadas pelo juízo.

Após não ser localizado, Caio foi corretamente citado por edital e, não comparecendo, nem constituindo advogado, foi aplicado o art. 366 do Código de Processo Penal, suspendendo-se o processo e o curso do prazo prescricional, em 4 de abril de 2008. Em 6 de julho de 2018, o novo juiz titular da vara criminal competente determinou que fossem realizadas novas diligências na tentativa de localizar o denunciado, confirmando que o processo, assim como o curso do prazo prescricional, deveria permanecer suspenso.

Com base nas informações narradas, na condição de advogado(a) de Caio, que veio a tomar conhecimento dos fatos em julho de 2018, responda aos questionamentos a seguir.

- a) Existe argumento para questionar a decisão do magistrado que, em julho de 2018, determinou que o processo e o curso do prazo prescricional permanecessem suspensos? (Valor: 0,65)
- b) Existe argumento de direito material a ser apresentado em busca da absolvição de Caio? (Valor: 0,60)

QUESTÃO 3

Em patrulhamento de rotina, policiais militares receberam uma informação não identificada de que Wesley, que estava parado em frente à padaria naquele momento, estaria envolvido com o tráfico de drogas da localidade. Diante disso, os policiais identificaram e realizaram a abordagem de Wesley, não sendo, em um primeiro momento, encontrado qualquer material ilícito com ele. Diante da notícia recebida momentos antes da abordagem, porém, e considerando que o crime de associação para o tráfico seria de natureza permanente, os policiais apreenderam o celular de Wesley e, sem autorização, passaram a

ter acesso às fotografias e conversas no WhatsApp, sendo verificado que existiam fotos armazenadas de Wesley portando suposta arma de fogo, bem como conversas sobre compra e venda de material entorpecente.

Entendendo pela existência de flagrante em relação ao crime permanente de associação para o tráfico, Wesley foi encaminhado para a Delegacia, sendo lavrado auto de prisão em flagrante. Após liberdade concedida em audiência de custódia, Wesley é denunciado como incurso nas sanções do art. 35 da Lei 11.343/2006. No curso da instrução, foram acostadas imagens das conversas de Wesley via aplicativo a que os agentes da lei tiveram acesso, assim como das fotografias. Os policiais foram ouvidos em audiência, ocasião em que confirmaram as circunstâncias do flagrante. O réu exerceu seu direito ao silêncio.

Com base nas fotografias acostadas, o juiz competente julgou a pretensão punitiva do estado procedente, aplicando a pena mínima de 3 anos de reclusão, além de multa, e fixando o regime inicial fechado, já que o crime imputado seria equiparado a hediondo. Ainda assim, substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Considerando as informações narradas, responda, na condição de advogado(a) de Wesley, intimado(a) para apresentação de recurso de apelação.

- a) Existe argumento a ser apresentado para questionar as provas utilizadas pelo magistrado como fundamento para condenação? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Mantida a condenação, qual o argumento a ser apresentado para questionar a sanção penal aplicada? Justifique. (Valor: 0,60)

QUESTÃO 4

Em processo no qual se imputava a Antônio a prática do crime de constituição de milícia privada, foi designada audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. No dia da audiência, as testemunhas de acusação não compareceram, determinando o magistrado, por economia processual, a oitiva das testemunhas de defesa presentes, apesar de o advogado de Antônio se insurgir contra esse fato. Na ocasião, foram ouvidas três testemunhas de defesa, dentre as quais Pablo, que prestou declarações falsas para auxiliar o colega nesse processo criminal. Identificada sua conduta, porém, houve extração de peças ao Ministério Público, que, em 9 de abril de 2019, ofereceu denúncia em face de Pablo, imputando-lhe a prática do crime de falso testemunho na forma majorada.

No processo de Antônio, foi designada nova audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação; novamente, Pablo, a seu pedido, prestou declarações, confirmando que havia mentido na audiência anterior, mas que agora contava a verdade, o que veio a prejudicar a própria defesa do réu. Com base nas declarações das testemunhas de acusação e nas novas declarações de Pablo, Antônio veio a ser condenado. Pablo, por sua vez, em seu processo pelo crime de falso testemunho, também veio a ser condenado, reconhecendo o magistrado a atenuante do art. 65, inciso III, alínea *b*, do Código Penal.

Considerando as informações narradas, responda, na condição de advogado(a) de Antônio e Pablo.

- a) Qual argumento de direito processual poderá ser apresentado por você para desconstituir a sentença condenatória do réu? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Qual o argumento de direito material a ser apresentado pela defesa técnica de Pablo para questionar sentença condenatória? Justifique. (Valor: 0,60)

11.2 QUESTÕES DISCURSIVAS PENAIS INÉDITAS

QUESTÃO 1

A sociedade empresarial Papéis Brasil S/A tem como atividade principal a produção de papéis e de papelão, e em sua linha de produção utiliza várias substâncias químicas para clareamento dos papéis. Em reunião de acionistas realizada recentemente, ficou decidido, pelos quatro acionistas presentes, que o lixo químico originado da linha de produção seria armazenado em tanques impróprios e, posteriormente, descartado no pequeno córrego que passava atrás da sede da indústria. Tal conduta foi realizada, por determinação dos quatro acionistas, por dois funcionários da citada empresa, que, após questionarem os patrões quanto à legalidade da ordem, foram ameaçados de demissão imediata caso não cumprissem a determinação, inclusive sendo ameaçados de serem rotulados falsamente de “ladrões” para que não conseguissem mais empregos em outros lugares. No dia determinado, o lixo químico foi derramado no pequeno rio, causando contaminação de suas águas, mortandade de peixes e a interrupção do abastecimento de águas de duas cidades localizadas um pouco abaixo da indústria. Diante da situação hipotética, responda fundamentadamente os questionamentos a seguir:

- a) A responsabilidade penal pela prática desta conduta recai sobre que pessoas?
- b) A pessoa jurídica poderá ser denunciada pelo crime mesmo que o Ministério Público não consiga individualizar as condutas dos acionistas?
- c) Caso ocorra a extinção da punibilidade das pessoas físicas, a pessoa jurídica será beneficiada de algum modo?

QUESTÃO 2

A pessoa jurídica Cravos Embelezamento atua no mercado de produtos de beleza há alguns anos. Nos últimos tempos vem passando por inúmeras dificuldades financeiras, o que levou seu diretor financeiro a decidir por interromper os repasses de IRPF ao fisco, embora os descontos nos salários dos seus funcionários continuassem ocorrendo, pois não havia caixa suficiente para o pagamento dos salários e do recolhimento, optando o gestor por manter os salários em dia junto aos funcionários. Também por decisão do dirigente, a empresa deixou de emitir notas fiscais pelo fornecimento de alguns produtos, deixando de pagar os tributos estaduais e federais, referentes à sua comercialização.

Os fatos correram apenas no último mês de funcionamento da empresa, que acabou encerrando suas atividades informalmente em virtude das dificuldades financeiras atravessadas. Notificado pelos órgãos fiscais competentes, Julio, na condição de representante legal da sociedade, compareceu e defendeu a empresa nas averiguações legais. Concluído o procedimento fiscal, foram lançados definitivamente os tributos devidos. De acordo com a situação hipotética, responda as questões a seguir.

- a) Quais os crimes praticados?
- b) A quem compete processar e julgar tais crimes?
- c) O Ministério Público pode denunciar Julio com base em peças de informação oferecidas pelo contador da empresa, antes da conclusão dos processos administrativos?

Caso Julio, sabendo do lançamento definitivo, obtenha parcelamento dos tributos sonegados e não recolhidos, haverá reflexos penais?

QUESTÃO 3

Carlos Agal, na última semana, na condução de um carro de som, passou pelas ruas de um bairro da cidade de São Paulo executando uma gravação realizada por ele horas antes. Na gravação, afirmava que os comerciantes de tal bairro deveriam negar atendimento, em seus estabelecimentos, a pessoas de origem nordestina, pois a presença massiva de migrantes nordestinos na cidade era responsável pelo alto índice de desemprego e de violência, e que os nordestinos ainda eram responsáveis pelas péssimas opções políticas nas últimas eleições. No final do dia, Juscelino Moura, nordestino e morador da cidade, procura por Carlos Agal com o objetivo de solicitar explicações sobre o ocorrido. Carlos Agal o convida para entrar em sua casa e lhe oferece uma bebida, que continha um forte sedativo. Após o desmaio, Carlos amarra Juscelino e, somente pelo fato de ser nordestino, passa a agredi-lo fisicamente, por algumas horas, causando sofrimento físico. Em razão das lesões corporais sofridas, Juscelino perde a visão de um dos olhos. Quais os crimes praticados por Carlos Agal?

QUESTÃO 4

Paul Leo, turista norte-americano, chegou ao Brasil no último sábado, com a finalidade de realizar turismo pelas praias cariocas. Após pedir informações a um taxista sobre a prostituição na cidade, foi sugerido que consultasse alguns sites na internet que oferecem tais serviços de forma mais discreta e segura. Paul Leo consultou um dos sites e percebeu que, embora as profissionais parecessem jovens, havia uma nota informando que todas eram maiores de 18 anos. Sentindo-se seguro quanto à legalidade de seu ato, Paul Leo telefonou para um dos números informados, acertou os valores e contratou os serviços a serem prestados no próprio hotel em que estava hospedado. No horário combinado recebeu em seu quarto a jovem prostituta, que se apresentou na recepção do hotel com o nome de Maria Clara, apresentando documento de identidade, que atesta ser maior de dezoito anos, e teve com ela atos sexuais. Após algumas horas, atendendo a denúncia anônima, chegou ao hotel uma equipe da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, que, após verificar que os documentos da jovem eram falsos, prendeu em flagrante Paul Leo. Instaurado o inquérito policial, todos os fatos foram apurados e houve o indiciamento do investigado pelo crime de prostituição infantojuvenil, previsto no art. 218-B, § 2.º, I, do CP. Encerrado o inquérito, foi encaminhado ao Ministério Público, que procedeu à denúncia do agente pelos mesmos fatos. A denúncia foi recebida e a família de Paul Leo procurou seu escritório de advocacia.

- a) Qual instrumento de impugnação poderá ser utilizado em favor do agente? Fundamente.
- b) Quais argumentos podem ser utilizados em sua defesa? Fundamente.

QUESTÃO 5

Julio foi preso em flagrante quando vendia três comprimidos de *ecstasy* para um jovem na porta de uma festa de música eletrônica. Apresentado à autoridade policial, foi realizado o laudo de constatação e realizada a prisão em flagrante, imediatamente comunicada ao juízo competente que, atendendo a requerimento da autoridade policial, determinou busca e apreensão na residência do rapaz, a fim de encontrar outras drogas ilícitas; entretanto, nada mais fora encontrado. Após encerramento do inquérito policial e encaminhamento ao Ministério Público, foi oferecida e recebida a denúncia. Em depoimento, Julio informou que é estudante de química, trabalha em um laboratório de medicamentos e nunca foi preso ou processado, e informou que adquiriu as drogas de um estrangeiro que conheceu na véspera num bar da zona sul da cidade, com a finalidade de vender e arrecadar dinheiro para comprar uns livros que estava precisando. Após o devido processo legal, o agente foi condenado como incurso no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, à pena de reclusão de dois anos e oito meses, em regime fechado.

- a) O regime inicial de cumprimento de pena poderia ser outro? Fundamente.
- b) É possível substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos? Fundamente.

QUESTÃO 6

Maria está internada na UTI de um hospital particular. Há alguns dias entrou em coma, e as perspectivas de sobrevivência são muito ruins. João é enfermeiro no mesmo hospital e foi designado para cuidar da higiene pessoal da paciente. Na tarde de ontem, quando realizava os atos de higiene corporal da paciente, João decidiu praticar atos sexuais com ela, aproveitando-se da completa incapacidade de resistência provocada pelo coma. No dia seguinte, os vestígios da prática de tais atos foram notados pela chefe da UTI, que comunicou sua desconfiança à diretoria e às autoridades policiais. Com a chegada dos policiais, foi realizada perícia na paciente e, para surpresa de todos, os peritos constataram que Maria tinha morte cerebral há pelo menos quatro dias e que os atos sexuais foram praticados com ela no dia anterior, recolhendo líquido espermático utilizado legalmente na identificação do enfermeiro João como autor dos atos libidinosos. Considerando os fatos narrados, qual tese de defesa pode ser utilizada em favor do agente? Fundamente.

QUESTÃO 7

Mário encontrou no quintal de sua casa uma pistola calibre 9 mm, de propriedade ignorada e com a numeração de identificação raspada. Levou a arma para o interior da residência e guardou em local seguro e escondido no interior de um armário. Dias após o fato, arrependido e preocupado com a eventual possibilidade de ser preso, procurou pela Delegacia de Polícia Federal e declarou o fato, afirmando que gostaria de entregar a arma de fogo voluntariamente. De imediato obteve uma guia de transporte, com validade de 48 horas, para levar a arma até a delegacia. Caso a entrega seja realmente realizada, como fica a situação jurídico-penal do agente? Houve crime? Pode ser punido?

QUESTÃO 8

Julio conduzia seu veículo automotor por uma via urbana com excesso de velocidade, quando colidiu no veículo conduzido regularmente por Maria na mesma via. A colisão, além dos danos patrimoniais, causou lesões corporais em Natalia, que estava no banco do carona do veículo conduzido por Maria. Julio e Maria, exaltados, discutiam os danos patrimoniais e decidiram não prestar socorro a Natalia, embora tendo notado as lesões sofridas por ela. Michel, pedestre que passava pelo local no momento do acidente, também decidiu afastar-se sem prestar socorro à vítima. De acordo com a situação hipotética, tipifique as condutas dos agentes.

QUESTÃO 9

Qual a ação penal dos crimes a seguir? Fundamente suas respostas.

- a) Lesão corporal leve praticada com violência doméstica, prevista no art. 129, § 9.º, do CP.
- b) Estupro qualificado pela morte da vítima, previsto no art. 213, § 2.º, do CP.
- c) Injúria por preconceito racial, praticada contra funcionário público em razão de suas funções.

QUESTÃO 10

Carlos, na última quinta-feira, aproveitando-se da viagem de seus vizinhos, entrou na casa vazia e subtraiu uma grande quantidade de bens. Quando saía do local, foi abordado por Mércia, mãe do dono da casa, que chegava para alimentar os cães e molhar as plantas. Para garantir que levaria os bens subtraídos, desferiu dois disparos de arma de fogo contra a vítima, que acabou morrendo em razão dos ferimentos. Tipifique a conduta de Carlos.

11.3 QUESTÕES DISCURSIVAS PROCESSUAIS PENAIS INÉDITAS

QUESTÃO 1

Sobre os recursos e ações autônomas de impugnação, responda as assertivas a seguir de forma completa.

- a) Qual(is) o(s) meio(s) de impugnação privativos da defesa no processo penal?
- b) Cabe revisão criminal de uma decisão proferida pelo Tribunal do Júri?
- c) Pessoa jurídica pode impetrar HC? Ser coatora? Paciente?
- d) Qual o órgão competente para julgar uma revisão criminal de uma decisão colegiada proferida pelo Superior Tribunal de Justiça?
- e) Qual recurso cabe da decisão que denega HC proferido pelo juiz de 1.º grau? Exemplifique ao menos um caso nessa situação.

QUESTÃO 2

Deco, Jorginho e Margareth, comprovadamente integrantes de uma organização criminosa nacionalmente conhecida, são presos e acusados por homicídio qualificado e tráfico de drogas em 2007.

São denunciados formalmente pelo promotor de justiça, que detalha com riqueza todas as condutas. A 1.ª fase do tribunal do júri tramita dentro da legalidade e os três são pronunciados pelo nobre magistrado. Recurso interposto no prazo legal, o Tribunal de Justiça confirma a decisão. Paralelamente à marcação do julgamento em plenário, sobrevém a reforma processual penal de 2008, em pleno vigor, que, entre algumas mudanças, extingue o protesto por novo júri.

O julgamento dura três dias seguidos, com um grande interesse da sociedade e cobertura da imprensa. Todos são condenados. Pena de 21 anos de reclusão em regime inicialmente fechado para cada um. A sociedade respira aliviada.

Acerca da questão apresentada, responda os itens a seguir fundamentadamente.

- a) Qual o recurso da decisão de pronúncia e seu respectivo prazo?
- b) Qual a natureza jurídica da decisão de pronúncia?
- c) Caso fossem impronunciados, qual seria o recurso e seu prazo?
- d) Conceitue organização criminosa.
- e) Enfrente o cabimento de liberdade provisória no crime de tráfico de drogas.
- f) Uma vez condenados, você, advogado, é indagado acerca da possibilidade de apresentação do Protesto por Novo Júri. Qual seria sua resposta?

QUESTÃO 3

Sobre os procedimentos penais no Diploma Processual Penal, responda de forma fundamentada as assertivas a seguir.

- a) Qual o critério determinante para se definir os procedimentos ordinário, sumário, sumaríssimo e do funcionário público?
- b) Qual(is) a(s) diferença(as) entre os procedimentos ordinário e sumário?
- c) Qual(is) a(s) diferença(as) entre o procedimento ordinário e o funcionário público?
- d) Em que procedimentos existe a possibilidade de defesa preliminar? Qual seu momento correto? Qual seu prazo?

QUESTÃO 4

Jairo, prefeito do município de Minduri, no interior de Minas Gerais, adora viajar. Comenta-se no município que quem governa mesmo é seu vice, Armando. Em uma de suas viagens, Jairo, em Gramado, no Rio Grande do Sul, envolve-se em uma briga em um restaurante elegante e chique. Jairo, muito ciumento com sua esposa Babi, agride um rapaz que olhou para sua mulher. Por conta das agressões, a vítima é levada ao hospital local e permanece internada sem previsão de alta. Impressionou a fúria do prefeito.

Retornando à sua cidade natal justamente em época de eleição, Jairo vai aos locais rurais e mais pobres da região e, em troca de cestas básicas, camisas e transporte gratuito, traz as pessoas humildes para votarem em sua reeleição.

Acerca da questão apresentada, responda de forma fundamentada e integral, tipificando as condutas

com seus respectivos órgãos competentes para julgamento.

QUESTÃO 5

Acerca do Juizado Especial Criminal (Lei 9.099/1995), responda, fundamentadamente.

- a) Quais os princípios informadores do Juizado Especial Criminal?
- b) Haveria alguma possibilidade de um crime que não seja de menor potencial ofensivo ser julgado pelo ditames da Lei 9.099/1995?
- c) Mencione ao menos três hipóteses de julgamento de um crime de menor potencial ofensivo fora do Juizado Especial Criminal.
- d) Cabe suspensão condicional do processo para o crime de estelionato?
- e) Qual a consequência jurídica do acordo feito pela composição civil dos danos?
- f) Havendo a possibilidade e sendo direito do autor do crime de menor potencial ofensivo, qual a consequência da inércia do MP em não oferecer a transação penal? E de não oferecimento da suspensão condicional do processo?
- g) Quais os recursos cabíveis em sede de Jecrim? E os prazos?

QUESTÃO 6

Uma notícia curiosa chama a atenção da população de Brasília. Um furto de R\$ 12.000,00 em moedas e algumas barras de chocolate da lanchonete localizada dentro das dependências do Congresso Nacional. Sobre essa notícia, responda fundamentadamente:

- a) A que órgão cabe a apuração dos fatos?
- b) Em caso de crimes federais, qual(is) a(s) medida(s) que o Órgão do Ministério Público deve tomar ao receber o inquérito policial?
- c) No caso da letra anterior, disserte sobre a sistemática do arquivamento do inquérito policial.
- d) A quem cabe a investigação de crimes eleitorais?

QUESTÃO 7

Jeferson é um trabalhador exemplar. Trabalha em regime de plantão na Penitenciária Federal de Catanduvas – Paraná. Pai de três filhos e com a esposa desempregada, as despesas começam a se acumular e as dívidas do cartão de crédito começam a lhe tirar o sono. Sua esposa não admite oferecer produtos alimentícios de segunda linha às suas filhas.

Certa noite, Jeferson recebe um telefonema anônimo lhe perguntando se ele estaria interessado em ganhar uma “grana fácil”. Jeferson, homem honesto e desconfiado, não aceita a oferta, achando que é um trote. No dia seguinte, em seu habitual trajeto ao trabalho, para na padaria do bairro para o tradicional café com leite e é surpreendido por um homem educado e distinto que lhe diz, em poucas palavras: “Nós iremos lhe ligar hoje novamente. Atenda e escute”. O homem sorri friamente e vai embora. Jeferson fica indignado, ainda mais com o visível sotaque estrangeiro de seu misterioso interlocutor. No mesmo dia, à noite, o telefone toca no mesmo horário e Jeferson é chamado pelo nome.

– Jeferson?

– Sim – responde estranhamente.

– Sabemos que você está com problemas financeiros. Vamos resolver isso para você. Amanhã você receberá um pacote com R\$ 5.000,00 antes de ir para a penitenciária. Você apenas deverá deixar de revistar um visitante do presídio. Ele estará de camisa polo vermelha, calça jeans e sapato branco, além de possuir bigode. Ou seja, um dinheiro fácil.

Jeferson, pensativo, acaba aceitando a oferta, mas antes pergunta:

– O que será levado para dentro do presídio?

– Celular – responde e o telefone é desligado.

No dia seguinte, tudo ocorre como combinado, e Jeferson identifica claramente o homem que não será revistado tradicionalmente. O que Jeferson não contava era com a prisão desse homem no dia seguinte, que contou tudo à polícia.

Sobre o fato narrado, responda fundamentadamente.

- a) Quais os crimes cometidos pelos três envolvidos?
- b) Em uma eventual acusação formal, os envolvidos teriam algum privilégio processual?
- c) Em eventual privilégio processual, aborde a posição de nossos tribunais superiores sobre o tema.

QUESTÃO 8

Giovana, famosa líder comunitária na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, é surpreendida durante sua campanha eleitoral à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com uma traição de seu marido. Este possui um caso com uma menina da comunidade 10 anos mais nova que ela. Giovana não quer acreditar, pois abriu mão de seus sonhos para ter uma bela família, todavia, descobre por meio do Facebook a traição.

No domingo da eleição, Petrópolis tem um dia calmo de votação, a não ser pela notícia da morte do marido de Giovana. No dia seguinte, com o resultado das eleições, Giovana descobre que é a mais nova Deputada Estadual da Assembleia Fluminense. É nomeada, toma posse, mas também é acusada pelo assassinato de seu marido. O Ministério Público acredita em crime passional. Sobre a narrativa apresentada, disserte, fundamentadamente, sobre a competência penal para eventual julgamento de Giovana abordando TODOS os aspectos jurídicos pertinentes ao caso.

QUESTÃO 9

Linda acabou de passar no exame da OAB. Passou sua faculdade inteira estagiando em um excelente escritório na área criminal. Tornou-se braço direito do Dr. Geraldo, sócio-fundador. Linda, muito atenta, aprendeu com o nobre jurista que o Direito não é uma ciência que está restrita às leis. É preciso “estudar” as pessoas e ter sensibilidade. Com a aprovação e nota máxima, é promovida a advogada jr. do escritório. Em sua primeira atuação como advogada, é levada para observar uma audiência de instrução e julgamento pelo ilustre Dr. Geraldo, que lhe alerta sobre as peculiaridades do caso.

Iniciada a audiência, o membro do Ministério Público senta ao lado do Juiz e convoca o acusado, um senhor de 70 anos, a entrar na sala. Sérgio é acusado de inúmeros estelionatos e por esse motivo está escoltado e algemado.

Dr. Geraldo o defende, pois foram amigos de infância, mas tomaram rumos diferentes na vida. Iniciada a instrução, Sérgio não é alertado sobre o direito ao silêncio e responde todas as perguntas feitas pela rigorosa juíza. Após suas perguntas, as partes não têm a oportunidade de participar do ato. Em seguida, são chamadas as testemunhas de acusação. A excelentíssima juíza inicia as perguntas e mais uma vez não permite a participação do promotor de justiça e do advogado. Vale observar que a nobre magistrada fez inúmeras perguntas às testemunhas de acusação e pouquíssimas às testemunhas de defesa.

Encerrado o feito, a juíza informa que a regra atual são as alegações finais escritas por memoriais, motivo este que a faz encerrar a audiência dando vista às partes para que em 10 dias ofereçam suas alegações. Retornando ao escritório, Linda é indagada pelo seu mentor Dr. Geraldo.

Ajude-a a responder, fundamentadamente e com os respectivos dispositivos de lei, os questionamentos a seguir:

- a) Existe(m) alguma(s) nulidade(s) que pode(m) ser alegada(s)?
- b) Determine dois princípios que motivaram a alteração da nova audiência de instrução e julgamento.
- c) Qual sua opinião a respeito da posição do Ministério Público na sala de audiência?

QUESTÃO 10

Nelson, 60 anos, é um famoso aposentado muito querido em seu bairro. Apesar da idade, está sempre disposto a ajudar seus amigos. Toda sexta-feira, na feira do bairro, muito descontraído, faz suas compras com prazer. Na última terça, 10 de fevereiro do corrente ano, é anunciada uma promoção imperdível de mamões papaia, fruta predileta de Nelson. A fila da barraca está longa, mas o dono permite a venda preferencial para Nelson, não só pela idade, mas por ser um comprador habitual. Os demais não veem problema, salvo Marcelo, garoto arruaceiro, que estava ali na fila obrigado por seu pai, um reformado coronel que queria dar-lhe disciplina e alimentação saudável.

Marcelo, indignado, na frente de todos, xinga raivosamente Nelson: “Seu velho gagá, não fura fila não! Tem mais é que ficar em casa esperando a morte chegar! Sai daí, velho babão”.

Triste, desolado e impressionado com a juventude de hoje, você, advogado, que estava na fila e admira Nelson, lhe oferece seus serviços jurídicos.

Sobre a narrativa, determine o que pode ser feito em favor de Nelson, determinando o prazo legal para a medida jurídica cabível.

-
- 1 Com Gabarito Comentado oficial.
 - 2 Com Gabarito Comentado Oficial.
 - 3 Com Gabarito Comentado Oficial.
 - 4 Com Gabarito Comentado Oficial.

12.1 PEÇAS PRÁTICO-PROFISSIONAIS INÉDITAS QUE ESTÃO AO LONGO DA OBRA

Peça 01	
Peça	Notícia-Crime
Endereçamento	Delegado de Polícia de Búzios – Rio de Janeiro
Fundamento Legal	Art. 5.º, II, do CPP
Preliminares	–
Fundamentos	Tipificar a conduta como crime de furto qualificado (art. 155, § 4.º, I, do CP)
Pedidos	Investigação com devida abertura do Inquérito Policial
Autenticação	Padrão
Comentários	Partimos do princípio de que uma notícia-crime não é uma peça exclusiva de advogado, todavia, acreditamos que para a densidade desta obra, esta deve estar presente. A narrativa nos traz apenas fatos, em nada de aspectos procedimentais, sendo assim, não temos processo. É bem clara a ausência de autoria e de que o crime é contra o patrimônio. Além disso, nos exige a primeira medida,

	razão pela qual deva ser feita notícia-crime. Tipificar a conduta, nesse caso, não seria fundamental, todavia, para um certame de alto nível, tal medida se faz necessária. Uma breve análise do art. 155 do CPP nos orienta para a qualificadora de rompimento de obstáculo, lembrando que neste caso não poderia incidir também a causa de aumento do repouso noturno.
--	--

Peça 02	
Peça	Relaxamento de Prisão
Endereçamento	Juiz de Direito da Vara Criminal
Fundamento Legal	Art. 5.º, LXV, da CF c/c art. 310, I, do CPP
Preliminares	–
Fundamentos	Flagrante Preparado Súmula 145 do STF: Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.
Pedidos	Reconhecimento da Ilegalidade da Prisão. Expedição do Alvará de Soltura. Subsidiariamente a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
Autenticação	Padrão
	O flagrante preparado é uma das hipóteses mais famosas de ilegalidade na prisão. Nessa situação, um verdadeiro

Comentários	ensaio é feito para que o criminoso se sinta incentivado a cometer tal delito. Acreditamos que nesse caso sua vontade não é mais livre, exigência fundamental para a conduta dolosa, e sim viciada pelo incentivo por parte de outrem. Na questão não se deve mencionar outros aspectos senão estes dispostos na Súmula 145 do STF.
--------------------	---

Peça 03	
Peça	Liberdade Provisória
Endereçamento	Juiz de Direito do Juizado Especial
Fundamento Legal	Art. 5.º, LVI, da CF c/c arts. 310, III, e 321 do CPP
Preliminares	–
Fundamentos	Demonstrar a ausência dos requisitos da Preventiva (art. 312 do CPP). Demonstrar a possibilidade de liberdade provisória tendo em vista bons antecedentes, primariedade, trabalho e residência fixos, além da demonstração de comparecimento em eventual intimação (art. 321 do CPP). Abordar que a prisão, atualmente, é só em último caso, segundo alterações trazidas pela Lei 12.403/2011 (art. 282, § 6.º, do CPP). Possibilidade ainda de mencionar que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão.

Pedidos	Reconhecimento da Ausência de Requisitos da Prisão Preventiva. Expedição do Alvará de Soltura. Subsidiariamente a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
Autenticação	Padrão
Comentários	Atualmente a peça de liberdade provisória perdeu muito de sua interposição. Acreditamos que com as exigências dos arts. 306 e 310 do CPP a liberdade provisória se tornou mais uma decisão judicial do que uma medida prático-profissional por parte da defesa técnica. Tivemos o cuidado, nesse caso, de mencionar a urgência da medida antes das 24 horas estabelecidas pelo art. 306 do CPP. Nesse singular caso, se faz presente a medida de liberdade provisória. Senão vejamos. Caso o juiz não seja informado dessa prisão em flagrante, esta se tornará ilegal, cabendo, portanto, relaxamento de prisão. Se comunicado, adotará o próprio relaxamento, a prisão preventiva e a liberdade provisória. Ressalvas feitas, os fundamentos desta peça são por demais simples, exigindo-se somente a demonstração da necessidade de prisão preventiva, mencionando-se os requisitos pessoais do requerente e possibilitando, ainda, ao magistrado uma das inovadoras medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP.

Peça	Revogação da Prisão Preventiva
Fundamento Legal	Art. 310, II c/c art. 316 do CPP
Preliminares	–
Fundamentos	Competência da Justiça Federal (art. 109, IV c/c art. 21, VII, da CF) para julgamento de crime de Moeda Falsa (art. 289 do CPP). Abordar ausência de garantia da ordem pública, ordem econômica e conveniência da instrução criminal.
Pedidos	Reconhecimento da Ausência de Requisitos da Prisão Preventiva. Expedição do Alvará de Soltura. Subsidiariamente a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
Autenticação	–
	Primeiro cuidado que se deve ter neste caso Prático-Profissional proposto é a competência. O crime de moeda falsa é julgado pela Justiça Federal, por ser a emissão de moeda um interesse federal ligado à União Federal, conforme o art. 109, IV c/c art. 21, VII, da CF. No mais, deve-se informar que, por mais que se tenham indícios de autoria e materialidade, os requisitos estão ausentes, tais como a conveniência da instrução criminal, onde o enunciado informa a confissão e a facilitação nas investigações. Além disso, falsificação não significa

Comentários	obrigatoriamente uma garantia da ordem econômica, muito menos supostamente integrar organização criminal enseja uma prisão em decorrência da garantia da ordem pública. Vale ainda observar que não cabe neste caso a aplicação da Súmula 73 do STJ, por se tratar de falsificações idênticas e não grosseiras como preconiza o entendimento sumular que se segue: “A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual.”
--------------------	--

Peça 05	
Peça	Queixa-Crime
Endereçamento	Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Fundamento Legal	Arts. 30, 41 e 44 do CPP c/c art. 100, § 2.º, do CP
Preliminares	–
Fundamentos	Incidência da Violência Doméstica com base nos arts. 1.º, 5.º e 7.º, V, da Lei 11.340/2006; Difamação (art. 139 do CP); Injúria (art. 140 do CP); Causa de Aumento (art. 141, III, do CP).
	Recebimento da Ação, Apresentação da Defesa,

Pedidos	Condenação Final, Indenização conforme o art. 387, IV, do CPP, Rol de Testemunhas.
Autenticação	Prazo Fatal: 23 de julho de 2013
	O caso apresentado surpreende desde o início pela incidência da famosa Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). No caso em tela sem dúvidas há tal colocação por dois motivos: primeiro porque a vítima é mulher, depois porque existe claramente uma superioridade moral e financeira entre o autor do crime e a vítima. Além disso, sabemos que, quando se fala em “crime de violência doméstica”, não podemos ficar restritos às agressões físicas. Neste aspecto importante a colação do art. 7.º da mencionada lei: Art. 7.º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I – a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe

Comentários

cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

III – a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V – a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

Quanto aos crimes, a difamação do art. 139 do CP se faz presente quando o pai relata que “a filha só quer saber de badalar, chega bêbada em casa.” Trata-se de um fato relatado que não constitui crime, capaz de tipificarmos tais ofensas como difamação.

Já a injúria (art. 140 do CP) é visualizada quando do momento em que o autor das ofensas informa que a vítima é “vagabunda”.

Não esqueçamos da causa de aumento, tendo em vista

	ter sido informado que o fato ocorreu na presença de várias pessoas, exigência essa do art. 141, III, do CP e do rol de testemunhas que necessita ser apresentado após autenticação. André e Felipe presenciaram o fato e precisam ser mencionados.
--	---

Peça 06	
Peça	Queixa-Crime Subsidiária da Pública
Endereçamento	Juiz de Direito da Vara Criminal
Fundamento Legal	Arts. 30, 41 e 44 do CPP c/c art. 100, § 3.º, do CP
Preliminares	–
Fundamentos	Perda de Prazo do Ministério Público, conforme o art. 46 do CPP; Tipificação da conduta no crime do art. 171 do CP.
Pedidos	Recebimento da Ação, Apresentação da Defesa, Condenação Final, Indenização, conforme o art. 387, IV, do CPP, Rol de Testemunhas.
Autenticação	Padrão
	Peça de fácil identificação tendo em vista a ausência de procedimento judicial, o que nos faz entender ser uma medida inaugural. Com a inércia do respectivo promotor

Comentários	de justiça, titular exclusivo da ação penal pública, conforme o art. 129, I, da CF, a presente ação se torna medida extraordinária, já que o crime de estelionato (art. 171 do CP) é de iniciativa ministerial. No mais, parecidíssima com a já vista queixa-crime.
--------------------	---

Peça 07	
Peça	Resposta do Acusado
Endereçamento	12ª Vara Criminal da Comarca da Capital
Fundamento Legal	Art. 396 c/c art. 396-A do CPP
Preliminares	Exceção de Incompetência (art. 95, II, do CPP) do Juízo Estadual por se tratar de crimes contra carteiro e agência comunitária ligados à empresa pública federal dos Correios (ECT); Preliminares de Ilegalidade da Busca Domiciliar sem mandado judicial e de Invasão de Domicílio durante a noite sem situação de flagrância, conforme o art. 5.º, XI, da CF – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”;
Fundamentos	Buscar a absolvição sumária dos crimes de sequestro e incêndio pela ausência de conduta dolosa nesses dois crimes, com base no art. 397, inciso III, CPP.

Pedidos	Reconhecimento da Exceção de Incompetência e remessa ao juízo competente; Reconhecimento da Nulidade da Diligência com respectivo pedido de desentranhamento dos autos de tal medida, conforme o art. 564, IV, do CPP por ofensa constitucional ao art. 5.º, XI, da CF; Reconhecimento da absolvição sumária dos crimes de incêndio e sequestro com base no art. 397, III, CPP.
Autenticação	11 de setembro de 2012
Comentários	Questão que merece destaque tendo em vista o surgimento de exceções, preliminares e fundamentações. Peça completa que percorre por inteiro o roteiro de uma resposta do acusado. Inicialmente a preocupação é quanto à competência. Entendem nossos tribunais superiores que crimes em detrimento de carteiros e agências dos correios comunitárias são de competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, IV, 2.ª parte, da CF. Existe um ataque direto ao serviço postal, serviço este de interesse da União Federal. Num segundo plano a pesquisa deve ser feita em relação às preliminares e, na ausência de extinções de punibilidade, a pesquisa de violações constitucionais deve ser feita. Descobre-se, assim, duas ilegalidades constitucionais. O elemento central da configuração da conduta é a vontade dolosa ou culposa. Não havendo nenhuma das

duas, deve-se almejar a atipicidade da conduta. Isso ocorreu com as exageradas tipificações ministeriais no tocante aos crimes de sequestro e incêndio. Em nenhum momento do enunciado percebe-se demonstração desse especial fim de agir desses crimes da denúncia do Ministério Público. Talvez algum outro crime pode até ter acontecido, mas deveria o órgão acusatório analisar melhor os fatos.

Vale ainda lembrar, seguindo a melhor doutrina, que a resposta do acusado não é o momento oportuno para pedir eventuais desclassificações, deixando-as para a fase de memoriais.

Sobre a contagem do prazo, insta salientar que esse prazo é processual e começa a contar no primeiro dia útil subsequente à entrega do mandado pessoal. Sobre a contagem, o art. 798, CPP, não nos deixa dúvidas.

Peça 08

Peça	Exceção de Suspeição
Endereçamento	23. ^a Vara Criminal
Fundamento Legal	Art. 396-A, § 1.º c/c art. 95, I, do CPP
Preliminares	–
Fundamentos	Demonstração de amizade íntima conforme artigo legal, comprometendo, assim, a imparcialidade de julgamento.
	Reconhecimento da Suspeição, conforme o art. 99 do CPP;

Pedidos	Subsidiariamente que o juiz apresente a defesa e remeta o presente incidente ao tribunal, conforme o art. 100 do CPP.
Autenticação	17 de abril de 2013
Comentários	Hipótese das mais raras a apresentação da exceção em tela, pois geralmente, com base na instrumentalidade das formas, estes incidentes de defesa são inseridos no corpo da resposta do acusado, como já tivemos oportunidade de ver. Suspeição é uma tentativa de se proteger a imparcialidade do julgamento e simplesmente isto deve ser demonstrado sem maiores questionamentos.

Peça 09	
Peça	Alegações Finais por Memoriais
Endereçamento	Juiz da Vara Criminal
Fundamento Legal	Art. 403, § 3.º, do CPP
Preliminares	Violação ao Direito de Presença aos Atos Processuais (art. 5.º, LV, da CF c/c Súmula 523 do STF); Pacto de São José da Costa Rica (art. 8.º, 2, “d”, “e” e “f”) Violação ao Princípio do Devido Processo Legal por inversão na ordem da AIJ (art. 5.º, LIV c/c art. 400 do CPP).
	Absolvição por ausência de provas – Princípio do In Dubio

Fundamentos	Pro Reo (art. 386, V, do CPP); Subsidiariamente, retirada das causas de aumento do uso de emprego de arma e do concurso de duas ou mais pessoas por ausência de demonstração da utilização da arma e dos requisitos para configuração do concurso de pessoas.
Pedidos	Decretação das Nulidades, conforme os arts. 5.º, LIV c/c art. 5.º, LV, da CF c/c art. 564, IV, do CPP; Absolvição com base no art. 386, V, do CPP; Retirada das causas de aumento.
Autenticação	Padrão
	Peça de grande abrangência por se tratar da última manifestação antes da sentença penal. Nesta peça tudo que puder ser alegado dentro da razoabilidade deve ser mencionado, inclusive casos subsidiários. A peça prático-profissional proposta trabalha as preliminares, avaliando a ordem procedimental numa audiência alterada pela reforma processual penal de 2008 (Lei 11.719/2008) e a capacidade de perceber que a presença em atos de instrução faz parte da ampla defesa. Nesse sentido preconiza o Pacto de São José da Costa Rica, em seu art. 8.º, 2 letras: d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor;

Comentários

e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;

f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos,

Ainda deve-se mencionar uma das súmulas mais interessantes para a defesa no processo penal, a de número 523 do STF:

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

No mais, o conhecido princípio da dúvida se faz presente como principal fundamentação da peça, pois não fica claro em seu enunciado a autoria do delito e sabemos que para haver condenação é necessária a certeza da autoria.

Concluindo, a retirada das causas de aumento por ausência de sua demonstração efetiva.

Peça 10

Peça

Recurso em Sentido Estrito

Endereçamento

Juiz Federal (folha de interposição) e Tribunal Regional Federal (razões recursais)

Fundamento Legal	Art. 581, X, do CPP
Preliminares	–
Fundamentos	Concessão da liberdade tendo em vista a contribuição do paciente com a persecução criminal; Incapacidade de permanência na prisão para servir de exemplo.
Pedidos	Reforma da decisão para que se conceda a expedição do alvará de soltura.
Autenticação	Padrão
Comentários	Tendo em vista ter sido o juiz federal que não concedeu o habeas corpus, a necessidade de medida exclusiva de advogado se impõe por meio de recurso em sentido estrito. Nossos tribunais superiores entendem que tal medida, pela internacionalidade, é de competência da justiça federal. Sendo assim, órgão de 2.º grau é o Tribunal Regional Federal. No mais, sem devaneios, abordar a justiça de se responder em liberdade tendo em vista a contribuição com a persecução criminal e enfatizar que a prisão não pode servir, simplesmente, de exemplo.

Peça 11

Peça	Apelação
Endereçamento	Folha de Interposição para o Juiz-Presidente do IV Tribunal do Júri e as razões recursais dirigidas ao Tribunal

	de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Fundamento Legal	Art. 593, III, a, do CPP
Preliminares	Argumentar contrariamente à prisão em decorrência da decisão de pronúncia. Ausência de fundamentação para a mesma, conforme o art. 413, § 3.º, do CPP. Nulidade da Pronúncia que não se limitou aos indícios de autoria e materialidade conforme o art. 413, § 1.º, do CPP. Nulidade do julgamento com base em documentos exibidos sem anuência da defesa conforme o art. 479 do CPP. Nulidade por indução do promotor a recusa conforme o art. 478 do CPP. Nulidade na ordem dos quesitos conforme o art. 483 do CPP.
Fundamentos	–
Pedidos	Nulidade e novo julgamento
Autenticação	Felipe 123.456 10 de dezembro de 2010
	Nesta apelação proveniente de decisão do Tribunal do Júri, devemos ficar atentos, principalmente ao art. 593, III, do Diploma Processual Penal, pois é ele que delimita a elaboração da peça de apelação. No tribunal do júri vigora o princípio da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF). Este dogma é traduzido com a

Comentários

impossibilidade de determinado tribunal de 2.º grau alterar o mérito da decisão dos jurados. Atentamente percebemos que a fundamentação que ataca o mérito da decisão dos jurados é tão somente a do art. 593, III, “d”, cuja proteção constitucional pode ser visualizada no próprio artigo em seu § 3.º, onde eventual provimento da apelação gerará um novo júri e não sua reforma pelo tribunal de 2.º grau.

Entretanto, no caso em tela, estamos diante de inúmeras nulidades e a fundamentação de nossa apelação restringe-se a mencioná-las. Estranhamente, o recurso inteiro gira em torno das nulidades da pronúncia, da exibição de documentos, de quesitação errônea feita em Sala Especial. Ótimo treinamento acerca do procedimento do Tribunal do Júri.

Peça 12

Peça	Embargos de Declaração
Endereçamento	Juiz de Direito da 18.ª Vara Criminal
Fundamento Legal	Art. 382 do CPP
Preliminares	–
Fundamentos	Por omissão e obscuridade, tendo em vista a ausência de manifestação sobre qual o crime que ensejara a condenação em 1 ano, além da falta de provimento jurisdicional acerca da suspensão condicional do processo requerida expressamente pela parte.

Pedidos	De nova sentença penal. De concessão da Suspensão Condicional do Processo.
Autenticação	16 de junho de 2013
Comentários	Peça extremamente simples com pouquíssima incidência em provas prático-profissionais. Lembro-lhes que os embargos de declaração em face de sentença têm seu fundamento legal no art. 382 do CPP e não no art. 619 do CPP, pois este dispositivo se refere aos embargos em 2. ^a Instância. No caso apresentado fora uma sentença obscura, por não mencionar o crime pelo qual houve a condenação, além de omissão acerca de eventual deferimento de medida despenalizadora de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/1995). Vale observar que tal medida não é exclusiva do Juizado Especial Criminal, cabendo, inicialmente, para os crimes cuja pena mínima em abstrato não ultrapasse 1 ano.

Peça 13	
Peça	Embargos Infringentes e de Nulidade
Endereçamento	Folha de Interposição e Razões para o Tribunal Regional Federal
Fundamento Legal	Art. 609, parágrafo único, do CPP
Preliminares	—
	Nulidade absoluta da sentença condenatória em virtude da ausência de exame de corpo de delito obrigatório nos crimes materiais (art. 158 c/c art. 564, III, “b”, do CPP) e

Fundamentos	a necessidade de absolvição do embargante por insuficiência de provas (art. 386, VII, do Estatuto Processual Penal).
Pedidos	Reforma do Acórdão com base no voto dissidente.
Autenticação	Padrão
Comentários	Peça de extrema simplicidade, tendo em vista sua tranquila identificação quando se aborda em seu enunciado que a decisão colegiada fora não unânime, permitindo-se, assim, o presente recurso privativo da defesa no processo penal cabível em decisões dessa monta, ou seja, por maioria. Endereçamento ao TRF por se tratar de crime federal e que não é remetido aos tribunais superiores. Em conclusão, o próprio enunciado nos fornece o que deverá ser atacado em sede de embargos infringentes e de nulidade.

Peça 14

Peça	Recurso Especial
Endereçamento	Folha de Interposição ao Tribunal Regional Federal e as razões ao Superior Tribunal de Justiça
Fundamento Legal	Art. 105, III, "a", da CF c/c art. 1.029 do NCPC.
Preliminares	—
Fundamentos	Pagamento integral do débito tributário fiscal, segundo o art. 9.º, § 2.º, da Lei 10.684/2003, extingue a

	punibilidade.
Pedidos	Reconhecimento da Extinção da Punibilidade.
Autenticação	Padrão
	A apresentação do recurso especial se faz necessária por se tratar de acórdão unânime que ofende lei federal. Inicialmente vale salientar que o Ministério Público respeitou a aplicação da Súmula Vinculante 24, que exige a configuração do débito tributário na esfera fiscal. Senão vejamos: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1.º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.” Todavia, com o pagamento integral do mesmo, deveria o Tribunal ter reconhecido a extinção da punibilidade, segundo o art. 9.º, § 2.º, da Lei 10.684/2003, que copiamos integralmente pela importância do mesmo: “Art. 9.º É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1.º e 2.º da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento. § 1.º A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. § 2.º Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o

Comentários

agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios.”

Vale observar que a matéria tem tratamento diferente quando se tratar de parcelamento do débito tributário. A suspensão da pretensão punitiva será determinada desde que este parcelamento seja feito antes do recebimento da ação penal, conforme regras, neste particular, do art. 83 e parágrafos da Lei 9.430/1996 alterada pela Lei 12.382/2011. Vejamos:

“Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1.º e 2.º da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. (Redação dada pela Lei 12.350, de 2010)

§ 1.º Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento. (Incluído pela Lei 12.382, de 2011)

§ 2.º É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de

parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. (Incluído pela Lei 12.382, de 2011)

§ 3.º A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. (Incluído pela Lei 12.382, de 2011)

§ 4.º Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no caput quando a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. (Incluído pela Lei 12.382, de 2011)

§ 5.º O disposto nos §§ 1.º a 4.º não se aplica nas hipóteses de vedação legal de parcelamento. (Incluído pela Lei 12.382, de 2011)

§ 6.º As disposições contidas no caput do art. 34 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicam-se aos processos administrativos e aos inquéritos e processos em curso, desde que não recebida a denúncia pelo juiz. (Renumerado do Parágrafo único pela Lei 12.382, de 2011)”

Peça 15

Peça

Recurso Extraordinário

Endereçamento

Interposição ao Tribunal de Justiça e Razões ao Supremo Tribunal Federal

Fundamento Legal	Art. 102, III, "a", da CF c/c art. 1.029 do NCPC.
Preliminares	–
Fundamentos	Prequestionamento por meio dos Embargos de Declaração; Violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5.º, XLVI, da CF) e da dignidade da pessoa humana; Desrespeito à Súmula Vinculante 26; Desrespeito à Súmula 471 do STJ.
Pedidos	Reconhecimento e Possibilidade da Progressão de Regime.
Autenticação	Padrão
	Primeiramente, devemos arguir o prequestionamento informando acerca dos embargos de declaração apresentados. Pquestionar significa informar que a matéria já fora objeto de análise nas instâncias inferiores. A Lei 8.072/1990, famosa Lei dos Crimes Hediondos, ao integrar o sistema legal e penal brasileiro, surgiu como uma das demonstrações da política criminal emergencial, ou seja, uma inocente tentativa de trazer maiores rigores aos crimes mais graves de nossa legislação. Uma dessas medidas foi justamente o cumprimento de pena em regime integralmente fechado. Todavia, esta postura contraria diretamente garantias constitucionais, principalmente o princípio da individualização da pena, que deve ser o primeiro fundamento desta questão

Comentários

inédita ora apresentada. Conforme o art. 5.º, XLVI, da CF: “XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:”. O STF, entendendo desta forma, decidiu pela inconstitucionalidade do cumprimento integral no regime fechado e assim surgiram duas súmulas que devem ser colocadas neste recurso extraordinário:

Súmula Vinculante 26: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Súmula 471 do STJ: “Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional”.

Peça 16

Peça	Agravo em Execução
Endereçamento	Juiz da Vara de Execuções Penais (VEP) ou Criminais (VEC) e razões para o Tribunal de Justiça
Fundamento Legal	Art. 66, III, “e” c/c art. 197 da Lei 7.210/1984
Preliminares	—

Fundamentos	Art. 83, II, do CP c/c art. 131 da Lei 7.210/1984
Pedidos	Concessão de Livramento Condicional
Autenticação	Padrão
Comentários	O principal cuidado nesta peça é realizar o Recurso em Sentido Estrito (art. 581, XII, do CPP) em vez do Agravo em Execução (art. 197 da LEP). Frisamos que algumas decisões, atualmente, pós-ano de 1984, são passíveis de Agravo em Execução. Esta é uma delas. Outro detalhe é a possibilidade do juízo de retratação nos moldes do art. 589 do CPP, já que este recurso segue os moldes do RESE. No mérito deve-se pleitear o livramento condicional com argumentos no CP e na própria Lei de Execuções Penais sem maiores problemas, enfatizando que a suposta (celular) falta grave no início de cumprimento da pena não pode ensejar o impedimento do benefício. Vejamos importante art. 83 do CP: Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V – cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Peça 17

Peça	Revisão Criminal
Endereçamento	Tribunal de Justiça
Fundamento Legal	Art. 621, I ou III, do CPP
Preliminares	–
Fundamentos	Inobservância de benefícios da execução da pena; Cumprimento de tempo de pena por um ano a mais.
Pedidos	Reconhecimento do Erro, conforme o art. 626 do CPP;

	Justa Indenização, conforme o art. 630 do CPP.
Autenticação	Padrão
Comentários	Peça única sem maiores dificuldades com baixíssima incidência em certames práticos. Basicamente esta revisão serve para reconhecer eventuais erros que ocorreram durante a execução da pena e o pedido de justa indenização. Competente é o Tribunal de Justiça, visto que o erro transitou em julgado em 1. ^a instância, conforme o art. 624, II, do CPP.

Peça 18	
Peça	Habeas Corpus Preventivo
Endereçamento	Supremo Tribunal Federal
Fundamento Legal	Art. 5.º, LXVIII, da CF c/c art. 660, § 4.º, do CPP
Preliminares	–
Fundamentos	Pedido de Liminar Demonstrar a ameaça à liberdade, posicionar o impetrante na posição de colaborador testemunhal.
Pedidos	Reconhecimento da iminência do ataque à liberdade é a expedição do salvo-conduto.
Autenticação	Padrão
	Peça que não é exclusiva de advogado, cuja elaboração não exige maiores formalidades. O caso apresentado é bem comum aos dias atuais com as respectivas comissões

Comentários	investigando escândalos que envolvem dinheiro público. Deve-se impetrar o presente remédio constitucional perante o Supremo Tribunal Federal pelo envolvimento de detentores de foro privilegiado na mais alta corte. Fora isso, a peça segue padrão determinado em modelo fornecido em capítulo próprio.
--------------------	---

Peça 19	
Peça	Defesa Preliminar
Endereçamento	Juiz de Direito
Fundamento Legal	Art. 514 do CPP
Preliminares	—
Fundamentos	Abordar a Justa Causa como Condição da Ação; Demonstrar a falta de Justa Causa para a Ação Penal com base no art. 395, III, do CPP.
Pedidos	Pelo não recebimento da ação penal com base no art. 395, III, do CPP.
Autenticação	25 de janeiro de 2013
	Notemos que a peça de defesa preliminar se faz a ideal, tendo em vista apenas uma informação no caso apresentado, ou seja, apenas a denúncia oferecida. É importante frisar que se no caso apresentado já estivéssemos de posse da informação de que a denúncia já fora recebida, a peça cabível seria a resposta à acusação.

Comentários	A defesa preliminar tem basicamente uma função, que seria impedir o recebimento da ação penal. Dissertando sobre a justa causa como aquele conjunto protetivo e informativo que traduz os elementos mínimos de indícios de autoria e materialidade, devemos frisar a ausência do mesmo no caso em tela. Basear a denúncia em informações colhidas em outras investigações é, no mínimo, temerário à persecução penal.
--------------------	---

Peça 20	
Peça	Defesa Preliminar
Endereçamento	Juiz de Direito da Vara Criminal
Fundamento Legal	Art. 55 c/c art. 55, § 1.º, da Lei 11.343/2006
Preliminares	–
Fundamentos	Demonstração de requisitos do uso de Drogas, conforme o art. 28, § 2.º, da Lei 11.343/2006; Desclassificação para o uso; Enfatizar circunstâncias pessoais; Remessa ao Juizado Especial Criminal, segundo o art. 48, § 1.º, da Lei 11.343/2006.
Pedidos	Desclassificação para o uso; Remessa ao Juizado Especial Criminal; Pena de Advertência, conforme o art. 28, I, da Lei 11.343/2006.

Autenticação	Padrão
	A defesa preliminar na lei de drogas tem dupla função. A de impedir o recebimento da ação penal e de argumentar todas as teses de defesa. Este cuidado se faz necessário pela ausência de resposta do acusado no procedimento da lei de drogas após o recebimento da ação penal. Por aqui a defesa preliminar também é anterior ao recebimento, ou seja, logo após o oferecimento da ação penal. Partindo-se desta identificação, devemos nos atentar para os novos padrões diferenciadores do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) com o crime de uso de drogas do mesmo diploma legislativo em seu art. 28. O requisito famoso da quantidade de drogas apreendida agora está acompanhado por mais outros sete requisitos que devem ser trabalhados nesta peça. Grifo nosso: “Art. 28. (...) § 2.º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” A questão nos informa inclusive que a personagem é bem-sucedida, permitindo-se assim uma abordagem econômica de que não precisaria vender droga para sobreviver.
Comentários	

Concluindo, o crime de uso é de menor potencial ofensivo, gerando assim um deslocamento natural ao Juizado Especial Criminal, conforme o art. 48, § 1.º, da Lei 11.343/2006.

Não foi exigido o prazo nessa peça, mas lembramos que ele é de 10 dias, diferente do funcionário público que é de 15 dias.

12.2 GABARITO DAS DISCURSIVAS OFICIAIS

12.2.1 Exame OAB Unificado – 2010.2 – FGV

QUESTÃO 1

Comentários

O examinador pretende que o candidato perceba a ilicitude da gravação realizada pelo delegado, sem o consentimento do réu, sem a presença da defesa técnica, consistindo em ato informal e sem valor probatório, uma vez que o depoimento em repartição policial é formal e regido pelas mesmas regras dos depoimentos em juízo. O delegado sequer havia informado ao preso acerca do direito de permanecer calado, previsto no art. 5.º, LXIII, da Constituição (o artigo tem que ser citado na resposta). O candidato deveria, ainda, constatar a contaminação das demais provas apresentadas na questão, pois todas derivaram do depoimento ilícito anterior, argumentando no sentido da aplicação da teoria das provas ilícitas por derivação, prevista no art. 157, § 1.º, do CPP. Quanto à infiltração dos agentes, prevista pela Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) no art. 53, há necessidade de autorização judicial, o que não ocorreu no caso narrado, devendo ser considerada ilícita e contaminando qualquer outro tipo de prova obtida a partir dela.

Por fim, no aspecto material, o candidato devia reconhecer o *bis in idem* na cumulação entre os crimes de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, e de quadrilha ou bando, previsto no art. 288 do CP. Ambos punem a associação de pessoas para a prática de crimes, devendo, no presente caso, prevalecer o da lei especial, por força do princípio da especialidade, afastando a regra geral do Código Penal.

GABARITO

Gravação informal obtida pelo delegado de polícia constitui prova ilícita, já que o preso tem o direito de ser informado dos seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado (art. 5.º, LXIII, da Constituição). O depoimento policial é um ato formal e, segundo o art. 6.º, V, deve observar as

regras para a oitiva do acusado na fase judicial, previstas no Capítulo III, Título VII, do Código de Processo Penal. Como as demais provas foram obtidas a partir do depoimento que constitui prova ilícita, devem igualmente ser consideradas ilícitas (art. 157, § 1.º, do Código de Processo Penal). (0,3)

A infiltração de agente policial, conforme determina o artigo 53, I, da Lei 11.343/2006, só pode ser determinada mediante autorização judicial e oitiva do Ministério Público. (0,3)

Não se admite a acumulação das acusações de quadrilha e associação para o tráfico, já que as duas redações típicas compreendem as mesmas ações objetivas (estabilidade na comunhão de ações e desígnios para a prática de crimes). (0,4)

**Com o advento da Lei 12.850/2013, o crime de quadrilha ou bando passou a denominar-se “associação criminosa”.*

QUESTÃO 2

Comentários

A questão envolve a aplicação do princípio da especialidade entre o Código Penal e a Lei 8.137/1990, que prevê crimes contra a ordem tributária. O item I avalia o crime praticado por funcionário público que exige vantagem indevida com a finalidade de deixar de cobrar um tributo. Pelas regras gerais do Código Penal, quando um funcionário público exige vantagem indevida em razão da função, o crime configurado é de concussão, previsto no art. 316, *caput*, do CP. Entretanto, a questão trata de funcionário da ordem tributária atraindo a aplicação da Lei 8.137/1990, lei específica, que no art. 3.º, II, prevê as condutas de solicitar, receber, exigir e aceitar promessa de vantagem indevida, por funcionário da ordem tributária, com a finalidade específica de deixar de cobrar ou lançar tributos. Portanto, o primeiro item da questão deve ser respondido com aplicação desse dispositivo.

No item II, o funcionário público exige vantagem indevida advinda de cobrança de tributo que sabia não ser devido pelo comerciante. Nesta situação configura-se a modalidade qualificada do crime de excesso de exação, prevista no art. 316, § 2.º, do CP. O excesso de exação ocorre, conforme o art. 316, § 1.º, quando o funcionário que atua junto à ordem tributária cobra tributos que sabe ou devia saber indevidos e, também, quando emprega na cobrança de tributos devidos meios vexatórios ou gravosos, não autorizados por lei, devendo os valores ser recolhidos aos cofres públicos. Nos casos em que os valores cobrados forem apropriados pelo funcionário incide a qualificadora, como na hipótese da questão, prevista no art. 316, § 2.º, do CP.

GABARITO

Art. 3.º da Lei 8.137/1990 (0,5) e excesso de exação qualificada – art. 316, § 2.º, do CP (0,5). A exigência de vantagem indevida por funcionário público em razão de sua função caracteriza, em princípio, o delito de concussão. A Lei 8.137/1990, a lei dos crimes contra a ordem tributária, criou, no que interessa à questão, dois tipos novos: inseriu no art. 316 do Código Penal dois parágrafos, criando o excesso de exação – nas hipóteses em que a vantagem indevida for ela mesma um

tributo ou contribuição social indevida – , e sua forma qualificada, que se dá quando a vantagem é apropriada pelo agente. O outro novel tipo penal está no art. 3.º da Lei 8.137/1990, que tipifica uma forma específica de concussão: a exigência de vantagem indevida para deixar de cobrar tributo devido.

QUESTÃO 3

Comentários

O item I da questão tem resposta derivada diretamente do Código de Processo Penal, pois o examinador indaga acerca do recurso cabível da decisão de pronúncia. Nas decisões de primeira instância, ressalvados os embargos de declaração, cabem em processo penal basicamente dois recursos, o recurso em sentido estrito e a apelação. O cabimento do recurso em sentido estrito é expresso no art. 581 do CPP, assim, o candidato deve analisar se a decisão a ser atacada está prevista neste dispositivo, estando, o recurso será este. Já a apelação é residual, cabendo para quaisquer outras decisões definitivas não atacáveis pelo recurso em sentido estrito. A decisão de pronúncia aparece no art. 581, IV, como hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito, devendo ser indicada como resposta do primeiro item da questão. Determinado o recurso, o item II é respondido com facilidade. O prazo previsto no art. 586 do CPP para o recurso em sentido estrito é de cinco dias.

O item III analisa o mérito da questão que envolvia a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também denominada teoria da *conditio sine qua non*, adotada pelo art. 13, *caput*, do CP. Como a causa da morte, segundo a perícia realizada, foi a ingestão de veneno letal, antes da conduta dolosa do réu, configurando uma causa preexistente absolutamente independente, este deve responder por tentativa de homicídio e não pelo resultado, pois não pode ser estabelecida a relação de causalidade entre sua conduta e o resultado morte ocorrido. Portanto, o candidato deveria argumentar no sentido da reforma da decisão de pronúncia de homicídio consumado para homicídio tentado, por força da causa preexistente absolutamente independente, com fundamento no art. 13, *caput*, do CP.

GABARITO

- (i) *Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal. (0,2)*
- (ii) *Cinco dias, nos termos do art. 586 do Código de Processo Penal. (0,2)*
- (iii) *Deveria ser requerida a desclassificação de crime consumado para tentado, já que a ação de Pedro não deu origem à morte de José. Trata-se de hipótese de concausa absolutamente independente preexistente. (0,4) Art. 13 do Código Penal. (0,2)*

QUESTÃO 4

Comentários

A questão envolve uma das hipóteses de erros acidentais, mais especificamente o denominado

aberratio ictus ou erro na execução, previsto no art. 73 do CP. Tal hipótese ocorre quando o agente, por força de acidente ou erro na utilização dos meios que escolheu para executar o crime, acaba atingindo pessoa diversa da que pretendia atingir com sua conduta. A solução legalmente prevista determina que o agente responda por sua conduta como se tivesse atingido quem pretendia, criando uma espécie de transferência das características do fato da vítima pretendida para a vítima real. O outro tema tratado na questão é a legítima defesa, arts. 23, II, e 25 do CP, que acarreta a exclusão da ilicitude do fato quando praticado para repelir uma agressão injusta atual ou iminente a um direito. Assim, como o agente agia em legítima defesa contra um agressor e por erro na execução acabou atingindo outra pessoa, deve ser reconhecida a exclusão da ilicitude pela legítima defesa, uma vez que deverá responder como se tivesse atingido quem ele pretendia atingir. No gabarito oficial o examinador citou também o art. 20, § 3.º, que era dispensável ao citar o art. 73 do CP.

GABARITO

Trata-se o presente caso de um erro na execução (art. 73 do CP, 1.ª parte), atendendo-se, conforme o citado artigo, ao disposto no § 3.º do art. 20 do Código Penal. Por outro lado, verifica-se que Aurélio, ao efetuar o disparo, agiu em legítima defesa (art. 25 do CP) própria e real. Entretanto, por um erro, acertou pessoa diversa (Cornélio) do agressor (Berilo). Mesmo assim, não fica afastada a legítima defesa, posto que, de acordo com o art. 20, § 3.º, do CP, “não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime”. Levando-se, ainda, em consideração o fato de que Aurélio agiu em defesa de uma agressão injusta e atual, utilizando-se, ainda, dos meios necessários e que dispunha para se defender.

QUESTÃO 5

Comentários

O item I exige que o candidato conheça a Lei de Execução Penal, que em seu art. 197 previu o recurso de Agravo em Execução para todas as decisões do juiz da execução penal. Com essa previsão, alguns incisos do art. 581 do CPP foram derogados. Decisões que antes eram atacadas pelo recurso em sentido estrito, hoje o são por agravo em execução. O critério de diferenciação é verificar qual o juízo da decisão. Sempre que for o juízo da execução penal incide o agravo em execução pelo princípio da especialidade.

A argumentação a ser apresentada envolve a aplicação das leis penais no aspecto temporal. Como o crime foi praticado em 2006, antes da entrada em vigor da Lei 11.464/2007, a progressão de regime deve ser regida pela Lei de Execução Penal, aplicando-se a fração de 1/6 de cumprimento da pena. As frações específicas de 2/5, quando primário, e 3/5, quando reincidente, para progressão de regime nos crimes hediondos ou equiparados, incluídas na Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990), art. 2.º, § 2.º, pela Lei 11.464/2007, não podem retroagir por serem mais severas que a fração anterior. Além dos dispositivos legais, o candidato também deve fundamentar sua resposta na Súmula Vinculante 26 do STF e na Súmula 471 do STJ.

GABARITO

- a) *Recurso Cabível: Agravo em Execução, nos termos do previsto no art. 197 da Lei 7.210/1984.*
- b) *Fundamentação: Com o advento da Lei 11.464/2007, restou legalmente instituída a possibilidade de progressão de regime nos crimes hediondos e equiparados, respeitando, assim, o princípio constitucional da individualização da pena. A mencionada lei fixou prazo diferenciado para tais delitos, afastando o critério de cumprimento de 1/6 da pena, determinando o cumprimento de 2/5, para primários, e 3/5, para reincidentes. No entanto, no caso em comento, o delito fora cometido antes da entrada em vigor da Lei 11.464/2007, sendo esta prejudicial ao réu no que tange ao prazo para progressão, razão pela qual não poderá ser aplicada retroativamente. Logo, quando do pedido perante o juízo da execução, Lucas já havia cumprido o requisito objetivo exigido para a progressão de regime, ou seja, 1/6, devendo ser concedido, nos termos do art. 112 da Lei 7.210/1984. O requerimento deve ser de progressão de regime. Pontuação para argumentação: 0,5. Pontuação para indicação dos dispositivos legais: 0,2.*

12.2.2 Exame OAB Unificado – 2010.3 – FGV

QUESTÃO 1

Comentários

A letra “a” da questão deve ser respondida considerando alguns fatores, primeiramente a ausência de previsão legal de recursos específicos para a decisão que não absolve sumariamente o réu, segundo, a ausência de especificação na questão do conteúdo de tal decisão. A questão não deixava claro se a defesa havia requerido a extinção da punibilidade do crime de apropriação indébita das contribuições previdenciárias pelo pagamento dos tributos, sendo o pedido negado pelo juiz, quando então caberia o recurso em sentido estrito para atacar decisão que nega a extinção da punibilidade. Portanto, a situação apresentada deve ser atacada por meio da ação autônoma de impugnação de *habeas corpus*, com base no art. 647 do CPP, com o fito de trancar a ação penal.

A decisão atacada pelo *habeas corpus* é do juiz da Vara Criminal Federal, portanto, o endereçamento correto é o Tribunal Regional Federal.

No mérito, a questão envolve a extinção da punibilidade dos crimes contra a ordem tributária, previstos nos arts. 168-A, 337-A e 334, todos do CP, bem como nos arts. 1.º e 2.º da Lei 8.137/1990. O pagamento dos tributos sonegados ou apropriados nestes crimes enseja a extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 9.º, § 2.º, da Lei 10.684/2003. A questão narra que foram realizados os pagamentos referentes ao crime do art. 168-A do CP, portanto, deve ser requerida a extinção da punibilidade. Com o encerramento da ação penal em referência ao crime do art. 168-A, pelas razões já expostas, a Justiça Federal passa a ser incompetente para julgar a sonegação do ICMS. Por tratar-se de tributo local, a competência passa a ser da Justiça Estadual, devendo ser arguida a consequente incompetência absoluta da Justiça Federal no prosseguimento do feito.

GABARITO

- a) *Habeas corpus, uma vez que não há previsão de recurso contra a decisão que não absolvera sumariamente o acusado, sendo cabível a ação mandamental, conforme estabelecem os arts. 647 e seguintes do CPP. No caso, não seria admissível o recurso em sentido estrito, uma vez que o enunciado não traz qualquer informação acerca da fundamentação utilizada pelo magistrado para deixar de absolver sumariamente o réu, não podendo o candidato deduzir que teria sido realizado e indeferido pedido expresso de reconhecimento de extinção da punibilidade.*
- b) *Ao Tribunal Regional Federal.*
- c) *Extinção da punibilidade pelo pagamento do débito quanto ao delito previsto no art. 168-A do CP e após, restando apenas acusação pertinente à sonegação de tributo de natureza estadual, incompetência absoluta – em razão da matéria – do juízo federal para processar e julgar a matéria. Quanto à Súmula Vinculante 24, o enunciado não traz qualquer informação no sentido de que a via administrativa ainda não teria se esgotado, não podendo o candidato deduzir tal fato.*

QUESTÃO 2

Comentários

O examinador narra a história de um furto em concurso de pessoas praticado por um filho, acompanhado de uma estranha, contra seu próprio pai. A letra “a” questiona se o filho pode ser punido por seu ato. Evidentemente, trata-se da incidência da escusa absolutória prevista no art. 181, II, do CP, que beneficia os autores de crimes patrimoniais quando praticados contra ascendentes ou descendentes. Nesta hipótese há o crime – fato típico, antijurídico e culpável –, mas o legislador previu uma escusa absolutória, afastando as consequências penais do ato. Na letra “b”, o questionamento envolve a extensão do citado benefício ao terceiro (estranho à relação de ascendência) que participa do crime. Por tratar-se de circunstância de caráter pessoal, a escusa absolutória não se comunica aos demais agentes, conforme dispõe o art. 30 do CP e expressamente o art. 183 do CP. A agente deve ser punida por furto qualificado pelo concurso de pessoas, pois houve concurso de pessoas, embora para um dos agentes incida a escusa absolutória. O gabarito oficial indicava como resposta o furto qualificado pelo repouso noturno, que não parece a resposta mais adequada, por duas razões: primeiro, por não ser uma qualificadora, e sim uma circunstância de aumento de pena. Segundo, porque a incidência da qualificadora do concurso de pessoas afasta a incidência do aumento noturno.

A letra “c” discute a competência para julgar e punir o crime de furto. Evidentemente, pela regra do art. 69, I, do CPP, a competência em razão do local do crime é do lugar onde o crime se consumou, portanto, na questão, Belo Horizonte.

GABARITO

- a) *Não, uma vez que incide sobre o caso a escusa absolutória prevista no art. 181, II, do CP.*
- b) *Sim, uma vez que a circunstância relativa a Caio é de caráter pessoal, não se comunicando a ele (art. 30 do CP). Assim, poderá ser punida pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno.*

- c) *Belo Horizonte, local em que o delito se consumou, conforme os arts. 69, I, do CPP e 6.º do CP.*

QUESTÃO 3

Comentários

A questão narra a prática de um crime de latrocínio praticado contra particular logo após o saque de valores em agência da Caixa Econômica Federal – CEF. O primeiro ponto a ser analisado é a competência para o processo e julgamento do crime de latrocínio. A questão indica que a denúncia foi oferecida junto ao Tribunal do Júri na Justiça Federal, porém, o crime de latrocínio não é crime doloso contra a vida, a competência para o processo e julgamento é da Vara Criminal comum e não do Tribunal do júri. Outrossim, a competência para o caso narrado não é da Justiça Federal, e sim da Justiça Estadual, não havendo incidência do art. 109, IV, da Constituição, devendo a competência permanecer na justiça comum do Estado. A competência para o processo e julgamento do *habeas corpus* é do TRF respectivo, pois os atos de coação foram praticados pelo Juiz Federal que recebeu a denúncia e decretou a prisão. Quanto à decretação da prisão preventiva, a questão deixa claro tratar-se de ato ilegal, fundamento em conjecturas abstratas e não em elementos de necessidade da decretação cautelar. A prisão cautelar exige requisitos claros e concretos, e não elementos vagos e abstratos.

GABARITO

- a) *Não, pois a competência para processamento e julgamento é de uma vara comum da justiça estadual, por se tratar de crime patrimonial e que não ofende bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas.*
- b) *Não, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que considerações genéricas e presunções de que em liberdade as testemunhas possam sentir-se amedrontadas não são argumentos válidos para a decretação da prisão antes do trânsito em julgado de decisão condenatória, pois tal providência possui natureza estritamente cautelar, de modo que somente poderá ser determinada quando calcada em elementos concretos que demonstrem a existência de risco efetivo à eficácia da prestação jurisdicional.*
- c) *Tribunal Regional Federal, pois a autoridade coatora é juiz de direito federal.*

QUESTÃO 4

Comentários

Letra “a”: A questão envolve a clássica diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente, muito debatida em crimes de trânsito, quando resulta em morte das vítimas. O dolo eventual, regido pela teoria do consentimento, ocorre quando o agente PREVÊ o resultado como consequência possível da conduta que quer realizar e ACEITA sua ocorrência. A culpa consciente, por outro lado, ocorre quando o agente PREVÊ o resultado como consequência possível da conduta, mas ACREDITA sinceramente ser capaz de evitá-lo, o agente nega o resultado, NÃO ACEITA sua ocorrência. Na

questão em exame, fica claro que o agente não aceitou as mortes, ao contrário, acreditou em sua capacidade de evitá-lo.

Letra “b”: Houve culpa consciente e não dolo eventual, o que torna a vara criminal do Tribunal do Júri incompetente para o processo e julgamento, devendo o crime ser desclassificado para homicídio culposo e encaminhado ao juízo competente.

Letra “c”: A decisão de pronúncia está prevista no rol taxativo das decisões atacáveis por recurso em sentido estrito, conforme o art. 581, IV, do CPP. A petição de interposição deve ser endereçada ao Juiz de Direito da Vara Criminal do Tribunal do Júri.

GABARITO

- a) *Incompetência do juízo, uma vez que Caio praticou homicídio culposo, pois agiu com culpa consciente, na medida em que, embora tenha previsto o resultado, acreditou que o evento não fosse ocorrer em razão de sua perícia.*
- b) *Desclassificação da imputação para homicídio culposo e declínio de competência, conforme previsão do art. 419 do CPP.*
- c) *Recurso em sentido estrito, conforme previsão do art. 581, IV, do CPP. A peça de interposição deveria ser dirigida ao juiz de direito da vara criminal vinculada ao tribunal do júri, prolator da decisão atacada.*

QUESTÃO 5

Comentários

Letra “a”: A Lei de Execução Penal, Lei 7.210/1984, no art. 197, prevê que as decisões do juiz da execução serão impugnadas por recurso de agravo em execução. O meio mais adequado tecnicamente para impugnar a decisão narrada na questão é esse recurso. A banca também aceitou como resposta a ação autônoma de impugnação de *Habeas corpus*, sempre cabível em matéria penal, ainda mais em casos diretamente relacionados à privação da liberdade.

Letra “b”: A progressão de regime em geral está regulada pelo art. 112 da LEP, sendo que os requisitos exigidos são o cumprimento de 1/6 da pena e o bom comportamento carcerário. Embora a lei não exija, a jurisprudência tem autorizado a realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime, conforme a Súmula 439 do STJ. Nos crimes hediondos e equiparados há requisito específico, previsto no art. 2.º, § 2.º, da Lei 8.072/1990, que exige o cumprimento de 2/5 da pena, se primário, ou 3/5, se reincidente. Entretanto, essas frações específicas foram incluídas na Lei de Crimes Hediondos pela Lei 11.464/2007. Anteriormente a lei vedava a progressão de regime, mas fora considerada inconstitucional pelo STF, o que tornou aplicáveis os requisitos previstos na LEP. Assim, o STF, por meio da Súmula Vinculante 26, concluiu que a progressão de regime por crimes hediondos ou equiparados praticados até a entrada em vigor da Lei 11.464/2007 deve ser verificada com os requisitos do art. 112 da LEP. A partir da lei nova, aplicam-se as novas frações introduzidas na Lei de Crimes Hediondos. O mesmo entendimento foi consolidado pelo STJ na Súmula 471. O crime da questão foi praticado em 10 de

novembro de 2006, portanto, aplica-se o disposto no art. 112 da LEP, fazendo jus à progressão de regime com 1/6 da pena.

GABARITO

- a) Habeas Corpus e agravo em execução penal.
- b) *Tendo em vista que a norma que alterou as regras relativas à progressão de regime possui natureza penal e é mais gravosa ao réu, não pode retroagir de modo a abarcar fatos que lhe são anteriores. No caso, o delito foi praticado antes da edição da lei, devendo, em consequência, ser aplicada a fração de 1/6 para a progressão de regime.*

12.2.3 IV Exame OAB Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Comentários

Letra “a”: O crime praticado por Jorge, conforme os dados fornecidos pela questão, foi o crime de apropriação indébita com aumento de pena, previsto no art. 168, § 1.º, do CP. A questão afirma que ele se apropriou dos valores que estavam na sua posse, em razão da profissão exercida por ele, para fins de realização de pagamentos. Assim, está bem clara a inversão da posse necessária à configuração do crime de apropriação indébita, bem como a relação da posse ao exercício de profissão, configurando-se a causa de aumento de pena.

Letra “b”: A interceptação de correspondências sem autorização judicial ou fora dos casos admitidos em lei constitui ato ilícito previsto como crime, quando realizado por particular, no art. 40 da Lei 6.538/1978, o que torna a carta violada uma prova ilícita, inadmissível em juízo. Portanto, a denúncia criminal lastreada apenas em uma carta violada, prova ilícita, não pode ser recebida pelo juiz por falta de justa causa.

GABARITO

- a) *Sim. Apropriação indébita qualificada (ou majorada) em razão do ofício, prevista no art. 168, § 1.º, III, do CP.*
- b) *Falta de justa causa para a instauração de ação penal, já que a denúncia se encontra lastreada exclusivamente em uma prova ilícita, porquanto decorrente de violação a uma norma de direito material (art. 151 do CP).*

QUESTÃO 2

Comentários

Letra “a”: A questão envolve a possibilidade de nomeação de assistente de acusação para fins recursais, quando o Ministério Público se mantém inerte diante de nulidades praticadas pela defesa.

A possibilidade de a esposa da vítima constituir um advogado com assistente de acusação está prevista no art. 598 do CPP. O advogado deverá interpor recurso de apelação com fundamento no art. 593, III, alíneas “a” e “d”, diante da violação pela defesa da regra contida no art. 478, I, do CPP, que impede a leitura da decisão do Tribunal durante o julgamento no Júri.

Letra “b”: A questão envolve a possibilidade de o Tribunal anular a decisão do Tribunal do Júri, reconhecendo nulidade não alegada no recurso do Ministério Público, submetendo o réu a novo julgamento. Tal possibilidade acarretaria violações aos princípios da proibição da *reformatio in pejus* e também ao da correlação entre o pedido realizado pela acusação e o ato decisório do Tribunal. O candidato deveria fundamentar sua resposta na Súmula 160 do STF.

GABARITO

- a) *Sim. A esposa da vítima deveria constituir advogado para que ele se habilitasse como assistente de acusação e interpusse recurso de apelação, com fundamento nos arts. 598 e 593, III, “a” e “d”. Afinal, a defesa violou a proibição expressa contida no art. 478, I, do CPP, ao ler trecho de decisão que julgou admissível a acusação e manteve a pronúncia do réu. Além disso, tendo o réu confessado o homicídio, a absolvição se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos.*
- b) *Não, pois a Súmula 160 do STF proíbe que o Tribunal conheça de nulidade não arguida no recurso de acusação. Assim, a violação ao art. 478, I, do CPP, por parte da defesa não poderia ser analisada se a acusação não lhe tivesse feito menção no recurso interposto.*

QUESTÃO 3

Comentários

A competência para o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, em regra na Justiça Estadual, somente havendo deslocamento da competência para a Justiça federal nas hipóteses do art. 109, IV, da CRFB/1988. No caso em análise não há qualquer dessas situações para deslocar a competência. Portanto, a primeira nulidade que poderia ser citada é a incompetência absoluta da Justiça Federal. Além desse aspecto, o candidato também deveria comentar que a competência de foro por prerrogativa de função cessa com a perda do mandato, quando voltam a incidir as regras gerais de competência.

Os mesmos fundamentos anteriores também fundamentam a nulidade relativa à inobservância ao princípio do juiz natural, com violação dos arts. 413 e 414 do CPP e 5.º, LIII, da CRFB.

A segunda nulidade possível está na violação do princípio da ampla defesa pela nomeação de advogado único, realizada pelo juízo deprecado. A questão informa que as defesas dos réus eram conflitantes, portanto, nomear um único defensor para ambos viola a ampla defesa. Nulidade relativa aos arts. 564, IV, do CP e 5.º, LV, da CRFB/1988.

GABARITO OFICIAL

Primeiramente, há que ser arguida nulidade por incompetência absoluta (art. 564, I, do CPP), pois

no caso não há incidência de nenhuma das hipóteses mencionadas no art. 109 da CRFB que justifiquem a atração do processo à competência da Justiça Federal. Ademais, o fato de os agentes serem ex-deputados federais não enseja deslocamento de competência. Nesse sentido, competente é o Tribunal do Júri da Comarca onde se deram os fatos, pois, cessado o foro por prerrogativa de função, voltam a incidir as regras normais de competência para o julgamento da causa, de modo que, dada a natureza da infração (crime doloso contra a vida), a competência é afeta ao Tribunal do Júri de Arsenal.

Além disso, também deverá ser arguida nulidade com base no art. 564, IV, do CPP. A nomeação de somente um advogado para ambos os réus, feita pelo juízo deprecado, não respeita o princípio da ampla defesa (art. 5.º, LV, da CRFB), pois, como as defesas eram conflitantes, a nomeação de um só advogado prejudica os réus. Por fim, com base nos arts. 413 e 414 do CPP, bem como no art. 5.º, LIII, da CRFB/1988, poderá ser arguida nulidade pela falta de apreciação da causa pelo juiz natural do feito.

QUESTÃO 4

Comentários

A questão envolve situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Não fica clara na questão a ocorrência de violência física, o que dispensa a apreciação do art. 129, § 9.º, do CP. O candidato, na letra “a” da questão, deveria demonstrar que as perturbações emocionais praticadas contra a mulher estão previstas no art. 7.º, II, da Lei 11.340/2006, como formas de violência doméstica contra a mulher, o que acarreta a incidência das regras gerais da citada lei. Assim, a renúncia ao direito de representação é possível, desde que realizada em audiência especial na presença do juiz, conforme dispõe o art. 16 da Lei 11.340/2006.

Na questão contida na letra “b”, o candidato deveria afirmar que a pena de prestação pecuniária está proibida, conforme disposto no art. 17 da Lei 11.340/2006. Dentre outras medidas de maior rigor, a Lei Maria da Penha vedou a aplicação de penas exclusivamente pecuniárias aos condenados por atos de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

GABARITO OFICIAL

Trata-se de crime capitulado na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), conforme transcrito a seguir: “Art. 7.º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;”

Além disso, o Código Penal assim dispõe: “Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena – detenção, de três meses a um ano.

§ 9.º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei 11.340, de 2006)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei 11.340, de 2006)

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1.º a 3.º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9.º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço). (Incluído pela Lei 10.886, de 2004)”

Sendo assim, de acordo com a Lei supracitada, a renúncia à representação só é admitida na presença do Juiz, em audiência especialmente designada para esta finalidade, nos termos do art. 16 da Lei 11.340/2006 e, de acordo com o artigo 17 da referida lei, a prestação pecuniária é vedada.

12.2.4 V Exame OAB Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Comentários

Letra “a”: A competência dos Juizados Especiais Criminais é para o julgamento das contravenções penais e dos crimes de menor potencial ofensivo, que tem pena máxima não superior a dois anos. Na verificação da competência, devem ser levadas em conta as causas de aumento de pena, quando aplicadas na pena máxima, devem manter-se no patamar de 2 anos, caso ultrapassem esse limite, a competência passa a ser das varas criminais. No caso concreto apresentado na questão, há uma calúnia (art. 138 – pena de detenção de 6 meses a 2 anos) praticada contra funcionário público em razão da função (art. 141, II), o que acarreta a incidência do aumento de pena de 1/3. A incidência da causa de aumento de pena de 1/3 eleva a pena máxima do crime para 2 anos e 8 meses. Assim, a competência para processar e julgar esse crime é da vara criminal comum, e não do JECRIM.

Letra “b”: As medidas despenalizadoras previstas pela Lei 9.099/1995 aplicam-se, em regra, aos crimes de menor potencial ofensivo. A única medida que não está vinculada a esse tipo de crime é a suspensão condicional do processo (*sursis* processual), que pode ser aplicada a qualquer crime que tenha pena mínima não superior a um ano, mesmo que não seja de menor potencial ofensivo, conforme previsto no art. 89 da Lei 9099/1995. Portanto, de todas as medidas despenalizadoras previstas pela lei, a única aplicável ao agente é o *sursis* processual.

Letra “c”: A questão narra uma situação clara de erro de tipo provocado por terceiro. Antônio não tinha consciência de que a imputação era falsa, por isso a relatou ao juiz. Quando não há consciência dos elementos reais que compõem a conduta, caracteriza-se o ERRO DE TIPO, não havendo dolo de caluniar o defensor público. Portanto, o candidato deveria responder que não houve crime. Houve erro de tipo, conforme o art. 20, *caput*, do Código Penal, excludente de tipicidade, não havia dolo. Como o crime não tem modalidade culposa, mesmo em caso de erro evitável ou inescusável o fato será atípico.

GABARITO

- a) *Não, pois, de acordo com o art. 141, II, do CP, quando a ofensa for praticada contra funcionário público em razão de suas funções, a pena será aumentada de um terço, o que faz com que a sanção máxima abstratamente cominada seja superior a dois anos.*
- b) *Sim, suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/1995.*
- c) *Não. Antônio agiu em erro de tipo vencível/inescusável. Conforme previsão do art. 20 do CP, nes hipótese, o agente somente responderá pelo crime se for admitida a punição a título culposo, o que não é o caso, pois o crime em comento não admite a modalidade culposa. Vale lembrar que não houve dolo na conduta de Antônio.*

QUESTÃO 2

Comentários

Letra “a”: O crime praticado por Adaílton é o estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, *caput*. No gabarito oficial a banca se satisfaz com essa resposta. Entretanto, pensamos que o candidato deveria também indicar a incidência do aumento de pena previsto no art. 226, II, do CP, pois, ainda que a questão não deixasse claro, o agente era pai ou padrasto da vítima, bem como a caracterização de crime continuado, já que a questão afirmava que os fatos ocorriam desde novembro de 2010, o que indica o concurso de crimes. Assim, nossa resposta seria: Praticou crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, com aumento de pena previsto no art. 226, II, em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP.

Letra “b”: O candidato deveria imputar a Esmeralda a condição de “agente garantidora”, permitindo a tipificação do crime comissivo por omissão, na forma do art. 13, § 2.º, “a”, do CP. Ainda que Esmeralda não tenha concorrido com ações para os crimes de Adaílton, não há concurso de pessoas entre eles, ela devia e podia ter impedido tais condutas. Portanto, Esmeralda praticou crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, na forma de crime comissivo por omissão, conforme o art. 13, § 2.º, “a”. A banca se contentou com essa resposta. Da mesma forma que na letra anterior, entendemos que o candidato deveria aplicar o aumento de pena do art. 226, II, e configurar o crime continuado previsto no art. 71, *caput*, ambos do CP.

Letra “c”: A ação penal do estupro de vulnerável, por ter vítima menor de 18 anos, é ação penal pública incondicionada, não sendo necessário qualquer ato da avó da vítima, conforme dispõe o art. 225, parágrafo único, do CP. Outrossim, ainda que o crime fosse de ação penal privada ou, eventualmente, em situações de ação penal privada subsidiária da pública, em caso de inércia do Ministério Público, a avó não seria parte legítima para oferecer a queixa-crime no lugar da neta menor.

GABARITO

- a) *Sim. Estupro de vulnerável, conduta descrita no art. 217-A do CP.*
- b) *Sim. Esmeralda também praticou estupro de vulnerável (art. 217-A do CP c/c art. 13, § 2.º, “a”, do CP), uma vez que tinha a obrigação legal de impedir o resultado, sendo garantidora da menor.*
- c) *Não, pois se trata de ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 225, parágrafo único,*

do CP.

QUESTÃO 3

Comentários

Letra “a”: A questão envolve prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, aquela que ocorre entre a publicação da sentença e o trânsito em julgado da condenação. A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, devendo a prescrição ser calculada com a pena aplicada na condenação, pois essa passou a ser a pena máxima aplicável no caso concreto (o recurso exclusivo da defesa impede que o tribunal aumente a pena da condenação, proibição da *reformatio in pejus*), conforme dispõe o art. 110, § 1.º, do CP. A pena de um ano e dez dias-multa prescreve em quatro anos, conforme dispõe o art. 109, V, do CP, portanto, a pretensão punitiva prescreveu em 17.10.2010. Assim, na condição de advogado, o candidato deveria ingressar com *Habeas corpus* com fundamento no art. 648, VII, do CPP ou, o que nos parece ser mais adequado, ingressar com uma mera petição dirigida ao relator do recurso requerendo o reconhecimento da prescrição e consequente extinção da punibilidade.

Letra “b”: A questão envolve a prescrição da pretensão executória, aquela que ocorre após o trânsito em julgado global da sentença condenatória. O candidato deveria lembrar que o condenado é reincidente, portanto, a prescrição da pretensão executória sofre aumento de 1/3, conforme disposto no art. 110, *caput*. Assim, considerando-se a pena de um ano e dez dias-multa, que tem o prazo prescricional de quatro anos previsto no inciso V do art. 109 do CP, somado o acréscimo da reincidência, o prazo da prescrição da pretensão executória é de cinco anos e quatro meses. Portanto, o candidato deveria afirmar, demonstrando os fundamentos apresentados, que a situação seria diferente, pois não haveria prescrição da pretensão executória.

GABARITO

- a) *Ingressar com habeas corpus com fulcro no art. 648, VII, do CPP (extinção de punibilidade – art. 107, IV, do CP), ou com mera petição diretamente dirigida ao relator do processo, considerando-se que a prescrição é matéria de ordem pública e pode até ser conhecida de ofício. O argumento a ser utilizado é a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva superveniente/intercorrente/subsequente (causa extintiva de punibilidade), pois, já ciente do máximo de pena in concreto possível, qual seja, 1 ano e 10 dias-multa, o Estado teria até o dia 17.10.2010 para julgar definitivamente o recurso da defesa, o que não ocorreu, nos termos dos arts. 109, V; 110, § 1.º; e 117, I e IV, todos do CP. Vale lembrar que a prescrição da pretensão punitiva superveniente pressupõe o trânsito em julgado para a acusação (tal como ocorreu na espécie) e é contada a partir da publicação da sentença penal condenatória, último marco interruptivo da prescrição relacionado na questão. Vale ressaltar que não basta o candidato mencionar que houve prescrição. Tem que ser específico, dizendo ao menos que se trata de prescrição da pretensão punitiva.*
- b) *Sim, a situação seria diferente, pois neste caso não haveria prescrição da pretensão executória*

nem outra modalidade qualquer. Como Jaime é reincidente, já que o segundo furto foi cometido após o trânsito em julgado definitivo de sentença que lhe condenou pelo primeiro furto (art. 63 do CP), a prescrição da pretensão executória tem seu prazo acrescido de 1/3, de acordo com o art. 110 do CP. Assim, o Estado teria até 23.02.2012 para capturar Jaime, nos termos dos arts. 110, caput, e 112, I, do CP.

QUESTÃO 4

Comentários

Letra “a”: A questão indagava o recurso cabível da decisão que rejeita a queixa. O candidato precisava tipificar corretamente os fatos narrados no enunciado, a fim de determinar quais os crimes praticados por Maria, e, a partir dessa definição, descobrir o procedimento e o recurso cabível da decisão de rejeição da queixa. A tipificação dos fatos foi o ponto mais importante da questão, em que houve a maior incidência de erro. A questão narra evidentemente um crime de dano, previsto no art. 163 do CP, que foi praticado contra um automóvel em péssimo estado de conservação e com tributos atrasados, sendo que aqui o candidato devia afastar a incidência da qualificadora do prejuízo considerável. Outrossim, a questão afirmava que o dano foi motivado por ciúmes, o que não caracteriza, segundo a doutrina majoritária, motivo torpe como qualificadora do dano. O motivo torpe em crimes patrimoniais relaciona-se à obtenção de vantagens econômicas, e não a sentimentos. Assim, o candidato percebia que os crimes praticados foram dano simples (art. 163, *caput*, do CP) e injúria simples (art. 140, *caput*, do CP), cujas penas máximas somadas não ultrapassam o máximo de dois anos, definindo-se a competência do Juizado Especial Criminal. A Lei 9.099/1995 prevê no art. 82 o recurso de apelação para todas as decisões em matéria penal.

Observação: Caso o candidato errasse a tipificação do crime de dano, entendendo pela incidência da qualificadora, seja do considerável prejuízo para a vítima, seja do motivo torpe pelo ciúme, os crimes deixariam de ser de competência do JECRIM, passando a competência para a vara criminal comum, aplicando-se as regras do Código de Processo Penal, que prevê o recurso em sentido estrito contra as decisões de rejeição da denúncia ou da queixa. Assim, erraria toda a questão, conforme se nota nos próximos comentários.

Letra “b”: O prazo é de 10 dias, conforme previsto no art. 82, § 1.º, da Lei 9.099/1995.

Letra “c”: Turma Recursal, conforme o art. 82 da Lei 9.099/1995.

Letra “d”: A tese é de não incidência da extinção da punibilidade pela decadência, pois o prazo decadencial da queixa é de 6 meses e deve ser contado de acordo com a regra contida no art. 10 do CP, por tratar-se de prazo de direito material. Assim, não havia decadência, devendo a queixa ser recebida.

GABARITO

- a) *Como se trata de crime de menor potencial ofensivo, o recurso cabível é Apelação, de acordo com o art. 82 da Lei 9.099/1995. Vale lembrar que a qualificadora do art. 163, parágrafo único, IV, do CP, relativa ao motivo egoístico do crime de dano, caracteriza-se apenas quando o agente*

pretende obter satisfação econômica ou moral. Assim, a conduta de Maria, motivada por ciúme, não se enquadra na hipótese e configura a modalidade simples do delito de dano (art. 163, caput). Cabe ainda destacar que não houve prejuízo considerável a João, já que o carro danificado estava em mau estado de conservação, o que afasta definitivamente a qualificadora tipificada no art. 163, parágrafo único, IV, do CP. Assim, o concurso material entre o crime patrimonial e a injúria não ultrapassa o patamar máximo de 2 anos, que define os crimes de menor potencial ofensivo e a competência dos Juizados Especiais Criminais, sendo cabível, portanto, apelação (art. 82 da Lei 9.099/1995);

- b) 10 dias, de acordo com o § 1.º do art. 82 da Lei 9.099/1995;*
- c) Turma Recursal, consoante o art. 82 da Lei 9.099/1995;*
- d) O prazo para interposição da queixa-crime é de seis meses a contar da data do fato, conforme previu o art. 38 do CPP. Trata-se de prazo decadencial, isto é, prazo de natureza material, devendo ser contado de acordo com o disposto no art. 10 do CP – inclui-se o primeiro dia e exclui-se o último.*

12.2.5 VI Exame OAB Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Comentários

A questão apresenta situação clássica de discriminante putativa provocada por erro de tipo permissivo, prevista no art. 20, § 1.º, do CP. O agente, acreditando que seria vítima de uma agressão injusta iminente contra sua vida, suposição causada por situação fática, acredita estar em legítima defesa e causa a morte de seu suposto agressor, embora utilizando meios necessários com moderação, apenas um golpe de faca. Entretanto, a agressão não era real, caracterizando a putatividade da legítima defesa. Em razão da legítima defesa putativa inevitável, o agente deve ser isento de pena e ter excluída sua culpabilidade (consequentemente, não há crime).

Na letra “b” o examinador aumenta o número de golpes de faca para 35 (trinta e cinco), evidenciando um excesso na legítima defesa putativa. Da mesma forma que na legítima defesa real, previsão do art. 23, parágrafo único, o excesso é punível. Assim também ocorre na legítima defesa putativa, somente há exclusão do crime na medida em que seria excluída a ilicitude pela legítima defesa real, devendo o agente responder pelo excesso.

GABARITO

- a) Não, pois atuou sob o manto de discriminante putativa, instituto previsto no art. 20, § 1.º, do CP, uma vez que supôs, com base em fundado receio, estar em situação de legítima defesa. Como se limitou a dar uma facada, a sua reação foi moderada, não havendo que se falar em punição por excesso.*
- b) Ainda que tenha procurado se defender de agressão que imaginou estar em vias de ocorrer, Caic agiu em excesso doloso, devendo, portanto, responder por homicídio doloso, na forma do art. 23,*

parágrafo único, do CP.

QUESTÃO 2

Comentários

A questão narra uma situação de legítima defesa real, excludente de antijuridicidade do fato. Na letra “a” questiona acerca do momento processual narrado na questão. Indagando quanto à peça que deve ser redigida naquele momento processual, trata-se de resposta à acusação, no procedimento do Tribunal do Júri, prevista pelo art. 406 do CPP, devendo ser endereçada ao Juiz da Vara Criminal do Tribunal do Júri.

Quanto ao direito material, questionado na letra “b”, o candidato deve apresentar como tese de defesa do réu Luiz a exclusão da ilicitude do fato pela legítima defesa, conforme disposto nos arts. 23, II, e 25 do CP. Outrossim, no que tange a Hugo, indagação da letra “c”, deve ser aplicada a teoria da acessoriedade limitada, que exige para a incriminação do partícipe, no concurso de pessoas, que o fato realizado pelo autor seja típico e antijurídico. Como Luiz agiu em legítima defesa, seu fato é apenas típico, a antijuridicidade é excluída, não podendo atingir o partícipe. O examinador também aceitou a resposta negativa fundamentada na inexistência de liame subjetivo, afastando, portanto, o concurso de pessoas e qualquer responsabilidade penal.

GABARITO

- a) *Resposta à acusação, no prazo de 10 dias (art. 406 do CPP), endereçada ao juiz-presidente do Tribunal do Júri.*

OU

Habeas corpus para extinção da ação penal; ação penal autônoma de impugnação que não possui prazo determinado; endereçado ao Tribunal de Justiça Estadual.

- b) *A tese defensiva aplicada a Luiz é a da legítima defesa real, instituto previsto no art. 25 do CP, cuja natureza é de causa excludente de ilicitude. Não houve excesso, pois a conduta de José (que mirava com o facão na cabeça de Luiz) configurava injusta agressão e claramente atentava contra a vida de Luiz.*

- c) *Hugo não praticou fato típico, pois, de acordo com a Teoria da Acessoriedade Limitada, o partícipe somente poderá ser punido se o agente praticar conduta típica e ilícita, o que não foi o caso, já que Luiz agiu amparado por uma causa excludente de ilicitude, qual seja, legítima defesa (art. 25 do CP).*

OU

Não havia liame subjetivo entre Hugo e Luiz, requisito essencial ao concurso de pessoas, razão pela qual Hugo não poderia ser considerado partícipe.

QUESTÃO 3

Comentários

Por tratar-se de prisão ilegalmente decretada, o meio para impugnação da decisão é o pedido de relaxamento de prisão, junto ao próprio juiz que decretou a prisão temporária, ou a impetração de *habeas corpus*, junto ao Tribunal de Justiça. A prisão temporária somente pode ser decretada na fase do inquérito policial, portanto, a partir do encerramento do inquérito policial a prisão cautelar admitida é a prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP, e não a prisão temporária prevista pela Lei 7.960/1989. Outrossim, a decretação da prisão temporária, ainda que no curso do inquérito policial, depende de requisitos específicos, entre os quais a previsão do crime em rol taxativo na lei específica. O crime de estelionato, objeto da questão, não está previsto no rol autorizador da restrição cautelar da liberdade, portanto, a prisão foi decretada ilegalmente. Deve-se salientar que não houve crime de formação de quadrilha ou bando, previsto no art. 288 do CP, pois este exige o ânimo de habitualidade na prática de crimes. A questão deixa claro que o objetivo dos agentes era a prática apenas deste estelionato, não configurando a associação típica na quadrilha ou bando, que autorizaria a decretação da prisão temporária na fase de inquérito policial.

GABARITO

- a) *Relaxamento de prisão, endereçado ao juiz de direito estadual, ou habeas corpus, endereçado ao Tribunal de Justiça estadual.*
- b) *Ilegalidade da prisão, pois não há formação de quadrilha quando a reunião se dá para a prática de apenas um delito. Não há que se falar em formação de quadrilha, subsistindo apenas o delito único de estelionato. Nesse sentido, não se poderia decretar a prisão temporária, pois tal crime não está previsto no rol taxativo indicado no art. 1.º, III, da Lei 7.960/1989. Ademais, a prisão temporária é medida exclusiva do inquérito policial, não podendo, em hipótese alguma, ser decretada quando já instaurada a ação penal.*

**Com o advento da Lei 12.850/2013, o crime de quadrilha ou bando passou a denominar-se “associação criminosa”.*

QUESTÃO 4

Comentários

O agente Augusto Cesar é autor mediato do crime previsto no art. 6.º da Lei 7.492/1986, crimes contra o sistema financeiro nacional, uma vez que praticados no âmbito de uma empresa que atua no mercado financeiro, afastando pelo princípio da especialidade tipos penais análogos previstos no Código Penal. O crime se configura para o agente, por força da regra contida no art. 20, § 2.º, do CP, o erro de tipo provocado por terceiro, que dispõe acerca da tipificação da conduta para quem provocou o erro de tipo no outro agente. Quanto ao agente Carlos Alberto, que prestou a informação falsa aos acionistas investidores, configura-se erro de tipo essencial, previsto no art. 20, *caput*, do CP. Assim, não houve dolo de realizar a conduta prevista no tipo penal, o que torna o fato atípico.

GABARITO

- a) *Sim, pois Augusto César agiu com dolo preordenado, sendo autor mediato do crime previsto no art. 6.º da Lei 7.492/1986.*

6.º da Lei 7.492/1986.

- b) Poderia argumentar que Carlos Alberto não agiu com dolo, uma vez que recebera informações erradas. Agiu, portanto, em hipótese de erro de tipo essencial invencível/escusável, com base no art. 20, caput, ou art. 20, § 2.º, do CP.

12.2.6 VII Exame OAB Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Comentários

A questão envolve a relação entre o crime contra a fé pública e o crime contra a ordem tributária, quando o primeiro foi praticado como meio exclusivo para a realização do segundo. A aplicação do princípio da consunção enseja que o crime-fim absorve o crime-meio quando este se exaure naquele. Essa regra é muito comum nos crimes contra a fé pública, pois, em regra, são crimes-meio para outros, como ocorre classicamente no estelionato, conforme dispõe o Verbete 17 da Súmula do STJ. Portanto, o candidato devia demonstrar que o crime de sonegação de tributos, previsto no art. 1.º da Lei 8.137/1990, absorve o crime de falsidade ideológica praticado como meio para sua realização, aplicando-se o princípio da consunção.

GABARITO

A questão objetiva avaliar o conhecimento acerca dos princípios relativos ao conflito aparente de normas. Há de se levar em consideração que problemáticas não narradas no enunciado não podem ser objeto de exigência. Assim, nos termos da questão, levando em conta apenas os dados fornecidos, o examinando somente fará jus à pontuação integral se desenvolver argumentação lastreada no princípio da consunção (ou princípio da absorção).

Deverá, igualmente, demonstrar conhecimento de que o crime descrito no art. 299 do CP (falsidade ideológica) teria constituído meio para o cometimento do delito-fim (crime contra a ordem tributária – art. 1.º da Lei 8.137/1990), de tal modo que a vinculação entre a falsidade ideológica e o crime contra a ordem tributária permitiria reconhecer, em referido contexto, a preponderância desse último. Consequentemente, Ricardo somente deveria responder pelo delito previsto no art. 1.º da Lei 8.137/1990.

Acerca desse ponto e com o intuito de privilegiar o desenvolvimento do raciocínio, não será cobrado o inciso preciso do mencionado artigo da Lei 8.137/1990. Todavia, pelo mesmo motivo, eventual resposta que traga apenas a consequência (tipificação da conduta de Ricardo), de maneira isolada e dissociada da correta argumentação e desenvolvimento, não poderá ser pontuada.

Por fim, teses contraditórias no desenvolvimento da aplicação do princípio da consunção maculam a integralidade da questão. Todavia, com o fim de privilegiar a demonstração de conhecimento correto, não serão descontados pontos pela alegação de teses subsidiárias, ainda que inaplicáveis ao caso, desde que não configurem respostas contraditórias.

QUESTÃO 2

Comentários

Houve erro de tipo essencial provocado por terceiros. O erro de tipo essencial, conforme o art. 20, *caput*, do CP, acarreta a exclusão do dolo, afetando a tipicidade do fato. Por isso, a aposentada não pode ter sua conduta tipificada como tráfico, devendo ser considerada atípica. É possível configurar autoria mediata para o jovem que pediu que ela levasse a encomenda, mas esse aspecto não era cobrado na questão.

GABARITO

A questão pretende buscar do examinando conhecimento acerca do instituto do erro de tipo essencial, inclusive para diferenciá-lo das demais modalidades de erro. Assim, para garantir pontuação, a resposta deverá trazer as seguintes informações: a tese defensiva aplicável é a de que Larissa agiu em erro de tipo essencial incriminador, instituto descrito no art. 20, caput, do CP, pois desconhecia circunstância elementar descrita em tipo penal incriminador. Ausente o elemento típico, qual seja, o fato de estar transportando drogas, faz que, nos termos do dispositivo legal, se exclua o dolo, mas permita-se a punição por crime culposos e, como o dispositivo legal do art. 33 da Lei 11.343/2006 não admite a modalidade culposa, o fato se tornaria atípico.

Ressalte-se que, levando em conta que o Exame de Ordem busca o conhecimento técnico e acadêmico dos examinandos, não serão pontuadas respostas que tragam teses contraditórias. Assim, a resposta indicativa de qualquer outra espécie de erro (seja acidental, de tipo permissivo ou de proibição) implica a impossibilidade de pontuação, estando a questão maculada em sua integralidade. Entende-se por tese contraditória aquelas que elencam diversas modalidades de erro, ainda que uma delas seja a correta.

Também com o fim de privilegiar o raciocínio e a demonstração de conhecimento, a mera indicação da consequência correta (atipicidade do fato), dissociada da argumentação pertinente e identificação do instituto aplicável ao caso, não será passível de pontuação. Do mesmo modo, não será pontuada a mera indicação do dispositivo legal, qual seja, o art. 20, caput, do CP.

QUESTÃO 3

Comentários

O crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, previsto no art. 122 do CP, prevê duas penas: a primeira, de reclusão de dois a seis anos, para as hipóteses de ocorrência da morte; a segunda, de um a três anos para a hipótese de resultar em lesão corporal grave. Assim, as condutas de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio somente serão típicas quando resultarem em morte ou lesão grave. Nas demais situações, serão atípicas.

GABARITO

O examinando deve responder, no item “a”, que João não cometeu qualquer crime, pois o delito

descrito no art. 122 do CP, o qual prevê a conduta de instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio, não admite a forma tentada (art. 14, II, do CP), sendo certo que tal delito somente se consuma com a ocorrência de lesões corporais graves ou morte. Nesse sentido, como Maria teve apenas alguns arranhões, não houve crime.

Todavia, com o fim de privilegiar a demonstração de conhecimento doutrinário, será aceita como resposta correta ao item “a” a indicação de que haveria crime, mas que o fato não seria punível por faltar condição objetiva de punibilidade. Nesse caso específico, o examinando deverá demonstrar conhecimento sobre o conceito analítico de crime (fato típico, antijurídico e culpável), indicando que a punibilidade não o integra.

Ainda quanto ao item “a”, é indispensável a indicação do dispositivo em análise. Portanto, afirmações vagas e genéricas não são passíveis de pontuação.

Já no item “b”, o examinando deveria responder que, ante a ocorrência de lesões corporais de natureza grave em Maria, a condição jurídica de João seria alterada, passando ele a responder pelo delito previsto no art. 122 do CP na modalidade consumada.

Ressalte-se que, levando em consideração a natureza do Exame de Ordem, não será atribuída pontuação para respostas com teses contraditórias, ou mesmo sugestivas de delito na modalidade tentada. Ademais, considera-se errada a resposta indicativa de configuração de concurso de crimes ou a fundamentação isolada.

Pelo mesmo motivo exposto no item “a” (impossibilidade de consideração de afirmações vagas ou genéricas), também não é passível de pontuação a resposta, no item “b”, que não indique, de maneira expressa, o artigo legal a que se refere a questão. Desse modo, a mera referência à pena de reclusão de 1 a 3 anos, ou seja, a mera indicação do preceito secundário do tipo, dissociada da tipificação da conduta, também não é pontuada.

Por fim, também não será pontuada a simples transcrição do artigo, dissociada da demonstração de conhecimento doutrinário.

QUESTÃO 4

GABARITO

Para garantir pontuação, o examinando deveria, no item “a”, deixar expresso que Joana não cometeu qualquer crime porque não houve sequer conduta de sua parte. Cabe ressaltar que somente será aceita, como fundamento para essa hipótese, a ausência de conduta, levando em consideração o conhecimento teórico exigido no Exame de Ordem.

Assim, descabe analisar a existência de elemento subjetivo (dolo ou culpa), ilicitude ou culpabilidade, pois tais somente seriam apreciados quando houvesse conduta. Consequentemente, a resposta que trouxe apenas tal análise (sem mencionar a conduta) não será pontuada no item respectivo.

Ainda no tocante ao item “a”, o examinando deverá indicar que Maurício, diferentemente de Joana, cometeu crime, qual seja, estelionato (ou que teria praticado a conduta descrita no art. 171, caput, do CP), mas que poderia alegar em sua defesa a escusa absolutória prevista no art. 181, II, do CP. Sobre esse ponto, não será passível de pontuação a mera indicação do dispositivo legal, dissociada

da argumentação exigida.

De igual modo, não será pontuada nenhuma outra modalidade de estelionato senão aquela descrita no caput do art. 171 do CP. Ressalte-se que dados não descritos no enunciado não podem ser presumidos pelos examinandos.

Também não será passível de pontuação a indicação genérica do art. 181 do CP, sem a especificação do inciso adequado ou de argumentação pertinente ao inciso. Ademais, aplicação da escusa absolutória não conduz à atipicidade da conduta. A conduta continua típica, ilícita e culpável, havendo apenas opção legislativa pela não imposição de sanção de natureza penal, embora a sentença possa produzir efeitos civis.

Em relação ao item “b”, a atribuição de pontos estaria condicionada à expressa argumentação no sentido de que a condição jurídica de Maurício seria alterada na medida em que a isenção de pena prevista no Código Penal não se aplica aos crimes de roubo (ou à prática da conduta descrita no art. 157, caput, do CP), nos termos do art. 183, I, do CP. Portanto, Maurício seria processado e apenado pelo crime cometido.

Cumprе salientar que a mera indicação de artigo legal, dissociada da correta argumentação (em qualquer um dos itens), não pode ser pontuada. De igual modo, a mera indicação, no item “b”, de que não haveria isenção de pena (ou de que não se aplicaria o art. 181, II, do CP, por força do disposto no art. 183, I, do CP), sem a correta tipificação da conduta, não é passível de pontuação.

Além disso, levando em conta que o delito de roubo não se confunde com a extorsão, não será admitida fungibilidade entre as condutas de forma a se considerar qualquer das duas como a prática empreendida por Maurício.

Por fim, não poderá ser considerada correta a resposta que imponha a causa de aumento de pena prevista no § 2.º, I, do art. 157 do CP. Isso porque a controvérsia acerca da incidência da referida causa de aumento quanto ao uso de arma de brinquedo foi suficientemente solucionada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2001, cancelou o verbete sumular 174, no julgamento do REsp 213.054-SP.

12.2.7 VIII Exame OAB Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Comentários

A questão envolve a aplicação da Súmula Vinculante 24, que criou uma espécie de dependência de instâncias, entre a instância penal e a administrativa, que necessariamente deve preceder a persecução penal. O STF entende, no enunciado citado, que os crimes contra a ordem tributária de natureza material, ou seja, aqueles que dependem de uma efetiva sonegação para configuração, por exigirem um resultado naturalístico, somente se configuram quando o fisco conclui pela efetiva sonegação. Portanto, não é possível praticar atos de persecução penal sem o lançamento definitivo do tributo, com a conclusão do procedimento administrativo fiscal, pois o fato somente será típico com a conclusão do procedimento e consequente lançamento do tributo.

GABARITO

O examinando deverá desenvolver raciocínio acerca da atipicidade do fato, eis que, conforme entendimento pacificado no STF, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1.º, I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo (verbete 24 da Súmula Vinculante do STF).

Diante da inexistência de crime, em sede de resposta à acusação, deve-se alegar hipótese de absolvição sumária, conforme o art. 397, III, do CPP. Por fim, cumpre destacar que, em virtude de o enunciado da questão ser expresso ao exigir fundamentação na resposta, a mera transcrição da referida Súmula (seja de forma direta, seja de forma indireta, dos termos da frase), bem como a mera indicação do art. 397 do CPP, não autorizam a pontuação integral.

QUESTÃO 2

Comentários

A questão explora a diferença entre o furto (art. 155, *caput*), o furto qualificado pela fraude (art. 155, § 4.º, II) e o estelionato (art. 171). Evidentemente, a diferença entre os crimes está na conduta realizada pelo agente. Enquanto a conduta prevista no crime de furto é subtrair, a conduta do estelionato é obter. No furto, o agente retira a coisa do poder da vítima sem sua autorização, sem que ela consinta na retirada; já no estelionato, ele engana a vítima para que ela, em erro, o autorize na retirada da coisa, na obtenção da vantagem. Portanto, a conduta realizada por Abel caracteriza a obtenção do carro, após enganar a vítima, evidenciando o crime de estelionato. Já a conduta de Felipe consistiu na subtração das chaves do carro e, conseqüentemente, do próprio veículo, portanto houve furto.

GABARITO

Relativamente ao item “a” da questão, o examinando, para garantir a atribuição integral dos pontos respectivos, deverá desenvolver raciocínio no sentido de que Abel cometeu apenas o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal brasileiro.

Outrossim, deverá indicar que o crime caracteriza-se pela fraude que é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente a chave de seu carro para Abel.

*No que tange ao item “b”, deverá ser desenvolvido raciocínio no sentido de que Felipe cometeu apenas o delito de furto simples, capitulado no art. 155, *caput*, do Código Penal.*

Saliente-se que, no caso em tela, não serão admitidas respostas que indiquem a incidência de qualificadoras, uma vez que, apesar de o agente ter se vestido de manobrista, tal fato em nada interferiu na subtração do bem.

Tampouco se pode falar em crime cometido mediante destreza, haja vista que, no enunciado da questão, não há qualquer referência ao fato de Felipe possuir habilidades especiais que pudessem fazer com que efetivasse a subtração sem que a vítima percebesse.

*Assim sendo, o delito por ele praticado foi, apenas, o de furto na forma simples, descrito no *caput* do art. 155 do Código Penal.*

Ainda no item “b”, de maneira alternativa e com o fim de privilegiar demonstração de conhecimento jurídico, será pontuado o examinando esclarecer somente estar presente o núcleo do tipo e, por conta disso, a conduta de Felipe apenas se enquadraria no caput do artigo citado.

Por fim, em nenhum dos itens poderá ser atribuída pontuação pela mera explicação da atuação dos agentes, se essa estiver dissociada da correta tipificação do crime.

QUESTÃO 3

GABARITO

Para garantir pontuação à questão, o examinando deverá, no item “a”, responder, nos termos do questionado, que a hipótese tratada é de mutatio libelli, instituto descrito no art. 384 do CPP.

Não serão admitidas respostas que tragam emendatio libelli, tendo em vista que o enunciado da questão é claro ao dispor que “os fatos narrados na denúncia não corresponderiam àquilo que efetivamente teria ocorrido”. Tal expressão, por si só, ainda afastaria a incidência do disposto no art. 383, do CPP, uma vez que aquele dispositivo legal traz explicitamente restrição à sua utilização para hipóteses em que não ocorra modificação na “descrição do fato contida na denúncia ou queixa”.

Quanto ao item “b”, para garantir a pontuação pertinente, o examinando deverá responder que o juiz não poderia, na sentença, dar nova capitulação (e com base nela condenar os réus), porque deve obediência aos princípios da imparcialidade e inércia da jurisdição.

De maneira alternativa e com o fim de privilegiar a demonstração de conhecimento jurídico, será admitida resposta no sentido de que tal conduta, por parte do magistrado, feriria o sistema/princípio acusatório ou, ainda, no sentido de que tal conduta feriria o princípio da correlação/congruência entre acusação e sentença.

Ressalte-se que, no tocante ao item “b”, a questão solicita análise acerca da conduta do magistrado que, na sentença, daria nova capitulação aos fatos em decorrência de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação.

Nesse sentido, cabe destacar que, à luz do sistema acusatório adotado pela Constituição da República Federativa do Brasil, o julgador deve ser imparcial e, por isso, suas decisões devem estar balizadas pelo contexto fático descrito na peça acusatória (princípio da correlação entre acusação e sentença).

Assim, caso o magistrado viesse a condenar os réus com fundamento em fatos não narrados na denúncia – tal como descrito no enunciado –, não só estaria substituindo-se ao acusador (a quem pertence a atribuição de determinar quais fatos serão imputados aos acusados), mas também estaria violando as garantias do contraditório e ampla defesa dos réus, uma vez que lhes teria subtraído a possibilidade de debater as eventuais provas de tais fatos.

Por fim, para garantir a pontuação relativa ao item “c”, o examinando deverá responder que NÃO é possível que o Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso de apelação, proceda à mutatio libelli, pois, nos termos do verbete 453 da Súmula do STF, verbis: “não se aplica à segunda instância o art. 384 (...)”.

Tal conclusão, no item “c”, decorre do reconhecimento que, advindo inovação no contexto fático que envolve a conduta imputada ao réu no curso da instrução, não pode haver julgamento com base

nesse novo contexto fático antes que as partes possam exercer o contraditório em sua plenitude. Nessa esteira, cabe destacar que a sede própria do contraditório acerca dos fatos e das provas é o primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Tomadas essas duas premissas, alcança-se a conclusão de que eventual modificação da definição jurídica do fato decorrente de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação não pode ser realizada diretamente pelo segundo grau de jurisdição.

QUESTÃO 4

GABARITO

A questão visa obter do examinando o conhecimento acerca da extinção da punibilidade pela prescrição. Dessa forma, para obtenção da pontuação relativa ao item “a”, o examinando deve indicar que a punibilidade do réu está extinta com base na prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso de tempo superior a quatro anos.

Cumpra-se destacar que tal modalidade de prescrição é a única que se coaduna com o caso apresentado pelos seguintes fatos:

i. tendo havido o trânsito em julgado para a acusação (pois somente a defesa interpôs recurso de apelação), deve ser considerado o quantum de pena aplicada por ocasião da sentença condenatória, ou seja, um ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, não podendo esta ser majorada por força do princípio que impede a sua reforma para pior (*non reformatio in pejus*). Assim, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme o art. 107, IV, c/c arts. 109, V, e 110, § 1.º, todos do CP;

ii. considerando apenas os dados narrados no enunciado, os únicos marcos interruptivos da prescrição, segundo o art. 117 do CP, são o recebimento da denúncia (30.10.2000) e a publicação da sentença penal condenatória (29.07.2005).

Assim, com base na pena aplicada na sentença (com trânsito em julgado para o Ministério Público), retroagindo-se ao primeiro marco interruptivo narrado pela questão (recebimento da denúncia), observa-se que entre este e o segundo marco interruptivo (publicação da sentença condenatória), transcorreu lapso temporal maior do que quatro anos, com a consequente prescrição da pretensão punitiva.

Ressalte-se que justamente pela objetividade do item “a”, e por não ter havido o trânsito em julgado para ambas as partes, a indicação de espécie distinta de prescrição, que não a punitiva, macula a integralidade da resposta e impede a atribuição de pontuação. Não há que se falar, no caso em comento, em prescrição da pretensão executória. Em relação ao item “b”, o examinando, para fazer jus à pontuação respectiva, deve responder que o disposto no art. 110, caput, do CP não é aplicável ao caso narrado, pois tal artigo somente é aplicado em se tratando de prescrição da pretensão executória. Como o caso apresentado demonstra a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não há que se falar no aumento de 1/3 (um terço) no prazo prescricional. Esse entendimento é corroborado pelo verbete 220 da Súmula do STJ ao afirmar que “a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva”.

12.2.8 IX Exame OAB Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Comentários

O concurso de pessoas (agentes) exige a formação do liame subjetivo, que, embora não exija um ajuste prévio à execução, deve ocorrer até a consumação do crime. No caso apresentado na questão não há liame subjetivo na execução do furto, portanto, não há concurso de pessoas entre os agentes, devendo esta ser a resposta da letra “a”. O crime praticado pelo amigo, objeto da letra “b”, foi de favorecimento real, previsto no art. 349 do CP, pois a guarda do automóvel se deu para devolução ao próprio agente do furto, crime antecedente, e não para terceiros, quando seria configurado o crime de receptação.

GABARITO

- a) *Não há concurso de agentes, pois o auxílio foi proposto após a consumação do crime de furto. Assim, não estão presentes os requisitos necessários à configuração do concurso de agentes, mormente liame subjetivo e identidade da infração penal.*
- b) *Favorecimento real (art. 349 do CP).*

Obs.: Respostas contraditórias não serão pontuadas.

QUESTÃO 2

Comentários

A questão apresenta hipótese clássica de arrependimento eficaz, previsto no art. 15 do CP, uma vez que, após a prática da conduta homicida, o agente se arrepende e age de modo a impedir o resultado, conferindo eficácia a seu arrependimento. A consequência é a exclusão da tentativa, devendo o agente responder somente pelos atos praticados até o momento em que se arrependeu; na questão, lesões corporais de natureza grave, previstas no art. 129, § 1.º, do CP.

Na hipótese de arrependimento ineficaz, narrada na letra “b”, o agente deve responder pelo homicídio doloso consumado. O art. 15 do CP, quando prevê a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, exige eficácia dos dois institutos como forma de exclusão da tipicidade da tentativa. Se o resultado ocorre, não há incidência dos benefícios.

GABARITO

- a) *Não, pois Wilson será beneficiado pelo instituto do arrependimento eficaz, previsto na parte final c art. 15 do Código Penal. Assim, somente responderá pelos atos praticados, no caso, as lesões corporais graves sofridas por Junior.*

Obs.: A mera indicação de artigo legal não garante atribuição de pontos. Também não serão pontuadas respostas contraditórias.

- b) *Nesse caso, como não houve eficácia no arrependimento, o que é exigido pelo art. 15 do Código Penal, Wilson deverá responder pelo resultado morte, ou seja, deverá responder pelo delito de homicídio doloso consumado.*

QUESTÃO 3

Comentários

A questão envolve situação de ineficácia do meio para produzir a morte da vítima. O examinador considerou que a ineficácia era absoluta em produzir a morte, o que configura o crime impossível como excludente de tipicidade formal, afastando a existência do crime de homicídio tentado. Portanto, a decisão, questionamento da letra “a”, deve ser de absolvição sumária, fundamentada no art. 415, III, do CPP, por atipicidade do fato narrado.

No aspecto processual, objeto da letra “b”, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, pois a decisão de pronúncia está expressamente prevista no art. 581, IV, do CPP, interposto na forma do art. 586, no prazo de cinco dias. O endereçamento deve ser para o Juiz da Vara Criminal do Tribunal do Júri e as razões, para o Tribunal de Justiça.

GABARITO

- a) *Deveria absolvê-lo sumariamente, por força do art. 415, III, do CPP. O caso narrado não constitui crime, sendo hipótese de crime impossível.*
- b) *É cabível recurso em sentido estrito (art. 581, IV, do CPP); deve ser interposto no prazo de cinco dias (art. 586 CPP); a petição de interposição deve ser endereçada ao juiz a quo e as razões deverão ser endereçadas ao Tribunal de Justiça.*

QUESTÃO 4

Comentários

A questão trata do direito ao duplo grau de jurisdição fixado pelo Pacto Internacional de São José da Costa Rica, ratificado no Brasil pelo Decreto 678/1992, que prevê em seu art. 8, “h”, a garantia do direito de recorrer da sentença a um juiz ou tribunal superior. Nos casos de foro por prerrogativa de função com julgamento em única e última instância, o direito ao duplo grau é suprimido, como acontece nos julgamentos de ações penais diretamente pelo STF. Entretanto, o STF entende que a união de processos resultante da conexão não acarreta violação do princípio, mesmo que pessoas sem o foro especial sejam levadas a julgamentos em órgãos especiais, conforme regramento contido no Enunciado 704 da Súmula do STF, excluindo o direito ao duplo grau de jurisdição.

GABARITO

- a) *Não procedem os argumentos da defesa de Laura, com base no Verbete 704 da Súmula do STF. O fato de Laura ser julgada diretamente pelo Tribunal de Justiça não lhe tira a possibilidade de*

manejar outros recursos. Assim, não há qualquer ferimento ao devido processo legal, nem ao contraditório e muito menos à ampla defesa. Por fim, também não há que se falar em desrespeito ao princípio do juiz natural, já que a atração por conexão ou continência não configura criação de tribunal de exceção, sendo certo que não se pode confundir “juiz natural” com “juízo de primeiro grau”.

- b) Laura não possui direito ao duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau assegura o julgamento da causa em primeira instância e a revisão da sentença por órgão diverso. O recurso que traduz por excelência o princípio do duplo grau é a apelação, a qual devolve ao Tribunal, para nova análise, toda a matéria de fato e de direito. Como Laura será julgada diretamente pelo Tribunal de Justiça, não terá direito ao duplo grau de jurisdição, mas isso não a impede de exercer o contraditório e nem a ampla defesa, estando-lhe assegurado, assim, o devido processo legal.

Obs.: Não serão pontuadas respostas contraditórias.

12.2.9 X Exame de Ordem Unificado – FGV¹

QUESTÃO 1

GABARITO

A questão objetiva do examinando demonstração de conhecimento acerca de institutos relativos à execução penal, bem como de entendimento jurisprudencialmente consolidado acerca do tema.

Com efeito, existe jurisprudência no sentido de que o cometimento de falta grave interrompe o prazo de concessão do benefício de progressão de regime. Todavia, tal situação (progressão de regime) é diversa daquela narrada na questão, que trata de instituto distinto, qual seja, o livramento condicional.

Nesse sentido, a resposta do examinando deve ser dividida em duas alegações complementares: partindo-se da premissa que o art. 83 do CP não prevê a interrupção do prazo se cometida falta grave, é forçoso reconhecer a total ausência de previsão legal. Aliás, é pacífico o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, no sentido de que o cometimento de falta grave, por falta de previsão legal, não interrompe o prazo para aquisição do benefício do livramento condicional, o que se subsume, inclusive, pelo teor do Verbete 441 da Súmula do STJ, in verbis: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.

Por fim, levando-se em conta o comando da questão, o examinando deve concluir seu raciocínio acerca da impossibilidade do pleito Ministerial com base em institutos principiológicos. Nesse sentido, cabe ressaltar que a alegação do Ministério Público configura ofensa ao princípio da legalidade; ofende, outrossim, a vedação de dupla punição (princípio do ne bis in idem).

Ressalte-se que, com a finalidade de privilegiar a demonstração de conhecimento jurídico, também poderá ser aceito desenvolvimento no sentido de que o objetivado pelo Parquet permitiria, em última análise, analogia in malam partem, o que também é vedado pelo Direito Penal, tendo em vista o já mencionado princípio da legalidade.

QUESTÃO 2

GABARITO

Na presente questão, cabe ao examinando identificar o instituto por ela versado, qual seja, o erro de tipo accidental, na modalidade do resultado diverso do pretendido, previsto no art. 74 do Código Penal.

Referido instituto traz como consequência, para o caso sob exame, a punição do agente por crime doloso em relação ao objetivo por ele almejado (que no caso foi o crime de dano previsto no art. 163 do Código Penal), bem como a sua punição na modalidade culposa pelo resultado não intencional por ele alcançado, desde que o tal delito admita a modalidade culposa.

Nesse sentido, observa-se que o outro resultado alcançado foi o crime de homicídio, que admite a modalidade culposa, de acordo com o art. 121, § 3.º, do CP.

Sendo assim, uma vez tendo Maria alcançado os dois resultados, deverá ser punida por ambos (dano doloso e homicídio culposo) na forma do art. 70 do Código Penal, ou seja, em concurso formal próprio, que determina a majoração da pena do crime mais grave de 1/6 até 1/2.

QUESTÃO 3

GABARITO

- a) O órgão competente é a Justiça Estadual, haja vista que as duas cidades mencionadas ficam no Brasil (Porto Vera Cruz é município do Rio Grande do Sul e Foz do Iguaçu é município do Paraná) e que não há qualquer menção à transposição de fronteira nacional. A competência somente poderia ser atribuída à Justiça Federal se José tivesse cometido o crime de tráfico internacional de entorpecentes (objetivo de traficar para o exterior), na forma do disposto no art. 70, caput, da Lei 11.343/2006 e do verbete 522 da Súmula do STF.*
- b) Sim, é competente a Justiça Estadual, pois conforme já mencionado não houve dolo de traficar para o exterior.*

QUESTÃO 4

GABARITO

Segundo os dados narrados na questão, Wilson, por ser salva-vidas, tem o dever legal de agir para evitar o resultado e, naquele momento, podia perfeitamente agir. Assim, trata-se de agente garantidor. Nesse caso, responde por delito comissivo por omissão, qual seja, homicídio doloso praticado via omissão imprópria: art. 121 c/c art. 13, § 2.º, “a”, ambos do CP. Erika, por sua vez, por ter instigado Wilson a não realizar o salvamento de Ana Paula, responde como partícipe de tal homicídio, nos termos do art. 29 do CP. Não há que se falar em omissão de socorro por parte de Erika, pois, conforme dados expressos no enunciado, ela não sabia nadar e nem tinha como chamar por ajuda.

12.2.10 XI Exame de Ordem Unificado – FGV²

QUESTÃO 1

Comentários

O recurso que deve ser interposto pelo Ministério Público é o de agravo em execução, criado em 1984 por meio da Lei de Execução Penal (7.210) em seu art. 197. O prazo desse recurso, segundo a Súmula 700, STF, é de cinco dias, e este serve para impugnar decisões interlocutórias proferidas pelo juiz da vara de execução penal. Devemos lembrar que, para se ter certeza da utilização desse recurso, a análise do art. 66 da LEP é fundamental, pois nele se encontram as decisões proferidas durante o trâmite executório que podem gerar inconformismo por parte dos envolvidos, gerando, assim, o interesse recursal.

Quanto à letra “b”, assim demonstrou o espelho de correção: “pois de acordo com o Verbete 493 da Súmula do STJ, é inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto. Ademais, embora ao Juiz seja lícito estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, em complementação daquelas previstas na LEP (art. 115 da LEP), não poderá adotar a esse título nenhum efeito já classificado como pena substitutiva (art. 44 do CPB), porque aí ocorreria o indesejável *bis in idem*, importando na aplicação de dúplice sanção. Ademais, o art. 44 do Código Penal é claro ao afirmar a natureza autônoma das penas restritivas de direitos que, por sua vez, visam substituir a sanção corporal imposta àqueles condenados por infrações penais mais leves. Diante do caráter substitutivo das sanções restritivas, vedada está sua cumulatividade com a pena privativa de liberdade, salvo expressa previsão legal, o que não é o caso. Precedente: STJ, *Habeas corpus* 218.352/SP (2011/0218345-1).

GABARITO

- a) *Agravo em Execução (art. 197 da LEP).*
- b) *Não, pois de acordo com o verbete 493 da Súmula do STJ, é inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto.*
Ademais, embora ao Juiz seja lícito estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, em complementação daquelas previstas na LEP (art. 115 da LEP), não poderá adotar a esse título nenhum efeito já classificado como pena substitutiva (art. 44 do CPB), porque aí ocorreria o indesejável bis in idem, importando na aplicação de dúplice sanção. Ademais, o art. 44 do Código Penal é claro ao afirmar a natureza autônoma das penas restritivas de direitos que, por sua vez, visam substituir a sanção corporal imposta àqueles condenados por infrações penais mais leves. Diante do caráter substitutivo das sanções restritivas, vedada está sua cumulatividade com a pena privativa de liberdade, salvo expressa previsão legal, o que não é o caso. Precedente: STJ, Habeas Corpus 218.352/SP (2011/0218345-1).

QUESTÃO 2

Comentários

Notemos que a questão deixa claro que o acórdão proferido em 2.^a instância foi decidido de forma unânime, impedindo, logicamente, a apresentação dos embargos infringentes e de nulidade do art. 609, parágrafo único, CPP. Sendo assim, o recurso cabível à espécie é o recurso especial com base no art. 105, III, “a”, CF, com a folha de interposição endereçada ao Tribunal de Justiça e as razões para o Superior Tribunal de Justiça.

Já quanto à pergunta de alínea “b”, o candidato deveria mencionar o fenômeno da *reformatio in pejus*. Esse instituto impede que o tribunal de 2.^o grau que recebe um recurso tão somente apresentado pela defesa agrave ou piore a situação presente em sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. É importante salientar que esse fenômeno só acontece quando somente a defesa recorre, conforme deixa bem claro o art. 617 CPP. Vejamos o espelho de correção: “Deve ser salientado que não agiu corretamente o Tribunal de Justiça ao fixar as condições do *sursis*, pois tal tarefa cabia ao juiz *a quo*, e, como ele não o fez, bem como não houve impugnação por parte do Ministério Público acerca de tal omissão, a atitude do Tribunal configura verdadeira *reformatio in pejus*, vedada pelo art. 617, do CPP”.

GABARITO

- a) *Cabível a interposição de recurso especial, com fulcro no art. 105, III, “a”, da CRFB/88.*
- b) *Deve ser salientado que não agiu corretamente o Tribunal de Justiça ao fixar as condições do sursis, pois tal tarefa cabia ao juiz a quo e, como ele não o fez, bem como não houve impugnação por parte do Ministério Público acerca de tal omissão, a atitude do Tribunal configura verdadeira reformatio in pejus, vedada pelo art. 617, do CPP.*

QUESTÃO 3

Comentários

- a) Deve ser considerado portador de bons antecedentes, quando, da condenação pelo crime de roubo, ainda não havia sentença condenatória transitada em julgado por outros crimes.
- b) O juiz deverá considerá-lo como portador de maus antecedentes, uma vez que na data da sentença já havia a condenação transitada em julgado pelo roubo. Entretanto, não pode ser considerado como reincidência, pois o trânsito em julgado da condenação anterior aconteceu após a prática do crime de extorsão, na forma do art. 63 do CP, e não é possível configurar a reincidência.
- c) O juiz pode considerar as condenações pelo roubo e pela extorsão como causas de maus antecedentes, pois na data da condenação pelo estelionato já havia as sentenças condenatórias transitadas em julgado pelos dois crimes anteriores. Quanto à reincidência, não é possível configurá-la, pois o trânsito em julgado das sentenças anteriores ocorreu somente após a prática do novo crime, na forma do art. 63 do CP.

GABARITO

A questão objetiva busca extrair do examinando conhecimento de institutos relativos à dosimetria

da pena, em especial no tocante à circunstância judicial dos maus antecedentes e à agravante da reincidência. Munido de tal conhecimento, o examinando deve ser capaz de identificar os institutos e também diferenciá-los quando diante de um caso concreto.

Nesse sentido, relativamente ao item “a”, percebe-se que Ricardo possui bons antecedentes. Eventual sentença condenatória ainda não transitada em julgado não tem o condão de implicar-lhe maus antecedentes, pois isso significaria acréscimo de tempo em sua pena e contrariaria, assim, o princípio do estado de inocência, constitucionalmente previsto.

No item “b”, atendendo-se ao comando da questão, o examinando deve indicar que Ricardo é primário. Isso porque a extorsão foi cometida em 10.09.09, antes, portanto, do trânsito em julgado da sentença que o condenou pelo roubo (ocorrido em 15.05.2010), tal como manda o art. 63 do CP. Não obstante a primariedade de Ricardo, ele é portador de maus antecedentes, pois na data da sentença relativa ao delito de extorsão (18.10.2010) já havia ocorrido o trânsito em julgado da sentença do crime de roubo.

Por fim, em relação ao item “c”, o examinando deve indicar que ainda permanece a primariedade de Ricardo, pois o delito de estelionato foi cometido antes do trânsito em julgado de qualquer outro delito. Perceba-se que um indivíduo somente pode ser considerado reincidente se o crime pelo qual está sendo julgado tiver sido cometido após o trânsito em julgado de sentença que lhe haja condenado por delito anterior, nos termos do art. 63, do CP.

Todavia, Ricardo é portador de maus antecedentes, pois na data da sentença relativa ao estelionato já havia ocorrido o trânsito em julgado de duas outras sentenças condenatórias.

QUESTÃO 4

Comentários

Questão interessante que avalia conhecimentos de prática penal e do devido processo legal que norteia toda uma preparação para o exame de Ordem. Após a denúncia apresentada e o consequente recebimento e citação, a defesa deve, em 10 dias, apresentar a resposta do acusado conforme o art. 396 c/c art. 396-A CPP. Nesse momento, deve a defesa, depois de superar exceções, preliminares, causas de não recebimento da ação, atualmente possíveis de se arguir conforme STJ em seu informativo 522, buscar a absolvição sumária do art. 397, CPP. Na questão em comento, o inciso específico que deve ser mencionado é o art. 397, III – que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Já na alínea “b” da questão, o gabarito oficial é bem claro: “Está ausente a tipicidade material. Isso porque, pela moderna doutrina, somente haverá tipicidade se, além da tipicidade formal (subsunção do fato à norma), estiver presente, também, a tipicidade material, assim entendida como efetiva lesão relevante ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado”. Deve, portanto, incidir o princípio da insignificância como excludente da tipicidade material.

GABARITO

A questão objetiva extrair do examinando conhecimento acerca da absolvição sumária, bem como dos elementos essenciais à configuração da tipicidade penal de uma conduta.

- a) *O juiz deve absolver sumariamente a ré, devendo fundamentar sua decisão no art. 397, III do CPP.*
- b) *Está ausente a tipicidade material. Isso porque, pela moderna doutrina, somente haverá tipicidade se, além da tipicidade formal (subsunção do fato à norma), estiver presente, também, a tipicidade material, assim entendida como efetiva lesão relevante ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado.*

12.2.11 XII Exame de Ordem Unificado – FGV³

QUESTÃO 1

Comentários

Excelente questão, diga-se de passagem, formulada pela banca examinadora. Exigir do candidato o conhecimento de uma súmula sempre nos pareceu uma extraordinária forma de avaliação. Curiosamente, no caso em tela, duas súmulas, do STJ e do STF, semelhantes, devem ser inseridas na resposta. Senão, vejamos:

Súmula 244, STJ: “Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos”.

Súmula 521, STF: “O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado”.

Em conclusão, devemos abordar na resposta que o juiz competente é o da comarca “Z”, e não “Y”, e este pedido deve ser feito via exceção de incompetência (art. 95, II, CPP c/c art. 108, CPP) ou, como aborda o espelho de correção: “Deve ser arguida exceção de incompetência com fundamento no art. 108 do CPP OU preliminar de incompetência na resposta à acusação. O estelionato é crime material e se consuma no local onde ocorreu o efetivo prejuízo econômico. No caso em tela, o efetivo prejuízo econômico se deu no lugar onde o título foi recusado, ou seja, na comarca ‘Z’. Assim, aplica-se o disposto no verbete 521 da Súmula do STF e o verbete 244 da Súmula do STJ. Consequentemente, deve ser feito pedido de remessa do feito à comarca ‘Z’, onde poderão ser ratificados os atos até o momento praticados, prosseguindo-se na instrução”.

GABARITO

Deve ser arguida exceção de incompetência com fundamento no art. 108 do CPP OU Preliminar de incompetência na resposta à acusação. O estelionato é crime material e se consuma no local onde ocorreu o efetivo prejuízo econômico. No caso em tela, o efetivo prejuízo econômico se deu no lugar onde o título foi recusado, ou seja, na comarca “Z”. Assim, aplica-se o disposto no verbete 521 da Súmula do STF e o verbete 244 da Súmula do STJ. Consequentemente, deve ser feito pedido de remessa do feito à comarca “Z”, onde poderão ser ratificados os atos até o momento praticados, prosseguindo-se na instrução.

QUESTÃO 2

Comentários

Clássica questão dos amantes dos temas prisionais dentro do processo penal. Flagrante e suas situações. A mais conhecida, a do flagrante preparado, é a resposta correta dessa questão. Quando existe algum tipo de influência, incentivo, preparação para que se cometa algum eventual delito, o entendimento é de que não existe situação flagrancial. A própria Súmula 145, STF, que evidentemente deve ser mencionada, nos dá a resposta da alínea “b”. Vejamos sua redação:

Súmula 145, STF: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.

A tese, portanto, que deve ser mencionada é a de crime impossível do art. 17, CP. O crime impossível torna o fato atípico, deixando de ser crime.

GABARITO

A situação narrada configura hipótese de flagrante preparado (ou provocado). Tal prisão em flagrante é nula e deve ser imediatamente relaxada, haja vista o fato de ter sido preparada por um agente provocador, que adotou medidas aptas a impedir por completo a consumação do crime.

Inclusive, o verbete 145 da Súmula do STF disciplina que nas situações como a descrita no enunciado inexistente crime.

Aplica-se, também, o art. 17 do Código Penal: o flagrante preparado constitui hipótese de crime impossível.

Sendo assim, a melhor tese defensiva aplicável a Ricardo é aquela no sentido de excluir a prática de crime com base no verbete 145, da Súmula do STF, e no art. 17, do Código Penal.

Note-se que o enunciado da questão deixa claro que busca a melhor tese defensiva no campo jurídico-penal. Assim, eventuais respostas indicativas de soluções no âmbito processual (tais como: prisão ilegal que deve ser relaxada), ainda que corretas, não serão consideradas para efeito de pontuação, haja vista o fato de não responderem ao questionado.

QUESTÃO 3

Comentários

Não é possível falar em tentativa de homicídio, pois o agente, embora com dolo inicial de matar, quando estava na fase de execução, no *iter criminis*, desistiu de prosseguir, o que configura desistência voluntária, prevista no art. 15 do CP, devendo o agente responder somente pelos atos já praticados, e não pela tentativa. Como o agente sequer atingiu a vítima, não há tipicidade dos seus atos.

GABARITO

O examinando deve responder que Félix não deve ser responsabilizado por tentativa de homicídio, pois a hipótese narrada enquadra-se naquela descrita no art. 15, do CP, em sua primeira parte, ou

seja, trata do instituto da desistência voluntária. Isso porque, conforme narrado no enunciado, percebe-se que o agente (Félix), desistiu de prosseguir na execução do delito quando ainda lhe sobrava, do ponto de vista objetivo, margem de ação. Assim, conforme o dispositivo legal supracitado, Félix responderia apenas por eventuais atos praticados. Note-se, entretanto, que os atos praticados pelo agente não traduzem a prática de crime, razão pela qual Félix não responde por nada.

QUESTÃO 4

Comentários

Como se trata de decisão proferida pelo juiz da execução penal, o recurso cabível é o agravo, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal – 7.210/1984. O prazo para a interposição do recurso é de cinco dias, contados da data da publicação da decisão no D.O., conforme dispõe a Súmula 700 do STF.

A letra “c” cobrava uma exceção à regra; em geral o art. 197 dispõe que o agravo não tem efeito suspensivo, mas o art. 179 da LEP estabelece que o juiz somente poderá determinar a desinternação ou a cessação da medida de segurança quando transitada em julgado a decisão, assim o agravo nessa situação terá indiretamente o efeito suspensivo, pois, enquanto o agravo estiver sendo julgado, a desinternação não se concretiza.

GABARITO

- a) *Como se trata de decisão proferida pelo juiz da execução penal, o recurso cabível é o Agravo, previsto no art. 197, da Lei de Execução Penal – 7.210/1984.*
- b) *O prazo para a interposição do recurso é de cinco dias, contados da data da publicação da decisão no D.O., conforme dispõem as Súmulas do STF 699 e 700.*

SÚMULA 699 – O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO, EM PROCESSO PENAL, É DE CINCO DIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.038/1990, NÃO SE APLICANDO O DISPOSTO A RESPEITO NAS ALTERAÇÕES DA LEI 8.950/1994 AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SÚMULA 700 – É DE CINCO DIAS O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL.

- c) *Via de regra, o recurso de Agravo em Execução não tem efeito suspensivo, conforme previsão do art. 197, da LEP. Todavia, a hipótese tratada no enunciado é a única exceção à regra supramencionada, i.e., o agravo possui, na hipótese do enunciado, efeito suspensivo, conforme previsto no art. 179, da LEP.*

Portanto, a interposição desse recurso suspende a eficácia da sentença.

12.2.12 XIII Exame de Ordem Unificado – FGV⁴

QUESTÃO 1

Comentários

- a) *A tentativa, art. 14, II, do CP, exige que o agente entre na fase de execução do crime, o que notadamente não ocorreu na letra “a”, quando o agente decide que foi preso quando ainda estava na fase de cogitação, o que não pode ser punido.*
- b) *O fato seria atípico, uma vez que o art. 333 do CP não prevê os verbos pagar, dar ou satisfazer. Somente há previsão dos verbos oferecer ou prometer. Por isso o fato é atípico formalmente, por não estar previsto em lei.*

GABARITO

A questão objetiva extrair do examinando conhecimento acerca do iter criminis e dos crimes praticados por particular contra a administração pública.

Nesse sentido, relativamente à alternativa “a”, o examinando deve lastrear sua resposta no sentido de que o delito de corrupção ativa (art. 333 do CP) é crime formal que não admite, via de regra, a modalidade tentada (exceto, como exemplo recorrente na doutrina, se o crime for praticado via escritos). Além disso, levando em conta a narrativa do enunciado, percebe-se que o delito em análise sequer teve o início da execução e, muito menos, atingiu a consumação. Isso porque a corrupção ativa somente se consuma com o efetivo oferecimento ou promessa de vantagem indevida, o que não ocorreu no caso narrado.

Consequentemente, a conduta levada a efeito por Gustavo é atípica.

No que se refere a alternativa “b”, por sua vez, o examinando deve indicar que, caso Gustavo pagasse a quantia solicitada pelo policial, ele não responderia por corrupção ativa, pelo simples fato de que tal conduta sequer está descrita no tipo penal do art. 333 do CP, configurando, portanto, fato atípico.

QUESTÃO 2

Comentários

- a) *Sim, o furto praticado por ele está consumado, conforme entendimento prevalente nos tribunais superiores. Tanto o STF quanto o STJ têm adotado, para determinar a consumação do furto, bem como do roubo, a teoria da amotio, que define como momento de consumação a retirada da coisa do local onde a vítima deixou, acarretando a perda da disponibilidade sobre a coisa. Por outro lado, a doutrina brasileira, divergente da jurisprudência, vem adotando a teoria da ablatio, que prolonga o momento de consumação, dependendo a consumação da apreensão da coisa, além da retirada do local. Assim, é necessário que se torne possuidor da coisa. A questão pontuou somente a posição dos tribunais. Há outras duas teorias sobre a consumação do furto, contrectatio e illatio, mas as duas principais estão expostas no comentário.*
- b) *A principal tese, não sendo admitido o princípio da insignificância, é a incidência do furto qualificado, art. 155, § 2.º, no crime qualificado pelo § 4.º. A matéria é pacífica nos tribunais superiores, quando a coisa é de pequeno valor e o criminoso primário; se não for possível aplicar a insignificância, incidirá o privilégio em favor do agente. Atualmente, o entendimento está sumulado no Enunciado 511.*

GABARITO

A questão trata do crime de furto e busca extrair do examinando conhecimento específico sobre dois pontos importantes acerca do tema: o momento consumativo do delito e a incidência do privilégio. A primeira indagação tem cunho eminentemente teórico, enquanto a segunda é de caráter prático, pois exige que o examinando saiba interpretar informações dadas no enunciado e, a partir delas, identificar a incidência do privilégio, o que será capaz de reduzir significativamente a resposta penal a ser dada ao personagem da questão. Nesse sentido, para fazer jus aos pontos relativos ao item “a”, o examinando deve responder afirmativamente, indicando que o furto atingiu a consumação. Com efeito, diversas teorias existem sobre o momento consumativo do crime de furto, sendo certo que a predominante, tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, é a Teoria da Amotio, segundo a qual a consumação ocorre quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo – tal como ocorreu no caso narrado –, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica da coisa. Também merece destaque, embora não seja o entendimento majoritário, reflexão sobre o momento consumativo do crime de furto narrado no enunciado com a adoção da Teoria da Ablatio. Perceba-se que ainda assim a resposta seria a mesma: o furto foi consumado. Isso porque, para aqueles que adotam a Teoria da Ablatio, o furto consuma-se quando o agente, depois de apoderar-se da coisa, consegue deslocá-la de um lugar para o outro – fato que, da mesma forma, foi narrado no enunciado. Cabe ressaltar que a Banca Examinadora, com o intuito de privilegiar a demonstração de conhecimento jurídico, aceitará como justificativa correta ambas as fundamentações acima expostas, sem perder de vista que os Tribunais Superiores adotam a Teoria da Amotio. Pelo mesmo motivo, entretanto, não será pontuada a resposta que traga apenas a afirmativa “sim”, desprovida de qualquer justificativa ou mesmo com justificativa equivocada.

No tocante ao item “b”, para que receba a pontuação respectiva, o examinando deve indicar que, de acordo com a questão, desconsiderando a argumentação no sentido de aplicação do princípio da insignificância (que pelo próprio enunciado afigura-se como inaplicável), a principal tese defensiva deve ser o reconhecimento do furto qualificado e privilegiado (art. 155, § 2.º, c/c art. 155, § 4.º, III, ambos do CP). Isso porque a qualificadora da utilização de chave falsa possui natureza objetiva, sendo compatível com o furto privilegiado, que é de ordem subjetiva. O reconhecimento do furto privilegiado ou mínimo deve ser o argumento defensivo em sede de apelação por trazer vários benefícios a Antônio, como a substituição da pena de reclusão pela pena de detenção, a diminuição da pena de um a dois terços ou aplicação da pena de multa. Cabe destacar que há muito tempo a controvérsia sobre a possibilidade de furto privilegiado e qualificado foi superada, existindo diversos julgados tanto no STF quanto no STJ sobre o tema. Inclusive, o próprio STF, no Informativo 580, manifestou-se sobre a possibilidade de tal combinação, sendo, portanto, a melhor tese defensiva.

QUESTÃO 3

Comentários

Acreditamos que essa questão teve influência de situações narradas pela mídia, em especial a

famosa Ação Penal 470, mais conhecida como “mensalão”, em que após a condenação transitar em julgado no STF, teve o feito enviado à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para os trâmites executórios. Adaptado e fictício, evidentemente, o personagem Jeremias, depois de ser condenado e ter decisão transitada em julgado pela Justiça Federal, terá seu processo enviado à vara de execuções penais estaduais, pois atualmente não temos varas de execuções penais na Justiça Federal. Seu pedido, portanto, deve ser feito ao juiz da vara de execuções penais do Estado. Um detalhe que faz toda a diferença nessa questão: o examinador exige jurisprudência sumulada, portanto, finalizemos:

Súmula 192, STJ: “Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual”.

GABARITO

Não obstante Jeremias ter sido condenado pela Justiça Federal, a competência para o processamento do pedido é da Justiça Estadual, haja vista que Jeremias cumpre pena em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária; daí a transferência de competência da execução penal para a Justiça Estadual, conforme preceitua a Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça.

SÚMULA 192 – Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual.

QUESTÃO 4

Comentários

- a) *A resposta deveria ser positiva, pois o STF considerou inconstitucional a obrigatoriedade do regime inicial fechado, por violação do princípio da individualização da pena, previsto no art. 5.º, LVII, da Constituição, conforme se verifica no julgamento do HC 111.840 do STF.*
- b) *A resposta deveria ser positiva, sim; o crime de tráfico privilegiado, art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, embora traga vedação expressa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, foi considerado inconstitucional nesse ponto, tendo inclusive sua eficácia suspensa por decisão do Senado Federal, por meio da Resolução 5/2012. Assim cabem as penas restritivas de direitos, pelo menos teoricamente, desde que cumpridos os requisitos do art. 44 do CP.*

GABARITO

A questão objetiva extrair do examinando conhecimento atualizado acerca da jurisprudência do STF.

Nesse sentido, relativamente ao item “a”, a resposta deve ser lastreada no sentido de que cabe, sim, impugnação ao regime inicial fechado, fixado exclusivamente com base no artigo 2.º, § 1.º, da Lei 8.072/1990. Isso porque o STF, no HC 111.840/ES, declarou inconstitucional a previsão, na Lei dos Crimes Hediondos, da exigência da fixação do regime inicial fechado. Na oportunidade a Corte

se manifestou no sentido de que a definição do regime deveria sempre ser analisada independentemente da natureza da infração. A CRFB/88 contemplaria as restrições aplicadas à Lei 8.072/1990, dentre as quais não estaria a obrigatoriedade de imposição de regime extremo para início de cumprimento de pena. Tal posicionamento vem sendo reiterado pela Suprema Corte, sendo certo que a fixação do regime inicialmente fechado deve conter uma fundamentação em concreto, sob pena de ofensa à individualização da pena.

No tocante ao item “b”, devemos observar que o STF, no HC 97.256/RS, decidiu que o art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, é inconstitucional ao vedar a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Após a reiteração do entendimento pela Suprema Corte, foi editada a resolução 5 do Senado, com o seguinte teor: “art. 1.º – É suspensa a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4.º do art. 33, da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus 97.256/RS”. Desta forma, é possível a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, desde que o réu preencha os requisitos do art. 44, do CP.

12.2.13 XIV Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

Comentários

A questão objetiva extrair do examinando conhecimento acerca da teoria geral das nulidades no Processo Penal. Nesse sentido, para garantir os pontos relativos à questão, o examinando deve, na alternativa “a”, indicar que a hipótese é de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, “i”, c/c o art. 572, ambos do CPP. Em relação à alternativa “b”, o examinando deve lastrear sua resposta no sentido de que não foi correta a atitude do Tribunal de Justiça. Isso porque, de acordo com o Verbete 160 da Súmula do STF, o Tribunal de Justiça não pode acolher, contra o réu, nulidade não aventada pela acusação em seu recurso. Assim, agir significaria desrespeito ao princípio da vedação à *reformatio in pejus* indireta. O enunciado da questão foi claro ao informar que o recurso do Ministério Público não alegou nenhuma nulidade. Destarte, levando em conta que o réu foi absolvido em relação ao delito de homicídio, o reconhecimento de nulidade implicar-lhe-á em prejuízo.

No mais, vale observar ensinamentos do grande mestre e Professor Guilherme de Souza Nucci em seu Código de Processo Penal comentado, 9. ed., RT: “Trata-se de norma cogente, implicando nulidade absoluta a instalação dos trabalhos, no Tribunal do Júri, com menos de 15 jurados. Não se trata de mera formalidade, mas de uma margem de segurança para que possam ocorrer as recusas imotivadas das partes – três para cada uma –, permitindo, ainda, restar um número mínimo de jurados para configurar um sorteio”.

Pelo CPP, trata-se de nulidade absoluta, conforme art. 572, que define que só algumas podem ser sanadas, e tal característica é inerente à relativa. Como o dispositivo penal não fala de sanabilidade da letra “i”, pelo CPP, considera-se absoluta tal nulidade.

Concluindo, vale observar que o tema de nulidade é muito discutido em nossos tribunais e a análise

regular de julgamentos no STF/STJ se faz necessária.

GABARITO

A questão objetiva extrair do examinando conhecimento acerca da teoria geral das nulidades no Processo Penal. Nesse sentido, para garantir os pontos relativos à questão, o examinando deve, na alternativa “a”, indicar que a hipótese é de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, “i” c/c art. 572, ambos do CPP. Em relação à alternativa “b”, o examinando deve lastrear sua resposta no sentido de que não foi correta a atitude do Tribunal de Justiça. Isso porque, de acordo com o Verbete 160 da Súmula do STF, o Tribunal de Justiça não pode acolher, contra o réu, nulidade não aventada pela acusação em seu recurso.

Assim agir significaria desrespeito ao princípio da veda a reformatio in pejus indireta.

O enunciado da questão foi claro ao informar que o recurso do Ministério Público não alegou nenhuma nulidade. Destarte, levando em conta que o réu foi absolvido em relação ao delito de homicídio, o reconhecimento de nulidade implicar-lhe-á em prejuízo.

Por fim, com a finalidade de privilegiar a demonstração de conhecimento jurídico, a Banca convencionou aceitar também, no item “b”, o verbatim 713 da Súmula do STF como fundamento à impossibilidade de o Tribunal acolher, contra o réu, nulidade não aventada pela acusação em seu recurso.

QUESTÃO 2

Comentários

Acerca do recurso de agravo em execução, vale ainda acrescentar que o art. 66 da Lei de Execução Penal, em seu inciso III, letra “b”, traz expressamente a decisão que merece ser atacada por meio de agravo.

GABARITO

A questão objetiva extrair do examinando conhecimento acerca da lei penal no tempo (regramento legal e entendimento jurisprudencial), bem como da execução penal.

Nesse sentido, relativamente à alternativa “a”, o examinando deve indicar que o recurso a ser interposto é o agravo, previsto no art. 197 da LEP.

Tendo em conta a própria natureza do Exame de Ordem, a mera indicação do dispositivo legal não será pontuada.

No que tange ao item “b”, por sua vez, a resposta deve ser lastreada no sentido de que, de acordo com os verbetes 26 da Súmula Vinculante do STF e 471 da súmula do STJ, Mário, por ter cometido o crime hediondo antes da Lei 11.464/2007, não se sujeita ao art. 2.º, § 2.º, da Lei 8.072/1990, por se tratar de novatio legis in pejus, devendo ocorrer sua progressão de regime com base no art. 112 da Lei de Execuções Penais, observando o quantum de 1/6 de cumprimento de pena.

Cabe destacar que tal entendimento surgiu do combate ao art. 2.º, § 2.º, da Lei 8.072/1990, que previa o cumprimento de pena no regime integralmente fechado para os crimes hediondos ou

equiparados. Após longo debate nos Tribunais Superiores, reconheceu-se a inconstitucionalidade da previsão legal, por violação ao princípio da individualização da pena, culminando na progressão de regime com o quorum até então existente, qual seja, 1/6, com base no art. 112 da LEP.

O legislador pátrio, após o panorama jurisprudencial construído, alterou a redação do art. 2.º, § 2.º, da Lei 8.072/1990, autorizando a progressão de regime de forma mais gravosa para aqueles que cometeram crimes hediondos, por meio do cumprimento de 2/5 para os réus primários e 3/5 para os reincidentes.

No entanto, a nova redação conferida ao art. 2.º, § 2.º, da Lei 8.072/1990, por meio da Lei 11.464/2007, externa-se de forma prejudicial àqueles que cometeram crimes hediondos em data anterior a sua publicação, tendo em vista que os Tribunais Superiores autorizavam a sua progressão com o cumprimento de 1/6 da pena.

Diante dessa construção jurisprudencial, os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento por meio dos verbetes 26 da Súmula Vinculante do STF e 471 da Súmula do STJ.

QUESTÃO 3

Comentários

Vale mencionar um equívoco nesse espelho, pois a competência da Justiça Federal, com base no art. 109 da CF, é em razão da matéria, da natureza, e não da pessoa, como diz o gabarito comentado oficial. Por sorte, isso em nada influenciará na resposta do candidato. Apenas fica o registro. Além da Súmula 42 do STJ, outra súmula que poderia ser mencionada é a 508 do STF.

GABARITO

*A Constituição da República, em seu art. 109, IV, estabelece que compete à Justiça Federal o julgamento das infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Trata-se de competência determinada *ratione personae*. Assim, para se estabelecer a competência de julgamento dos crimes mencionados no enunciado, o examinando deverá, em primeiro lugar, levar em consideração a natureza jurídica da pessoa lesada.*

Destarte, no caso do item “a”, a competência para julgamento do crime em que foi lesada a CEF é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da CRFB/1988.

Relativamente ao item “b”, levando-se em conta que o lesado foi o Banco do Brasil, a competência para o julgamento do crime praticado é da Justiça Estadual, pois, como visto anteriormente, referida instituição está fora do alcance da regra insculpida no art. 109, IV, da CF, sendo certo que a competência da Justiça Estadual é residual. Além disso, há também o verbatim 42 da Súmula do STJ sobre o tema: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

QUESTÃO 4

Comentários

Questão de extrema simplicidade, na qual se afere a habilidade do candidato em pesquisar na legislação dispositivos legais. O primeiro cuidado seria em relação ao art. 581, X, CPP que traz a possibilidade do recurso em sentido estrito de decisão concessiva ou denegatória de *habeas corpus* em 1.^a instância. Já a partir dos tribunais o recurso que deve ser interposto é o famoso ROC.

GABARITO

De acordo com a jurisprudência atualizada, tanto do STJ como do STF, bem como com o mandamento descrito no art. 105, II, “a”, da Constituição Federal, em habeas corpus caberá recurso ordinário. O art. 30 da Lei 8.038/1990 determina ser de cinco dias o prazo para interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de habeas corpus proferida pelos Tribunais dos Estados. No caso narrado no enunciado, o recurso deve ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, conforme informa o art. 105, II, “a”, da Constituição Federal, já que se trata de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça.

12.2.14 XV Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

GABARITO

A questão tem como objetivo extrair do examinando conhecimento acerca do tema Execução Penal. Conforme o enunciado informa, o Decreto de Indulto previa que apenas impediria o benefício a punição pela prática de falta grave nos 12 meses anteriores à sua publicação. Diante disso, a jurisprudência vem entendendo que a prática de falta grave após a publicação do Decreto, ainda que antes da análise do requerimento do benefício pelo órgão competente, não impede sua concessão, respeitando-se, assim, o princípio da legalidade. Miguel faz jus ao benefício, motivo pelo qual deve o seu advogado interpor Agravo de Execução da decisão do juiz da VEP, sendo o seu prazo de cinco dias, conforme art. 197 da Lei 7.210, c/c art. 586, CPP e Súmula 700 do STF.

Cumprе destacar que a questão em análise foi dividida em dois itens. Nesse sentido, para fazer jus à pontuação relativa ao item “a”, o examinando deveria indicar de modo expрesso o cabimento do recurso de Agravo em Execução, cuja previsão legal está no art. 197 da Lei de Execuções Penais; outrossim, deveria indicar que o prazo para a interposição de referido recurso é de cinco dias, tal como indica o verbete 700 da Súmula do STF. Por fim, para receber a pontuação relativa ao item “b”, o examinando deveria indicar que Miguel fazia jus ao benefício do indulto porque preenchia os requisitos nele previstos, a saber: o tempo exigido pelo decreto e a ausência de cometimento de falta grave (ou ausência de sanção pela prática de falta grave no período mencionado em referido decreto), de modo que, em respeito ao princípio da legalidade, o magistrado não poderia estabelecer outros requisitos que não constassem expressamente do decreto.

Como determina o próprio espelho de correção, a simples indicação de dispositivo legal não pontua. De igual modo, as respostas devem ser sempre justificadas. Além disso, a indicação de duas ou

mais medidas processuais (ainda que uma delas seja a correta), não será pontuada, pois o comando da questão determina a indicação de apenas uma.

QUESTÃO 2

GABARITO

A questão em análise busca extrair conhecimento acerca do tema prisão preventiva. Durante muito tempo se controverteu sobre a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, em especial durante as investigações policiais. A Lei 12.403 conferiu novo tratamento ao tema. Na hipótese narrada, o juiz, ainda durante a fase de investigação, sem ação penal em curso, decretou a prisão preventiva do indiciado de ofício, o que não é admitido pelo art. 311 do Código de Processo Penal, tendo em vista que violaria o princípio da imparcialidade, o princípio da inércia e até mesmo o sistema acusatório. Ainda que a decretação da prisão preventiva de ofício neste momento fosse admitida, a fundamentação apresentada seria insuficiente, pois a gravidade em abstrato do crime não pode justificar a aplicação de medidas cautelares pessoais. O juiz não fundamentou a prisão preventiva, medida excepcional, considerando o princípio da presunção de inocência e o direito à liberdade, com circunstâncias em concreto do caso.

Nesse sentido, percebe-se que a questão em análise dividiu-se em dois itens distintos.

Para receber a pontuação relativa ao item “a”, considerando-se o comando da questão (“Poderia o magistrado adotar tal medida? Justifique”), o examinando deveria responder que o magistrado não poderia ter agido daquela forma, calcando-se no sistema acusatório que norteia o processo penal brasileiro desde sua expressa adoção pela nossa Magna Carta. Consoante o sistema acusatório, o juiz deve ser inerte e imparcial, de sorte que a decretação de uma prisão cautelar de ofício por parte do magistrado fere frontalmente tais postulados. Ademais, interpretando-se o art. 311 do CPP, resta claro que o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício na fase de inquérito. Tal interpretação decorre, obviamente, de uma leitura baseada no sistema acusatório. Nesse ínterim, é oportuno destacar que eventuais respostas calcadas no art. 311 do CPP, necessariamente, deveriam demonstrar que tal dispositivo veda a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz na fase de inquérito policial. A tal constatação somente se chega a partir de uma interpretação principiológica, razão pela qual não merecem pontuação as respostas que se limitarem a indicar como fundamento da negativa o art. 311 do CPP, simplesmente, sem qualquer análise mais aprofundada.

Por fim, para fazer jus à pontuação relativa ao item “b”, considerando-se o comando da questão, o examinando deveria indicar que a fundamentação apresentada pelo magistrado não foi suficiente, pois a gravidade em abstrato do delito, segundo entendimento pacífico, não é argumento idôneo, capaz de justificar uma prisão cautelar. Mais uma vez, a simples indicação de dispositivo legal não deve ser pontuada, sendo necessário, tal como manda o enunciado, que o examinando justifique sua resposta.

QUESTÃO 3

GABARITO

Para auferir a pontuação relativa ao item “a”, considerando-se o comando da questão, o examinando deve indicar que a medida jurídica a ser adotada para impedir de imediato o prosseguimento da ação penal é o habeas corpus, devendo fundamentar sua resposta no art. 5.º, LXVIII, CRFB/88, ou no art. 647 do CPP, ou no art. 648, incisos I ou VI, do CPP. Ressalte-se que em virtude da celeridade na tramitação inerente ao habeas corpus, tal medida é aquela que de imediato atenderia os interesses em jogo, sendo, portanto, a mais acertada ao caso narrado.

Cumprir destacar que o habeas corpus deveria ter por objetivo o trancamento da ação penal, tendo em vista que o fato praticado ainda não era típico. Além disso, não serão pontuadas as respostas que indicarem duas ou mais medidas jurídicas a serem adotadas, ainda que uma delas seja o habeas corpus, isso porque o comando da questão era claro ao pedir a indicação de apenas uma.

Por fim, no tocante ao item “b”, destaca-se que a situação narrada pelo enunciado representa um constrangimento ilegal a Raquel. Nesse sentido, levando-se em conta o comando da questão, resta evidente que a principal tese jurídica a ser apresentada é aquela calcada no verbete 24 da Súmula Vinculante do STF, segundo a qual não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. Inclusive, dessa forma, vêm entendendo os Tribunais Superiores que, antes do esgotamento da instância administrativa com lançamento do tributo, não pode ser oferecida denúncia pela prática do crime (art. 1.º, incisos I ao IV, da Lei 8.137).

Ressalte-se que a mera indicação do verbete sumular não será pontuada, tampouco a resposta que indicar apenas a atipicidade ou a falta de lançamento definitivo do tributo, sem qualquer outra justificativa ou desenvolvimento. Esclareça-se: o fato praticado por Raquel é atípico porque não houve o efetivo lançamento definitivo do crédito tributário, sendo certo que tal justificativa é essencial para a atribuição dos pontos. De igual modo, o lançamento definitivo do tributo e/ou a necessidade de esgotamento da via administrativa e/ou a falta de justa causa para a propositura da ação penal são teses alegáveis, desde que calcadas no verbete 24 da Súmula Vinculante do STF.

QUESTÃO 4

GABARITO

A questão exige do candidato conhecimento acerca do tema prescrição. O enunciado deixa clara a data de nascimento de Julia, demonstrando que esta era menor de 21 anos na data dos fatos. Entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória foram ultrapassados mais de três anos. A pena privativa de liberdade definitiva aplicada para Julia foi de um ano, que, na forma do art. 109, V, do Código Penal, prescreve em quatro anos. Ocorre que, como Julia era menor de 21 anos na data dos fatos, o prazo prescricional deverá ser contado pela metade, conforme prevê o art. 115 do Código Penal; dois anos, portanto.

Nesse sentido, para fazer jus à pontuação relativa ao item “a”, considerando-se o comando da questão, a tese defensiva a ser alegada para impedir o cumprimento da pena é justamente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória foi ultrapassado o prazo prescricional de dois anos, nos termos anteriormente descritos. Fundamenta-se tal resposta no art. 109, V, c/c art. 115, ambos do

CP.

Ressalte-se que somente poderá ser pontuada a resposta que indicar corretamente a espécie de prescrição incidente ao caso, até porque era esse o objeto da questão.

Todavia, para privilegiar a demonstração de conhecimento jurídico, a Banca pontuará a resposta que não destacar a “prescrição da pretensão punitiva retroativa”, desde que o examinando indique expressamente tratar-se de prescrição da pretensão punitiva e também aponte os marcos interruptivos em que ela se operou, a saber: entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Para ter direito a essa flexibilização, entretanto, o examinando deve atender a ambas as exigências.

De igual modo, a resposta que traga duas ou mais espécies de prescrição (mesmo que uma delas seja a correta), não será pontuada por considerar-se contraditória.

Já no que tange ao item “b”, faz-se necessário à atribuição dos pontos respectivos que o examinando responda que a principal consequência do acolhimento da tese anteriormente esposada é o reconhecimento da extinção da punibilidade de Júlia (art. 107, IV, CP) e que, em decorrência disso, desaparecerão também todos os demais efeitos penais e/ou civis, tais como a reincidência, os maus antecedentes ou mesmo a possibilidade de a condenação funcionar como título executivo no juízo cível.

12.2.15 XVI Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

GABARITO

- a) *A questão narra que Carlos foi condenado pela prática de crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido. Em que pese o crime de tráfico ser equiparado a hediondo, hoje o entendimento que prevalece no âmbito do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é possível a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, sendo a previsão do art. 2.º, § 2.º, da Lei 8.072/1990 inconstitucional, pois violadora do princípio da individualização da pena. Assim, analisando as circunstâncias do caso concreto, nada impede que o magistrado fixe o regime semiaberto ao caso, até porque a pena-base não se afastou do mínimo legal, o que indica que as circunstâncias do art. 59 do CP são favoráveis.*
- b) *Ainda consta do enunciado que o Tribunal de Justiça, em julgamento exclusivo da defesa, optou por realizar uma reclassificação da conduta, aplicando a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343, em vez de manter a condenação pelo crime de posse de arma de fogo. Não poderia, porém, o Tribunal ter adotado essa conduta, pois ela é prejudicial ao réu. Como o recurso foi exclusivo da defesa, a reclassificação viola o princípio da vedação da reformatio in pejus. O prejuízo da nova classificação decorre de alguns fatores: para o cálculo de eventual prescrição, tendo em vista que a causa de aumento é considerada para fixação do prazo prescricional, enquanto que, havendo dois crimes, o prazo seria fixado de maneira separada para cada um; um dos crimes é punido com detenção, o que impede fixação do regime inicial fechado, deixando isso*

de ocorrer com a causa de aumento; na execução, a progressão de regime, no caso da causa de aumento, será calculada em 2/5 (ou 3/5, se reincidente) do total de seis anos, enquanto que, se mantidas as condenações separadas, esse percentual somente seria aplicado sobre a pena de cinco anos, pois sobre um ano seria aplicado o percentual de 1/6, já que a posse de arma de fogo não é crime hediondo.

QUESTÃO 2

GABARITO

- a) Luan foi condenado pela prática de crimes de estupro e atentado violento ao pudor em concurso material. O entendimento que prevalecia antes da edição da Lei 12.015 era a da impossibilidade de aplicação da continuidade delitiva entre essas duas infrações, pois não seriam crimes da mesma espécie. Ocorre que, com a inovação legislativa ocorrida no ano de 2009, a conduta antes prevista no art. 214 do Código Penal passou a ser englobada pela figura típica do art. 213 do CP. Apesar de não ter havido abolitio criminis, certo é que a lei é mais benéfica. Sendo assim, poderá retroagir para atingir situações anteriores e caberá a redução de pena de Luan.

A jurisprudência amplamente majoritária entende que, de acordo com a nova redação, o art. 213 do CP passou a prever um tipo misto alternativo. Assim, quando praticada conjunção carnal e outro ato libidinoso diverso em um mesmo contexto e contra a mesma vítima, haveria crime único. Outros, minoritariamente, entendem que o artigo traz um tipo misto cumulativo, de modo que ainda seria possível punir o agente que pratica conjunção carnal e outro ato libidinoso diverso por dois crimes. De qualquer forma, mesmo para essa segunda corrente, caberia a redução de pena de Luan, pois agora seria possível a aplicação da continuidade delitiva, já que os crimes são de mesma espécie. O examinando poderá adotar qualquer uma das duas correntes, desde que assegure a aplicação da nova lei mais benéfica para Luan.

- b) O órgão competente perante o qual deverá ser formulado o pedido de aplicação da lei mais benigna e, consequentemente, da redução da pena, é o juízo da Vara de Execuções Penais, considerando que já ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória, na forma da Súmula 611 do STF ou do art. 66, I, da LEP.

QUESTÃO 3

GABARITO

- a) O crime praticado por Rubens e Enrico foi o de injúria, na forma do art. 140 do Código Penal. Apesar das ofensas serem relacionadas à pessoa que pratica crimes, já que Eduardo foi chamado de “ladrão” e “estelionatário”, não há que se falar em crime de calúnia. A calúnia exige, para sua configuração, que seja atribuída ao ofendido a prática de determinado fato que configure crime. No caso, porém, não foram atribuídos fatos, mas sim qualidades pejorativas. Em razão disso, o crime praticado foi o de injúria.
- b) O argumento a ser formulado pela defesa é o de que o perdão do ofendido oferecido a um dos

querelados a todos aproveita (art. 51 do CPP), gerando a extinção da punibilidade dos coautores, caso seja aceito (art. 107, V, do CP). Ao conceder perdão para Rubens, necessariamente esse perdão deve ser estendido para Enrico, de modo que, com sua aceitação, haverá extinção da sua punibilidade.

QUESTÃO 4

GABARITO

- a) Considerando que o enunciado narra que foi realizada validamente a prisão em flagrante de Wesley pela prática do crime de receptação simples, a medida processual a ser formulada é o pedido de liberdade provisória, evitando que seja decretada a prisão preventiva do indiciado.*
- b) A representação da autoridade policial não foi elaborada de maneira adequada em relação à sua fundamentação, pois não estão preenchidos os requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal, sendo estes indispensáveis para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. O crime praticado pelo indiciado não tem pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Ademais, não é o acusado reincidente na prática de crime doloso, devendo ser destacado que a existência de ação em curso não afasta a ausência de configuração do inciso II do art. 313. Os requisitos do inciso III também não estão atendidos, sendo incabível a prisão preventiva, independentemente da fundamentação com os pressupostos do art. 312 do CPP.*

12.2.16 XVII Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

GABARITO

- a) Foi imputado um crime de furto qualificado, pois houve rompimento de obstáculo. Ocorre que, para a punição por essa modalidade qualificada do crime, são necessárias a realização de exame de local e a constatação do rompimento de obstáculo por prova pericial (art. 158 do CPP). Assim têm decidido de maneira recorrente os Tribunais Superiores, não sendo suficiente a simples afirmação dos policiais, no sentido de que Rodrigo narrou que tinha subtraído os cigarros, pois essa confirmação foi apenas quanto à subtração, e os agentes da lei nem mesmo compareceram ao estabelecimento para verificar se, de fato, houve tal rompimento. Assim, diante da ausência de comprovação pericial da qualificadora, o crime praticado foi de furto simples.*
- b) Em caso de acolhimento da tese defensiva, com a consequente desclassificação da conduta de Rodrigo de furto qualificado para furto simples, não poderá ser o acusado de imediato condenado, devendo o magistrado abrir vista para que o Ministério Público se manifeste sobre a possibilidade de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, pois a pena mínima passou a ser de um ano de reclusão. Nesse sentido é o enunciado 337 da Súmula do STJ, que permite que, em caso de desclassificação ou procedência parcial, seja oferecida proposta de suspensão condicional do processo, ainda que encerrada a instrução.*

QUESTÃO 2

GABARITO

- a) *Deveria o examinando demonstrar que a prisão preventiva decretada em desfavor de Jorge, com base no art. 313, III, do Código de Processo Penal, não é válida no caso concreto. De início, é possível perceber que os requisitos previstos no art. 313, I e II, do CPP não estão presentes, pois a pena máxima para o crime praticado é inferior a quatro anos e Jorge é primário e de bons antecedentes. Em relação ao inciso III do art. 313, não basta que o crime seja praticado em situação de violência doméstica e familiar contra mulher. Para regularidade da prisão, é preciso que seja aplicada para garantir execução de medida protetiva de urgência. Dessa forma, somente será cabível caso exista uma medida protetiva anteriormente aplicada e descumprida ou, ao menos, que, após aplicação da medida protetiva, exista risco concreto de descumprimento. No caso, de imediato o magistrado, após requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva, sem que houvesse medida protetiva de urgência previamente aplicada. Assim, não foi válida a prisão.*
- b) *Deveria o examinando esclarecer que o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação, nos termos do art. 147, parágrafo único, do Código Penal, de modo que é possível a retratação do direito de representação. Como o crime foi praticado em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, contudo, alguns requisitos são trazidos pela lei de modo a garantir que essa manifestação seja livre de pressões. Tais requisitos são trazidos pelo art. 16 da Lei 11.340/2006, que admite a retratação antes do recebimento da denúncia, desde que realizada em audiência especial, na presença do magistrado, após manifestação do Ministério Público.*

QUESTÃO 3

GABARITO

- a) *A medida processual é exceção de incompetência. Pela narrativa apresentada no enunciado é possível concluir que o crime foi praticado, inclusive consumado, na cidade de Santos. Logo, na forma do art. 70 do Código de Processo Penal, o juízo competente será o da comarca de Santos, e não o de Mogi das Cruzes. Considerando a incompetência territorial existente, deveria o advogado de Antônio formular uma exceção de incompetência, no prazo de defesa, nos termos do art. 108 do Código de Processo Penal.*
- b) *Envolvendo o mérito, deve o examinando expor que, ainda que confessados os fatos, não houve emprego de arma na hipótese, de modo que deveria ser afastada a majorante do art. 157, § 2.º, I, do Código Penal. A hipótese narrada deixa claro que Antônio abordou Ruth e empregou grave ameaça, mas que, em momento algum, utilizou, mencionou ou mostrou a arma que portava quando de sua prisão em flagrante. O argumento de que a faca, por ser arma branca, não é suficiente para o reconhecimento da causa de aumento não é adequado. O que se exigia era a demonstração de que, no caso concreto, não houve efetivo emprego da arma, como exige o dispositivo supramencionado.*

QUESTÃO 4

GABARITO

- a) *O ofendido, por intermédio de um advogado, poderia apresentar recurso de apelação, ainda que não tenha se habilitado, em momento anterior, como assistente de acusação. Prevê o art. 598 do Código de Processo Penal que, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido, ainda que não tenha se habilitado como assistente de acusação, poderá interpor apelação. O prazo será de 15 dias a partir do fim do prazo do Ministério Público. No caso, houve omissão do Ministério Público, então caberá o recurso do ofendido, sendo certo que, diante da sentença absolutória, além da legitimidade, existe interesse recursal. Deve ser esclarecido que não basta o examinando afirmar que deveria Flavio habilitar-se como assistente de acusação, caso esta afirmação não venha acompanhada da possibilidade de interposição de recurso de apelação.*
- b) *No mérito, o examinando deveria demonstrar o equívoco da decisão do magistrado. A hipótese narrada indica que a ingestão de bebida alcoólica foi consciente e intencional, ainda que o resultado embriaguez não tenha sido. Contudo, prevê o art. 28, II, do Código Penal que a embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade penal. Assim, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, poderia afastar a culpabilidade, levando a uma absolvição.*

12.2.17 XVIII Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

GABARITO

- a) *A questão exige do candidato conhecimento do tema da prescrição. Foi narrada, na hipótese, a condenação de Karen por quatro crimes de furto qualificado, sendo de 2 anos a pena definitiva de cada um deles. Reconhecida a continuidade delitiva, a pena final fixada foi de 2 anos e 6 meses de reclusão.*
Prevê o art. 119 do Código Penal que, em caso de concurso de crimes, a análise da prescrição deverá ser feita sobre a pena de cada um dos crimes isoladamente. Assim, no caso, a prescrição deveria considerar a pena aplicada de 2 anos para cada um dos delitos, não de 2 anos e 6 meses. A pena fixada entre 1 e 2 anos prescreverá em 4 anos, na forma do art. 109, V, do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, foram ultrapassados mais de 4 anos; logo, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Diante do exposto, a tese defensiva a ser alegada é a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade retroativa.
- b) *A consequência jurídica do acolhimento da tese é o reconhecimento da extinção da punibilidade de Karen, na forma do art. 107, inciso IV, do Código Penal. Além disso, considerando que a prescrição foi da pretensão punitiva, essa condenação não gerará qualquer efeito, não podendo funcionar como maus antecedentes, reincidência ou título executivo na esfera cível.*

QUESTÃO 2

GABARITO

- a) *A defesa técnica de João poderia requerer a aplicação da lei nova, que é mais benéfica para o acusado. A redação anterior do art. 288, parágrafo único, do CP previa que, no caso de aquele crime ser praticado com armas de fogo, a pena seria dobrada. Hoje, o dispositivo prevê que a pena, nessa mesma hipótese, será “apenas” aumentada de, no máximo, metade. Assim, no caso de João, como sua pena-base foi aplicada em 3 anos, a pena final restaria em, no máximo, 4 anos e 6 meses. A nova lei, então, é favorável ao condenado, de modo que pode retroagir para atingir situações pretéritas, na forma do art. 2.º, parágrafo único, do CP.*
- b) *Considerando que já houve trânsito em julgado da sentença condenatória, o juízo competente para formulação do requerimento é o da Vara de Execuções Penais, na forma do Enunciado 611 da Súmula não vinculante do STF ou do art. 66, inciso I, da LEP.*

QUESTÃO 3

GABARITO

- a) *A decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que o acusado e sua namorada alegaram a existência de legítima defesa. De fato, a namorada da vítima e uma testemunha afirmaram que esta causa excludente da ilicitude não existiu. Contudo, existem duas versões nos autos, com provas em ambos os sentidos, logo os jurados são livres para optar por uma delas, de acordo com a íntima convicção. Não houve arbitrariedade ou total dissociação da prova dos autos, mas apenas escolha de uma das versões. Assim, a soberania dos veredictos deve prevalecer, não cabendo ao Tribunal fazer nova análise do mérito, se a decisão não foi manifestamente contrária as provas produzidas.*
- b) *Não poderá o Tribunal anular o julgamento com base na existência de nulidade ocorrida durante a sessão plenária. De fato, prevê o art. 448, inciso IV, do CPP que estão impedidos de servir no mesmo Conselho os irmãos. Ocorre que o Enunciado 713 da Súmula não vinculante do STF afirma categoricamente que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição”. O Ministério Público apresentou apelação apenas com fundamento na alínea d do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal. Assim, está limitado o efeito devolutivo, de modo que o Tribunal somente poderá analisar a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Decisão em contrário prejudicaria a ampla defesa, pois eventual nulidade não foi combatida pela defesa em sede de contrarrazões. Poderia, ainda, o candidato basear sua resposta no Enunciado 160 da Súmula do STF, que afirma que é nula a decisão que acolhe, contra réu, nulidade não arguida pela acusação.*

QUESTÃO 4

GABARITO

- a) *A medida processual a ser adotada pelo advogado de John é a interposição de recurso de Embargos Infringentes, na forma do art. 609, parágrafo único, do CPP, considerando que a decisão proferida em sede de apelação não foi, em relação à substituição da pena, unânime.*
- b) *Para fazer prevalecer o voto vencido, deverá o examinando demonstrar a possibilidade de ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que foi reconhecido que o acusado é primário, de bons antecedentes e que não se dedica ao crime nem integra organização criminosa. Em que pese o art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006 vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de inconstitucionalidade, entendeu que tal vedação viola o princípio da individualização da pena. Ademais, diante dessa decisão, o Senado Federal editou a Resolução 5, suspendendo a eficácia da parte da redação do art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, que veda a substituição.*

12.2.18 XIX Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

GABARITO

- a) *O recurso cabível da sentença do magistrado que condenou João é o recurso de apelação, cujo prazo de interposição é de 5 dias e o fundamento é o art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.*
- b) *A principal tese jurídica a ser apresentada é o requerimento de absolvição do acusado, pois, em que pese ter havido violação do dever objetivo de cuidado, essa violação não representou incremento do risco no caso concreto, pois, ainda que observada a velocidade máxima prevista para a pista, com respeito ao dever de cuidado, o resultado teria ocorrido da maneira como se deu. Dessa forma, o examinando pode fundamentar o pedido de absolvição com base na ausência de incremento do risco, sendo essa ausência, de acordo com a Teoria da Imputação Objetiva, fundamento para absolvição. De qualquer maneira, o cerne da resposta é a indicação de que não foi a violação do dever de cuidado a responsável pelo resultado lesivo, de modo que não deveria João ser por ele responsabilizado.*

A Banca também considerou como correta a resposta que indicava a inexistência de culpa, apesar da violação do dever objetivo de cuidado, em razão da ausência do elemento previsibilidade, sob a alegação de que João não poderia prever que uma bicicleta atravessaria seu caminho em uma rodovia de tráfego intenso, em local inadequado.

QUESTÃO 2

GABARITO

- a) *Sim, existe medida a ser buscada pelo advogado de Ronaldo para evitar sua punição. Ronaldo foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 2.º da Lei 12.850/2013. Ocorre que o art. 4.º, inciso I, deste mesmo diploma legal prevê o instituto da “colaboração premiada”, que poderá ocorrer*

quando o agente colaborar efetiva e voluntariamente com a investigação, resultando na identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações por eles praticadas. Diante da vontade de Ronaldo de esclarecer sobre quem seriam os demais integrantes da organização criminosa, deveria o seu advogado buscar um acordo de colaboração premiada, sendo certo que algumas das consequências do acordo que podem ser aplicadas pelo juiz é o perdão judicial ou a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

- b) Ainda que o acordo de “delação premiada” seja válido, de maneira adequada estabeleceu o legislador impossibilidade de condenação exclusivamente com base nas declarações do agente colaborador, nos termos do art. 4.º, § 16, da Lei 12.850/2013. Para um decreto condenatório, é necessário que as declarações de Ronaldo sejam confirmadas por outros elementos de prova. Os Tribunais Superiores vêm decidindo que as informações procedentes da “colaboração premiada” precisam ser confirmadas por outros elementos de prova – a chamada prova de corroboração.*

QUESTÃO 3

GABARITO

- a) O examinando deveria alegar que, em relação a Vanessa, o processo é nulo desde a citação. Quando Vanessa foi citada por edital, ela estava presa em estabelecimento na mesma unidade da Federação do juízo processante, logo sua citação foi nula, conforme Enunciado 351 da Súmula de Jurisprudência do STF. Como ela não tomou conhecimento da ação nem mesmo foi interrogada, pois teve sua revelia decretada, o prejuízo é claro. Assim, em sede de apelação, antes de enfrentar o mérito da apelação, deveria o advogado buscar a anulação de todos os atos após sua citação, inclusive da sentença. Poderia, ainda, o candidato justificar a nulidade na exigência trazida pelo art. 360 do CPP, que prevê que o réu preso deve ser citado pessoalmente.*
- b) Vanessa não foi corretamente condenada pela prática do crime de peculato. Em que pese o art. 30 do Código Penal prever que as “circunstâncias” de caráter pessoal se comunicam quando elementares do crime, não é possível, no caso concreto, a aplicação desse dispositivo, porque o enunciado deixa claro que Vanessa não tinha conhecimento da condição de funcionário público de João, não sendo possível responsabilizá-la por peculato. A simples afirmação de que as circunstâncias pessoais não se comunicam é insuficiente para atribuição da pontuação, pois, quando elementares, poderá haver comunicação, desde que o agente tenha conhecimento dessa situação. Da mesma forma, inadequada a afirmativa no sentido de que o particular não pode ser responsabilizado pelo crime próprio de peculato, pois insuficiente.*

QUESTÃO 4

GABARITO

- a) A medida processual a ser apresentada pelo advogado de Carlos é o agravo previsto no art. 197 da Lei 7.210/1984, também conhecido como agravo de execução ou agravo em execução. Prevê o mencionado dispositivo que, das decisões proferidas em sede de execução, será cabível o recurso*

de agravo. No caso, o enunciado deixa claro que houve decisão condenatória com trânsito em julgado e que a decisão a ser combatida foi proferida pelo Juízo da Execução, analisando progressão de regime.

- b) O argumento a ser apresentado pelo advogado de Carlos é o de que a decisão do magistrado foi equivocada, pois não é possível fixar, como condição especial ao regime aberto, o cumprimento de prestação de serviços à comunidade. O art. 115 da LEP prevê expressamente que o magistrado, no momento de fixar o regime aberto, poderá determinar condições especiais, além das obrigatórias e genéricas dispostas nos incisos desse dispositivo. Ocorre que a legislação penal não disciplina quais seriam essas condições especiais, de forma que surgiu a controvérsia sobre a possibilidade de serem fixadas penas substitutivas em atenção a essa previsão. O tema, porém, foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no Enunciado 493 de sua Súmula de Jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade de serem fixadas penas substitutivas (art. 44 do Código Penal) como condições especiais ao regime aberto. A ideia que prevaleceu foi a de que, apesar de ser possível o estabelecimento de condições especiais, estas não podem ser penas previstas no Código Penal, sob pena de bis in idem ou dupla punição.

12.2.19 XX Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

GABARITO

- a) Tratando-se de crime culposo, o fato de a pena ter ficado acomodada em mais de quatro anos, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo certo que o encarceramento deve ser deixado para casos especiais, quando se manifestar extremamente necessário. O art. 44, inciso I, do Código Penal, afirma expressamente que caberá substituição, independente da pena aplicada, se o crime for culposo. No caso, como o fundamento exclusivo do magistrado foi a pena aplicada, é possível afastá-lo e, conseqüentemente, buscar a substituição em sede de recurso.
- b) O fato de o acusado não ter comparecido ao interrogatório, por si só, não justifica o decreto prisional, devendo ser entendida a sua ausência como extensão do direito ao silêncio. Hoje, o interrogatório é tratado pela doutrina e pela jurisprudência não somente como meio de prova, mas também como meio de defesa. Por sua vez, o direito à ampla defesa inclui a defesa técnica e a autodefesa. No exercício da autodefesa, pode o acusado permanecer em silêncio durante seu interrogatório. Da mesma forma, poderá deixar de comparecer ao ato como extensão desse direito, sendo certo que no caso não haveria qualquer prejuízo para a instrução nesta ausência, já que a audiência seria apenas para interrogatório. A prisão, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, reclama fundamentação concreta da necessidade da medida, não podendo ser aplicada como forma de antecipação de pena. A banca examinadora considerou como adequada a alegação do não cabimento da prisão preventiva pelo fato de o crime praticado por Fausto ser culposo, não atendendo, assim, o requisito do art. 313, inc. I, do CPP. A mera alegação, em abstrato, de

ausência dos requisitos da prisão preventiva foi considerada insuficiente, bem como a mera citação do dispositivo legal acima destacado.

QUESTÃO 2

GABARITO

- a) *No caso concreto, a autoridade policial não poderia ter representado pela prisão temporária de Lúcio. De início, deve ser destacado que o crime de receptação, ainda que em sua modalidade qualificada, não está previsto no rol de delitos estabelecido pelo art. 1.º, inciso III, da Lei 7.960/1989. Isso, por si só, já afastaria a possibilidade de ser decretada a prisão temporária. Ademais, os outros requisitos trazidos pelos incisos I e II do art. 1.º do mesmo diploma legal também não estão preenchidos, uma vez que Lúcio possui residência fixa e a medida não se mostra imprescindível para as investigações do inquérito policial. Ressalta-se que a prisão temporária não se confunde com a preventiva, de modo que a fundamentação com base nos arts. 312 e 313 do CPP será considerada insuficiente.*
- b) *O crime praticado por Lúcio foi o de receptação simples e não em sua modalidade qualificada. Prevê art. 180, § 1.º, do Código Penal, que a pena será de três a oito anos, quando o agente “Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime”. A ideia do legislador foi punir mais severamente aquele comerciante que se aproveita de sua profissão para ter um acesso facilitado ou maior facilidade na venda de bens produtos de crimes. Assim, para tipificar a modalidade qualificada, é necessário que a receptação tenha sido praticada pelo agente no exercício de atividade comercial ou industrial. Não basta que o autor seja comerciante. No caso concreto, apesar de comerciante, Lúcio não teve acesso ao celular produto de crime em razão de sua atividade comercial, pois o adquiriu de seu vizinho. Além disso, essa mesma atividade comercial não facilitaria eventual revenda do bem, já que sua intenção foi ficar com o celular para si. Dessa forma, configurado, apenas, o crime de receptação simples.*

QUESTÃO 3

GABARITO

- a) *A tese de direito material a ser alegada pelo advogado de Andy é que, no caso, não poderia ele ter sido punido pela tentativa, tendo em vista que houve desistência voluntária. Prevê o art. 15 do CP que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução responde apenas pelos atos já praticados e não pela tentativa do crime inicialmente pretendido. Isso porque o agente opta por não prosseguir quando pode, ao contrário da tentativa, quando o agente não pode prosseguir por razões alheias à sua vontade. No caso, a execução já tinha sido iniciada, quando Andy empregou fraude. O benefício, porém, não foi obtido, sendo certo que o crime não se consumou pela vontade do próprio agente. Assim, sua conduta se torna atípica e deveria ele ser absolvido.*

- b) *Não há vedação legal, podendo Andy fazer jus ao benefício da suspensão condicional do processo. O crime de estelionato possui pena mínima de um ano, o que está de acordo com as exigências do art. 89 da Lei 9.099/1995. Ademais, prevê o dispositivo que não caberá suspensão se o agente já houver sido condenado ou se responder a outro processo pela prática de crime. Todavia, no caso, Andy havia sido condenado pela prática de contravenção penal, logo não há vedação à concessão do benefício.*

QUESTÃO 4

GABARITO

A questão exige do examinando a diferenciação entre os delitos de racismo e injúria racial.

- a) *Não agiu corretamente a autoridade policial ao indiciar Patrícia pela prática do crime de racismo, tendo em vista que o delito praticado foi de injúria racial, previsto no art. 140, § 3.º, do Código Penal. Enquanto a injúria racial consiste em ofender a honra de alguém valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, o crime de racismo atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça, ainda que a discriminação tenha sido praticada em determinado momento contra apenas uma pessoa. Ao contrário da injúria racial, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. No caso, não houve discriminação de Joana em razão de sua cor. Não foi, em razão de sua cor, Joana proibida de frequentar determinado local ou adotar determinada conduta. Ocorre, por parte de Patrícia, uma ofensa à honra subjetiva de Joana, para tanto valendo-se de elementos referentes à sua cor, de modo que o delito praticado foi de injúria racial.*
- b) *O argumento defensivo é que o crime de injúria racial é de ação penal pública condicionada à representação e que, passados mais de seis meses desde a data do fato e conhecimento da autoria, a vítima não teve interesse em ver a autora criminalizada, de modo que deve ser reconhecida a decadência e, conseqüentemente, o inquérito ser arquivado.*

12.2.20 XX Exame de Ordem Unificado – Reaplicação em Porto Velho/RO – FGV

QUESTÃO 1

GABARITO

- a) *O enunciado narra a prática de um crime de furto simples consumado, praticado por Jorge contra sua tia Marta, com quem ele coabitava. Diante dessa relação de coabitação e parentesco, a ação penal pela prática de tal delito tem natureza de ação pública condicionada à representação. Isso porque o art. 182, inciso III, do Código Penal prevê que somente se procede mediante representação a ação penal pela prática de crime contra o patrimônio em desfavor de tio, com quem o agente coabita. Não houve violência ou grave ameaça e a vítima não era maior de 60 anos, logo inaplicável o art. 183 do Código Penal. Sendo a ação condicionada à representação, e não tendo ocorrido no prazo de seis*

meses, ocorreu a decadência, de modo que a punibilidade de Jorge deve ser extinta (art. 107, inciso IV, do Código Penal).

- b) Não poderia o magistrado condenar o denunciado nos termos da imputação original, pois tal conduta violaria os princípios da ampla defesa e do contraditório, além, do princípio da correlação. Ademais, de acordo com art. 384, § 4.º, do Código de Processo Penal, o juiz ficará adstrito aos termos do aditamento.

QUESTÃO 2

GABARITO

- a) Não é possível a condenação de Livia na hipótese narrada. Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante não foram ouvidos em juízo, logo não foram produzidas provas testemunhais pela acusação sob o crivo do contraditório, sendo certo que o art. 155 do Código de Processo Penal impede que uma condenação seja baseada exclusivamente em elementos informativos produzidos durante o inquérito. Por sua vez, o vídeo, acostado aos autos, deve ser considerado prova ilícita, pois realizado em um interrogatório sem assegurar as garantias constitucionais, quais sejam, a de o preso permanecer em silêncio e estar acompanhado por um advogado. Há quem defenda que a gravação por um dos interlocutores, por si só, não constitui prova ilícita. Ocorre que, no caso concreto, a particularidade é que foi feito um interrogatório sem as garantias constitucionais, o que a jurisprudência tem chamado de “interrogatório sub-reptício”.
- b) Sim, é possível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada pela restritiva de direito. A redação do art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, veda expressamente esta substituição. Ocorre que, em sede de controle difuso de constitucionalidade, o STF considerou tal vedação em abstrato inconstitucional, por violar o princípio da individualização da pena. Em razão disso, o Senado, através da Resolução 05, de 2012, suspendeu a eficácia desta parte do dispositivo. Nada impede, assim, que, avaliando as particularidades do caso concreto, ocorra a substituição. Livia é primária e de bons antecedentes, não tendo praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, logo a substituição é adequada.

QUESTÃO 3

GABARITO

- a) O examinando deve defender que não foi praticado crime contra a honra de funcionário público por parte de João, pois este estava apenas atuando na condição de advogado de Pedro, não ultrapassando os limites daquilo que sua função lhe permite. Em tese, o crime praticado por João seria o de injúria. Ocorre que, nos termos do art. 142, inciso I, do Código Penal, não constitui crime de injúria a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Assim, a conduta de João foi atípica, não configurando a prática de crime contra a honra, pois a possível ofensa praticada foi na discussão da causa, defendendo o interesse de Pedro em juízo.
- b) O examinando deveria manifestar-se pela nulidade do processo a partir do ato ilegal de destituição d

advogado legalmente constituído ou da sentença, pois não poderia o magistrado ter desconstituído de ofício o advogado, sendo uma escolha da parte indicar a defesa técnica de sua confiança. No caso de ser necessário outro defensor, deveria o juiz intimar o acusado para que manifeste seu interesse em constituir outro advogado ou ser assistido pela Defensoria Pública. Na hipótese, a desconstituição de João e a posterior nomeação de Defensor Público para elaborar alegações finais, sem nem mesmo ter conversado com Pedro, prejudicou sua ampla defesa, garantida pelo art. 5.º, inciso LV, da CRFB/1988, razão pela qual deve a sentença ser anulada.

QUESTÃO 4

GABARITO

- a) *Deveria o advogado buscar a absolvição de Maria pelo fato de não ter praticado dolosamente o abandono de incapaz ou, ao menos, a desclassificação para homicídio culposo. O crime de abandono de incapaz somente pode ser praticado de forma dolosa, não admitindo a responsabilização criminal do agente a título de culpa. Na hipótese, de acordo com o texto apresentado, Maria não teve a intenção de abandonar a criança no veículo, tendo, de forma negligente, a esquecido no interior do carro. Dessa forma, não há como ser mantida a condenação pelo crime de abandono de incapaz. O art. 133, § 2.º, do Código Penal, apesar de ser aplicável quando o resultado morte decorrer de culpa, exige que haja dolo na conduta antecedente, qual seja, abandono de incapaz, o que não ocorreu na presente hipótese.*
- b) *Para garantir a liberdade imediata de Maria, o advogado deveria impetrar habeas corpus visando restabelecer a liberdade da ré até o trânsito em julgado da sentença condenatória. A regra geral, que obviamente admite exceções, é a de que o acusado deve apelar na mesma condição em que se encontrava no curso da instrução. Estando solto, apela solto; estando preso e sendo condenado em primeira instância, em especial à pena em regime de cumprimento fechado, poderá ser mantida a prisão. No caso concreto deveria ser combatida a decisão que decreta a prisão preventiva de Maria. Alguns argumentos poderiam ser apresentados pelo examinando. Primeiramente, poderia ele alegar que não houve circunstância fática nova a justificar a decretação da prisão preventiva, que é medida cautelar e não antecipação do cumprimento da pena. Da mesma forma, poderia esclarecer que a motivação pela comoção social é insuficiente, pois não confunde com o risco para a ordem pública, ademais, de acordo com jurisprudência firme dos Tribunais Superiores, comoção social não enseja prisão cautelar. A sentença condenatória não inovou a situação de modo a justificar a alteração do status libertatis. Por fim, poderia o examinando alegar que Maria foi condenada a quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto. A imposição de prisão preventiva, que é medida cautelar, acabaria sendo mais gravosa do que a medida final aplicada, o que violaria o princípio da homogeneidade.*

12.2.21 XXI Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

GABARITO

- a) O(a) examinando(a) deve concluir pela incompetência do Juízo, tendo em vista que o crime praticado não é doloso contra a vida. Nos termos do art. 74, § 1.º, do Código de Processo Penal (ou art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea d, da CRFB), ao Tribunal do Júri cabe apenas o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os conexos. No caso, mesmo de acordo com a imputação contida na denúncia, o resultado de morte foi culposo; logo, a competência é do juízo singular.
- b) O(a) examinando(a) deve defender que não poderia Júlio responder pelo crime de lesão corporal seguida de morte, porque aquele resultado não foi causado a título de dolo nem culpa. O crime de lesão corporal seguida de morte é chamado de preterdoloso. A ação é dirigida à produção de lesão corporal, sendo o resultado morte produzido a título de culpa. Costuma-se dizer que há dolo no antecedente e culpa no consequente. Um dos elementos da culpa é a previsibilidade objetiva, somente devendo alguém ser punido na forma culposa quando o resultado não querido pudesse ser previsto por um homem médio, sendo que a ausência de previsibilidade subjetiva, capacidade do agente, no caso concreto, de prever o resultado, repercute na culpabilidade. Na hipótese, não havia previsibilidade objetiva, o que impede a tipificação do delito de lesão corporal seguida de morte. Também poderia o candidato responder que havia uma concausa preexistente, relativamente independente, desconhecida, impedindo Júlio de responder pelo resultado causado. Em princípio, a concausa relativamente independente preexistente não impede a punição do agente pelo crime consumado. Contudo, deve ela ser conhecida do agente ou ao menos existir possibilidade de conhecimento, sob pena de responsabilidade penal objetiva.

QUESTÃO 2

GABARITO

A questão exige do(a) examinando(a) conhecimento sobre os crimes em espécie previstos na Lei 10.826/2003, bem como sobre a extensão dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Narra o enunciado que Vinícius foi condenado pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, pois tinha o material bélico, devidamente municiado, em seu local de trabalho. Consta, ainda, que o laudo de exame pericial da arma de fogo e das munições apreendidas somente foi juntado após manifestação das partes em alegações finais, tendo o magistrado proferido sentença condenatória de imediato.

- a) Em sede de apelação, deveria o advogado de Vinícius buscar o reconhecimento da nulidade da sentença, tendo em vista que, após manifestação da defesa, houve juntada de laudo de exame de arma de fogo, ou seja, de prova pericial, sem que fosse aberta vista às partes em relação à documentação. O não acesso pela defesa ao laudo de exame pericial violou o princípio da ampla defesa, em sua vertente da defesa técnica, além do próprio princípio do contraditório, já que aquela prova não lhe foi submetida. Assim, deveria a sentença ser anulada, sendo certo que o prejuízo foi constatado com a condenação do réu.
- b) A tese de direito material a ser apresentada pela defesa técnica de Vinícius para buscar uma condenação mais branda é de que o delito praticado pelo réu foi de posse de arma de fogo e não de

porte de arma de fogo, tendo em vista que o agente possuía, em seu local de trabalho, arma de fogo de uso permitido. Prevê o art. 12 da Lei 10.826/2003 que o crime de posse de arma de fogo poderá ocorrer não apenas quando o material bélico estiver na residência do agente, mas também em seu local de trabalho, desde que o agente seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento. No caso, todos os requisitos foram observados, já que a arma estava no local de trabalho de Vinícius, estabelecimento do qual o agente era proprietário e sócio-gerente. Assim, deveria a defesa buscar a desclassificação para o delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

QUESTÃO 3

GABARITO

- a) *A tese jurídica a ser apresentada pela defesa de Paulo para garantir sua absolvição é de insuficiência probatória, já que o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente com base em elementos informativos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Claramente o magistrado considerou apenas os elementos informativos produzidos em sede policial, que não foram submetidos ao princípio do contraditório. O conceito de prova exige o respeito a esse princípio. Os elementos informativos somente podem embasar um decreto condenatório se confirmados por provas produzidas sob o crivo do contraditório. Ademais, não estamos diante de nenhuma das exceções trazidas pelo art. 155, in fine, do CPP. Considerando que a decisão do magistrado baseou-se exclusivamente nas palavras da vítima em sede policial e na confissão do acusado na delegacia, não havendo provas produzidas em juízo, a condenação foi indevida.*
- b) *Em busca da redução da pena aplicada, deveria o(a) advogado(a) de Paulo defender que o aumento da pena-base em razão da ameaça de morte empregada representa violação ao princípio do ne bis in idem, tendo em vista que a grave ameaça constitui elementar do tipo de roubo, e que deveria ser reconhecida a atenuante da confissão, pois, ainda que qualificada, escorou o decreto condenatório do magistrado, nos termos do Enunciado 545 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo, de maneira tranquila, que a confissão qualificada, ou seja, aquela que apresenta causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, apesar de o agente confessar os fatos, é suficiente para o reconhecimento da atenuante.*

QUESTÃO 4

GABARITO

- a) *Sim, existem argumentos a serem apresentados pelo(a) advogado(a) de Diana para evitar o prosseguimento da ação penal. De fato, em princípio, a conduta de Diana se adequa perfeitamente ao previsto no art. 171, § 2.º, inciso VI, do Código Penal, tendo em vista que emitiu cheque sem provisão de fundos. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento, através do Enunciado 554 da Súmula de Jurisprudências, de que o pagamento dos valores após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal; todavia, a contrario sensu, pacificaram a*

jurisprudência e a doutrina a posição de que, se o pagamento do cheque for realizado antes do recebimento da denúncia, haverá obstáculo ao prosseguimento da ação. Alguns foram os fundamentos que justificaram tal posição jurisprudencial, mas trata-se, principalmente, do princípio da intervenção mínima, característica do Direito Penal, e da ideia de que aquele que efetua o pagamento antes do recebimento da denúncia indica a inexistência de dolo de enganar e de obter vantagem ilícita em detrimento alheio. No caso apresentado, Diana efetuou o pagamento do cheque antes de o inquérito ser encaminhado ao Ministério Público com relatório final, logo antes do recebimento da denúncia, de modo que pode ser buscado, inclusive por meio de habeas corpus, o imediato trancamento da ação penal.

- b) *Entende o Supremo Tribunal Federal que o crime de estelionato é delito de natureza material, de modo que estará consumado no momento da recusa de pagamento do cheque sem provisão de fundos pelo sacado. Nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, será competente para processamento e julgamento o foro da comarca onde ocorreu o resultado do crime (Comarca de Santos). Assim, nos termos do Enunciado 521 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o foro competente para processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade de emissão dolosa de cheques sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado”.*

12.2.22 XXII Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

GABARITO

A questão exige do examinando conhecimento sobre os delitos tipificados na Lei 11.343/2006, além dos requisitos para decretação válida de interceptação telefônica.

- a) *A tese de direito processual a ser suscitada para defesa de Cássio para afastar a prova obtida é a invalidade da decisão que determinou a interceptação telefônica de Cássio, tendo em vista que, de início, foi determinada pelo prazo de 30 dias. Inicialmente deve ser destacado que a autoridade policial possui legitimidade para representar pela decretação da interceptação de comunicações telefônicas, nos termos do art. 3.º, inciso I, da Lei 9.296/1996. Ademais, o crime investigado é punido com pena de reclusão e consta do enunciado que a prova não poderia ser obtida por outros meios disponíveis. Todavia, prevê o art. 5.º do mesmo diploma legal que a decisão que concede a medida deverá ser fundamentada e que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual período se comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Diante disso, ainda que possa o período de 15 dias ser renovado, não pode, de início, a autoridade judicial determinar a interceptação por mais de 15 dias, sob pena de nulidade.*
- b) *A tese de direito material a ser alegada para tornar a conduta de Cássio menos gravosa é que foi praticado o delito previsto no art. 33, § 3.º da Lei 11.343/2006, já que o agente oferecia drogas, de maneira eventual, sem objetivo de lucro, para seus amigos para juntos consumirem. Não há, assim, que se falar em prática de tráfico do art. 33 da Lei 11.343/2006 e nem mesmo na aplicação do § 4.º*

do mesmo dispositivo, já que o agente era portador de maus antecedentes.

QUESTÃO 2

GABARITO

- a) *Sim, o advogado de Antônio, já no momento de apresentar resposta à acusação, deveria apresentar exceção de suspeição em face da Promotora de Justiça, tendo em vista a presença da causa de suspeição prevista no art. 254, incisos I e IV, do Código de Processo Penal (CPP). Prevê o dispositivo em questão que o juiz dar-se-á por suspeito quando for amigo íntimo de alguma das partes ou quando tiver aconselhado uma das partes. Carla é muito amiga da genitora da vítima e ainda aconselhou a ofendida e sua família sobre como agir diante do ocorrido. Ademais, o art. 258 do CPP estabelece que as previsões referentes às causas de impedimento e suspeição do magistrado são aplicáveis, no que couber, ao Ministério Público. Claro está o envolvimento de Carla com a causa, de modo que sua suspeição deve ser reconhecida. Considerando que a mesma não se declarou suspeita, oferecendo denúncia, caberia ao advogado apresentar exceção de suspeição, nos termos do art. 95, inciso I, do CPP, e do art. 104 do CPP.*
- b) *A principal alegação defensiva, de mérito, de direito material, é a de que houve erro de tipo por parte denunciado, nos termos do art. 20 do Código Penal, de modo que fica afastado o seu dolo. Diante da situação apresentada, claro está que Antônio não tinha conhecimento que Joana tinha apenas 13 anos de idade, merecendo destaque as partes se conheceram em uma festa de música eletrônica, ocasião em que a ofendida afirmara estar na faculdade, o que, por si só, já afastaria as suspeitas de que fosse menor de 14 anos. Ainda que se entendesse que o erro foi vencível, não poderia Antônio ser responsabilizado, tendo em vista que esse afasta o dolo e não há previsão de responsabilização culposa pelo crime de estupro de vulnerável. No caso, é irrelevante a posição dos Tribunais Superiores no sentido de que o passado sexual da vítima não deve ser analisado, bastando que a mesma tenha, objetivamente, menos de 14 anos de idade. Ocorre que o problema apresentado em nada com esse tema se confunde, já que sequer sabia o réu a idade da vítima, que é uma das elementares do tipo.*

QUESTÃO 3

GABARITO

- a) *Apesar de a contravenção penal causar prejuízo ao patrimônio de autarquia federal, a Justiça Federal não é competente para julgar a infração penal, tendo em vista que o art. 109, inciso IV, da Constituição da República Federativa do Brasil prevê expressamente que a Justiça Federal terá competência para julgar infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União e de suas entidades autárquicas e empresas públicas, excluídas as contravenções penais. Diferente da regra geral, as contravenções penais, ainda que nas circunstâncias do dispositivo acima mencionado, devem ser julgadas perante a Justiça Estadual, no caso, Juizado Especial Criminal Estadual.*

- b) Apesar de Maurício ter iniciado a execução de uma contravenção penal e a mesma não ter se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que, em tese, configura tentativa, que, pela regra do Código Penal, impõe a punição pelo crime pretendido com redução de pena, na hipótese apresentada, a infração penal que não restou consumada foi uma contravenção. Nos termos do previsto no art. 4.º do Decreto-Lei 3.688/1941, não se pune a tentativa de contravenção penal. Assim, no momento em que Maurício não conseguiu consumir o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, sua conduta não é punível.

QUESTÃO 4

GABARITO

- a) A defesa de Marcos deverá formular requerimento de relaxamento da prisão, tendo em vista que não havia situação de flagrante a justificar a formalização do Auto de Prisão em Flagrante. Narra o enunciado que, de fato, Marcos, mediante grave ameaça, inclusive com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu coisas alheias móveis de Diego e Júlio, logo praticou dois crimes de roubo. As vítimas reconheceram o acusado, de modo que há justa causa para o oferecimento de denúncia. Todavia, não havia situação de flagrante a justificar a prisão do acusado. Isso porque o reconhecimento e prisão de Marcos ocorreram mais de sete horas após o fato, sendo certo que não houve perseguição e nem com o agente foram encontrados instrumentos ou produtos do crime. Dessa forma, nenhuma das situações previstas no art. 302 do Código de Processo Penal restou configurada. Em sendo a prisão ilegal, o requerimento a ser formulado é de relaxamento da prisão. Insuficiente, no caso, o examinando apresentar requerimento de liberdade provisória. Primeiro porque, em sendo a prisão ilegal, sequer deveriam ser analisados os pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal nesse momento. Além disso, a princípio, não seria caso de reconhecimento de ausência dos motivos da preventiva, já que foi praticado crime com circunstâncias graves e o agente é triplamente reincidente.
- b) O equívoco a ser alegado em relação à capitulação delitiva refere-se ao concurso de crimes. Sem dúvidas, confirmados os fatos, houve crime de roubo, já que foram subtraídas coisas alheias móveis e houve emprego de grave ameaça, ainda que apenas através de palavras de ordem e emprego de simulacro de arma de fogo. Da mesma forma, dois foram os crimes patrimoniais praticados. Isso porque dois patrimônios foram atingidos e presente o elemento subjetivo, tendo em vista que Marcos sabia que estava subtraindo pertences de duas pessoas diversas. Todavia, com uma só ação, mediante uma ameaça, foram subtraídos bens de dois patrimônios diferentes. Assim, deverá ser reconhecido o concurso formal de delitos, aplicando-se a regra da exasperação da pena, e não o concurso material, com aplicação do cúmulo material de sanções.

12.2.23 XXIII Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

GABARITO

- a) *A defesa deveria alegar que a prova obtida a partir da apreensão da faca é ilícita, não podendo ser valorada no momento da sentença. Estabelece o art. 5.º, inciso XI, da CRFB/1988 que a casa é asilo inviolável, não podendo nela ninguém ingressar sem consentimento do morador. A própria Constituição, todavia, traz exceções a esta regra, como na hipótese de flagrante delito ou mediante ordem judicial, durante o dia. Não havia, no caso apresentado, situação de flagrante delito, já que a simples posse de faca não configura crime e, em relação ao crime/ato infracional praticado no dia anterior, não havia situação de flagrância, pois ausentes os requisitos do art. 302 do CPP. Ademais, não houve autorização do morador e nem existia ordem judicial de busca e apreensão, já que os policiais decidiram ingressar no imóvel porque viram a arma suja de sangue através da janela aberta.*
- b) *Sim, existe, tendo em vista que José Barbosa não poderia ser denunciado pela prática de crime de homicídio qualificado, já que era inimputável na data dos fatos. O Código Penal, para definir o momento do crime, adota a Teoria da Atividade, prevendo o art. 4.º que se considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que em outro seja produzido o resultado. Dessa forma, o crime foi praticado no dia 7 de março de 2016, quando José Barbosa tinha 17 anos. Estabelece o art. 27 do CP que será inimputável o menor de 18 anos. O fato de a consumação do delito só ter ocorrido após a maioridade penal de José Barbosa é irrelevante para o caso concreto, já que outro foi o momento da ação.*

QUESTÃO 2

GABARITO

- a) *Narra o enunciado que Gabriel cumpria pena privativa de liberdade pela prática de crime de porte de arma de fogo, quando obteve livramento condicional. No curso do livramento condicional, todavia, vem a ser condenado pela prática de crime de roubo, tendo o magistrado da execução decidido pela revogação do benefício e também por desconsiderar o período de pena cumprido em livramento. Da decisão proferida pelo juízo da execução cabe Agravo em Execução, na forma do art. 197 da Lei de Execuções Penais, com prazo de interposição de cinco dias. Não há previsão expressa em lei sobre o procedimento a ser adotado no recurso de agravo, de modo que pacificou a doutrina e a jurisprudência que o processamento a ser adotado é semelhante ao do recurso em sentido estrito. Diante disso, cabível o juízo de retratação pelo magistrado competente para execução.*
- b) *O argumento a ser apresentado pela defesa de Gabriel é que não poderiam ter sido desconsiderados os dias de livramento condicional como pena cumprida. De fato, Gabriel foi condenado, definitivamente, pela prática de crime no curso do livramento condicional, logo cabível a revogação do benefício. Trata-se, inclusive, de hipótese de revogação obrigatória. Ocorre que a condenação que justificou a revogação foi em razão da prática de delito anterior à obtenção do benefício, e não de novo crime praticado no curso do livramento. Dessa forma, as condições do livramento condicional vinham sendo regularmente cumpridas pelo apenado, de modo que os dias em que ficou em livramento deverão ser computados como pena cumprida e não desconsiderados. Assim,*

errou o magistrado ao afirmar que deveria Gabriel cumprir um ano e seis meses de pena, desconsiderando os seis meses cumpridos de livramento. Nos termos do aqui exposto estão as previsões dos art. 86 e do art. 88, ambos do Código Penal.

QUESTÃO 3

GABARITO

- a) *Sim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a revogação do benefício da transação penal, com posterior oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, caso as condições impostas venham a ser descumpridas, nos termos do Enunciado 35 da Súmula Vinculante do STF. Durante muito tempo se controverteu sobre as consequências do descumprimento das condições impostas quando da transação penal, alguns defendendo que apenas seria cabível a execução das mesmas, pois, uma vez homologada, haveria imediata extinção da punibilidade, enquanto outros admitiam a revogação do benefício, que estaria condicionado ao cumprimento das imposições. O STF, diante da controvérsia, pacificou o entendimento, por meio de enunciado vinculante, entendendo que a decisão homologatória de transação penal, nos termos do art. 76 da Lei 9.099/1995, não faz coisa julgada material, de modo que, descumpridas suas cláusulas, a situação anterior deve ser retomada, inclusive possibilitando ao Ministério Público o oferecimento de denúncia.*
- b) *Embora, literalmente, os fatos praticados por Cláudio se adequem à figura típica descrita no art. 154-A do Código Penal, não é possível a responsabilização penal do autor pelo crime em questão, tendo em vista que os fatos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei 12.737/2012, de modo que não pode uma lei mais grave ao acusado retroagir para prejudicá-lo. O princípio da legalidade impõe que não é possível a punição de qualquer pessoa por fato que a lei não define como crime no momento de sua ocorrência. Como consequência desse princípio, estabeleceu o art. 5.º, inciso XL, da CRFB/1988 que a lei não retroagirá, salvo para favorecer o réu. No mesmo sentido as previsões do art. 1.º do Código Penal. Assim, diante da irretroatividade da lei penal desfavorável, considerando que os fatos ocorreram em 29 de dezembro de 2011 e a Lei que introduziu o art. 154-A no Código Penal somente foi editada no ano de 2012, incabível a punição de Cláudio pelo delito em questão, ainda que a denúncia seja em momento posterior.*

QUESTÃO 4

GABARITO

- a) *A capitulação delitiva realizada pelo Ministério Público não está integralmente correta, pois, em que pese exista prova da materialidade e indícios de autoria em relação ao crime de homicídio culposo, não poderia ter sido imputada a causa de aumento prevista no art. 121, § 4.º, do CP, tendo em vista que a idade da vítima somente é relevante, no momento de analisar tal causa de aumento, quando o homicídio é de natureza dolosa. Assim, deveria ser afastada a causa de aumento imputada.*
- b) *O argumento a ser apresentado pela defesa técnica é da aplicação do perdão judicial, devendo o juiz*

deixar de aplicar a pena. De acordo com o art. 121, § 5.º, do CP, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências de a infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção se torne desnecessária. De fato, pelas circunstâncias narradas no enunciado, houve crime de homicídio culposo, já que Manoel conduzia sua bicicleta em alta velocidade, com o filho de dois anos no colo, sem observância do dever objetivo de cuidado. Todavia, seu comportamento causou a morte de seu próprio filho, o que, por si só, demonstra que as consequências da infração já foram graves o suficiente para o autor do fato, tornando a sanção penal efetivamente desnecessária.

12.2.24 XXIV Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

- a) Deveria o advogado de Arnaldo buscar sua absolvição em razão da ausência de prova da materialidade, tendo em vista que o crime deixou vestígios e não consta dos autos exame pericial. Não foi acostado boletim de atendimento médico ou exame de corpo de delito, direto ou indireto, de Severino, que sequer foi ouvido em juízo para confirmar as lesões. As testemunhas ouvidas, em que pese tenham confirmado que Arnaldo desferiu um soco na vítima, também não foram capazes de assegurar a existência de lesão corporal. Por fim, o art. 158 do Código de Processo Penal prevê expressamente que, quando a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, não o suprimindo a confissão do acusado.*
- b) Sim, existe o benefício da suspensão condicional da pena, previsto no art. 77 do Código Penal, em especial em seu § 2.º, no caso concreto. Caso mantida a condenação e a pena aplicada, Arnaldo não poderia ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que o crime foi praticado mediante violência, não atendendo ao disposto no art. 44 do Código Penal. Nada impede, porém, que seja buscada a suspensão condicional da pena, tendo em vista que todos os requisitos estão preenchidos. A regra, de acordo com o Código Penal, é que a pena aplicada em até dois anos, respeitados os demais requisitos, possa ter sua execução suspensa. Todavia, Arnaldo era maior de 70 anos na data dos fatos, o que permite a aplicação do art. 77, § 2.º, do CP, também conhecido como sursis etário, que traz como requisito objetivo a aplicação de pena privativa de liberdade em até quatro anos e não apenas de dois anos.*

QUESTÃO 2

- a) Sim, existe. A medida judicial a ser apresentada em favor de Túlio é a ação de impugnação conhecida como Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, inciso II ou inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, após a sentença condenatória com trânsito em julgado, foi verificado que o documento de identificação de Maria era ideologicamente falso, já que constava data nascimento diferente da real. A mudança na data de nascimento de Maria altera o fundamento para condenação, tendo em vista que, na realidade, era maior de 14 anos na data dos fatos. O examinando pode, ainda, defender o cabimento do instituto da revisão criminal com base no surgimento de provas novas, após a sentença, que comprovem a inocência do acusado, quais*

sejam as fotografias e declarações dos pais no sentido de que a certidão de nascimento da filha era falsa e que, na verdade, Maria era maior de 14 anos na data dos fatos.

- b) O argumento a ser apresentado é de atipicidade da conduta praticada por Túlio, tendo em vista que Maria era maior de 14 anos na data dos fatos. O art. 217-A do Código Penal prevê o crime de estupro de vulnerável, sendo uma de suas hipóteses quando o agente pratica conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com menor de 14 anos. Mesmo que Túlio acreditasse que Maria era menor de 14 anos, objetivamente ela não o era, uma vez que nasceu em 9 de julho de 2000. Provado que seu nascimento ocorreu mais de 14 anos antes dos fatos, necessária a absolvição de Túlio em razão da atipicidade da conduta. Importante destacar que os atos sexuais praticados foram consentidos por Maria, logo não há que se falar em crime de estupro do art. 213 do Código Penal.

QUESTÃO 3

A questão exige do candidato conhecimento sobre as previsões da Lei 12.850/2013. Durante muito tempo a doutrina e a jurisprudência controverteram sobre o conceito do crime de organização criminosa, definição esta que não era trazida diretamente pela legislação brasileira. Superando a controvérsia, a Lei 12.850/2013, conhecida como Lei de Organizações Criminosas, trouxe o conceito de organização criminosa em seu art. 1.º, § 1.º. Da mesma forma, a Lei 12.850/2013 trouxe uma série de instrumentos de investigação e obtenção de meios de prova.

- a) A infiltração de agentes determinada pela autoridade policial não foi válida, pois não houve autorização judicial e porque havia outros meios de investigação para obtenção de provas, como o próprio enunciado demonstra. O art. 3.º da Lei 12.850/2013 prevê como meio de obtenção de prova a infiltração, por policial, em atividade de investigação, na forma do art. 11 do mesmo diploma legal. Ocorre que os arts. 10 e 11 trazem uma série de requisitos para a validade desse meio de obtenção de prova. A infiltração de agentes deverá ser precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, autorização essa que não ocorreu no caso apresentado. Ademais, além dos indícios da prática do crime de organização criminosa, necessário que as provas não possam ser obtidas por outros meios. Na hipótese apresentada, as provas poderiam ser obtidas de outra forma, tanto que assim efetivamente o foram. Diante disso, a infiltração de agentes não foi válida.
- b) A defesa deveria buscar a não condenação dos denunciados pelo fato de o crime imputado não ter sido praticado, já que não estão presentes todas as elementares do tipo. Isso porque o art. 2.º da Lei 12.850/2013 estabelece que é crime promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa. Já o art. 1.º, § 1.º do mesmo diploma traz o conceito de organização criminosa, definindo que seria a associação de quatro ou mais pessoas (requisito atendido), estruturalmente organizada e com divisão de tarefas, ainda que informal (requisito atendido), com objetivo de obter vantagem de qualquer natureza (requisito atendido), mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de caráter internacional (requisito não atendido). O grupo de denunciados se organizou para prática de crimes de receptação simples, cuja pena máxima não ultrapassa quatro anos. Assim, a conduta praticada não se adequa ao tipo imputado.

QUESTÃO 4

- a) *A defesa de Pablo deverá formular pedido de liberdade provisória, tendo em vista que, apesar de ostentar diversas condenações pela prática de crimes graves, na situação apresentada, com base nas informações constantes do auto de prisão em flagrante, poderá o juiz verificar que Pablo agiu amparado por causa excludente da ilicitude, de modo que poderá conceder liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, conforme previsão do artigo 310, parágrafo único, do CPP.*
- b) *O argumento de direito material a ser apresentado é que Pablo deverá ser absolvido do crime imputado porque agiu amparado por estado de necessidade, que é causa excludente da ilicitude. Todos os requisitos estabelecidos pelo art. 24 do CP estão preenchidos, tendo em vista que havia situação de perigo atual ao seu filho, não provocada por Pablo, e não tinha ele outra maneira de agir para proteção, tendo em vista que o cão adotava comportamento agressivo e tentava atacar a criança. Além disso, em que pese a relevância da vida de um cachorro para o seu dono, o sacrifício da vida de uma criança não era razoável exigir nas circunstâncias do caso concreto. Não há que se falar em legítima defesa, porém, pois esta pressupõe injusta agressão, o que, por sua vez, somente se configura com um comportamento humano.*

12.2.25 XXV Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

- a) *O argumento a ser apresentado pela defesa de Bruna é que sua conduta, em tese, poderia configurar ato infracional, mas não crime sob o ponto de vista técnico, já que inimputável na data dos fatos. Inicialmente, importante recordar que, de acordo com a teoria majoritária, três são os elementos do conceito analítico do crime: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Por sua vez, a culpabilidade é formada pelos elementos imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial conhecimento da ilicitude. Prevê o art. 27 do Código Penal que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Diante disso, Bruna, menor de 18 anos na data dos fatos, não pratica crime, mas tão só ato infracional. Isso porque o art. 4.º do Código Penal estabelece que se considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. No momento dos golpes desferidos por Julia e Bruna em Maria, com intenção de matar, Bruna era menor de 18 anos, logo inimputável, ainda que, quando do resultado morte, já fosse maior.*
- b) *O requerimento a ser formulado é de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso IV, do CPP. O Código de Processo Penal prevê, desde a Lei n.º 12.403/11, a prisão domiciliar em substituição a prisão provisória, não sendo mais restrita à fase de execução da pena. Já com a Lei n.º 13.257/16, passou o CPP a prever, no art. 318, inciso IV, a possibilidade de requerimento de substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a presa for gestante, não mais havendo limitação do período de gestação. Basta a condição de gestante de acordo com a lei. Assim, considerando que Julia estava grávida de 20 semanas, cabível o requerimento. Ressalte-se que argumentações no sentido de revogação da prisão pela ausência de fundamentos dos arts. 312 e 313 do CPP não serão aceitas, tendo em vista que o próprio comando da questão deixa claro o preenchimento delas.*

QUESTÃO 2

- a) *A medida a ser adotada pela família de Clara e seus advogados é a apresentação de queixa substitutiva da denúncia, dando início à ação penal privada subsidiária da pública. Sem dúvida, o crime a ser imputado a João é de ação penal pública incondicionada, de modo que, em princípio, caberia ao Ministério Público oferecer denúncia. Todavia, de acordo com o que consta do enunciado, houve omissão por parte do Ministério Público, tendo em vista que recebido o inquérito com relatório final de indiciamento de João, o Parquet se manteve inerte, não oferecendo denúncia, requerendo o arquivamento ou solicitando diligências. Assim, diante da omissão do Ministério Público, será admitida ação privada subsidiária da pública, nos termos do art. 29 do Código de Processo Penal e art. 5.º, inciso LIX, da CRFB/88, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva.*
- b) *O crime a ser imputado a João é de extorsão mediante sequestro qualificada, nos termos do art. 159 § 1.º, do Código Penal, tendo em vista que João sequestrou Clara, criança de 11 anos, restringindo sua liberdade, com a clara intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem econômica indevida como condição para o resgate.*

QUESTÃO 3

- a) *O argumento a ser apresentado pela defesa técnica de Carlos é no sentido de que a prática de falta grave não gera o reinício do prazo de contagem do livramento condicional. Narra o enunciado que Carlos, quando do cumprimento da sua pena, praticou falta grave no interior do estabelecimento penitenciário. De acordo com o art. 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/84, a prática de falta grave enseja à regressão de regime. Todavia, a Lei de Execução Penal não prevê como consequência da prática de falta grave o reinício do prazo para obtenção do livramento condicional, sendo certo que a execução penal também está sujeita ao princípio da legalidade. Dessa forma, equivocada a decisão do magistrado de determinar a interrupção do prazo para obtenção de livramento condicional, nos termos da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça.*
- b) *Sem prejuízo, a defesa técnica de Carlos, de imediato, por meio de Habeas Corpus, poderia buscar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória para evitar a execução do restante da pena privativa de liberdade. Isso porque o prazo da prescrição da pretensão executória, quando há início do cumprimento da pena, inicia-se quando da interrupção deste cumprimento, conforme art. 112, II, CP, que ocorreu em 10/03/2015.*

QUESTÃO 4

- a) *O recurso cabível da decisão de pronúncia é o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, inciso IV, do CPP. Em relação ao argumento de direito processual, deveria o candidato alegar que houve nulidade durante a instrução probatória, tendo em vista que o magistrado formulou diretamente perguntas às testemunhas, sendo que o Código de Processo Penal prevê o sistema de cross examination para oitiva das testemunhas, cabendo as partes formularem as perguntas diretamente para as testemunhas, podendo ser complementados pelo magistrado, na forma dos*

arts. 411 e 212, ambos do CPP. No caso, o magistrado formulou diretamente as perguntas, não oportunizou às partes a complementação e houve devida impugnação em momento adequado. A conduta do juiz configura cerceamento de defesa, de modo que devem ser anulados todos os atos desde a instrução.

- b) *Em relação ao argumento de direito material, deveria a defesa de Vitor questionar a capitulação jurídica realizada pelo Ministério Público. De fato, Vitor, ao efetuar disparos de arma de fogo contra José, em direção ao seu peito, tinha a intenção de matá-lo, como o enunciado deixa claro. Todavia, os disparos de Vitor não foram suficientes para causar a morte de seu inimigo por circunstâncias alheias à sua vontade, já que os projéteis atingiram a perna de José. José recebeu atendimento médico e já estava no quarto com curativos. Posteriormente, José veio a ser mordido por escorpião, sendo que o veneno do animal causou, exclusivamente, sua morte. Certo é que José só estava no hospital em razão dos disparos de Vitor, mas houve causa superveniente, relativamente independente, que por si só causou a morte de José. Diante disso, o resultado fica afastado, mas responde Vitor pelos atos já praticados, conforme previsão do art. 13, § 1.º, do Código Penal. Assim, por mais que José tenha falecido, Vitor deveria responder pelo crime de tentativa de homicídio.*

12.2.26 XXVI Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

- a) *O argumento de direito processual a ser apresentado em sede de recurso é que o mandado de busca e apreensão que justificou a realização de diligência na residência de Gabriel é inválido, tendo em vista que genérico. O mandado de busca e apreensão em determinada residência, por ser uma restrição aos direitos fundamentais da inviolabilidade de domicílio, trazidos pelo art. 5.º, inciso XI, da CRFB/88, e da privacidade deve ser determinado e amparado em fundadas razões no envolvimento com ilícito. No caso, o mandado foi genérico, sem indicar o endereço exato onde deveria ser cumprido, apesar de as residências do condomínio serem separadas e identificadas. Por essas mesmas razões, houve violação, ainda, da previsão do art. 243, inciso I, do CPP, que diz que no mandado deve ser indicada o mais precisamente possível a casa onde será realizada a diligência.*
- b) *Ainda que diante do descumprimento da medida de prestação de serviços à comunidade, não poder ser convertida esta em pena privativa de liberdade. Desde a Lei 11.343/2006, o crime de posse de material entorpecente para consumo próprio deixou de ser punido com pena privativa de liberdade, apesar de prevalecer o entendimento de que a conduta não deixou de ser considerada crime. De acordo com o art. 28, inciso II, da Lei 11.343/2006, uma das sanções que pode ser imposta em caso de condenação é a prestação de serviços à comunidade, podendo esta ser fixada pelo prazo de 10 meses em razão da reincidência. Em que pese a prestação de serviços à comunidade ser pena restritiva de direitos de acordo com o Código Penal, o que, em tese, admitiria a conversão em pena privativa de liberdade diante de descumprimento, o tratamento trazido pela Lei 11.343/2006 é peculiar. Estabelece o art. 28, § 6.º, da Lei 11.343/2006 que, em caso de descumprimento da medida imposta em sentença, em busca de sua execução, pode ser aplicada multa ou*

admoestação verbal, permanecendo, porém, a vedação na imposição de sanção penal privativa de liberdade, tendo em vista que a prestação de serviços à comunidade não foi aplicada como pena substitutiva da privativa de liberdade como ocorre no Código Penal.

QUESTÃO 2

- a) A defesa de Roberto poderia buscar a restituição do bem apreendido, tendo em vista que não tem qualquer relação com o fato, logo não interessa ao processo (art. 118 do CPP). Ademais, há nota fiscal a demonstrar a propriedade do bem, logo o pedido de restituição poderia ser formulado diretamente nos autos aos magistrado, já que não há controvérsia sobre o propriedade do bem (art. 120 do CPP). Da mesma forma, o celular de Roberto não é produto nem instrumento do crime, não havendo qualquer vedação em sua restituição (art. 119 do CPP).*
- b) Ainda que confessados os fatos, existe argumento de direito material para buscar evitar a condenação do crime de roubo. Em que pese Pedro tenha sido vítima de violência e, também, tenha tido seu celular subtraído, não há falar em crime de roubo por parte de Roberto. Isso porque a violência empregada não foi com o objetivo de subtrair coisa alheia móvel, como exige o art. 157 do Código Penal. Pelo contrário, Arthur, Adriano e Junior queriam praticar crime de lesão corporal. Por sua vez, Roberto subtraiu o celular que caiu do bolso de Pedro, não se utilizando, porém, de grave ameaça ou violência para subtrair a coisa. Tanto é assim que Roberto não tinha vínculo com os agentes quando dá prática dos atos de violência, apenas se aproveitando da facilidade na subtração gerada pela situação. Logo, deve ser afastada a prática delitiva do crime de roubo majorado, ainda que reste a possibilidade de desclassificação e condenação pelo crime de furto.*

QUESTÃO 3

- A questão narra que Breno foi denunciado pela prática do crime de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio consumado, crime este previsto no art. 122 do CP. Inicialmente, o delito está previsto no rol de crimes contra a vida, de modo que, em sendo doloso, deve ser julgado pelo Tribunal do Júri.*
- a) O procedimento observado durante a ação penal em desfavor de Breno não foi adequado, tendo em vista que consta do enunciado que foi observado o procedimento comum ordinário. Ocorre que, conforme já destacado, o crime previsto no art. 122 do CP é crime doloso contra a vida, logo de competência do Tribunal do Júri, devendo ser observado o procedimento especial previsto nos arts. 406 e seguintes do CPP. Aplica-se, ao caso, o art. 394, § 3.º, do CPP, e não o art. 394, § 1.º, do mesmo diploma legal.*
 - b) Para questionar a capitulação delitiva realizada pelo Ministério Público, a defesa deveria argumentar que a conduta de Breno não é punível. Isso porque o art. 122 do CP somente prevê a punição no caso de o resultado morte se consumir ou se forem causadas lesões graves. Caso sejam causadas apenas lesões de natureza leve, ainda que tenha havido instigação ao suicídio, a conduta não será punível por opção do legislador, sequer havendo falar em tentativa na hipótese.*

QUESTÃO 4

- a) *O recurso cabível da decisão de rejeição da queixa-crime é o recurso de apelação, com prazo de 10 dias, conforme previsão do art. 82 da Lei n.º 9.099/95. O advogado de Renata apresentou queixa-crime em face de Larissa pela prática do crime de dano simples, delito esse de menor potencial ofensivo, logo aplicáveis as previsões da Lei n.º 9.099/95. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa, como regra, caberá recurso em sentido estrito, no prazo de 5 dias, conforme o art. 581, inciso I, do CPP. Todavia, o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais prevê peculiaridades que o afasta do procedimento comum ordinário do CPP. De acordo com o art. 82 da Lei n.º 9.099/95, da sentença e da decisão de rejeição de denúncia ou queixa caberá recurso de apelação, sempre com o prazo de 10 dias.*
- b) *O argumento para combater a decisão do magistrado é o de que a contagem do prazo decadencial somente se inicia na data do conhecimento da autoria do crime e não necessariamente na data dos fatos. Sendo crime de ação penal privada, o dano está sujeito ao prazo decadencial de 6 meses previsto no art. 38 do CPP. Ocorre que este dispositivo estabelece que tal prazo somente se iniciará no dia em que o ofendido vier a saber quem é o autor do crime e não na data dos fatos. Na situação apresentada, Renata somente tomou conhecimento da autoria em 23 de outubro de 2017, de modo que nesse dia o prazo se iniciou, e não em 20 de julho de 2017. Dessa forma, não há falar em decadência.*

12.2.27 XXVII Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

- a) *O argumento de direito processual é que houve nulidade da sentença em razão da existência de cerceamento de defesa, uma vez que a testemunha Carla poderia ter sido ouvida pelo magistrado. Primeiramente ressalta-se que Carla é classificada pela doutrina como testemunha referida, tendo em vista que somente se teve conhecimento dela e de que esta presenciou os fatos quando da oitiva da vítima em juízo. O art. 209 do CPP menciona a possibilidade de oitiva das testemunhas referidas. Ademais, o art. 401, § 1.º, do CPP estabelece que as testemunhas referidas, assim como as que não prestem compromisso, não serão computadas no número máximo de 8 testemunhas a serem ouvidas. Dessa forma, a decisão do magistrado, que reconheceu a conveniência da oitiva, mas a indeferiu apenas por já ter atingido a defesa o limite máximo de testemunhas, foi equivocada e gerou um cerceamento no exercício do direito de defesa, precisando ser ressaltado que o advogado manifestou de imediato seu inconformismo com a decisão. A alegação em abstrato no sentido de que o magistrado poderia ouvir testemunhas para além das arroladas não foi considerada suficiente pela Banca, tendo em vista que não combate o argumento do juiz no sentido de que as testemunhas referidas estariam abrangidas pelo limite máximo de testemunhas estabelecido no procedimento comum ordinário.*
- b) *O argumento de direito material em busca da redução da sanção aplicada é o de que o aumento realizado na terceira fase de aplicação da pena deveria ser do mínimo legal, ou seja, de 1/3, uma vez que não foi apresentada fundamentação razoável para aumento acima do mínimo. Certo é que a mera indicação do número de major antes – fundamento este exclusivo utilizado pelo magistrado –*

é considerada insuficiente para justificar o aumento acima do mínimo, nos termos da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, diante da ausência de fundamentação para o aumento de 3/8, o aumento deveria ser da fração mínima de 1/3.

Não será considerado suficiente pela Banca a afirmativa de não aplicação das causas de aumento pelo fato de o coautor não ser identificado.

QUESTÃO 2

- a) *O argumento de direito processual a ser apresentado é o de que houve violação ao princípio da correlação, o que gera a nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa e ao princípio do contraditório. Isso porque a denúncia narrou que Lucas guardava, em seu local de trabalho, duas armas de fogo de calibre restrito. Sem que houvesse aditamento da denúncia, o magistrado condenou o réu pela prática de dois crimes de posse de arma de fogo de numeração suprimida, previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003. Apesar do crime imputado na denúncia e o reconhecido na sentença estarem previstos no mesmo dispositivo legal, eles não se confundem e a narrativa dos fatos é diferente. O réu somente se defendeu sobre as armas apreendidas como de uso restrito, não podendo, então, o magistrado modificar os fatos para dar nova capitulação jurídica, nos termos do art. 384 do CPP. Se não houvesse alteração dos fatos, poderia o juiz aplicar o art. 383 do CPP, mas não foi isso que ocorreu na hipótese narrada. Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade da sentença.*
- b) *Em busca de questionar o mérito da decisão, o advogado deveria argumentar que a conduta de Lucas de guardar, em seu local de trabalho, duas armas de fogo com numeração suprimida configura crime único previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, e não dois crimes autônomos, seja em concurso material ou formal. As armas estavam sendo guardadas em um mesmo contexto, logo a violação ao bem jurídico protegido foi única, podendo, porém, a quantidade de armas ser considerada no momento da aplicação da pena.*

QUESTÃO 3

- a) *A delação foi realizada de maneira inadequada sob o aspecto formal, podendo o novo advogado de Francisco buscar desconstituí-la. De acordo com o art. 4.º, § 6.º, da Lei n.º 12.850/2013, o juiz não participará do acordo de delação premiada. Em que pese o magistrado sempre deva assegurar o respeito ao direito dos envolvidos e a paridade de armas, fato é que nas negociações do acordo de colaboração o juiz deve se manter inerte, cabendo apenas a ele homologar o acordo caso tenham sido observadas as formalidades legais. No momento em que o magistrado participou das negociações, a ilegalidade do acordo restou configurada, podendo ser este desconstituído.*
- b) *O argumento de direito material em busca de questionar a capitulação jurídica e, conseqüentemente, da absolvição, é o de que apesar de o crime envolver 5 agentes e haver plena divisão de tarefas, a reunião e comunhão de esforços era voltada para a prática de um crime específico, e não de vários delitos, não havendo estabilidade e permanência a justificar a imputação do crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013. Para a configuração do crime imputado, não basta a reunião com a intenção de*

praticar um crime específico, como consta do enunciado. Ainda que apenas um delito tenha sido praticado, a intenção do grupo deve ser a prática de CRIMES (no plural), e não uma infração penal em comunhão de ações e desígnios. A mera alegação em abstrato de que os requisitos do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 não foram preenchidos, sem enfrentar especificamente a pluralidade de crimes ou a exigência de estabilidade/permanência, não será considerada suficiente para a atribuição de pontos.

QUESTÃO 4

- a) *A questão narra que Maria foi pronunciada pela suposta prática de crime de homicídio qualificado, sendo que, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, entendeu o magistrado por pronunciar Maria nos termos da denúncia. Da decisão de pronuncia caberá recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inciso IV, do CPP. Caso a decisão proferida pelo magistrado fosse de impronúncia, não haveria falar em recurso em sentido estrito. Antes da edição da Lei 11.689/2008, a decisão de impronúncia também era combatida mediante recurso em sentido estrito. Todavia, houve alteração legislativa e, desde então, da decisão de impronúncia, por ser terminativa, caberá recurso de apelação, assim como ocorreria na absolvição sumária, conforme previsão do art. 416 do CPP.*
- b) *A tese de direito material seria a de que Maria agiu em legítima defesa putativa, nos termos do art. 21, § 1.º, do Código Penal (erro de tipo permissivo), tendo em vista que acreditava estar atuando em legítima defesa. Isso porque Clara havia ameaçado Maria de morte caso esta realizasse um xingamento, o que foi feito por Maria. Ainda que diante de eventual injúria, se verídica, a conduta de Clara de efetuar disparo de arma de fogo configuraria uma injusta agressão, pois, no mínimo, haveria excesso em sua conduta. Caso, de fato, Clara tivesse pego, em sua bolsa, sua arma de fogo, configurada estaria a legítima defesa e, conseqüentemente, a conduta de Maria seria legítima. Todavia, na verdade Maria supôs situação que não existia, já que Clara apenas pegou seu celular para realizar uma ligação. Diante disso, a atuação em legítima defesa foi apenas putativa.*

12.2.28 XXVIII Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

A questão exige do examinando conhecimento sobre os princípios aplicáveis ao Processo Penal, bem como sobre as previsões do Código de Processo Penal sobre o tema “Prisão”.

- a) *Com base nas informações constantes do enunciado, não poderia Matheus ser obrigado a realizar o teste de bafômetro nos termos informados pela autoridade policial. Matheus foi o autor de um atropelamento de vítima que sofreu lesões corporais em razão de sua conduta com violação do dever objetivo de cuidado. Independentemente, a autoridade policial não poderia exigir a contribuição de Matheus para produção de provas contra ele próprio em relação ao crime do art. 306 da Lei n.º 9.503/97 (CTB). O princípio do nemo tenetur se detegere, trazido, entre outros diplomas, pelo Pacto de San Jose da Costa Rica, estabelece que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.*

Apesar de haver controvérsia sobre a extensão desse princípio, em relação à exigência de conduta positiva do investigado/acusado na produção de prova que pode lhe prejudicar, prevalece o entendimento no sentido de que não existe obrigatoriedade na contribuição. O exame de etilômetro exige que o investigado adote um comportamento positivo, já que é preciso que ele sopre ar em determinado aparelho, de modo que não pode Matheus ser obrigado a realizar tal teste se assim não o desejar, podendo o crime do art. 306 do CTB ser identificado por outros meios de prova.

- b) Em busca da liberdade de Matheus, o advogado deveria formular requerimento de relaxamento da prisão, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva exige a presença dos requisitos e pressupostos trazidos pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Independentemente do risco de reiteração delitiva, os pressupostos do art. 313 do CPP não foram atendidos. O crime imputado não é doloso e não tem pena máxima superior a 4 anos, ainda que considerada eventual causa de aumento. Em relação à reincidência, o art. 313, inciso II, do CPP apenas admite a prisão se aquela for em crimes dolosos. No caso, o enunciado deixa claro que Matheus era reincidente específico na prática de crimes culposos, logo, não preenchidos os requisitos legais desde o início, a decretação da prisão torna-se ilegal, devendo ser relaxada, nos termos do art. 5.º, inciso LXV, CRFB/88.*

QUESTÃO 2

- a) Sim, existe argumento em busca da aplicação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. De acordo com a literalidade do art. 33, § 2.º, do Código Penal, sendo o réu reincidente, cabível a aplicação do regime inicial fechado. Ocorre que tal previsão poderá ser extremamente severa diante de situações concretas em que outro regime de cumprimento de pena se mostre mais adequado. Diante disso, procurando mitigar as consequências dessa previsão do Código Penal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive por meio da Súmula 269 do STJ, admite a aplicação do regime inicial semiaberto aos reincidentes condenados ao cumprimento de pena fixada em até 4 anos, desde que favoráveis as demais circunstâncias judiciais. No caso, apesar da reincidência, a pena foi aplicada em 1 ano e 6 meses de reclusão, não sendo reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, a reincidência anterior sequer era específica. Diante disso, possível ao advogado de Hugo pleitear a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. A mera indicação do candidato de que com base na pena imposta o regime inicial adequado seria aberto não é suficiente para atribuição de pontos.*
- b) Sim, é possível ao advogado buscar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. De fato, como destacado pelo magistrado, a princípio, o art. 44, inciso II, do Código Penal, veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na hipótese de o réu ser reincidente na prática de crimes dolosos. Não há dúvida de que Hugo era reincidente, já que possuía condenação pela prática de crime doloso anterior, com trânsito em julgado, sendo o crime de apropriação indébita praticado posteriormente.*
- Todavia, o próprio art. 44, § 3.º, do Código Penal, admite a substituição, mesmo diante de reincidência, desde que essa não seja específica e a medida seja socialmente recomendável. Na situação apresentada, Hugo não é reincidente específico sequer na prática de crimes contra o patrimônio, já*

que a condenação anterior refere-se ao crime de lesão corporal dolosa. Ademais, com base nas informações expostas, a medida seria socialmente recomendável, tendo em vista que Hugo estava trabalhando e cuidava de filhos menores de idade. O crime não envolveria violência ou grave ameaça à pessoa. Assim, excepcionalmente, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

QUESTÃO 3

A questão exige do examinando conhecimento sobre o tema Execução Penal. Narra o enunciado que Leal, apenado em regime inicial semiaberto, após estar cumprindo pena há 11 meses, considerando a prestação de serviços extramuros, pretende a progressão para o regime aberto, ressaltando que não sofreu qualquer sanção administrativa.

- a) Sim, os requisitos legais estão preenchidos. De acordo com o art. 112 da Lei n.º 7.210/84, o requisito objetivo para progressão de regime é o cumprimento de 1/6 da pena aplicada, que, no caso, significaria 1 ano de pena privativa de liberdade. Segundo consta do enunciado, Leal ficou 11 meses preso em cumprimento da pena, o que, a princípio, não atenderia ao requisito objetivo. Todavia, há período de pena remida que justifica a progressão de regime. Leal trabalhou por 120 dias, o que gera uma remição de 40 dias de acordo com o art. 126 da LEP, devendo ser esclarecido que o “trabalho extramuros” justifica a remição de pena, nos termos da Súmula 562 do STJ. Ademais, o tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos (Art. 128 da LEP). Dessa forma, cumprido mais de 1 ano da pena aplicada, possível a progressão de regime.
- b) A inexistência de vagas em regime compatível não é fundamento idôneo para manutenção do apenado em regime mais severo, nos termos da Súmula Vinculante 56 do STF. Preenchidos os requisitos legais, o apenado possui direito à progressão para regime compatível ao cumprimento de sua pena, não podendo a deficiência do Estado lhe prejudicar. De acordo com a jurisprudência do STF, havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

QUESTÃO 4

- a) Será competente para julgamento de Talles o juízo da Comarca de Cardoso Moreira, local em que te sido praticado o crime de roubo. De acordo com as informações constantes do enunciado, três crimes de furto foram praticados em conexão com um crime de roubo, tendo em vista que o agente, em continuidade, subtraiu bens de estabelecimentos diversos para obter instrumentos para a prática do crime de roubo. A conexão probatória, então, é clara. Havendo conexão entre crimes que foram praticados em diferentes comarcas, sendo que todos os juízos seriam de mesma categoria, aplicam-se as previsões do art. 78, inciso II, do CPP. Não há falar em competência da cidade de São Fidélis, pois nenhum dos crimes foi consumado no local, somente lá ocorrendo a prisão em

flagrante. Restariam as cidades de Bom Jesus de Itabapoana e Cardoso Moreira. De acordo com o art. 78, inciso II, alínea a, do CPP, o primeiro critério a ser observado é o local onde foi praticado o crime ao qual for cominada a pena mais grave. O crime mais grave imputado é o de roubo majorado, logo competente a Comarca de Cardoso Moreira. O critério do número de crimes praticados somente seria relevante se a todos os delitos fosse prevista a mesma pena.

- b) O argumento de direito material é o de que não haveria falar em crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, tendo em vista que a restrição em questão foi a normal do tipo para subtração dos bens, não se estendendo por tempo significativo relevante, para além daquele necessário para a subtração, conforme exige a doutrina e a jurisprudência.*

12.2.29 XXIX Exame de Ordem Unificado – FGV

QUESTÃO 1

- a) Sim, a capitulação jurídica realizada pelo Ministério Público e acolhida na sentença poderá ser questionada, tendo em vista que não deveria ter sido imputada a qualificadora do concurso de agentes. O art. 155, § 4.º, inciso IV, do CP prevê qualificadora do furto quando este for praticado mediante concurso de duas ou mais pessoas. Ocorre que, apesar de Caio e Bruno serem irmãos e terem praticado crimes de furto no mesmo local, data e horário, não houve concurso de agentes. Entre os requisitos para configuração do concurso de agentes está o liame subjetivo, que não restou configurado na hipótese apresentada. A todo momento o enunciado deixa claro que Caio e Bruno sequer sabiam da conduta um do outro, não havendo que se falar, então, em comunhão de ações e designios e, conseqüentemente, concurso de agentes, apesar de configurado o crime de furto simples em relação a ambos.*
- b) Mesmo em caso de manutenção da capitulação apresentada, ou seja, de furto qualificado, seria possível a redução da pena aplicada em razão do privilégio previsto no art. 155, § 2.º, do CP. Apesar de os agentes responderem a outras ações penais, nos termos da Súmula 444 do STJ, não havendo sentença condenatória anterior com trânsito em julgado, são considerados tecnicamente primários e de bons antecedentes. Ademais, as coisas furtadas podem ser consideradas de pequeno valor, não havendo que se falar em insignificância, na hipótese, seja pelo valor dos bens seja porque o enunciado indaga sobre a redução da pena aplicada e não afastamento da tipicidade da conduta.*

É preciso, ainda, ressaltar que os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que a figura do furto privilegiado poderá ser reconhecida ainda que o crime em questão seja de furto qualificado, topograficamente localizado após a disciplina do privilégio, nos termos da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça.

QUESTÃO 2

Narra o enunciado que Caio teria efetuado disparos de arma de fogo, no interior de seu quintal, na direção da parede do imóvel em que residia, estando a casa vazia. Ademais, consta a informação

que os disparos foram realizados do quintal para o interior da residência, sendo que as munições ficaram alojadas na parede. Os fatos, porém, foram descobertos por policiais militares, vindo Caio a ser denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003.

- a) A decisão do magistrado não foi correta. De fato, uma vez que o denunciado não foi localizado para citação pessoal, seria cabível sua citação por edital. Em consequência, não comparecendo o denunciado e nem constituindo advogado, em razão da natureza de citação ficta, o processo, assim como o curso do prazo prescricional, deve ficar suspenso. Ocorre que uma suspensão indefinida do prazo prescricional acabaria por criar um crime, na prática, imprescritível, o que, de acordo com grande parte da doutrina, não poderia ocorrer através de legislação ordinária. Diante disso, através da Súmula 415 do STJ, foi pacificado o entendimento de que a suspensão do prazo prescricional somente poderia durar o período do prazo prescricional, regulado pela pena máxima do crime imputado. O delito do art. 15 da Lei 10.826/2003 tem pena máxima prevista de 4 anos, de modo que o prazo prescricional seria de 8 anos. Desde a suspensão do processo, na forma do art. 366 do CPP, passaram-se mais de 8 anos, logo o prazo prescricional deveria voltar a correr em abril de 2016, sendo equivocada a decisão do magistrado de, em 2018, determinar que fosse mantida a suspensão do prazo prescricional.
- b) Sim, existe argumento de direito material a ser apresentado pela defesa técnica de Caio em busca de sua absolvição. Deveria o advogado alegar a atipicidade da conduta, tendo em vista que nem todas as elementares do crime do art. 15 da Lei 10.826/2003 foram preenchidas. Em que pese tenha Caio realizado disparos de arma de fogo, não haveria que se falar no crime imputado, pois os disparos não foram realizados em via pública e nem em direção à via pública. Apesar de a rua da residência do denunciado ser habitada, os disparos foram realizados dentro de um quintal, em direção à parede da casa onde não havia ninguém. Independentemente de a conduta ser moralmente reprovável, não foi praticado o delito imputado.

QUESTÃO 3

A questão exige do candidato conhecimento sobre uma pluralidade de temas, destacando-se a prova ilícita, Lei 11.343/2006 e os crimes hediondos.

Narra o enunciado que Wesley foi abordado por policiais militares e, apesar de nada ilícito ter sido encontrado com ele, os policiais, sem autorização, apreenderam seu celular e obtiveram acesso às conversas de Wesley via aplicativo WhatsApp e ao álbum de fotografias, onde encontraram imagens de Wesley supostamente com armas de fogo. Com base nesse conteúdo do celular, Wesley foi preso em flagrante, denunciado e condenado como incurso nas sanções penais do art. 35 da Lei 11.343/2006.

- a) Sim, existe argumento para questionar as provas que serviram de fundamento para a condenação, tendo em vista que se tratam de provas ilícitas. As provas utilizadas pelo magistrado foram obtidas com violação ao direito à intimidade, já que os policiais obtiveram acesso ao teor das conversas de Wesley por mensagens e suas fotografias sem sua autorização ou sem prévia autorização judicial. Ocorreu violação à garantia de inviolabilidade da intimidade e vida privada, assegurada no art. 5.º, inciso X, da CRFB, já que não houve o indispensável requerimento (e autorização judicial) de quebra

de sigilo de dados. Dessa forma, estamos diante de provas ilícitas, que devem ser desentranhadas do processo, nos termos do art. 157 do CPP.

- b) O argumento a ser apresentado para questionar a sanção penal aplicada é o de que o crime de associação para o tráfico não é delito equiparado ao hediondo, diferente do tráfico do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que não está previsto no rol taxativo do art. 1.º da Lei 8.072/1990. Em respeito ao princípio da legalidade, não há que se falar em analogia in malam partem. Considerando que o crime de associação para o tráfico não está previsto na Constituição como equiparado a hediondo e nem é mencionado no art. 1.º da Lei de Crimes Hediondos, não pode o magistrado conferir tal natureza em sua decisão, ainda que exista previsão no sentido de que o prazo do livramento condicional será de mais de 2/3, prazo esse típico dos crimes hediondos e equiparados. Ademais, ainda que fosse considerada a natureza hedionda do delito, a previsão obrigatória de regime inicial fechado vem sendo considerada inconstitucional pelos Tribunais Superiores (art. 2.º, § 1.º, da Lei 8.072/1990) por violar o princípio da individualização da pena.

QUESTÃO 4

- a) O advogado de Antônio poderá buscar o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória em razão da violação ao devido processo legal. Isso porque, de acordo com o art. 400 do CPP, na audiência, primeiro devem ser ouvidas as testemunhas da acusação. Somente após a produção de provas pela acusação poderiam ser ouvidas as testemunhas de defesa e interrogado o acusado. Violando a ordem da oitiva das testemunhas, tendo a defesa se insurgido contra tal inversão e ficando claro o prejuízo com a condenação e alteração dos fatos por parte de Pablo, deverá ser reconhecida a nulidade do processo desde a primeira audiência de instrução e julgamento.
- b) A conduta de Pablo de, em audiência de instrução e julgamento de processo criminal, fazer afirmação falsa como testemunha, a princípio, configura o crime realmente imputado: art. 342, § 1.º, do CP. Ocorre que, até como forma de incentivar a retratação e minorar os prejuízos causados em processos, previu o legislador, no art. 342, § 2.º, do CP, que se o agente se retrata ou declara a verdade antes da sentença ser proferida no processo em que ocorreu o ilícito, o fato deixa de ser punível. No caso, Pablo se retratou, narrou a verdade, antes mesmo de ser proferida a sentença condenatória de Antônio. Dessa forma, não poderia o magistrado reconhecer que tal retratação funcionaria apenas como atenuante do art. 65, inciso III, alínea b, do CP, ou arrependimento posterior, devendo reconhecer a extinção da punibilidade do agente, já que o fato deixa de ser punível.

12.3 GABARITO DAS QUESTÕES DISCURSIVAS PENAIS INÉDITAS

Questão 01

Tema

Crimes Ambientais – Responsabilidade Penal das pessoas jurídicas – Requisitos da denúncia

**Gabarito &
Comentários**

a) A responsabilidade penal por crimes ambientais recai sobre as pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes das condutas realizadas, bem como sobre a pessoa jurídica que tenha sido beneficiada pela conduta de seus representantes legais, contratuais ou por decisão dos membros do órgão colegiado gestor, conforme dispõe o art. 3.º e seu parágrafo único da Lei 9.605/1998. Portanto, devem ser responsabilizados pelo crime ambiental previsto no art. 54, § 2.º, III, da Lei 9.605/1998, os diretores responsáveis pela prática da conduta e a pessoa jurídica; os empregados que executaram a conduta devem ser absolvidos por força da coação moral irresistível.

b) Não, o art. 41 do CPP exige que a denúncia descreva o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, portanto, é necessário que a denúncia descreva a conduta criminosa, que é exclusivamente praticada pelo homem e não pela pessoa jurídica. Por essa razão, o STJ entende que a denúncia pelo crime ambiental deve descrever a conduta do homem, representante da pessoa jurídica, e, demonstrado o interesse ou benefício desta, inclua a pessoa jurídica na denúncia criminal. Portanto, a pessoa jurídica não pode ser denunciada sozinha pelo crime ambiental.

c) Não, desde que comprovado o fato típico, antijurídico e culpável, ainda que ocorra a extinção da punibilidade das pessoas físicas, é possível condenar a pessoa jurídica pelo crime ambiental.

Questão 02

Tema

Crimes contra a ordem tributária

Gabarito & Comentários

- a) O diretor da empresa praticou os crimes previstos nos art. 1.º, V, da Lei 8.137/1990, por ter deixado de emitir notas fiscais acarretando a supressão no pagamento de tributos estaduais e federais, e o crime do art. 2.º, II, da Lei 8.137/1990 pela apropriação de valores descontados dos empregados a título de imposto de renda, que não foram repassados ao fisco na forma e prazos legais.
- b) A competência para o processo e julgamento dos crimes será da justiça federal, conforme dispõe o art. 109, IV, da Constituição Federal, uma vez que o fato narrado envolve a sonegação e apropriação de tributos federais. Em razão da conexão entre a sonegação de tributos federais e estaduais ocorre a união dos processos, nos termos do art. 79 do CPP, devendo os processos penais pela sonegação de tributos estaduais ser unificados com os federais e julgado pela Justiça Federal.
- c) Não. Os crimes contra a ordem tributária de natureza material dependem do lançamento definitivo dos tributos em sede administrativa, conforme entendimento esboçado na Súmula Vinculante 24 do STF.
- d) Sim. O parcelamento dos tributos sonegados e apropriados, desde que o pedido seja formalizado até o recebimento da denúncia, acarreta a suspensão da pretensão punitiva penal, conforme dispõe o art. 83, § 2.º, da Lei 9.430/1996. Ocorrendo a quitação do parcelamento, haverá extinção da punibilidade, conforme

dispõe o art. 83, § 4.º, da Lei 9.430/1996.

Questão 03

Tema

Lei de Racismo e Lei de Tortura

Gabarito & Comentários

Carlos Agal praticou o crime de racismo, previsto no art. 20 da Lei 7.716/1989, pois incitou e induziu os comerciantes a praticarem atos de discriminação por procedência nacional, e o crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1.º, III, por força da debilidade permanente da visão, causada pela cegueira parcial. É importante ressaltar que não houve crime de tortura racial, prevista no art. 1.º, I, "c", da Lei 9.455/1997, pois o tipo penal somente prevê a proteção das raças e religiões, não havendo previsão quanto à origem nacional, devendo ser configurado o crime de lesão corporal.

Questão 04

Tema

Crimes sexuais e erro de tipo

Gabarito & Comentários

- a) O meio adequado é a impetração de habeas corpus, com fundamento no art. 648 do CPP, com o objetivo de trancamento da ação penal, pois não há previsão legal de recurso para a decisão que recebe a denúncia e a questão não fala em citação ou intimação para apresentar a resposta do acusado.
- b) O argumento defensivo é a atipicidade da conduta, tendo em conta a ocorrência de erro de tipo essencial, previsto no art. 20, caput, do CP. O agente desconhecia a

idade da vítima, foi induzido, pela informação contida no site e pela apresentação de documentos falsos na recepção do hotel, a acreditar que se tratava de maior de 18 anos. Assim, está em erro de tipo quanto ao elemento "menor de 18 anos" contido no tipo penal do crime de prostituição infantojuvenil, devendo o fato ser considerado atípico por exclusão do dolo.

Questão 05

Tema

Lei de drogas e Lei de Crimes Hediondos

Gabarito & Comentários

a) Sim. O crime de tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo, conforme dispõe o art. 5.º, XLIII, da CR/1988. A Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072/1990, prevê no art. 2.º, § 1.º, a obrigatoriedade do regime inicial fechado no cumprimento da pena pelos crimes hediondos e equiparados, impedindo a fixação dos regimes semiaberto ou aberto como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Porém, o Supremo Tribunal Federal entendeu que esta regra viola o princípio da individualização da pena, cabendo ao juiz determinar o regime inicial de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Assim, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser estabelecido pelo juiz na sentença, com base no art. 33, § 2.º, "a", "b" e "c", combinados com o art. 59, III, do CP.

b) Sim. As proibições da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, contidas nos arts. 33, § 4.º, e 44 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), foram consideradas inconstitucionais pelo STF, inclusive

	tendo a eficácia suspensa pela Resolução 05/2012 do Senado Federal. Portanto, quando cumpridos os requisitos exigidos pelo art. 44 do CP, a substituição deve ser realizada.
--	--

Questão 06

Tema	Crime Impossível e Crimes Sexuais
Gabarito & Comentários	Trata-se de atos sexuais praticados contra pessoa com morte cerebral, embora tal fato fosse desconhecido do agente, declarada posteriormente em perícia médico-legal. O bem jurídico tutelado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, é a dignidade sexual, em especial a liberdade sexual. Esse bem jurídico está relacionado a pessoas vivas, cessando com a morte da vítima. Portanto, uma pessoa morta é objeto absolutamente impróprio para a prática do crime de estupro de vulnerável, configurando a exclusão da tipicidade do fato pelo crime impossível, previsto no art. 17 do CP.

Questão 07

Tema	Desarmamento
Gabarito & Comentários	Mário praticou o crime de posse ilegal de arma de fogo com sinal de identificação suprimido, previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, por ter guardado a arma irregularmente em sua casa. Entretanto, a decisão de procurar pela Polícia Federal para realizar a entrega voluntária da arma acarreta a extinção da

punibilidade pelo crime de posse, conforme dispõe o art. 32 do mesmo diploma legal. Portanto, houve crime, mas a entrega acarreta a extinção da punibilidade do agente.

Questão 08

Tema

Código de Trânsito Brasileiro

Gabarito & Comentários

Julio praticou crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com causa de aumento de pena pela omissão de socorro, prevista no art. 303, parágrafo único, da Lei 9.503/1997 (CTB), pois conduzia seu veículo com imprudência, caracterizada pelo excesso de velocidade, e dolosamente não socorreu a vítima das lesões que provocou culposamente. Maria, condutora do outro veículo, que conduzia regularmente, sem culpa, praticou o crime de omissão de socorro, previsto no art. 304 do CTB. O transeunte, Michel, praticou crime de omissão de socorro previsto no art. 135 do CP.

Questão 09

Tema

Ação penal – Honra – Crimes Sexuais – Lesão corporal

a) O crime de lesão corporal leve qualificado pela violência doméstica previsto no art. 129, § 9.º, em regra, é de ação penal pública condicionada à representação, conforme dispõe o art. 88 da Lei 9.099/1995. Entretanto, se a vítima do crime for mulher, incide a Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, que no art. 41 afasta a aplicação da Lei 9.099/1995 nas situações de violência doméstica contra a mulher. Nestas hipóteses, a ação penal será

Gabarito & Comentários	pública incondicionada. b) Trata-se de crime complexo que soma o estupro, crime de ação penal pública condicionada a representação, e o homicídio culposo, crime de ação penal pública incondicionada. Por força do art. 101 do CP, nestas situações deve prevalecer a ação penal pública incondicionada. c) O crime de injúria qualificada pelo preconceito de raça, cor, etnia, religião e origem, previsto no art. 140, § 3.º, do CP, é crime de ação penal pública condicionada a representação. Portanto, mesmo quando praticado contra funcionários públicos, a ação penal é condicionada, não se aplicando à espécie a Súmula 714 do STF.
-----------------------------------	---

Questão 10	
Tema	Crimes contra o Patrimônio
Gabarito & Comentários	Carlos praticou crime de latrocínio, previsto no art. 157, §§ 1.º e 3.º, do CP. A conduta do agente era inicialmente de furto, entretanto, o uso da violência, logo após a subtração dos bens, com o fim de assegurar a detenção das coisas para si, transforma o crime em roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1.º, afastando-se a figura típica do furto. Por fim, a violência do roubo impróprio causou a morte da vítima, o que qualifica o roubo, configurando o latrocínio.

12.4 GABARITO DAS QUESTÕES DISCURSIVAS PROCESSUAIS PENAS INÉDITAS

Questão 01

Tema

Recursos e Ações Autônomas

**Gabarito &
Comentários**

- a) Embargos Infringentes e de Nulidade (art. 609, parágrafo único, do CPP) e Revisão Criminal (art. 621 do CPP).
- b) Apesar de algumas controvérsias doutrinárias, acreditamos que sim, pois entre a soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII, "c", da CF) constitucional e a injustiça ou erro de uma decisão, na balança da ponderação e da razoabilidade deve prevalecer a correção da justiça.
- c) Pessoa Jurídica pode impetrar e ser coatora de HC, proibindo-se apenas sua figura como paciente.
- d) Segundo o art. 105, I, "e", da CF, o próprio STJ.
- e) Caberá o Recurso em Sentido Estrito com base no art. 581, X, do CPP. Poderíamos exemplificar com a impetração de HC em 1.º grau quando o Delegado de Polícia instaura inquérito policial para investigações. Nesse caso, como figura este como coator, o HC deve ser dirigido ao juiz de 1.º grau.

Questão 02

Tema

Júri e Recursos

- a) Recurso em Sentido Estrito com prazo de cinco dias (art. 581, IV c/c art. 586 do CPP).

**Gabarito &
Comentários**

b) Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa.

c) Da impronúncia e da absolvição sumária cabe apelação, segundo o art. 416 do CPP.

d) Segundo a Lei 12.694/2012, um hiato foi preenchido em nossa legislação, trazendo segurança jurídica ao conceito de organização criminosa. Vejamos o art. 2.º da mencionada lei: "Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a associação, de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional".

e) Apesar de o art. 44 da Lei 11.343/2006 impedir a concessão de liberdade provisória no crime de tráfico, tal preceito não deve mais perdurar, pois no HC 104.339/STF, Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi declarado parcialmente inconstitucional tal artigo, justamente esta proibição. O constitucionalista ministro abordou que tal proibição fere os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, mencionando ainda que: "afastar de norma genérica retira do juiz competente a oportunidade no caso concreto de analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar. Seria inequívoca antecipação da pena".

f) Pela impossibilidade de apresentar o recurso de

Protesto por Novo Júri, pois como no momento da sentença este recurso havia sido revogado, a apresentação deste não seria viável. Não há que se falar em direito adquirido, já que a lei processual é muito clara em seu art. 2.º sobre a aplicação da lei processual imediata ao da sua publicação.

Questão 03

Tema

Procedimento

a) O art. 394 do CPP nos remete à resposta da presente questão: "O procedimento será comum ou especial. (Redação dada pela Lei 11.719, de 2008).

§ 1.º O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo: (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

I – ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade; (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

II – sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade; (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)

III – sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. (Incluído pela Lei 11.719, de 2008)"

Já o procedimento a que é submetido o funcionário público se encontra no art. 513 e seguintes do CPP e é aplicado quando dois requisitos são concomitantemente

Gabarito & Comentários

preenchidos, que seriam a figura do funcionário público (art. 327 do CP) cometendo um dos crimes funcionais (art. 312 e seguintes do CP).

b) No procedimento ordinário a audiência de instrução e julgamento deve ser marcada em 60 dias, segundo o art. 400 do CPP, já no procedimento sumário em até 30 dias, segundo o art. 531 do CPP. Visualizamos outra diferença quanto ao número de testemunhas. Enquanto no procedimento ordinário podem ser arroladas até oito testemunhas (art. 401 do CPP), no sumário, são até cinco (art. 532 do CPP). Concluindo, pela lei, no procedimento ordinário temos a regra das alegações finais orais e a possibilidade, excepcional, nos casos de diligências, número de acusados e complexidade, das alegações finais escritas por memoriais (art. 403, § 3.º c/c art. 404, parágrafo único, do CPP). Já no procedimento sumário só temos, pela lei, a possibilidade das alegações orais, segundo o art. 534 do CPP.

Esta última diferença não seria tão presente assim, pois existe a permissão de o magistrado, com base no art. 394, § 5.º, do CPP, aplicar por analogia ao procedimento sumário as regras do ordinário.

c) A Defesa Preliminar é o meio defensivo utilizado para impedir o recebimento da ação e é apresentada logo depois do oferecimento da ação penal. No direito brasileiro temos essa possibilidade em três procedimentos. Vejamos:

– Funcionário Público, conforme o art. 514 do CPP, com prazo de 15 dias;

– Procedimento da Lei de Drogas, art. 55 c/c art. 55, § 1.º, da lei, no prazo de 10 dias.

Questão 04

Tema

Competência

Gabarito & Comentários

Acerca do crime de Lesão Corporal (art. 129 do CP) que o prefeito inicialmente cometeu, seu foro de competência para julgamento é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conforme o art. 29, X, da CF, mesmo sendo o crime cometido em outro Estado, segundo decisões de nossos tribunais superiores.

Já em relação à conduta de crime eleitoral tipificada no art. 302 do Código Eleitoral, percebemos claramente a incidência da Súmula 702 do STF: “A competência do Tribunal de Justiça para julgar Prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau”.

Portanto, deve responder o prefeito perante o TRE.

Questão 05

Tema

Juizado Especial Criminal

a) Segundo o art. 62 da Lei 9.099/1995, eis os princípios: “O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível,

**Gabarito &
Comentários**

a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade”.

b) Uma única possibilidade trazida no art. 94 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003): “Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal”.

c) Concurso de Crimes (art. 63 da Lei 9.099/1995), Prerrogativa de Função e Violência Doméstica, conforme o art. 41 da Lei 11.340/2006;

d) Em tese, sim, pois o crime de estelionato tem pena mínima de um ano, permitindo-se a aplicação da medida despenalizadora da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/1995);

e) Renúncia, segundo o art. 74 da Lei 9.099/1995: “A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação”.

f) Em ambos os casos, o envio dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para que faça a proposta ou a delegue aplicando-se por analogia o art. 28 do CPP. Ainda no

tocante à suspensão, a redação da Súmula 696 é clara nesse sentido: "Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal".

g) Apenas os recursos de Apelação e Embargos de Declaração, respectivamente nos arts. 82 e 83 da Lei 9.099/1995, com prazos de dez e cinco dias. Vale observar que, encaminhado o feito para as turmas recursais, também pode ser apresentado o Recurso Extraordinário.

Questão 06

Tema

Inquérito Policial

a) Segundo a Súmula 397 do STF, compete à Polícia Legislativa: "O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito".

b) O membro do Ministério Público poderá denunciar, ou seja, oferecer a ação penal se tiver elementos suficientes para tal medida. Pode ainda requisitar novas diligências, conforme o art. 16 do CPP, ou ainda requerer o arquivamento do inquérito policial nos casos de insuficiência de provas, extinções da punibilidade, entre

**Gabarito &
Comentários**

outras possibilidades.

c) Vale observar que neste procedimento de arquivamento na esfera federal, caso não haja homologação do arquivamento do inquérito por parte do juiz de 1.º grau, antes dos autos chegarem ao Procurador-geral, conforme o art. 28 do CPP, as Câmaras de Coordenação e Revisão do MPU irão elaborar um parecer nesse sentido. Vejamos importante detalhe no art. 62, IV, da Lei Complementar 75/1993:

Art. 62. Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão:

I – promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que atuem em ofícios ligados ao setor de sua competência, observado o princípio da independência funcional;

II – manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins;

III – encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais que atuem em seu setor;

IV – manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral;

V – resolver sobre a distribuição especial de feitos que, por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme;

VI – resolver sobre a distribuição especial de inquéritos, feitos e procedimentos, quando a matéria, por sua

	natureza ou relevância, assim o exigir; VII – decidir os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Federal. Parágrafo único. A competência fixada nos incisos V e VI será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior”. Polícia Federal, segundo o art. 2.º da Resolução 22.376, de 28.08.2006, do Tribunal Superior Eleitoral, que permite aplicação subsidiária da Polícia Civil nos locais onde não existam órgãos de Polícia Federal. d) Compete à Polícia Federal a investigação de crimes eleitorais e, de forma subsidiária, às polícias civis.
--	--

Questão 07

Tema	Crimes Funcionais e Procedimento do Funcionário Público
	a) O Funcionário Público responde por Corrupção Passiva (art. 317 do CP) com aumento de pena do § 1.º do mesmo artigo. Eventual crime do art. 319-A do CP é absorvido por crime acima. Já os particulares envolvidos respondem pelo crime do art. 333, parágrafo único, do CP, que também absorve a conduta do art. 349-A do CP. b) O funcionário público terá direito a defesa preliminar do art. 514 do CPP antes do recebimento da ação penal. c) O STJ, segundo a Súmula 330, entende que, havendo inquérito policial prévio, dispensa-se a defesa preliminar. Vejamos a redação da mencionada súmula: “É

Gabarito & Comentários

desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial”.

Já o STF entendeu que a falta de defesa preliminar seria causa de nulidade absoluta, todavia, isto não é o que vem acontecendo mais recentemente. Vejamos decisão sobre o tema, que considera sua falta como nulidade relativa, exigindo-se demonstração de prejuízo: “A 2.^a Turma iniciou julgamento de habeas corpus em que servidor público almeja a anulação da ação penal contra ele instaurada ante a ausência de notificação prévia, nos termos do art. 514 do CPP (“Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de 15 dias”). O Min. Joaquim Barbosa, relator, indeferiu a ordem. Ressaltou que a falta de notificação para apresentar defesa preliminar acarretaria somente a nulidade relativa, a qual deveria ser oportunamente arguida, sob pena de preclusão. Consignou que o impetrante não demonstrara a tempestividade da alegação de nulidade, tampouco a ocorrência de prejuízo ao regular exercício do direito de defesa. Salientou que, com a superveniência da sentença condenatória, não se mostraria razoável a anulação de todo o feito a fim de oportunizar ao réu o oferecimento da defesa prévia. Após, pediu vista o Min. Ayres Britto. HC 104.054/RJ, rel. Min. Joaquim Barbosa, 17.05.2011. (HC-104.054)”

Tema	Competência
Gabarito & Comentários	Segundo as constituições estaduais, deputado estadual possui foro privilegiado nos respectivos Tribunais de Justiça dos Estados. Curiosamente, nossos Tribunais Superiores entendem que para o caso em espécie não se aplica a Súmula 721 do STF, tendo em vista a simetria constitucional, trazendo, portanto, a competência para o caso no Tribunal de Justiça. Vejamos súmula seguida de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 721 do STF: “A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual”. Entendimento do STJ sobre a matéria: “Cuida-se de conflito de competência cuja essência é saber a quem cabe julgar os crimes dolosos contra a vida quando praticados por deputado estadual, isto é, se a prerrogativa de função desses parlamentares está inserida na própria Constituição Federal ou apenas na Constituição do estado. A Seção, por maioria, entendeu que as constituições locais, ao estabelecer para os deputados estaduais idêntica garantia prevista para os congressistas, refletem a própria Constituição Federal, não se podendo, portanto, afirmar que a referida prerrogativa encontra-se prevista, exclusivamente, na Constituição estadual. Assim, deve

prevalecer a teoria do paralelismo constitucional, referente à integração de várias categorias de princípios que atuam de forma conjunta, sem hierarquia, irradiando as diretrizes constitucionais para os demais diplomas legais do estado. Consignou-se que a adoção de um critério fundado na aplicação de regras simétricas reforça a relevância da função pública protegida pela norma do foro privativo. Ademais, a própria Carta da República institui, em seu art. 25, o princípio da simetria, dispondo que os estados organizam-se e se regem pelas constituições e leis que adotarem, observando-se, contudo, os princípios por ela adotados. Diante desses fundamentos, por maioria, conheceu-se do conflito e se declarou competente para o julgamento do feito o TJ. CC 105.227-TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 24.11.2010.”

Questão 09

Tema

Nulidades

a) A primeira nulidade a ser abordada é o uso indiscriminado das algemas, desrespeitando-se assim, absurdamente, a Súmula Vinculante 11: “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

**Gabarito &
Comentários**

Já a segunda nulidade é a falta de menção acerca ao direito ao silêncio, conforme o art. 5.º, LXIII, da CF: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado” e o art. 186 do CPP: “Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas”.

Uma terceira nulidade é a impossibilidade que as partes tiveram de não se manifestar durante o interrogatório. O art. 188 do CPP permite esclarecimentos posteriores à presidência do ato pelo juiz. Assim dispõe o mencionado artigo: “Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante”.

Quarta nulidade é o desrespeito à inquirição das testemunhas, conforme o art. 212 do CPP, que permite perguntas diretas das partes, inovação esta trazida pela grande reforma processual de 2008. Vejamos: “As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida”.

Concluindo, a regra agora são as alegações finais orais e não as escritas, como quer o juiz. Disposição esta do art. 403 do CPP: “Não havendo requerimento de diligências,

ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença”.

b) Princípio da Concentração dos Atos de Instrução e da Identidade Física do Juiz, conforme o art. 399, § 2.º, do CPP: “Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente.

§ 1.º O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação.

§ 2.º O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”.

c) Permanecendo o ilustre promotor de justiça ao lado do juiz, continuaríamos a correr o risco de eventual disparidade de armas e ofensas à ampla defesa e contraditório. Vale observar que a matéria é bem polêmica com argumentos válidos para ambos os lados.

Questão 10

Tema

Ação Penal

Gabarito &

Injúria preconceituosa ou qualificada fora o crime cometido, segundo o art. 140, § 3.º, do CP. Com a reforma da Lei 11.330/2009, tal crime é passível de ação penal pública.

Comentários

Condicionada à representação (art. 145 do CP), obrigando a mesma a ser apresentada num prazo de seis meses a partir do conhecimento da autoria, conforme os arts. 38 e 39 do CPP.

-
- 1 Com Gabarito Comentado oficial.
 - 2 Com Gabarito Comentado Oficial.
 - 3 Com Gabarito Comentado Oficial.
 - 4 Com Gabarito Comentado Oficial.